



جامعة الأزهر
كليات الشريعة والقانون، والدراسات الإسلامية
قسم الفقه

المادة: الفقه الحنفي (المعاملات)
للفرقة الثانية شعبة الشريعة والقانون والدراسات الإسلامية
للعام الجامعي ٢٠٢٥/٢٠٢٦ م
(النصية والموضوعية)

لجنة إعداد الدراسة النصية

أ.د. محمد أحمد حلمي الطوابي. أستاذ الفقه ووكيل كلية الشريعة والقانون بطنطا للدراسات العليا
سابقاً

د. علي عاطف امارة. مدرس الفقه بكلية الشريعة والقانون بطنطا

لجنة إعداد الدراسة الموضوعية

أ.د/ أحمد عبد العليم عبد اللطيف أبوعليو. أستاذ الفقه بكلية الشريعة والقانون بأسبوط

أ.د/ إبراهيم رمضان عطايا. أستاذ ورئيس قسم الفقه بكلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات
بمدينة السادات

أ.د/ هناء فهمي أحمد عيسى. أستاذ ورئيس قسم الفقه بكلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات
بالمنصورة

د/ أحمد سيد أحمد عبد المقصود الشافعي. مدرس الفقه بكلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنين
بالديداون شرقية

د/ أحمد محمد السيد المرسي العفيفي. مدرس الفقه بكلية الشريعة والقانون بطنطا

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، وبعد: فهذا مصنف في: بعض أبواب المعاملات، المقرر تدريسها لطلاب الفرقة الثانية، من أقسام الشريعة من كليات الشريعة، وكليات الدراسات الإسلامية، للبنين والبنات، مرحلة الليسانس، جامعة الأزهر، ويتناول موضوعات: القسم النصي، وموضوعات: القسم الموضوعي، كما هو مبين.

وقد قامت على إعداده ثلة من أساتذة الفقه بكليات الشريعة والقانون، وكليات الدراسات الإسلامية بجامعة الأزهر.

والموضوعات التي يتضمنها الكتاب لها أهمية كبيرة في تكوين الطالب الأزهرى، فهي تنطوي على أحكام الحلال والحرام في تعاملات الناس اليومية، من: البياعات، من: بيع، وسلم، وصرف، واستصناع، وكذلك الشركات، والمضاربات، وعقود الضمان من الكفالة، والحوالة، وعقود الأمانات من: ودائع وعواري، ثم عقود المزارعة، والمساقاة، والقسمة.

فبدراسة هذه العقود يستطيع الطالب معرفة ما يحل منها، وما يحرم. وتعلم ذلك من الواجبات، فمن عرف الحلال والحرام، استطاع أن يتحراها في مطعمه ومشربه وملبسه، وفي قوله وفي فعله، وفي سائر تصرفاته.

ولقد كان سلفنا الصالح يتحرون الحلال والحرام، مخافة الوقوع في الحرام. والحلال: هو ما أحله الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، والحرام: هو ما حرم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وليس لأحد كائنا من كان أن يحل حراماً أو يحرم حلالاً، إلا بدليل من كتاب الله أو سنة نبيه ﷺ، ومن حرم ما أحل الله هو كمن أحل ما حرم الله، قال تعالى: {ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع قليل ولهم عذاب أليم} النحل ١١٦، ١١٧. وقال ﷺ: (ألا يمسن الناس على بشيء إلا ما أحلت لهم، ولا ما حرمت عليهم) رواه الامام مالك في الموطأ كتاب الاقضية.

المحتويات

أولاً: موضوعات الدراسة النصية

١. البيوع

٢. الخيارات

٣. بيوع المربحة والتولية

ثانياً: موضوعات الدراسة الموضوعية

الفصل الأول الفصل التمهيدي: التعريف بالمال وأقسامه والعقد وأنواعه.

الفصل الثاني: الربا.

الفصل الثالث: السلم.

الفصل الرابع: الاستصناع.

الفصل الخامس: المضاربة.

الفصل السادس: الصرف.

الفصل السابع: الكفالة.

الفصل الثامن: الحوالة.

الفصل التاسع: الشركة.

الفصل العاشر: المزارعة

الفصل الحادي عشر: المساقاة.

الفصل الثاني عشر: القسمة

الفصل الثالث عشر: الوديعة

الفصل الرابع عشر: العارية.

القسم الأول
الدراسة النصية في الفقه الحنفي
الفقرة الثانية بتسميها

(كتاب^(١) البيوع^(٢))

(مشروعية البيع وأدلته)

مشروعية^(٣) البيع ثبتت بالكتاب^(٤) ،

(١) الكتاب في اللغة : بمعنى الضم والجمع والحكم والاسم الكتابة والكتاب : ما يكتب فيه وكتب الكتاب كتباً وكتابة: أي خطه، . المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي: لأحمد بن محمد بن علي المقرئ الفيومي ٥١٤/٢ . ط. المكتبة العلمية- بيروت، مختار الصحاح للشيخ الإمام محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي: ٢٣٤ . مادة: كتب . ط. دار الكتب العلمية - بيروت ، طبعة ١٤١٥ هـ - ١٩٩٥ م .

والكتاب : صحف ضم بعضها إلى بعض .

المعجم الوجيز : ٢٥٧ . مادة : كتب . ط. وزارة التربية والتعليم، ١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ م .
واصطلاحاً: طائفة من المسائل اعتبرت مستقلة ؛ سواء كانت مستقلة في نفسها ككتاب اللقطة أو تابعة لما بعدها ككتاب الطهارة أو مستتبعة لما قبلها ككتاب الصلاة .
مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر . للفتية : عبد الرحمن بن محمد بن سليمان المعروف بداما أفندي ٨ / ١ . ط. دار إحياء التراث العربي. بيروت- لبنان .

وعرفه الخطيب الشربيني : بأنه اسم لجملة مختصة من العلم مشتملة على أبواب وفصول غالباً .
مغنى المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج. للشيخ: محمد الشربيني الخطيب على متن المنهاج لأبي زكريا بن شرف النووي ١ / ١١٤ . ط. مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر .

(٢) البيع في اللغة : البيع ضد الشراء ، والبيع الشراء أيضاً ، وهو من الأضداد ، وبعث الشيء وأبيعه بيعاً ومبيعاً وهو شاذ وقياسه مباعاً والابتياح الاشتراء .
لسان العرب ٨ / ٢٣ .

واصطلاحاً: عبارة عن مبادلة المال بالمال على سبيل التراضي .
حاشية ابن عابدين ٥٠٢/٤ .

(٣) المشروعية : تعنى نسبة الفعل إلى الشرع ، فإذا قيل عقد البيع مشروع فمعنى ذلك أنه داخل ضمن ما أجازته الشرع ؛ فيكون داخلاً في دائرة المباح أو المندوب أو الواجب .
محاضرات في المعاملات المالية في الفقه الإسلامي. أ. د / محمد سيد أحمد عامر : ٦ . ط. التركي للكمبيوتر وطباعة الأوفست طنطا - ١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٢ م .

(٤) الكتاب : هو كلام الله المنزل على رسوله محمد- ﷺ - المكتوب في المصاحف المنقول عن النبي - ﷺ - نقلاً متواتراً بلا شبهة ، أو هو ما نقل إلينا بين دفتي المصاحف تواتراً .

والسنة (١) ، والإجماع (٢) أما الكتاب : فقول الله تعالى : ﴿ وأحل الله البيع وحرم الربا ﴾ (٣) .

كشف الأسرار شرح أصول البزدوي لعبد العزيز بن أحمد البخاري ١ / ٢٢ . ط. دار الكتاب الإسلامي ، شرح التلويح على التوضيح لمسعود بن عمر التفتازاني ١ / ٤٦ . ط. مكتبة صبيح بمصر (١) السنة في اللغة: الطريقة ، والسنة السيرة حميدة كانت أو ذميمة .
المصباح المنير ١ / ٢٩٢ ، مختار الصحاح : ١٣٣ .
واصطلاحاً : عرفها الأصوليون : بقولهم بأنها اسم للطريق المسلك في الدين من غير افتراض ولا وجوب وهي قول النبي - ﷺ - وفعله وتقديره .
كشف الأسرار شرح أصول البزدوي ٢ / ٣٠٢ ، والتقرير والتحبير في شرح التحرير لمحمد بن محمد بن أمير الحاج ٢ / ٢٢٣ . ط. دار الكتب العلمية .
وعرفها الفقهاء بأنها : ما واطب عليها النبي - ﷺ - حتى صارت عادة ، ولم يتركها إلا أحياناً ؛ لأن السنة هي الطريقة المسلوكة في الدين . رد المختار على الدر المختار لخاتمة المحققين محمد أمين الشهير بابن عابدين ١ / ١٠٣ . ط. مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر ، الطبعة الثانية ١٣٨٦هـ-١٩٦٦م .

وعرفها أهل الحديث بأنها : ما أضيف إلى النبي - ﷺ - من قول أو فعل أو تقرير .
توجيه النظر إلى أصول الأثر ١ / ٤٠ .
(٢) الإجماع في اللغة : العزم والاتفاق. يقال : أجمعت على شيء : أي عزمت عليه ومنه قول الله تعالى : ﴿ فأجمعوا أمركم ﴾ سورة يونس من الآية (٧١) أي : ادعوا شركاءكم وأجمع القوم على كذا : أي اتفقوا عليه.

القاموس المحيط ٣/ ١٥ ، مختار الصحاح: ٤٧ ، المعجم الوجيز: ١١٦ .
واصطلاحاً : اتفاق أهل الحل والعقد من أمة محمد - ﷺ - على أمر من الأمور .
الإبهاج لعلي بن عبد الكافي السبكي المتوفى سنة ٧٥٦ هـ . تحقيق. جماعة من العلماء ٢/ ٣٤٩ . ط. دار الكتب العلمية - بيروت ، الطبعة الأولى ١٤٠٤ هـ .
(٣) سورة البقرة : من الآية (٢٧٥) .

وقوله تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ) (١)، وأما السنة ، فما روى في السنن (٢) مسنداً (٣) إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: (يا معشر التجار: إن البيع يحضره اللغو والحلف فشوبوه بالصدقة) (٤)

(١) سورة النساء الآية (٢٩) .

وجه الدلالة : هذه الآية تدل على أن الحق سبحانه وتعالى نهانا فيها عن أخذ أموال الغير بطريق الغصب أو النهب أو السرقة أو الاحتيال وغير ذلك مما هو ممنوع شرعاً ، وأمرنا بأخذها بطريق حلال مشروع وهو التجارة، والتجارة لا تكون إلا عن طريق البيع والشراء المشروعين .
الجامع لأحكام القرآن للقرطبي. تحقيق. أ. د محمد إبراهيم الحنفاوي، أ.د محمود حامد عثمان ١٣٦/٣ . ط. دار الحديث بالقاهرة ، ١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٢ م .

(٢) أصحاب السنن : أبو داود، والترمذي، والنسائي ، وابن ماجه ، والدار قطني .
توجيه النظر إلى أصول الأثر لطاهر الجزائري الدمشقي . تحقيق. عبد الفتاح أبو غدة ٨٣/١ . ط. الناشر مكتبة المطبوعات الإسلامية - حلب ، الطبعة الأولى ١٤١٦ هـ - ١٩٩٥ م .
(٣) المسند : عند أهل الحديث هو الذي اتصل سنده من راويه إلى منتهاه ، وأكثر ما يستعمل ذلك فيما جاء عن رسول الله - ﷺ - دون ما جاء عن الصحابة .
وقال الحاكم : هو ما اتصل سنده مرفوعاً إلى النبي - ﷺ - .

التقييد والإيضاح شرح مقدمة ابن الصلاح. للحافظ زين الدين عبد الرحيم بن الحسين العراقي . تحقيق. عبد الرحمن عثمان ٦٤/١ . ط. دار الفكر للنشر والتوزيع. بيروت - لبنان ، الطبعة الأولى ١٣٨٩ هـ - ١٩٧٠ م ، المنهل الروي في مختصر علوم الحديث لمحمد بن إبراهيم بن جماعة. تحقيق. محيي الدين عبد الرحمن رمضان ٣٩/١ . ط. دار الفكر - دمشق ، الطبعة الثانية ١٤٠٦ هـ .

(٤) أخرجه سليمان بن الأشعث أبو داود السجستاني الأزدي في سننه . تحقيق. محمد محيي الدين (٢٦٢/٢) كتاب البيوع - باب في التجارة يخالطها اللغو والحلف ، حديث رقم ٣٣٢٦ . ط. دار الفكر وأحمد بن حنبل الشيباني في مسنده (٦/٤) ، حديث رقم ١٦١٨٤ . ط. مؤسسة قرطبة بالقاهرة ، والمعجم الكبير لسليمان بن أحمد بن أيوب أبو القاسم الطبراني . تحقيق . حمدي بن عبد المجيد السلفي (٣٥٦/١٨) ، حديث رقم ٩١١ . ط. مكتبة العلوم والحكم - الموصل ، الطبعة الثانية ١٤٠٤ هـ - ١٩٨٣ م ، وابن ماجه لمحمد بن يزيد أبي عبد الله القزويني في سننه . تحقيق. محمد فؤاد عبد الباقي (٧٢٦/٢) كتاب التجارات - باب التوقي في التجارة ، حديث رقم ٢١٤٥ . ط. دار الفكر - بيروت . كلهم من حديث قيس عن أبي غرزة .

درجة هذا الحديث :

قال عنه أبو عيسى: حديث حسن صحيح ، وقال : لا نعرف لقيس عن النبي - ﷺ - غير هذا . عون المعبود شرح سنن أبي داود لمحمد شمس الحق العظيم أبادي أبي الطيب (١٢٤/٩) . ط. دار

وقد بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس يتبايعون فقرهم (١) على ذلك،
وأما الإجماع (٢) فهو منعقد على جواز البيع

الكتب العلمية - بيروت ، الطبعة الثانية ١٤١٥ هـ ، تحفة الأحوذى بشرح جامع الترمذى لمحمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم المباركفوري أبى العلا (٣٣٥/٤) . ط. دار الكتب العلمية - بيروت .
وجه الدلالة : دل هذا الحديث على مشروعية البيع ، كما أن فيه دليلاً على أنه يحضره اللغو والحلف ،
فأمر النبي - ﷺ - أن يخلط التجار ذلك بالصدقة ، وهذا واضح من أمره - ﷺ - بالتشويب ؛
لأنها تطفئ غضب الرب . المرجعين السابقين بتصرف .

(١) التقرير: أحد وجوه السنة، وهذا ثابت بالاستقراء: أي بالتتابع. شرح فتح القدير ٢٢٩/٦ .
ومعنى التقرير: أن يقول الصحابي أو غيره: فعل فلان أو أحد بحضرة النبي - ﷺ - ، ولا يذكر إنكاره.
مقدمة في أصول الحديث لعبد الحق بن سيف الدين بن سعد الله البخاري الدهلوي . تحقيق. سليمان الحسيني الندوي ١ / ٣٧ . ط. دار البشائر الإسلامية . بيروت - لبنان ، الطبعة الثانية ١٤٠٦ هـ -
١٩٨٦ م ، تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي لعبد الرحمن بن أبى بكر السيوطي . تحقيق.
عبد الوهاب عبد اللطيف ١ / ١٩٤ . ط. مكتبة الرياض الحديثة - الرياض .

(٢) وقد حكى الإجماع غير واحد ، انظر : العناية شرح الهداية بهامش شرح فتح القدير لأكمل الدين محمد بن محمود البابرتي المتوفى سنة ٧٨٦ هـ ٢٢٩/٦ ، مواهب الجليل في شرح مختصر خليل لمحمد بن محمد بن عبد الرحمن الخطاب ٢٢٧/٤ . ط. دار الفكر - بيروت ، المذهب في فقه الإمام الشافعي لأبى إسحاق إبراهيم ابن عامر ابن يوسف الفيروز آبادي الشيرازي المتوفى سنة ٤٧٦ هـ ، ٣٤٢/١ . ط. مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر ، الطبعة الثالثة ١٣٩٦ هـ - ١٩٧٦ م ، المغنى للإمام العلامة أبى محمد عبد الله ابن قدامة ٢٠٩/٤ . ط. دار الغد العربي ١٤١٥ هـ - ١٩٩٤ م . =

وتتميماً للفائدة : فقد أشار الكمال بن الهمام في كتابه شرح فتح القدير إلى الحكمة التي من أجلها شرع البيع فقال : إن سبب شرعيته تعلق البقاء المعلوم فيه لله تعالى على وجه جميل ، وذلك أن الإنسان لو استقل بابتداء بعض حاجاته من حرث الأرض ثم بذر القمح وخدمته وحراسته وحصده ودرسه ثم تزييته ثم تنظيفه وطحنه بيده وعجنه وخبزه لم يقدر على مثل ذلك ، وفى الكتان والصوف للبسه وبناء ما يظله من الحر إلى غير ذلك ، فلا بد من أن تدفعه الحاجة إلى أن يشتري شيئاً ويبتدىء مزاوله شيء فلو لم يشرع البيع سبباً للتمليك فى البديلين ، لاحتاج أن يؤخذ على التغالب والمقاهرة .

(انعقاد البيع وركنه)

قال (١) : البيع يُعقَد (٢) بِالْإِيجَابِ (٣) وَالْقَبُولِ (٤)، إِذَا كَانَ بِلَفْظِي الْمَاضِي مِثْلَ أَنْ يَقُولَ

(١) قال: أي القدوري في مختصره .

(٢) أي يوجد به شرعاً ، وعكسه الباطل .

والعقد في اللغة : يقال : عقدت الحبل عقداً من باب ضرب فانعقد والعقدة ما يمسكه ويوثقه ، ومنه قيل : عقدن البيع وعقدة النكاح وغيره . إحكامه وإبرامه .

المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي ٢ / ٤٢١ .

واصطلاحاً: العقد ما يعقده العاقد على أمر يفعله هو أو يعقد على غيره فعله على وجه إلزامه إياه .
أحكام القرآن لأبي بكر أحمد بن علي الرازي الجصاص ٣ / ٢٨٥ .

الانعقاد هاهنا : تعلق كلام أحد العاقلين بالآخر شرعاً على وجه يظهر أثره في المحل .
البنية في شرح الهداية ٤/٨ .

وقد قسم الحنفية العقود من حيث :

أ- انعقادها إلى : منعقد ، وباطل .

ب- ومن حيث صحتها إلى : صحيح ، وفاسد .

ج- ومن حيث نفاذها إلى : نافذ ، وموقوف .

د- ومن حيث لزومها إلى : لازم ، وجائز .

البحر الرائق ٥ / ٢٧٨ وما بعدها .

(٣) الإيجاب في اللغة: معناه: الإثبات والإلزام. يقال : وجب الشيء يجب وجوباً أي : ثبت ولزم .

القاموس المحيط ١ / ١٢ ، ومختار الصحاح : ٢٩٥ . باب الواو . مادة : وجب .

واصطلاحاً : هو ما يذكر أولاً من كلام أحد العاقلين (البائع والمشتري) .

اللباب في شرح الكتاب للشيخ عبد الغنى الغنيمي الدمشقي . الميداني الحنفي : ٢٢٢ . ط . المعاهد

الأزهرية ١٣٩٧هـ - ١٩٧٧م

(٤) القبول في اللغة : يقال : قبلت العقد أقبله من باب تعب قبولاً بالفتح ، والضم لغة : حكاها ابن

الأعرابي، وقبلت القول : صدقته، وقبلت الهدية ،أي: أخذتها. ويقال: أقبلت الدنيا عليه: جاءته

بخيرها المصباح المنير ٢/ ٤٨٨ ، والمعجم الوجيز ص: ٤٨٨ .

واصطلاحاً : بأنه ما يذكر ثانياً من أحد العاقلين . اللباب في شرح الكتاب ص: ٢٢٢ .

أَحَدُهُمَا بَعَتْ وَالْآخَرُ اشْتَرَيْتَ ، لِأَنَّ الْبَيْعَ إِنْشَاءٌ (١) تَصَرُّفٌ (٢) وَالْإِنْشَاءُ يُعْرَفُ بِالشَّرْعِ (٣)
وَالْمَوْضُوعُ لِلْإِخْبَارِ قَدْ أُسْتُعْمِلَ فِيهِ فَيَنْعَقِدُ بِهِ ، وَلَا يَنْعَقِدُ بِالْفُظَيْنِ أَحَدُهُمَا لَفْظُ الْمُسْتَقْبَلِ (٤) ،
وَالْآخَرُ لَفْظُ الْمَاضِي ، بِخِلَافِ النِّكَاحِ (٥) ،

(١) الإنشاء: إثبات أمر لم يكن ، ويراد به الإيجاد للحال، ومعنى قوله: إنشاء تصرف: أن هذا التصرف إنشاء؛ لأن المبادلة ما كانت ثابتة، وقد ثبتت بعد صدور اللفظين ؛ فيكون إنشاء. البناية في شرح الهداية ١٠ / ٧ .

(٢) التصرف في اللغة : مأخوذ من مادة : صرف، والصرف التقلب والحلية . يقال : فلان يصرف ويتصرف ويصطرف لعياله: أي يتكسب لهم، ومنه التصرف في الأمور . يقال : صرفت الرجل في أمرى تصرفاً فيتصرف فيه. لسان العرب ٩ / ١٩٠ .

واصطلاحاً : هو كل ما يكون من تصرفات الشخص القولية، ويرتب عليه الشارع أثراً شرعياً في المستقبل.

الملكية ونظرية العقد للإمام أبي زهرة: ١٨١ . ط. دار الفكر العربي ١٣٩٦ هـ - ١٩٧٦ م.

(٣) لما فيه من إثبات معنى يكون اللفظ علة له ، والعبد لا يقدر على ذلك إنما له قدرة الإخبار عن الكائن أو ما سيكون وطلبه. شرح فتح القدير ٦ / ٢٣١ .

الشرع في اللغة: عبارة عن البيان والإظهار ، يقال : شرع الله الدين شرعاً ؛ إذا أظهره وبينه . النهاية في غريب الحديث والأثر لأبي السعادات المبارك بن محمد الجزري . تحقيق. طاهر أحمد الزاوي -

محمود محمد الطناحي ٢ / ٤٦٠ . ط. المكتبة العلمية - بيروت ١٣٩٩ هـ - ١٩٧٩ م

واصطلاحاً: نهج الطريق الواضح، واستعير للطريقة الإلهية بين الدين ، والشروع في الشيء الدخول فيه والتلبس بفعله ، وعبر بعضهم بقوله: الشروع تلبس بجزء يقصد تحصيل الأجزاء الباقية .

التوقيف على مهمات التعاريف للمناوي ص: ٤٢٨ ، التعريفات للجرجاني ص: ١٦٧ .

(٤) هذا إذا لم ينو به الحال، فإذا نوى به انعقد به أيضاً .

وعلل الكمال بن الهمام بقوله : واعلم أن عدم الانعقاد بالمستقبل ، هو إذا لم يتصادقا على نية الحال أما إذا تصادقا على نية البيع في الحال فينعقد به في القضاء ؛ ولأن صيغة الاستقبال تحتل الحال فيثبت بالنية . شرح فتح القدير ٦ / ٢٣٢ .

(٥) النكاح في اللغة : الوطء والعقد . القاموس المحيط لمحمد بن يعقوب الفيروز آبادي ١ / ٣١٤ .

ط. مؤسسة الرسالة - بيروت ، المصباح المنير ٢ / ٦٢٤ .

واصطلاحاً : عقد يفيد ملك المتعة قصداً .

رد المحتار على الدر المختار ٣ / ٣ ، الباب في شرح الكتاب : ٦٦٤ .

وَقَدْ مَرَّ الْفَرْقُ هُنَاكَ (١)، وَقَوْلُهُ رَضِيتْ بِكَذَا أَوْ أَعْطَيْتُكَ بِكَذَا أَوْ خُذْهُ بِكَذَا فِي مَعْنَى قَوْلِهِ بَعْتُ وَاشْتَرَيْتُ (٢)؛ لِأَنَّهُ يُؤَدِّي مَعْنَاهُ (٣)، وَالْمَعْنَى هُوَ الْمُعْتَبَرُ فِي هَذِهِ الْعُقُودِ (٤)، وَلِهَذَا يَنْعَقِدُ بِالتَّعَاطِي (٥) فِي النَّفِيسِ (٦) وَالْخَسِيسِ (٧) هُوَ الصَّحِيحُ (٨) لِتَحَقُّقِ الْمُرَاضَةِ، قَالَ (٩): وَإِذَا أُوجِبَ أَحَدُ الْمُتَعَاقِدَيْنِ الْبَيْعَ فَلَاخَرُ بِالْخِيَارِ إِنْ شَاءَ قَبْلَ فِي الْمَجْلِسِ وَإِنْ شَاءَ رَدًّا، وَهَذَا خِيَارُ الْقَبُولِ؛ لِأَنَّهُ لَوْ لَمْ يَثْبُتْ لَهُ الْخِيَارُ يُلْزَمُهُ حُكْمُ الْبَيْعِ مِنْ غَيْرِ رِضَاهُ، وَإِذَا لَمْ يَفْسُدْ لِحُكْمِ بَدُونِ

(١) حيث قال في كتاب النكاح ما توضيحه : أن قوله زوجني توكيل بالنكاح والواحد يتولى طرفي النكاح ، فإن الوكيل في النكاح معبر وسفير ، وإنما المنع في الحقوق دون التعبير ، ولا يرجع الحقوق إليه بخلاف البيع ؛ لأنه مباشر حتى رجعت الحقوق إليه . العناية شرح الهداية ٣٠٧/٣ .

(٢) هذا لبيان أن انعقاد البيع لا ينحصر في لفظ بعث واشتريت ؛ بل كل ما دل على ذلك ينعقد به . العناية شرح الهداية ٦ / ٢٣٣ .

(٣) وكذا إذا قال : اشتريت منك هذا بكذا فقال : خذه ، يعنى بعث بذلك فخذه ؛ لأنه أمره بالأخذ بالبدل ؛ وهو لا يكون إلا بالبيع فقدر البيع اقتضاء فصار كل ما يؤدي معنى بعث واشتريت سواء في انعقاد البيع به ؛ لأن المعنى هو المعتبر في هذه العقود . العناية شرح الهداية ٦ / ٢٣٣ .

(٤) أشار الإمام البahrتي : بقوله : بعث واشتريت ؛ لأن بعض العقود قد تحتاج إلى اللفظ ، ولا ينعقد بدونه كما في المفاوضة ، إذا لم يبيننا جميع ما تقتضيه . المرجع السابق .

(٥) التعاطي في اللغة : التناول والجرأة على الشيء من عطا الشيء يعطوه إذا أخذه وتناوله وعاطى الصبى أهله عمل لهم وناولهم ما أرادوا . لسان العرب ١٥ / ٧٠ .

واصطلاحاً : وضع الثمن وأخذ المثل من تراض منهما من غير لفظ ، وهو يفيد أنه لا بد من الإعطاء من الجانبين ؛ لأنه من المعاطاة . البحر الرائق شرح كنز الدقائق ٥ / ٢٩١ .

وعرفه الإمام العيني بقوله: هو أن البائع يعطى المبيع ولا يتلفظ بشيء ، والمشتري يعطى الثمن كذلك البناية في شرح الهداية ٧ / ١٣ .

(٦) المبيع نفيساً بأن يكثر ثمنه كالعبد .

(٧) بأن يقل ثمنه كالبقول والرمانة والخبز واللحم ونحو ذلك .

(٨) إشارة إلى ما تقدم من أن البيع بالتعاطي يصح مطلقاً في النفيس والخسيس .

والصحيح : هذا اللفظ يستعمل للترجيح بين الأقوال ، فقد يذكر للمسألة الواحدة عدة أقوال ، ويذيل أحدها بقولهم وهو الصحيح ، وتذيل العبارة بهذا اللفظ يدل على أن بقية الأقوال ضعيفة ؛ لأن مقابل

الصحيح هو الفاسد ، فيتعين العمل بالصحيح وتترك بقية الأقوال .

مصطلحات المذاهب الفقهية . لمريم محمد الظفيري ص : ١١٤ . ط . دار ابن حزم .

(٩) أي : قال القدوري في مختصره ص : ٧٨ .

قَبُولِ الْآخِرِ (١) فَلِلْمُوجِبِ أَنْ يَرْجِعَ عَنْهُ قَبْلَ قَبُولِهِ (٢) لِيُخْلُوهُ عَنْ إِبْطَالِ حَقِّ الْغَيْرِ (٣) (٤) وَإِنَّمَا يَمْتَدُّ إِلَى آخِرِ الْمَجْلِسِ (٥) (٦)، لِأَنَّ الْمَجْلِسَ جَامِعُ الْمُتَفَرِّقَاتِ فَاعْتَبِرَتْ سَاعَتُهُ سَاعَةً وَاحِدَةً (٧) دَفْعًا

(١) والأصل في ثبوت الخيار ما حدث البخاري بإسناده إلى حكيم بن حزام رضي الله عنه قال : قال رسول الله - ﷺ : - (البيعان بالخيار ما لم يتفرقا أو قال حتى يتفرقا ، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما.

الحديث : أخرجه البخاري في صحيحه (٢ / ٧٣٢ ، ٧٣٣) كتاب البيوع- باب السهولة والسماحة في الشراء والبيع ، حديث رقم ١٩٧٣ ، مسلم في صحيحه ، لمسلم بن الحجاج أبو الحسين القشيري النيسابوري . تحقيق . فؤاد عبد الباقي (٣ / ١١٦٤) كتاب البيوع- باب الصدق في البيع ، حديث رقم ١٥٣٢ . ط. دار إحياء التراث العربي - بيروت ، وابن حبان في صحيحه لمحمد بن حبان بن أحمد بن أبي حاتم التميمي السبكي . تحقيق . شعيب الأرنؤوط (١١ / ٢٦١) كتاب البيوع ، حديث رقم ٤٩٠٤ . ط. مؤسسة الرسالة - بيروت ، الطبعة الثانية ١٤١٤ هـ - ١٩٩٣ م ، وأحمد في مسنده (٣ / ٤٠٢ ، ٤٠٣) حديث رقم ١٥٣٤٩ . كلهم من حديث حكيم بن حزام .

(٢) والمراد من التفريق هو التفريق قولاً لا بديناً.

(٣) ولأن المشتري لو لم يثبت له الخيار بالقبول أو الرد يلزم إلزام العقد عليه بلا رضا فلا يجوز ، ولذا يثبت الخيار للبائع قبل قبول المشتري ، فإن شاء بقى على إيجابه وإن شاء رجع عن ذلك؛ لأنه لم يترتب على إيجابه حكم العقد قبل قبول صاحبه ، فإن رجع بعد ذلك عن إيجابه لا يلزم إبطال حق صاحبه ، فكان له الرجوع

(٤) فإن قلت : يثبت للمشتري حق التملك بقول البائع فيكون الرجوع له إبطالاً فيجاب على ذلك: بأن هذا الحق ثبت له من جهة البائع فيكون له إبطال ما أثبتته . البناءة في شرح الهداية ٧ / ١٥ .

(٥) ثم خيار القبول يمتد إلى آخر المجلس ما لم يوجد دليل من القيام أو بالاشتغال بعمل يدل على الإعراض، فإذا وجد فلا يصح القبول بعد ذلك . أحكام القرآن للجصاص ٣ / ١٣٨ ، ١٣٩ .

(٦) هذا يجوز أن يكون جواباً عما يقال ما وجه اختصاص خيار الرد والقبول بالمجلس ولم يبطل الإيجاب عقيب خلوه عن القبول أو يتوقف على ما وراء المجلس .

تقرير الجواب: أن امتداده إلى آخر المجلس لأن المجلس جامع المتفرقات كما في الصرف والسلم ، وخيار المخيرة وقراءة آية السجدة فاعتبرت ساعة المجلس ساعة واحدة كما في الأشياء المذكورة

البناءة في شرح الهداية ٧ / ١٦ ، العناية شرح الهداية بهامش فتح القدير ٦ / ٢٣٥ .

(٧) أي ساعات المجلس .

لِّلْعُسْرِ وَتَحْقِيقًا لِلْيُسْرِ (١) ، وَالْكِتَابُ كَالْخِطَابِ ، (٢) ، وَكَذَا الْإِرْسَالُ (٣) حَتَّى أُعْتَبِرَ مَجْلِسُ
بُلُوغِ الْكِتَابِ ، وَأَدَاءِ الرِّسَالَةِ

-
- (١) وإنما فعل كذلك هنا أيضاً دفعاً للعسر عن البائع والمشتري جميعاً .
أما عن المشتري فلأن في إبطاله قبل انقضاء المجلس عسر له .
وأما عن البائع فلأن في إبقائه فيما وراء المجلس عسراً له في التوقف ، وفي التوقف على المجلس عسر
لهما جميعاً وأشار بقوله : " طلبا لليسر " أي لأجل تحقيق اليسر في حقهما
البنائية في شرح الهداية ١٦ / ٧ .
- (٢) هو أن يكتب إليه : أما بعد : فقد بعث عبدى فلاناً منك بألف درهم فلما بلغه الكتاب قال في
مجلسه ذلك : اشتريت ، تم البيع ؛ لأن الخطاب والجواب من الغائب بالكتاب يكون .
- (٣) الإرسال : التوجيه وأرسل الشيء أطلقه وأهمله . لسان العرب ١١ / ٢٨٣ ، ٢٨٥ .

(موافقة القبول للإيجاب في المبيع والثلث)

وَلَيْسَ لَهُ (١) أَنْ يَقْبَلَ فِي بَعْضِ الْمَبِيعِ وَلَا أَنْ يَقْبَلَ الْمُشْتَرِي بَعْضَ الثَّمَنِ (٢) لِعَدَمِ رِضَا الْآخَرِ
بِتَفْرِيقِ الصَّفَقَةِ (٣)، إِلَّا إِذَا بَيَّنَّ ثَمَنَ (٤) كُلِّ وَاحِدٍ؛ لِأَنَّهُ صَفَقَاتُ (٥) مَعْنَى (٦)، قَالَ (٧): وَأَيُّهُمَا قَامَ
(٨) عَنِ الْمَجْلِسِ قَبْلَ الْقَبُولِ بَطَلَ الْإِيجَابُ؛ لِأَنَّ الْقِيَامَ دَلِيلُ الْإِعْرَاضِ وَالرُّجُوعِ (١)، وَلَهُ ذَلِكَ

(١) أي البائع .

(٢) بيانه أن البائع إذا أوجب في شيء فقبل المشتري في بعض ذلك أو أوجب المشتري في شيء فقبل البائع في بعضه ، فإن ذلك لا يجوز ؛ لأن فيه تفريق الصفقة وأحد العاقلين لا يملك تفريق الصفقة على الآخر في الإتمام؛ لأن في التفريق ضرراً وهذا؛ لأن الإنسان قد يجمع بين الشيئين في البيع والشراء رغبة في بيع أحدهما أو شراؤه ، فإذا قبل صاحبه في البعض يفوت الغرض المتبقي من الجمع وهو ضرر لا محالة .

(٣) فإن من عادة الناس ضم الرديء إلى الجيد في البياعات ليروج الرديء بالجيد، فلو ثبت خيار القبول في أحدهما فالمشتري يقبل العقد في الجيد ويترك الرديء على البائع فيزول الجيد عن ملكه بأقل من ثمنه وفيه ضرر للبائع فكان تفريق الصفقة مستلزماً للضرر. البناءة في شرح الهداية ١٩/٧. ومعنى تفريق الصفقة : ألا يتناول حكم العقد جميع المعقود عليهم أو يتناوله ثم ينحسر عنه، فتكون الصفقة الواحدة المجتمعة قد تفرقت، أو تبعضت، أو تجزأت. الموسوعة الفقهية الكويتية ٥٧ / ٢٠ .

(٤) الثلث : اسم لما يأخذه البائع في مقابلة البيع عيناً كان أو سلعة وكل ما يحصل عوضاً عن شيء فهو ثمن . التعاريف ص: ٢٢٤ .

الفرق بين الثمن والقيمة :

الثلث : ما تراضيا عليه المتبايعان سواء زاد على القيمة أو نقص .

القيمة : ما قوم به الشيء بمنزلة المعيار من غير زيادة ولا نقصان .

الجوهرة النيرة شرح مختصر القدوري ١/٤٤٧-٤٤٨ .

(٥) الصفقة: ضرب اليد على اليد في البيع أو البيعة ثم جعلت عبارة عن العقد نفسه . المغرب في ترتيب المعرب ١ / ٤٧٦ ..

(٦) لأن البيع الذي فيه بيان ثمن كل واحد صفقتان من حيث المعنى. البناءة ٧ / ١٩ .

(٧) هذا لفظ القدوري في مختصر ص: ٧٨ .

(٨) قوله أيهما قام : ذكر على وجه التعميم على المتعاقدين احترازاً عن إيجاب الخلع والعق على مال

(٢) عَلَى مَا ذَكَرْنَاهُ (٣)، وَإِذَا حَصَلَ الْإِجَابُ وَالْقَبُولُ لَزِمَ الْبَيْعُ (٤) وَلَا خِيَارَ (٥) لِوَاحِدٍ مِنْهُمَا إِلَّا مِنْ عَيْبٍ أَوْ عَدَمِ رُؤْيَةٍ (٦) (٧)، وَقَالَ الشَّافِعِيُّ (٨) : يَثْبُتُ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا خِيَارُ الْمَجْلِسِ (٩) لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: (الْمُتَبَايَعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا) (١) . وَلَنَا (٢) أَنَّ فِي

-
- (١) يعنى إذا وجد الإيجاب من أحد المتعاقدين ثم قام أحدهما أيهما كان من البائع أو المشتري قبل قبول الآخر بطل الإيجاب السابق ؛ لأن القيام دليل الاعتراض
- (٢) أي : لكل واحد منهما الإعراض والرجوع عما أوجب الموجب قبل قول الآخر .
- (٣) إشارة إلى قوله: (لأنه لو لم يثبت له الخيار، يلزمه حكم العقد من غير رضاه) إلى قوله: (فللموجب أن يرجع؛ لخلوه عن إبطال حق الغير) . البناءة في شرح الهداية ٢١ / ٧
- (٤) البيع اللزم : ما يمتنع انفكاكه عن الشيء، أو هو ما لا يكون لأحد العاقلين فيه حق الفسخ دون رضا الآخر ، كالبيع والصرف والسلم .
- درر الحكام في شرح مجلة الأحكام ١ / ١١٠ ، المنشور في القواعد الفقهية لبدر الدين محمد بن بهادر الزركشي ٢ / ٣٨٩ ، الأشباه والنظائر للسيوطي ص: ٢٧٦ .
- (٥) الخيار : اسم من الاختيار ، وهو طلب خير الأمرين . لسان العرب ٤ / ٢٦٧ .
- ومعناه : كون الإنسان مخيراً بين تنفيذ العقد وبين فسخه .
- درر الحكام في شرح مجلة الأحكام : ١ / ١١٠ .
- (٦) إنما خص خيار العيب وعدم الرؤية مع أن خيار الشرط مانع من لزوم البيع أيضاً ؛ لأنهما في كل بيع يوجدان ، أما خيار الشرط فعارض مبنى على الشرط .
- الجوهرة النيرة شرح مختصر القدوري ١ / ٤٣٣ .
- (٧) هذا لفظ القدوري في مختصره : اعلم أن الإيجاب والقبول إذا حصلا من الأهل ، مضافاً إلى المحل مع شرط النفاذ ، وهو الملك أو الولاية ، لزم البيع وليس لواحد من المتعاقدين بعد ذلك فسخ العقد في المجلس ولا بعد افتراقهما ، إلا برضا الآخر
- (٨) المذهب في فقه الإمام الشافعي ١ / ٣٤٣ .
- (٩) خيار المجلس : بأنه حق شرعي يثبت لكل واحد من المتعاقدين الحرية في إمضاء العقد ، أو فسخه ما دام في مجلس العقد ، ولم يتفرقا بأبدانهما أو يتخيرا .
- التجريد للإمام أبي الحسين أحمد بن محمد بن جعفر البغدادي القدوري . تحقيق . أ. د / محمد أحمد سراج أستاذ ورئيس قسم الشريعة بكلية الحقوق جامعة الإسكندرية ٥ / ٢٢٢٥ . ط. دار السلام للطباعة ، الطبعة الأولى ١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٤ م .

الْفَسْخُ(٣)إِبْطَالُ حَقِّ الْآخِرِ فَلَا يَجُوزُ، وَالْحَدِيثُ مَحْمُولٌ عَلَى خِيَارِ الْقَبُولِ، وَفِيهِ إِشَارَةٌ إِلَيْهِ
(٤)فَإِنَّهُمَا مُتَبَايِعَانِ حَالَةَ الْمُبَاشَرَةِ لَا بَعْدَهَا أَوْ يَحْتَمِلُهُ فَيُحْمَلُ عَلَيْهِ (٥)،
وَالْتَفَرُّقُ فِيهِ تَفَرُّقُ الْأَقْوَالِ (١).

(١) أخرجه مالك في الموطأ . تحقيق. د/ تقى الدين الندوي أستاذ الحديث الشريف (٣ / ١٩٤) ،
كتاب البيوع في التجارات والسلم - باب ما يوجب البيع بين البائع والمشتري، حديث رقم ٧٨٤ ،
ط. دار العلم - دمشق ، الطبعة الأولى ١٤١٣هـ - ١٩٩١م ، النسائي في سننه الكبرى لأحمد
بن شعيب أبي عبد الرحمن النسائي. تحقيق. د / عبد الغفار سليمان البنداري (٧/٤) كتاب البيوع
- باب وجوب الخيار للمتبايعين قبل افتراقهما، حديث رقم ٦٠٥٩ . ط. دار الكتب العلمية -
بيروت ، الطبعة الأولى ١٤١١هـ - ١٩٩١ ، كلهم من حديث نافع عن ابن عمر .

(٢) أي : أدلة الحنفية ومن وافقهم .

(٣)الفسخ في اللغة: الضعف والجهل وإفساد الرأي والنقض وانفسخ العزم والبيع والنكاح انتقض .
القاموس المحيط ١ / ٢٦٦ .

واصطلاحاً : رفع العقد من الأصل وجعله كأن لم يكن . بدائع الصنائع ٥ / ٤١٨ .

الفرق بين الفسخ والانفساخ : فالفسخ قلب كل واحد من العوضين لصاحبه ، والانفساخ : انقلاب كل
واحد من العوضين لصاحبه فالأول فعل المتعاقدين أو الحاكم إذا ظفروا بالعقود المحرمة ، والثاني :
صفة العوضين . فالأول : سبب شرعي والثاني : حكم شرعي. الانفاساخ فهو انحلال ارتباط العقد
سواء أكان أثراً للفسخ أو نتيجة لعوامل غير اختيارية فإذا كان الانحلال أثراً للفسخ كانت العلاقة بين
الفسخ والانفساخ علاقة السبب بالمسبب كما إذا فسخ أحد العاقدين عقد البيع بسبب العيب في
المبيع مثلاً . فالانفساخ في هذه الحالة نتيجة الفسخ الذي مارسه العاقد اختياراً .

أما إذ لم يكن الانفاساخ أثر الفسخ بل نتيجة لعوامل خارجة عن إرادة العاقدين كموت أحد العاقدين من
العقود غير اللازمة فلا يوجد بين الفسخ والانفساخ علاقة سببية وكما إذا تلفت الدابة المعينة .

المنثور في القواعد الفقهية لبدر الدين بن محمد بهادر الزركشي ٤٢/٣ . ط. وزارة الأوقاف الكويتية ،
أنوار البروق في أنواع الفروق ٣ / ٢٦٩ ، الموسوعة الفقهية الكويتية ٧ / ٢٥

(٤)وفيه إشارة إلى ذلك: لأن الأحوال ثلاث: قبل قبولهما. وبعد قبولهما، وبعد كلام الموجب قبل قول
الآخر، وإطلاق المتبايعين في الأولين مجاز باعتبار ما يؤول إليه ، أو ما كان عليه. والثالث حقيقة
فيكون مراداً، أو يحتمل أن يكون مراداً فيحمل عليه. والفرق بينهما أن أحدهما مراد والآخر محتمل
للإرادة. العناية شرح الهداية ٢٥٨/٦

(٥) فيحمل عليه :أي عند قيام الدليل ، وهو أن الحمل على خيار المجلس يوجب ابطال حق الغير

(العلم بقدر المبيع)

قَالَ: وَالْأَعْوَاضُ الْمُشَارُ إِلَيْهَا لَا يُحْتَاجُ إِلَى مَعْرِفَةِ مِقْدَارِهَا فِي جَوَازِ الْبَيْعِ؛ لِأَنَّ بِالْإِشَارَةِ كِفَايَةً فِي التَّعْرِيفِ (٢)، وَجَهَالَةُ (٣)
الْوَصْفِ (١) فِيهِ لَا تُفْضِي إِلَى الْمُنَازَعَةِ (٢).

(١) والتفرق فيه. اعلم أن خيار القبول ثابت مالم يتفرقا قولاً ، فإن تفرقا قولاً بأن قال أحدهما بعت ، والآخر اشريت ن لم يبق الخيار بعده، وهذا مبني علّا أن التفرق يطلق على الأعيان والمعاني بالاشتراك اللفظي، وترجيح جهة التفرق بالأقوال بما ذكرنا من أداء حمله على التفرق بالأبدان. البناية شرح الهداية ١٣/٨.

(٢) اعلم أن الأعواض ، إذا كانت مشاراً إليها سواء كانت ثمناً أو مثمناً ، لا يشترط فيها معرفة المقدار في جواز البيع ؛ لأن بالإشارة يحصل التعريف النافي للجهالة المفضية إلى المنازعة ، المانعة من التسليم والتسلم ، اللذين أوجبهما عقد البيع ؛ فكل جهالة لا تمنع من التسليم والتسلم لا تمنع جواز العقد. العناية شرح الهداية ٦ / ٢٤١ .

(٣) الجهالة في اللغة : يقال جهلت الشيء جهلاً و جهالة خلاف علمته ، وجهل الحق أضاعه فهو جاهل، وجهل الشيء لم يعرفه. المصباح المنير ١/ ١١٢، مختار الصحاح : ٤٥
والجهل هو اعتقاد الشيء على خلاف ما هو عليه . التعريفات للجرجاني ص: ١٠٨ .
واصطلاحاً : كل ما علم حصوله وجهلت صفته كبيع الإنسان ما في كفه فهو يحصل قطعاً لكنه لا يدري أي شيء هو .

والفرق بين " الجهالة والغرر " :

فرق الإمام القرافي بين الغرر والجهالة فقال :

أصل الغرر: هو الذي لا يدري هل يحصل أم لا ؟ أما ما علم حصوله وجهلت صفته فهو المجهول .
فالغرر والمجهول كل واحد منهما أعم من الآخر من وجه وأخص من وجه .
فيوجد كل واحد منهما مع الآخر وبدونه .

أما وجود الغرر بدون الجهالة فكشراء العبد الآبق المعلوم قبل الإباق لا جهالة فيه وهو غرر ؛ لأنه لا يدري هل يحصل أم لا ؟

وأما وجود الجهالة بدون الغرر فكشراء حجر يراه لا يدري أزجاج هو أم ياقوت مشاهدته تقتضي القطع بحصوله وعدم معرفته تقتضي الجهالة به .

وأما اجتماع الغرر والجهالة فكالعبد الآبق المجهول الصفة قبل الإباق .

أنوار البروق في أنواع الفروق: لأحمد بن إدريس القرافي ٣/ ٢٦٥ ، ٢٦٦.

(العلم بقدر الثمن وصفته)

وَالْأَثْمَانُ الْمُطْلَقَةُ (٣) لَا تَصِحُّ إِلَّا أَنْ تَكُونَ مَعْرُوفَةً الْقَدْرِ وَالصِّفَةِ؛ لِأَنَّ التَّسْلِيمَ وَالتَّسْلَمَ وَاجِبٌ بِالْعَقْدِ، وَهَذِهِ الْجِهَالَةُ مُفْضِيَةٌ إِلَى الْمُنَازَعَةِ فَيَمْتَنِعُ التَّسْلِيمُ وَالتَّسْلَمُ، وَكُلُّ جِهَالَةٍ هَذِهِ صِفَتُهَا (٤) تَمْنَعُ الْجَوَازَ، هَذَا هُوَ الْأَصْلُ .

(جواز البيع بثمن حال أو مؤجل)

قَالَ: وَيَجُوزُ الْبَيْعُ بِثَمَنِ حَالٍ وَمُؤَجَّلٍ إِذَا كَانَ الْأَجَلُ مَعْلُومًا لِإِطْلَاقِ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ (٥) وَعَنْهُ -عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ- أَنَّهُ اشْتَرَى مِنْ يَهُودِيٍّ (٦) طَعَامًا إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ

(١) أي جهالة القدر في العوض المشار إليه أي : وصف المقدار في التعريف أو في البيع لا يفضى إلى المنازعة ؛ لأنها حاضرة ، والتقابض حال ، بخلاف جهالة وصف المقدار في المسلم فيه ، حيث لا يجوز لأدائها إلى المنازعة لعدم حضوره . البناءة في شرح الهداية ٧ / ٢٨ .

(٢) المنازعة : المخاصمة . لسان العرب ٨ / ٣٥٨ .

(٣) والمراد بالأثمان المطلقة: الدراهم والدنانير، لأنهما أثمان بكل حال ؛ لأن الله خلق الذهب والفضة ثمنًا للأشياء، والمعنى بالثمنية كونه بحال يقدر به مالية الأشياء، ويتوصل به إليها ، وهما (الذهب والفضة) بهذه الصفة قبل الصياغة وبعدها، ويجوز أن يراد بها المطلقة عن قيد الإشارة بأن يقول مثلاً : بعت بذهب أو قال بفضة، فلا يجوز العقد إلا ببيان القدر كالخمس والعشرة والوصف كالبخاري والسمرقندي ؛ لأنه إذا لم يبين القدر والصفة يفضى إلى المنازعة المانعة من التسليم والتسلم ، فلا يحصل المقصود من العقد ، فيبطل العقد وهذا ؛ لأن وضع الأسباب لقطع المنازعات .

العناية شرح الهداية ٦ / ٢٤٢ ، البناءة في شرح الهداية ٧ / ٢٩

(٤) أي كل جهالة مفضية إلى المنازعة؛ تمنع جواز العقد .

البناءة في شرح الهداية ٧ / ٢٩ .

(٥) سورة البقرة : من الآية (٢٧٥) .

(٦) يهودي : اسمه : أبو الشحم رجل من بنى ظفر في شعير .

أخرجه : أحمد بن حجر العسقلاني في فتح الباري شرح صحيح البخاري (٥ / ١٤٠) ، وسنن البيهقي

(٦ / ٣٧) ، والبناءة في شرح الهداية ٧ / ٣١ .

وَرَهْنَهُ(١)، وَلَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ الْأَجَلُ مَعْلُومًا (٢)؛ لِأَنَّ الْجَهَالََةَ فِيهِ مَانِعَةٌ مِنَ التَّسْلِيمِ الْوَاجِبِ بِالْعَقْدِ، فَهَذَا يُطَالِبُهُ (٣) بِهِ فِي قَرِيبِ الْمُدَّةِ، وَهَذَا يُسَلِّمُهُ فِي بَعِيدِهَا (٤)(٥) .

(العلم بنوع النقود وصفتها)

قَالَ: وَمَنْ أَطْلَقَ الثَّمَنَ فِي الْبَيْعِ (٦) كَانَ عَلَى غَالِبِ نَقْدِ الْبَلَدِ (٧)؛ لِأَنَّهُ الْمُتَعَارَفُ، وَفِيهِ التَّحَرِّيُ لِلْجَوَازِ فَيُصَرَّفُ إِلَيْهِ فَإِنْ كَانَتْ النُّقُودُ مُخْتَلِفَةً فَالْبَيْعُ فَاسِدٌ إِلَّا أَنْ يُبَيِّنَ أَحَدُهُمَا (٨) وَهَذَا إِذَا كَانَ الْكُلُّ فِي الرَّوَاجِ سَوَاءً (٩)؛ لِأَنَّ الْجَهَالََةَ مُفْضِيَةٌ إِلَى الْمُنَازَعَةِ إِلَّا أَنْ تَرْتَفِعَ الْجَهَالََةُ بِالْبَيَانِ أَوْ

(١) أخرجه البخاري في صحيحه (٢ / ٧٢٩ . ٨٤١) كتاب البيوع - باب شراء النبي - ﷺ - بالنسيئة ، حديث رقم ١٩٦٢ ، ٢٢٥٦ ، ومسلم في صحيحه (٣ / ١٢٢٦) كتاب المساقاة - باب الرهن وجوازه في الحضر والسفر ، حديث رقم ١٦٠٣ . كلهم من حديث عائشة .

(٢) وأما كون الأجل معلوماً ؛ فلما روى في الصحيح والسنن مسنداً إلى ابن عباس رضى الله عنهما قال: (قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون في التمر السنتين والثلاث ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أسلف في

تمر فليسلف في كيل معلوم ، ووزن معلوم إلى أجل معلوم .

أخرجه مسلم في صحيحه (٣ / ١٢٢٦) كتاب المساقاة - باب السلم ، حديث رقم ١٦٠٤

(٣) أي: البائع يطالب المشتري ، أي المشتري في بعيدها : أي في بعيد المدة .

(٤) البناءية في شرح الهداية ٧ / ٣١ .

(٥) والمعنى فيه أن الأجل إذا كان مجهولاً يفضى إلى المنازعة المانعة من التسليم الذى أوجبه العقد ؛ لأن البائع يطالب المشتري بتسليم الثمن في مدة قريبة ، والمشتري يريد تسليمه في مدة بعيدة ؛ فتقع المنازعة لا محالة ، ووضع الأسباب لرفع المنازعة ، فإذا أدى العقد إلى المنازعة بسبب الجهالة ، كان فاسداً ؛ لقراءة العقد عن المقصود .

العناية شرح الهداية ٦ / ٢٤٣ ، البناءية في شرح الهداية ٧ / ٣١ .

(٦) بأن ذكر القدر دون الصفة .

(٧) نقد البلد : أي البلد الذى جرى فيه البيع لا في بلد المتبايعين ، وفيه التحري للجواز : أي وفى غالب نقد البلد التحري لجواز العقد .

البناءية في شرح الهداية ٧ / ٣٢ ، البحر الرائق شرح كنز الدقائق ٥ / ٣٠٣ .

(٨) يعنى إذا بين أحد النقود في المجلس انقلب العقد جائزاً بعد فساد .

البناءية في شرح الهداية ٧ / ٣٢ .

(٩) لأن الجهالة مقضية إلى المنازعة ؛ لأنه لا يمكن ترجيح بعضها على بعض لإطلاق التسمية .

يَكُونُ أَحَدُهُمَا أَغْلَبَ وَأَرْوَجَ (١) فَحَيْثُ يُصْرَفُ إِلَيْهِ تَحَرِّيًّا لِلْجَوَازِ (٢)، وَهَذَا إِذَا كَانَتْ مُخْتَلِفَةً فِي الْمَالِيَّةِ (٣) فَإِنْ كَانَتْ سَوَاءً فِيهَا كَالثَّنَائِي (٤) وَالثَّلَاثِي (٥) وَالنُّصْرَتِي الْيَوْمَ بِسَمَرْقَنْدَ. وَالْاِخْتِلَافُ بَيْنَ الْعَدَالِي بِفَرَاغَانَهُ (٦) جَازَ الْبَيْعُ إِذَا أُطْلِقَ اسْمُ الدَّرْهِمِ، كَذَا قَالُوا (٧)، وَيَنْصَرَفُ إِلَى مَا قَدَّرَ بِهِ مِنْ أَيْ نَوْعٍ كَانَ؛ لِأَنَّهُ لَا مُتَارَعَةَ وَلَا اخْتِلَافَ فِي الْمَالِيَّةِ ، قَالَ : وَيَجُوزُ بَيْعُ الطَّعَامِ وَالْحُبُوبِ مُكَايَلَةً وَمُجَازَفَةً (٨)،

المرجع السابق .

(١) الرواج : يقال راج المتاع يروج رواجاً من باب قال والاسم "الرواج" نفق وكثر طلابه ، وراجت الدارهم رواجاً تعامل الناس بها ورجتها ترويجاً جوزتها ، وروج فلان كلامه زينه وأبهمه فلا تعلم حقيقته .

المصباح المنير ١ / ٢٤٢ ، مختار الصحاح ص : ١١٠ .

(٢) أي فساد البيع في اختلاف النقود، إذا كانت مستوية الرواج ، فإذا كان أحدهما أروج جاز البيع العناية شرح على الهداية ٦ / ٢٤٥ ، البناية في شرح الهداية ٧ / ٣٣ .

(٣) أي: فساد العقد في النقود المستوية الرواج، فيما إذا كانت تلك النقود تختلف ماليتها ، فإذا استوت في المالية فلا فساد ، لعدم تفضيل بعضها على بعض وإن كان هناك تفاوت مع أنواعها . العناية شرح الهداية ٦ / ٢٤٥ ، مجمع الأنهر ٢ / ٩ .

(٤) أي: في المالية . البناية في شرح الهداية ٧ / ٣٣ .

(٥) الثنائي والثلاثي : هي أسماء دراهم كانت ببلادهم مختلفة المالية ، وكذا الركياني ، والخليفتي في الذهب ، كان الخليفتي أفضل مالية عندهم ، والعدلي اسم لدراهم . شرح فتح القدير ٦ / ٢٤٤ .

وحاصله: أن الثنائي قطعتان من فضة إما بدانق أو بدرهم، والثلاثي: ثلاث قطع منها إما بدانق أو بدرهم . البحر الرائق شرح كنز الدقائق ٥ / ٣٠٤ .

(٦) وهي لغة فقهاء ما وراء النهر ، يسمون الدرهم عدلياً ، وقد استعملوه في كتبهم البناية في شرح الهداية ٧ / ٣٤ .

(٧) أي : قال المتأخرون من المشايخ .

العناية في شرح الهداية ٦ / ٢٤٥ ، البناية في شرح الهداية ٧ / ٣٤ .

(٨) الجزاف في البيع والشراء ، وهو الحدس بلا كيل ولا وزن. والمراد من جواز البيع مجازفة : إذا باع بخلاف الجنس . والمكايلة : : معاملة الشخص الشخص بالكيل المعزب في ترتيب المعرب ١ / ١٤٥ ، ١٤٦ ، البناية في شرح الهداية ٧ / ٣٤ .

وَهَذَا إِذَا بَاعَهُ بِخِلَافِ جِنْسِهِ (١) لِقَوْلِهِ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: (إِذَا اخْتَلَفَ النُّوعَانِ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ بَعْدَ أَنْ يَكُونَ يَدًا بِيَدٍ) (٢)، بِخِلَافِ مَا إِذَا بَاعَهُ بِجِنْسِهِ مُجَازَفَةً لِمَا فِيهِ مِنْ اِحْتِمَالِ الرِّبَا، وَلِأَنَّ الْجَهَالََةَ غَيْرُ مَانِعَةٍ مِنَ التَّسْلِيمِ وَالتَّسَلُّمِ فَشَابَهُ جَهَالَةُ الْقِيَمَةِ (٣).
(العلم بآلة الكيل والوزن)

قَالَ: وَيَجُوزُ بِإِنَاءٍ بَعَيْنِهِ لَا يُعْرَفُ مِقْدَارُهُ وَبِوَزْنٍ حَجَرٍ بَعَيْنِهِ لَا يُعْرَفُ مِقْدَارُهُ ؛ لِأَنَّ الْجَهَالََةَ لَا تُفْضِي إِلَى الْمُنَازَعَةِ لِمَا أَنَّهُ يَتَعَجَّلُ فِيهِ التَّسْلِيمُ فَيُنْذِرُ هَلَاكَهُ (٤) قَبْلَهُ بِخِلَافِ السَّلَمِ (٥)؛ لِأَنَّ

-
- (١) المراد من جواز البيع مجازفة : إذا باع بخلاف الجنس .
(٢) أخرجه مالك في الموطأ رواية ومحمد بن الحسن بدون لفظ " بعد أن يكون يدًا بيد " (١٦٢/٣)، كتاب البيوع في التجارات والسلم - باب ما يكره من بيع التمر بالرطب، حديث رقم ٧٦٤، وأبو بكر عبد الله بن محمد بن أبي شيبة في مصنفه بلفظ " إذا اختلف النوعان في كيف شئت " ، تحقيق . كمال يوسف الحوت (٤ / ٣٢٠) كتاب البيوع - باب في الحنطة بالشعير اثنتين ، حديث رقم ٢٠٥٩٩ . ط . مكتبة الرشد بالرياض ، الطبعة الأولى سنة ١٤٠٩ هـ .
درجة الحديث : هذا الحديث غريب جداً ؛ لأنه دائر على زيد بن عياش ، وزيد بن عياش مجهول وهو ممن لا يقبل حديثه، واستحسن أهل الحديث هذا الطعن .
نصب الرأية في تخريج أحاديث الهداية ٥٠/٤ - ٥١ .
(٣) أي : شابه جهالة المجازفة جهالة القيمة ، ولأن الجهالة لا تفضي إلى المنازعة ؛ فلا تمنع التسليم كجهالة القيمة مثل ما إذا اشترى شيئاً مجهول القيمة بثمن معلوم ، ولا يدرى أن القيمة أزيد من الثمن أو أنقص منه ولا يعتبر بتلك الجهالة ؛ لأنها ليست مانعة من التسليم ، أما إذا باع الطعام جنساً بجنس مجازفة ، فلا يجوز لاحتمال الربا ؛ لأن علة ربا الفضل القدر والجنس وهي موجودة ، فإذا باع الطعام جنساً بجنس فيما لا يدخل تحت القدر وهو الكيل مثلاً بالمجازفة جاز كبيع الحفنة بالحفنة، فإنه جاز عندنا لعدم القدر .
البنية في شرح الهداية ٧ / ٣٥ ، شرح فتح القدير ٦ / ٢٤٥ .
(٤) أي: هلاك الإناء والحجر قبل التسليم . البنية في شرح الهداية ٧ / ٣٦ .
(٥) السلم في اللغة : السلف . أنيس الفقهاء : ٢١٨ .
واصطلاحاً : اسم لعقد يوجب الملك في الثمن عاجلاً وفي المثلن آجلاً .
الاختيار لتعليل المختار ٢ / ٣٥ .

التَّسْلِيمِ فِيهِ مُتَأَخَّرٌ وَالْهَلَاكُ لَيْسَ بِنَادِرٍ قَبْلَهُ فَتَحَقَّقُ الْمُنَازَعَةُ (١) ، وَعَنْ أَبِي حَنِيفَةَ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ فِي
الْبَيْعِ أَيْضاً (٢) ، وَالْأَوَّلُ أَصَحُّ وَأَظْهَرُ (٣) .

(١) اعلم أن السلم لا يجوز إلا بمكيال معروف القدر، فإذا اشترط بمكيال غير معروف أو بإناء لا يعرف قدره لا يجوز ، ويبيع العين بمكيال لا يعرف قدره جائز ، كما إذا اشترى قفيزاً من صبرة بإناء لا يعرف قدره يداً بيد ، والفرق أن التسليم في بيع العين واجب الحال فيحصل ذلك غالباً لقيام الملك واليد فلا يمتنع جواز البيع لعجز موهوم بهلاك الإناء ؛ لأنه نادر فلا يعتد به ، فلو اعتبر العجز الموهوم لم يجز عقد أصلاً ، والتسليم في السلم ليس بواجب في الحال ، بل هو مؤجل إلى مدة ، والهلاك قبل زمان التسليم ليس بنادر ، فإذا لم يعرف مقدار الإناء أو الحجر فهلك ، يفضى إلى المنازعة ، وهو خلاف وضع الأسباب ، فلهذا اشترط في السلم أن يكون المسلم فيه معلوم الكيل أو الوزن ، حتى تكون القدرة على التسليم ثابتة حكماً ؛ فترتفع المنازعة
المبسوط للسرخسي ١٢ / ١٤١ ، العناية شرح الهداية ٦ / ٢٤٦ .

وزاد الإمام الكاساني : علة أخرى وهي : أن القدرة على تسليم المبيع شرط انعقاد العقد وصحته ، والقدرة على التسليم عند العقد فائتة في باب السلم ؛ لأن السلم بيع المفاليس ، وفي ثبوت القدرة عند محل الأجل شك قد تثبت ، وقد لا تثبت ؛ لأنه إن بقي المكيال والحجر والخشبة ثبت ، وإن لم يبق لا يقدر ، فوقع الشك في ثبوت القدرة ؛ فلا تثبت بالشك على الأصل المعهود في غير الثابت بيقين إذا وقع الشك في ثبوته أنه لا يثبت ، بخلاف بيع العين ؛ لأن هناك القدرة على التسليم ثابتة عند العقد ، وفي فواتها بالهلاك شك فلا تقوت بالشك على الأصل المعهود في الثابت بيقين إذا وقع الشك في زواله أنه يزول الشك . بدائع الصنائع ٥ / ٣٠٨ .

(٢) وعلل الإمام البابر تي لذلك بقوله : إن البيع أيضاً لا يجوز كالسلم ؛ لأن البيع في المكيلات والموزونات إما أن يكون مجازفة ، أو يذكر القدر ، ففي المجازفة المعقود عليه هو ما يشار إليه ، ولا معتبر بالمعيار ، وفي غيرها المعقود عليه هو ما يسمى من القدر ولم يوجد شيء ، فإن الغرض عدم المجازفة ، والمكيال إذا لم يكن معلوماً لم يسم شيء من القدر . العناية شرح الهداية ٦ / ٢٤٧

(٣) الأول : أصح من حيث الدليل ، وأظهر : من حيث الرواية والتعليل ، أراد به ما ذكره القدوري بقوله : ويجوز بإناء بعينه لا يعرف مقداره (البنية في شرح الهداية ٣٨/٧).

قَالَ: وَمَنْ بَاعَ صُبْرَةً (١) طَعَامٍ كُلُّ قَفِيزٍ (٢) بِدِرْهَمٍ (٣) جَازَ الْبَيْعُ فِي قَفِيزٍ وَاحِدٍ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ؛ إِلَّا أَنْ يُسَمِّيَ جُمْلَةً قُفْزَانَهَا وَقَالَ (٤) وَقَالَ لَا يَجُوزُ فِي الْوَجْهَيْنِ، لَهُ أَنَّهُ تَعَذَّرَ الصَّرْفُ (٥) إِلَى الْكُلِّ لِجَهَالَةِ الْمَبِيعِ وَالْثَمَنِ فَيُصْرَفُ إِلَى الْأَقَلِّ وَهُوَ مَعْلُومٌ، وَإِلَّا أَنْ تَزُولَ الْجَهَالَةُ بِتَسْمِيَةِ جَمِيعِ الْقُفْزَانِ أَوْ بِالْكَيْلِ فِي الْمَجْلِسِ (٦) وَصَارَ هَذَا كَمَا لَوْ قَالَ لِفُلَانٍ عَلَيَّ كُلُّ دِرْهَمٍ فَعَلَيْهِ دِرْهَمٌ وَاحِدٌ بِالْإِجْمَاعِ.

(١) الصبرة : ما جمع من الطعام بلا كيل ولا وزن بعضه فوق بعض .

لسان العرب ٤ / ٤٤١ ، مختار الصحاح ص : ١٤٩ .

(٢) القفيز : من المكاييل معروف وهو ثمانية مكاييك عند أهل العراق وهو من الأرض قدر مائة وأربع ذراعاً وقيل: هو مكيال تتواضع الناس عليه .

لسان العرب ٥ / ٣٩٦ ، ومختار الصحاح : ٢٢٨ .

القفيز = ١٢ صاعاً = ثمانية مكاييك والمكوك = صاع ونصف ويساوي القفيز بالكيلو جرام . ويساوي القفيز باللتر - عند الجمهور = ١٢×٢١٧٢ كيلو جرام = ٢٦٠٠٦٤ كيلو جرام ، عند أبي حنيفة ومحمد = ١٢×٣٢٠٩٧٦ لتراً عند أبي حنيفة ومحمد = ٣٠٣٦٢×١٢ = ٣٠٣٦٢٤ لتراً . معجم الفقهاء : ٣٦٨ .

(٣) الدرهم : اسم للمضروب من الفضة ، وهو مُعَرَّبٌ وزنه ، فِغْلٌ بكسر الفاء والدرهم ستة دوانق = ٤٨ حبة = ٢٠٩٧٩ غراماً والدرهم التي توزن بها الأشياء مقدارها ٥١ حبة = ٣٠١٧١ غراماً .

المصباح المنير ١/ ١٩٣ ، ١٩٤ ، معجم لغة الفقهاء لمحمد قلجعي : ٢٠٨ . ط. دار النفائس . الدرهم العراقي (٣٠١٧) غم ، الدرهم الحالي المصري (٣٠١٢) غم ، والدرهم العربي (٢٠٩٧٥) غم . الفقه الإسلامي وأدلته أ.د/ وهبة الزحيلي ١/ ١٤٣ . ط. دار الفكر، الطبعة الثانية ١٤٢٥هـ- ٢٠٠٥م

(٤) وعندهما يجوز في جميع القفزان سواء سمي جملة القفزان أو لم يسم الجوهرة النيرة شرح مختصر القدوري ١/ ٤٣٦ ، الاختيار لتعليل المختار ٢ / ٥ .

(٥) أي: صرف المبيع لجهالة الثمن والمبيع جهالة تقضى إلى المنازعة ؛ لأن جملة القفزان غير معلوم ، فيكون ما بإزائهما غير معلوم أيضاً ؛ لأن البائع يطالب من المشتري الثمن أولاً ، والثمن غير معلوم . البناية في شرح الهداية ٧ / ٣٩ .

(٦) أنه إذا كال في المجلس جاز بالاتفاق، لزوال المانع قبل تقرر الفساد.

وَلَهُمَا (١) أَنَّ الْجَهَالََةَ بِيَدِهِمَا (٢) بِيَدِهِمَا إِزَالَتُهَا (٣) وَمِثْلُهَا غَيْرُ مَانِعٍ (٤) ، وَكَمَا إِذَا بَاعَ عَبْدًا مِنْ عَبْدَيْنِ عَلَى أَنَّ الْمُشْتَرِيَ بِالْخِيَارِ (٥) ثُمَّ إِذَا جَازَ فِي قَفِيزٍ وَاحِدٍ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ فَلِلْمُشْتَرِي الْخِيَارُ لِتَفَرُّقِ الصَّفَقَةِ عَلَيْهِ (٦) ، وَكَذَا إِذَا كِيلَ فِي الْمَجْلِسِ (٧) أَوْ سَمِيَ جُمْلَةً فُقُزَانِهَا؛ لِأَنَّهُ عَلِمَ ذَلِكَ الْآنَ فَلَهُ الْخِيَارُ، كَمَا إِذَا رَأَهُ وَلَمْ يَكُنْ رَأَهُ وَقَتَ الْبَيْعِ ، قَالَ: وَمَنْ بَاعَ قَطِيعَ غَنَمٍ (٨) كُلُّ شَاةٍ

قيد بالمجلس ؛ لأن ساعات المجلس تعتبر ساعة واحدة دفعاً للعسر ، فإذا حصل العلم بعد العقد في المجلس ، يجعل ذلك كالعلم حالة العقد ، بخلاف العلم بعد الافتراق حيث لا ينقلب العقد جائزاً لتقرر الفساد ؛ للجهالة . تبين الحقائق شرح كنز الدقائق ٤ / ٦ .

(١) أي قول أبو يوسف ومحمد .

(٢) المراد بالجهالة: جهالة الثمن بالنسبة للمشتري بعد الكيل وتفرق الصفقة على البائع قبل الكيل (٣) قوله بيدهما إزالتها : فإنها ترتفع بكيل كل منهما ، فإن قدر المبيع كما يعلم بكيل البائع ، فذلك يعلم بكيل المشتري ، فكان إزالة الجهالة بيدهما ، وقيد بقوله : "بيدهما" احترازاً عن البيع بالرقم ، فإنه لا يجوز ؛ لأن إزالتها إما بيد البائع إن كان هو الراقم ، أو بيد الغير إن كان الراقم غيره ، وعلى كل حال فالمشتري لا يقدر على إزالته.

العناية شرح الهداية ٦/٢٤٨، ٢٤٩ ، البناء في شرح الهداية ٧/٤٠ .

(٤) أي ومثل هذه الجهالة التي بيد العاقدین إزالتها ، غير مانعة من جواز البيع.

(٥) إن شاء أخذ هذا ، وإن شاء أخذ ذلك ، فإذا أخذ أيهما شاء ارتفعت الجهالة ، فكذا هنا.

البناء في شرح الهداية ٧ / ٤٠ .

(٦) وجه قول أبي حنيفة : إن القدر المسمى من القفيز أو القفيزين أو الثلاثة معلوم القدر معلوم الثمن، فجاز البيع فيه، وما زاد على ذلك مجهول القدر مجهول الثمن ؛ لأن الثمن بعدد القفزان وعددها مجهول؛ فكان الثمن مجهولاً؛ وجهالة الثمن مفسدة للعقد كبيع الشيء برقمه، لكن لما لم تكن الجهالة لازمة قلنا بثبوت الخيار بعد العلم . مخطوط بدار الكتب ، حاشية الطحاوي على الدر المختار ٣ / ١٨

(٧) أي المشتري بالخيار، ولكن لا لتفرق الصفقة؛ بل لأنه لم يكن راضياً بجملته الثمن .

البناء في شرح الهداية ٧ / ٤٠ .

(٨) القطيع : الطائفة من الغنم والنعم ونحوه ، والغالب عليه أنه من عشر إلى أربعين ، وقيل : ما بين

خمس وعشرين والجمع أقطاع .

لسان العرب ١ / ٢٨١ ، مختار الصحاح : ٢٢٧ .

بِدِرْهِمٍ فَسَدَ الْبَيْعُ فِي جَمِيعِهَا (١)، عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ (٢) رَحِمَهُ اللَّهُ ، وَكَذَلِكَ مَنْ بَاعَ ثَوْبًا مُذَارَعَةً ، كُلُّ ذِرَاعٍ (٣) بِدِرْهِمٍ وَلَمْ يُسَمَّ جُمْلَةَ الذَّرَاعَانِ ، وَكَانَ كُلُّ مَعْدُودٍ مُتَّفَاوِتٍ (٤) ، وَعِنْدَهُمَا يَجُوزُ فِي الْكُلِّ لِمَا قُلْنَا (٥) ، وَعِنْدَهُ يَنْصَرِفُ إِلَى الْوَاحِدِ لِمَا بَيَّنَّا غَيْرَ أَنَّ بَيْعَ شَاةٍ مِنْ قَطِيعٍ غَنَمٍ وَذِرَاعٍ مِنْ ثَوْبٍ لَا يَجُوزُ لِلتَّفَاوُتِ ، وَيَبْعُ قَفِيزٍ مِنْ صَبْرَةٍ يَجُوزُ لِعَدَمِ التَّفَاوُتِ (٦) ، فَلَا تُفْضِي الْجَهَالَةُ إِلَى

(١) أي فسد البيع عند أبي حنيفة لوجهين :

أحدهما : أن الذراع من الثوب يختلف والثاني : أنه لا يمكن تسليمه إلا بضرر على البائع
الجوهرة النيرة شرح مختصر القدوري ١ / ٤٣٧ .

(٢) أي : الخلاف بين أبي حنيفة والصاحبين حيث إن البيع فاسد في الجميع عند أبي حنيفة ؛ لأن التفاوت بين الشاة موجودة ، وفي ذلك جهالة تفضي إلى المنازعة ، وأما عندهما ، يجوز في الكل ، لما قلنا من أن الجهالة بيدهما إزالتها . العناية شرح الهداية ٦ / ٢٥٠ ، ٢٥١ .

(٣) الذراع : بكسر ما بين المرفق إلى طرف الإصبع الوسطى والساعد وقد تذكر فيها والجمع أذرع. لسان العرب ٨ / ٩٣ ، المصباح المنير ١ / ٢٠٧ ، شرح فتح القدير ٦ / ٢٥٤ .

(٤) كالخشب والأواني ونحوهما ، أي متفاوت في القيمة ، ولم يسم جملة العدد

وهذه المسألة على ثلاثة أوجه :

أحدها : أن يبين جملة الذرعان ، وقال بعده : كل ذراع بدرهم ، ولم يبين جملة الثمن فهو جائز ؛ لأن المبيع معلوم وجملة الثمن معلومة لبيان الذرعان .

ثانيها : أن يبين جملة الثمن لا المبيع وقال بعده : كل ذراع بدرهم فهو أيضاً جائز ؛ لأنه لما بين جملة الثمن وسمى لكل ذراع درهما صار جميع الذرعان معلوماً .

ثالثها : أن لا يبين جملة المبيع ولا جملة الثمن وقال بعده : كل ذراع بدرهم فهي مسألة الكتاب .
البنية في شرح الهداية ٧ / ٤٢ .

(٥) (لما قلنا) إشارة إلى قوله: (فيصرف إلى الأقل) لكن الأقل هو الشاة الواحدة ، أو الذراع من ثوب لم يصرف إليه ؛ للتفاوت ، والقفيز الواحد من صبرة يصرف إليه ؛ لعدم التفاوت فظهر الفرق .
البنية في شرح الهداية ٧ / ٥١ .

(٢) وأصل ذلك : أن جملة الثمن إذا لم تكن معلومة يبطل البيع عنده ؛ كبيع كل شاة من هذا القطيع بكذا ، وعندهما هو جائز ؛ لأن طريق المعرفة قائم من غير أن ينفرد به أحد العاقلين ، وقيام طريق المعرفة بقيام المعرفة .

الْمُنَازَعَةِ فِيهِ، وَتَقْضِي إِلَيْهَا فِي الْأَوَّلِ (١) فَوَضَحَ الْفَرْقُ، قَالَ: وَمَنْ ابْتِاعَ صُبْرَةً طَعَامٍ عَلَى أَنَّهَا مِائَةٌ قَفِيزٍ بِمِائَةِ دِرْهَمٍ فَوَجَدَهَا أَقَلَّ (٢) كَانَ الْمُشْتَرِي بِالْخِيَارِ إِنْ شَاءَ أَخَذَ الْمَوْجُودَ بِحِصَّتِهِ مِنَ الثَّمَنِ، وَإِنْ شَاءَ فَسَخَّ الْبَيْعَ لِيَتَفَرَّقَ الصَّفْقَةُ عَلَيْهِ قَبْلَ التَّمَامِ، فَلَمْ يَتِمَّ رِضَاهُ بِالْمَوْجُودِ، وَإِنْ وَجَدَهَا أَكْثَرَ فَالزِّيَادَةُ لِلْبَائِعِ؛ لِأَنَّ الْبَيْعَ وَقَعَ عَلَى مِقْدَارٍ مُعَيَّنٍ (٣) وَالْقَدْرُ لَيْسَ بِوَصْفٍ (٤)، وَمَنْ اشْتَرَى ثَوْبًا عَلَى أَنَّهُ عَشْرَةُ أذْرُعٍ (٥) بِعَشْرَةِ دَرَاهِمٍ أَوْ أَرْضًا عَلَى أَنَّهَا مِائَةُ ذِرَاعٍ بِمِائَةِ دِرْهَمٍ فَوَجَدَهَا أَقَلَّ فَالْمُشْتَرِي

ولأبي حنيفة أن الثمن مجهول حقيقة ؛ ففسد البيع به كما إذا باع الشيء برقمه ، ولا يقال: أن ثمن الواحد معلوم؛ لأننا نقول: كل المبيع مجهول ؛ لأنه لا يعلم حال العقد ما مبلغ الشاة ، وما مبلغ الذرعان ، وكل واحد أيضاً مجهول للتفاوت ؛ فلا يمكن الصرف إلى الواحد ، بخلاف القفيز الواحد في بيع كل قفيز من هذه الصبرة بكذا ، فإن البيع ينصرف إليه لتيقنه؛ لعدم تفاوته. تبين الحقائق شرح كنز الدقائق ٧/٤، البناية في شرح الهداية ٧ / ٤٢ ، ٤٣ .
(١) أي: وتقضي الجهالة إلى المنازعة في بيع شاة من قطيع ، وذراع من ثوب إذا صرف العقد إلى الشاة الواحدة أو الذراع الواحد البناية شرح الهداية ٧ / ٤٢ - ٤٣ .

(٢) أي وجد الصبرة أقل من مائة قفيز .

(٣) وهي مائة قفيز

(٤) اعلم أن المبيع إذا كان كميلاً يتعلق العقد بما سمي من الكيل مثل : أن قال : بعت هذه الصبرة على أنها مائة قفيز بمائة درهم ، ولا يتفاوت الحكم من بين أن يسمى لكل قفيز ثمنًا، بأن قال: كل قفيز بكذا، أو لم يسم ، فإذا وجد المسمى كما قدر ، فهو للمشتري بلا خيار ، فإن وجد زائداً ، فالزيادة للبائع؛ لأنها لم تدخل تحت العقد ؛ لأن العقد وقع على مائة قفيز ، فالزيادة ليست من المائة ، وإن وجد ناقصاً كان للمشتري الخيار؛ لتفرق الصفقة ؛ لأن العقد وقع على جملة معلومة ، فإذا نقصت يلزم تفريق الصفقة لا محالة ، فله الخيار من الأخذ والترك ، فإن أراد الأخذ ، أخذ الموجود بحصته من الثمن وطرح حصة النقصان ؛ لأن الففزان لما كانت معقوداً عليها انقسم الثمن عليها.

تبين الحقائق شرح كنز الدقائق ٦/٤، رد المحتار على الدر المختار ٥٤٢/٤ .

(٥) اعلم أن الذريعات يختلف الجواب فيها بين أن سمي لكل ذراع ثمنًا ؛ بأن قال كل ذراع بكذا ، وبين أن لم يسم ، أما إذا لم يسم فقال : بعت هذا الكرياس على أنه عشرة أذرع بعشرة دراهم فوجده زائداً فهي للمشتري ، ولا خيار للبائع ، وإن وجده ناقصاً ، كان للمشتري الخيار ، إن شاء أخذ الموجود بجميع الثمن ، وإن شاء ترك ؛ وهذا لأن الذرع في الأعيان المذروعة جارية مجرى الصفة ، لكنها تحتمل أن تكون مقصودة بالذكر، والدليل على أنها جارية مجرى الصفة أن وجودها يزيد في قدر

بِالْخِيَارِ، إِنْ شَاءَ أَخَذَهَا بِجُمْلَةِ الثَّمَنِ، وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ ؛ لِأَنَّ الذَّرَاعَ وَصَفَ (١) فِي الثُّوبِ؛ أَلَا تَرَى أَنَّهُ عِبَارَةٌ عَنِ الطُّوْلِ وَالْعَرْضِ، وَالْوُصْفُ لَا يُقَابَلُهُ شَيْءٌ مِنَ الثَّمَنِ (٢) كَأَطْرَافِ الْحَيَوَانِ (٣) فَلِهَذَا يَأْخُذُهُ بِكُلِّ الثَّمَنِ ، بِخِلَافِ الْفَصْلِ الْأَوَّلِ؛ لِأَنَّ الْمِقْدَارَ يُقَابَلُهُ الثَّمَنُ فَلِهَذَا يَأْخُذُهُ بِحَصَّتِهِ، إِلَّا أَنَّهُ يَتَخَيَّرُ لِفَوَاتِ الْوُصْفِ الْمَذْكُورِ (٤) لِتَغْيِيرِ الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ فَيَخْتَلُّ الرِّضَا. قَالَ (وَإِنْ وَجَدَهَا أَكْثَرَ مِنَ الذَّرَاعِ الَّذِي سَمَّاهُ فَهُوَ لِلْمُشْتَرِي وَلَا خِيَارَ لِلْبَائِعِ) ؛ (٥) لِأَنَّهُ صِفَةٌ، فَكَانَ بِمَنْزِلَةِ مَا إِذَا بَاعَهُ مَعِيًّا، فَإِذَا هُوَ سَلِيمٌ (٦)،

الأصل وفي قيمته كسائر الصفات ؛ لفوات الوصف المرغوب ، فإن أراد الأخذ أخذ بجميع الثمن؛ لأن الوصف لا يقابله شيء من الثمن ،وأما إذا سمي لكل ذراع ثمناً ، فقال : بعت هذا الكرّاس بعشرة على أنها عشرة كل ذراع بدرهم ، فإن وجده ناقصاً كان للمشتري الخيار ؛ لفوات الوصف المرغوب فيه ، إن شاء أخذ الجميع كل ذراع بدرهم ، وإن شاء فسخ البيع . تبين الحقائق شرح كنز الدقائق ٤ / ٦ .

(١) المراد بالوصف : ما لوجود تأثيره في تقوم غيره وبعده تأثير في نقصان غيره .
(٢) إلا إذا كان مقصوداً بالتناول حقيقة ، كما إذا قطع البائع يد العبد المبيع قبل القبض يسقط نصف الثمن، أو حكماً لحق البائع ، كما إذا حدث عيب آخر عند المشتري ، أو لحق الشارع كما إذا خاط المشتري الثوب المبيع ثم اطلع على عيب يكون للوصف قسط من الثمن. العناية شرح الهداية ٦ / ٢٥٣ ، البناء في شرح الهداية ٧ / ٤٥ .

(٣) يعنى إذا اشترى جارية فاعورت عند البائع لا ينقص شيء من الثمن ، وكذا المشتري يبيعها مرابحة إذا اعورت بعد ما قبضها بدون البيان

(٤) كما إذا اشتراه على أنه كاتب فوجده لا يحسن الكتابة .
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع للكاساني ٢٣٨/٥ ، ٢٣٩ .

(٥) لأنه وصف تابع للمبيع لا يقابله شيء من الثمن ، فصار كما إذا باعه معيياً فوجده سليماً ، فالبائع لا يخير بل يجبر على التسليم ، كما إذا باع عبداً على أنه أعمى فإذا هو بصير .

العناية شرح الهداية ٦ / ٢٥٢ ، الجوهرة النيرة شرح مختصر القدوري ١ / ٤٣٨ ، درر الحكام شرح غرر الأحكام ٢ / ١٤٨ .

(٦) كما إذا باع عبداً على أنه أعمى فوجده المشتري بصيراً ، حيث لا خيار بدائع الصنائع للكاساني ٥ / ٢٣٩ ، تبين الحقائق شرح كنز الدقائق ٤ / ٧ .

لَوْ قَالَ بَعْتُكَهَا عَلَى أَنَّهَا مِائَةُ ذِرَاعٍ بِمِائَةِ دِرْهَمٍ (١)، كُلُّ ذِرَاعٍ بِدِرْهَمٍ فَوَجَدَهَا نَاقِصَةً،
فَالْمُشْتَرِي بِالْخِيَارِ إِنْ شَاءَ أَخَذَهَا بِحَصَّتِهَا مِنَ الثَّمَنِ، وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ؛ لِأَنَّ الْوُصْفَ وَإِنْ كَانَ تَابِعًا
لِكُنْهِ صَارَ أَصْلًا بِإِفْرَادِهِ ذَكَرَ الثَّمَنِ فَيَنْزِلُ كُلُّ ذِرَاعٍ مَنْزِلَةَ ثَوْبٍ (٢)؛ وَهَذَا لِأَنَّهُ لَوْ أَخَذَهُ بِكُلِّ الثَّمَنِ لَمْ
يَكُنْ آخِذًا لِكُلِّ ذِرَاعٍ بِدِرْهَمٍ، وَإِنْ وَجَدَهَا زَائِدَةً فَهُوَ بِالْخِيَارِ إِنْ شَاءَ أَخَذَ الْجَمِيعَ كُلُّ ذِرَاعٍ
بِدِرْهَمٍ (٣)، وَإِنْ شَاءَ فَسَخَّ الْبَيْعَ (٤) لِأَنَّهُ إِنْ حَصَلَ لَهُ الزِّيَادَةُ فِي الذَّرْعِ تَلَزَمَتْهُ زِيَادَةُ الثَّمَنِ فَكَانَ نَفْعًا
يَشُوْبُهُ ضَرَرٌ (٥) فَيَتَخَيَّرُ، وَإِنَّمَا يَلْزَمُهُ الزِّيَادَةُ لِمَا بَيَّنَّا (٦) أَنَّهُ صَارَ أَصْلًا، وَلَوْ أَخَذَهُ بِالْأَقْلَ لَمْ يَكُنْ
آخِذًا بِالْمَشْرُوطِ (٧).

(١) أي : بعت الثياب أو بعت الأرض . العناية شرح الهداية ٧ / ٤٦ .
(٢) بيانه أنها بالإفراد بالذکر صارت أصلاً معقوداً عليه ، لكنها وصف حقيقة ، فباعتبار أنها أصل ،
دخل الزيادة في العقد وصار بإزائها ثمن ، ومن حيث أنها وصف كان المشتري - بالنقصان ؛ لفوات
الوصف المرغوب فيه - الخيار . بدائع الصنائع ٥ / ٢٣٩ .
(٣) لأن الوصف وإن كان تابعاً ، لكنه صار أصلاً بإفراده بذكر الثمن ، فنزل كل ذراع منزلة ثوب وهذا
معنى قولهم: إن الوصف يقابله شيء من الثمن إذا كان مقصوداً بالتناول ؛ وهذا لأنه لو أخذه
بجميع الثمن لم يكن المشتري آخذاً كل ذراع بدرهم ، وهو لم يبيع إلا بشرط أن يكون كل ذراع
بدرهم؛ لذلك يأخذ الموجود بقيمته من الثمن .

العناية شرح الهداية ٦ / ٢٥٣ ، الجوهرة النيرة شرح مختصر القدوري ١ / ٤٣٨ .
(٤) لتفريق الصفقة؛ لأن المبيع إذا لم يوجد تاماً لا يوجد العقد حقيقة ، وكان أخذ الأقل كالبيع
بالتعاطي . مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر ١٢/٢ ، رد المحتار على الدر المختار ٤ / ٥٤٤ .
(٥) لأنه إن حصل له الزيادة في المبيع تلزمه الزيادة في الثمن ، فيتخير وليس أن يأخذ القدر المسمى
ويترك الزائد؛ لأن التبعض يضر البائع، بخلاف الصبرة؛ لأن القدر الزائد ليس وصفاً بل هو أصل

العناية شرح الهداية ٦ / ٢٥٤ ، تبیین الحقائق شرح كنز الدقائق ٤ / ٦ .
(٦) قوله : (لما بينا) إشارة إلى قوله : قبل أربعة خطوط ، لكنه صار أصلاً بإفراده بذكر الثمن .
العناية في شرح الهداية ٦ / ٢٥٣ .

(٧) أما ثبوت الخيار فلأنه نفع يشوبه مضرة ؛ لأن الزيادة نفع، ولزوم الزيادة بإزائها ضرر أي : زيادة
المبيع نفع وزيادة الثمن ضرر ، فأما أخذ الجميع كل ذراع بدرهم ؛ فلأن الذراع من حيث أنها صفة
دخل جميع العين في البيع ، ومن حيث أنها صارت مقصودة معقوداً عليها بالإفراد بالذکر زيد في

قَالَ: وَمَنْ اشْتَرَى عَشْرَةَ أَذْرُعٍ مِنْ مِائَةِ ذِرَاعٍ مِنْ دَارٍ أَوْ حَمَّامٍ (١) فَالْبَيْعُ فَاسِدٌ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ (٢)، وَقَالَا: هُوَ جَائِزٌ، إِنْ اشْتَرَى عَشْرَةَ أَسْهُمٍ (٣) مِنْ مِائَةِ سَهْمٍ (٤) جَازَ فِي قَوْلِهِمْ جَمِيعًا (٥) لَهُمَا أَنَّ عَشْرَةَ أَذْرُعٍ مِنْ مِائَةِ ذِرَاعٍ عَشْرُ الدَّارِ فَأَشْبَهَ عَشْرَةَ أَسْهُمٍ. وَلَهُ أَنَّ الدَّرَاعَ اسْمٌ لِمَا يَذْرَعُ بِهِ (٦)، وَاسْتَعِيرَ لِمَا يَحِلُّهُ الدَّرَاعُ (٧)

الثلثين بإزاء كل ذراع ، فلو لم يلزمه شيء بإزاء الزيادة كان كل ذراع بأقل من درهم . وذلك خلاف المشروط .

البنية في شرح الهداية ٧ / ٤٨ .

(١) أشار صاحب العناية إلى أنه لا فرق بين أن يكون المبيع مما ينقسم أو مما لا ينقسم فهو فاسد عند أبي حنيفة . العناية شرح الهداية ٦ / ٢٥٤ ، رد المحتار على الدر المختار ٤ / ٢٤٥ .

(٢) أن فساد البيع عند أبي حنيفة؛ لجهالة جملة الذرعان ، فأما إذا عرفت مساحتها ، فهو جائز ، وجعل ذلك نظير بيع كل شاة من القطيع بعشرة .

البنية في شرح الهداية ٧ / ٤٩ ، رد المحتار على الدر المختار ٤ / ٥٤٤ .

(٣) أسهم : السهم اسم للجزء الشائع . شرح فتح القدير ٦ / ٢٥٤ .

(٤) وجه قولهما : أن بيع عشر الدار جائز بالإجماع ، والعشرة الأذرع من المائة عشر فجاز ، ولهذا يجوز بيع عشرة أسهم من مائة سهم منها إجماعاً .

(٥) مبنى الخلاف : على أن المؤدى من عشرة أذرع من مائة ذراع معين ، أو شائع فعندهما شائع كأنه باع عشر مائة وبيع الشائع جائز اتفاقاً، كما في بيع عشرة أسهم من مائة سهم، وعنده مؤداة قدر معين، والجوانب مختلفة الجودة، فتقع المنازعة في تعيين مكان العشرة، ففسد البيع، فلو اتفقوا على أن مؤدى عشرة أذرع من مائة من هذه الدار شائع، لم يختلفوا لو اتفقوا على أنه متعين، لم يختلفوا فهو نظير اختلافهم في نكاح الصابئة مبنى على أنهم يعبدون الكواكب ولا كتاب لهم أو لهم كتاب فلو اتفقوا على الثاني اتفقوا على جوازه، أو على الأول اتفقوا على عدم الجواز فالشأن في ترجيح المبنى.

تبين الحقائق شرح كنز الدقائق ٤ / ٧ .

(٦) وهو الخشبة . درر الحكام شرح غرر الأحكام ٢ / ١٤٩ .

(٧) قوله : (فاستعير لما يحله الذراع) أي استعير الذراع لمحل الذراع ، وهو الممسوح ، وكان القياس أن يقول : استعيرت ؛ لأنه أسند إلى ضمير الذراع وهي مؤنثة لكن ذكر الفعل على تأويل الذراع بما يذرع به . أي : الشيء الذي يذرع به .

حاشية المحقق سعد الله بن أمير خان الشهير بسعدى جلبى بهامش فتح القدير ٦ / ٢٥٤ .

وَهُوَ الْمُعَيَّنُ دُونَ الْمَشَاعِ (١)،

وَذَلِكَ غَيْرُ مَعْلُومٍ (٢)، بِخِلَافِ السَّهْمِ (٣)، وَلَا فَرْقَ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ بَيْنَ مَا إِذَا عَلِمَ مِنْ جُمْلَةِ الدَّرَاعَانِ أَوْ لَمْ يَعْلَمْ (٤) وَهُوَ الصَّحِيحُ خِلَافًا لِمَا يَقُولُهُ الْخَصَّافُ لِبَقَاءِ الْجَهَالَةِ، وَلَوْ اشْتَرَى عَدْلًا (٥) عَلَى أَنَّهُ عَشْرَةُ أَثْوَابٍ فَإِذَا هُوَ تِسْعَةٌ أَوْ أَحَدَ عَشَرَ فَسَدَ الْبَيْعُ (٦) لَجَهَالَةِ الْمَبِيعِ أَوْ الثَّمَنِ (٧)، وَلَوْ بَيْنَ لِكُلِّ ثَوْبٍ ثَمَنًا جَازَ فِي فَصْلِ النُّقْصَانِ بِقَدْرِهِ وَلَهُ الْخِيَارُ (١)، وَلَمْ يَجْزُ فِي

(١) الشائع : المنتشر ، وسهم مشاع ، وشائع أي : حصة من شيء غير مقسوم .

معجم لغة الفقهاء : ٤٣٠ ، مختار الصحاح : ١٤٨ .

(٢) قوله : (وذلك غير معلوم) أي ما يحله الذراع غير معلوم موضعه ؛ لأنه لا يدري من أي جانب هو ؟ . البناءية في شرح الهداية ٧ / ٤٨ .

(٣) وجه قول أبي حنيفة : إن البيع وقع على قدر من الدار معين لا على شائع وذلك القدر مجهول في نفسه ؛ لأن موضعه لا يعلم أمن جانب شرقي هو ؟ أو من جانب غربي ؟ أو من غيرهما ؟ فيصير هو بائعاً في الحقيقة عشرة أذرع عيناً من الدار وتلك الأذرع مجهولة في نفسها ؛ فلا يصح بيع المجهول ، فصار كأنه باع بيتاً من بيوت الدار ولم يعين البيت ، أو باع قسماً من الأقسام من الدار المقسومة ؛ وهذا ؛ لأن القسم ليس باسم للشائع ، بل اسم لجزء مقدر معين ، لكنه لما كان مجهولاً في نفسه لجهالة موضعه لم يجز البيع ، بخلاف بيع عُشر الدار وبيع عشرة أسهم من مائة سهم من الدار ؛ لأن العُشر اسم لجزء شائع معلوم في نفسه ، .

رد المحتار على الدر المختار ٤ / ٥٤٥ ، تبیین الحقائق شرح كنز الدقائق ٤ / ٨٥٧ ،

(٤) دليل قوله : (ولا فرق عند أبي حنيفة) يعني أن جملة ذراعان الدار - وإن عُرُفت - لا يعلم موضع عشرة أذرع من مائة ذراع منها ، فبقيت الجهالة . البناءية في شرح الهداية ٧ / ٤٩ .

(٥) عدل : عدل الشيء بالكسر مثله من جنسه وفي المقدار ومنه عدل المتاع .

لسان العرب ١١ / ٤٣٢ ، أنيس الفقهاء في تعريفات الألفاظ المتداولة بين الفقهاء ١ / ٢٠٨

(٦) أي جهالة المبيع فيها إذا كان العدل أحد عشر ؛ لأنه يكون بائعاً عشرة أثواب من أحد عشر ثوباً ، والعشرة مجهولة ، ولجهالة الثمن فيما إذا كان العدل تسعة ؛ لأنه لا بد من حصة الثوب الناقص ، وهي مجهولة ، فلو قال لجهالة الثمن أو المبيع كان أولى .

(٧) فسد البيع ؛ لجهالة المبيع في الزيادة : لأن الزائد لم يدخل تحت العقد ؛ فيجب رده والأثواب مختلفة ، فكان المبيع مجهولاً جهالة تقضى إلى المنازعة .

الزِيَادَةِ) لِجَهَالَةِ الْعَشْرَةِ الْمَسِيعةِ(٢)، وَقِيلَ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ لَا يَجُوزُ فِي فَصْلِ النُّقْصَانِ أَيْضًا(٣)،
وَلَيْسَ بِصَحِيحٍ (٤)، بِخِلَافِ مَا إِذَا اشْتَرَى ثَوْبَيْنِ عَلَى أَنَّهُمَا هَرَوِيَّانِ فَإِذَا أَحَدُهُمَا مَرُويٌّ (٥) حَيْثُ
لَا يَجُوزُ فِيهِمَا، وَإِنْ بَيْنَ ثَمَنٍ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا؛ لِأَنَّهُ جَعَلَ الْقَبُولَ فِي الْمَرُويِّ شَرْطًا لِحُجُوزِ الْعَقْدِ فِي

ولجهالة الثمن في فصل النقصان؛ لأنه يحتاج إلى أن يسقط حصة ثمن المعلوم، وهو مجهول؛ لأنه لا
يدري أنه كان جيداً أو وسطاً أو رديئاً وحينئذ لا تدرى قيمته بقين، حتى تسقط فكانت جهالتها توجب
جهالة الباقي من الثمن، فلا يشك في فساد؛ لأنه يؤدي إلى النزاع .

تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق ٨/٤ ، العناية شرح الهداية ٢٥٥/٦ .

(١) وإن نقصت جاز البيع في الموجود؛ لأن ثمن كل ثوب معلوم، وللمشتري الخيار لتفريق الصفقة
عليه. العناية في شرح الهداية ٢٥٦/٦ .

(٢) وهذا إذا لم يبين ثمن كل ثوب، بل قال: بعثك هذه الرزمة على أنه عشرة بكذا، وكان فيها الزيادة
في العدد أو النقصان، أما إذا بين ثمن كل ثوب فقال: بعثك هذه الرزمة على أنها عشرة أثواب،
فلا شك في فساد البيع؛ لأن المبيع مجهول لما قلنا .

وهذا فيما إذا كان الثوب أحد عشر مثلاً؛ لأن العقد يتناول العشرة فعلى المشتري رد الثوب الزائد، وهو
مجهول وبجهالته يصير البيع مجهولاً .

البنية في شرح الهداية ٧ / ٥٠ ، مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر ٢ / ١٣ ز

(٣) وَقَالَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا : هَذَا قَوْلُهُمَا ، وَعَلَى قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ : لَا يَجُوزُ الْبَيْعُ فِي النُّقْصَانِ كَمَا فِي
الزِّيَادَةِ ؛ لِاشْتِمَالِ الصَّفَقَةِ عَلَى الْمَوْجُودِ وَالْمَعْدُومِ ، وَلَمْ يَجْزِ فِي الْمَعْدُومِ فَتَعَدَى إِلَى الْمَوْجُودِ .

كما لو جمع بين حُر وعبد في صفقة واحدة، وسمى لكل واحد ثمنًا، فإنه لا يجوز البيع عنده

تبيين الحقائق كنز شرح الدقائق ٨/٤، العناية شرح الهداية ٢٥٦/٦ .

(٤) قَالَ صَاحِبُ الْهَدَايَةِ: (وَلَيْسَ بِصَحِيحٍ) أَيِ مَا قِيلَ : إِنْ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ لَا يَجُوزُ الْبَيْعُ فِي فَصْلِ
النُّقْصَانِ لَيْسَ بِصَحِيحٍ ؛ لِأَنَ ثَمَنَ كُلِّ ثَوْبٍ مَعْلُومٌ قِطْعًا ، فَإِذَا نَقَصْتَ يَكُونُ بَاقِي الثَّمَنِ مَعْلُومًا لَا
مَحَالَةَ ، وَلَا يَشْبَهُ هَذَا . الْبَنِيَّةُ فِي شَرْحِ الْهَدَايَةِ ٧ / ٥٠ .

أي : ليس بثابت؛ لأن المراد أن ما نسب إلى أبي حنيفة هنا ليس بثابت وليس من باب الترجيح.

(٥) مَرُو : مَدِينَةُ عَظِيمَةٍ مِنْ أَشْهُرِ الْمَدَنِ بِخَرَّاسَانَ . بَيْنَهَا وَبَيْنَ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْ نَيْسَابُورَ وَهَرَاهُ وَبَلْخَ
وَبَخَارِي اثْنَا عَشَرَ يَوْمًا .

ومرو: بسكون الراء نسبة إلى قرية من قرى الكوفة، وأما بالنسبة إلى مرور المعروفة بخراسان فقد
التزموا فيها زيادة الزاي، فيقال مروزي وكأنه للفرق بين القريتين .

شرح فتح القدير ٢٥٦/٦ ، معجم البلدان ٥ / ١١٢ ، ١١٣ .

الْهَرَوِيُّ، وَهُوَ شَرْطٌ فَاسِدٌ (١) وَلَا قَبُولَ يُشْتَرَطُ فِي الْمَعْدُومِ (٢)، فَافْتَرَقَا (٣)، وَلَوْ اشْتَرَى ثَوْبًا وَاحِدًا عَلَى أَنَّهُ عَشْرَةُ أَذْرُعٍ كُلُّ ذِرَاعٍ بِدِرْهَمٍ فَإِذَا هُوَ عَشْرَةٌ وَنِصْفٌ أَوْ تِسْعَةٌ وَنِصْفٌ، قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ - رَحِمَهُ اللَّهُ -: فِي الْوَجْهِ الْأَوَّلِ يَأْخُذُهُ بِعَشْرَةٍ مِنْ غَيْرِ خِيَارٍ (٤)، وَفِي الْوَجْهِ الثَّانِي يَأْخُذُهُ بِتِسْعَةٍ إِنْ شَاءَ وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ - رَحِمَهُ اللَّهُ -: فِي الْوَجْهِ الْأَوَّلِ يَأْخُذُهُ بِأَحَدٍ عَشَرَ إِنْ شَاءَ، وَفِي الثَّانِي يَأْخُذُ بِعَشْرَةٍ

شَاءَ (٥)، وَقَالَ مُحَمَّدٌ - رَحِمَهُ اللَّهُ -: يَأْخُذُ فِي الْأَوَّلِ بِعَشْرَةٍ وَنِصْفٍ إِنْ شَاءَ، وَفِي الثَّانِي بِتِسْعَةٍ

(١) الشرط الفاسد : ما لا يقتضيه العقد ، وفيه منفعة لأحد المتعاقدين ، أو للمعقود عليه ، ولا يلزم مقتضى العقد ، ولا ما جرى عليه التعامل بين الناس ، ولا مما ورد في الشرع دليل بجوازه. الجوهرة النيرة ١ / ٢٠٣ ، درر الحكام في شرح مجلة الأحكام ١ / ١٦١ .

(٢) ما إذا باع ثوبين على أنهما هرويان فظهر أحدهما مروى حيث لا يجوز البيع فيهما ؛ لأنه جعل القبول في الثوب المروى - وهو معدوم - شرطاً لصحة العقد في الهروي ، وهو شرط فاسد ؛ لأنه لا قبول في المعدوم فيفسد العقد فيهما جميعاً سواء بين ثمن كل واحد منهما ، أو لم يبين . بدائع الصنائع للكاساني ٢ / ٢٠٨ ، ٢٠٩ العناية شرح الهداية ٦ / ٢٥٦ ، درر الحكام شرح غرر الأحكام ٢ / ١٤٩ .

(٣) أي شراء العدل على أنه عشرة أثواب بمائة ، كل ثوب بعشرة ، فإذا هو تسعة، وشراء الثوبين على أنهما هرويان ، فإذا أحدهما مروى افترقا ، حيث يجوز البيع في الأول دون الثاني. البناءة في شرح الهداية ٧ / ٥١ .

(٤) هذه المسألة لم يذكرها محمد في الزيادات ، رواية الأصول ، وإنما ذكرها في النوادر حكاة الفقيه أبو جعفر، ولم يذكرها صاحب الهداية في البداية ، وإنما ذكرها تفريعاً هنا . ثم نقول : إذا شرط في الثوب أنه عشرة أذرع كل ذراع بدرهم ، فزاد على العشرة نصف ذراع ، أو نقص عنها نصف ذراع .

(٥) قال أبو حنيفة : يأخذ في الأول الثوب بعشرة ، ويسلم له النصف مجاناً ، وهذا بلا خيار ، وفي الثاني يأخذه بتسعة إن شاء ، وأبو يوسف جعل نصف ذراع بمنزلة ذراع كامل، ففي الأول يأخذه بأحد عشر، والثاني يأخذه بعشرة، وله الخيار في الوجهين . وعند محمد يأخذ الأول بعشرة ونصف ، وفي الثاني بتسعة ونصف ، وله الخيار في الوجهين أيضاً، اعتباراً للجزء بالكل .

تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق ٤ / ٩ ، شرح فتح القدير ٦ / ٢٥٧ ، ٢٥٨ .

وَنَصْفٍ وَيُخَيَّرُ؛ لِأَنَّ مِنْ ضَرُورَةِ مُقَابَلَةِ الذَّرَاعِ بِالدَّرْهِمِ مُقَابَلَةً نِصْفِهِ بِنِصْفِهِ فَيَجْرِي عَلَيْهِ حُكْمُهَا (١) وَلِأَبِي يُوسُفَ - رَحِمَهُ اللَّهُ - أَنَّهُ لَمَّا أَفْرَدَ كُلُّ ذِرَاعٍ بِبَدَلٍ نَزَلَ كُلُّ ذِرَاعٍ مَنَزَلَةً تُؤَبِّ عَلَى حَدِّهِ وَقَدْ انْتَقَصَ (٢) وَلِأَبِي حَنِيفَةَ - رَحِمَهُ اللَّهُ - أَنَّ الذَّرَاعَ وَصَفٌ فِي الْأَصْلِ، وَإِنَّمَا أَخَذَ حُكْمَ الْمِقْدَارِ بِالشَّرْطِ وَهُوَ مُقَيَّدٌ بِالذَّرَاعِ (٣)، فَعِنْدَ عَدَمِهِ عَادَ الْحُكْمُ إِلَى الْأَصْلِ (٤)، وَقِيلَ فِي الْكِرْيَاسِ (٥) الَّذِي لَا يَتَفَاوَتْ جَوَانِبُهُ لَا يَطِيبُ لِلْمُشْتَرِي مَا زَادَ عَلَى الْمَشْرُوطِ؛ لِأَنَّهُ بِمَنَزَلَةِ الْمَوْزُونِ حَيْثُ لَا يَضُرُّهُ الْفَضْلُ (٦)، وَعَلَى هَذَا لَوْ قَالُوا: يَجُوزُ بَيْعُ ذِرَاعٍ مِنْهُ (٧)، وَمَنْ بَاعَ دَارًا دَخَلَ بِنَاوُهَا فِي الْبَيْعِ

(١) قوله : (فيجربى عليه) أي فيقسم الذراع على الدرهم فيكون نصف الذراع بنصف الدرهم . العناية شرح الهداية ٦ / ٢٥٧، شرح فتح القدير ٦ / ٢٥٧.

(٢) وجه قول أبي يوسف : أن كل ذراع لما أفرد بذكر بدل ، كانت كل ذراع كثوب ببيع على أنه ذراع ، فإذا انتقص الثوب من الذراع لم ينتقص شيء من الثمن ، وللمشتري الخيار ، فكذا هذا لكن الخيار في الزيادة ؛ لأنه نفع يشوبه مضرة ، وفي النقصان لفوات الوصف المرغوب فيه .

(٣) وجه قول أبي حنيفة : أن الذراع يعتبر وصفاً في الأصل ، وإنما نأخذ حكم الأصل إذا وجد الشرط ، ثم الشرط وجد في الذراع لا فيما دونها ، فكان الحكم في الذراع باقياً على الأصل ، فكان وصفاً ، والوصف لا يقابله شيء من الثمن ، لكن ليس له الخيار في صورة الزيادة ؛ لأن العشرة والنصف بمنزلة العشرة الجيدة ، فإذا اشترى شيئاً على أنه معيب ، فوجده سليماً يأخذه بلا خيار ، فكذا هنا ، وفي صورة النقصان يأخذه بتسعة إن شاء ؛ لأن النصف الزائد على التسعة بمنزلة الوصف ، فلا يقابله شيء من الثمن، لكن الخيار لفوات الوصف المرغوب فيه وهو النصف الناقص عن العشرة ، وبقول محمد : نأخذ.

(٤) أي عند عدم الشرط وهو كونه مقيداً بالذراع ، عاد حكم الذراع إلى الأصل، وهو جريان الذراع مجرى الوصف، فلا جرم عُدَّ نصف ذراع جودة، فصارت العشرة والنصف كالعشرة الجيدة . البناءة في شرح الهداية ٧ / ٥٣ .

(٥) الكرياسي : بكسر الكاف فارسي معرب ينسب إليه فيقال كرابيس وهو ثوب من القطن الأبيض . لسان العرب ٦ / ١٩٥ ، القاموس المحيط ١ / ٧٣٥ .

(٦) الفصل : وهو بالصاد المهملة أي: القطع . البناءة في شرح الهداية ٧ / ٥٣ .

(٧) وعلى هذا: أي المشايخ: إذا باع ذراعاً منه ولم يعين موضعه جاز كما في الحنطة إذا باع قفيزاً منها . العناية شرح الهداية ٦ / ٢٨٠

وَأِنْ لَمْ يُسَمَّهِ، لِأَنَّ اسْمَ الدَّارِ يَتَنَاوَلُ الْعَرْصَةَ (١) وَالْبِنَاءَ فِي الْعُزْفِ) وَلِأَنَّهُ مُتَّصِلٌ بِهَا اتِّصَالَ قَرَارٍ فَيَكُونُ تَبَعًا لَهُ، وَمَنْ بَاعَ أَرْضًا دَخَلَ مَا فِيهَا مِنَ النَّخْلِ وَالشَّجَرِ وَإِنْ لَمْ يُسَمَّهِ؛ لِأَنَّهُ مُتَّصِلٌ بِهَا لِلْقَرَارِ فَأَشْبَهَ الْبِنَاءَ (وَلَا يَدْخُلُ الزَّرْعُ فِي بَيْعِ الْأَرْضِ إِلَّا بِالتَّسْمِيَةِ) (٢) لِأَنَّهُ مُتَّصِلٌ بِهَا لِلْفَصْلِ فَشَابَهَ الْمُتَاعَ الَّذِي فِيهَا (٣) ، وَمَنْ بَاعَ نَخْلًا أَوْ شَجَرًا فِيهِ ثَمَرٌ فَثَمَرَتُهُ لِلْبَائِعِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُتَاعَ (٤) لِقَوْلِهِ -

(١) العرصة : بوزن الضربة كل بقعة بين الدور واسعة ليس فيها بناء .

مختار الصحاح ص: ١٧٨ .

(٢) لأن الشجر متصل بالأرض اتصال تأبيد ، ولرفعه غاية معلومة، فأشبهه المتاع الموضوع في الأرض ، فلم يدخل تحت البيع إلا بالشرط ، ولا يقال : يرد عليكم بيع جارية أو شاة أو بقرة في بطنها ولد ، حيث يدخل الولد تحت البيع ، وإن لم يتصل بالأم اتصال تأبيد ، ولانفصال الولد أيضاً غاية معلومة ، بالحديث ، وهو حديث عائشة (الولد لا يبقى في البطن أكثر من سنتين) . لأننا نقول: الولد قبل الانفصال كسائر أجزاء الأم حكماً ، وحقيقة : أما حكماً فإنه يعتق بعنق الأم، وأما حقيقة فإنه يتغذى بغذاء الأم. وينتقل بانئقالها . تبين الحقائق شرح الدقائق ٤ / ١١ .

(٣) البناية في شرح الهداية ٧ / ٥٤ ، ٥٥ ، شرح فتح القدير ٦ / ٢٦١ .

وقد علل الإمام العبادي بوجه المشاركة بين الولد والزرع في الأرض، حيث بينهما مناسبة؛ لقوله تعالى : ﴿ فَأَتُوا حَرْثَكُمْ أَنِّي سِنْتُمْ ﴾ سورة البقرة من الآية (٢٢٣) ، فكيف دخل الولد ولم يدخل الزرع؟ قلنا: لما لم يقدر أحد غير الله على فصل الولد من أمه ، ووجدت المجانسة بينه وبين أمه، نزل منزلة الجزء منها؛ فلم يعتبر انفصاله في ثانياً الحال؛ لوجود معنى الجزئية، ولعدم إمكان البائع من فصله، وأما الزرع فليس من جنس الأرض، فيتمكن من فصله كل أحد.

الجوهرة النيرة شرح مختصر القدوري ١/ ٤٤٠، ٤٣٩

ثم قال في المحيط: والأصل أن ما كان لقطعه مدة معلومة ، فهو كالثمن ؛ فلا يدخل، وما ليس لقطعه مدة معلومة ، يدخل كالشجر .

ثم قال: وأما الأشجار، فإن كانت بحالة تقطع في كل ثلاث سنين ، إن كانت تقلع من الأصل تدخل تحت البيع، وهو الشجر الصغير الذي يبتاع في السوق في الربيع .

وإن كانت تقطع من وجه الأرض، فالصحيح أنها تدخل تحت البيع أيضاً من غير ذكر، مثمرة كانت أو غير مثمرة ، صغيرة أو كبيرة للحطب أو لغيره ، وفيه اختلاف المشايخ المحيط

البرهاني في الفقه النعماني ٦ / ٣١٥ ، ٣١٦ ، البناية في شرح الهداية ٧ / ٥٥ ، .

(٤) أي إلا أن يشترط المشتري الثمرة لنفسه ، فحينئذ تكون الثمرة له بأن يقول المشتري : اشتريت هذا

الشجر مع ثمره، سواء كانت مؤبرة أو لا. الجوهرة النيرة ١/ ٤٤٠ .

عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - (مَنْ اشْتَرَى أَرْضًا فِيهَا نَخْلٌ فَالْتَمَرَةُ لِلْبَائِعِ (١) إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ)
 (٢)، وَلِأَنَّ الْإِتِّصَالَ وَإِنْ كَانَ خِلْقَةً فَهُوَ لِلْقَطْعِ لَا لِلْبَقَاءِ فَصَارَ كَالزَّرْعِ ، وَيُقَالُ لِلْبَائِعِ اقْطَعْهَا (٣) ،
 وَسَلَّمِ الْمُبِيعَ (٤) ، وَكَذَا إِذَا كَانَ فِيهَا زَرْعٌ ؛ لِأَنَّ مِلْكَ الْمُشْتَرِي مَشْغُولٌ بِمِلْكِ الْبَائِعِ فَكَانَ عَلَيْهِ
 تَفْرِيفُهُ وَتَسْلِيمُهُ ، كَمَا إِذَا كَانَ فِيهِ مَتَاعٌ (٥) وَقَالَ الشَّافِعِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ - : يُتْرَكُ حَتَّى يَظْهَرَ صَلاَحُ
 الثَّمَرِ وَيُسْتَحْصَدُ الزَّرْعُ ؛ لِأَنَّ الْوَاجِبَ إِنَّمَا هُوَ التَّسْلِيمُ الْمُعْتَادُ ، وَالْمُعْتَادُ أَنْ لَا يُقْطَعَ (٦) ،
 وَصَارَ كَمَا إِذَا انْقَضَتْ مُدَّةُ الْإِجَارَةِ وَفِي الْأَرْضِ زَرْعٌ (٧) . وَقُلْنَا : هُنَاكَ التَّسْلِيمُ وَاجِبٌ أَيْضًا
 حَتَّى يُتْرَكَ بِأَجْرٍ ، وَتَسْلِيمُ الْعَوَضِ كَتَسْلِيمِ الْمُعَوَّضِ (١) ، وَلَا فَرْقَ بَيْنَ مَا إِذَا كَانَ الثَّمَرُ بِحَالٍ لَهُ

- (١) بيان: أن قوله : (فالثمر للبائع) يشمل المؤبر وغير المؤبر ، فيكون بعمومه حجة عليهم ، ولأن
 العقد وقع على الأصل ، فلا يدخل تحته الثمر ، سواء أبرت النخل ، " التأبير : التلقيح ، وهو أن
 يشق عناقيد الكم ويذر فيها من طلع الفحل فإنه يصلح ثمر إناث النخل . شرح فتح القدير ٢٦١/٦ .
 " أو لم تؤبر ، كما في ثمر سائر الشجر ، ولأن الاتصال بالنخل ، وإن كان أمراً خلقياً ، لكنه للقطع
 لا للبقاء ؛ فصار كالزراع ؛ فلم يدخل تحت البيع . البناية شرح الهداية ٣٤/٨ .
 (٢) أخرجه الزيلعي في نصب الرأية وقال عنه : هذا الحديث بلفظه غريب جداً .
 نصب الرأية في تخريج أحاديث الهداية ٤ / ٧ .
 (٣) أي فيما إذا باع أرضاً فيها زرع لم يسمه ، أو شجراً عليه ثمر ، لم يشترطه حتى بقى الزرع والثمر
 على ملك البائع . رد المحتار على الدر المختار ٤ / ٥٥٤ .
 (٤) وعلل الإمام البارتي بقوله : وسلم المبيع فارغاً لوجوب ذلك عليه ، فيؤمر بتفريغ ملك المشتري عن
 ملكه ، بقطع الثمرة ورفع الزرع . العناية شرح الهداية ٦ / ٢٦٢ ، ٢٦٣ .
 (٥) ولنا أن ملك المشتري ، وهو الشجر والأرض ، مشغول بملك البائع ، وهو الثمر والزرع ، فيجب
 على البائع تفريغه ، وتسليمه ، كما إذا باع أرضاً فيها متاعه
 قيد بالمبيع : لأن المدة إذا انقضت في الإجارة ، وفي الأرض زرع فإن المستأجر لا يؤمر بقلع زرع ،
 وإنما يبقى بأجر المثل إلى انتهائه ؛ لأنها للانتفاع وذلك بالترك دون القلع ، بخلاف الشراء ؛ لأنه
 ملك الرقبة فلا يراعى فيه إمكان الانتفاع ؛ ولأن التسليم ، وإن وجب عليه فارغة لكن التسليم العوض
 تسليم للمعوض فافتراً ؛ فلا يقاس البيع على الإجارة . البحر الرائق شرح كنز الدقائق ٣٢٤/٥
 (٦) ليس لمشتري الأشجار أن يكلف البائع قطع الثمار ؛ بل له الإبقاء إلى أوان القطاف للعرف .
 الوجيز للغزالي ٣١٠/١ ، المهذب في فقه الشافعي ٣٧٣/١ ، البناية في شرح الهداية ٥٧/٧ .
 (٧) وأما مسألة الإجارة ، فالتسليم ثمة يجب للحال ، ولهذا وجب تبقية الزرع بأجرة مبتدأة ، فلو لم يكن
 تسليم الأرض واجباً للحال ، لم يجب أجرة أخرى . بدائع الصنائع للكاساني ٥ / ٢٤٧ .

قِيمَةً أَوْ لَمْ يَكُنْ فِي الصَّحِيحِ (٢)، وَيَكُونُ فِي الْحَالَيْنِ لِلْبَائِعِ؛ لِأَنَّ بَيْعَهُ يَجُوزُ فِي أَصَحِّ الرَّوَايَتَيْنِ عَلَى مَا تَبَيَّنَ فَلَا يَدْخُلُ فِي بَيْعِ الشَّجَرِ مِنْ غَيْرِ ذِكْرِ، وَأَمَّا إِذَا بَاعَ الْأَرْضَ وَقَدْ بَذَرَ فِيهَا صَاحِبُهَا وَلَمْ يَنْبُتْ بَعْدُ لَمْ يَدْخُلْ فِيهِ؛ لِأَنَّهُ مُودَعٌ فِيهَا كَالْمَتَاعِ، وَلَوْ نَبَتَ وَلَمْ تَصِرْ لَهُ قِيمَةً فَقَدْ قِيلَ لَا يَدْخُلُ فِيهِ (٣)، وَقَدْ قِيلَ يَدْخُلُ فِيهِ، وَكَأَنَّ هَذَا (٤) بِنَاءً عَلَى الْإِخْتِلَافِ فِي جَوَازِ بَيْعِهِ (٥) قَبْلَ أَنْ تَنَالَهُ لِمَشَافِرِ (٦)، وَالْمَنَاجِلِ (٧) ،

وَلَا يَدْخُلُ الزَّرْعُ وَالشَّمَرُ بِذِكْرِ الْحُقُوقِ وَالْمَرَافِقِ (٨)؛ لِأَنَّهُمَا لَيْسَا مِنْهُمَا ، وَلَوْ قَالَ بِكُلِّ قَلِيلٍ وَكَثِيرٍ هُوَ لَهُ وَمِنْهَا مِنْ حُقُوقِهَا أَوْ قَالَ مِنْ مَرَافِقِهَا لَمْ يَدْخُلَا فِيهِ لِمَا قُلْنَا (١)، وَإِنْ لَمْ يَقُلْ مِنْ حُقُوقِهَا أَوْ

(١) فَإِنْ قُلْنَا : التسليم الواجب هو المعتاد ، ولهذا لا يجب نقل المتاع من الدار المبيعة في الليل ، بل ينتظر إلى أن يكون النهار ويوجد الحمال ، وكذا ينتظر إلى أن يستحصد الزرع إذا انقضت مدة الإجارة ، ولا يؤمر بقلع الزرع للحال ، والمعتاد في مسألتنا أن ينتظر إلى القطاف والحصاد. شرح فتح القدير ٦ / ٢٦٢ ، المذهب في فقه الإمام الشافعي ١ / ٣٧٢ . ٣٧٣ .

(٢) يتصل بقوله : (ومن باع نخلاً أو شجراً فيه ثمرة ، فثمرته للبائع في الحالين). البناءة في شرح الهداية ٧ / ٥٨ .

(٣) اختار الفقيه أبو الليث أنه لا يدخل بكل حال ، إلا إذا بيع مع الأرض نصاً أو دلالة والصواب أنه يدخل . نص عليه في شرح القُدوري . البناءة في شرح الهداية ٧ / ٥٩ .

(٤) يعنى الاختلاف في دخول الزرع الذى ليست له قيمة وعدمه . شرح فتح القدير ٦ / ٢٦٤ .
(٥) الخلاف مبنى على الاختلاف ، في جواز بيعه قبل أن تناله المشار والمناجل ، قال في الفتح : يعنى أن من قال : لا يجوز بيعه قال : يدخل ، ومن قال : يجوز ، قال : لا يدخل ، ولا يخفى أن كلاً من الاختلافين مبنى على سقوط تقومه وعدمه ، فإن القول بعدم جواز بيعه ، ودخوله في البيع ، كلاهما مبنى على سقوط تقومه ، والأوجه جواز بيعه على رجاء تركه ، كما يجوز بيع الجحش ، كما ولد رجاء حياته ، فينتفع به في ثاني الحال. رد المحتار على الدر المختار ٤ / ٥٥٣ .

(٦) المشار : مشفر البعير : شفته ، وجمعه مشافر .
لسان العرب ٤ / ٤١٩ ، العناية شرح الهداية ٥ / ٢٦٤ .

(٧) المناجل : بكسر الميم ما يحصد به الزرع والجمع مناجل .
الصاحح للجوهري ٢ / ٤٦٥ ، مختار الصحاح : ٢٧٠ ، البناءة في شرح الهداية ٧ / ٥٩ ، البحر الرائق شرح كنز الدقائق ٥ / ٣٢١ .

(٨) المرافق : جمع مرفق بفتح الميم وكسر الفاء قال الجوهري : والمرفق من الأمر : وهو ما ارتفعت به ، وانتفعت به ، ومرافق الدار مسيل الماء ونحوها ، والمرفق موصل الذراع في العضد .الصاحح للجوهري ٤ / ١٤٨٢ ، لسان العرب ١٠ / ١٢٠ .

مِنْ مَرَّافِقِهَا دَخَلَا فِيهِ. وَأَمَّا الشَّمْرُ الْمَجْدُودُ وَالزَّرْعُ الْمَحْصُودُ فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ الْمَتَاعِ لَا يَدْخُلُ إِلَّا
بِالتَّصْرِيحِ بِهِ .

(بيع الثمر)

قَالَ : وَمَنْ بَاعَ ثَمَرَةً لَمْ يَبْدُ (٢) صَلاَحُهَا (٣) أَوْ قَدْ بَدَأَ جَارَ (٤) الْبَيْعِ ؛ لِأَنَّهُ مَالٌ مُتَقَوِّمٌ،

(١) قوله : (لما قلنا) إشارة إلى قوله : لأنهما ليسا منهما . البناء في شرح الهداية ٧ / ٦٠ .
(٢) المراد من البدو : الظهور ، ومن الصلاح : صلاحية الانتفاع به ، بأن يخرج سليماً والانتفاع حاصل
في ثاني الحال فصح البيع ، والمراد منه النهى عن بيع ثمرة لم تكن بعد .
بدائع الصنائع ٥ / ٢٠٧ ، البناء في شرح الهداية ٧ / ٦١ .
(٣) لا خلاف للعلماء في بيع الثمار بعد بدو الصلاح ، لكن الخلاف في تفسير بدو الصلاح ، فعندنا
هو أن يأمن من العاهة والفساد ، ذكره في المبسوط ، وعند الشافعي رحمته الله ظهور الصلاح بظهور
الفتح ومبادئ الحلاوة ، أما قبل بدو الصلاح إذا اشتراه مطلقاً يجوز عندنا وعند الشافعي ، ومالك
وأحمد رحمهم الله لا يجوز المبيع ، والبيع بشرط القطع قبل بدو الصلاح يجوز فيما ينتفع به بالإجماع ،
وبشرط الترك لا يجوز بالإجماع ، وبيع الثمار قبل الظهور لا يجوز بالإجماع ، وبعد الظهور على
أوجه :

أحدهما : أن يبيعهما قبل صيرورتها منتفعاً بها ، فإن لم يصلح لتناول بنى آدم وعلف الدواب ، فقال
شيخ الإسلام لا يجوز ، وذكر القدوري في شرحه والإسيباني أنه يجوز ، وإليه أشار محمد في
كتاب الزكاة في باب العُشر والخراج في الجامع وهو الصحيح .
والثاني : ما إذا باعه بعد ما صار منتفعاً به ، إلا أنه لم يتناه عظمه ، فالبيع جائز عند الكل ، إذا باعه
مطلقاً ، أو بشرط القطع ، ولو باعه بشرط الترك لا يجوز في القياس ، وهو قولهما ، ويجوز في
الاستحسان ، وهو قول محمد والشافعي ومالك وأحمد .

البناء في شرح الهداية ٧ / ٦٠ ، ٦١ ، شرح فتح القدير ٦ / ٢٦٤ ، ٢٦٥ ،

(٤) جاز : أي : صح وأبيح .

(تحقيق مسألة بيع الثمرة قبل بدو صلاحها مطلقاً)

اختلف الفقهاء في هذه المسألة على رأيين :-

الرأي الأول : لجمهور الفقهاء المالكية والشافعية والحنابلة والظاهرية :

قالوا لا يجوز بيع الثمار قبل بدو صلاحها مطلقاً " أي بدون شرط قطع ولا تبقية " .

إِمَّا لِكَوْنِهِ مُنْتَفَعًا بِهِ فِي الْحَالِ أَوْ فِي الثَّانِي، وَقَدْ قِيلَ لَا يَجُوزُ قَبْلَ أَنْ يَبْدُو صلاحُهَا وَالْأَوَّلُ أَصَحُّ وَعَلَى الْمُشْتَرِي قَطْعُهَا فِي الْحَالِ تَفْرِيعًا لِمَلِكِ الْبَائِعِ، وَهَذَا إِذَا اشْتَرَاهَا مُطْلَقًا أَوْ بِشَرْطِ الْقَطْعِ (وَأِنْ شَرَطَ تَرْكُهَا عَلَى التَّخِيلِ فَسَدَ الْبَيْعُ) (١)؛ لِأَنَّهُ شَرْطٌ لَا يَقْتَضِيهِ الْعَقْدُ وَهُوَ شَغْلُ مَلِكِ الْغَيْرِ أَوْ هُوَ صَفَقَةٌ فِي صَفَقَةٍ وَهُوَ إِعَارَةٌ أَوْ إِجَارَةٌ فِي بَيْعٍ، وَكَذَا بَيْعُ الزَّرْعِ بِشَرْطِ التَّرِكِ لِمَا قُلْنَا (٢) وَكَذَا إِذَا تَنَاهَى عِظْمُهَا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَبِي يُوسُفَ رَحِمَهُمَا اللَّهُ لِمَا قُلْنَا (٣) وَاسْتَحْسَنَهُ مُحَمَّدٌ -

الرأي الثاني : للحنفية يجوز ذلك إلا أنه يلزم المشتري القطع لا من جهة ما هو بيع ما لم يره بل من جهة أن ذلك شرط عنده في بيع الثمر حيث جاء في المبسوط (... وإن اشتراه مطلقاً يجوز عندنا ؛ لأن مطلق العقد يقتضي تسليم المعقود عليه في الحال فهو وشرط القطع سواء ... " .

سبب الخلاف: هل يحمل الإطلاق على القطع وهو الجائز أو على التبقية وهي الممنوعة؟ فمن حمل الإطلاق على التبقية قال لا يجوز، ومن حمله على القطع قال يجوز .

(١) بأن قال : اشتريته على أنني أتركه على النخل ، فقد فسد البيع . البناءة في شرح الهداية ٧ / ٦٢
(٢) ثم أعلم أن بيع الثمار بعد الظهور لما جاز ، وجب على المشتري قطع ذلك للحال ؛ لأن ملك البائع مشغول بملكه ، فيجب تفريغه ، كما لو اشترى طعاماً في بيت ، وجب على المشتري نقل الطعام عن البيت ، ثم جواز بيع الثمر فيما إذا اشتراها مطلقاً ، عن قيد تركها على النخل ، أو اشتراها بشرط القطع ، أما إذا اشتراها بشرط الترك يكون البيع فاسداً بلا خلاف بين أصحابنا سواء بدا صلاحها أو لم يبد ،

(٣) لأنه شرط لا يقتضيه العقد ، وفيه منفعة لأحد المتعاقدين ، ولا يلائم العقد ، ولا جري به التعامل بين الناس ، ومثل هذا الشرط مفسد للبيع ؛ لأن مطلق البيع يقتضي تسليم المعقود عليه ؛ ولأنه لا يتمكن من الترك إلا بإعارة الشجر والأرض ، وهما ملك البائع ، فصار بشرط الترك شرطاً للإعارة فكان شرطه صفقة في صفقة ، وأنه منهي هذا إذا لم يبد صلاحه ، وكذا إذا بدا صلاحه فباع بشرط القطع أو مطلقاً . بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع للكاساني ٥ / ٢٥٧ .

رَحِمَهُ اللَّهُ - لِلْعَادَةِ، (١)، بِخِلَافِ مَا إِذَا لَمْ يَتَنَاهَ عِظْمُهَا؛ لِأَنَّهُ شَرَطَ فِيهِ الْجُزْءَ الْمَعْدُومَ وَهُوَ الَّذِي يَزِيدُ لِمَعْنَى فِي الْأَرْضِ أَوْ الشَّجَرِ (٢) .

(حكم الفضل الناتج عن ترك الثمر أو الزرع في حالة الشراء المطلق)
وَلَوْ اشْتَرَاهَا مُطْلَقًا (٣) وَتَرَكَهَا بِإِذْنِ الْبَائِعِ طَابَ لَهُ الْفَضْلُ، وَإِنْ تَرَكَهَا بِغَيْرِ إِذْنِهِ تَصَدَّقَ بِمَا زَادَ فِي ذَاتِهِ (٤) لِحُصُولِهِ بِجِهَةِ مَحْظُورَةٍ (٥)، وَإِنْ تَرَكَهَا بَعْدَمَا تَنَاهَى عِظْمُهَا لَمْ يَتَصَدَّقْ بِشَيْءٍ (٦)؛ لِأَنَّ

(١) وعلل الإمام الكاساني علة للرد على قول محمد فقال : دعوى تعامل الناس شرط الترك في المبيع ممنوعة، وإنما التعامل بالمسامحة بالترك، من غير شرط في عقد البيع. بدائع الصنائع ٢٥٨/٥
(٢) فرق محمد بين التناهي وعدمه ، وقال : إذا لم يتناه عظمها وشرط الترك يحدث في المبيع أجزاء زائدة بمعنى في الأرض أو الشجر ، فيفسد العقد ؛ لأنه يصير حينئذ شرطاً للجزء المعدوم ، وليس كذلك إذا تناهى عظمها ؛ لأنه لا يحدث جزء زائد.
الجواب: أنا لا نسلم أن التعامل جرى في اشتراط الترك ، ولكن المعتاد في مثله الإذن في تركه ، بلا شرط في العقد .

العناية شرح الهداية ٦ / ٢٦٨ ، البحر الرائق شرح كنز الدقائق ٥ / ٣٢٧ .
(٣) يعني لو اشتراها من غير شرط القطع والترك . البناءة في شرح الهداية ٧ / ٦٣ .
(٤) كيفية التصديق : بأن تقوم قبل الإدراك ، وتقوم بعده ، فيتصدق بما زاد من قيمته إلى وقت الإدراك ؛ لأن ما زاد حصل بجهة محظورة ، وهى حصولها بقوة الأرض المغصوبة
الجوهرة النيرة شرح مختصر القدوري ١ / ٤٤٠ ، العناية شرح الهداية ٦ / ٢٦٨ .
(٥) **الحظر** في اللغة : المنع ، وهو ضد الإباحة ، وحظره فهو محظور أي محرم ، وبابه : نصر .
النهاية في غريب الأثر والحديث ١/٩٩٧ ، مختار الصحاح: ٦٠ .
واصطلاحاً : عرفه صاحب الفصول في الأصول فقال : ما يستحق بفعله العقاب ويتركه الثواب .
الفصول في الأصول ٣ / ٢٤٧ .

وعرفه ابن عابدين بأنه : ما منع من استعماله شرعاً . رد المختار على الدر المختار ٦ / ٣٣٦ .
(٦) ثم تفرع المسألة : أعنى مسألة القدوري بأن يقال : لو اشتراها مطلقاً وتركها ، فلا يخلو : إما أن يكون قبل تناهى عظمها ، أو بعد التناهي ، فإن كان قبل التناهي ففيه وجهان : إما أن يكون الترك بإذن البائع ، أو بغير إذنه ، فإن كان بالإذن حل له الفضل ، وإن كان بغير إذنه لا يطيب له ذلك ، ويتصدق به؛ لأنه حصل بجهة محظورة وهى غصب ملك الغير وإن كان بعد التناهي لا يتصدق بشيء أصلاً سواء كان الترك بإذن البائع ، أو بغير إذنه ؛ لأنه لم يحصل الازدياد في عين المبيع

هَذَا تَغْيِيرُ حَالَةٍ لَا تَحَقُّقُ زِيَادَةٍ (١)، وَإِنْ اشْتَرَاهَا مُطْلَقًا وَتَرَكَهَا عَلَى النَّخِيلِ ، وَقَدْ اسْتَأْجَرَ النَّخِيلَ إِلَى
وَقْتِ الْإِدْرَاكِ طَابَ لَهُ الْفَضْلُ (٢)؛ لِأَنَّ الْإِجَارَةَ بَاطِلَةٌ (٣) لِعَدَمِ التَّعَارُفِ وَالْحَاجَةِ (٤) فَبَقِيَ الْإِذْنُ
مُعْتَبَرًا، بِخِلَافِ مَا إِذَا اشْتَرَى الزَّرْعَ وَاسْتَأْجَرَ الْأَرْضَ إِلَى أَنْ يُدْرِكَ وَتَرَكَهُ حَيْثُ لَا يَطِيبُ لَهُ الْفَضْلُ
(٥)؛ لِأَنَّ الْإِجَارَةَ فَاسِدَةٌ (٦) لِلْجَهَالَةِ (٧)

لا كَيْلًا وَلَا وَزْنَ ، وَإِنَّمَا تَغْيِيرُ حَالِ الْمَبِيعِ مِنْ حَيْثُ النُّضْجِ . تَبْيِينُ الْحَقَائِقِ شَرْحُ كَنْزِ الدَّقَائِقِ ٤ / ١٢ .

(١) أَي لَا تَحَقُّقُ زِيَادَةٍ فِي الْجِسْمِ ، فَإِنَّ الثَّمَرَةَ إِذَا صَارَتْ بِهَذِهِ الْمِثَابَةِ لَا يَزِيدُ فِيهَا مِنْ مَلِكِ الْبَائِعِ بِغَيْرِ
إِذْنِهِ شَيْءٍ ، بَلِ الشَّمْسُ تَنْتَضِجُهَا وَالْقَمَرُ يَلُونَهَا ، وَالْكَوَاكِبُ تَعْطِيهَا الطَّعْمَ .
الْعُنَايَةُ شَرْحُ الْهِدَايَةِ ٢٦٨/٦ ، الْبِنَايَةُ فِي شَرْحِ الْهِدَايَةِ ٧ / ٦٣ .
(٢) وَأَمَّا طِيبُ الْفَضْلِ ؛ فَلَأَنَّ التَّرِكَ حَصَلَ بِإِذْنِ الْمُشْتَرَى .
بِدَائِعِ الصَّنَائِعِ ٥ / ٢٥٨ ، شَرْحُ فَتْحِ الْقَدِيرِ ٦ / ٢٦٥ .
(٣) أَمَّا بَطْلَانُ الْإِجَارَةِ فَلَأَنَّ جَوَازَ الْإِجَارَةِ عُرِفَ بِالِاسْتِحْسَانِ لَتَعَامَلِ النَّاسَ ، وَلَا تَعَامَلِ لِلنَّاسِ فِي
اسْتِئْجَارِ الْأَشْجَارِ لِتَرْكِ الثَّمَارِ عَلَيْهَا ، فَلَمْ تَكُنِ الْإِجَارَةُ مَنَعْقِدَةً .
(٤) الْحَاجَةُ : مَا يَفْتَقِرُ الْإِنْسَانُ إِلَيْهِ مَعَ أَنَّهُ يَبْقَى بِدُونِهِ ، وَالضَّرُورَةُ : مَا لَا يَدُّ لَهُ فِي بَقَاةِهِ .
قَوَاعِدُ الْفَقْهِ لِلْبَرَكَتِي : ٢٥٧ .

(٥) وَهَذَا بِخِلَافِ مَا إِذَا اشْتَرَى الزَّرْعَ وَتَرَكَهُ عَلَى الْأَرْضِ ، وَقَدْ اسْتَأْجَرَ الْأَرْضَ إِلَى أَنْ يُدْرِكَ الزَّرْعُ ،
حَيْثُ لَا يَطِيبُ لَهُ الْفَضْلُ ، وَيَجِبُ أَجْرُ الْمَثَلِ ؛ وَهَذَا لِأَنَّ إِجَارَةَ الْأَرْضِ مَتَعَارَفٌ حَتَّى إِذَا بَيَّنَّ الْمُدَّةَ
صَحَّتْ ، فَلَمَّا لَمْ يَبَيِّنِ الْمُدَّةَ فِي مَسْأَلَتِنَا فَسَدَتْ ، وَالْوَاجِبُ فِي الْإِجَارَةِ الْفَاسِدَةِ أَجْرُ الْمَثَلِ ، وَإِنَّمَا لَمْ
يَطِبْ لَهُ الْفَضْلُ ؛ لِأَنَّ جَهَالَ مَدَّةِ الْإِدْرَاكِ وَرَثَتْ خُبْنًا ؛ فَوَجِبَ التَّصَدُّقُ . الْجَوْهَرَةُ النِّيرَةُ شَرْحُ مُخْتَصَرِ
الْقُدُورِيِّ ١/ ٤٤٠ ، بِدَائِعِ الصَّنَائِعِ ٥ / ٢٥٨ .

(٦) الْفَاسِدُ فِي اللُّغَةِ : فَسَدَ الشَّيْءُ فَسُودَ مِنْ بَابِ قَعْدَ فَهُوَ فَاسِدٌ ، وَالْجَمْعُ فَسْدَى ، وَالْإِسْمُ الْفَسَادُ
وَالْمَفْسَدَةُ ضِدُّ الْمَصْلُحَةِ . الْمَصْبَاحُ الْمُنِيرُ ٢ / ٤٧٢ ، مُخْتَارُ الصَّحَاحِ : ٢١١ .
وَاصْطِلَاحًا : مَا كَانَ مَشْرُوعًا بِأَصْلِهِ لَا بِوَصْفِهِ كَبَيْعِ مَالٍ يَجْنِسُهُ مَتَفَاضِلًا وَنَحْوَهُ فَإِنَّهُ مَشْرُوعٌ مِنْ حَيْثُ
أَنَّهُ بَيْعٌ وَمَمْنُوعٌ مِنْ حَيْثُ أَنَّهُ يَشْتَمِلُ عَلَى الزِّيَادَةِ .

كَشَفَ الْأَسْرَارَ شَرْحُ أَصُولِ الْبَزْدَوِيِّ ١/ ٢٧٢ ، رَدُّ الْمُحْتَارِ عَلَى الدَّرَرِ الْمُخْتَارِ ٥ / ٤٩ .

(٧) وَإِنَّمَا فَسَدَتْ الْإِجَارَةُ هُنَا ؛ لِجَهَالَةِ وَقْتِ إِدْرَاكِ الزَّرْعِ ، فَإِنَّ الْإِدْرَاكَ قَدْ يَتَقَدَّمُ لَشِدَّةِ الْحَرِّ ، وَقَدْ يَتَأَخَّرُ
لِلْبَرْدِ ، وَالْفَاسِدُ مَا لَمْ يَحَقِّقْ مِنْ حَيْثُ الْأَصْلِ ، فَأَمَّا أَنْ يَكُونَ مُتَضَمِّنًا لَشَيْءٍ ، وَيُفْسِدُ ذَلِكَ الشَّيْءُ

فَأُورِثَتْ خُبْنًا (١) وَلَوْ اشْتَرَاهَا مُطْلَقًا فَأَثْمَرَتْ ثَمَرًا آخَرَ قَبْلَ الْقَبْضِ فَسَدَ الْبَيْعُ؛ لِأَنَّهُ لَا يُمَكِّنُهُ تَسْلِيمُ فَالْقَوَامِ لِتَعَذُّرِ التَّمْيِيزِ (٢)، وَلَوْ أَثْمَرَتْ بَعْدَ الْقَبْضِ يَشْتَرِكَانِ فِيهِ لِلَاخْتِلَافِ (٣) وَالْقَوْلُ: قَوْلُ الْمُشْتَرِي (٤) فِي مِقْدَارِهِ؛ لِأَنَّهُ فِي يَدِهِ، وَكَذَا فِي الْبَاذِنَجَانِ وَالْبَطِيخِ (٥)،

لفساد المتضمن ، وإذا انتفى الإذن كان الفضل خبيثاً وسبيله التصديق . العناية شرح الهداية ٢٦٨/٦ ، البناية في شرح الهداية ٦٤ / ٧ .

(١) وزاد الإمام البابر في علة أخرى ، وهى عدم الحاجة إلى ذلك ؛ لأن الحاجة إلى الترك بالإجارة إنما تتحقق إذا لم يكن مخلص سواها ، وها هنا يمكن للمشتري أن يشتري الثمار مع أصولها . العناية شرح الهداية ٢٦٨ / ٦

(٢) أي بين الثمر الذي خرج بعد المبيع ، وبين ما خرج قبل البيع . البناية في شرح الهداية ٦٤ / ٧

(٣) لأن التخلية قبض ، وحكم البيع يتم ويتناهى بالقبض ، والثمرة تكون بينهما لاختلاط ملك أحدهما بالآخر اختلاطاً لا يمكن التمييز بينهما؛ فكان الكل مشتركاً بينهما بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ٢٥٨ / ٥ .

(٤) ولو اشتراها مطلقاً ، وأخرجت الشجرة في مدة الترك ثمرة أخرى ، فالحادث كله للبائع سواء كان الترك بإذن البائع أو بغير إذنه ؛ لأن الحادث تولد عن ملك البائع ، ولم يرد عليه العقد ، فإن حلها للبائع له : جاز ، فإن اختلط الحادث بالموجود وقت العقد ، بحيث لا يمكن التمييز بينهما: فإن كان ذلك قبل تخلية البائع بين المشتري والثمار ، فسد العقد ؛ لأن المبيع صار مجهولاً ، بحيث يتعذر تسليمه؛ كما لو تعذر بالهلاك وإن كان بعد التخلية لم يفسد العقد وكانا شريكين لاختلاط ملكهما ، والقول في الزيادة قول المشتري ؛ لأن المبيع في يده . تحفة الفقهاء لعلاء الدين السمرقندي ٥٦ / ٢ .

(٥) فحاصله أن لهذه المسألة ثلاث صور :

إحداها : إذا خرج الثمار كله ، فإنه يجوز بيعه بالاتفاق ، وحكمه ما مضى . وثانيها : أن لا يخرج شيء منه ، فإنه لا يجوز بيعه اتفاقاً . وثالثها : أن يخرج بعضها دون بعض ، فإنه لا يجوز في ظاهر المذهب ، وقيل: يجوز إذا كان الخارج أكثر ، ويجعل المعدوم تبعاً للموجود استحساناً لتعامل الناس ؛ وللضرورة ، وكان شمس الأئمة الحلواني ، وأبو بكر محمد بن الفضل يفتيان به . مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر ١٩/٢ .

وَالْمَخْلَصُ (١) أَنْ يَشْتَرِيَ الْأَصُولَ لِتَحْصُلَ الزِّيَادَةُ عَلَى مَلِكِهِ (٢)، قَالَ: وَلَا يَجُوزُ أَنْ يَبِيعَ ثَمَرَةً وَيَسْتَشْنِي مِنْهَا، أَرَطَالًا (٣) مَعْلُومَةً (٤) خِلَافًا لِمَالِكٍ - رَحِمَهُ اللَّهُ -؛ لِأَنَّ الْبَاقِيَ بَعْدَ الْإِسْتِثْنَاءِ مَجْهُولٌ، بِخِلَافِ مَا إِذَا بَاعَ وَاسْتَشْنَى نَخْلًا مُعَيَّنًا؛ لِأَنَّ الْبَاقِيَ مَعْلُومٌ بِالْمُشَاهَدَةِ (٥)، قَالَ ﷺ: قَالُوا هَذِهِ رَوَايَةُ الْحَسَنِ (٦) وَهُوَ قَوْلُ الطَّحَاوِيِّ (٧)؛ أَمَّا عَلَى ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ يَنْبَغِي أَنْ يَجُوزَ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ أَنَّ

(١) أي من فساد البيع : أي الحيلة في جوازه فيما إذا حدث قبل القبض ، أن يشتري الأصول لتحصل الزيادة على ملكه ، أي ويستأجر الأرض ، ويقدم الشراء على الإجارة ، فإن قدم الإجارة لا يجوز ؛ لأن الأرض تكون مشغولة بملك الأجر . تبين الحقائق شرح كنز الدقائق ١٢/٤ .

(٢) أي على ملك المشتري ، فإنه يمكنه بيع الأصل بما فيه من الثمر ، فيصير الأصل ملكاً له ، فبعد ذلك ما تولد من الأصل يحدث على ملكه . تحفة الفقهاء للسمرقندي ٥٧ / ٢

(٣) الرطل : بالكسر والفتح لغة : نصف من وعن الأصمعي : هو بالكسر الذي يوزن به ، أو يكال به . قال أبو عبيدة : وزنه مائة درهم وثمانية وعشرون درهماً ، والرطل اثنتا عشرة أوقية ، والأوقية أربعون درهماً فتلك أربع مائة وثمانون درهماً ، الرطل العراقي = ٧١٢٨.٤ درهماً = ٤٠٧.٥ جراماً . المغرب في ترتيب المعرب ١ / ٣٣٣ ، معجم لغة الفقهاء : ٢٢٣ .

(٤) محل الاختلاف : ما إذا استثنى معيناً ، فإن استثنى جزءاً كربع وثلاث ، فإنه صحيح اتفاقاً ، وكذا لو كان الثمر مجزواً واستثنى منه أرطالاً جاز ، وقيد بالأرطال ؛ لأنه لو استثنى رطلاً واحداً جاز اتفاقاً ؛ لأنه استثناء القليل من الكثير ، بخلاف الأرطال لجواز أن لا يكون إلا ذلك القدر ، فيكون استثناء الكل من الكل . البحر الرائق شرح كنز الدقائق ٥ / ٣٢٨ .

(٥) لأنه إذا استثنى قدراً معلوماً كان الباقي مجهولاً وجهالة المعقود عليه يفسد العقد، ولا يشبه هذا إذا استثنى نخلة بعينها؛ لأن الباقي معلوم بالمشاهدة فصح ، ولأن هذا الاستثناء لا يدخل غرر في المبيع ، فلم يمنع صحة العقد . المنتقى شرح الموطأ ٤ / ٢٣٧ .

(٦) الحسن : هو الحسن بن زياد اللؤلؤي الكوفي أبو علي قاضي فقيه من أصحاب أبي حنيفة ، كان فطناً فقيهاً نبياً ، أخذ عنه وسمع منه ، وكان عالماً بمذهبه بالرأي ، من كتبه : أدب القاضي ، ومعاني الإيمان ، والنفقات ، مات - رَحِمَهُ اللَّهُ - سنة أربع ومائتين . تاج التراجم: ٢٢ ، الفوائد البهية: ٦٠ .

(٧) رواية الحسن والطحاوي محمولة على ما إذا لم يكن الثمر منتفعاً به، لأنه ربما يصيبه آفة ، وليس فيه إلا القدر المستثنى فيتطرق فيه الضرر . البحر الرائق شرح كنز الدقائق ٥ / ٣٢٨ .

مَا يَجُوزُ إِيرَادُ الْعَقْدِ عَلَيْهِ بِإِنْفِرَادِهِ يَجُوزُ اسْتِثْنَاؤُهُ مِنَ الْعَقْدِ، وَبَيْعُ قَفِيزٍ مِنْ صُبْرَةٍ جَائِزٌ فَكَذَا اسْتِثْنَاؤُهُ، بِخِلَافِ اسْتِثْنَاءِ الْحِمْلِ (١) وَأَطْرَافِ الْحَيَوَانِ (٢)؛ لِأَنَّهُ لَا يَجُوزُ بَيْعُهُ، فَكَذَا اسْتِثْنَاؤُهُ (٣).

(بيع الغيبات)

وَيَجُوزُ بَيْعُ الْحِنْطَةِ فِي سُنْبُلِهَا وَالْبَاقِلَاءِ (٤) فِي قَشْرِهِ (٥) وَكَذَا الْأُرْزُ وَالسَّمْسِمُ. وَقَالَ الشَّافِعِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ -: لَا يَجُوزُ بَيْعُ الْبَاقِلَاءِ الْأَخْضَرِ (٦)، وَكَذَا الْجَوْزُ وَاللُّوزُ وَالْفُسْتُقُ فِي قَشْرِهِ (١) الْأَوَّلِ عِنْدَهُ (٢)، وَلَهُ فِي بَيْعِ السُّبُلَةِ قَوْلَانِ، وَعِنْدَنَا يَجُوزُ ذَلِكَ كُلُّهُ، لَهُ (٣) أَنَّ الْمَعْقُودَ عَلَيْهِ مَسْتُورٌ بِمَا

(١) من الجارية الحامل أو الشاة .

(٢) كما إذا باع هذه الشاة إلا إلیتها ، وهذا العبد إلا يده ، فيصير مشتركاً متميزاً ، بخلاف ما لو كان مشتركاً على الشيوخ ، فإنه جائز ، وإنما قال : ينبغي ؛ لأن جواب هذه المسألة ليس مصرحاً به في ظاهر الرواية ، وهو إن كل ما جاز إفراده بإيراد العقد عليه جاز استثنائه ، ويصير الباقي مبيعاً ، إلا أن عدم الجواز أقيس بمذهب أبي حنيفة ، في بيع صبرة من طعام كل قفيز بدرهم ، فإنه أفسد البيع بجهالة قدر المبيع ، وقت العقد ، وهو لازم في استثناء أرتال معلومة مما على الأشجار ، وإن لم يفض إلى المنازعة . شرح فتح القدير ٦ / ٢٧٠ .

(٣) وهذا ؛ لأن الاستثناء يقتضى أن يكون المستثنى مقصوداً معلوماً ، وإفراد العقد يقتضى أن يكون المعقود عليه مقصوداً معلوماً فتشاركاً في القصد والعلم ، فما جاز أن يقع معقوداً عليه بانفاده جاز أن يستثنى ، وبالعكس وعلى هذا لو قال : بعثك هذه الصبرة بكذا إلا قفيزاً منها بدرهم صح ، في جميع الصبرة إلا قفيزاً ؛ لأنه استثنى ما يجوز إفراده بالعقد عليه. وأما لو قال : بعثك هذا القطيع من الغنم إلا شاة منها بغير عينها بمائة درهم فلا يجوز ؛ لأنه استثنى ما لا يجوز إفراد العقد عليه . العناية شرح الهداية ٦ / ٢٧٠ ، ٢٧١ .

(٤) الباقلاء : نبات عشبي حولي تؤكل قرونه وكذلك بذوره والباقلاء مثل الفول واللوبياء .

المعجم الوجيز : ٥٨ .

(٥) وهذا إذا باعه بخلاف جنسه ، أما بجنسه فلا يجوز لاحتمال الربا ؛ لأنه لا يدرى قدر ما في السنبل ، ودق السنبل على البائع ؛ لأنه فعل توصل به البائع إلى الأقباض المستحق عليه ، يعنى إذا باعه مكايلة. الجوهرة النيرة شرح مختصر القدوري ١ / ٤٤١ .

(٦) لأن الحب قد يكون صغاراً، وقد يكون كباراً، وقد يكون في بيوته ما لا شيء فيه، وقد يكون فيه حب متغير وذلك غرر من غير حاجة فلم يجز .

المهذب في فقه الإمام الشافعي ١ / ٣٥١ .

لَا مَنْفَعَةَ لَهُ فِيهِ (٤)، فَأَشْبَهَ تُرَابَ الصَّاعَةِ (٥) إِذَا بَاعَ بِجِنْسِهِ، وَلَنَا مَا رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ
وَالسَّلَامُ - (أَنَّهُ نَهَى عَنْ بَيْعِ التَّخْلِ حَتَّى يُزْهِيَ، وَعَنْ بَيْعِ السُّنْبُلِ حَتَّى يَبْيَضَّ وَيَأْمَنَ الْعَاهَةُ) (٦)
وَلِأَنَّهُ حَبٌّ مُنْتَفَعٌ بِهِ فَيَجُوزُ بَيْعُهُ فِي سُنْبُلِهِ كَالشَّعِيرِ وَالْجَامِعُ كَوْنُهُ مَا لَا مُتَقَوِّمًا، بِخِلَافِ تُرَابِ
الصَّاعَةِ (٧)؛ لِأَنَّهُ إِنَّمَا لَا يَجُوزُ بَيْعُهُ بِجِنْسِهِ لِاحْتِمَالِ الرِّبَا، حَتَّى لَوْ بَاعَهُ بِخِلَافِ جِنْسِهِ جَارَ
(٨)، وَفِي مَسْأَلَتِنَا لَوْ بَاعَهُ بِجِنْسِهِ لَا يَجُوزُ أَيْضًا لِشُبْهَةِ الرِّبَا؛ لِأَنَّهُ لَا يَدْرِي قَدَرُ مَا فِي السَّنَابِلِ، وَمَنْ

-
- (١) القشر : قشر الشيء قشراً ، نزع عنه قشره ، وقشر الشيء أزال عنه قشره ، وقشر كل شيء غشائه خلقه وعرضه . الصحاح للجوهري ٢ / ٧٩٢ ، لسان العرب ٥ / ٩٣ .
- (٢) لأنه مجهول القدر مجهول الصفة، وذلك غرر من غير حاجة فلم يجز .
- المهذب في فقه الشافعي ١ / ٣٥٢ .
- (٣) أي : الشافعي .
- (٤) المجموع شرح المهذب ٩ / ٣٧٣ .
- (٥) تراب الصاعَة : المراد به التراب الذي فيه ذرات الذهب والفضة ، أو برادة الذهب والفضة ، ويعنى بذلك أنه لا يجوز لاحتمال الربا ، ولا ينصرف إلى خلاف الجنس تحريماً للجواز ، كما في بيع الدرهم والدينارين بدرهمين ودينار ؛ لأن التراب ليس بمال بمتقوم .
- البنية في شرح الهداية ٧ / ٦٧ ، البحر الرائق شرح كنز الدقائق ٥ / ٣٢٥ .
- (٦) أخرجه مسلم في صحيحه (١١٦٥/٣) كتاب البيوع - باب النهى عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها بغير شرط القطع، رقم ١٥٣٥ ، أبو داود في سننه (٢ / ٢٧٣) كتاب البيوع- باب في بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها، رقم ٣٣٦٨ ، والترمذي في سننه (٣ / ٥٢٩) كتاب البيوع - باب كراهية بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، رقم ١٢٢٦ - ١٢٢٧ ، أحمد في مسنده (٥/٢) رقم ٤٤٩٣ . كلهم من حديث ابن عمر .
- (٧) وأما تراب الصاعَة، فإنما لم يجز بيعه إذا بيع بجنسه؛ لاحتمال الربا لا لاستتاره بما لا ينفعه حتى إذا بيع بخلاف جنسه جاز ؛ لعدم ذلك الاحتمال ، وكذلك نقول في موضع النزاع: إذا بيع بالجنس لا يجوز حتى إذا باع الحنطة في السنبُل بالحنطة، لم يجز لاحتمال الربا . شرح فتح القدير ٦ / ٢٧١ ، البنية في شرح الهداية ٧ / ٦٨ .
- (٨) أن بيع تراب الصاعَة بخلاف الجنس إنما يجوز إذا وجد فيه الذهب والفضة ، وإذا لم يوجد فلا .
- البنية في شرح الهداية ٧ / ٦٨ .

بَاعَ دَارًا دَخَلَ فِي الْبَيْعِ مَفَاتِيحُ إِغْلَاقِهَا (١)؛ لِأَنَّهُ يَدْخُلُ فِيهِ الْإِغْلَاقُ؛ لِأَنَّهَا مُرَكَّبَةٌ فِيهَا لِلْبَقَاءِ
وَالْمِفْتَاحُ يَدْخُلُ فِي بَيْعِ الْعَلْقِ مِنْ غَيْرِ تَسْمِيَةٍ (٢)؛ لِأَنَّهُ بِمَنْزِلَةِ بَعْضٍ مِنْهُ (٣) إِذْ لَا يُنْتَفَعُ بِهِ
بِدُونِهِ (٤).

قَالَ: وَأَجْرُهُ الْكَيْالِ (٥) وَنَاقِدِ (٦) الثَّمَنِ عَلَى الْبَائِعِ (٧)، أَمَّا الْكَيْلُ فَلَا بُدَّ مِنْهُ لِلتَّسْلِيمِ وَهُوَ عَلَى
الْبَائِعِ وَمَعْنَى هَذَا إِذَا بَاعَ مُكَايَلَةً (٨)، وَكَذَا أَجْرَةُ الْوَزَّانِ وَالزَّرَّاعِ (٩) وَالْعَدَّادِ (١٠) وَأَمَّا النَّقْدُ

-
- (١) الإغلاق جمع غلق بالتحريك ، وهو ما يغلق ويفتح بالمفتاح .
لسان العرب ١٠ / ٢٩١ ، تبين الحقائق شرح كنز الدقائق ٤ / ١٠ .
(٢) لأنه كالجزم منه ؛ إذا لا ينتفع به بدونه ، والداخل في الشيء داخل في ذلك الشيء : هذا إذا كانت
الأغلاق مركبة في حيطان الدار ، أما إذا كانت منفصلة فلا تدخل بدون الذكر .
العناية شرح الهداية ٦ / ٢٧٣ ، البناية في شرح الهداية ٧ / ٦٩ .
(٣) أي ؛ لأن المفتاح بمنزلة بعض الغلق . البناية في شرح الهداية ٧ / ٦٩ .
(٤) أي بالغلق بدون المفتاح .
(٥) قيد بالكيل : لأن صب الحنطة في الوعاء على المشتري .
مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر ٢ / ٢١ ، البحر الرائق شرح كنز الدقائق ٥ / ٣٣٠ .
(٦) النقد والتناقد : تمييز الدراهم وإخراج الزيف منها ، ونقدت الرجل الدراهم ، بمعنى : أعطيته ،
ونقدتها له على الزيادة أيضاً فانتهدها ، أي : قبضها . لسان العرب ٣ / ٤٢٥ .
(٧) لأن الكيل لابد منه للتسليم ، وهو على البائع ، وهذا إذا باعه مكايلة ، أما إذا باعه مجازفة فلا يجب
على البائع أجره الكيال ؛ لأنه لا يجب عليه الكيل ؛ فلا تجب عليه أجرته .
الجوهرة النيرة شرح مختصر القدوري ١ / ٤٤١ .
(٨) ولأن التسليم واجب وهو لا يحصل إلا بهذه الأفعال ، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب .
العناية شرح الهداية ٦ / ٢٧٤ ، البناية في شرح الهداية ٧ / ٧٠ ، شرح فتح القدير ٦ / ٢٧٢ .
(٩) لأنه من تمام التسليم وتسليم المبيع عليه . مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر ٢ / ٢١ .
(١٠) العدّ : يقال : عدّ الدراهم وغيرها عدّاً ، وتعداداً ، حسبها وأحصاها ، والعداد : آلة تستعمل لقياس
الزمن أو سرعة الآلات ، وعد الشيء : هيأه وجهزه .
المعجم الوجيز ص : ٤٠٨ .

وَأَيُّهُ ابْنُ رُسْتَمَ (١) عَنْ مُحَمَّدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ؛ لِأَنَّ النَّقْدَ يَكُونُ بَعْدَ التَّسْلِيمِ (٢)؛ أَلَا تَرَى أَنَّهُ يَكُونُ بَعْدَ
الْوَزْنِ وَالْبَائِعِ هُوَ الْمُحْتَاجُ إِلَيْهِ لِيُمَيِّزَ مَا تَعَلَّقَ بِهِ حَقُّهُ مِنْ غَيْرِهِ أَوْ لِيَعْرِفَ الْمَعِيبَ لِيَرُدَّهُ (٣)، وَفِي
رَوَايَةِ ابْنِ سَمَاعَةَ (٤) أَنَّهُ عَلَى الْمُشْتَرِي؛ لِأَنَّهُ يَحْتَاجُ إِلَى تَسْلِيمِ الْجَيِّدِ الْمُقَدَّرِ، وَالْجُودَةَ تُعْرَفُ بِالنَّقْدِ

وإنما تلزم أجرة الكيال على البائع ؛ لأن إيفاء المبيع لازم ، والإيفاء لا يتحقق إلا بالكيل إذا بيع مكيالة
، وكذا أجرة وزن المبيع إذا بيع بشرط الوزن على البائع، وكذا أجرة العداد والذراع إذا بيع بشرط العد
والذرع؛ لأن تحقق الإيفاء بذلك .

البنائية في شرح الهداية ٧ / ٧٠ .

(١) ابن رستم : أبو بكر المروزي، أحد الأعلام، تفقه على محمد بن الحسن، وروى عن أبي عصمة
نوح بن أبي مريم المروزي، وأسد بن عمرو البجلي وهما ممن تفقها على أبي حنيفة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، تفقه عليه
الجم الغفير، وسمع من مالك، والثوري، وشعبة، وحمام، قدم بغداد غير مرة، وحدث بها فروى عنه
إمام أئمة الحديث أبو عبد الله أحمد بن حنبل.

قال الدارمي: سألت يحيى بن معين عن إبراهيم بن رستم فقال : ثقة ، ومات في اليوم العاشر وهو يوم
الأربعاء لعشر بقين من جمادى الآخر سنة إحدى عشرة ومائتين وصلى عليه الأمين محمد الطاهر
. الجواهر المضية في طبقات الحنفية ٣٨/١ ، الفوائد البهية : ٩ ، ١٠ .

(٢) وأما أجرة ناقد الثمن فالمذكور في المختصر رواية ابن رستم عن محمد .

يعنى أن أجرة ناقد الثمن المذكور في مختصر القدوري أنها على البائع. مختصر القدوري: ٧٩

(٣) وجه ذلك: أن النقد يكون بعد الوزن والتسليم ، فالذي يحتاج إلى النقد بعد التسليم هو البائع ؛ لأنه
يحتاج إلى تمييز حقه من الجيد من غير حقه من الرديء ؛ كي يأخذ الجيد لا الرديء ، أو : البائع
يحتاج إلى النقد ؛ لأنه يرده إذا وجده معيباً . تبين الحقائق شرح كنز الدقائق ١٤/٤ .

(٤) ابن سماعة : محمد بن سماعة بن عبيد بن هلال بن وكيع بن بشر التميمي أبو عبد الله ، حافظ
للحديث ثقة ، حدث عن الليث بن سعد ، وأبي يوسف ومحمد، وأخذ الفقه عنهما وعن الحسن بن
زياد، وكتب النوادر عن أبي يوسف ومحمد، ولد سنة ثلاثين ومائة، ومات سنة ثلاث وثلاثين
ومائتين، بلغ هذا السن وهو يركب الخيل ، ويصلى كل يوم مائتي ركعة، وولى القضاء للمأمون
ببغداد، ولما مات قال يحيى بن معين : مات ريحانة العلم من أهل الرأي ، له كتاب: أدب القاضي
، وكتاب المحاضر، والسجلات، والنوادر، وغيرها . تاج التراجم: ٥٤ ، ٥٥ ، الفوائد البهية: ١٧٠ .

كَمَا يُعْرِفُ الْقَدْرُ بِالْوَزْنِ فَيَكُونُ عَلَيْهِ (١)، قَالَ: وَأُجْرَةُ وَزَانِ الثَّمَنِ عَلَى الْمُشْتَرِي (٢) لِمَا بَيَّنَّا أَنَّهُ هُوَ الْمُحْتَاجُ إِلَى تَسْلِيمِ الثَّمَنِ وَالْوَزْنِ يَتَحَقَّقُ التَّسْلِيمُ، قَالَ: وَمَنْ بَاعَ سِلْعَةً بِثَمَنِ قِيلَ لِلْمُشْتَرِي ادْفَعْ الثَّمَنَ أَوَّلًا (٣)؛ لِأَنَّ حَقَّ الْمُشْتَرِي تَعَيَّنَ فِي الْمَبِيعِ (٤) فَيَقْدَمُ دَفْعُ الثَّمَنِ لِتَعَيَّنِ حَقِّ الْبَائِعِ بِالْقَبْضِ (٥) لِمَا أَنَّهُ لَا يَتَعَيَّنُ بِالتَّعَيُّنِ تَحْقِيقًا لِلْمَسَاوَةِ (٦)، قَالَ: وَمَنْ بَاعَ سِلْعَةً (١) بِسِلْعَةٍ (٢)، أَوْ ثَمَنًا

(١) وفي رواية ابن سماعة عن محمد: أجرة النقاد على المشتري؛ لأنه هو المحتاج إلى تسليم الجيد؛ لأن حق البائع في القدر والجودة جميعاً، وإيفاء القدر والجودة على المشتري فكما أن الوزن لإيفاء القدر فكذلك النقد لإيفاء الجودة، فيجب أجرة النقاد على المشتري كما تجب أجرة الوزان عليه؛ لأن الإيفاء عليه، هذا إذا لم يقبضها، فإن كان قد قبضها فعلى البائع؛ لأنه قبض حقه ظاهراً، فإنما يطلب بالنقد، إذا أدى فكان الناقد عاملاً له، فكانت أجرة عمله له.

بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ٥ / ٣٦١، البناءة في شرح الهداية ٧ / ٧٠.

(٢) لأن على المشتري تعيين الثمن له وتوفيقه للبائع، وذلك لا يحصل إلا بالوزن، فكان عمله له فالأجرة عليه. الجوهرة النيرة ١ / ٤٤٢، شرح فتح القدير ٦ / ٢٧٢.

(٣) اعلم أن للبائع حق حبس المبيع إلى أن يستوفي الثمن إذا كان الثمن حالاً، ولا يسلمه إلا إذا سلم المشتري الثمن؛ لأن قضية العقد المساواة بين العاقلين، وحق المشتري يتعين في المبيع، فينبغي أن يتعين حق البائع في الثمن أيضاً، ولا يتعين الثمن إلا بالقبض.

وصورة هذا: أن يقال للبائع: أحضر المبيع ليعلم أنه قائم فإذا أحضر قيل للمشتري: سلم الثمن أولاً. تبیین الحقائق شرح كنز الدقائق ٤ / ١٤.

(٤) فلو كلف المشتري بالدفع مع أن المبيع غائب يتقدم حق البائع في القبض ويتأخر حق المشتري فيه، فلا يجوز ذلك؛ لارتفاع المساواة، ثم المبيع في زمان الحبس من ضمان البائع إلى أن يسلمه إلى المشتري، حتى إذا هلك في يد البائع انتقض البيع، ويعود الثمن إلى المشتري. البناءة في شرح الهداية ٧ / ٧١.

(٥) لأن المشتري إنما أمر الدفع أولاً؛ ليتعين حق البائع في الثمن.

تبیین الحقائق شرح كنز الدقائق ٤ / ١٤.

(٦) لأن الدراهم والدنانير لا يتعينان في عقود المعاوضات عندنا في حق الاستحقاق، وإن عينت، وإنما يتعينان في حق الجنس والقدر والصفة، بخلاف، ما إذا كان الثمن مؤجلاً إذ ليس للبائع حق حبس المبيع؛ لأن بالتأجيل أسقط حقه في الحبس، وكذا إذا كان بعض الثمن حالاً وبعضه مؤجلاً، فله حق حبس البيع إلى استيفاء الحال، ولو سلم المشتري جميع الثمن الحال إلا درهماً، فله حبس جميع المبيع؛ لأن حق الحبس لا يتجزأ.

بِشْمَنِ (٣)، قِيلَ لَهُمَا (٤) سَلِّمَا مَعًا لِاسْتَوَائِهِمَا فِي التَّعِينِ فَلَا حَاجَةَ إِلَى تَقْدِيمِ أَحَدِهِمَا فِي الدَّفْعِ . (٥) .

بَابُ (٦) خِيَارِ الشَّرْطِ (٧) وَدَلِيلِ مَشْرُوعِيَّتِهِ وَمُدَّتِهِ (٨) قَالَ: خِيَارُ الشَّرْطِ جَائِزٌ فِي الْبَيْعِ لِلْبَائِعِ وَالْمُشْتَرِي، وَلَهُمَا الْخِيَارُ (٨)

الجوهرة النيرة شرح مختصر القدوري ١ / ٤٤٢ .

(١) بيع السلعة معجلاً، إما أن يكون بثمن أو بسلعة، فإن كان الأول يقال للمشتري: ادفع الثمن أولاً ؛ لأن حق المشتري تعين في المبيع ؛ فيقدم دفع الثمن ليتعين حق البائع بالقبض ؛ لكونه مما لا يتعين بالتعيين تحقيقاً للمساواة في تعين حق كل واحد منهما ، وفي المالية أيضاً؛ لأن الدين أنقص من العين، وعلى هذا إذا كان المبيع غائباً عن حضرتها فالمشتري، أن يمتنع عن تسليم الثمن حتى يحضر المبيع ليتمكن من قبضه، وإن كان الثاني يقال لهما : سلما معاً . العناية شرح الهداية ٦ / ٢٧٥ - ٢٧٤

(٢) هذا بيع المقايضة .

(٣) ويسمى هذا بيع الصرف .

(٤) أي للبائع والمشتري

(٥) وذلك؛ لأن العاقلين استويا في ثبوت الحق ، ولا مزية لأحدهما على الآخر ، فلا حاجة إلى تقديم أحدهما على الآخر في الدفع ؛ فيؤمران بالدفع معاً ، لأن في الصورة الأولى حق كل واحد منهما متعين قبل القبض، وفي الثانية لا ، أي لأنهما غير متعينين فتساويا. الجوهرة النيرة شرح مختصر القدوري ١ / ٤٤٢ ، مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر ٢ / ٢١ .

(٦) الباب في اللغة: مدخل البيت ومن الكتاب: القسم يجمع مسائل من جنس واحد.

والجمع: أبواب وبيان . المعجم الوجيز : ٦٦ .

واصطلاحاً : اسم لجملة مختصة من الكتاب مشتملة على فصول غالباً .

معنى المحتاج إلى معرفة ألفظ المنهاج ١ / ١١٤ .

وعُرف أيضاً بأنه : طائفة من المسائل الفقهية اشتمل عليها كتاب .

مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر ١ / ٣٧ .

(٧) خيار الشرط: هو أن يشترط أحد العاقلين أو كلاهما لنفسه، أو لغيره حق فسخ العقد مدة معلومة

من الزمان، كأن يقول المشتري مثلاً: اشتريت هذه العين بثمن كذا على أني بالخيار ثلاثة أيام فما

دونها. الجوهرة النيرة شرح مختصر القدوري ١ / ٤٤٣ ، الاختيار لتعليل المختار ٢ / ١٣ .

(٨) ولخيار الشرط أنواع :

ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فَمَا دُونَهَا (١)، وَالْأَصْلُ فِيهِ مَا رُوِيَ: «أَنَّ حَبَّانَ بْنَ مُنْقِدٍ بْنَ عَمْرِو الْأَنْصَارِيِّ كَانَ يُغْبَنُ فِي الْبَيْعَاتِ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: (إِذَا بَايَعْتَ فَقُلْ لَا خِلَابَةَ (٢)، وَلِي الْخِيَارُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ) (٣) (٤)، وَلَا يَجُوزُ أَكْثَرُ مِنْهَا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَهُوَ قَوْلُ زُفَرٍ وَالشَّافِعِيِّ. رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا وَقَالَ (٥):

- فاسد بالاتفاق : كما إذا قال اشتريت على أنى بالخيار أو على أنى بالخيار أياماً ، أو على أنى بالخيار أبداً .

- جائز بالاتفاق : وهو أن يقول على أنى بالخيار ثلاثة أيام فما دونها .

- مختلف فيه : وهو كأن يقول : على أنى بالخيار شهراً ، أو شهرين ، فإنه فاسد عند أبي حنيفة وزفر والشافعي، جائز عند أبي يوسف ومحمد، سواء أكان لأحد العاقلين أم لهما جميعاً ، أو شرط أحدهما الخيار لغيره . العناية شرح الهداية ٢٧٦/٦ ، ٢٧٧ ، والفتاوى الهندية ٣٨/٣ ، رد المحتار على الدر المختار ٥٦٧/٤

(١) قيد بالبيع احترازاً من الطلاق والعناق . الجوهرة النيرة ١ / ٤٤٣ .

(٢) أي الخديعة

(٣) أخرجه مالك في الموطأ (٢ / ٦٨٥) كتاب البيوع - باب جامع البيوع، رقم ١٣٦٨ ، والبخاري

في صحيحه (٢ / ٧٤٥) كتاب البيوع - باب ما يكره من الخداع في البيع، رقم ٢٠١١ ومسلم

في صحيحه (٣ / ١١٦٥) كتاب البيوع - باب من يخدع في البيع، رقم ٥٣٣ ، وأبو داود في

سننه (٢ / ٣٠٤) كتاب الإجارة - باب في الرجل يقول عند البيع لا خِلَابَةَ، رقم ٣٥٠٠.

(٤) وعلق الإمام البائري : مبيناً وجه الاستدلال من هذا الحديث فقال ما نصه : إن شرط الخيار شرط يخالف مقتضى العقد ، وهو اللزوم، وكل ما هو كذلك فهو مفسد إلا أنا جوزناه بهذا النص على خلاف القياس فيقتصر على المدة المذكورة فيه .

هذا وقد أثار البائري : اعتراضاً مفترضاً وأجاب عنه بقوله : فإن قيل : كيف جاز للبائع والمذكور في النص هو المشتري ؟ فكما عديتم فيمن له الخيار فليتعد في مدته .

ويجاب على ذلك : إن في النص إشارة إلى ذلك وهو لفظ المفاعلة؛ ولأن البائع في معنى المشتري في معنى المناط فيلحق به دلالة وكثير المدة ليس كقليلها؛ لأن معنى الفرق يتمكّن بزيادة المدة فيزداد الغرر، وهو مفسد . العناية شرح الهداية ٦ / ٢٧٧ .

(٥) أبي يوسف ومحمد .

يَجُوزُ إِذَا سَمِيَ مُدَّةً مَعْلُومَةً (١) لِحَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ : (أَنَّهُ أَجَازَ الْخِيَارَ إِلَى شَهْرَيْنِ) ، وَلِأَنَّ الْخِيَارَ إِنَّمَا شُرِعَ لِلْحَاجَةِ إِلَى التَّرَوِّي لِيُنْدَفَعَ الْعَبْنُ (٢) ، وَقَدْ تَمَسَّ الْحَاجَةُ إِلَى الْأَكْثَرِ فَصَارَ كَالْتَّأْجِيلِ (٣) فِي الثَّمَنِ (٤) ، وَلِأَبِي حَنِيفَةَ أَنَّ شَرْطَ الْخِيَارِ يُخَالِفُ مُقْتَضَى الْعَقْدِ وَهُوَ الزُّومُ ، وَإِنَّمَا جَوَازُهُ بِخِلَافِ الْقِيَاسِ لِمَا رَوَيْنَاهُ مِنَ النَّصِّ ، فَيُقْتَصَرُ عَلَى الْمُدَّةِ الْمَذْكُورَةِ فِيهِ (٥) وَانْتَفَتْ الزِّيَادَةُ (٦) ؛ إِلَّا أَنَّهُ إِذَا أَجَازَ فِي الثَّلَاثِ جَازَ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ خِلَافًا لِزُفَرٍ ، هُوَ يَقُولُ : إِنَّهُ انْعَقَدَ فَاسِدًا فَلَا يَنْقَلِبُ جَائِزًا ، وَلَهُ أَنَّهُ أَسْقَطَ الْمُفْسِدَ (٧)

- (١) قولهما : بمدة معلومة؛ لأن الخيار إذا كان مجهولاً بأن قال : اشتريت على أنى بالخيار أياماً أو قال: مؤبداً ، فإنه غير جائز اتفاقاً . مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر ٢ / ٢٤ .
- (٢) الغبن في اللغة : بالتسكين في البيع، والغبن بالتحريك في الرأي يقال غبنه في البيع بالفتح أي: خدعه، وقد غبن فهو مغبون ، وغبنته في البيع إذا نقصه فهو غبين أي : ضعيف الرأي . الصحاح في اللغة ٦ / ٢١٧٢ ، مختار الصحاح : ١٩٦ .
- واصطلاحاً : ضربٌ وهو الخداع يراد به ما يجرى بينهم من الزيادة والنقصان ولا يتحرزون عنه .
- طلبة الطلبة في الإصطلاحات الفقهية: للشيخ نجم الدين أبي حفص عمر بن محمد النسفي الحنفي . تحقيق. أبي عبد الله محمد حسن إسماعيل الشافعي : ١١٥ .
- (٣) الأجل : مدة الشيء ووقته الذي يحل فيه ، وهو الوقت المضروب المحدود في المستقبل . قواعد الفقه للبركتي : ١٦٠ .
- (٤) لأن التأجيل في الثمن يجوز في قليل المدة وكثيرها، إن كان يخالف مقتضى العقد؛ لأجل الحاجة فكذا ههنا، والقياس على التأجيل في الثمن غير صحيح؛ لأن الأجل يشترط للقدرة على الأداء، وهي إنما تكون بالكسب، وهو لا يحصل في كل مدة فقد يحتاج إلى مدة طويلة . البناءة في شرح الهداية ٧ / ٧٧ العناية شرح الهداية ٦ / ٢٨٠ .
- (٥) أي يقتصر شرط الخيار لكونه بخلاف القياس على المدة المذكورة في البعض ، لعل النص، وهو ثلاثة أيام، وأراد بالنص حديث حبان . البناءة في شرح الهداية ٧ / ٧٧ .
- (٦) وجواب أبي حنيفة عن هذا، أن ذكر الأجل في الثمن لتحصيل القدرة على الأداء بالكسب أو بدخل غلاته وهي لا تتحقق غالباً وظاهراً في أدنى مدة ، ولهذا جاز الزيادة على الثلاث بخلاف شرط الخيار ؛ فإنه لإبلاء العذر والنظر في أن البيع رابح أو خاسر، ومدة الثلاث تامة في هذا المعنى فلا حاجة إلى الزيادة. تبیین الحقائق ٤ / ١٤ .
- (٧) وهو اشتراط اليوم الرابع .

قَبْلَ تَقَرُّرِهِ (١) فَيَعُودُ جَائِزًا (٢) كَمَا إِذَا بَاعَ بِالرَّقْمِ (٣) وَأَعْلَمَهُ فِي الْمَجْلِسِ، وَلِأَنَّ الْفَسَادَ بِاعْتِبَارِ الْيَوْمِ الرَّابِعِ (٤)، فَإِذَا أَجَازَ قَبْلَ ذَلِكَ لَمْ يَتَّصِلِ الْمُفْسِدُ بِالْعَقْدِ، وَلِهَذَا قِيلَ: إِنَّ الْعَقْدَ يَفْسُدُ بِمُضِيِّ جُزْءٍ مِنْ الْيَوْمِ الرَّابِعِ (٥)، وَقِيلَ يَنْعَقِدُ فَاسِدًا ثُمَّ يَرْتَفِعُ الْفَسَادُ بِحَذْفِ الشَّرْطِ، وَهَذَا عَلَى الْوَجْهِ الْأَوَّلِ، وَلَوْ اشْتَرَى عَلَى أَنَّهُ إِنْ لَمْ يَنْقُذْ (٦) الثَّمَنَ إِلَى ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فَلَا بَيْعَ بَيْنَهُمَا جَازَ، وَإِلَى

(١) أي قبل ثبوته وتحققه ؛ لأن ثبوته بمضي ثلاثة أيام، فيعود جائزاً .

البنية في شرح الهداية ٧ / ٧٨ ، شرح فتح القدير ٦ / ٢٨٠ .

(٢) إذا سقط الخيار قبل دخول اليوم الرابع زال الموجب للفساد فيعود جائزاً ، وهذا ؛ لأن هذا العقد لم يكن فاسداً لعينه بل لما فيه من تغيير مقتضى العقد في اليوم الرابع ، فإذا زال المغير عاد جائزاً .

العناية شرح الهداية ٦ / ١٨١ .

(٣) كما لو باع ثوباً برقمه كيفية ترقيم الثوب : وهو أن يُعلم البائع على الثوب بعلامة كالكتابة ، يعلم بها الدلال أو غيره ثمن الثوب، ولا يعلم المشتري ذلك، فإذا قال : بعثك هذا الثوب برقمه وقبل المشتري من غير أن يعلم المقدار، انعقد البيع فاسداً ، فإن علم المشتري قدر الرقم في المجلس، وقبله انقلب جائزاً بالاتفاق . العناية شرح الهداية ٦ / ٢٨١ .

(٤) هذا تعليل على الرواية الثانية وتقريره : أن اشتراط الخيار غير مفسد للعقد ، وإنما المفسد اتصال اليوم الرابع بالأيام الثلاثة ، فإذا جاز قبل ذلك لم يتصل المفسد بالعقد ؛ فكان صحيحاً . العناية شرح الهداية ٦ / ٢٨٠ - ٢٨١ .

الجواب عما قاس عليه زفر من المسائل: أن الفساد فيها في صلب العقد ؛ لأنه بسبب المبيع وهو البديل ، فلم يكن رفعه وفي مسألتنا في شرطه فأمكن . شرح فتح القدير ٦ / ٢٨١ .

(٥) إن العقد موقوف إلى الإجازة في المدة ، فإذا مضى جزء من اليوم الرابع فحينئذ يفسد العقد. تبين الحقائق شرح كنز الدقائق ٤/١٥، المبسوط للسرخسي ١٣/٦٣، البنية في شرح الهداية ٧/٧٨.

(٦) النقد في اللغة : الإعطاء والإقباض يقال : نقده الدراهم ونقد له الدراهم ، أي أعطاه إياه فانقدها أي : قبضها ، ونقد الدراهم نقداً وانتقدها : أخرج منها الزيف ، ودرهم نقد أي وزان جيد ، وناقده : ناقشه في الأمر . مختار الصحاح : ٢٨١ ، المعجم الوجيز : ٦٢٩ .

واصطلاحاً : هو حق يشترطه العاقد للتمكن من الفسخ؛ لعدم النقد وله صورتان :

أ- أن يقول البائع للمشتري : بعث منك هذا العين بدين لك على ، على أنى متى قضيت الدين فهو لي ، أو يقول البائع : بعثك هذا بكذا ، على أنى متى دفعت لك الثمن تدفع العين إلي .

ب- التعاقد واشترط أن المشتري إذا لم ينقد الثمن إلى مدة معلومة فلا عقد بينهما .

البحر الرائق شرح كنز الدقائق ٦ / ٨ ، الموسوعة الفقهية الكويتية ٢٠ / ١٨١ .

أَرْبَعَةَ أَيَّامٍ لَا يَجُوزُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَبِي يُوسُفَ (١) ، وَقَالَ مُحَمَّدٌ: يَجُوزُ إِلَى أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ أَوْ أَكْثَرَ، فَإِنْ نَقَدَ فِي الثَّلَاثِ جَازَ فِي قَوْلِهِمْ جَمِيعًا (٢)، وَالْأَصْلُ فِيهِ (٣) أَنَّ هَذَا فِي مَعْنَى اشْتِرَاطِ الْخِيَارِ (٤) إِذْ الْحَاجَةُ مَسَّتْ إِلَى الْإِنْفِسَاحِ عِنْدَ عَدَمِ النَّقْدِ تَحَرُّزًا عَنِ الْمُمَاطَلَةِ فِي الْفَسْخِ (٥) فَيَكُونُ مُلْحَقًا بِهِ، وَقَدْ مَرَّ أَبُو حَنِيفَةَ عَلَى أَصْلِهِ فِي الْمُلْحَقِ بِهِ (٦) وَنَفَى الزِّيَادَةَ عَلَى الثَّلَاثِ وَكَذَا مُحَمَّدٌ فِي

(١) لأن هذا في معنى الخيار من حيث أن المقصود منهما التفكير، وشرط فوق الثلاثة مفسد فكذا هذا. مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر ٢ / ٢٥ .

(٢) وهذه المسألة على عدة وجوه :

- إما أن لم يبين الوقت أصلاً ، بأن قال : على أنك ، إن لم تنقد الثمن فلا بيع بيننا .
- أو يبين وقتاً مجهولاً بأن قال : على أنك إن لم تنقد الثمن أياماً فلا بيع ، وفي هذين الوجهين العقد فاسد .

- وإن بين وقتاً معلوماً ، إن كان ذلك الوقت مقدراً بثلاثة أيام، أو دون ذلك بأن قال : على أنه إن لم ينقد الثمن إلى ثلاثة أيام فلا بيع بينهما فالعقد جائز عند علمائنا الثلاثة- رحمهم الله تعالى- .
- والقياس يأبى جواز هذا العقد مع هذا الشرط ، وبه أخذ زفر ؛ لأنه شرط لا يقتضيه البيع وإن ترك المدة أكثر من ثلاثة أيام ، قال أبو حنيفة : البيع فاسد ، وقال محمد : البيع جائز ، فإن نقد في الثلاث جاز في قولهم جميعاً .

المحيط البرهاني في الفقه النعماني ٦ / ٤٨٦ ، الفتاوى الهندية ٣ / ٣٩ .

(٣) أي: في الشراء بشرط أنه إذا لم ينقد الثمن، فلا بيع بينهما. قوله : (إن هذا) أي الشراء بهذا الشرط البنائية في شرح الهداية ٧ / ٨٠ .

(٤) لأن معنى الخيار نقد الثمن على تقدير إجازة البيع ، وعدم نقده على تقدير فسخ البيع ، فكذا هنا إن شاء نقد الثمن فتم البيع ، وإن شاء لم ينقد فانفسخ البيع ، ثم الخيار مشروع للحاجة إلى التروي والحاجة إليه موجودة هنا أيضاً ؛ لأنه يحتاج إلى الفسخ إذا لم يكن الثمن منقوداً ، فيكون مشروعاً، ثم لما كان هذا البيع مشروعاً كان ملحقاً بالخيار ، فجاز إلى الثلاثة كالخيار عند أبي حنيفة، وإلى أكثر من ذلك إذا كانت المدة معلومة، الخيار عند محمد وكذا عند أبي يوسف على قوله الآخر .

البنائية في شرح الهداية ٧ / ٨٠ ، ٨١ .

(٥) أي: عن المدافعة فيه تعليل لقوله : الحاجة مست إلى الانفساخ ، عند عدم النقد ، وكأنه ذكر هذا جواباً لسؤال يرد عليه ، بأن يقال : لا نسلم أن الحاجة ماسة إلى الانفساخ ؛

(٦) أي: في شرط الخيار .

تَجْوِيزِ الزِّيَادَةِ، وَأَبُو يُوسُفَ أَخَذَ فِي الْأَصْلِ بِالْأَثَرِ (١)، وَفِي هَذَا بِالْقِيَاسِ (٢) وَفِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ قِيَاسٌ آخَرٌ وَإِلَيْهِ مَالُ زُفَرٍ وَهُوَ أَنَّهُ بَيْعٌ شُرْطَ فِيهِ إِقَالَةٌ (٣) فَاسِدَةٌ لِتَعَلُّقِهَا بِالشَّرْطِ (٤)، وَاشْتِرَاطُ الصَّحِيحِ مِنْهَا فِيهِ مُفْسِدٌ لِلْعَقْدِ، فَاشْتِرَاطُ الْفَاسِدِ أَوْلَى وَوَجْهُهُ الْإِسْتِحْسَانُ مَا بَيَّنَّا (٥) .

(ملك المبيع في زمن الخيار)

قَالَ: وَخِيَارُ الْبَائِعِ يَمْنَعُ خُرُوجَ الْمَبِيعِ عَنْ مِلْكِهِ (٦)؛ لِأَنَّ تَمَامَ هَذَا السَّبَبِ بِالْمُرَاضَةِ وَلَا يَتِمُّ مَعَ الْخِيَارِ (٧) ،

(١) أي: أخذ أبو يوسف في شرط الخيار ، حيث جوز الزيادة على الثلاثة بأثر ابن عمر؛ لأنه جوز ذلك (٢) أي : وفيما إذا اشترى على أنه إن لم ينقد الثمن إلى أربعة أيام فلا بيع بينهما ، أخذ بالقياس ولم يجوز الزيادة على الثلاثة ، وبيان القياس مر آنفاً .

(٣) الإقالة في اللغة : الفسخ والرفع ، يقال : أقاله يقله إقالة ، وتقايلاً: إذا فسخا البيع وعاد المبيع إلى ملكه ، والثمن إلى المشتري .

لسان العرب ١١/٥٨٠ ، النهاية في غريب الحديث والأثر ٤/١٣٤ .

وفى الاصطلاح : هي فسخ في حق المتعاقدين بيع في حق ثالث .

تبين الحقائق شرح كنز الدقائق ٤ / ٧٠ .

(٤) أي : لتعلق الإقالة ، وهذا بيان فساد الإقالة .

(٥) يعنى : أن هذا البيع لا يجوز إلى ثلاثة أيام أيضاً قياساً ، كما قال زفر ، لكننا جوزناه استحساناً ، ووجهه ما بينا ، وهو أن الحاجة مست إلى الانفساخ عند عدم النقد .

البنية في شرح الهداية ٧ / ٨١ ، ٨٢ ، العناية في شرح الهداية ٦ / ٢٨١ .

(٦) لأن تمام البيع لا يكون إلا بالتراضي؛ لكون الرضا داخلاً في حقيقته الشرعية، ولا تتم المراضاة بالخيار ؛ لأن البيع به يصير علة اسماً ومعنى لا حكماً ، فمنع ابتداء الحكم وهو الملك فيبقى على ملك صاحبه.

تبين الحقائق شرح كنز الدقائق ٤/١٦ ، العناية في شرح الهداية ٦/٢٨٣ .

(٧) إذا كان الخيار للبائع والمشتري جميعاً لم يخرج المبيع عن ملكه ولا الثمن عن ملكهما بالإجماع ولو كان الخيار للبائع، لم يخرج المبيع عن ملكه ولم يدخل في ملك المشتري بالإجماع ، والثمن يزول عن ملك المشتري بالإجماع ، لكن لا يدخل في ملك البائع عند أبي حنيفة، وعندهما يدخل ، ولو كان الخيار للمشتري لم يزل الثمن عن ملكه، ولم يدخل في ملك البائع بالإجماع، وخارج المبيع عن ملك البائع ولم يدخل في ملك المشتري عنده .

وَلِهَذَا يَنْفُذُ عِتْقُهُ (١)، وَلَا يَمْلِكُ الْمُشْتَرِي التَّصَرُّفَ فِيهِ وَإِنْ قَبَضَهُ بِإِذْنِ الْبَائِعِ ، وَلَوْ قَبَضَهُ
الْمُشْتَرِي وَهَلَكَ فِي يَدِهِ فِي مُدَّةِ الْخِيَارِ (٢) ضَمِنَهُ (٣) بِالْقِيَمَةِ؛
لَأَنَّ الْبَيْعَ يَنْفَسَخُ بِالْهَلَاكِ (٤)؛ لِأَنَّهُ كَانَ مُؤَقُّوفاً، وَلَا نَفَاذَ بِدُونِ الْمَحَلِّ فَبَقِيَ مَقْبُوضاً (٥) فِي

وجه قول أبي حنيفة: إن الخيار إذا كان للبائع ، فالمبيع لم يخرج عن ملكه ، وإذا كان للمشتري فالثمن
لم يخرج عن ملكه ، وهذا يمنع دخول الثمن في ملك البائع في الأول ، ودخول المبيع في ملك
المشتري في الثاني لوجهين :

الأول : أنه جمع بين البذل والمبدل في عقد المبادلة، وهذا لا يجوز .
الثاني : أن في هذا ترك التسوية بين العاقلين في حكم المعاوضة ، وهذا لا يجوز؛ لأنهما لا يرضيان
بالتفاوت . بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ٥ / ٣٩٢ ، ٣٩٣ .

(١) لأن خيار البائع يمنع تصرف المشتري في المبيع ، ولا يمنع تصرف البائع مع وجود القبض
المأذون فيه للمشتري ، فدل على أنه لم يزل عن ملك البائع .

ألا ترى أن إعتاق البائع ينفذ فيه ابتداء ، وكل رقبة ينفذ فيها إعتاق الإنسان ابتداء لم تكن ملكاً لغيره ،
كما في سائر عبيده ، وليس خيار الشرط كخيار العيب والرؤية؛ لأن خيار العيب والرؤية لا يمنع
تصرف المشتري فلم يمنع انتقال الملك إليه ، وخيار الشرط للبائع مانع تصرف المشتري ؛ فيمنع
انتقال الملك إليه ، لبقاء ملك البائع فيه بلا اختلال . شرح فتح القدير ٦ / ٢٨٣ .

(٢) وتقييد المصنف الهلاك بكونه في مدة الخيار : ليخرج ما إذا هلك بعدها ، وإنه حينئذ يضمن
بالثمن ؛ لأنه هلك بعدما انبرم المبيع ؛ لعدم فسخ البائع في المدة . شرح فتح القدير ٦ / ٢٨٤ .

(٣) الضمان في اللغة : مصدر ضمن الشيء ضماناً فهو ضامن وضمين إذا كفل به ، وضمن الرجل
ونحوه ضماناً كفله أو التزم أن يؤدي عنه ما يقصر في أدائه . المعجم الوجيز : ٣٨٣ .

واصطلاحاً : هو إعطاء مثل الشيء إن كان من المثليات وقيمته إن كان من القيميات .

درر الحكام في شرح مجلة الأحكام ١ / ٤٤٨ ، قواعد الفقه للبركتي : ٣٥٩ .

(٤) ثم لو هلك المبيع فيما إذا كان الخيار للبائع لا يخلو ، إما أن يكون هلك قبل التسليم إلى المشتري
أو بعده فإن هلك قبل التسليم انفسخ البيع ؛ لأن بهلاك المعقود عليه ينتقض ، وإن هلك بعد التسليم
في مدة الخيار بطل البيع وتلزمه القيمة .

أما بطلان البيع؛ فلأن المعقود عليه صار إلى حالة لا يجوز ابتداء العقد عليه في ذلك الحال ، فلا
تلقحه الإجازة ، وأما لزوم القيمة فهو مذهبنا .

بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ٥ / ٤٠٣ ، البنائة في شرح الهداية ٧ / ٨٣ .

(٥) فبقى مقبوضاً: في يد المشتري لا على وجه الأمانة المحضة كالوديعة والإعارة؟ كما نقل عن ابن
أبي ليلى أنه لم يضمنه ؛ لأنه ما رضى البائع بقبضه إلا على جهة العقد فأقل
ما فيه أن يكون كالمقبوض على سوم الشراء وفي المقبوض على سوم الشراء القيمة إذا هلك وهو

يَدِهِ عَلَى سَوْمِ الشَّرَاءِ وَفِيهِ الْقِيَمَةُ (١)، وَلَوْ هَلَكَ فِي يَدِ الْبَائِعِ انْفُسَخَ الْبَيْعُ وَلَا شَيْءَ عَلَى الْمُشْتَرِي عَتَبًا بِالْبَيْعِ الصَّحِيحِ الْمُطْلَقِ (٢) .

قَالَ: وَخِيَارُ الْمُشْتَرِي لَا يَمْنَعُ خُرُوجَ الْمَبِيعِ عَنْ مِلْكِ الْبَائِعِ ؛ لِأَنَّ الْبَيْعَ فِي جَانِبِ الْآخِرِ لَازِمٌ، وَهَذَا؛ لِأَنَّ الْخِيَارَ إِنَّمَا يَمْنَعُ خُرُوجَ الْبَدَلِ عَنْ مِلْكِ مَنْ لَهُ الْخِيَارُ؛ لِأَنَّهُ شَرَعَ نَظَرًا لَهُ دُونَ الْآخَرِ. قَالَ: إِلَّا أَنَّ الْمُشْتَرِي لَا يَمْلِكُهُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ، وَقَالَا: يَمْلِكُهُ؛ لِأَنَّهُ لَمَّا خَرَجَ عَنْ مِلْكِ الْبَائِعِ فَلَوْ لَمْ يَدْخُلْ فِي مِلْكِ الْمُشْتَرِي يَكُونُ زَائِلًا لَا إِلَى مَالِكٍ وَلَا عَهْدَ لَنَا بِهِ فِي الشَّرْعِ (٣)، وَلِأَبِي حَنِيفَةَ أَنَّهُ لَمَّا لَمْ يَخْرُجِ الثَّمَنُ عَنْ مِلْكِهِ فَلَوْ قُلْنَا بِأَنَّهُ يَدْخُلُ الْمَبِيعُ فِي مِلْكِهِ لَا جَمْعَ الْبَدَلَانِ فِي مِلْكِ رَجُلٍ وَاحِدٍ حُكْمًا لِلْمُعَاوَضَةِ (٤)، وَلَا أَصْلَ لَهُ فِي الشَّرْعِ ؛ لِأَنَّ الْمُعَاوَضَةَ تَقْتَضِي الْمُسَاوَاةَ؛ وَلِأَنَّ الْخِيَارَ شَرَعَ نَظَرًا لِلْمُشْتَرِي لِيَتَرَوَى فَيَقِفَ عَلَى الْمَصْلَحَةِ (٥)، وَلَوْ ثَبَتَ الْمِلْكُ رُبَّمَا يَعْتَقُ عَلَيْهِ مِنْ غَيْرِ اخْتِيَارِهِ بِأَنَّهُ كَانَ قَرِيبَهُ فَيَفُوتُ النَّظَرُ، قَالَ: فَإِنْ هَلَكَ فِي يَدِهِ هَلَكَ بِالثَّمَنِ (٦)، وَكَذَا إِذَا دَخَلَهُ عَيْبٌ (١)

قيمي والمثل في المثل إذا كان القبض بعد تسمية الثمن أما إذا لم يسم ثمن فلا ضمان في الصحيح . شرح فتح القدير ٦ / ٢٨٣ .

(١) ثم لزوم القيمة على المشتري فيما إذا لم يكن المبيع مثلياً ، أما إذا كان مثلياً فيلزمه المثل ، وهذا إذا هلك في مدة الخيار ، أما إذا هلك بعدها يلزمه الثمن لا القيمة ؛ لأن العقد قد لزم وانبرم

(٢) قوله : (اعتباراً بالصحيح المطلق) أي بالبيع الصحيح المطلق عن الخيار ، فإن البيع يفسخ بهلاك المبيع ثمة فكذا هنا ، وإنما قيد بالصحيح وإن كان حكم الفاسد كذلك ، لما أن الأصل المعتبر به الذي يقاس عليه غيره هو الصحيح لا الفاسد .

(٣) لهما أن الخيار شرع بسبيل النظر لمن شرط له الخيار ، والنظر له في منع الخيار : زوال ملكه عنه لا في منعه دخول شيء في ملكه ، ولأن الملك يزول عن البائع بالاتفاق فإن لم ينتقل إلى المشتري كان زائلاً لا إلى مالك فلا يجوز ؛ لأنه لا نظير له في الشرع .

تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق ٤ / ١٦ ، الجوهرة النيرة شرح مختصر القدوري ١ / ٤٤٥ .

(٤) احتراز عن الضمان في غصب المدبر . البناءة في شرح الهداية ٧ / ٨٥ .

(٥) ورجح قول أبي حنيفة : بأن شرعية الخيار نظراً للمشتري ؛ ليتروى فيقف على المصلحة ، فلو دخل في ملكه ربما يكون عليه لا له ، بأن كان المبيع قريبه ، فيعتق عليه من غير اختياره ، فعاد على موضوعه بالنقض . العناية شرح الهداية ٦ / ٢٨٥ - ٢٨٦ .

(٦) إن هلك المبيع في يد المشتري هلك بالثمن ، وسواء هلك في مدة الخيار ، عدها ، فعليه الثمن في الوجهين . ، البناءة في شرح الهداية ٧ / ٨٦ .

بِخِلَافِ مَا إِذَا كَانَ الْخِيَارُ لِلْبَائِعِ. وَوَجْهُ الْفَرْقِ (٢) أَنَّهُ إِذَا دَخَلَهُ عَيْبٌ يَمْتَنِعُ الرَّدُّ، وَالْهَلَاكُ لَا يَعْرِى (٣) عَنْ مُقَدِّمَةِ عَيْبٍ فِيهِلِكُ، وَالْعَقْدُ قَدْ انْبَرَمَ (٤) فَيَلْزِمُهُ الثَّمَنُ (٥)، بِخِلَافِ مَا تَقَدَّمَ؛ لِأَنَّ بِدُخُولِ الْعَيْبِ لَا يَمْتَنِعُ الرَّدُّ حُكْمًا بِخِيَارِ الْبَائِعِ فِيهِلِكُ وَالْعَقْدُ مُؤَقُّوفٌ، قَالَ: وَمَنْ اشْتَرَى امْرَأَتَهُ عَلَى أَنَّهُ بِالْخِيَارِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ لَمْ يَفْسُدِ النِّكَاحُ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَمْلِكْهَا لِمَا لَهُ مِنَ الْخِيَارِ (وَأِنْ وَطَّهَا لَهُ أَنْ يَرُدَّهَا)؛ لِأَنَّ الْوُطْءَ بِحُكْمِ النِّكَاحِ (إِلَّا إِذَا كَانَتْ بِكْرًا)؛ لِأَنَّ الْوُطْءَ يُنْقِصُهَا، وَهَذَا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ (وَقَالَ: يَفْسُدُ النِّكَاحُ)؛ لِأَنَّهُ مَلَكَهَا (وَأِنْ وَطَّهَا لَمْ يَرُدَّهَا)؛ لِأَنَّ وَطْأَهَا يَمْلِكُ الْيَمِينَ فَيَمْتَنِعُ الرَّدُّ (٦) وَإِنْ كَانَتْ ثَيِّبًا: وَلِهَذَا الْمَسْأَلَةُ أَخَوَاتُ (٧) كُلُّهَا تَبْتَنِي عَلَى وَقُوعِ الْمَلِكِ لِلْمُشْتَرِي بِشَرْطِ الْخِيَارِ وَعَدَمِهِ: مِنْهَا عِتْقُ الْمُشْتَرَى عَلَى الْمُشْتَرِي إِذَا كَانَ قَرِيبًا (٨)

(١) أي إذا دخل المبيع العيب في يد المشتري والخيار له ، يجب الثمن ، لأنه صار بذلك ممسكاً ببعضه ، فلو رده لتفرقت الصفقة على البائع قبل الإتمام ، وهو لا يجوز ، فلزم البيع وسقط الخيار والمراد من العيب عيب لا يرتفع ، كقطع اليد مثلاً . البحر الرائق ٦ / ١٥ .

(٢) أي بين ما إذا كان الخيار للمشتري ، وهلك في يده ، حيث يجب الثمن وبين ما إذا كان الخيار للبائع ، وهلك في يد المشتري ، حيث تجب القيمة وقد بينا الفرق آنفاً .
العناية شرح الهداية ٦ / ٢٨٥ - ٢٨٦ ، البناية في شرح الهداية ٧ / ٨٧ .

(٣) يعرى : يقال عرى الرجل من ثيابه من باب تعب عريا ، عرية فهو عار وعرى من العيب يعرى فهو عر من باب تعب إذ سلم منه ، والعراء بالمد المكان المتسع الذي لا ستر به . المصباح المنير ٢ / ٤٠٦ .

(٤) أبرمت الأمر إبراماً أي أحكمته . المصباح المنير ١ / ٤٥ .

(٥) دخله عيب في مدة الخيار فتعذر رده ، فيلزمه الثمن لانبرام العقد . البناية ٧ / ٨٦ .

(٦) الجامع الصغير لمحمد بن الحسن الشيباني ١ / ٣٤٤ .

وجه البيان : أن خيار المشتري لما منع دخول المبيع في ملكه عنده ، فالمشتري لم يملك زوجته عنده ، فلا يفسد النكاح ، ويكون الوطء حاصلاً بحكم ملك النكاح ، لا بملك اليمين ، فيضاف إلى البائع ، فلا يمنع الرد ، عندهما خيار المشتري ، لما لم يمنع دخول المبيع في ملك المشتري ، ملك المشتري امرأته فيفسد النكاح ، وكان الوطء حاصلاً بحكم ملك اليمين ، فيمنع الرد . المحيط البرهاني في الفقه النعماني ٦ / ٤٨٨ .

(٧) أي نظائر البناية في شرح الهداية ٧ / ٨٩ .

(٨) أي قرابة محرمة . تبين الحقائق شرح كنز الدقائق ٤ / ١٧ .

لَهُ فِي مُدَّةِ الْخِيَارِ (١) ، وَمِنْهَا: عِتْقُهُ إِذَا كَانَ الْمُشْتَرِي حَلَفَ إِنْ مَلَكَتْ عَبْدًا فَهُوَ حُرٌّ، بِخِلَافِ مَا إِذَا قَالَ: إِنْ اشْتَرَيْتُ فَهُوَ حُرٌّ؛ لِأَنَّهُ يَصِيرُ كَالْمُنْشِيِّ لِلْعِتْقِ بَعْدَ الشَّرَاءِ فَيَسْقُطُ الْخِيَارُ (٢)، وَمِنْهَا أَنَّ حَيْضَ الْمُشْتَرَاةِ فِي الْمُدَّةِ لَا يُجْتَنَزُّ بِهِ عَنِ الْإِسْتِبْرَاءِ عِنْدَهُ (٣) وَعِنْدَهُمَا يُجْتَنَزُّ؛ (٤) وَلَوْ رُدَّتْ بِحُكْمِ الْخِيَارِ إِلَى الْبَائِعِ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ الْإِسْتِبْرَاءُ عِنْدَهُ (٥)، وَعِنْدَهُمَا يَجِبُ إِذَا رُدَّتْ بَعْدَ الْقَبْضِ (٦)، وَمِنْهَا إِذَا وَلَدَتْ الْمُشْتَرَاةُ فِي الْمُدَّةِ بِالنِّكَاحِ لَا تَصِيرُ أُمًّا وَلَدٍ لَهُ عِنْدَهُ (١) خِلَافًا

(١) يعنى إذا اشترى ذا رحم محرم منه ، بشرط الخيار ، لا يعتق عليه فى مدة الخيار ؛ لأنه لم يملكه ، وخياره كما كان ، فإن فسخ البيع عاد إلى ملك البائع ، وإن أجاز عتق عليه ، ولزمه الثمن ، وعندهما يعتق عليه من زمان الشراء ؛ لأنه ملكه ، ويلزمه الثمن ، ولا يبقى خياره . بدائع الصنائع للکاساني ٥ / ٣٩٣ .

(٢) يعنى إذا قال : إن ملكت عبداً فهو حر ، ثم اشترى عبداً بشرط الخيار ، لا يعتق عند أبى حنيفة في مدة الخيار ؛ لأنه لم يملكه ، خلافاً لهما ، وهذا بخلاف ما إذا قال : إن اشتريتك فأنت حر ، فاشتراه بالخيار ، يعتق عليه ، ويبطل خياره ، ويلزمه الثمن بالإجماع ، أما عندهما فلا يشكل ؛ لأنه حنث بالشراء ؛ لأن المعلق بالشرط كالمنطوق به عند وجود الشرط ، فكأنه قال بعد الشراء - وله الخيار - أنت حر ، وأما عند أبى حنيفة - رَحِمَهُ اللهُ - فيعتق ؛ لأن المعلق بالشرط كالمرسل ، عند وجود الشرط ولو أرسل العتق بعد شرائه ، بشرط الخيار ينفذ عتقه . الجوهرة النيرة ١ / ٤٤٧ ، بدائع الصنائع ٥ / ٣٩٣ .

(٣) إذا اشترى جارية بالخيار ثلاثة أيام ، وقبضها ، فحاضت عنده في مدة الخيار ، أو حصل فيها بعض الحيضة في مدة الخيار ، فاخترها وصارت للمشتري فلا يجتزأ بتلك الحيضة من الاستبراء ، وعليه أن يستبرئها بحيضة أخرى عند أبى حنيفة ، لأنها لم تدخل في ملكه عنده ، ولم يوجد سبب الاستبراء . بدائع الصنائع ٥ / ٣٩٤ .

(٤) لأنها دخلت في ملكه ، فكانت الحيضة بعد وجود سبب وجوب الاستبراء ، فكانت محسوبة منه . بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ٥ / ٣٩٤ .

(٥) لأنه إنما يجيب بتجديد الملك ، ولم يوجد حيث لم تدخل في ملك غيره ، فكأنه لم يزل ملك البائع . رد المحتار على الدر المختار ٤ / ٥٧٨ ، الاختيار لتعليل المختار ٢ / ١٥ .

(٦) وإن كان الفسخ بعد القبض وجب على البائع استبرأؤها قياساً واستحساناً لاستحداث الملك بعد ملك المشتري الملك المؤكد بالقبض ، فيثبت توهم الشغل شرح فتح القدير ٦ / ٢٨٧ .

لَهُمَا (٢)، وَمِنْهَا إِذَا قَبِضَ الْمُشْتَرِي الْمَبِيعَ بِإِذْنِ الْبَائِعِ ثُمَّ أَوْدَعَهُ عِنْدَ الْبَائِعِ فَهَلَكَ فِي يَدِهِ فِي الْمُدَّةِ هَلَكَ مِنْ مَالِ الْبَائِعِ لَارْتِفَاعِ الْقَبْضِ بِالرَّدِّ لِعَدَمِ الْمَلِكِ عِنْدَهُ (٣)، وَعِنْدَهُمَا مِنْ مَالِ الْمُشْتَرِي لِصِحَّةِ الْإِيدَاعِ بِاعْتِبَارِ قِيَامِ الْمَلِكِ (٤)، وَمِنْهَا لَوْ كَانَ الْمُشْتَرِي عَبْدًا مَأْذُونًا لَهُ فَأَبْرَأَهُ (٥) الْبَائِعُ مِنَ الثَّمَنِ فِي الْمُدَّةِ بَقِيَ عَلَى خِيَارِهِ عِنْدَهُ؛ لِأَنَّ الرَّدَّ امْتِنَاعٌ عَنِ التَّمَلُّكِ وَالْمَأْذُونُ لَهُ يَلِيهِ، وَعِنْدَهُمَا بَطْلُ خِيَارِهِ؛ لِأَنَّهُ لَمَّا مَلَكَهُ كَانَ الرَّدُّ مِنْهُ تَمْلِيكًا بغيرِ عَوْضٍ وَهُوَ لَيْسَ مِنْ أَهْلِهِ، وَمِنْهَا إِذَا اشْتَرَى ذِمِّيٌّ مِنْ ذِمِّيٍّ خَمْرًا عَلَى أَنَّهُ بِالْخِيَارِ ثُمَّ أَسْلَمَ بَطْلَ الْخِيَارِ عِنْدَهُمَا؛ لِأَنَّهُ مَلَكَهَا فَلَا يَمْلِكُ رَدَّهَا وَهُوَ مُسْلِمٌ. وَعِنْدَهُ يَبْطُلُ الْبَيْعُ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَمْلِكْهَا فَلَا يَتَمَلَّكُهَا بِإِسْقَاطِ الْخِيَارِ بَعْدَهُ وَهُوَ مُسْلِمٌ (٦)،

(١) لأنها لم تدخل في ملكه ، وهو على خياره ، إن شاء فسخ البيع وعادت إلى ملك البائع ، وإن شاء أجزاه ، وصارت أم ولد له ، ولزمه الثمن ، وعندهما صارت أم ولده بنفس الشراء ؛ لأنها دخلت في ملكه ، فبطل خياره ولزمه الثمن . بدائع الصنائع ٥ / ٣٩٣ .

(٢) ومحله : ما إذا كان قبل القبض ، أما بعده فسقط الخيار اتفاقاً ، وتصير أم ولد للمشتري ؛ لأنها تعيبت عنده بالولادة .

البحر الرائق شرح كنز الدقائق ٦ / ١٧ ، مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر ٢ / ٢٧ .

(٣) لأن القبض قد ارتفع بالرد ؛ إذ الوديعة لم تصح ؛ لعدم ملك المودع ، وإذا ارتفع القبض كان هلاك المبيع قبل القبض وأنه من مال البائع . العناية شرح الهداية ٦ / ٢٨٨ .

(٤) وقالوا : يهلك على المشتري ويلزمه الثمن ؛ لأن من مذهب أبي حنيفة أنه لم يملكه المشتري وارتفع قبضه بالرد على البائع ، فهلك المبيع قبل القبض ، وهلاك المبيع قبل القبض يبطل البيع . شرح فتح القدير ٦ / ٢٨٨ .

(٥) الإبراء في اللغة: التخلص يقال براء إذا تنزه وتباعد وأبرأ فلان فلاناً من حق له عليه خلصه منه. لسان العرب ١ / ٣٣ ، المعجم الوجيز : ٤٢ .

واصطلاحاً : إسقاط الشخص حقاً له في ذمة آخر ، أو هو أن يبرئ أحداً آخر من تمام حقه الذي له في ذمته أو يحط مقدار منه عن ذمته . درر الحكام شرح مجلة الأحكام ٤ / ١٤ ،

(٦) وجملته ما قال في ذمى اشترى من ذمى خمرًا أو خنزيراً ؛ فإن الشراء لا يخلو: إما أن يسلم أو يسلم أحدهما قبل قبض الخمر أو الخنزير ، بطل البيع في الأحوال كلها ، سواء كان البيع باتاً، أو بشرط الخيار لهما أو لأحدهما ؛ لأنهما أسلما والحرام غير مقبوض والإسلام يلاقي الحرمة القائمة بالرد ، والفائنة بالعفو .

قَالَ: وَمَنْ شَرِطَ لَهُ الْخِيَارُ فَلَهُ أَنْ يَفْسَخَ (١) فِي الْمُدَّةِ وَلَهُ أَنْ يُجِيرَ، فَإِنْ أَجَازَهُ بغيرِ حَضْرَةِ (٢) صَاحِبِهَا جَازَ، وَإِنْ فُسِّخَ لَمْ يَجْزُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ الْآخِرُ حَاضِرًا (٣) عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَمُحَمَّدٍ، وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ: يَجُوزُ (٤) وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ وَالشَّرْطُ هُوَ الْعِلْمُ، وَإِنَّمَا كُنِيَ بِالْحَضْرَةِ عَنْهُ، لَهُ أَنَّهُ مُسَلَّطٌ

ولو أسلما أو أسلم أحدهما بعد القبض، فإنه ينظر: إن كان العقد باتاً لا خيار فيه، جاز العقد ، ولا يبطل ؛ لأنهما أسلما ، والحرام غير مقبوض ، وإن كان العقد بشرط الخيار للبائع ، فأسلم البائع بطل البيع ، لما ذكرنا أن المبيع لم يخرج من ملك البائع ، والإسلام منع إخراجه عن ملكه بالعقد ، ولو أسلم المشتري فلا يبطل العقد ، وخيار البائع على حاله ؛ لأن العقد من جانب المشتري بات فإن اختار البائع الفسخ عادت الخمر إليه ، وإن اختار الإجازة صارت الخمر للمشتري حكماً ، والمسلم من أهل أن يمتلك الخمر حكماً ، كما يمتلك بالميراث ، وإن كان الخيار للمشتري فأسلم المشتري ، بطل العقد في قول أبي حنيفة ، وقالوا : يتم العقد ولا يبطل ؛ لأن من مذهب أبي حنيفة أن المشتري لم يملكه ، فالإسلام يمنعه من تملك الخمر بالعقد وعندهما ملكه ، والإسلام منعه من إخراجه من ملكه ، إن أسلم البائع حكماً لا يبطل بالإخراج وخيار المشتري على حاله ؛ لأن العقد من جانب البائع بات ، فإن اختار المشتري البيع ، صار له ، وإن فسخ البيع صار الخمر للبائع حكماً ، والمسلم من أهل أن يمتلك الخمر حكماً ، ولو شرط الخيار لهما جميعاً ، فإن المبيع لا يخرج من ملك البائع ، والتمن أيضاً لا يزول من ملك المشتري . تبين الحقائق ٤ / ١٧ ، ١٨ ، بدائع الصنائع ٥ / ٣٩٤ ، ٣٩٥ .

(١) أي : العقد .

(٢) يريد بغير علمه في مدته ، بالقول أو الفعل ، كتصرف البائع في الثمن ، والمشتري في البيع ، وإن لم يعلم صاحبه بالاتفاق ؛ لكونه راضياً وقت إثبات الخيار .

مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر ٢ / ٢٨ .

والمراد من الحاضرة : علم صاحبه أو علم من يقوم مقامه عند الطرفين ؛ لأن الفسخ تصرف في حق صاحبه ، وإذا لا يجوز بدون علمه ، كالوكيل إذا عزل الموكل ، لا يثبت حكم عزله في حقه ما لم يعلم فالخيار باق على حاله . مجمع الأنهر ٢ / ٢٩ .

(٣) نفس الحضور ليس بشرط، وإنما الشرط علمه بالفسخ في المدة، وإن لم يعلم إلا بعدها فقد تم البيع .
الجوهرة النيرة شرح مختصر القدوري ١ / ٤٤٩ .

(٤) والخلاف في جوازه بغير علم الآخر هو الفسخ بالقول في المدة ، بأن يقول: فسخت، أو رددت البيع وغير ذلك مما يدل على رد البيع ، وأما الفسخ بالفعل فيجوز بغير علمه اتفاقاً . شرح فتح القدير ٦ / ٢٩١ .

عَلَى الْفَسْخِ مِنْ جِهَةِ صَاحِبِهِ فَلَا يُتَوَقَّفُ عَلَى عِلْمِهِ كَالْإِجَازَةِ (١)، وَلِهَذَا لَا يُشْتَرَطُ رِضَاهُ وَصَارَ كَالْوَكِيلِ بِالْبَيْعِ، وَلَهُمَا أَنَّهُ تَصَرَّفَ فِي حَقِّ الْغَيْرِ وَهُوَ الْعَقْدُ بِالرَّفْعِ، وَلَا يَغْرَى عَنِ الْمَضَرَّةِ؛ لِأَنَّهُ عَسَاهُ يَعْتَمِدُ تَمَامَ الْبَيْعِ السَّابِقِ فَيَتَصَرَّفُ فِيهِ فَتَلَزُمُهُ غَرَامَةُ الْقِيَمَةِ بِالْهَلَاكِ فِيمَا إِذَا كَانَ الْخِيَارُ لِلْبَائِعِ، أَوْ لَا يَطْلُبُ لِسَلْعَتِهِ مُشْتَرِيًا فِيمَا إِذَا كَانَ الْخِيَارُ لِلْمُشْتَرِيِ، وَهَذَا نَوْعُ ضَرَرٍ (٢) فَيَتَوَقَّفُ عَلَى عِلْمِهِ وَصَارَ كَعَزْلِ الْوَكِيلِ (٣)، بِخِلَافِ الْإِجَازَةِ لِأَنَّهُ لَا إِزَامَ فِيهِ (٤)، وَلَا نَقُولُ إِنَّهُ مُسَلَّطٌ، وَكَيْفَ يُقَالُ ذَلِكَ وَصَاحِبُهُ لَا يَمْلِكُ الْفَسْخَ وَلَا تَسْلِيْطَ فِي غَيْرِ مَا يَمْلِكُهُ الْمُسَلَّطُ (٥) (٦)، وَلَوْ كَانَ فَسْخٌ فِي حَالِ غَيْبَةِ صَاحِبِهِ وَبَلَغَهُ فِي الْمُدَّةِ تَمَّ الْفَسْخُ لِحُصُولِ الْعِلْمِ بِهِ، وَلَوْ بَلَغَهُ بَعْدَ مُضِيِّ الْمُدَّةِ تَمَّ الْعَقْدُ

(١) والدليل على التسليط أنه لا يشترط رضا صاحبه في الفسخ.

تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق ٤ / ١٨ .

والحيلة في جوازه : أن يأخذ منه وكيلاً حتى إذا بدا له الفسخ رده عليه.

تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق ٤ / ١٨ ، رد المحتار على الدر المختار ٤ / ٥٧٩ .

(٢) الضرر في اللغة : ضد النفع والمضرة خلاف المنفعة ، وضربه يضره ضرراً ، وأضر به وضاره ،

مضارة ، وضرراً بمعنى والاسم الضرر ، وقيل: الضرر ما تضرر به صاحبك وتنتفع به أنت ،

والضرر أن تضره من غير أن تنتفع به. لسان العرب ٤ / ٤٨٢ .

واصطلاحاً : هو الذي يصيب الإنسان في نفسه ، أو في بدنه . معجم لغة الفقهاء : ٥٢ .

(٣) يعني إذا عزل الموكل الوكيل ، فقد يتوقف العزل على علم الوكيل ؛ حتى لا يتضرر بلزوم الثمن

عليه ، إذا كان وكيلاً بالشراء ، ويبطلان.

(٤) بيان الضرر والغرر أن المشتري إذا فسخ بلا علم البائع ، ربما لا يطلب البائع لسعته مشترياً،

وفيه نوع ضرر ، وإذا فسخ البائع بلا علم المشتري ، يتصرف المشتري في البيع اعتماداً على البيع

السابق ، فيغرم قيمته إذا هلك ، وربما تكون القيمة أكثر من ذلك الثمن

وفيه الضرر والغرر تبين الحقائق ٤ / ١٨ ، العناية شرح الهداية ٦ / ٤٢٩ .

(٥) المراد من سلطه: أذن له التصرف في حقه ذلك بالرفع في المدة ، فإذا منع تضمن شرط الخيار

الإذن بلا علمه للضرر ، فكان الإذن مقيداً بعدم محل الضرر ، وهو حال العلم . شرح فتح القدير

٦ / ٢٩٢ .

(٦) ولأن التسليط على الفسخ ممن لا يملكه غير معقول ، ولا مشروع ، كالتملك من غير المالك؛

بخلاف الوكيل فإنه يملكه .

العناية شرح الهداية ٦ / ٢٩١ ، المبسوط للسرخسي ١٣ / ٤٥ .

بِمُضِيِّ الْمُدَّةِ قَبْلَ الْفَسْخِ، قَالَ: (وَإِذَا مَاتَ مَنْ لَهُ الْخِيَارُ (١) طَلَّ خِيَارُهُ (٢) وَلَمْ يَنْتَقِلْ إِلَى وَرَثَتِهِ (٣)، وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: يُورَثُ عَنْهُ (٤)؛ لِأَنَّهُ حَقٌّ لَا زِمَ ثَابِتٌ فِي الْبَيْعِ فَيَجْرِي فِيهِ الْإِرْثُ كَخِيَارِ الْعَيْبِ وَالتَّعْيِينِ (٥) (٦) ، وَلَنَا أَنَّ الْخِيَارَ لَيْسَ إِلَّا مَشِيئَةً وَإِرَادَةً وَلَا يَتَصَوَّرُ انْتِقَالُهُ، وَالْإِرْثُ فِيمَا يَقْبَلُ الْإِنْتِقَالَ (٧)؛ بِخِلَافِ خِيَارِ الْعَيْبِ؛ لِأَنَّ الْمَوْرَثَ اسْتَحَقَّ الْمَبِيعَ سَلِيمًا فَكَذَا الْوَارِثُ، فَأَمَّا نَفْسُ الْخِيَارِ لَا يُورَثُ، وَأَمَّا خِيَارُ التَّعْيِينِ .

- (١) هذا التعبير يتناول البائع والمشتري وغيرهما جميعاً ، فإن كان الخيار للبائع دخل الثمن في ملك ورثته، وإن كان الخيار للمشتري دخل المبيع في ملك ورثته في التركة وللبيع الثمن في التركة ، إن لم يكن قبضه ، وإن مات من لا خيار له ، فالآخر على خياره بالإجماع ، فإن أمضى البيع مضى، وإن فسخه انفسخ. حاشية الطحاوي على الدر المختار ٣/٣٥، شرح فتح القدير ٦/٢٩٤ .
- (٢) وتم البيع من قبله أيهما كان؛ لأن بالموت ينقطع الخيار، وقطعه يوجب تمام البيع كما لو انقضت المدة ، فإن كانا جميعاً بالخيار فمات أحدهما، تم البيع من قبله والآخر على خياره، فإن مات جاز عليه. الجوهرة النيرة شرح مختصر القدوري ١ / ٤٤٩ .
- (٣) والمراد بنفي التوريث عندنا ، أن العقد لا يفسخ بفسخ الوارث ، كما كان يفسخ بفسخ المورث حياته . تبين الحقائق شرح كنز الدقائق ٤ / ١٨ .
- (٤) لأنه حق لازم يختص بالمبيع ، فانقل بالموت إلى الوارث ، كحبس المبيع إلى أن يحضر الثمن. المذهب في فقه الإمام الشافعي ١ / ٣٧٧ .
- (٥) خيار التعيين : شراء أحد الشيئين أو الثلاثة على أن يعين أيهما شاء .
- درر الحكام في شرح مجلة الأحكام ١ / ٣١١ .
- (٦) له: أنه حق من حقوق الملك فيجرب فيه الإرث كخيار العيب والرؤية، وكخيار التعيين ، فإنه يورث، فكذا هنا كما إذا اشترى أحد الثوبين على أن المشتري بالخيار في أحدهما ، يأخذ أيهما شاء، بثمن معلوم ويرد الآخر. البناء في شرح الهداية ٧/٩٩، العناية شرح الهداية ٦ / ٢٩٣ .
- (٧) ولنا: أن الإرث إنما يكون فيما يتصور انتقاله ، لا فيما لا يتصور انتقاله ، ، فلا يجري فيه الإرث ، وإنما قلنا : إن الإرث فيما يتصور انتقاله ، بدليل أن سائر تصرفات المورث من القدرة والعلم ، ونحو ذلك لا تورث ، وكذا منكوحته لا تورث .
- وإنما قلنا : إن الخيار لا يتصور انتقاله ؛ لأن خيار من له الخيار عبارة عن مشيئته وإرادته في الفسخ والإجازة ، ومشيئته قد انقطعت بالموت كسائر صفاته ، فلم يجز الإرث في الخيار ولأنه مدة

يُثْبِتُ لِلْوَارِثِ ابْتِدَاءً (١)، لاختِلَاطِ مِلْكِهِ بِمِلْكِ الْغَيْرِ لَا أَنْ يُورَثَ الْخِيَارُ ، قَالَ: وَمَنْ اشْتَرَى شَيْئًا وَشَرَطَ الْخِيَارَ لِغَيْرِهِ (٢) فَأَيُّهُمَا (٣) أَجَازَ الْخِيَارَ وَأَيُّهُمَا نَقَضَ انْتَقَضَ وَأَصْلُ هَذَا أَنَّ اشْتِرَاطَ الْخِيَارِ لِغَيْرِهِ جَائِزٌ اسْتِحْسَانًا، وَفِي الْقِيَاسِ لَا يَجُوزُ وَهُوَ قَوْلُ زُفَرٍ (٤) ؛ لِأَنَّ الْخِيَارَ مِنْ مَوَاجِبِ الْعَقْدِ وَأَحْكَامِهِ (٥)، فَلَا يَجُوزُ اشْتِرَاؤُهُ لِغَيْرِهِ كَاشْتِرَاطِ الثَّمَنِ عَلَى غَيْرِ الْمُشْتَرِي، وَلَنَا أَنَّ الْخِيَارَ لِغَيْرِ الْعَاقِدِ لَا يَثْبُتُ إِلَّا بِطَرِيقِ النِّيَابَةِ عَنِ الْعَاقِدِ فَيَقْدَرُ الْخِيَارُ لَهُ اقْتِضَاءٌ ثُمَّ يُجْعَلُ هُوَ نَائِبًا عَنْهُ تَصْحِيحًا لِتَصَرُّفِهِ، وَعِنْدَ ذَلِكَ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا الْخِيَارُ، فَأَيُّهُمَا أَجَازَ جَازَ، وَأَيُّهُمَا نَقَضَ انْتَقَضَ ، وَلَوْ

مضروبة في عقد البيع ، فبطل بالموت كالأجل تبين الحقائق شرح كنز الدقائق ٤ / ١٩ ، حاشية الطحاوي على الدر المختار ٣ / ٣٥ .

(١) فنقول : ثبت ذلك للوارث ابتداء لا بسبيل الإرث، أعنى أنه بطل ذلك الخيار الأول، وتجدد للوارث خيار آخر حكماً ؛ لاختِلَاطِ ملكه بملك غيره ، ألا يرى أن المورث كان له أن يفسخ ، وكان خياره مؤقتاً ، والوارث ليس له الفسخ ، وليس خياره بمؤقت .

العناية شرح الهداية ٦ / ٢٩٥ - ٢٩٦ ، البنائة في شرح الهداية ٧ / ١٠٠ .

(٢) المراد من الغير هنا : غير العاقدين .

(٣) أي من المشتري والغير أو البائع . مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر ٢ / ٣٠ .

(٤) وقال زفر : لا يجوز البيع بهذا الشرط ، وهو القياس ؛ لأن الخيار حكم من أحكام العقد فلا يجوز شرطه لغير العاقد ، أعنى أن الخيار إذا اشترط يكون حكماً من أحكام العقد ، وواجباً من مواجبه ، فلا يصح اشتراط حكم العقد لغير العاقد ، كاشتراط الملك لغيره ، أو اشتراط الثمن على غيره ، وجه الاستحسان: إن اشتراط الخيار لغير العاقد لم يثبت بطريق الأصالة بل بطريق النيابة عن العاقد اقتضاء تصحيحاً لتصرف العاقد على حسب الإمكان، فكأنه اشترط الخيار لنفسه أولاً ، ثم جعل الأجنبي نائباً عن نفسه ، فكان ثبوت الخيار للعاقد مقتضى صحة ثبوت الخيار للأجنبي، ولأن هذا تعليق انفساخ البيع وانبرامه بفعل الغير، والبيع لا يحتمل ذلك، وقياساً على خيار الرؤية والعيب. شرح فتح القدير ٦ / ٢٩٦ ، البحر الرائق شرح كنز الدقائق ٦ / ٢١١ .

(٥) **حكم العقد** : هو الغرض والغاية منه ، ففي عقد البيع : يكون الحكم هو ملكية المبيع للمشتري ، و ملكية الثمن للبائع ، وفي عقد الإجارة : يكون هو ملك منفعة العين المستأجرة للمستأجر ، و ملكية المؤجر للأجرة . الأموال ونظرية العقد لأستاذنا الدكتور / محمد يوسف موسى ص : ٣٧٢ ، والفقهاء الإسلامي وأدلته ٥ / ٣٣٦٧ .

أَجَارَ أَحَدَهُمَا وَفَسَخَ الْآخَرُ يُعْتَبَرُ السَّابِقُ (١) لَوْجُودِهِ فِي زَمَانٍ لَا يُزَاحِمُهُ فِيهِ غَيْرُهُ، وَلَوْ خَرَجَ الْكَلَامَانِ مِنْهُمَا مَعًا يُعْتَبَرُ تَصَرُّفُ الْعَاقِدِ فِي رِوَايَةٍ وَتَصَرُّفُ الْفَاسِخِ فِي أُخْرَى. وَجْهُ الْأَوَّلِ أَنَّ تَصَرُّفَ الْعَاقِدِ أَقْوَى؛ لِأَنَّ النَّائِبَ يَسْتَفِيدُ الْوِلَايَةَ مِنْهُ، وَجْهُ الثَّانِي أَنَّ الْفَسْخَ أَقْوَى (٢)؛ لِأَنَّ الْمَجَارَ يُلْحَقُهُ الْفَسْخُ وَالْمَفْسُوخُ لَا تَلْحَقُهُ الْإِجَازَةُ، وَلَمَّا مَلَكَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا التَّصَرُّفَ رَجَحْنَا بِحَالِ التَّصَرُّفِ، وَقِيلَ الْأَوَّلُ قَوْلُ مُحَمَّدٍ وَالثَّانِي قَوْلُ أَبِي يُوسُفَ، وَاسْتِخْرَاجُ (٣) ذَلِكَ (٤) مِمَّا إِذَا بَاعَ الْوَكِيلُ مِنْ رَجُلٍ وَالْمُوكَّلُ مِنْ غَيْرِهِ مَعًا؛ فَمُحَمَّدٌ يُعْتَبَرُ فِيهِ تَصَرُّفُ الْمُوكَّلِ، وَأَبُو يُوسُفَ يُعْتَبَرُ هُمَا (٥)، قَالَ: وَمَنْ بَاعَ عَبْدَيْنِ (٦) بِالْأَلْفِ دِرْهَمٍ عَلَى أَنَّهُ بِالْخِيَارِ فِي أَحَدِهِمَا ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فَالْبَيْعُ فَاسِدٌ، وَإِنْ بَاعَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِخَمْسِمِائَةٍ عَلَى أَنَّهُ بِالْخِيَارِ فِي أَحَدِهِمَا بَعَيْنِهِ جَارَ الْبَيْعِ وَالْمَسْأَلَةُ عَلَى أَرْبَعَةِ أَوْجُهٍ: أَحَدُهَا أَنَّ لَا يُفْصَلُ الثَّمَنَ وَلَا يُعَيَّنُ الَّذِي فِيهِ الْخِيَارُ وَهُوَ الْوَجْهُ الْأَوَّلُ فِي الْكِتَابِ وَفَسَادُهُ لِجَهَالَةِ الثَّمَنِ وَالْمَيْسَعِ؛ لِأَنَّ الَّذِي فِيهِ الْخِيَارُ كَالْخَارِجِ عَنِ الْعَقْدِ، إِذْ الْعَقْدُ مَعَ الْخِيَارِ لَا يَنْعَقِدُ فِي حَقِّ الْحُكْمِ فَبَقِيَ الدَّاخِلُ فِيهِ أَحَدُهُمَا وَهُوَ غَيْرُ مَعْلُومٍ، وَالْوَجْهُ الثَّانِي أَنَّ يُفْصَلُ الثَّمَنَ وَيُعَيَّنُ الَّذِي فِيهِ الْخِيَارُ وَهُوَ الْمَذْكُورُ ثَانِيًا فِي الْكِتَابِ، وَإِنَّمَا جَارَ؛ لِأَنَّ الْمَيْسَعِ مَعْلُومٌ وَالثَّمَنُ مَعْلُومٌ وَقَبُولُ الْعَقْدِ فِي الَّذِي

(١) فسخاً كان أو إجازة لوجوده في زمان لا يزاحمه فيه أحد ، وتصرف الآخر بعده يلغو؛ لأن السابق إن كان فسخاً ، فالمفسوخ لا تلحقه الإجازة، وإن كان إجازة فقد انبرم العقد وبعد انبرامه لا ينفرد أحد المتعاقدين بفسخه. تبين الحقائق شرح كنز الدقائق ٤ / ١٩ .

(٢) وهو أن الفسخ أولى ؛ لأن الخيار مشروط بالفسخ لا للإجازة ، والفاسخ منهما يتصرف بحكم الخيار تصرفاً شرع الخيار لأجله ، فكان تصرفه أولى . المبسوط للسرخسي ١٣ / ٤٩ .

(٣) استخراج : يقال : استخراج الشيء استنبطه واستخرج الشيء من المعدن خلصه من ترابه والخارج من كل شيء ظاهره . لسان العرب ٧ / ٤١٠ ، المعجم الوجيز : ١٩٠ .

(٤) إشارة إلى الاختلاف بين أبي يوسف ومحمد في ذلك : أراد - رحمهما الله -
يعنى أن المنسوب إليهما ليس بمنقول عنهما .

العناية شرح الهداية ٦ / ٢٩٨ ، البناية في شرح الهداية ٧ / ١٠٤ .

(٥) أي يعتبر تصرف الموكل وتصرف الوكيل .

البناية في شرح الهداية ٧ / ١٠٣ - ١٠٤ ، شرح فتح القدير ٦ / ٢٩٧ .

(٦) أراد بالعبدین: القيميين احترازاً عن قيمي أو مثليين ، إذ فى القيمي الواحد إذا شرط الخيار في نصف يصح مطلقاً ، وفى المثليين كذلك لعدم التفاوت.

رد المحتار على الدر المختار ٤ / ٤٨٤ ، حاشية الطحاوي على الدر المختار ٣ / ٣٦ .

فِيهِ الْخِيَارُ وَإِنْ كَانَ شَرْطًا لِانْعِقَادِ الْعَقْدِ فِي الْآخِرِ وَلَكِنْ هَذَا غَيْرُ مُكْسِدٍ لِلْعَقْدِ لِكَوْنِهِ مَحَلًّا لِلْبَيْعِ كَمَا إِذَا جَمَعَ بَيْنَ قَيْنِ (١) وَمُدَبِّرٍ (٢) ، وَالثَّالِثُ أَنْ يُفْصَلَ وَلَا يُعَيَّنَ (٣) وَالرَّابِعُ أَنْ يُعَيَّنَ وَلَا يُفْصَلَ (٤) (٥)، فَالْعَقْدُ فَاسِدٌ فِي الْوَجْهَيْنِ: إِمَّا لِجَهَالَةِ الْمَبِيعِ أَوْ لِجَهَالَةِ الثَّمَنِ، قَالَ: وَمَنْ اشْتَرَى ثَوْبَيْنِ عَلَى أَنْ يَأْخُذَ أَيُّهُمَا شَاءَ بِعَشْرَةٍ وَهُوَ بِالْخِيَارِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فَهُوَ جَائِزٌ، وَكَذَا الثَّلَاثَةُ، فَإِنْ كَانَتْ أَرْبَعَةً أَثَوَابٍ فَالْبَيْعُ فَاسِدٌ وَالْقِيَاسُ أَنْ يَفْسُدَ الْبَيْعُ فِي الْكُلِّ لِجَهَالَةِ الْمَبِيعِ (٦)، وَهُوَ قَوْلُ زُفَرٍ (٧) وَالشَّافِعِيِّ - رَحِمَهُمَا اللَّهُ - وَجْهُ الْإِسْتِحْسَانِ أَنْ شَرَعَ الْخِيَارَ لِلْحَاجَةِ إِلَى دَفْعِ الْغَبْنِ لِيَخْتَارَ مَا هُوَ الْأَرْفَقُ وَالْأَوْفَقُ (٨)، وَالْحَاجَةُ إِلَى هَذَا النَّوعِ مِنَ الْبَيْعِ مُتَحَقِّقَةٌ؛ لِأَنَّهُ يَحْتَاجُ إِلَى اخْتِيَارٍ مَنْ يَتَّقُ بِهِ أَوْ اخْتِيَارٍ مَنْ يَشْتَرِيهِ لِأَجْلِهِ، وَلَا يُمَكِّنُهُ الْبَائِعُ مِنَ الْحَمْلِ إِلَيْهِ إِلَّا بِالْبَيْعِ فَكَانَ فِي مَعْنَى مَا وَرَدَ بِهِ

(١) القن : هو العبد الذي لا يجوز بيعه ولا اشتراؤه . التعريفات: ٢٢٩ .
وعُرف أيضاً : بأنه الرقيق الذي لم يحصل فيه شيء من أسباب العتق .
تحرير ألفاظ التنبيه : ٢٠٤ .

(٢) المدبر: هو من أعتق عن دبر يعني في آخر حياة المولى فالمطلق منه ، أن يعلق عتقه بموت مطلق، مثل إن مت فأنت حر ، أو بموت يكون الغالب وقوعه ، مثل : إن مت إلى نحو مائة سنة فأنت حر ، والمقيد منه أن يعلقه بموت مقيد ، مثل : إن مت في مرضى هذا فأنت حر . تبين الحقائق شرح كنز الدقائق ٣ / ٩٧ ، التعريفات للرجاني : ٢٦٥ .

(٣) وأما الوجه الثالث : فإنما فسد البيع فيه لجهالة الثمن ، لما أن من فيه الخيار ليس بداخل في الحكم فيبقى الآخر مفرداً وثمانه مجهول

رد المحتار على الدر المختار ٤ / ٥٨٥ ، شرح فتح القدير ٦ / ٢٩٩ .

(٤) أن يعين الذي فيه الخيار ولا يفصل الثمن مثال ذلك كقول البائع : بعثك هذين بألف على أني بالخيار في هذا

(٥) وأما الوجه الرابع : فإنما فسد البيع فيه لجهالة المبيع ، وهذا لما قلنا : إن الذي فيه الخيار ليس بداخل في حكم العقد ، فبقى الآخر مفرداً ، وهو مجهول .

المحيط البرهاني ٦ / ٥١٧ ، تبين الحقائق شرح كنز الدقائق ٤ / ٢٠ .

(٦) لأنه باع أحدهما غير عين ، وهو غير معلوم ، فكان المبيع مجهولاً فيمنع صحة البيع كما لو باع أحد الأثواب الأربعة وذكر الخيار . بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ٥ / ٢٣٣ .

(٧) لأن هذا البيع غرر؛ لأنه لا يدري أن المبيع هذا أم الآخر، وقد نهى النبي ﷺ - عن بيع الغرر .

(٨) الأرفق : بالنظر إلى الثمن . والأوفق : أي بحاله عند المعاينة . البناءة ٧ / ١٠٧ .

الشَّرْعُ (١)، غَيْرَ أَنَّ هَذِهِ الْحَاجَةَ تَنْدَفِعُ بِالثَّلَاثِ (٢) لِوُجُودِ الْجَيِّدِ وَالْوَسْطِ وَالرَّدِيِّ فِيهَا، وَالْجَهَالَةُ لَا تُفْضِي إِلَى الْمُنَازَعَةِ فِي الثَّلَاثِ (٣) لِتَعْيِينِ مَنْ لَهُ الْخِيَارُ (٤)، وَكَذَا فِي الْأَرْبَعِ (٥)، إِلَّا أَنَّ الْحَاجَةَ إِلَيْهَا غَيْرُ مُتَحَقِّقَةٍ وَالرُّخْصَةُ تُبَوِّتُهَا بِالْحَاجَةِ وَكَوْنُ الْجَهَالَةِ غَيْرُ مُفْضِيَةٍ إِلَى الْمُنَازَعَةِ فَلَا تَثْبُتُ بِأَحَدِهِمَا. ثُمَّ قِيلَ: يُشْتَرَطُ أَنْ يَكُونَ فِي هَذَا الْعَقْدِ خِيَارُ الشَّرْطِ مَعَ خِيَارِ التَّعْيِينِ، وَهُوَ الْمَذْكُورُ فِي الْجَامِعِ الصَّغِيرِ، وَقِيلَ لَا يُشْتَرَطُ وَهُوَ الْمَذْكُورُ فِي الْجَامِعِ الْكَبِيرِ، فَيَكُونُ ذِكْرُهُ عَلَى هَذَا الْإِعْتِبَارِ وَفَاقًا لَا شَرْطًا؛ وَإِذَا لَمْ يَذْكُرْ خِيَارَ الشَّرْطِ لَا بُدَّ مِنْ تَوْقِيتِ خِيَارِ التَّعْيِينِ بِالثَّلَاثِ عِنْدَهُ وَبِمُدَّةٍ مَعْلُومَةٍ أَيْتُهَا كَانَتْ عِنْدَهُمَا، ثُمَّ ذَكَرَ فِي بَعْضِ النُّسخِ: اشْتَرَى ثَوْبَيْنِ وَفِي بَعْضِهَا اشْتَرَى أَحَدَ الثَّوْبَيْنِ وَهُوَ الصَّحِيحُ (٦)؛ لِأَنَّ الْمَبِيعَ فِي الْحَقِيقَةِ أَحَدُهُمَا وَالْآخَرُ أَمَانَةٌ، وَالْأَوَّلُ تَجَوُّزٌ وَاسْتِعَارَةٌ، وَلَوْ هَلَكَ

(١) أراد به شرط الخيار الذي ورد في حديث حبان رضى الله عنهما - وهو ما رواه البخاري مسنداً إلى عبد الله بن عمر - رضى الله عنهما - : (أن رجلاً ذكر للنبي - ﷺ - أنه يخدع في البيوع ، فقال : إذا بايعت فقل : لا خُلابة) أي : لا خديعة . سبق تخريجه

(٢) لأن الله تعالى ذكر الخيار في ثلاثة أشياء ، في كفارة اليمين وجزاء الصيد ، وكفارة الأذى ، فلما كانت للثلاثة أثر في كتاب الله تعالى استحسناً في الثلاثة ، وفيما زاد عليها أخذنا بالقياس ، ثم لما جاز البيع بهذا الشرط فللمشتري الخيار : إن شاء أخذ أحد الثوبين = ولزمه ثمنه ، والآخر عنده أمانة ، وإن شاء ردهما جميعاً ، وليس له أخذهما جميعاً ؛ لأن المبيع أحدهما لا غير . بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ٥ / ٣٨٧ .

(٣) جواب لقوله : (والقياس أن يفسد البيع في الكل ؛ لجهالة المبيع) .

البنية في شرح الهداية ٧ / ١٠٦ - ١٠٧ .

(٤) لأن الثلاثة على جميع الأنواع ، والجهالة ليست مفضية إلى المنازعة ، وهذا جواب عما قال الإمام الشافعي وزفر - رحمهما الله - من الجهالة في وجه القياس تقريره أن هذه الجهالة لا تقضى إلى المنازعة في الثلاث أي في الثياب الثلاث لتعيين من له الخيار .

البنية في شرح الهداية ٧ / ١٠٧ .

(٥) لوجود جميع الأوصاف المذكورة في الثلاث؛ ولأن في الأربعة قد يتفق ثوبان على صفة واحدة ، فيحتاج إلى اختيار آخر ، فتكثر الجهالة . البنية في شرح الهداية ٧ / ١٠٨ .

(٦) يعنى : اختلفت الرواية في نسخ الجامع الصغير والصحيح هو المذكور ثانياً ؛

لأن المبيع أحدهما لا هما ، والأول مجاز ؛ لاحتمال أن يكون كل واحد منهما هو المبيع ، وأثبت فخر الإسلام النسخة الأولى لا غير مجازاً، أو يجوز أن يقال في المجاز : إنه إطلاق اسم الكل

أَحَدُهُمَا أَوْ تَعَيَّبَ لِرِمَّةِ الْبَيْعِ فِيهِ بِشَمْنِهِ (١) وَتَعَيَّنَ الْآخَرُ لِلْأَمَانَةِ (٢) لَامْتِنَاعِ الرَّدِّ بِالشَّعْبِ، وَلَوْ هَلَكَ جَمِيعًا مَعًا يَلْزِمُهُ نِصْفُ ثَمَنِ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا لِشُيُوعِ الْبَيْعِ وَالْأَمَانَةِ فِيهِمَا (٣)، وَلَوْ كَانَ فِيهِ خِيَارُ الشَّرْطِ لَهُ أَنْ يَرَهُمَا جَمِيعًا، وَلَوْ مَاتَ مَنْ لَهُ الْخِيَارُ فَلِوَارِثِهِ أَنْ يَرُدَّ أَحَدَهُمَا؛ لِأَنَّ الْبَاقِيَ خِيَارُ التَّعْيِينِ لِلَاخْتِلَافِ، وَلِهَذَا لَا يَتَوَقَّفُ فِي حَقِّ الْوَارِثِ (٤). وَأَمَّا خِيَارُ الشَّرْطِ لَا يُوْرَثُ وَقَدْ ذَكَرْنَاهُ مِنْ قَبْلُ، قَالَ: وَمَنْ اشْتَرَى دَارًا عَلَى أَنَّهُ بِالْخِيَارِ فَبِيعَتْ دَارٌ أُخْرَى بِجَنْبِهَا فَأَخَذَهَا بِالشُّفْعَةِ فَهُوَ رِضًا؛ لِأَنَّ طَلَبَ الشُّفْعَةِ يَدُلُّ عَلَى اخْتِيَارِهِ الْمَلِكِ فِيهَا؛ لِأَنَّهُ مَا ثَبَتَ إِلَّا لِدَفْعِ ضَرَرِ الْجَوَارِ وَذَلِكَ بِالِاسْتِدَامَةِ (٥) فَيَتَضَمَّنُ ذَلِكَ سُقُوطَ الْخِيَارِ سَابِقًا عَلَيْهِ فَيَثْبُتُ الْمَلِكُ مِنْ وَقْتِ الشَّرَاءِ فَيَتَبَيَّنُ أَنَّ

على البعض كما في قوله تعالى: ﴿يَخْرُجُ مِنْهُمَا اللَّوْلُو وَالْمَرْجَانُ﴾ ، وإنما يخرجان من

الملح لا العذب الجامع الصغير لمحمد بن الحسن الشيباني ١ / ٣٤٤ .

(١) أي في الهالك أو المتعيب بثمنه الذي وقع عليه العقد ؛ لامتناع الرد بالهلاك ، أو بسبب العيب الذي حدث فيه عنده ، فلزم البيع فيه . البناية في شرح الهداية ٧ / ١٠٩ .

(٢) لأن الداخل تحت العقد أحدهما ، والذي لم يدخل في العقد قبضه بإذن مالكة ، على سوم الشراء . البناية في شرح الهداية ٧ / ١٠٩ - ١١٠ ، تبين الحقائق ٤ / ٢٢ .

(٣) ولو هلك الكل قبل القبض ، بطل البيع ، ولو هلك أحدهما بعد القبض تعين الهالك للبيع ولزمه ثمنه ؛ لأنه عجز عن رده ، وتعين الآخر للأمانة ، ولو هلكا جميعاً في يد المشتري ، إن كان الهالك على التعاقب لزمه ثمن الهالك الأول ، وهلك الباقي في يده أمانة ، ولو هلكا معاً لزمه نصف ثمن كل واحد منهما ؛ لأنه ليس أحدهما بأولى بالتعيين من الآخر ، لأن حالهما قبل الهلاك سواء ، فبعد الهلاك لا يتحقق تعيين البيع في أحدهما . فللمعارضة قلنا : فيتبع حكم الأمانة ، وحكم البيع فيهما فيكون أميناً في نصف كل واحد منهما مشترياً نصف كل واحد منهما ؛ ولأن كل واحد من الثمنين يلزمه من وجه دون وجه . فلهذا يلزمه نصف ثمن كل واحد منهما .

المبسوط للسرخسي ١٣ / ٥٦ ، الفتاوى الهندية ٣ / ٥٥ .

(٤) هذا إيضاح لكون الباقي خيار التعيين يعني أن الدليل على أن الباقي خيار التعيين بعد موت من له الخيار ، لا خيار الشرط عدم توقفه في حق الوارث؛ لأنه هو الذي لا يتوقف في حقه؛ لأنه لم يثبت له بسبيل الإرث، بل لاختلاط ملكه بملك غيره، فلو كان الباقي خيار الشرط لردهما الوارث جميعاً ، ولتوقف في حق الوارث لكن خيار الشرط لا يورث. البناية في شرح الهداية ٧ / ١١٠ ، حاشية سعد جلي بهامش شرح فتح القدير ٤ / ٣٠٤ .

(٥) أي دفع ضرر الجوار ، إنما يحتاج إليه باستدامة الملك في المشتراة بالخيار.

الْجَوَارَ كَانَ ثَابِتًا، وَهَذَا التَّفْرِيرُ يُحْتَاجُ إِلَيْهِ لِمَذْهَبِ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ خَاصَّةً (١). قَالَ: وَإِذَا اشْتَرَى (٢) الرَّجُلَانِ عَبْدًا عَلَى أَنَّهُمَا بِالْخِيَارِ فَرَضِي أَحَدُهُمَا (٣) فَلَيْسَ لِلْآخَرِ أَنْ يَرُدَّهُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَقَالَا: لَهُ أَنْ يَرُدَّهُ، وَعَلَى هَذَا الْخِلَافِ خِيَارُ الْعَيْبِ وَخِيَارُ الرُّؤْيَةِ (٤) لَهُمَا أَنْ يُثْبِتَ الْخِيَارَ لَهُمَا إِنْ ثَبَتَهُ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا (٥) فَلَا يَسْقُطُ بِإِسْقَاطِ صَاحِبِهِ لِمَا فِيهِ مِنْ إِبْطَالِ حَقِّهِ (٦)، وَلَهُ أَنْ الْمَبِيعَ خَرَجَ مِنْ مِلْكِهِ غَيْرَ مَعِيبِ الشَّرَكَةِ (٧)، فَلَوْ رَدَّهُ أَحَدُهُمَا رَدَّهُ مَعِيبًا بِهِ وَفِيهِ الْإِزَامُ ضَرَرٍ زَائِدٍ (٨)، وَلَيْسَ مِنْ

(١) إنما قال خاصة: لأن عندهما يدخل المبيع في ملك المشتري ، فلا يحتاج إلى التقرير الذي يؤدي إلى اختيار المالك ، فيجوز له أن يأخذ بالشفعة ويسقط بذلك خياره ، أما عنده ؛ فلأن خيار المشتري يمنع دخول المبيع في ملكه، ولا بد منه لاستحقاق الشفعة . العناية شرح الهداية ٣٠٥/٧ ، البنائة في شرح الهداية ١١١ / ٧ .

(٢) قيد المشتريين: لأن البائع لو كان اثنين، والمشتري واحد ، وفي البيع خيار شرط أو عيب ، فرد المشتري نصيب أحدهما دون الآخر، بحكم الخيار جاز اتفاقاً .

مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر ٢ / ٣٣، رد المحتار على الدر المختار ٤ / ٥٨٧ .

(٣) بالبيع صريحاً أو دلالة . رد المحتار على الدر المختار ٤ / ٥٨٧ .

(٤) يعنى اشترى شيئاً لم يرياه ، فراه أحدهما فرضي ، فليس لآخر أن يرده عنده وعندهما له ذلك. أو اشترى الرجلان شيئاً ، فاطلعا على عيب ، فرضي به أحدهما دون الآخر، لم يكن للآخر رده عنده، وعندهما له ذلك . شرح فتح القدير ٦ / ٣٠٥، مجمع الأنهر في ٢ / ٣٣.

(٥) ولا نسلم أن إثبات الخيار لهما إثبات لكل واحد منهما ، ألا ترى أن من وكل وكيلين أثبت الوكالة لهما ، وليس لأحدهما أن يتصرف دون الآخر. العناية شرح الهداية ٦ / ٣٠٥

(٦) فإذا رضى أحدهما لا يسقط برضاه خيار الآخر ؛ لأن فيه إلزام الضرر عليه بإبطال حقه في الخيار ، فكان للآخر الرد في نصيبه غاية ما في الباب أنه يلزم تفريق الصفقة على البائع ، ولكن لما باع من اثنين بالخيار لهما كان راضياً بالتفريق؛ لأن كل واحد مشترياً للنصف لا غير ، فله أن يرد الذي اشترى ، فصار كما إذا اشترى عبداً على أنه بالخيار في نصفه . فهو جائز؛ لأن النصف معلوم وثمنه معلوم . الجوهرة النيرة ١ / ٤٤٤ .

(٧) وجه قول أبي حنيفة : أن رد أحدهما ، لو جاز بدون صاحبه، يلزم الرد بعيب حادث لم يكن عند البائع ، والرد بالخيار إنما يصح إذا كان الرد على ما قبض ، أما بعيب حادث فلا ، وإنما يلزم الرد بعيب حادث ؛ لأن يد البائع كانت مجتمعة ، فإذا عادت إليه متفرقة كان التفريق عيباً ؛ لأن الشركة عيب ؛ لأن البائع قبل البيع كان يتمكن من التصرف يقصد به الانتفاع في المبيع متى شاء ،

صُرُورَةُ إِبْتَاتِ الْخِيَارِ لَهُمَا الرِّضَا بِرَدِّ أَحَدِهِمَا لِتَصَوُّرِ اجْتِمَاعِهِمَا عَلَى الرَّدِّ، قَالَ: وَمَنْ بَاعَ عَبْدًا عَلَى أَنَّهُ خَبَازٌ أَوْ كَاتِبٌ وَكَانَ بِخِلَافِهِ (٢) فَالْمُشْتَرِي بِالْخِيَارِ إِنْ شَاءَ أَخَذَهُ بِجَمِيعِ الثَّمَنِ وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ؛ لِأَنَّ هَذَا وَصْفٌ مَرْغُوبٌ فِيهِ فَيُسْتَحَقُّ فِي الْعَقْدِ بِالْشَّرْطِ (٣)، ثُمَّ فَوَاتُهُ يُوجِبُ التَّخْيِيرَ؛ لِأَنَّهُ مَا رَضِيَ بِهِ دُونَهُ (٤)، وَهَذَا يَرْجِعُ إِلَى اخْتِلَافِ النَّوعِ (٥) لِقِلَّةِ التَّفَاوُتِ فِي الْأَغْرَاضِ، فَلَا يَفْسُدُ الْعَقْدُ بَعْدَمِهِ

فتعذر برد أحدهما ولا يتمكن منه إلا بطريق التهاوي. البناية في شرح الهداية ٧ / ١١٢ ، رد المحتار على الدر المختار ٤ / ٥٨٧ .

(١) قيد الضرر بالزائد : لأن في امتناع الرد ضرراً أيضاً زائداً للرد ، ولكن لما لم يكن من الغير، بل لعجزه عن إيجاد شرط الرد ، كان دون الأول ، فإن الضرر الحاصل من الغير أقطع وأفجع من الحاصل من نفسه . العناية شرح الهداية ٦ / ٣٠٦ ، البناية في شرح الهداية ٧ / ١١٢ .

(٢) أي : ظهر أنه ليس بخباز أو ليس بكاتب . البناية في شرح الهداية ٧ / ١١٣ .

(٣) وإنما لم يفسد العقد بهذا الشرط ؛ لأنه من مقتضيات العقد ، ألا ترى أن الوصف الذي شرطه لو كان موجوداً في المبيع لدخل في العقد من غير ذكر ، وما هذا سبيله كان من مقتضيات العقد ، كما إذا اشترى على أن يملك المبيع، أو على أن يسلمه البائع إلى المشتري. بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ٥ / ٢٥٤، تبين الحقائق ٢٣ / .

(٤) والأصل هنا ما قالوا : إن من شرط صفة ، فوجد المبيع بخلافها ، فإن كانت الصفة مما لا تتفاوت فيها الأغراض تفاوتاً كبيراً ، كان المشتري بالخيار ، كما إذا اشترى حميراً على أنه أتان فإذا هو ذكر ، أو شاة على أنها نعجة ، فإذا هي كبش، وإذا كانت الصفة تتفاوت فيها الأغراض تفاوتاً كبيراً ، فالعقد فاسد ، أي إذا باع داراً على أنّ بناءها آجر ، فإذا هي لبن ، أو باع شخصاً على أنه جارية ، فإذا هو عبد ، فالبيع فاسد ؛ لأنه اختلاف كبير ، فهو بمنزلة الاختلاف في الجنس .

(٥) أي الاختلاف في العبد بكونه خبازاً أو غير خباز ، وبكونه كاتباً أو غير كاتب بمنزلة الاختلاف في النوع ، حتى لا يفسد العقد به بل يكون للمشتري الخيار .

والذكورة والأنوثة في سائر الحيوانات كالفرس والبقر والغنم ونحوها ، بخلاف الاختلاف في الذكورة والأنوثة في بني آدم ، فإنها بمنزلة الاختلاف في الجنس ، فيفسد العقد لفحش التفاوت.

البناية في شرح الهداية ٧ / ١١٣ - ١١٤ .

بِمَنْزِلَةِ وَصْفِ الذُّكُورَةِ وَالْأُنْثَى فِي الْحَيَوَانَاتِ وَصَارَ كَفَوَاتِ وَصْفِ السَّلَامَةِ (١)، وَإِذَا أَخَذَهُ أَخَذَهُ بِجَمِيعِ الثَّمَنِ؛ لِأَنَّ الْأَوْصَافَ لَا يُقَابَلُهَا شَيْءٌ مِنَ الثَّمَنِ لِكُونِهَا تَابِعَةً فِي الْعَقْدِ عَلَى مَا عُرِفَ (٢).

بَابُ خِيَارِ الرُّوْيَةِ (٣)

قَالَ (٤): وَمَنْ اشْتَرَى شَيْئًا لَمْ يَرَهُ فَالْبَيْعُ جَائِزٌ (٥)، وَلَهُ الْخِيَارُ إِذَا رَأَاهُ، إِنْ شَاءَ أَخَذَهُ بِجَمِيعِ الثَّمَنِ وَإِنْ شَاءَ رَدَّهَ، وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: لَا يَصِحُّ الْعَقْدُ أَصْلًا؛ لِأَنَّ الْمَبِيعَ مَجْهُولٌ (٦)، وَلَنَا قَوْلُهُ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - مَنْ اشْتَرَى شَيْئًا لَمْ يَرَهُ فَلَهُ الْخِيَارُ إِذَا رَأَاهُ؛ وَلِأَنَّ الْجَهَالََةَ بَعْدَ الرُّوْيَةِ لَا تُفْضِي إِلَى الْمُنَازَعَةِ، لِأَنَّهُ لَوْ لَمْ يُوَافَقْهُ يَرُدُّهُ (٧)، فَصَارَ كَجَهَالََةِ الْوَصْفِ فِي الْمُعَايِنِ الْمُشَارِ إِلَيْهِ (٨)،

(١) قوله : (وصار كفوات وصف السلامة) أي صار فوات وصف الخبز والكتابة فيما إذا اشترى على أنه خباز ، أو كاتب فوجده بخلافه ، كفوات وصف السلامة ، فيما إذا اشترى على أنه سليم ، فوجده معيباً ، فثمة له ولاية الرد فكذا هذا (على ما عرف).

(٢) ثم في مسألتنا إذا وجد العبد خبازاً أو كاتباً فيها ونعمت، وإن وجده بخلافه فله الخيار بين الأخذ بجميع الثمن إن شاء، والرد إن شاء؛ لأنه وصف مرغوب فيه ، فإذا فات وجب الخيار بين الأمرين لكنه إذا أخذ أخذ بجميع الثمن ؛ لأن الوصف لا يقابله شيء من الثمن ؛ لأنه بيع يدخل في العقد من غير ذكر، وفي جعله مقابلاً بشيء من الثمن يلزم جعله أصلاً ، فلا يجوز وهذا معنى قوله: (على ما عرف). تبين الحقائق شرح كنز الدقائق ٢٤/٤ ، البناية في شرح الهداية ٧ / ١١٥ .

(٣) قُضِيَ خِيَارُ الرُّوْيَةِ عَلَى خِيَارِ الْعَيْبِ لكونه أقوى منه؛ إذ تأثيره في منع تمام البيع، وتأثير خيار في منع لزوم الحكم.

(٤) أي الإمام القدوري رحمه الله-.

(٥) معناه: أن يقول الرجل لغيره: بعثك الثوب الذي في هذا الدكان وصفته كذا، أو الذرة التي في هذا الجوال وصفته كذا أو لم يذكر الصفة.

(٦) لأنه لم يعرف من المعقود عليه إلا الاسم، وكل ما كان كذلك لا يجوز بيعه لنهيهِ - عليه الصلاة والسلام - عن بيع الغرر، ونهيهِ عن بيع ما ليس عند الإنسان، وما ذلك إلا للجهالة.

(٧) لأنه لو لم يوافق بعد الرُّوْيَةِ يردّه على بائعه بلا نزاع؛ لأن النزاع يحصل إذا قلنا بانبرام العقد ولم نقل به.

(٨) بأن اشترى ثوباً مُشاراً إليه غير معلوم عدد زرعيته (أي طوله) يجوز لكونه معلوم العين، وإن لم يكن ثمة جهالة لا يفضي إلى النزاع.

وَكَذَا إِذَا قَالَ رَضِيتُ ثُمَّ رَأَهُ لَهُ أَنْ يَرُدَّهُ^(١) لِأَنَّ الْخِيَارَ مُعْلَقٌ بِالرُّؤْيَةِ لِمَا رَوَيْنَا^(٢) فَلَا يَثْبُتُ قَبْلَهَا^(٣).

وَحَقُّ الْفَسْخِ^(٤) قَبْلَ الرُّؤْيَةِ بِحُكْمِ أَنَّهُ عَقْدٌ غَيْرُ لَازِمٍ لَا بِمُقْتَضَى الْحَدِيثِ، وَلِأَنَّ الرِّضَا بِالشَّيْءِ قَبْلَ الْعِلْمِ بِأَوْصَافِهِ لَا يَتَحَقَّقُ فَلَا يُعْتَبَرُ قَوْلُهُ رَضِيتُ قَبْلَ الرُّؤْيَةِ بِخِلَافِ قَوْلِهِ رَدَدْتُ^(٥).

قَالَ: وَمَنْ بَاعَ مَا لَمْ يَرَهُ فَلَا خِيَارَ لَهُ^(٦) وَكَانَ أَبُو حَنِيفَةَ يَقُولُ: أَوَّلًا لَهُ الْخِيَارُ اعْتِبَارًا بِخِيَارِ الْعَيْبِ

وِخِيَارِ الشَّرْطِ^(٧) وَهَذَا؛ لِأَنَّ لُزُومَ الْعَقْدِ بِتَمَامِ الرِّضَا زَوَالًا^(٨) وَثُبُوتًا^(٩)، وَلَا يَتَحَقَّقُ ذَلِكَ إِلَّا بِالْعِلْمِ بِأَوْصَافِ الْمَبِيعِ، وَذَلِكَ بِالرُّؤْيَةِ فَلَمْ يَكُنْ الْبَائِعُ رَاضِيًا بِالزَّوَالِ^(١٠). وَوَجْهُ الْقَوْلِ الْمَرْجُوعِ إِلَيْهِ

(١) هذه المسألة تفريع على مسألة القدوري: يعني كما أن له الخيار إذا لم يقل رضيت، فكذا إذا قال ذلك ولم يره ثم رآه؛ لأن الخيار معلق بالرؤية والمعلق بالشئ لا يثبت قبله؛ لئلا يلزم وجود المشروط بدون الشرط، ولأنه لو لزم العقد بالرضا قبل الرؤية لزم امتناع الخيار عندها، وهو ثابت بالنص عندها فما أدى إلى إبطاله فهو باطل.

(٢) يعني قوله صلى الله عليه وسلم: "من اشترى شيئاً لم يره فله الخيار إذا رآه".

(٣) أي فلا يثبت الخيار قبل الرؤية؛ لأن المعلق بالشئ لا يثبت قبله؛ لئلا يلزم وجود المشروط بدون الشرط.

(٤) هذه الجملة جواب عن سؤال مقدر، وهو طلب الفرق بين الفسخ والإجازة قبل الرؤية؛ فإنه إذا أجاز قبل الرؤية لا يلزم، وإذا فسخ قبلها لزم مع استواء نسبة التصرفين في تعليقهما بالشرط في الحديث، ولا وجود للمعلق قبل الشرط.

(٥) لأنه فسخ لعدم الرضا.

(٦) صورته: أن يرث شيئاً فيبيعه قبل الرؤية، وحينئذ فلا خيار له.

(٧) أما خيار العيب: فإنه لا يختص بجانب المشتري، بل إذا وجد البائع الثمن زائفاً فهو بالخيار، إن شاء أجاز البيع وإن شاء ردّ، كالمشيئة إذا وجد المشتري المبيع معيباً، لكن لا يفسخ رد الثمن وينفسخ برد المبيع؛ لأنه أصلٌ دون الثمن، وأما خيار الشرط: فإنه يصح من الجانبين البائع والمشتري.

(٨) أي من حيث زوال ملك البائع عن السلعة التي باعها في حال البيع.

(٩) أي من حيث ثبوت ملك السلعة التي اشتراها المشتري في حال الشراء.

(١٠) أي قبل الرؤية لعدم تمام الرضا.

(١) أَنَّهُ مُعَلَّقٌ بِالشَّرَاءِ لِمَا رَوَيْنَا فَلَا يَثْبُتُ دُونَهُ (٢)، وَرُوِيَ " أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ بَاعَ أَرْضًا لَهُ بِالْبَصْرَةِ مِنْ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ فَقِيلَ لَطَلْحَةَ: إِنَّكَ قَدْ غُبِنْتَ (٣)، فَقَالَ: لِي الْخِيَارُ؛ لِأَنِّي اشْتَرَيْتُ مَا لَمْ أَرَهُ. وَقِيلَ لِعُثْمَانَ: إِنَّكَ قَدْ غُبِنْتَ، فَقَالَ: لِي الْخِيَارُ؛ لِأَنِّي بَعْتُ مَا لَمْ أَرَهُ. فَحَكَّمَا بَيْنَهُمَا جُبَيْرُ بْنُ مُطْعِمٍ. " فَقَضَى بِالْخِيَارِ لَطَلْحَةَ، وَكَانَ ذَلِكَ بِمَخْضَرٍ مِنَ الصَّحَابَةِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ - (٤).

ثُمَّ خِيَارَ الرَّؤْيَةِ غَيْرَ مُؤَقَّتٍ (٥) بَلْ يَبْقَى إِلَى أَنْ يُوْجَدَ مَا يُبْطِلُهُ، وَمَا يُبْطِلُ خِيَارَ الشَّرْطِ مِنْ تَعْيِبٍ (٦) أَوْ تَصَرُّفٍ يُبْطِلُ خِيَارَ الرَّؤْيَةِ، ثُمَّ إِنْ كَانَ تَصَرُّفًا لَا يُمَكِّنُ رَفْعَهُ كَالِإِعْتَاقِ وَالتَّذْيِيرِ أَوْ تَصَرُّفًا يُوجِبُ حَقًّا لِلْغَيْرِ كَالْبَيْعِ الْمُطْلَقِ (٧) وَالرَّهْنِ وَالْإِجَارَةَ يُبْطِلُهُ قَبْلَ الرَّؤْيَةِ وَبَعْدَهَا؛ لِأَنَّهُ لَمَّا لَزِمَ تَعَذُّرُ الْفَسْخِ فَبَطَلَ الْخِيَارُ وَإِنْ كَانَ تَصَرُّفًا لَا يُوجِبُ حَقًّا لِلْغَيْرِ كَالْبَيْعِ بِشَرْطِ الْخِيَارِ، وَالْمُسَاوَمَةِ وَالْهَبَةِ مِنْ غَيْرِ تَسْلِيمٍ لَا يُبْطِلُهُ قَبْلَ الرَّؤْيَةِ؛ لِأَنَّهُ لَا يَرْتَبِعُ عَلَى صَرِيحِ الرِّضَا وَيُبْطِلُهُ بَعْدَ الرَّؤْيَةِ لَوْجُودِ دَلَالَةِ الرِّضَا (٨).

(١) وهو عدم الخيار.

(٢) أي أن الخيار معلق بالشراء لقوله صلى الله عليه وسلم: "من اشترى شيئاً لم يره فله الخيار إذا رآه"، فلا يثبت دون الشراء، ورؤية المشتري.

(٣) أي خُدعت.

(٤) ولهذا رجع أبو حنيفة - رَحِمَهُ اللَّهُ - حين بلغه الخبر.

(٥) وهو المختار في المذهب، خلافاً لما ذهب إليه بعض المشايخ من أنه مؤقت بعد الرؤية بقدر ما يتمكن فيه من الفسخ، فإذا تمكن من الفسخ بعد الرؤية فلم يفسخ بطل خياره ولزم البيع فيه.

(٦) أي تعيب المبيع بعد الرؤية.

(٧) أي البيع المطلق عن شرط الخيار للبائع؛ لأن به لا يخرج المبيع عن ملكه وكالهبه مع التسليم.

(٨) فالحاصل أن التصرف الذي يبطل خيار الرؤية على ضربين: تصرف يبطله قبل الرؤية وبعدها، وتصرف لا يبطله قبل الرؤية ويبطله بعدها.

فأما الأول: فهو الذي لا يمكن رفعه كالإعتاق والتذبير، أو الذي يوجب حقاً للغير كالبيع المطلق عن خيار الشرط، والبيع بخيار الشرط للمشتري والرهن والإجارة، وهذا لأن هذا التصرف يعتمد الملك، وملك المتصرف في العين قائم، فصايف المحل ونفذ، وبعد نفوذه لا يقبل الفسخ والرفع، فتعذر

قَالَ: وَمَنْ نَظَرَ إِلَى وَجْهِ الصُّبْرَةِ ^(١)، أَوْ إِلَى ظَاهِرِ الثَّوبِ مَطْوِيًّا أَوْ إِلَى وَجْهِ الْجَارِيَةِ أَوْ إِلَى وَجْهِ الدَّابَّةِ وَكَفَّلَهَا ^(٢) فَلَا خِيَارَ لَهُ وَالْأَصْلُ فِي هَذَا أَنَّ رُؤْيَا جَمِيعِ الْمَبِيعِ غَيْرُ مَشْرُوطٍ لِتَعَدُّهِ فَيَكْتَفِي بِرُؤْيَا مَا يَدُلُّ عَلَى الْعِلْمِ بِالْمَقْصُودِ، وَلَوْ دَخَلَ فِي الْبَيْعِ أَشْيَاءُ فَإِنْ كَانَ لَا تَتَفَاوَتْ أَحَادُهَا كَالْمَكِيلِ وَالْمُوزُونِ، وَعَلَامَتُهُ أَنْ يَعْزُضَ بِالنَّمُودَجِ يَكْتَفِي بِرُؤْيَا وَاحِدٍ مِنْهَا إِلَّا إِذَا كَانَ الْبَاقِي أَرْدَا مِمَّا رَأَى فَحِينَئِذٍ يَكُونُ لَهُ الْخِيَارُ ^(٣)، وَإِنْ كَانَ تَتَفَاوَتْ أَحَادُهَا كَالثِّيَابِ وَالذَّوَابِّ لَا بُدَّ مِنْ رُؤْيَا كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهَا ^(٤)، وَالْجُوزُ وَالْبَيْضُ مِنْ هَذَا الْقَبِيلِ فِيمَا ذَكَرَهُ الْكَرْخِيُّ ^(٥)، وَكَانَ يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ مِثْلَ الْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ لِكُونِهَا مُتَقَارِبَةً ^(٦). إِذَا ثَبَتَ هَذَا فَنَقُولُ: النَّظَرُ إِلَى وَجْهِ الصُّبْرَةِ كَافٍ؛ لِأَنَّهُ يَعْرِفُ وَصْفَ الْبَقِيَّةِ؛ لِأَنَّهُ مَكِيلٌ يُعْزُضُ بِالنَّمُودَجِ، وَكَذَا النَّظَرُ إِلَى ظَاهِرِ الثَّوبِ مِمَّا يَعْلَمُ بِهِ الْبَقِيَّةَ إِلَّا إِذَا كَانَ فِي طَبْعِهِ مَا يَكُونُ مَقْصُودًا كَمَوْضِعِ الْعِلْمِ ^(٧)، وَالْوَجْهُ هُوَ الْمَقْصُودُ فِي الْإِدْمِي ^(٨)، وَهُوَ وَالْكَفْلُ فِي

الفسخ وبطل الخيار ضرورة، وكذلك تعلق حق الغير مانع من الفسخ فيبطل الخيار، حتى لو افتك الرهن أو مضت مدة الإجارة أو رد المشتري عليه بخيار الشرط ثم رآه لا يكون له الرد. وأما الثاني: فهو الذي لا يوجب حقاً للغير: كالبيع بشرط الخيار لنفسه والمساومة والهبة من غير تسليم: لا يبطل الخيار قبل الرؤية؛ لأنه لا يربو على صريح الرضا: أي لا يزيد عليه، وصريح الرضا لا يبطله قبل الرؤية فدلالته أولى.

(١) الصبرة: ما جُمِعَ من الطعام بلا كَيْلٍ ولا وَزْنٍ.

(٢) أي عَجَز الدابة.

(٣) وهو خيار العيب لا خيار الرؤية.

(٤) لأن رؤية البعض لا تعرف الباقي لتفاوت في أحاده.

(٥) أي والجوز والبيض من قبيل ما تتفاوت أحاده؛ لأنه يختلف بالصغر والكبر وهو اختيار قاضي خان - رَحِمَهُ اللَّهُ - فيما ذكره الكرخي - رَحِمَهُ اللَّهُ -.

(٦) مال صاحب "الهداية" إلى أنه يكتفي برؤية واحد منها، فقال: وكان ينبغي أن يكون الجوز والبيض مثل الحنطة والشعير لكون أحاد الجوز واللوز متقاربة، فيكتفي برؤية البعض عن الباقي.

(٧) وعلى هذا فالمسألة معروفة في الثوب الذي لا يتفاوت ظاهره وباطنه، حتى لو خالف لا بد من رؤية ظاهره وباطنه.

(٨) وذلك في شراء العبد والأمة، حتى لو نظر إلى غيره لا يبطل خياره.

الدَّوَابَّ فَيُعْتَبَرُ رُؤْيَا الْمَقْصُودِ وَلَا يُعْتَبَرُ رُؤْيَا غَيْرِهِ. وَشَرَطَ بَعْضُهُمْ رُؤْيَا الْقَوَائِمِ ^(١). وَالْأَوَّلُ هُوَ الْمَرْوِيُّ عَنْ أَبِي يُوسُفَ - رَحِمَهُ اللَّهُ - ^(٢).

وَفِي شَاةِ اللَّحْمِ ^(٣) لَا بُدَّ مِنَ الْجَسِّ لِأَنَّ الْمَقْصُودَ وَهُوَ اللَّحْمُ يُعْرَفُ بِهِ ^(٤). وَفِي شَاةِ الْقُنْيَةِ ^(٥) لَا بُدَّ مِنَ رُؤْيَا الضَّرْعِ، وَفِيمَا يُطْعَمُ لَا بُدَّ مِنَ الذَّوْقِ لِأَنَّ ذَلِكَ هُوَ الْمَعْرِفُ لِلْمَقْصُودِ.

قَالَ: وَإِنْ رَأَى صَحْنَ الدَّارِ ^(٦) فَلَا خِيَارَ لَهُ وَإِنْ لَمْ يُشَاهِدْ بُيُوتَهَا وَكَذَلِكَ إِذَا رَأَى خَارِجَ الدَّارِ أَوْ رَأَى أَشْجَارَ الْبُسْتَانِ مِنْ خَارِجٍ ' وَعِنْدَ زُفَرٍ لَا بُدَّ مِنْ دُخُولِ دَاخِلِ الْبُيُوتِ، وَالْأَصَحُّ أَنَّ جَوَابَ الْكِتَابِ عَلَى وَفَاقِ عَادَتِهِمْ فِي الْأُبْنِيَةِ ^(٧)؛ فَإِنَّ دُورَهُمْ لَمْ تَكُنْ مُتَفَاوِتَةً يَوْمِيًّا، فَأَمَّا الْيَوْمُ فَلَا بُدَّ مِنَ الدُّخُولِ فِي دَاخِلِ الدَّارِ لِلتَّفَاوُتِ ^(٨)، وَالنَّظَرُ إِلَى الظَّاهِرِ لَا يُوَقِّعُ الْعِلْمَ بِالدَّاخِلِ ، قَالَ ^(٩): " وَنَظَرُ الْوَكِيلِ كَنَظَرِ الْمُشْتَرِي ^(١٠) حَتَّى لَا يَرُدَّهُ إِلَّا مِنْ عَيْبٍ ^(١١)، وَلَا يَكُونُ نَظَرُ الرَّسُولِ كَنَظَرِ الْمُشْتَرِي ، وَهَذَا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ وَقَالَا: هُمَا سَوَاءٌ، ^(١٢)، وَلَهُ ^(١٣) أَنْ يَرُدَّهُ قَالَ مَعْنَاهُ الْوَكِيلُ بِالْقَبْضِ

(١) أي شرط بعض المشايخ - رَحِمَهُمُ اللَّهُ - رؤية قوائم الدابة.

(٢) الأول وهو رؤية الوجه والكفل مروى عن أبي يوسف - رَحِمَهُ اللَّهُ - في رواية بشر عنه، وعن أبي يوسف - رَحِمَهُ اللَّهُ - يعتبر في الدواب عرف التجار وهو رواية المعلى عنه، وعن محمد - رَحِمَهُ اللَّهُ -: يكفي رؤية الوجه اعتباراً بالعبد والأمة.

(٣) وهي الشاة التي تشتري للذبح لأجل اللحم.

(٤) ليعرف أنها سمينة أو هزيلة.

(٥) وهي الشاة التي تحبس في البيت للتربية والنسل لا للتجارة.

(٦) صحن الدار وسطها.

(٧) أي كان قول القدوري بناء على عادة أهل الكوفة وأهل بغداد في زمن أبي حنيفة .

(٨) لتفاوت الدور بكثرة المرافق وقتلتها، فلا يصير معلوماً بالنظر إلى صحنها وهو الصحيح.

(٩) أي محمد - رَحِمَهُ اللَّهُ - في "الجامع الصغير".

(١٠) صورة التوكيل أن يقول المشتري لغيره: كن وكيلي في قبض المبيع أي وكلتك بقبضه.

(١١) إذا ظهر فيه أي عيب لم يعلمه الوكيل.

(١٢) أي الوكيل والرسول سواء.

(١٣) أي للمشتري.

(١)، فَأَمَّا الْوَكِيلُ بِالشَّرَاءِ فَرُؤِيَّتُهُ تُسْقَطُ الْخِيَارَ بِالْإِجْمَاعِ لَهُمَا ^(٢) لِأَنَّهُ تَوَكَّلَ بِالْقَبْضِ دُونَ إِسْقَاطِ الْخِيَارِ فَلَا يَمْلِكُ مَا لَمْ يَتَوَكَّلْ بِهِ وَصَارَ كَخِيَارِ الْعَيْبِ وَالشَّرْطِ وَالْأَسْقَاطِ قَصْداً ^(٣).
وَلَهُ ^(٤) أَنَّ الْقَبْضَ نَوْعَانِ: تَامٌّ وَهُوَ أَنْ يَقْبِضَهُ ^(٥) وَهُوَ يَرَاهُ. وَنَاقِصٌ، وَهُوَ أَنْ يَقْبِضَهُ مَسْتُوراً ^(٦) وَهَذَا؛ لِأَنَّ تَمَامَهُ ^(٧) يَتِمَّامُ الصَّفَقَةَ وَلَا تَتِمُّ مَعَ بَقَاءِ خِيَارِ الرُّؤْيَةِ وَالْمُوَكَّلُ مَلَكُهُ ^(٨) بِنَوْعِيهِ، فَكَذَا الْوَكِيلُ، وَمَتَى قَبَضَ الْمُوَكَّلُ وَهُوَ يَرَاهُ سَقَطَ الْخِيَارُ فَكَذَا الْوَكِيلُ لِإِطْلَاقِ التَّوَكُّلِ، وَإِذَا قَبَضَهُ مَسْتُوراً انْتَهَى التَّوَكُّلُ بِالنَّاقِصِ مِنْهُ ^(٩) فَلَا يَمْلِكُ إِسْقَاطَهُ قَصْداً بَعْدَ ذَلِكَ ^(١٠)، بِخِلَافِ خِيَارِ الْعَيْبِ ^(١١)؛ لِأَنَّهُ يَمْنَعُ تَمَامَ الصَّفَقَةِ ^(١٢) فَيَتِمُّ الْقَبْضُ مَعَ بَقَائِهِ ^(١٣)، وَخِيَارُ الشَّرْطِ عَلَى هَذَا الْخِلَافِ ^(١) وَلَوْ سَلَّمَ

(١) قال المصنف -رَحِمَهُ اللَّهُ: (معناه): أي معنى قوله في "الجامع الصغير": (ونظر الوكيل كنظر المشتري): الوكيل بالقبض.

(٢) أي دليل أبي يوسف ومحمد -رحمهما الله-.

(٣) أي صار هذا كمن اشترى شيئاً، ثم وكَّلَ بقبضه، فقبض الوكيل معيباً رائياً عيبه لم يسقط خيار العيب للموكل.

وصار أيضاً كمن اشترى بخيار الشرط ووكَّلَ بقبضه، لم يسقط خيار الموكل.
أما الإسقاط قصداً: فصورته: أن الوكيل بالقبض إذا قبضه مستوراً ثم رآه وأسقط عنه الخيار قصداً لا يسقط الخيار عن الموكل.

(٤) أي دليل الإمام أبي حنيفة -رحمه الله-.

(٥) أي الوكيل.

(٦) وهو لا يسقط الخيار لعدم الرضا.

(٧) أي تمام القبض.

(٨) أي القبض.

(٩) أي بالقبض الناقص أحد نوعي القبض.

(١٠) لأنه لم يفوض إليه الإبطال قصداً، وإنما يثبت له الإبطال مقتضى تنميتهم القبض، وهنا لما القبض الناقص، انتهى الوكيل به فليس له بعد ذلك إبطال الخيار.

(١١) جواب عن قولهما: فصار كخيار العيب.

(١٢) لأنه لم يشرع تنميماً للقبض، بل لتسليم الجزء الفائت.

(١٣) أي بقاء الخيار.

(٢) فَأَلْمُوكُلُ لَا يَمْلِكُ التَّامَّ مِنْهُ فَإِنَّهُ لَا يَسْقُطُ بِقَبْضِهِ (٣)؛ لِأَنَّ الْإِخْتِيَارَ وَهُوَ الْمَقْصُودُ بِالْخِيَارِ يَكُونُ بَعْدَهُ (٤)، فَكَذَا لَا يَمْلِكُهُ وَكِيلُهُ، وَبِخِلَافِ الرَّسُولِ؛ لِأَنَّهُ لَا يَمْلِكُ شَيْئًا وَإِنَّمَا إِلَيْهِ تَبْلِيغُ الرِّسَالَةِ (٥) وَلِهَذَا لَا يَمْلِكُ الْقَبْضَ، وَالتَّسْلِيمَ إِذَا كَانَ رَسُولًا فِي الْبَيْعِ (٦).
 قَالَ: وَبَيْعُ الْأَعْمَى وَشِرَاؤُهُ جَائِزٌ وَلَهُ الْخِيَارُ إِذَا اشْتَرَى؛ لِأَنَّهُ اشْتَرَى مَا لَمْ يَرَهُ وَقَدْ قَرَّرْنَاهُ مِنْ قَبْلُ ثُمَّ يَسْقُطُ خِيَارُهُ بِجَسِّهِ الْمَبِيعِ إِذَا كَانَ يُعْرِفُ بِالْجَسِّ (٧)، وَيَشْمُهُ إِذَا كَانَ يُعْرِفُ بِالشَّمِّ (٨)، وَيَذُوقُهُ إِذَا كَانَ يُعْرِفُ بِالذَّوْقِ (٩).
 كَمَا فِي الْبَصِيرِ (١٠) وَلَا يَسْقُطُ خِيَارُهُ فِي الْعَقَارِ حَتَّى يُوصَفَ؛ لِأَنَّ الْوَصْفَ يُقَامُ مَقَامَ الرُّؤْيَا فِي السَّلَمِ (١١)، وَعَنْ أَبِي يُوسُفَ - رَحِمَهُ اللَّهُ - أَنَّهُ إِذَا وَقَفَ فِي مَكَانٍ لَوْ كَانَ بَصِيرًا لَرَأَاهُ وَقَالَ: قَدْ

-
- (١) وهذا جواب عن قولهما: (والشرط) أي: وكخيار الشرط، بيانه: أن خيار الشرط لا يصلح مقيساً عليه؛ لأنه على هذا الخلاف.
- (٢) أي ولو سلمنا بقاء الخيار.
- (٣) أي لا يملك القبض التام منه أي من القبض؛ لأن تمامه بتمام الصفقة، ولا تتم الصفقة مع بقاء خيار الشرط.
- (٤) أي بعد القبض.
- (٥) أي لا يملك شيئاً من القبض لا التام ولا الناقص، وإنما إليه تبليغ الرسالة، فيملك أداء الرسالة على أكمل الوجوه.
- (٦) أي ولأجل كونه مبلغاً للرسالة فقط، لا يملك قبض الثمن إذا كان رسولاً في البيع، ولا قبض المبيع إذا كان رسولاً في الشراء.
- (٧) كالشاة.
- (٨) كالطيّب.
- (٩) كالعسل.
- (١٠) فالبصير إذا لم ير المبيع، ولكن شمه فقط وهو مما يعرف بالشّم كالمسك ونحوه فرضي به ثم رأى فلا خيار له.
- (١١) يعني أن الوصف يقوم مقام المسلم فيه، وإن كان المسلم فيه معدوماً للعجز، والعجز في حق الأعمى ألزم؛ لأن رؤية المسلم فيه ممكنة، أما رؤية الأعمى غير ممكنة، فيقوم الوصف مقام الرؤية في حقه بالطريق الأولى.

رَضِيتُ سَقَطَ خِيَارِهِ، لِأَنَّ التَّشْبِيهَ يُقَامُ مَقَامَ الْحَقِيقَةِ فِي مَوْضِعِ الْعَجْزِ كَتَحْرِيكِ الشَّفَتَيْنِ يُقَامُ مَقَامُ الْقِرَاءَةِ فِي حَقِّ الْأَخْرَسِ فِي الصَّلَاةِ، وَإِجْرَاءِ الْمُوسَى مَقَامَ الْحَلْقِ فِي حَقِّ مَنْ لَا شَعْرَ لَهُ فِي الْحَجِّ^(١)، وَقَالَ الْحَسَنُ: يُؤَكَّلُ وَكِيلًا بِقَبْضِهِ وَهُوَ يَرَاهُ وَهَذَا أَشْبَهُ بِقَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ لِأَنَّ رُؤْيَةَ الْوَكِيلِ كَرُؤْيَةِ الْمُؤَكَّلِ عَلَى مَا مَرَّ آنِفًا^(٢).

قَالَ: وَمَنْ رَأَى أَحَدَ التَّوْبِينِ فَاشْتَرَاهُمَا ثُمَّ رَأَى الْآخَرَ جَارَ لَهُ أَنْ يَرُدَّهُمَا^(٣)؛ لِأَنَّ رُؤْيَةَ أَحَدِهِمَا لَا تَكُونُ رُؤْيَةَ الْآخَرِ لِلتَّفَاوُتِ فِي النَّيَابِ فَبَقِيَ الْخِيَارُ فِيمَا لَمْ يَرَهُ، ثُمَّ لَا يَرُدُّهُ وَحْدَهُ بَلْ يَرُدُّهُمَا كَيْ لَا يَكُونَ تَفْرِيقًا لِلصَّفَقَةِ قَبْلَ التَّمَامِ، وَهَذَا؛ لِأَنَّ الصَّفَقَةَ لَا تَتِمُّ مَعَ خِيَارِ الرُّؤْيَةِ قَبْلَ الْقَبْضِ وَبَعْدَهُ، وَلِهَذَا يَتِمَكَّنُ مِنَ الرَّدِّ بِغَيْرِ قَضَاءٍ وَلَا رِضًا وَيَكُونُ فَسْخًا مِنَ الْأَصْلِ^(٤)، وَمَنْ مَاتَ وَلَهُ خِيَارُ الرُّؤْيَةِ بَطَلَ خِيَارُهُ لِأَنَّهُ لَا يَجْرِي فِيهِ الْإِرْثُ عِنْدَنَا، وَقَدْ ذَكَرْنَاهُ فِي خِيَارِ الشَّرْطِ^(٥)،

(١) قَالَ ابْنُ الْهَمَامِ فِي "فَتْحِ الْقَدِيرِ" ٣٤٩/٦: "وَلَا يَخْفَى ضَعْفُهُ؛ لِأَنَّ الْعَجْزَ لَا يَتَحَقَّقُ إِلَّا بِتَحَقُّقِ الْعَجْزِ عَنِ الْوَصْفِ؛ فَإِنَّ الْقَائِمَ مَقَامَ الشَّيْءِ بِمَنْزِلَتِهِ، وَقَدْ ثَبَتَ شَرْعًا اعْتِبَارُهُ بِمَنْزِلَتِهِ فِي السَّلَامِ، وَوَجُوبُ إِجْرَاءِ الْمُوسَى مُخْتَلَفٌ فِيهِ، وَكَذَا التَّحْرِيكُ غَيْرُ لَازِمٍ لِلْأَمِيِّ.

(٢) فَيَسْقُطُ بِذَلِكَ خِيَارُهُ.

وَقَالَ مَشَايِخُ بَلْخٍ: يَمَسُّ الْحَيْطَانُ وَالْأَشْجَارُ، فَإِذَا قَالَ: رَضِيتُ سَقَطَ خِيَارِهِ؛ لِأَنَّ الْأَعْمَى إِذَا كَانَ ذَكِيًّا يَقِفُ عَلَى مَقْصُودِهِ بِذَلِكَ.

وَفِي رِوَايَةِ هِشَامٍ عَنْ مُحَمَّدٍ: أَنَّهُ يَعْتَبَرُ الْوَصْفَ مَعَ كُلِّ مَنْ الذُّوقُ وَاللَّمْسُ وَالْجَسُّ؛ لِأَنَّ التَّعْرِيفَ الْكَامِلَ فِي حَقِّهِ يَثْبُتُ بِهَذَا إِلَّا فِيمَا لَا يُمْكِنُ جَسَّهُ كَالثَّمَرِ عَلَى رَعُوسِ الشَّجَرِ فَيَعْتَبَرُ فِيهِ الْوَصْفُ لَا غَيْرَ فِي أَشْهُرِ الرِّوَايَاتِ، وَهُوَ الْمَرْوِيُّ عَنْ أَبِي يُوسُفَ وَمُحَمَّدٍ فِي شَرْحِ الْجَامِعِ الصَّغِيرِ لِأَبِي الْلَيْثِ.

(٣) فَالْجَمْعُ بَيْنَ الْأَشْيَاءِ الْمُتَفَاوِتَةِ الْآحَادِ فِي الْبَيْعِ: رُؤْيَةُ بَعْضِهَا لَا يَعْرِفُ الْبَاقِي، بَلْ لَا بَدَّ مِنْ رُؤْيَةِ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهَا، وَعَلَى هَذَا إِذَا رَأَى أَحَدَ التَّوْبِينِ فَاشْتَرَاهُمَا ثُمَّ رَأَى الْآخَرَ فَلَهُ الْخِيَارُ، لَكِنْ لَا يَرُدُّ الَّذِي رَأَاهُ وَحْدَهُ، بَلْ يَرُدُّهُمَا إِنْ شَاءَ كَيْ لَا يُلْزَمَ تَفْرِيقُ الصَّفَقَةِ قَبْلَ التَّمَامِ.

(٤) أَيْ يَكُونُ الرَّدُّ بِخِيَارِ الرُّؤْيَةِ فَسْخًا مِنَ الْإِبْتِدَاءِ، وَيَكُونُ فَسْخًا مِنَ الْأَصْلِ لِعَدَمِ تَحَقُّقِ الرِّضَا؛ لِعَدَمِ الْعِلْمِ بِصِفَاتِ الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ، فَلَا يَحْتَاجُ إِلَى الْقَضَاءِ وَالرِّضَا بِخِلَافِ خِيَارِ الْمَعِيبِ بَعْدَ الْقَبْضِ، فَإِنَّهُ لَا يَرُدُّ إِلَّا بِالرِّضَا وَالْقَضَاءِ لَتِمَامِ الْبَيْعِ.

(٥) خِيَارُ الشَّرْطِ لَا يَقْبَلُ الْإِنْتِقَالَ لِأَنَّهُ مُشَيِّئَةٌ، وَهُوَ عَرْضٌ وَالْعَرْضُ لَا يَنْتَقِلُ وَالْإِرْثُ فِيمَا يَنْتَقِلُ، فَكَذَا خِيَارُ الرُّؤْيَةِ، فَخِيَارُ الشَّرْطِ وَالرُّؤْيَةِ لَا يُورَثَانِ، وَخِيَارُ الْعَيْبِ وَالتَّعْيِينِ يورَثَانِ بِالِاتِّفَاقِ.

وَمَنْ رَأَى شَيْئًا ثُمَّ اشْتَرَاهُ بَعْدَ مُدَّةٍ، فَإِنْ كَانَ عَلَى الصَّفَةِ الَّتِي رَأَاهُ فَلَا خِيَارَ لَهُ لِأَنَّ الْعِلْمَ بِأَوْصَافِهِ حَاصِلٌ لَهُ بِالرُّؤْيَةِ السَّابِقَةِ، وَبِفَوَاتِهِ ^(١) يَثْبُتُ الْخِيَارُ؛ إِلَّا إِذَا كَانَ لَا يَعْلَمُهُ مَرِيئُهُ ^(٢) لِعَدَمِ الرِّضَا بِهِ وَإِنْ وَجَدَهُ مُتَغَيِّرًا فَلَهُ الْخِيَارُ لِأَنَّ تِلْكَ الرُّؤْيَةَ لَمْ تَقَعْ مُعْلِمَةً بِأَوْصَافِهِ فَكَأَنَّهُ لَمْ يَرَهُ، وَإِنْ اخْتَلَفَا فِي التَّغْيِيرِ ^(٣): فَالْقَوْلُ لِلْبَائِعِ لِأَنَّ التَّغْيِيرَ حَادِثٌ وَسَبَبُ اللُّزُومِ ظَاهِرٌ ^(٤)، إِلَّا إِذَا بَعَدَتْ الْمُدَّةُ عَلَى مَا قَالُوا ^(٥)؛ لِأَنَّ الظَّاهِرَ شَاهِدٌ لِلْمُشْتَرِي ^(٦)، بِخِلَافِ مَا إِذَا اخْتَلَفَا فِي الرُّؤْيَةِ لِأَنَّهَا أَمْرٌ حَادِثٌ وَالْمُشْتَرِي يُنْكِرُهُ فَيَكُونُ الْقَوْلُ قَوْلَهُ ^(٧).

قَالَ: وَمَنْ اشْتَرَى عِدْلَ زُطِّي ^(٨) وَلَمْ يَرَهُ فَبَاعَ مِنْهُ ثَوْبًا أَوْ وَهَبَهُ وَسَلَّمَهُ لَمْ يَرُدَّ شَيْئًا مِنْهَا إِلَّا مِنْ عَيْبٍ، وَكَذَلِكَ خِيَارُ الشَّرْطِ؛ لِأَنَّهُ تَعَذَّرَ الرَّدُّ فِيمَا خَرَجَ عَنْ مِلْكِهِ، وَفِي رَدِّ مَا بَقِيَ تَفْرِيقُ الصَّفَقَةِ قَبْلَ التَّمَامِ؛ لِأَنَّ خِيَارَ الرُّؤْيَةِ وَالشَّرْطِ يَمْنَعَانِ تَمَامَهَا ^(٩)، بِخِلَافِ خِيَارِ الْعَيْبِ لِأَنَّ الصَّفَقَةَ تَتِمُّ مَعَ خِيَارِ الْعَيْبِ بَعْدَ الْقَبْضِ، وَإِنْ كَانَتْ لَا تَتِمُّ قَبْلَهُ ^(١٠) وَفِيهِ وَضْعُ الْمَسْأَلَةِ ^(١١) فَلَوْ عَادَ إِلَيْهِ ^(١٢) بِسَبَبٍ

(١) أي بفوات العلم بأوصافه.

(٢) أي لا يعلم أنه هو الذي رآه، وكلمة الاستثناء من قوله: "فلا خيار له".

(٣) بأن قال المشتري: قد تغير، وقال البائع: لم يتغير.

(٤) أي لزوم العقد وهو الرؤية السابقة، أو البيع البات الخالي عن الشروط المفسدة، أو رؤية جزء من المعقود عليه.

(٥) أي المتأخرون، فحينئذ يكون القول قول المشتري.

(٦) لأن الشيء قد يتغير بطول الزمان، ومن شهد له الظاهر فالقول قوله وإليه مال شمس الأئمة السرخسي - رَحِمَهُ اللَّهُ -، وبه كان يفتي الصدر الشهيد - رَحِمَهُ اللَّهُ - والإمام ظهير الدين المرغيناني - رَحِمَهُ اللَّهُ -.

(٧) يعني إذا اختلف البائع والمشتري في رؤية المشتري: فالقول قول المشتري؛ لأن الرؤية أمر حادث، والمشتري ينكره فيكون القول قوله مع يمينه.

(٨) الْعِدْلُ: بِالْكَسْرِ الْمِثْلُ، وَمِنْهُ عِدْلُ الْمَتَاعِ. وَالزُّطُّ: جِبِلٌّ مِنَ الْهِنْدِ يُنْسَبُ إِلَيْهِمُ الثِّيَابُ الزُّطِّيَّةُ.

(٩) أي تمام الصفقة؛ لأن تمامها بالرضا ولا رضا مع وجودهما.

(١٠) أي وإن كانت الصفقة لا تتم قبل القبض في خيار العيب.

(١١) أي هذه المسألة في المقبوض؛ لأنه لو كان وضع المسألة قبل القبض لما جاز التصرف فيه.

(١٢) أي لو عاد الثوب إلى المشتري.

فَسُخِّ^(١) فَهُوَ عَلَى خِيَارِ الرُّؤْيَةِ^(٢)، كَذَا ذَكَرَهُ شَمْسُ الْأَيْمَةِ السَّرْحَسِيُّ^(٣)، وَعَنْ أَبِي يُوسُفَ أَنَّهُ^(٤) لَا يَعُودُ بَعْدَ سُقُوطِهِ^(٥) كَخِيَارِ الشَّرْطِ، وَعَلَيْهِ اعْتَمَدَ الْقُدُورِيُّ^(٦).

(بَابُ خِيَارِ الْعَيْبِ)^(٧)

وَإِذَا اطَّلَعَ الْمُشْتَرِي عَلَى عَيْبٍ فِي الْمَبِيعِ فَهُوَ بِالْخِيَارِ، إِنْ شَاءَ أَخَذَهُ بِجَمِيعِ الثَّمَنِ، وَإِنْ شَاءَ رَدَّهُ^(٩) لِأَنَّ مُطْلَقَ الْعَقْدِ^(١٠) يَفْتَضِي وَصْفَ السَّلَامَةِ، فَعِنْدَ قُوَّتِهِ يَتَخَيَّرُ كَيْ لَا يَتَضَرَّرَ بِالزُّومِ مَا لَا بِهِ، وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُمْسِكَهُ وَيَأْخُذَ التُّقْصَانَ؛ لِأَنَّ الْأَوْصَافَ لَا يُقَابِلُهَا شَيْءٌ مِنَ الثَّمَنِ فِي مُجَرَّدِ الْعَقْدِ^(١١)؛ وَلِأَنَّهُ^(١٢) لَمْ يَرْضَ بِزَوَالِهِ عَنْ مِلْكِهِ بِأَقْلٍ مِنَ الْمُسَمَى^(١٣) فَيَتَضَرَّرُ بِهِ، وَدَفْعَ الضَّرَرِ عَنْ

(١) كالدرد بخيار الرؤية أو الشرط أو العيب بالقضاء أو الرجوع في الهبة.

(٢) أي فالمشتري على خيار الرؤية لارتفاع المانع من الأصل.

(٣) في "المبسوط".

(٤) أي خيار الرؤية.

(٥) لأن الساقط لا يعود.

(٦) وفي فتاوى قاضي خان: وهو الصحيح.

(٧) أخر خيار العيب لأنه يمنع اللزوم بعد التمام، وإضافة الخيار إلى العيب من قبيل إضافة الشيء إلى سببه، والعيب: ما تخلص عنه أصل الفطرة السليمة مما يعد به ناقصاً.

(٨) لم أعلق على مسائل العيب لخلو زماننا منها.

(٩) هذا إذا لم يتمكن من إزالته بلا مشقة، فإن تمكن فلا كما في نجاسة الثوب المشتري، وأمكنه غسله دون أن ينتقص ثمنه.

(١٠) وهو ما لم يشترط فيه البراءة من كل عيب.

(١١) وهذا احتراز عما إذا كانت الأوصاف مقصودة بالتناول: كما إذا ضربت الدابة فاعورت، أو معيبة، أو قطع البائع يد المبيع قبل القبض فإنه يسقط نصف الثمن؛ لأنه صار مقصوداً بالتناول، أو حكماً بأن يمتنع الرد بحق البائع بالعيب أو بحق الشرع بالجناية فإن لها قسطاً من الثمن حينئذ.

(١٢) أي البائع.

(١٣) أي بأقل من الثمن المذكور في العقد.

المُشْتَرِي مُمَكِّن بِالرَّدِّ بِدُونِ تَضَرُّرِهِ، ^(١)، وَالْمُرَادُ عَيْبٌ كَانَ عِنْدَ الْبَائِعِ وَلَمْ يَرَهُ الْمُشْتَرِي عِنْدَ الْبَيْعِ وَلَا عِنْدَ الْقَبْضِ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ رِضًا بِهِ .

قَالَ ^(٢): وَكُلُّ مَا أَوْجَبَ نُقْصَانَ الثَّمَنِ فِي عَادَةِ التُّجَّارِ فَهُوَ عَيْبٌ ^(٣)؛ لِأَنَّ التَّضَرُّرَ بِنُقْصَانِ الْمَالِيَّةِ، وَذَلِكَ بِانْتِقَاصِ الْقِيَمَةِ وَالْمَرْجِعِ فِي مَعْرِفَتِهِ عُرْفُ أَهْلِهِ، وَالْإِبَاقُ وَالْبُؤْلُ فِي الْفِرَاشِ وَالسَّرِقَةُ فِي الصَّغِيرِ عَيْبٌ مَا لَمْ يَبْلُغْ، فَإِذَا بَلَغَ فَلَيْسَ ذَلِكَ بِعَيْبٍ حَتَّى يُعَاوَدَهُ بَعْدَ الْبُلُوغِ وَمَعْنَاهُ: إِذَا ظَهَرَتْ عِنْدَ الْبَائِعِ فِي صِغَرِهِ ثُمَّ حَدَّثَتْ عِنْدَ الْمُشْتَرِي فِي صِغَرِهِ فَلَهُ أَنْ يَرُدَّهُ؛ لِأَنَّهُ عَيْنُ ذَلِكَ، وَإِنْ حَدَّثَتْ بَعْدَ بُلُوغِهِ لَمْ يَرُدَّهُ؛ لِأَنَّهُ غَيْرُهُ، وَهَذَا؛ لِأَنَّ سَبَبَ هَذِهِ الْأَشْيَاءِ يَخْتَلِفُ بِالصَّغَرِ وَالْكِبَرِ، فَالْبُؤْلُ فِي الْفِرَاشِ فِي الصَّغَرِ لَضَعْفِ الْمَثَانَةِ، وَبَعْدَ الْكِبَرِ لِدَاءٍ فِي بَاطِنِهِ، وَالْإِبَاقُ فِي الصَّغَرِ لِحُبِّ اللَّعِبِ وَالسَّرِقَةُ لِقِلَّةِ الْمُبَالَاةِ، وَهُمَا بَعْدَ الْكِبَرِ لِحُبِّ الثَّيِّبِ فِي الْبَاطِنِ، وَالْمُرَادُ مِنَ الصَّغِيرِ مَنْ يَعْقِلُ، فَأَمَّا الَّذِي لَا يَعْقِلُ فَهُوَ ضَالٌّ لَا آبِقُ فَلَا يَتَحَقَّقُ عَيْبًا.

قَالَ (وَالْجُنُونُ فِي الصَّغَرِ عَيْبٌ أَبَدًا) وَمَعْنَاهُ: إِذَا جُنَّ فِي الصَّغَرِ فِي يَدِ الْبَائِعِ ثُمَّ عَاوَدَهُ فِي يَدِ الْمُشْتَرِي فِيهِ أَوْ فِي الْكِبَرِ يَرُدُّهُ؛ لِأَنَّهُ عَيْنُ الْأَوَّلِ، إِذِ السَّبَبُ فِي الْحَالَيْنِ مُتَّحِدٌ وَهُوَ فَسَادُ الْبَاطِنِ، وَلَيْسَ مَعْنَاهُ أَنَّهُ لَا يَشْتَرِطُ الْمُعَاوَدَةُ فِي يَدِ الْمُشْتَرِي؛ لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَادِرٌ عَلَى إِزَالَتِهِ وَإِنْ كَانَ قَلَمًا يَزُولُ فَلَا بُدَّ مِنَ الْمُعَاوَدَةِ لِلرَّدِّ .

قَالَ: وَالْبَخَرُ (٤) وَالْدَّفَرُ (٥) عَيْبٌ فِي الْجَارِيَةِ؛ لِأَنَّ الْمَقْصُودَ قَدْ يَكُونُ الْإِسْتِفْرَاشَ وَطَلَبَ الْوَلَدِ وَهُمَا يُحْلَلَانِ بِهِ، وَلَيْسَ بِعَيْبٍ فِي الْغُلَامِ؛ لِأَنَّ الْمَقْصُودَ الْإِسْتِخْدَامَ وَلَا يُحْلَلَانِ بِهِ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ مِنْ دَاءٍ؛ لِأَنَّ الدَّاءَ عَيْبٌ (وَالزَّنَا وَوَلَدُ الزَّنَا عَيْبٌ فِي الْجَارِيَةِ ذَوْنُ الْغُلَامِ)؛ لِأَنَّهُ يُحِلُّ بِالْمَقْصُودِ فِي الْجَارِيَةِ وَهُوَ الْإِسْتِفْرَاشُ وَطَلَبُ الْوَلَدِ، وَلَا يُحِلُّ بِالْمَقْصُودِ فِي الْغُلَامِ وَهُوَ الْإِسْتِخْدَامُ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ الزَّنَا عَادَةً لَهُ عَلَى مَا قَالُوا؛ لِأَنَّ اتِّبَاعَهُنَّ يُحِلُّ بِالْخِدْمَةِ.

(١) أي بدون تضرر البائع.

(٢) أي الإمام القدوري رحمه الله-، أراد بهذا بيان معرفة العيوب؛ لأنه قال أولاً: إذا اطلع المشتري على عيب .. إلى آخره يحتاج إلى معرفة العيوب فبين المعيب بهذا الضابط الكلي.

(٣) هذا ضابطٌ كُلِّيٌّ يُعْلَمُ بِهِ الْعُيُوبُ الْمُوجِبَةُ لِلْخِيَارِ عَلَى سَبِيلِ الْإِجْمَالِ.

(٤) البَخَرُ: رائحة متغيرة من الفم، وكل رائحة ساطعة فهو بخر مأخوذ من بخار القدر أو بخار الدخان.

(٥) الدَّفَرُ: نَتْنٌ رِيحُ الْإِبْطِ.

قَالَ (وَالْكَفَرُ عَيْبٌ فِيهِمَا) ؛ لِأَنَّ طَبَعَ الْمُسْلِمِ يَنْفِرُ عَنْ صُحْبَتِهِ. وَلِأَنَّهُ يَمْتَنِعُ صَرْفُهُ فِي بَعْضِ الْكَفَّارَاتِ فَتَحْتَاطُ الرُّغْبَةُ، فَلَوْ اشْتَرَاهُ عَلَى أَنَّهُ كَافِرٌ فَوَجَدَهُ مُسْلِمًا لَا يَرُدُّهُ؛ لِأَنَّهُ زَوَّالُ الْعَيْبِ. وَعِنْدَ الشَّافِعِيِّ يَرُدُّهُ؛ لِأَنَّ الْكَافِرَ يُسْتَعْمَلُ فِيمَا لَا يُسْتَعْمَلُ فِيهِ الْمُسْلِمُ، وَفَوَاتُ الشَّرْطِ بِمَنْزِلَةِ الْعَيْبِ.

قَالَ: فَلَوْ كَانَتْ الْجَارِيَةُ بِالْعَةِ لَا تَحِيضُ أَوْ مُسْتَحَاضَةً فَهُوَ عَيْبٌ ؛ لِأَنَّ ارْتِفَاعَ الدَّمِ وَاسْتِمْرَارَهُ عِلَامَةُ الدَّاءِ، وَيُعْتَبَرُ فِي الِارْتِفَاعِ أَقْصَى غَايَةِ الْبُلُوغِ وَهُوَ سَعْعُ عَشْرَةِ سَنَةٍ فِيهَا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ - رَحِمَهُ اللَّهُ -، وَيُعْرَفُ ذَلِكَ بِقَوْلِ الْأَمَةِ فَتَرُدُّ إِذَا انْضَمَّ إِلَيْهِ نُكُولُ الْبَائِعِ قَبْلَ الْقَبْضِ وَبَعْدَهُ وَهُوَ الصَّحِيحُ.

قَالَ (١): وَإِذَا حَدَّثَ عِنْدَ الْمُشْتَرِي عَيْبٌ فَاطَّلَعَ عَلَى عَيْبٍ كَانَ عِنْدَ الْبَائِعِ فَلَهُ أَنْ يَرْجِعَ بِالنَّقْصَانِ (٢) وَلَا يَرُدُّ الْمَبِيعَ؛ لِأَنَّ فِي الرَّدِّ إِضْرَارًا بِالْبَائِعِ؛ لِأَنَّهُ خَرَجَ عَنْ مِلْكِهِ سَالِمًا، وَيَعُودُ مَعِيًّا فَاِمْتَنَعَ، وَلَا بُدَّ مِنْ دَفْعِ الضَّرَرِ عَنْهُ فَتَعَيَّنَ الرُّجُوعُ بِالنَّقْصَانِ إِلَّا أَنْ يَرْضَى الْبَائِعُ أَنْ يَأْخُذَهُ بِعَيْبِهِ؛ لِأَنَّهُ رَضِيَ بِالضَّرَرِ (٣).

قَالَ: وَمَنْ اشْتَرَى ثَوْبًا فَقَطَعَهُ فَوَجَدَ بِهِ عَيْبًا رَجَعَ بِالْعَيْبِ؛ لِأَنَّهُ امْتَنَعَ الرَّدَّ بِالْقَطْعِ فَإِنَّهُ (٤) عَيْبٌ حَادِثٌ (٥)، فَإِنْ قَالَ الْبَائِعُ: أَنَا أَقْبَلُهُ كَذَلِكَ كَانَ لَهُ ذَلِكَ) ؛ لِأَنَّ الْإِمْتِنَاعَ لِحَقِّهِ وَقَدْ رَضِيَ بِهِ (٦)، فَإِنْ بَاعَهُ الْمُشْتَرِي لَمْ يَرْجِعْ بِشَيْءٍ (٧)؛ لِأَنَّ الرَّدَّ غَيْرُ مُمْتَنِعٍ بِرِضَا الْبَائِعِ فَيَصِيرُ هُوَ (٨) بِالْبَيْعِ حَاسِبًا لِلْمَبِيعِ فَلَا يَرْجِعُ بِالنَّقْصَانِ فَإِنْ قَطَعَ الثَّوْبُ (٩) وَخَاطَهُ أَوْ صَبَّغَهُ أَحْمَرَ، أَوْ لَتَّ السَّوِيقَ بِسَمْنٍ ثُمَّ اطَّلَعَ عَلَى

(١) أي القدوري.

(٢) أي بنقصان العيب بأن يُقَوِّمَ المبيع سليماً عن العيب القديم ويُقَوِّمَ معيباً به، فما كان بينهما من عشر أو ثمن أو سدس أو غير ذلك يرجع به على البائع.

(٣) والرضا إسقاط لحقه.

(٤) أي القطع.

(٥) ولا يقال: البائع يتضرر برده معيباً، والمشتري يتضرر لعدم رده، فكان الواجب ترجيح جانب المشتري.

(٦) أي لأن امتناع الرد كان لحق البائع، وقد رضي بالثوب المعيب فكان إسقاطاً لحقه.

(٧) أي إن باعه المشتري بعد القطع لم يرجع بشيء، سواء علم بالعيب أو لا.

(٨) أي المشتري.

(٩) الذي اشتراه.

عَيْبٍ رَجَعَ بِنُقْصَانِهِ) لِمُتَنَاعِ الرَّدِّ بِسَبَبِ الزِّيَادَةِ؛ لِأَنَّهُ لَا وَجْهَ إِلَى الْفَسْخِ فِي الْأَصْلِ ^(١) بِدُونِهَا؛ ^(٢) لِأَنَّهَا لَا تَنفَكُ عَنْهُ ^(٣)، وَلَا وَجْهَ إِلَيْهِ مَعَهَا ^(٤)؛ لِأَنَّ الزِّيَادَةَ لَيْسَتْ بِمَبِيعَةٍ فَا مَتَّعَ أَصْلًا ^(٥) "وَلَيْسَ لِلْبَائِعِ أَنْ يَأْخُذَهُ" ^(٦)؛ لِأَنَّ الْإِمْتِنَاعَ لِحَقِّ الشَّرْعِ لَا لِحَقِّهِ ^(٧) فَإِنْ بَاعَهُ الْمُشْتَرِي ^(٨) بَعْدَمَا رَأَى الْعَيْبَ رَجَعَ بِالنَّقْصَانِ؛ لِأَنَّ الرَّدَّ مُمْتَنِعٌ أَصْلًا قَبْلَهُ ^(٩)، فَلَا يَكُونُ بِالْبَيْعِ حَابِسًا لِلْمَبِيعِ ^(١٠) قُلْنَا: إِنَّ مَنْ اشْتَرَى فَقَطَعَهُ لِبَاسًا لَوْلَدِهِ الصَّغِيرِ وَخَاطَهُ ثُمَّ اطَّلَعَ عَلَى عَيْبٍ لَا يَرْجِعُ بِالنَّقْصَانِ، وَلَوْ كَانَ الْوَلَدُ كَبِيرًا يَرْجِعُ؛ لِأَنَّ التَّمْلِيكَ حَصَلَ فِي الْأَوَّلِ قَبْلَ الْخِيَاطَةِ ^(١١)، وَفِي الثَّانِي ^(١٢) بَعْدَهَا بِالتَّسْلِيمِ إِلَيْهِ ^(١٣).

قَالَ: (وَمَنْ اشْتَرَى عَبْدًا فَأَعْتَقَهُ أَوْ مَاتَ عِنْدَهُ ثُمَّ اطَّلَعَ عَلَى عَيْبٍ رَجَعَ بِنُقْصَانِهِ) أَمَّا الْمَوْتُ؛ فَلِأَنَّ الْمَلِكَ يَنْتَهِي بِهِ وَالْإِمْتِنَاعُ حُكْمِي لَا يَفْعَلُهُ، وَأَمَّا الْإِعْتَاقُ فَالْقِيَاسُ فِيهِ أَنْ لَا يَرْجِعَ؛ لِأَنَّ الْإِمْتِنَاعَ يَفْعَلُهُ فَصَارَ كَالْقَتْلِ، وَفِي الْإِسْتِحْسَانِ: يَرْجِعُ؛ لِأَنَّ الْعِتْقَ إِنِّهَاءُ الْمِلْكِ؛ لِأَنَّ الْأَدَمِيَّ مَا خُلِقَ فِي الْأَصْلِ مَحَلًّا لِلْمِلْكِ، وَإِنَّمَا يَنْبُتُ الْمِلْكُ فِيهِ مُوقَّتًا إِلَى الْإِعْتَاقِ فَكَانَ إِنِّهَاءً فَصَارَتْ كَالْمَوْتِ،

(١) أي في أي الثوب أو السويق.

(٢) أي بدون الزيادة.

(٣) أي لأن الزيادة لا تنفك عن الأصل.

(٤) أي لا وجه إلى الفسخ مع الزيادة.

(٥) أي امتنع الرد بالكلية.

(٦) أي أن يأخذ المبيع مع الزيادة.

(٧) أي امتناع الرد لحق الشرع بشبهة الربا، لا لحق البائع.

(٨) أي باع الثوب المصبوغ أو المخيط.

(٩) أي قبل بيع المشتري للزيادة الحادثة فيه بفعل المشتري.

(١٠) أي فلا يكون المشتري بالبيع حابساً للمبيع فيرجع بالنقصان.

(١١) لأنه بالقطع للصغير صار واهباً للثوب له مسلماً إليه، وصار الأب قابضاً عنه، وحق الرد الذي هو الحق الأصلي صار باطلاً بالقطع، فبطل البدل وهو الرجوع بالنقصان؛ لأنه صار حابساً للمبيع.

(١٢) وهو صورة كون الولد كبيراً.

(١٣) (بعدها): أي بعد الخياطة (بالتسليم إليه): أي إلى ولده الكبير فيكون له الرجوع بالنقصان؛ لأنه بمجرد القطع لا يكون مسلماً إليه؛ لأن الأب لا يصير قابضاً عن ولده الكبير = فلما خاطه خاطه على ملك نفسه فامتنع الرد بالخياطة فيرجع بالنقصان؛ لأنه لم يكن حابساً للمبيع.

وَهَذَا؛ لِأَنَّ الشَّيْءَ يَتَقَرَّرُ بِانْتِهَائِهِ فَيُجْعَلُ كَأَنَّ الْمَلِكَ بَاقٍ وَالرَّدُّ مُتَعَدِّرٌ. وَالتَّدْبِيرُ وَالِاسْتِيْلَادُ بِمَنْزِلَتِهِ؛ لِأَنَّهُ تَعَدَّرَ النَّفْلُ مَعَ بَقَاءِ الْمَحَلِّ بِالْأَمْرِ الْحُكْمِيِّ (وَإِنْ أَعْتَقَهُ عَلَى مَالٍ لَمْ يَرْجِعْ بِشَيْءٍ) ؛ لِأَنَّهُ حَبَسَ بَدَلَهُ وَحَبَسَ الْبَدَلَ كَحَبْسِ الْمُبْدَلِ. وَعَنْ أَبِي حَنِيفَةَ - رَحِمَهُ اللَّهُ - : أَنَّهُ يَرْجِعُ؛ لِأَنَّهُ إِنْهَاءٌ لِلْمَلِكِ وَإِنْ كَانَ بِعَوْضٍ .

(فَإِنْ قَتَلَ الْمُشْتَرِي الْعَبْدَ أَوْ كَانَ طَعَامًا فَأَكَلَهُ لَمْ يَرْجِعْ بِشَيْءٍ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ - رَحِمَهُ اللَّهُ - أَمَّا الْقَتْلُ فَالْمَذْكُورُ ظَاهِرُ الرِّوَايَةِ وَعَنْ أَبِي يُوسُفَ - رَحِمَهُ اللَّهُ - أَنَّهُ يَرْجِعُ) ؛ لِأَنَّ قَتْلَ الْمُوَلَى عَبْدَهُ لَا يَتَعَلَّقُ بِهِ حُكْمٌ دُنْيَاوِيٌّ فَصَارَ كَالْمَوْتِ حَتْفَ أَنْفِهِ فَيَكُونُ إِنْهَاءً. وَوَجْهُ الظَّاهِرِ أَنَّ الْقَتْلَ لَا يُوْجَدُ إِلَّا مَظْمُونًا، وَإِنَّمَا يَسْقُطُ الضَّمَانُ هَاهُنَا بِاعْتِبَارِ الْمَلِكِ فَيَصِيرُ كَالْمُسْتَفِيدِ بِهِ عَوْضًا، بِخِلَافِ الْإِعْتِقَاقِ؛ لِأَنَّهُ لَا يُوجِبُ الضَّمَانَ لَا مَحَالَةً كِإِعْتِقَاقِ الْمُعْسِرِ عَبْدًا مُشْتَرَكًا، وَأَمَّا الْأَكْلُ فَعَلَى الْخِلَافِ، فَعِنْدَهُمَا يَرْجِعُ وَعِنْدَهُ لَا يَرْجِعُ اسْتِحْسَانًا، وَعَلَى هَذَا الْخِلَافِ إِذَا لَبَسَ الثَّوبَ حَتَّى تَخْرُقَ لَهُمَا أَنَّهُ صَنَعَ فِي الْمَبِيعِ مَا يُفْصَدُ بِشِرَائِهِ وَيُعْتَادُ فِعْلُهُ فِيهِ فَأَشْبَهَ الْإِعْتِقَاقَ ، وَلَهُ أَنَّهُ تَعَدَّرَ الرَّدُّ بِفِعْلِ مَظْمُونٍ مِنْهُ فِي الْمَبِيعِ فَأَشْبَهَ الْبَيْعَ وَالْقَتْلَ، وَلَا مُعْتَبَرٌ بِكَوْنِهِ مَقْصُودًا؛ أَلَا يَرَى أَنَّ الْبَيْعَ مِمَّا يُفْصَدُ بِالشَّرَاءِ ثُمَّ هُوَ يَمْنَعُ الرُّجُوعَ، فَإِنْ أَكَلَ بَعْضَ الطَّعَامِ ثُمَّ عَلِمَ بِالْعَيْبِ فَكَذَا الْجَوَابُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ - رَحِمَهُ اللَّهُ -؛ لِأَنَّ الطَّعَامَ كَشَيْءٍ وَاحِدٍ فَصَارَ كَبَيْعِ الْبَعْضِ ، وَعِنْدَهُمَا أَنَّهُ يَرْجِعُ بِنُقْصَانِ الْعَيْبِ فِي الْكُلِّ، وَعَنْهُمَا أَنَّهُ يَرُدُّ مَا بَقِيَ؛ لِأَنَّهُ لَا يَضُرُّهُ التَّبْعِيضُ.

(قَالَ: وَمَنْ اشْتَرَى بَيْضًا أَوْ بَطِيخًا أَوْ قِثَاءً ^(١) أَوْ خِيَارًا أَوْ جَوْزًا فَكَسَرَهُ فَوَجَدَهُ فَاسِدًا فَإِنْ لَمْ يَنْتَفِعْ بِهِ ^(٢) رَجَعَ الثَّمَنُ كُلُّهُ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ بِمَالٍ فَكَانَ الْبَيْعُ بَاطِلًا ^(٣)، وَلَا يُعْتَبَرُ فِي الْجَوْزِ صَلَاحُ قِشْرِهِ

(١) القثاء: نوع من البطيخ نباتي قريب من الخيار، لكنه أطول، واحدته قثاءة، وهو اسم جنس لما يُسمى بمصنر الخيار والعجور والفقوس.

(٢) أي إن لم ينتفع بالمبيع كالقرع إذا وجدته مُرًّا، أو البيضة إذا وجدها فاسدة، وكذلك الفاكهة إذا وجدها فاسدة بعد الكسر فإن كان لا يساوي شيئاً يرجع بكل الثمن؛ لأنه تبين بطلان المبيع.

(٣) لعدم المالية؛ إذ المال ما ينتفع به في الحال أو في ثاني الحال، فإذا كان لا ينتفع به أصلاً لا يكون محلاً للبيع فبطل البيع، وبه قال الشافعي - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - واختاره المزني - رَحِمَهُ اللَّهُ - ، وهذا إذا كسره ولم يعلم بالعيب، أما لو كسره وهو عالم بالعيب، صار راضياً به فبطل حقه من كل وجه.

عَلَى مَا قِيلَ ^(١)؛ لِأَنَّ مَالِيَّتَهُ بِاعْتِبَارِ اللَّبِّ ^(٢)، وَإِنْ كَانَ يَنْتَفِعُ بِهِ مَعَ فَسَادِهِ لَمْ يَرُدَّهُ؛ لِأَنَّ الْكَسْرَ عَيْبٌ حَادِثٌ (و) لَكِنَّهُ (يَرْجِعُ بِنُقْصَانِ الْعَيْبِ) دَفْعًا لِلضَّرَرِ بِقَدْرِ الْإِمْكَانِ. ^(٣)، وَقَالَ الشَّافِعِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ -: يَرُدُّهُ ^(٤)؛ لِأَنَّ الْكَسْرَ بِتَسْلِيطِهِ ^(٥). قُلْنَا: التَّسْلِيطُ عَلَى الْكَسْرِ فِي مِلْكِ الْمُشْتَرِي لَا فِي مِلْكِهِ ^(٦) فَصَارَ كَمَا إِذَا كَانَ ثَوْبًا فَقَطَعَهُ ^(٧)، وَلَوْ وَجَدَ الْبَعْضُ فَاسِدًا وَهُوَ قَلِيلٌ جَارَ الْبَيْعُ اسْتِحْسَانًا؛ لِأَنَّهُ لَا يَخْلُو عَنْ قَلِيلٍ فَاسِدٍ ^(٨)، وَالْقَلِيلُ مَا لَا يَخْلُو عَنْهُ الْجَوْزُ عَادَةً كَالْوَاحِدِ وَالْاِثْنَيْنِ فِي الْمِائَةِ، وَإِنْ كَانَ الْفَاسِدُ كَثِيرًا لَا يَجُوزُ وَيَرْجِعُ بِكُلِّ الثَّمَنِ؛ لِأَنَّهُ جَمَعَ بَيْنَ الْمَالِ وَغَيْرِهِ فَصَارَ كَالْجَمْعِ بَيْنَ الْحُرِّ وَالْعَبْدِ. ^(٩)

قَالَ: وَمَنْ بَاعَ عَبْدًا فَبَاعَهُ الْمُشْتَرِي ثُمَّ رُدَّ عَلَيْهِ بَعِيْبٌ فَإِنْ قَبِلَ بِقَضَاءِ الْقَاضِي بِإِقْرَارٍ أَوْ بَيِّنَةٍ أَوْ بِإِبَاءِ يَمِينٍ لَهُ أَنْ يَرُدَّهُ عَلَى بَائِعِهِ؛ لِأَنَّهُ فَسَخَ مِنَ الْأَصْلِ فَجَعَلَ الْبَيْعَ كَأَنْ لَمْ يَكُنْ غَايَةُ الْأَمْرِ أَنَّهُ أَنْكَرَ قِيَامَ الْعَيْبِ لَكِنَّهُ صَارَ مُكَذَّبًا شَرْعًا بِالْقَضَاءِ، وَمَعْنَى الْقَضَاءِ بِالْإِقْرَارِ أَنَّهُ أَنْكَرَ الْإِقْرَارَ فَاتَّبَتْ بِالْبَيِّنَةِ، وَهَذَا بِخِلَافِ الْوَكِيلِ بِالْبَيْعِ إِذَا رُدَّ عَلَيْهِ بَعِيْبٌ بِالْبَيِّنَةِ حَيْثُ يَكُونُ رَدًّا عَلَى الْمُوَكَّلِ؛ لِأَنَّ الْبَيْعَ هُنَاكَ وَاحِدٌ وَالْمَوْجُودُ هَاهُنَا بَيْعَانِ، فَيُفْسَخُ الثَّانِي وَالْأَوَّلُ لَا يَنْفَسَخُ، وَإِنْ قَبِلَ بغير قَضَاءِ الْقَاضِي لَيْسَ لَهُ أَنْ يَرُدَّهُ؛ لِأَنَّهُ بَيْعٌ جَدِيدٌ فِي حَقِّ ثَالِثٍ وَإِنْ كَانَ فَسَخًا فِي حَقِّهِمَا وَالْأَوَّلُ ثَالِثُهُمَا.

(١) أشار به إلى الجواب عما قال بعض المشايخ - رَحِمَهُمُ اللَّهُ -: إذا كان لقشر الجوز قيمة: بأن كان في موضعٍ معتبراً كالحطب يوقد به، يرجع بحصة اللب ويصح العقد في قشره بحصة من الثمن؛ لأن العقد في القشر صادف محله.

(٢) أي لأن مالية الجوز قبل الكسر باعتبار اللب دون القشر.

(٣) من الجانبين.

(٤) أي إذا كسر مقدار ما لا بد منه للعلم بالعيب.

(٥) أي بتسليط البائع فصار كأنه فعله ورضي به.

(٦) أي لا في ملك البائع؛ لأنه بالبيع لم يبق ملكه، فلم يكن التسليط إلا في ملك المشتري، وذلك هدر لعدم ولايته عليه.

(٧) أي فصار كما إذا كان المبيع ثوباً فقطعه، ثم وجده معيباً: فإنه يرجع بالنقصان بالإجماع، وإن حصل التسليط منه لكونه هدرًا.

(٨) فهو كالتراب في الحنطة، وهذا في الاستحسان، وفي القياس: لا يجوز.

(٩) حيث يفسد في الكل.

"وفي الجامع الصغير: وإن رُدَّ عليه بإقراره بغير قضاءٍ بعيبٍ لا يحدث مثله لم يكن له أن يخصم الذي باعه) وبهذا يتبين أن الجواب فيما يحدث مثله وفيما لا يحدث سواء، وفي بعض روايات البيوع: إن كان فيما لا يحدث مثله يرجع بالتقصان للتيقن بقيام العيب عند البائع الأول. قال: ومن اشترى عبداً فقبضه فادعى عيباً لم يجز على دفع الثمن حتى يحلف البائع أو يقيم المشتري بينة؛ لأنه أنكر وجوب دفع الثمن حيث أنكر تعين حقه بدعوى العيب، ودفع الثمن أولاً ليتعين حقه بإزاء تعين المبيع؛ ولأنه لو قضي بالدفع فلعله يظهر العيب فينتقض القضاء فلا يفضي به صوناً لقضائه (فإن قال المشتري شهودي بالشام استحلف البائع ودفع الثمن) يعني إذا حلف ولا ينتظر حضور الشهود؛ لأن في الانتظار ضرراً بالبائع، وليس في الدفع كثير ضرر به؛ لأنه على حجبته، أما إذا نكل الرم العيب؛ لأنه حجة فيه .

قال: ومن اشترى عبداً فادعى إباحاً لم يحلف البائع حتى يقيم المشتري البينة أنه أبق عنده والمراذ التحليف على أنه لم يبق عنده؛ لأن القول وإن كان قوله ولكن إنكاره إنما يعتبر بعد قيام العيب به في يد المشتري ومعرفة بالحجة (فإذا أقامها حلف بالله لقد باعه وسلمه إليه وما أبق عنده قط) كذا قال في الكتاب، وإن شاء حلفه بالله ما له حق الرد عليك من الوجه الذي يدعي أو بالله ما أبق عندك قط أما لا يحلفه بالله لقد باعه وما به هذا العيب ولا بالله لقد باعه وسلمه وما به هذا العيب؛ لأن فيه ترك النظر للمشتري؛ لأن العيب قد يحدث بعد البيع قبل التسليم وهو موجب للرد، والأول دھول عنه والثاني يؤهم تعلقه بالشروط فيتأوله في اليمين عند قيامه وقت التسليم دون البيع، ولو لم يجد المشتري بينة على قيام العيب عنده وأراد تحليف البائع ما يعلم أنه أبق عنده يحلف على قولهما. واختلف المشايخ على قول أبي حنيفة - رحمه الله - لهما: إن الدعوى معتبرة حتى يترتب عليها البينة فكذا يترتب التحليف، ولله على ما قاله البعض أن الحلف يترتب على دعوى صحيحة، وليس تصح إلا من خصم ولا يصير خصماً فيه إلا بعد قيام العيب. وإذا نكل عن اليمين عندهما يحلف ثانياً للرد على الوجه الذي قدمناه. قال - رضي الله عنه -: إذا كانت الدعوى في إباق الكبير يحلف ما أبق منذ بلغ مبلغ الرجال؛ لأن الإباق في الصغير لا يوجب رده بعد البلوغ

قال: ومن اشترى جارية وتقابضا فوجد بها عيباً فقال البائع: بعثك هذه وأخرى معها وقال المشتري: بعثتها وحدها فالقول قول المشتري؛ لأن الاختلاف في مقدار المقبوض فيكون القول للقباض كما في العصب (وكذا إذا اتفقا على مقدار المبيع واختلفا في المقبوض) لما بينا.

قَالَ (وَمَنْ اشْتَرَى عَبْدَيْنِ صَفْقَةً وَاحِدَةً فَقَبَضَ أَحَدَهُمَا وَوَجَدَ بِالْآخَرِ عَيْبًا فَإِنَّهُ يَأْخُذُهُمَا أَوْ يَدْعُهُمَا) ؛ لِأَنَّ الصَّفْقَةَ تَتِمُّ بِقَبْضِهِمَا فَيَكُونُ تَفْرِيقُهَا قَبْلَ التَّمَامِ وَقَدْ ذَكَرْنَاهُ، وَهَذَا؛ لِأَنَّ الْقَبْضَ لَهُ شَبَهٌ بِالْعَقْدِ فَالتَّفْرِيقُ فِيهِ كَالْتَّفْرِيقِ فِي الْعَقْدِ ، وَلَوْ وَجَدَ بِالْمَقْبُوضِ عَيْبًا اخْتَلَفُوا فِيهِ. وَيُرْوَى عَنْ أَبِي يُوسُفَ - رَحِمَهُ اللَّهُ - أَنَّهُ يَرُدُّهُ خَاصَّةً، وَالْأَصَحُّ أَنَّهُ يَأْخُذُهُمَا أَوْ يَرُدُّهُمَا؛ لِأَنَّ تَمَامَ الصَّفْقَةِ تَعَلَّقَ بِقَبْضِ الْمُبِيعِ وَهُوَ اسْمٌ لِلْكُلِّ فَصَارَ كَحَبْسِ الْمُبِيعِ لَمَّا تَعَلَّقَ زَوَالُهُ بِاسْتِيفَاءِ الثَّمَنِ لَا يَزُولُ دُونَ قَبْضِ جَمِيعِهِ (وَلَوْ قَبْضَهُمَا ثُمَّ وَجَدَ) بِأَحَدِهِمَا عَيْبًا يَرُدُّهُ خَاصَّةً خِلَافًا لِزَفَرٍ. هُوَ يَقُولُ: فِيهِ تَفْرِيقُ الصَّفْقَةِ وَلَا يَعْرِى عَنْ ضَرَرٍ؛ لِأَنَّ الْعَادَةَ جَرَتْ بِصَمِّ الْجَبْدِ إِلَى الرَّدِّ فَإِشْبَهُ مَا قَبْلَ الْقَبْضِ وَخِيَارِ الرُّوْيَةِ وَالشَّرْطِ. وَلَنَا أَنَّهُ تَفْرِيقُ الصَّفْقَةِ بَعْدَ التَّمَامِ؛ لِأَنَّ بِالْقَبْضِ تَتِمُّ الصَّفْقَةُ فِي خِيَارِ الْعَيْبِ وَفِي خِيَارِ الرُّوْيَةِ وَالشَّرْطِ لَا تَتِمُّ بِهِ عَلَى مَا مَرَّ، وَلِهَذَا لَوْ أُسْتَحِقَّ أَحَدُهُمَا لَيْسَ لَهُ أَنْ يَرُدَّ الْآخَرَ. قَالَ: وَمَنْ اشْتَرَى شَيْئًا مِمَّا يُكَالُ ^(١) أَوْ يُوزَنُ ^(٢) فَوَجَدَ بَعْضَهُ عَيْبًا رَدَّهُ كُلَّهُ أَوْ أَخَذَهُ كُلَّهُ) وَمُرَادُهُ بَعْدَ الْقَبْضِ ^(٣)؛ لِأَنَّ الْمَكِيلَ إِذَا كَانَ مِنْ جِنْسٍ وَاحِدٍ فَهُوَ كَشَيْءٍ وَاحِدٍ؛ أَلَا يَرَى أَنَّهُ يُسَمَّى بِاسْمٍ وَاحِدٍ وَهُوَ الْكُرُّ وَنَحْوُهُ. وَقِيلَ هَذَا إِذَا كَانَ فِي وَعَاءٍ وَاحِدٍ، فَإِذَا كَانَ فِي وَعَاءَيْنِ ^(٤) فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ عَبْدَيْنِ حَتَّى يَرُدَّ الْوَعَاءَ الَّذِي وَجَدَ فِيهِ الْعَيْبَ دُونَ الْآخَرِ ، وَلَوْ أُسْتَحِقَّ بَعْضُهُ ^(٥) فَلَا خِيَارَ لَهُ فِي رَدِّ مَا بَقِيَ ؛ لِأَنَّهُ لَا يَضُرُّهُ التَّبَعِيزُ ^(٦)، وَالْإِسْتِحْقَاقُ لَا يَمْنَعُ تَمَامَ الصَّفْقَةِ؛ لِأَنَّ تَمَامَهَا بَرِضًا الْعَاقِدِ لَا بَرِضًا الْمَالِكِ، ^(٧)

(١) كالحنطة والتمر .

(٢) كالسمن والزعفران .

(٣) أي ومراده إذا كان الاطلاع على العيب بعد القبض، أما لو كان قبله فلا فرق بين المكيل والموزون وغيرهما كالثياب والعبيد من أنه يرد الكل أو يحبس الكل، بخلاف ما بعد القبض فإنه يجوز رد المعيب خاصة في غير المكيل والموزون دونهما، وإنما قلنا بعد القبض يرد الكل .

(٤) كما إذا اشترى عدلي حنطة صفقة فوجد بأحدهما عيباً فإنه يرد ذلك العدل خاصة .

(٥) أي بعض المكيل أو الموزون فلا خيار للمشتري في رد ما بقي بل يلزمه أن لا يرده، وروي عن أبي حنيفة أن له رده دفعاً لضرر مؤنة القسمة .

(٦) لا يضره التبعية، لا في القيمة ولا في المنفعة، أما في القيمة: فإن المد من القمح يباع على وزن ما يباع به الإردب والغرارة، وأما في المنفعة: فظاهر فلا يتضرر به .

(٧) تمامها برضا العاقد، وقد تحقق لا برضا المالك: يعني المستحق .

وَهَذَا ^(١) إِذَا كَانَ بَعْدَ الْقَبْضِ، أَمَا لَوْ كَانَ قَبْلَ الْقَبْضِ فَلَهُ أَنْ يَرُدَّ مَا بَقِيَ لِنَفْثِ الصَّفَقَةِ قَبْلَ التَّمَامِ ^(٢).

قَالَ (وَإِنْ كَانَ ثَوْبًا فَلَهُ الْخِيَارُ) ؛ لِأَنَّ التَّشْقِيقَ ^(٣) فِيهِ عَيْبٌ ^(٤) وَقَدْ كَانَ وَقْتُ الْبَيْعِ حَيْثُ ظَهَرَ الْإِسْتِحْقَاقُ، بِخِلَافِ الْمَكِيلِ وَالْمَوْزُونِ ^(٥).

قَالَ: وَمَنْ اشْتَرَى جَارِيَةً فَوَجَدَ بِهَا قُرْحًا فَدَاوَاهُ أَوْ كَانَتْ دَابَّةً فَرَكَبَهَا فِي حَاجَةٍ فَهُوَ رِضًا ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ دَلِيلُ قَصْدِهِ الْإِسْتِبْقَاءَ بِخِلَافِ خِيَارِ الشَّرْطِ؛ لِأَنَّ الْخِيَارَ هُنَاكَ لِلِاخْتِبَارِ وَأَنَّهُ بِالِاسْتِعْمَالِ فَلَا يَكُونُ الرُّكُوبُ مُسْقِطًا (وَإِنْ رَكَبَهَا لِيَرُدَّهَا عَلَى بَائِعِهَا أَوْ لِيَسْقِيَهَا أَوْ لِيَشْتَرِيَ لَهَا عُلْفًا فَلَيْسَ بِرِضًا) أَمَّا الرُّكُوبُ لِلرَّدِّ؛ فَلِأَنَّهُ سَبَبُ الرَّدِّ وَالْجَوَابُ فِي السَّقْيِ وَاشْتِرَاءِ الْعُلْفِ مَحْمُولٌ عَلَى مَا إِذَا كَانَ لَا يَجِدُ بُدًّا مِنْهُ، إِمَّا لِصُعُوبَتِهَا أَوْ لِعَجْزِهِ أَوْ لِكُونِ الْعُلْفِ فِي عَدَلٍ وَاحِدٍ، وَأَمَّا إِذَا كَانَ يَجِدُ بُدًّا مِنْهُ لِانْعِدَامِ مَا ذَكَرْنَاهُ يَكُونُ رِضًا.

قَالَ (وَمَنْ اشْتَرَى عَبْدًا قَدْ سَرَقَ وَلَمْ يَعْلَمْ بِهِ فَقُطِعَ عِنْدَ الْمُشْتَرِي لَهُ أَنْ يَرُدَّهُ وَيَأْخُذَ الثَّمَنَ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ - رَحِمَهُ اللَّهُ - . وَقَالَا: يَرْجِعُ بِمَا بَيْنَ قِيمَتِهِ سَارِقًا إِلَى غَيْرِ سَارِقٍ) وَعَلَى هَذَا الْخِلَافِ إِذَا قُتِلَ بِسَبَبٍ وَجَدَ فِي يَدِ الْبَائِعِ وَالْحَاصِلُ أَنَّهُ بِمَنْزِلَةِ الْإِسْتِحْقَاقِ عِنْدَهُ وَبِمَنْزِلَةِ الْعَيْبِ عِنْدَهُمَا. لَهُمَا أَنْ الْمَوْجُودَ فِي يَدِ الْبَائِعِ سَبَبُ الْقُطْعِ وَالْقَتْلِ وَأَنَّهُ لَا يُنَافِي الْمَالِيَّةَ فَتَنْفَذَ الْعَقْدُ فِيهِ لَكِنَّهُ مُتَعَيِّبٌ فَيَرْجِعُ بِنُقْصَانِهِ عِنْدَ تَعَدُّرِ رَدِّهِ وَصَارَ كَمَا إِذَا اشْتَرَى جَارِيَةً حَامِلًا فَمَاتَتْ فِي يَدِهِ بِالْوِلَادَةِ فَإِنَّهُ يَرْجِعُ بِفَضْلِ مَا بَيْنَ قِيمَتِهَا حَامِلًا إِلَى غَيْرِ حَامِلٍ. وَلَهُ أَنْ سَبَبُ الْوُجُوبِ فِي يَدِ الْبَائِعِ وَالْوُجُوبُ يُفْضِي إِلَى الْوُجُودِ

(١) أي كون الاستحقاق لا يوجب خيار الرد.

(٢) لأن تمامه بعد الرضا بالقبض.

(٣) أي التجزئة.

(٤) أي لو كان المستحق ثوباً ونحوه كعبدٍ وكتاب: فله الخيار؛ لأن التشقيق في الثوب عيب، والشركة والشركة في العبد عيب، فله الخيار بين رد الكل أو بقاءه شريكاً.

(٥) أي وقد كان هذا العيب وهو عيب الشركة كان ثابتاً وقت البيع وإنما تأخر ظهوره، والظهور فرع سابقة الثبوت فلم يحدث العيب عند المشتري بل ظهر عنده فلم يمنع الرد، بخلاف تمييز الجيد من الرديء في المكيل إذا كان في وعاء واحد أو كان صبرة فإنه عيب حدث عنده فلا يمكنه إلا رد الكل.

فَيَكُونُ الْوُجُودُ مُضَافًا إِلَى السَّبَبِ السَّابِقِ، وَصَارَ كَمَا إِذَا قُتِلَ الْمَغْصُوبُ أَوْ قُطِعَ بَعْدَ الرَّدِّ بِجَنَائِهِ وَجِدَتْ فِي يَدِ الْغَاصِبِ، وَمَا ذَكَرَ مِنَ الْمَسْأَلَةِ مَمْنُوعَةٌ .

وَلَوْ سَرَقَ فِي يَدِ الْبَائِعِ ثُمَّ فِي يَدِ الْمُشْتَرِي فَقُطِعَ بِهِمَا عِنْدَهُمَا يَرْجِعُ بِالتَّقْصَانِ كَمَا ذَكَرْنَا. وَعِنْدَهُ لَا يَرُدُّهُ بِدُونِ رِضَا الْبَائِعِ لِلْعَيْبِ الْحَادِثِ وَيَرْجِعُ بِرُبْعِ الثَّمَنِ، وَإِنْ قَبْلَهُ الْبَائِعُ فِثْلَاثَةِ الْأَرْبَاعِ؛ لِأَنَّ الْيَدَ مِنَ الْآدَمِيِّ نَصْفُهُ وَقَدْ تَلَفَتْ بِالْجَنَائَتَيْنِ وَفِي إِحْدَاهُمَا رُجُوعٌ فَيَتَنَصَّفُ؛ وَلَوْ تَدَاوَلَتْهُ الْأَيْدِي ثُمَّ قُطِعَ فِي يَدِ الْأَخِيرِ رَجَعَ الْبَاعَةُ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ عِنْدَهُ كَمَا فِي الْإِسْتِحْقَاقِ، وَعِنْدَهُمَا يَرْجِعُ الْأَخِيرُ عَلَى بَائِعِهِ وَلَا يَرْجِعُ بَائِعُهُ عَلَى بَائِعِهِ؛ لِأَنَّهُ بِمَنْزِلَةِ الْعَيْبِ وَقَوْلُهُ (فِي الْكِتَابِ وَلَمْ يَعْلَمْ الْمُشْتَرِي) يُفِيدُ عَلَى مَذْهَبِهِمَا؛ لِأَنَّ الْعِلْمَ بِالْعَيْبِ رِضًا بِهِ، وَلَا يُفِيدُ عَلَى قَوْلِهِ فِي الصَّحِيحِ؛ لِأَنَّ الْعِلْمَ بِالْإِسْتِحْقَاقِ لَا يَمْنَعُ الرُّجُوعَ.

قَالَ: وَمَنْ بَاعَ عَبْدًا وَشَرَطَ الْبَرَاءَةَ مِنْ كُلِّ عَيْبٍ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَرُدَّهُ بِعَيْبٍ وَإِنْ لَمْ يُسَمَّ الْعُيُوبُ بَعْدَهَا" وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: لَا تَصِحُّ الْبَرَاءَةُ بِنَاءً عَلَى مَذْهَبِهِ أَنَّ الْإِبْرَاءَ عَنِ الْحُقُوقِ الْمَجْهُولَةِ لَا يَصِحُّ. هُوَ يَقُولُ: إِنَّ فِي الْإِبْرَاءِ مَعْنَى التَّمْلِيكِ حَتَّى يَرْتَدَّ بِالرَّدِّ، وَتَمْلِيكِ الْمَجْهُولِ لَا يَصِحُّ. وَلَنَا أَنَّ الْجَهَالََةَ فِي الْإِسْقَاطِ لَا تُفْضِي إِلَى الْمُنَازَعَةِ وَإِنْ كَانَ فِي ضَمْنِهِ التَّمْلِيكِ لِعَدَمِ الْحَاجَةِ إِلَى التَّسْلِيمِ فَلَا تَكُونُ مُفْسِدَةً ، وَيَدْخُلُ فِي هَذِهِ الْبَرَاءَةِ الْعَيْبُ الْمَوْجُودُ وَالْحَادِثُ قَبْلَ الْقَبْضِ فِي قَوْلِ أَبِي يُوسُفَ. وَقَالَ مُحَمَّدٌ - رَحِمَهُ اللَّهُ - : لَا يَدْخُلُ فِيهِ الْحَادِثُ وَهُوَ قَوْلُ زُفَرٍ - رَحِمَهُ اللَّهُ - ؛ لِأَنَّ الْبَرَاءَةَ تَتَنَاوَلُ الثَّابِتَ. وَأَبِي يُوسُفَ أَنَّ الْغَرَضَ الْإِزَامُ الْعَقْدِ بِإِسْقَاطِ حَقِّهِ عَنْ صِفَةِ السَّلَامَةِ وَذَلِكَ بِالْبَرَاءَةِ عَنِ الْمَوْجُودِ وَالْحَادِثِ.

بَابُ ^(١) الْمُرَابَحَةِ وَالتَّوْلِيَةِ ^(٢)

قَالَ ^(٣) : الْمُرَابَحَةُ ^(٤) : نَقْلُ مَا مَلَكَهُ بِالْعَقْدِ الْأَوَّلِ بِالثَّمَنِ الْأَوَّلِ مَعَ زِيَادَةِ رِبْحٍ، وَالتَّوْلِيَةُ ^(٥) : نَقْلُ مَا مَلَكَهُ بِالْعَقْدِ الْأَوَّلِ بِالثَّمَنِ الْأَوَّلِ مِنْ غَيْرِ زِيَادَةِ رِبْحٍ. ^(٦) وَالبَّيْعَانِ جَائِزَانِ؛ لِاسْتِجْمَاعِ شَرَايِطِ الْجَوَازِ ^(٧) ،

(١) لما فرغ المصنف رحمه الله تعالى من ذكر أنواع البيوع التي ترجع إلى جانب المبيع، شرع في بيان أنواع البيوع التي ترجع أحكامها إلى جانب الثمن من المربحة والتولية والربا والصرف والبيع بالنسيئة، وتقديم الأول على الثاني؛ لأصالة المبيع دون الثمن. ينظر: العناية على الهداية (٤٩٥/٦)، البناءة على الهداية (٢٣١/٨).

(٢) أي هذا باب في بيان أحكام المربحة والتولية، والمربحة: بيع بالثمن الأول وزيادة، والتولية: بيع بالثمن الأول، والوضيعة: بيع بنقيصة عن الثمن الأول، وهي عقود مشروعة؛ لوجود شرائطها، وقد تعاملها الناس من لدن الصدر الأول إلى يومنا هذا، وتعامل الناس من غير نكير حجة شرعية، وقد صح «أنه - عليه الصلاة والسلام - لما أراد الهجرة قال لأبي بكر - رضي الله عنه - وقد اشترى بعيرين ولني أحدهما» وللناس حاجة إلى ذلك؛ لأن فيهم من لا يعرف قيمة الأشياء؛ فيستعين بمن يعرفها، ويطيب قلبه بما اشتراه وزيادة؛ ولهذا كان مبناها على الأمانة، ورأس المال في المواضعة حقه؛ فله أن يحط منه. ينظر: الاختيار لتعليل المختار (٢٨/٢)، العناية على الهداية (١٢٢/٦)، فتح باب العناية في شرح مختصر النقاية (٢٥٥، ٢٥٦/٣).

(٣) قائل النص هو الإمام أبو الحسين أحمد بن محمد المعروف بالقُدوري الحنفي المتوفى سنة (٤٢٨ هـ)، وكتابه: المختصر المشهور عند فقهاء الحنفية بالكتاب.

(٤) المربحة لغة بضم الميم: مصدر من باب المفاعلة الذي يستدعي مشاركة الاثنين. وشرعاً: بيع السلعة بما اشتراها به مع زيادة ربح معلوم. ينظر: طَلْبَةُ الطَّلَبَةِ (٢٤٠)، التعريفات للجرجاني (٢٦٦)، البناءة على الهداية (٢٣١/٨)، معجم لغة الفقهاء (٤٢٠).

(٥) التولية لغة: من ولى فلاناً عملاً؛ إذا أقامه عليه، وشرعاً: إعلام البائع المشتري بأن ثمن السلعة هو ثمن التكلفة دون زيادة ربح. ينظر: فتح باب العناية في شرح مختصر النقاية (٢٥٥، ٢٥٦/٣)، معجم لغة الفقهاء (٤٢٠).

(٦) يعني: بيع المربحة والتولية.

(٧) من الحرية والعقل والبلوغ ومبادلة المال بالمال؛ ولأن المبيع معلوم والثمن معلوم.

ينظر: الاختيار لتعليل المختار (٢٨/٢)، تبين الحقائق شرح كنز الدقائق (٧٣/٤)، شرح العلامة اللكنوي على الهداية (١٥٦/٥).

وَالْحَاجَةُ مَاسَّةٌ إِلَى هَذَا النَّوعِ مِنَ الْبَيْعِ؛ لِأَنَّ الْغَبِيَّ ^(١) الَّذِي لَا يَهْتَدِي فِي التَّجَارَةِ يَخْتِاجُ إِلَى أَنْ يَعْتَمِدَ فِعْلَ الذَّكِيِّ الْمُهْتَدِي وَتَطْيِبُ نَفْسُهُ بِمِثْلِ مَا اشْتَرَى وَبِزِيَادَةِ رِبْحٍ فَوَجِبَ الْقَوْلُ بِجَوَازِهِمَا، وَلِهَذَا كَانَ مَبْنَاهُمَا عَلَى الْأَمَانَةِ ^(٢) وَالْإِحْتِرَازِ عَنِ الْخِيَانَةِ وَعَنْ شُبُهَتَيْهَا، وَقَدْ صَحَّ «أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَمَّا أَرَادَ الْهَجْرَةَ ابْتِاعَ أَبُو بَكْرٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - بَعِيرَيْنِ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: وَلَيَّ ^(٣) أَحَدُهُمَا، فَقَالَ: هُوَ لَكَ بِغَيْرِ شَيْءٍ، فَقَالَ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ -: أَمَّا بِغَيْرِ ثَمَنِ فَلَا ^(٤).

قَالَ ^(٥) وَلَا تَصِحُّ الْمُرَابَحَةُ وَالتَّوَلِيَةُ حَتَّى يَكُونَ الْعَوْضُ مِمَّا لَهُ مِثْلٌ ^(٦)؛ لِأَنَّهُ إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ مِثْلٌ لَوْ مَلَكَهُ مَلَكَهُ بِالْقِيَمَةِ وَهِيَ مَجْهُولَةٌ (وَلَوْ كَانَ الْمُشْتَرِي بَاعَهُ مُرَابَحَةً مِمَّنْ يَمْلِكُ ذَلِكَ الْبَدَلُ

(١) الغبي: بفتح الغين وكسر الباء وتشديد الياء، هو الذي يخفى عليه الأمور، ويقال: هو قليل الفطنة، وهو على وزن فعيل. البناية على الهداية (٢٣١/٨)

(٢) أمور التجارة مبناها على الأمانة والتحرز عن الغش والخيانة، لأن المشتري يأتمن البائع في خبره معتمداً على قوله، فيجب على البائع التنزه عن الخيانة والتهمة وتجنب الكذب؛ لئلا يقع المشتري في بخس وغرور؛ ولأن التحرز عن ذلك كله واجب ما أمكن؛ قال الله تعالى عز شأنه: ﴿لَا يَأْتِيهِ الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ [الأنفال: ٢٧] ، وقال: - عليه الصلاة والسلام - «ليس منا من غشنا» ، وقال - عليه الصلاة والسلام - لو ابصت بن معبد: - رضي الله عنه = «الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات فذر ما يريبك إلى ما لا يريبك» وقال: - عليه الصلاة والسلام - «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يقفن مواقف التهم».

والاحتراز عن الخيانة وعن شبهة الخيانة والتهمة إنما يحصل ببيان ما يجب بيانه فلا بد من بيان ما يجب بيانه وما لا يجب؛ فإذا ظهرت الخيانة يرد أو يختار على ما هو مقرر عند الفقهاء. ينظر: بدائع الصنائع للكاساني (٢٣٥/٥)، الاختيار لتعليل المختار (٢٨/٢).

(٣) أي بعه مني تولية. شرح اللكنوي على الهداية (١٥٧/٥).

(٤) أخرجه - بمعناه - البخاري في صحيحه - كتاب المناقب - باب هجرة النبي صلى الله عليه وسلم حديث رقم (٣٩٠٦).

(٥) أي الإمام القدوري رحمه الله.

(٦) قوله: "مما له مثل" أي من ذوات الأمثال كالمكيلات والموزونات، والعديدات المتقاربة؛ لأنه إذا لم يكن من ذوات الأمثال بل من ذوات القيم أي العديدات المتقاربة كالثياب والدور فلا يمكن له رد

وَقَدْ بَاعَهُ بِرِنِحٍ دِرْهَمٍ أَوْ بِشَيْءٍ مِنَ الْمَكِيلِ مَوْصُوفٍ ^(١) جَازٍ؛ لِأَنَّهُ يَقْدَرُ عَلَى الْوَفَاءِ بِمَا التَّزَمَ (وَإِنْ بَاعَهُ ^(٢) رِنِحٌ دِه ^(٣) يَازِدُهُ ^(٤) لَا يَجُوزُ ؛ لِأَنَّهُ بَاعَهُ بِرَأْسِ الْمَالِ وَبِبَعْضِ قِيَمَتِهِ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ مِنْ ذَوَاتِ الْأَمْثَالِ ^(٥)، وَيَجُوزُ أَنْ يُضَيَّفَ إِلَى رَأْسِ الْمَالِ ^(٦) أَجْرَةَ الْقَصَّارِ ^(٧) وَالطَّرَازِ ^(٨) وَالصَّنِيعِ وَالْفَتْلِ ^(٩) وَأُجْرَةَ حَمْلِ الطَّعَامِ؛ لِأَنَّ الْعُرْفَ جَارٍ بِالْحَاقِ هَذِهِ الْأَشْيَاءِ بِرَأْسِ الْمَالِ فِي عَادَةِ التُّجَّارِ؛ وَلِأَنَّ كُلَّ مَا يَزِيدُ

عينه، ولا رد مثله، إذ لا مثل له، والقيمة مجهولة تعرف الخرز والظن، فيتمكن شبهة الخيانة، ويجب الاحتراز عنها.

ينظر: شرح العلامة اللكنوي على الهداية (١٥٧/٥)

(١) معين. المصدر السابق.

(٢) أي باع الذي اشتراه ببذل غير مثلي ممن يملك ذلك البذل بربح ده يازده إلخ. شرح اللكنوي على الهداية (١٥٧/٥)

(٣) لفظ (دِه) بفتح الدال وسكون الهاء: اسم للعشرة في اللغة الفارسية، ويازده: اسم أحد عشر بالفارسية أيضًا. ينظر: البناءة على الهداية (٢٣٣/٨).

(٤) قوله: "ربح ده يازده" أي بربح مقدار درهم على عشرة، فإن كان الثمن الأول عشرة كان الربح درهماً، وإن كان عشرين كان الربح درهمين، وإن كان ثلثين كان الربح ثلاث دراهم، فتسمية ربح ده يازده تقتضي أن يكون الربح من جنس رأس المال، لأنه جعل الربح مثل عشر الثمن، وعشر الشيء يكون من جنسه، والثمن ههنا ليس من ذوات الأمثال بل من ذوات القيم، فيصير بائعاً للعبد بذلك الثوب، وبجزء من أحد عشر جزء من الثوب، والجزء الحادي عشر لا يعرف إلا بالقيمة، فيكون بائعاً بالثوب، وبيع قيمته، والقيمة مجهولة فلا يجوز. ينظر: البناءة على الهداية (٢٣١/٨)، شرح اللكنوي على الهداية (١٥٨/٥)

(٥) وإذا كان من ذوات الأمثال قدر المشتري على تسليمه.

ينظر: الجوهرة النيرة (٤٨٠/١).

(٦) يعني المبيع..

(٧) يعني الخياط..

(٨) الطراز بكسر الطاء وتخفيف الراء: علّم بالثوب. ينظر: البناءة على الهداية (٢٣١/٨)، شرح اللكنوي على الهداية (١٥٨/٥).

(٩) الفتل: ما يصنع في أطراف الثياب بحريز أو كتان. ينظر: الجوهرة النيرة (٤٨٠/١).

في المبيع أو في قيمته يلحق به هذا هو الأصل، وما عددناه بهذه الصفة؛ لأن الصنع وأحواله^(١) يزيد في العين والحمل يزيد في القيمة إذ القيمة تختلف باختلاف المكان^(٢). (ويقول قام علي بكذا ولم يقل اشتريته بكذا)^(٣) كي لا يكون كاذباً وسوق الغنم بمنزلة الحمل^(٤)، بخلاف أجره الراعي وكراء بيت الحفظ؛ لأنه^(٥) لا يزيد في العين والمعنى، وبخلاف أجره التعليم لأن ثبوت الزيادة لمعنى فيه وهو حذافته^(٦)، فإن أطلع المشتري على خيانه^(٧) في المراجعة فهو بالخيار عند أبي حنيفة - رحمه الله -، إن شاء أخذه بجميع الثمن وإن شاء تركه .

-
- (١) يعني: الفتل والطرز. شرح العلامة اللكنوي على الهداية (١٥٨/٥).
- (٢) بحسب قرب المسافة وبعدها. وفي "شرح الطحاوي": وبعض مشايخنا - رحمه الله - أصل في ذلك أصلاً، فقال: كل ما يؤثر في المعقود عليه، فإن بدله يلحق برأس المال، وكل ما لا يؤثر في العين، فإنه لا يلحق برأس المال.
- وفي "الإيضاح: والمعنى الذي اعتمد عليه من اعتبار عادة التجار تعم المواضع كلها.
- ينظر: البنائة على الهداية (٢٣١/٨)، شرح اللكنوي على الهداية (١٥٨/٥).
- (٣) هذا لفظ القدوري - رحمه الله - يعني في كل موضع يجوز له أن يضم إلى رأس المال بقوله: قام علي بكذا. ولا يقول: اشتريته بكذا؛ تحرراً عن الكذب. ينظر: البنائة على الهداية (٢٣٤/٨)، النهر الفائق شرح كنز الدقائق (٤٥٧/٢).
- (٤) يعني في جواز ضم ما أنفق على الغنم في سياقها كما له أن يضم أجره الحمل. ينظر: البنائة على الهداية (٢٣٤/٨)، شرح اللكنوي على الهداية (١٥٩/٥).
- (٥) أي لأن أجره الراعي وكذا كراء بيت الحفظ. ينظر: البنائة على الهداية (٢٣٤/٨).
- (٦) يعني ذكاء ذهنه وفطنته. المصدران السابقان.
- (٧) المراد بالخيانة هنا: عدم الأمانة وترك البيان، وفسرها بعض فقهاء الحنفية: بأن يضم إلى الثمن ما لا يجوز ضمه، أو أخبر بأنه اشتراه بعشرة ورابع على درهم؛ فتبين أنه اشتراه بتسعة إما بإقراره أو بالبينة أو بنكوله عن اليمين وقد ادعاه المشتري.
- ثم إذا ظهرت الخيانة في المراجعة فلا يخلو: إما أن ظهرت في صفة الثمن، وإما أن ظهرت في قدره، فإن ظهرت في صفة الثمن؛ بأن اشترى شيئاً بنسيئة، ثم باعه مرابحة على الثمن الأول ولم يبين أنه اشتراه بنسيئة، أو باعه تولية ولم يبين ثم علم المشتري؛ فله الخيار بالإجماع إن شاء أخذه وإن شاء رده؛ لأن المراجعة عقد بني على الأمانة؛ لأن المشتري اعتمد البائع وانتتمه في الخبر عن الثمن الأول؛ فكانت الأمانة مطلوبة في هذا العقد؛ فكانت صيانتها عن الخيانة مشروطة دلالة؛ ففواتها يوجب الخيار كفوات السلامة عن العيب. بدائع الصنائع للكاساني (٢٣٥/٥)، البنائة على الهداية (٢٣٤/٨)، النهر الفائق شرح كنز الدقائق (٤٥٧/٢)، شرح اللكنوي على الهداية (١٥٩/٥).

وَإِنْ أَطْلَعَ عَلَى خِيَانَةٍ فِي التَّوْلِيَةِ أَسْقَطَهَا ^(١) مِنَ الثَّمَنِ، وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ - رَحِمَهُ اللَّهُ -: يَحْطُ فِيهِمَا، ^(٢) وَقَالَ مُحَمَّدٌ - رَحِمَهُ اللَّهُ -: يُخَيَّرُ فِيهِمَا ^(٣). لِمُحَمَّدٍ - رَحِمَهُ اللَّهُ - ^(٤): أَنَّ الْإِعْتِبَارَ لِلتَّسْمِيَةِ؛ لَكُونِهِ مَعْلُومًا، وَالتَّوْلِيَةُ وَالْمُرَابَحَةُ تَرْوِجُ وَتَرْغِيبُ؛ فَيَكُونُ ^(٥) وَصْفًا مَرْغُوبًا فِيهِ كَوْصَفِ السَّلَامَةِ ^(٦)؛ فَيَتَخَيَّرُ بِفَوَاتِهِ ^(٧)، وَلَأَبِي يُوسُفَ - رَحِمَهُ اللَّهُ - أَنَّ الْأَصْلَ فِيهِ ^(٨) كَوْنُهُ تَوْلِيَةً وَمُرَابَحَةً؛ وَلِهَذَا ^(٩) يَنْعَقِدُ بِقَوْلِهِ وَلَيْتَكَ بِالثَّمَنِ الْأَوَّلِ أَوْ بِعُتْكَ مُرَابَحَةً عَلَى الثَّمَنِ الْأَوَّلِ إِذَا كَانَ ذَلِكَ ^(١٠) مَعْلُومًا فَلَا بُدَّ مِنَ الْبِنَاءِ عَلَى الْأَوَّلِ وَذَلِكَ بِالْحَطِّ ^(١١)، غَيْرَ أَنَّهُ يُحْطُ فِي التَّوْلِيَةِ قَدْرُ الْخِيَانَةِ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ، وَفِي الْمُرَابَحَةِ مِنْهُ ^(١٢) وَمِنْ الرِّبْحِ، وَلَأَبِي حَنِيفَةَ - رَحِمَهُ اللَّهُ - أَنَّهُ لَوْ لَمْ يَحْطُ فِي

(١) يعني: أسقط قدرها من الثمن. البناءة على الهداية (٢٣٥/٨)، شرح اللكنوي على الهداية (١٥٨/٥).

(٢) أي يحط قدر الخيانة في المراجعة والتولية جميعًا، وبه قال الشافعي - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - في قول، وأحمد - رَحِمَهُ اللَّهُ - وابن أبي ليلى - رَحِمَهُ اللَّهُ - وحكى أبو حامد المروزي قولاً آخر عن الشافعي - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أن البيع لا يصح، وقيل: هو مذهب مالك - رَحِمَهُ اللَّهُ. ينظر: البناءة على الهداية (٢٣٥/٨).

(٣) يعني له الخيار، إن شاء أخذه بجميع الثمن، وإن شاء تركه وبه قال الشافعي - رضي الله عنه - في قول. ينظر: البناءة على الهداية (٢٣٥/٨).

(٤) أي دليل الإمام محمد بن الحسن رحمه الله تعالى.

(٥) أي يكون ذكر المراجعة والتولية..

(٦) أي كوصف سلامة المبيع؛ فإذا فات الوصف المرغوب فيه بظهور الخيانة كان بمنزلة العيب. البناءة على الهداية (٢٣٦/٨).

(٧) كما إذا وجد المبيع معيبًا. المصدر السابق.

(٨) أي قي لفظ المراجعة والتولية.

(٩) أي ولأجل كون العقد تولية ومراجعة.

(١٠) أي الثمن..

(١١) الحط والحطيطة بمعنى الوضيعة، ومنه: حططت من الدين، أي: أسقطت، والحطيطة: فعيلة

بمعنى مفعولة، واستحطه من الثمن كذا فحطه له، وانحط السعر: نقص، والحطيطة شرعًا: ما يترك

من الحق. ينظر: المصباح المنير ص (١٤٦)، معجم لغة الفقهاء (١٨٢).

(١٢) أي ويحط في المراجعة من رأس المال. البناءة على الهداية (٢٣٦/٨).

التَّوْلِيَةِ لَا تَبْقَى تَوْلِيَةً ^(١)؛ لِأَنَّهُ يَزِيدُ عَلَى الثَّمَنِ الْأَوَّلِ ^(٢)، فَيَتَغَيَّرُ التَّصَرُّفُ فَتَعَيَّنَ الْحَطُّ ، وَفِي الْمُرَابَحَةِ لَوْ لَمْ يُحِطْ تَبْقَى مُرَابَحَةً ^(٣)، وَإِنْ كَانَ يَتَفَاوَتُ الرَّبْحُ فَلَا يَتَغَيَّرُ التَّصَرُّفُ فَأَمَكَّنَ الْقَوْلُ بِالتَّخْيِيرِ ^(٤)، فَلَوْ هَلَكَ ^(٥) قَبْلَ أَنْ يَرُدَّهُ أَوْ حَدَثَ فِيهِ مَا يَمْنَعُ الْفَسْخَ ^(٦) يَلْزَمُهُ جَمِيعُ الثَّمَنِ فِي الرُّوَايَاتِ الظَّاهِرَةِ ^(٧)؛ لِأَنَّهُ مُجَرَّدُ خِيَارٍ لَا يُقَابِلُهُ شَيْءٌ مِنَ الثَّمَنِ كَخِيَارِ الرُّوْيَةِ وَالشَّرْطِ ^(٨)، بِخِلَافِ خِيَارِ الْعَيْبِ ^(٩)؛ لِأَنَّهُ ^(١٠) الْمُطَالَبَةُ بِتَسْلِيمِ الْفَائِتِ فَيَسْقُطُ مَا يُقَابِلُهُ ^(١١) عِنْدَ عَجْزِهِ ^(١٢).

قَالَ ^(١٣): وَمَنْ اشْتَرَى ثَوْبًا فَبَاعَهُ بِرِبْحٍ ثُمَّ اشْتَرَاهُ ، فَإِنْ بَاعَهُ مُرَابَحَةً طَرَحَ ^(١٤) عَنْهُ ^(١٥) كُلَّ رِبْحٍ كَانَ قَبْلَ ذَلِكَ ^(١)، فَإِنْ كَانَ ^(٢) اسْتَعْرِقَ الثَّمَنَ لَمْ يَبْعُهُ مُرَابَحَةً، وَهَذَا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ - رَحِمَهُ

- (١) يعني: لا يكون العقد تولية. المصدر السابق، النهر الفائق شرح كنز الدقائق (٤٥٧/٢).
- (٢) فيصير مرابحة.
- (٣) كما لو كانت من غير تصرف في العقد. ينظر: العناية على الهداية (١٢٧/٦).
- (٤) لفوات الرضا. البناءة على الهداية (٢٣٧/٨).
- (٥) يعني المبيع. المصدر السابق.
- (٦) عند ظهور الخيانة. المصدر السابق.
- (٧) احتراز به عما روي عن الإمام محمد - رَحِمَهُ اللَّهُ - في غير ظاهر الرواية: أنه يفسخ البيع على القيمة، إن كانت أقل من الثمن حتى يندفع الضرر عن المشتري. العناية على الهداية (١٢٧/٦)، البناءة على الهداية (٢٣٧/٨).
- (٨) وقد تعذر الرد بالهلاك أو غيره فيسقط خياره. المصدر السابق.
- (٩) بحيث لا يجب كل الثمن بل ينقص منه مقدار العيب لأجل العيب. المصدر السابق.
- (١٠) أي لأن خيار العيب. المصدر السابق.
- (١١) أي ما يقابل العيب من الثمن. المصدر السابق.
- (١٢) أي عجز المشتري عن تسليم الجزء الفائت بهلاك المبيع أو بحوث ما يمنع الفسخ. البناءة على الهداية (٢٣٧/٨).
- (١٣) قائل النص هنا هو الإمام محمد بن الحسن الشيباني رحمه الله في كتابه الجامع الصغير.
- (١٤) أي طرح البائع الأول وهو المشتري الثاني. البناءة على الهداية (٢٣٧/٨).
- (١٥) أي عن ثمن ما اشترى. شرح اللكنوي على الهداية (١٦١/٥).
- (١) يعني قبل الربح الذي حصل في العقد الثاني. المصدر السابق، البناءة على الهداية (٢٣٧/٨).
- (٢) أي الربح. البناءة على الهداية (٢٣٧/٨).

اللَّهُ - ^(١) وَقَالَ: ^(٢) يَبِيعُهُ مُرَابِحَةً عَلَى الثَّمَنِ الْأَخِيرِ، صُورَتُهُ: إِذَا اشْتَرَى ثَوْبًا بِعَشْرَةٍ وَبَاعَهُ ^(٣) بِخَمْسَةِ عَشَرَ ثُمَّ اشْتَرَاهُ ^(٤) بِعَشْرَةٍ فَإِنَّهُ يَبِيعُهُ مُرَابِحَةً بِخَمْسَةِ وَيَقُولُ قَامَ عَلَيَّ بِخَمْسَةٍ ^(٥)، وَلَوْ اشْتَرَاهُ بِعَشْرَةٍ وَبَاعَهُ بِعِشْرِينَ مُرَابِحَةً ثُمَّ اشْتَرَاهُ بِعَشْرَةٍ لَا يَبِيعُهُ مُرَابِحَةً أَصْلًا ^(٦)، وَعِنْدَهُمَا ^(٧): يَبِيعُهُ مُرَابِحَةً عَلَى الْعَشْرَةِ فِي الْفَضْلَيْنِ ^(٨)، لَهُمَا ^(٩): أَنَّ الْعَقْدَ الثَّانِي ^(١٠) عَقْدٌ مُتَجَدِّدٌ مُنْقَطِعُ الْأَحْكَامِ عَنِ الْأَوَّلِ فَيَجُوزُ الْمُرَابِحَةُ عَلَيْهِ، كَمَا إِذَا تَخَلَّلَ ثَالِثٌ ^(١١)، وَلَأَبَى حَنِيفَةَ - رَحِمَهُ اللَّهُ - أَنَّ شُبْهَةَ حُصُولِ الرِّبْحِ بِالْعَقْدِ الثَّانِي ثَابِتَةٌ ^(١٢)؛ لِأَنَّهُ يَتَأَكَّدُ بِهِ ^(١٣) بَعْدَمَا كَانَ عَلَى شَرَفِ السَّقُوطِ بِالظُّهُورِ عَلَى عَيْبِ ^(١) الشُّبْهَةِ

- (١) وبه قال الإمام أحمد رحمه الله. البناءة على الهداية (٢٣٧/٨).
- (٢) يعني: الصحابان أبو يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى، وبه قال الإمامان مالك والشافعي رحمهما الله تعالى. المصدر السابق.
- (٣) بعد القبض. شرح اللكنوي على الهداية (١٦١/٥).
- (٤) بعد نقد الثمن وتسليم المبيع.. المصدر السابق
- (٥) ولا يقول: اشتريته بخمسة لئلا يصير كاذبا. البناءة على الهداية (٢٣٨/٨).
- (٦) عند أبي حنيفة - رحمه الله - يعني: لا يبيعه مرابحة من غير بيان، بل يبيعه مساومة؛ لأنه إذا حط عنه الربح لا يبقى الثمن. البناءة على الهداية (٢٣٨/٨).
- (٧) أي عند أبي يوسف ومحمد رحمهما الله..
- (٨) يعني في المسألتين المذكورتين...
- (٩) يعني: دليل أبي يوسف ومحمد رحمهما الله..
- (١٠) أي الشراء بعشرة.
- (١١) بأن اشترى من مشتريه، توضيحه: باعه بعشرين ثم باعه المشتري إلى ثالث، ثم اشتره البائع بعشرة؛ تجوز المرابحة بعشرة. البناءة على الهداية (٢٣٧/٨).
- (١٢) يعني أن الربح الثاني الذي استفاده بالعقد كان على شرف السقوط؛ بأن يرد بعيب، فإذا اشتراه المشتري تأكد وهو معنى قول المصنف: (لأنه يتأكد به)
- البناءة على الهداية (٢٣٧/٨).
- (١٣) أي لأن الربح الذي كان على شرف السقوط يتأكد به، أي بالعقد الثاني البناءة على الهداية (٢٣٨/٨) النهر الفائق شرح كنز الدقائق (٤٥٧/٢).
- (١) وللتأكيد في بعض المواضع حكم الإيجاب، كما في شهود الطلاق قبل الدخول، إذا رجعوا نصف المهر؛ لتأكد ما كان على شرف السقوط؛ لاحتمال أنه يسقط بتقبيل ابن الزوج أو بالارتداد؛

كَالْحَقِيقَةِ فِي بَيْعِ الْمُرَابَحَةِ اخْتِطَاطًا؛ وَلِهَذَا ^(١) لَمْ تَجْزِ الْمُرَابَحَةُ فِيمَا أُخِذَ بِالصُّلْحِ لَشُبْهِهِ الْحَطِيطَةِ فَيَصِيرُ كَأَنَّهُ اشْتَرَى خَمْسَةً وَثَوْبًا بِعَشْرَةٍ فَيُطْرَحُ عَنْهُ خَمْسَةٌ ، بِخِلَافِ مَا إِذَا تَخَلَّلَ ثَالِثٌ؛ لِأَنَّ التَّأَكِيدَ ^(٢) حَصَلَ بِغَيْرِهِ ^(٣).

قَالَ: ^(٤) وَإِذَا اشْتَرَى الْعَبْدُ الْمَأْذُونُ لَهُ فِي التِّجَارَةِ ثَوْبًا بِعَشْرَةٍ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ يُحِيطُ بِرَقَبَتِهِ فَبَاعَهُ مِنَ الْمَوْلَى بِخَمْسَةِ عَشَرَ فَإِنَّهُ يَبِيعُهُ مُرَابَحَةً عَلَى عَشْرَةٍ، وَكَذَلِكَ إِنْ كَانَ الْمَوْلَى اشْتَرَاهُ فَبَاعَهُ مِنَ الْعَبْدِ؛ لِأَنَّ فِي هَذَا الْعَقْدِ شُبْهَةَ الْعَدَمِ بِجَوَازِهِ مَعَ الْمُنَافِي فَاعْتَبِرَ عَدَمًا فِي حُكْمِ الْمُرَابَحَةِ وَبَقِيَ الْإِعْتِبَارُ لِلأَوَّلِ فَيَصِيرُ كَأَنَّ الْعَبْدَ اشْتَرَاهُ لِلْمَوْلَى بِعَشْرَةٍ فِي الْفَصْلِ الْأَوَّلِ ^(٥)، وَكَأَنَّهُ يَبِيعُهُ لِلْمَوْلَى فِي الْفَصْلِ الثَّانِي ^(٦) فَيُعْتَبَرُ التَّمَنُّ الْأَوَّلُ .

قَالَ: ^(٧) وَإِذَا كَانَ مَعَ الْمُضَارِبِ ^(٨) عَشْرَةُ دَرَاهِمَ بِالنِّصْفِ فَاشْتَرَى ثَوْبًا بِعَشْرَةٍ وَبَاعَهُ مِنْ رَبِّ الْمَالِ بِخَمْسَةِ عَشَرَ

فإذا اعتبرنا التأكيد يصير البائع في مسألتنا مشترياً بالعقد الثاني ثوباً وخمسة دراهم بالعشرة، فيكون خمسة بإزاء الخمسة ويبقى الثوب بالخمسة، ويبيعه مرابحة على خمسة؛ احترازاً عن شبهة الخيانة. البناية على الهداية (٢٣٨/٨).

(١) أي للاحتياط. شرح اللكنوي على الهداية (١٦٢/٥) ..

(٢) أي تأكد الربح.

(٣) أي بفعل غيره وهو الثالث؛ فلم يستفد الربح المشتري الأول بالشراء الثاني؛ فانفتت الشبهة. البناية على الهداية (٢٣٨/٨).

(٤) أي الإمام محمد بن الحسن الشيباني رحمه الله في كتابه الجامع الصغير ..

(٥) وهو ما إذا باعه العبد من مولاه. شرح اللكنوي على الهداية (١٦٣/٥) ..

(٦) وهو ما إذا باعه المولى من عبده. المصدر السابق.

(٧) أي الإمام محمد رحمه الله في الجامع الصغير.

(٨) المضارب: هو العامل في شركة المضاربة، والمضاربة: بضم الميم، وفتح الراء: مشتقة من الضرب في الأرض، وهو السفر فيها للتجارة. وعقد المضاربة: هو عقد شركة يكون المال فيها من طرف، والعمل من طرف آخر، والربح بينهما على ما شرطاً، والخسارة على صاحب المال، وتسمى القراض. ينظر: طلبية الطلبة في الاصطلاحات الفقهية (٣٠١)، معجم لغة الفقهاء (٤٣٤).

فَإِنَّهُ ^(١) يَبِيعُهُ مُرَابَحَةً بِأَثْنِي عَشَرَ وَنِصْفٍ ^(٢)؛ لِأَنَّ هَذَا الْبَيْعَ وَإِنْ قُضِيَ بِجَوَازِهِ عِنْدَنَا عِنْدَ عَدَمِ الرِّبْحِ خِلَافًا لِزُفَرٍ رَحِمَهُ اللَّهُ ^(٣) عَ أَنَّهُ اشْتَرَى مَالَهُ بِمَالِهِ لِمَا فِيهِ ^(٤) مِنْ اسْتِفَادَةٍ وَلَايَةِ التَّصْرِيفِ ^(٥)، وَهُوَ مَقْصُودٌ ^(٦)، وَالْإِنْعِقَادُ يَتَّبِعُ الْفَائِدَةَ ^(٧)؛ فَفِيهِ شُبْهَةُ الْعَدَمِ؛ أَلَا تَرَى أَنَّهُ وَكَيْلٌ عَنْهُ فِي الْبَيْعِ الْأَوَّلِ مِنْ وَجْهِ ^(٨)؛ فَاعْتَبِرَ الْبَيْعُ الثَّانِي عَدَمًا ^(٩) فِي حَقِّ نِصْفِ الرِّبْحِ ^(١٠)، قَالَ ^(١١): (وَمَنْ اشْتَرَى جَارِيَةً فَاعْوَرَّتْ ^(١٢) أَوْ وَطَّئَهَا وَهِيَ ثِيْبٌ يَبِيعُهَا مُرَابَحَةً وَلَا يُبَيِّنُ)؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَحْتَسِبْ عِنْدَهُ شَيْئًا يُقَابِلُهُ الثَّمَنُ؛

(١) أي فإن رب المال.

(٢) لأن بيع المربحة بيع أمانة يحترز فيها عن الخيانة وعن شبهتها. ينظر: البناية على الهداية (٢٤٠/٨)، شرح اللكنوي على الهداية (١٦٣/٥)..

(٣) فإن عنده بيع المضارب من رب المال وبالعكس لا يجوز إذا لم يكن في المال ربح.. المصدران السابقان.

(٤) دليل قوله: (قضى بجوازه) وذلك أن ولاية التصرف انقطعت عن رب المال بتسليم المال إلى المضارب، ثم لما اشترى من المضارب استفاد ولاية التصرف، وهو معنى قوله: لما فيه، أي لما في هذا العقد. البناية على الهداية (٢٤١/٨).

(٥) أي ملك اليد، لأن رب المال بالتسليم إلى المضارب قطع ولاية التصرف عن ماله، وبالشراء عن المضارب يحصل له ولاية التصرف. البناية على الهداية (٢٤١/٨).

(٦) أي حصول ولاية التصرف هو المقصود. المصدر السابق.

(٧) أي انعقاد العقد يتبع الفائدة؛ لأن المال كالمملوك للمضارب في حق التصرف، وكغير المملوك لرب المال في حق التصرف، ولا يملك رب المال إبطال هذا الملك للمضارب إلا بالشراء؛ فجاز ذلك؛ لحصول الفائدة. المصدر السابق.

(٨) أي أن المضارب وكيل عن رب المال في البيع الأول من وجه؛ لأنه يعمل لنفسه ولرب المال؛ ولهذا يكون الربح لهما، بخلاف الوكيل؛ لأنه يعمل للموكل، ولهذا يكون الربح له. ينظر: البناية على الهداية (٢٤١/٨).

(٩) أي معدومًا.

(١٠) يعني لما كان فيه شبهة العدم اعتبر البيع الثاني عدما في حق نصف الربح؛ لأن ذلك حق رب المال. ينظر: البناية على الهداية (٢٤١/٨).

(١١) أي الإمام محمد رحمه الله في الجامع الصغير..

(١٢) في يد المشتري بأفة سماوية. شرح اللكنوي على الهداية (١٦٤/٥).

لِأَنَّ الْأَوْصَافَ تَابِعَةٌ لَا يُقَابَلُهَا الثَّمَنُ، وَلِهَذَا لَوْ فَاتَتْ قَبْلَ التَّسْلِيمِ لَا يَسْقُطُ شَيْءٌ مِنَ الثَّمَنِ، وَكَذَا مَنَافِعُ الْبُضْعِ لَا يُقَابَلُهَا الثَّمَنُ، وَالْمَسْأَلَةُ فِيمَا إِذَا لَمْ يُنْقِصْهَا الْوُطْءُ، وَعَنْ أَبِي يُوسُفَ - رَحِمَهُ اللَّهُ - فِي الْفَصْلِ الْأَوَّلِ أَنَّهُ لَا يَبِيعُ مِنْ غَيْرِ بَيَانٍ، كَمَا إِذَا اخْتَبَسَ بِفِعْلِهِ وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ - رَحِمَهُ اللَّهُ - (فَأَمَّا إِذَا فَقَّاهَا بِنَفْسِهِ أَوْ فَقَّاهَا أَجَنِيًّا فَأَخَذَ أَرْضَهَا ^(١) لَمْ يَبِعْهَا مُرَابَحَةً حَتَّى يُبَيِّنَ)؛ لِأَنَّهُ ^(٢) صَارَ مَقْصُودًا بِالْإِتْلَافِ فَيُقَابَلُهَا ^(٣) شَيْءٌ مِنَ الثَّمَنِ،

وَكَذَا إِذَا وَطَّئَهَا وَهِيَ بِكَرٍّ لِأَنَّ الْعُدْرَةَ ^(٤) جُزْءٌ مِنَ الْعَيْنِ يُقَابَلُهَا الثَّمَنُ وَقَدْ حَبَسَهَا. وَلَوْ اشْتَرَى ثَوْبًا فَأَصَابَهُ قَرْضٌ ^(٥) فَأَرِ أَوْ حَرَقَ نَارٍ يَبِيعُهُ مُرَابَحَةً مِنْ غَيْرِ بَيَانٍ ^(٦)، وَلَوْ تَكَسَّرَ بَشْرُهُ وَطِئَهُ لَا يَبِيعُهُ مُرَابَحَةً حَتَّى يُبَيِّنَ، وَالْمَعْنَى مَا بَيَّنَّاهُ ^(٧)، قَالَ ^(٨): (وَمَنْ اشْتَرَى غُلَامًا بِأَلْفِ دِرْهَمٍ نَسِئَةً ^(٩) فَبَاعَهُ بِرَبْحٍ مِائَةٍ وَلَمْ يُبَيِّنْ ^(١٠) فَعَلِمَ الْمُشْتَرِي، فَإِنْ شَاءَ رَدُّهُ، وَإِنْ شَاءَ قَبِلَ؛ لِأَنَّ لِلْأَجَلِ شَبْهًا بِالْمَبِيعِ؛ أَلَا يُرَى أَنَّهُ يَزَادُ فِي الثَّمَنِ لِأَجْلِ الْأَجَلِ، وَالشُّبْهَةُ فِي هَذَا مُلْحَقَةٌ بِالْحَقِيقَةِ فَصَارَ كَأَنَّهُ اشْتَرَى شَيْئَيْنِ وَبَاعَ أَحَدَهُمَا مُرَابَحَةً بِشَمَنِهِمَا، وَالْإِقْدَامُ عَلَى الْمُرَابَحَةِ يُوجِبُ السَّلَامَةَ عَنْ مِثْلِ هَذِهِ الْخِيَانَةِ فَإِذَا ظَهَرَتْ

(١) المراد بالأرض هنا: دية الجراحات. المصدر السابق.

(٢) أي لأن الوصف. المصدر السابق.

(٣) أي العين. المصدر السابق.

(٤) العذرة بالضم: البكارة. المصدر السابق.

(٥) قرض: بالقفاف، من قرض الثوب بالمقراض إذا قطعه. البناية على الهداية (٢٤٢/٨).

(٦) لأن الأوصاف تابعة لا يقابلها الثمن. المصدر السابق.

(٧) جاء في البناية على الهداية (٢٤٣، ٢٤٢/٨) ما نصه: " (والمعنى ما بيناه) يعني في الدليلين، أحدهما: في قرض الفأر، والآخر في تكسر الثوب) اهـ.

هذا: وبيان نفس العيب أمر لا بد منه، بأن يبين العيب والثمن من غير أن يبين أنه اشتراه سليماً ثم حدث به العيب عنده؛ لأن بيان ما فيه من العيب واجب شرعاً لقوله - صلى الله عليه وسلم - «من غشنا فليس منا» فلا يجوز إخفاؤه. ينظر: تبیین الحقائق (٧٨/٤). النهر الفائق شرح كنز الدقائق (٤٥٧/٢).

(٨) أي الإمام محمد رحمه الله في الجامع الصغير ..

(٩) أي إلى أجل.

(١٠) يعني: لم يبين أنه اشتراه نسيئة. شرح اللكنوى على الهداية (١٦٦/٥).

يُخَيَّرُ كَمَا فِي الْعَيْبِ (وَإِنْ اسْتَهْلَكَهُ^(١) ثُمَّ عَلِمَ ؛ لَزِمَهُ^(٢) بِالْأَلْفِ وَمِائَةٍ؛ لِأَنَّ الْأَجَلَ لَا يُقَابَلُهُ شَيْءٌ مِنْ الثَّمَنِ^(٣)).

قَالَ: ^(٤) فَإِنْ كَانَ وَلَاهُ إِيَّاهُ^(٥) وَلَمْ يُبَيِّنْ^(٦)؛ رَدَّهُ (إِنْ شَاءَ؛ لِأَنَّ الْخِيَانَةَ فِي التَّوْلِيَةِ مِثْلُهَا فِي الْمُرَابَحَةِ^(٧)؛ لِأَنَّهُ بِنَاءٌ عَلَى الثَّمَنِ الْأَوَّلِ، وَإِنْ كَانَ اسْتَهْلَكَهُ ثُمَّ عَلِمَ لَزِمَهُ بِالْأَلْفِ حَالَةً لَمَّا ذَكَرْنَاهُ^(٨).
وَعَنْ أَبِي يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ^(٩): أَنَّهُ^(١٠) يَرُدُّ الْقِيَمَةَ^(١١)، وَيَسْتَرِدُّ كُلَّ الثَّمَنِ، وَهُوَ نَظِيرُ مَا إِذَا اسْتَوْفَى الرُّبُوفَ^(١٢) مَكَانَ الْجِيَادِ وَعَلِمَ بَعْدَ الْإِتِّفَاقِ، وَسَيَّاتِيكَ مِنْ بَعْدِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى^(١) وَقِيلَ: ^(٢) يَقُومُ بِثَمَنِ حَالٍ وَبِثَمَنِ مُوجَلٍ فَيَرْجِعُ^(٣) بِفَضْلِ مَا بَيْنَهُمَا^(١)، وَلَوْ لَمْ يَكُنْ الْأَجَلُ

(١) وَإِنْ اسْتَهْلَكَ المشتري المبيع المذكور بوجه بأن باعه، أو بوجه آخر. البناءة على الهداية (٢٤٤/٨).

(٢) أي المبيع لزم المشتري لتعذر الفسخ. البناءة على الهداية (٢٤٤/٨).

(٣) لا يقابله شيء من الثمن حقيقة ولكن فيه شبهة المقابلة، فباعتبار شبهة الخيانة كان له أن يفسخ البيع إذا كان المبيع قائماً، فأما أن يسقط من الثمن شيء بعد الهلاك بمقابلة الأجل فلا. البناءة على الهداية (٢٤٤/٨).

(٤) أي الإمام محمد رحمه الله في الجامع الصغير.

(٥) أي باعه بالتولية. البناءة على الهداية (٢٤٤/٨).

(٦) أنه اشتراه بألف نسيئة ثم علم المشتري كان له الخيار. المصدر السابق

(٧) فلا زيادة ولا نقصان، فلا يمكن الحط هنا؛ لأن الثمن هو الألف ولا زيادة، فأى شيء يحط. المصدر السابق

(٨) أراد به قوله: (لأن الأجل لا يقابله شيء من الثمن). المصدر السابق

(٩) في النوادر. المصدر السابق

(١٠) أي قيمة العين. المصدر السابق

(١١) أي أن المشتري. المصدر السابق

(١٢) بأن كان له على آخر عشرة جياذ؛ فإذا استوفى زيوفاً، وعلم بعد الإنفاق يرد زيوفاً مثلاً ويأخذ الجياذ. البناءة على الهداية (٢٤٤/٨).

(١) أي في مسائل منثورة قبيل كتاب الصرف. المصدر السابق.

(٢) قائله الفقيه أبو جعفر الهندواني رحمه الله. المصدر السابق.

(٣) أي البائع. المصدر السابق.

مَشْرُوطًا فِي الْعَقْدِ وَلَكِنَّهُ مُنْجَمٌ مُعْتَادٌ^(٢)، قِيلَ: لَا بُدَّ مِنْ بَيَانِهِ؛ لِأَنَّ الْمَعْرُوفَ كَالْمَشْرُوطِ^(٣) وَقِيلَ: يَبِيعُهُ وَلَا يُبَيِّنُهُ^(٤)؛ لِأَنَّ الثَّمَنَ حَالٌ^(٥).

قَالَ^(٦): وَمَنْ وَلَّى رَجُلًا شَيْئًا بِمَا قَامَ عَلَيْهِ^(٧) وَلَمْ يَعْلَمْ^(٨) الْمُشْتَرِي بِكَمْ قَامَ عَلَيْهِ فَالْبَيْعُ فَاسِدٌ؛ لَجَهَالَةِ الثَّمَنِ^(٩)، فَإِنْ أَعْلَمَهُ^(١٠) الْبَائِعُ، يَعْنِي فِي الْمَجْلِسِ فَهُوَ بِالْخِيَارِ، إِنْ شَاءَ أَخَذَهُ وَإِنْ شَاءَ تَرَكَهُ؛ لِأَنَّ الْفَسَادَ لَمْ يَتَقَرَّرْ^(١١)، فَإِذَا حَصَلَ الْعِلْمُ فِي الْمَجْلِسِ جُعِلَ كَابْتِدَاءِ الْعَقْدِ^(١٢)، وَصَارَ كَتَأْخِيرِ الْقَبُولِ إِلَى آخِرِ الْمَجْلِسِ^(١)، وَبَعْدَ الْإِفْتِرَاقِ قَدْ تَقَرَّرَ فَلَا يُقْبَلُ الْإِصْلَاحُ، وَنَظِيرُهُ بَيْعُ الشَّيْءِ بِرَفْعِهِ^(١) إِذَا عَلِمَ^(٢) فِي الْمَجْلِسِ^(٣) وَإِنَّمَا يَتَخَيَّرُ أَنْ الرِّضَا لَمْ يَتِمَّ قَبْلَهُ^(٤)؛ لِعَدَمِ الْعِلْمِ فَيَتَخَيَّرُ، كَمَا فِي خِيَارِ الرُّؤْيَةِ^(٥).

-
- (١) أي التفاوت الذي بين القيمتين. البناية على الهداية (٢٤٥/٨).
- (٢) كعادة بعض البلدان يشتررون بعقد ويسلمون الثمن بعد أشهر، إما جملة وإما منجما. البناية على الهداية (٢٤٥/٨).
- (٣) أي لأن الثابت بالعرف كالمشروط بين العاقدين. البناية على الهداية (٢٤٥/٨).
- (٤) يعني لا يجب بيانه. البناية على الهداية (٢٤٥/٨).
- (٥) لعدم ذكر الأجل، والأصل الحال في الثمن. البناية على الهداية (٢٤٥/٨).
- (٦) أي الإمام محمد رحمه الله في الجامع الصغير ..
- (٧) يعني إذا قال: وليتك هذا بما قام علي، يريد به بما اشتراه به مع ما لحقه من المؤن، كالصبغ والعقل وغير ذلك. البناية على الهداية (٢٤٥/٨).
- (٨) أي والحال أنه لم يعلم. البناية على الهداية (٢٤٥/٨).
- (٩) وبه قال الشافعي - رحمه الله - في أصح الوجهين. والوجه الثاني: أنه لا يفسد البيع. البناية على الهداية (٢٤٥/٨).
- (١٠) أي فإن أعلم المشتري البائع بثمنه. البناية على الهداية (٢٤٥/٨).
- (١١) لأنه في مجلس العقد لا يتقرر؛ لأن ساعات المجلس كساعة واحدة؛ دفعا للضرر وتحقيقا لليسر. البناية على الهداية (٢٤٥/٨).
- (١٢) العقد لا يتقرر لأن ساعات المجلس كساعة واحدة دفعا للضرر وتحقيقا في وجهه، وفي وجهه قال: لا ينفلق صحيحا بعد ما انعقد فاسدا. البناية على الهداية (٢٤٥/٨).
- (١) فالتأخير إلى آخر المجلس معفو عنه كتأخير القبول إليه. الهداية (١٦٨/٥).

-
- (١) الرقم: بسكون القاف، صورته: أن التاجر يرقم الثياب، أي يعلمها بعلامة؛ بأن ثمنها كذا؛ فيبيع بذلك الثمن الذي هو معلوم للبائع غير معلوم للمشتري. المصدر السابق.
- (٢) أي المشتري إذا علم قدر ذلك الثمن. المصدر السابق.
- (٣) صح البيع، وإن كان بعد القبول، ويحصل كأنه علم وقت القبول، ولو علم بعد الافتراق لا يصح. المصدر السابق.
- (٤) أي قبل العلم بمقدار الثمن كما لا يتم بعدم الرؤية. المصدر السابق، شرح اللكنوي على الهداية (١٦٨/٥).
- (٥) أي كما يتخير في خيار الرؤية إذا رآه؛ إن شاء أخذه وإن شاء رده؛ لأن ورود الشرع بإثبات الخيار ثمن ورد هاهنا.
- المصدر السابق، شرح اللكنوي على الهداية (١٦٨/٥).

بابُ ^(١)الحقوق ^(٢)

(وَمَنْ اشْتَرَى مَنْزِلًا فَوْقَهُ مَنْزِلٌ فَلَيْسَ لَهُ الْأَعْلَى إِلَّا أَنْ يَشْتَرِيَهُ بِكُلِّ حَقٍّ هُوَ لَهُ ^(٣)أَوْ بِمُرَافِقِهِ ^(٤)، أَوْ بِكُلِّ قَلِيلٍ وَكَثِيرٍ هُوَ فِيهِ ^(٥)أَوْ مِنْهُ ^(٦)، وَمَنْ اشْتَرَى بَيْتًا فَوْقَهُ بَيْتٌ بِكُلِّ حَقٍّ لَمْ يَكُنْ لَهُ الْأَعْلَى ^(٧)، وَمَنْ اشْتَرَى دَارًا بِحُدُودِهَا فَلَهُ الْعُلُوُّ ^(٨)وَالْكَيْفُ ^(٩)جَمَعَ ^(١٠)بَيْنَ الْمَنْزِلِ وَالْبَيْتِ

(١) لما كانت الحقوق تابعة للملك ناسب ذكرها بعد ذكر مسائل البيوع، وكان من حق مسائل هذا الباب أن تذكر في الفصل المتصل بأول كتاب البيوع، إلا أن المصنف التزم ترتيب "الجامع الصغير"، وهناك هكذا وقع، فكذا هنا. ينظر: العناية على الهداية (١٧٨/٦)، البناية على الهداية (٢٠١/٨)، شرح اللكنوي على الهداية (٢٠٢/٥).

(٢) أي هذا باب في بيان أحكام الحقوق، وهو جمع حق، وهو ما يستحقه الرجل، وله معان أخرى، منها الحق ضد الباطل. ينظر: البناية على الهداية (٢٠١/٨).

(٣) أي إلا أن يقول وقت شرائه المنزل: اشتريته بكل حق هو له أي للمنزل، كالمسيل، والطريق الذي فيه حق الخروج والدخول. ينظر: البناية على الهداية (٢٠١/٨)، شرح اللكنوي على الهداية (٢٠٢/٥).

(٤) أي أو يشتريه بمرافقه بأن يقول: اشتريته بمرافقه، أي منافعه، والمرافق: جمع مرفق.. وفي "المغرب": مرافق الدار: المتوضأ والمطبخ ونحوهما، الواحد مرفق بكسر الميم، وفتح الفاء لا غير. ينظر: المغرب في ترتيب المعرب (١٩٤)، البناية على الهداية (٢٠١/٨)، شرح اللكنوي على الهداية (٢٠٢/٥).

(٥) أي أو إلا أن يشتريه بكل قليل وكثير هو فيه، أي في المنزل. ينظر: البناية على الهداية (٢٠١/٨)، شرح اللكنوي على الهداية (٢٠٢/٥).

(٦) أي من المنزل، وهنا ثلاثة أشياء: المنزل والبيت والدار، وفسرها المصنف كلها؛ ليتبين ما يترتب على كل اسم منها من الاحتياج إلى تصريح ما يدل على المرافق؛ لدخولها وعدمه. ينظر: البناية على الهداية (٢٠١/٨).

(٧) أي البيت الأعلى. ينظر: البناية على الهداية (٢٠١/٨).

(٨) الذي عليها. ينظر: البناية على الهداية (٢٠١/٨).

(٩) أي وله الكنيف أيضاً، وهو المستراح. ينظر: العناية على الهداية (٤١/٧)، البناية على الهداية (٢٠١/٨).

(١٠) أي محمد - رحمه الله - في "الجامع الصغير". المصدر السابق، شرح اللكنوي على الهداية (٢٠٣/٥).

وَالدَّارِ، فَاسْمُ الدَّارِ يَنْتَظِمُ الْعُلُوَّ^(١)؛ لِأَنَّهُ^(٢) اسْمٌ لِمَا أُدِيرَ عَلَيْهِ الْحُدُودُ وَالْعُلُوُّ مِنْ تَوَابِعِ الْأَصْلِ وَأَجْزَائِهِ^(٣) فَيَدْخُلُ فِيهِ وَالْبَيْتُ اسْمٌ لِمَا يُبَاتُ فِيهِ، وَالْعُلُوُّ مِثْلُهُ^(٤)، وَالشَّيْءُ لَا يَكُونُ تَبَعًا لِمِثْلِهِ^(٥) فَلَا يَدْخُلُ فِيهِ^(٦) إِلَّا بِالتَّنْصِصِ عَلَيْهِ^(٧)، الْمَنْزِلُ بَيْنَ الدَّارِ وَالْبَيْتِ لِأَنَّهُ يَتَأْتَى فِيهِ مَرَافِقُ السُّكْنَى مَعَ ضَرْبِ قُصُورٍ^(٨)؛ إِذْ لَا يَكُونُ فِيهِ مَنْزِلُ الدَّوَابِّ^(٩)، فَلِشَبْهِهِ^(١٠) بِالدَّارِ يَدْخُلُ الْعُلُوُّ فِيهِ تَبَعًا عِنْدَ ذِكْرِ التَّوَابِعِ، وَلِشَبْهِهِ بِالْبَيْتِ لَا يَدْخُلُ فِيهِ بِدُونِهِ^(١١)، وَقِيلَ فِي عُرْفِنَا يَدْخُلُ الْعُلُوُّ فِي جَمِيعِ ذَلِكَ^(١٢)؛ لِأَنَّ كُلَّ مَسْكَنِ يُسَمَّى بِالْفَارِسِيَّةِ خَانَهُ وَلَا يَخْلُو عَنْ عُلُوٍّ^(١٣)، وَكَمَا يَدْخُلُ الْعُلُوُّ فِي اسْمِ

(١) يعني يشمل من غير نص باسمه الخاص، ومن غير ذكر الحقوق. المصدر السابق، شرح اللكنوي على الهداية (٢٠٣/٥).

(٢) أي لأن العلو. البناءة على الهداية (٢٠١/٨).

(٣) فلا يخرج عنها. البناءة على الهداية (٢٠١/٨).

(٤) أي مثل البيت. البناءة على الهداية (٢٠٢/٨).

(٥) لأن تبع الشيء أدنى منه لا محالة لا مثله. المصدر السابق، شرح اللكنوي على الهداية (٢٠٣/٥).

(٦) أي لا يدخل العلو في شراء البيت. البناءة على الهداية (٢٠٢/٨).

(٧) أي على اسم العلو بذكره. المصدر السابق.

(٨) . يعني لكن فيه قصور. البناءة على الهداية (٢٠٢/٨).

(٩) أي لأنه لا يكون فيه منزل الدواب، وما يجري مجرى ذلك.

البناءة على الهداية (٢٠٢/٨).

(١٠) أي فلشبهه المنزل بالدار. البناءة على الهداية (٢٠٢/٨).

(١١) أي بدون ذكره؛ لأن المنزل له منزلة بين المنزلتين. هذا: والمنزل: اسم لما يشتمل على بيوت

ومطبخ وموضع قضاء الحاجة، ولكن لا يكون فيه صحن. وقيل: المنزل: لاسم لبيتين أو ثلاثة يُنْزَلُ

فيه ليلاً أو نهاراً. البناءة على الهداية (٢٠٢/٨).

(١٢) أي الدار والمنزل والبيت. وقال الإمام الزاهد العتابي في شرح الجامع الصغير: هذا - يعني الذي

ذكره أولاً - في عرفهم وفي عرفنا: يدخل العلو من غير ذكر في الفصول كلها؛ لأن في عرفنا الدار

والمنزل والبيت كله واحد. البناءة على الهداية (٢٠٢/٨).

(١٣) يعني في عرف بلاد العجم يسمى كذلك، سواء كان المسكن صغيراً أو كبيراً، ولفظ خانه بالخاء

المعجمة وفتح النون وهو اسم البيت بالعجمي. البناءة على الهداية (٢٠٢/٨).

الدَّارِ يَدْخُلُ الْكَنِيفُ؛ لِأَنَّهُ مِنْ تَوَابِعِهِ (١). وَلَا تَدْخُلُ الظِّلَّةُ (٢) إِلَّا بِذِكْرِ مَا ذَكَرْنَا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ (٣)؛ لِأَنَّهُ (٤) مَبْنِيٌّ عَلَى هَوَاءِ الطَّرِيقِ (٥) فَأَخَذَ حُكْمَهُ (٦). وَعِنْدَهُمَا: (٧) إِنْ كَانَ مِفْتَاحُهُ (٨) فِي الدَّارِ (٩)؛ يَدْخُلُ مِنْ غَيْرِ ذِكْرِ شَيْءٍ مِمَّا ذَكَرْنَا (١٠)؛ لِأَنَّهُ (١١) مِنْ تَوَابِعِهِ (١٢) فَشَابَهُ الْكَنِيفَ (١٣)، قَالَ: (١٤) وَمَنْ اشْتَرَى بَيْتًا فِي دَارٍ أَوْ مَنْزِلًا أَوْ مَسْكَنًا لَمْ يَكُنْ لَهُ (١٥) الطَّرِيقُ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِيَهُ بِكُلِّ حَقٍّ هُوَ لَهُ أَوْ بِمَرَافِقِهِ (١٦) أَوْ بِكُلِّ قَلِيلٍ وَكَثِيرٍ (١). كَذَا الشُّرْبُ (٢)

(١) أي من توابع الدار. وفي بعض النسخ من توابعه. قال الكاكي: أي من توابع الدار؛ لأنه يجوز فيه التذكير؛ لأنه مؤنث غير حقيقي، ولأن الدار اسم لما أدير عليه الحائط، والكنيف مما أدير عليه الحائط، فيكون من الدار؛ فيدخل تحت بيع الدار بلا ذكر الحقوق. البناءة على الهداية (٢٠٢/٨).

(٢) وهي الساباط، الذي أحد طرفيه على الدار المبيعة، والطرف الآخر على دار أخرى، أو على الأسطوانات في السكة، ومفتحة في الدار، وفي المغرب: "قول الفقهاء ظلة الدار يريدون السدة التي تكون فوق الباب" اهـ. ينظر: المغرب (٢٩٨)، العناية على الهداية (٤١/٧)، البناءة على الهداية (٢٠٢/٨).

(٣) وهو قوله: (بكل حق هو له أو مرافقه أو بكل قليل وكثير هو فيه). البناءة على الهداية (٢٠٢/٨).

(٤) أي لأن الظلة على تأويل الساباط. المصدر السابق.

(٥) والطريق لا يدخل إلا بذكر التوابع؛ فكذا الظلة. شرح اللكنوي على الهداية (٢٠٣/٥).

(٦) أي حكم الطريق. البناءة على الهداية (٢٠٢/٨).

(٧) أي وعند أبي يوسف ومحمد رحمهما الله.

(٨) أي مفتاح الظلة. البناءة على الهداية (٢٠٢/٨).

(٩) أي في البيع. البناءة على الهداية (٢٠٢/٨).

(١٠) من المرافق والحقوق. البناءة على الهداية (٢٠٢/٨).

(١١) أي لأن الظلة. البناءة على الهداية (٢٠٢/٨).

(١٢) أي من توابع الدار. البناءة على الهداية (٢٠٢/٨).

(١٣) حيث يدخل من غير ذكر شيء من الحقوق والمرافق. البناءة على الهداية (٢٠٢/٨).

(١٤) أي قال الإمام محمد رحمه الله في الجامع الصغير. البناءة على الهداية (٢٠٢/٨).

(١٥) أي للمشتري. البناءة على الهداية (٢٠٢/٨).

(١٦) أو يشتري بمرافقه. البناءة على الهداية (٢٠٢/٨).

وَالْمَسِيلُ (٣)؛ لِأَنَّهُ (٤) خَارِجُ الْحُدُودِ (٥)، إِلَّا أَنَّهُ مِنَ التَّوَابِعِ (٦)؛ فَيَدْخُلُ بِذِكْرِ التَّوَابِعِ (٧)، بِخِلَافِ
 الْإِجَارَةِ (٨)؛ لِأَنَّهَا تُعَقَّدُ لِلِانْتِفَاعِ فَلَا يَتَحَقَّقُ (٩) إِلَّا بِهِ، إِذِ الْمُسْتَأْجِرُ لَا يَشْتَرِي الطَّرِيقَ عَادَةً
 (١٠)، وَلَا يَسْتَأْجِرُهُ فَيَدْخُلُ تَحْصِيلًا لِلْفَائِدَةِ الْمَطْلُوبَةِ مِنْهُ (١١)، أَمَّا الْإِنْتِفَاعُ بِالْمَبِيعِ مُمَكِّنٌ بِدُونِهِ
 (١٢)؛ لِأَنَّ الْمُشْتَرِيَّ عَادَةً يَشْتَرِيهِ (١٣)،
 وَقَدْ يَتَجَرُّ فِيهِ (١٤)؛ فَيَسْبِغُهُ مِنْ غَيْرِهِ فَحَصَلَتْ الْفَائِدَةُ (١٥)، وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ.

- (١) هو منه، أو فيه؛ فيكون له الطريق حينئذ. وقال الكاكي: المراد الطريق الخاص في ملك إنسان.
 قلنا: طريقها إلى مكة غير نافذة، وإلى طريق عام؛ فيدخل.
 البناية على الهداية (٢٠٢/٨).
- (٢) الشرب بكسر الشين: النصيب من الماء للأراضي وغيرها. التعريفات للرجاني (١٦٦).
 (٣) المسيل بفتح الميم وكسر السين. مجرى الماء وغيره. معجم لغة الفقهاء (٤٢٩).
 (٤) أي لأن كل واحد من الطريق والشرب والمسيل. شرح اللكنوي على الهداية (٢٠٣/٥).
 (٥) أي حدود المبيع. المصدر السابق، البناية على الهداية (٢٠٤/٨).
 (٦) لأنها إنما يقصد بها الانتفاع. المصدران السابقان.
 (٧) أي بذكر الحقوق والمرافق . البناية على الهداية (٢٠٤/٨).
 (٨) يعني: تدخل هذه الأشياء المذكورة (الطريق والشرب والمسيل وغيرها) في الإجارة بدون ذكر
 الحقوق والنص عليها في عقد الإجارة، وبه قال الإمام الشافعي رضي الله عنه.
 البناية على الهداية (٢٠٤/٨).
 (٩) يعني: لا يتحقق الانتفاع إلا بهذه الحقوق. المصدر السابق،
 شرح اللكنوي على الهداية (٢٠٣/٥).
 (١٠) وكذا لا يشتري الشرب والمسيل. البناية على الهداية (٢٠٤/٨)، شرح اللكنوي على الهداية
 (٢٠٣/٥).
 (١١) أي من الاستئجار. المصدران السابقان.
 (١٢) أي بدون الطريق. المصدر السابقان.
 (١٣) أي يشتري الطريق والشرب والمسيل، ووحد الضمير لكل واحد أو بتأويل المذكور. البناية على
 الهداية (٢٠٤/٨).
 (١٤) أي قد بتاجر في شرائه.. البناية على الهداية (٢٠٤/٨).
 (١٥) أي حصلت الفائدة المطلوبة. البناية على الهداية (٢٠٤/٨).

بَابُ الْإِسْتِحْقَاقِ (١)

وَمَنْ اشْتَرَى جَارِيَةً فَوَلَدَتْ عِنْدَهُ (٢) فَاسْتَحَقَّهَا رَجُلٌ بَيِّنَةٌ فَإِنَّهُ يَأْخُذُهَا وَوَلَدَهَا (٣)، وَإِنْ أَقَرَّ بِهَا (٤) لِرَجُلٍ لَمْ يَتَّبِعْهَا وَلَدَهَا (٥).
وَوَجْهُ الْفَرْقِ: (٦) أَنَّ الْبَيِّنَةَ حُجَّةٌ مُطْلَقَةٌ (٧)؛ فَإِنَّهَا كَاسِمِهَا مُبَيِّنَةٌ (٨)؛ فَيُظْهَرُ بِهَا (٩) مِلْكُهَا (١٠) مِنَ الْأَصْلِ (١١)، وَالْوَلَدُ كَانَ مُتَّصِلًا بِهَا فَيَكُونُ لَهُ (١٢)، أَمَّا الْإِقْرَارُ حُجَّةٌ قَاصِرَةٌ يُثْبِتُ الْمَلِكُ فِي الْمُخْبَرِ بِهِ (١) ضَرُورَةَ صِحَّةِ الْإِخْبَارِ (٢)، وَقَدْ انْدَفَعَتْ بِإِثْبَاتِهِ بَعْدَ الْإِنْفِصَالِ (١) فَلَا يَكُونُ الْوَلَدُ لَهُ (٢).

(١) أي هذا باب في بيان حكم الاستحقاق، وهو طلب الحق، وذكر هذا الباب عقيب باب الحقوق للمناسبة التي بينهما لفظاً ومعنى.

البنائية على الهداية (٢٠٥/٨)، شرح اللكنوي على الهداية (٢٠٣/٥).

(٢) أي عند المشتري ولدت من غير مولاه. البنائية على الهداية (٢٠٥/٨).

(٣) أي فإن المستحق يأخذ الجارية ويأخذ ولدها معها أيضاً. المصدر السابق.

(٤) أي وإن أقر بالجارية. المصدر السابق.

(٥) أي لم يتبع الجارية ولدها؛ لا يأخذ المقر له الولد، ويأخذ الأمة فقط... المصدر السابق.

(٦) يعني: ودليل الفرق بين البينة والإقرار؛ حيث يأخذ الجارية ولدها بالبينة فقط، لا بالإقرار. المصدر السابق.

(٧) يعني غير مقتصرة على المقضي عليه فهي حجة في قول كافة الناس. المصدر السابق.

(٨) من التبين، وهو الإظهار، وأصله من البيان، وهو الظهور. المصدر السابق.

(٩) أي بالبينة. المصدر السابق.

(١٠) أي ملك الرجل المستحق. المصدر السابق.

(١١) يعني في حق الجارية والولد جميعاً. المصدر السابق.

(١٢) يعني: أن الولد كان متصلاً بالجارية؛ فيكون الولد للمستحق، ولهذا يرجع الباعة بعضهم على بعض. المصدر السابق.

(١) أي مقصوراً على ما أقر به وهو الجارية. المصدر السابق.

(٢) أي لأجل ضرورة صحة إخبار المخبر. المصدر السابق.

ثُمَّ قِيلَ: (٣) يَدْخُلُ الْوَلَدُ فِي الْقَضَاءِ بِالْأُمِّ تَبَعًا، وَقِيلَ يُشْتَرَطُ الْقَضَاءُ بِالْوَلَدِ (٤)، وَإِلَيْهِ (٥) تُشِيرُ الْمَسَائِلُ، فَإِنَّ الْقَاضِيَ إِذَا لَمْ يَعْلَمْ بِالزَّوَائِدِ (٦) قَالَ مُحَمَّدٌ رَحِمَهُ اللَّهُ: لَا تَدْخُلُ الزَّوَائِدُ فِي الْحُكْمِ، (٧)؛ فَكَذَا الْوَلَدُ إِذَا كَانَ فِي يَدِ غَيْرِهِ لَا يَدْخُلُ تَحْتَ الْحُكْمِ (٨) بِالْأُمِّ تَبَعًا (٩) قَالَ (١٠): وَمَنْ اشْتَرَى عَبْدًا فَإِذَا هُوَ حُرٌّ (١١)، وَقَدْ قَالَ الْعَبْدُ لِلْمُشْتَرِي (١٢): اشْتَرَيْتَنِي فَإِنِّي عَبْدٌ لَهُ (١)، فَإِنْ كَانَ الْبَائِعُ حَاضِرًا أَوْ غَائِبًا غَيْبَةً مَعْرُوفَةً (٢)؛ لَمْ يَكُنْ عَلَى الْعَبْدِ شَيْءٌ (٣)، وَإِنْ كَانَ

(١) يعني: قد اندفعت الضرورة بإثبات الملك بعد انفصال الولد؛ فلا يظهر الإلحاق بالولد. المصدر السابق.

(٢) ولهذا لا يرجع المشتري على البائع بالثمن عند الاستحقاق بالإقرار. السابق.

(٣) أشار بهذا إلى اختلاف المشايخ - رحمهم الله - في فصل الاستحقاق بالبينة في أن الولد في القضاء بالأم يدخل تبعاً أم لا. فقال بعضهم: يدخل الولد في القضاء بالأم تبعاً؟ وقيل: يشترط القضاء بالولد على حدة. المصدر السابق.

(٤) على حدة؛ لأنه أصل يوم القضاء لكونه منفصلاً عن الأم، فلا بد من الحكم، كذا قيل، وهو الأصح. المصدر السابق.

(٥) أي إلى هذا القول، وهو اشتراط القضاء بالولد. المصدر السابق.

(٦) يعني: إذا قضى القاضي بالأصل، ولم يعرف الزوائد. المصدر السابق.

(٧) يعني: لا تدخل الزوائد في الحكم بالأصل؛ فيجب الحكم بالزوائد أيضاً. المصدر السابق.

(٨) أي حكم القاضي. البناية على الهداية (٢٠٦/٨).

(٩) أي من حيث التبعية للأم؛ لأنها منفصلة من الأصل يوم القضاء في الولد، لعدم دخوله إذا كان في يد الغائب في القضاء بالأم؛ لأنه إذا دخل حينئذ يكون قضاء على الغائب. المصدر السابق

(١٠) أي الإمام محمد رحمه الله في الجامع الصغير. المصدر السابق.

(١١) كلمة إذا للمفاجأة، أي فظهر أنه حر. المصدر السابق.

(١٢) أي والحال: أن العبد قد قال للمشتري: اشتريني فإنني عبد له. المصدر السابق.

(١) إنما قيد بهذين القيدين، لأنه لو قال وقت البيع: إني عبد، ولم يأمره بالشراء، أو قال: اشتريني، ولم يقل: إني عبد لا يرجع عليه بالثمن في قولهم، كذا ذكره الإمام التمرتاشي في جامعه محالاً إلى شيخ الإسلام خواهر زاده. المصدر السابق.

(٢) أي يدري مكانه. المصدر السابق.

(٣) لأن البائع هو الذي أخذ ماله فوجب أن يسترد منه، والعبد لم يأخذ منه شيئاً.

الْبَائِعُ لَا يُدْرَى أَيْنَ هُوَ رَجَعَ الْمُشْتَرِي عَلَى الْعَبْدِ (١)، وَرَجَعَ هُوَ (٢) عَلَى الْبَائِعِ، وَإِنْ ارْتَهَنَ عَبْدًا مُقَرًّا بِالْعُبُودِيَّةِ فَوَجَدَهُ حُرًّا لَمْ يَرْجِعْ عَلَيْهِ عَلَى كُلِّ حَالٍ (٣)، وَعَنْ أَبِي يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ أَنَّهُ لَا يَرْجِعُ فِيهِمَا (٤)؛ لِأَنَّ الرُّجُوعَ بِالْمُعَاوَضَةِ أَوْ بِالْكَفَالَةِ (٥)، وَالْمَوْجُودُ لَيْسَ إِلَّا الْإِخْبَارُ كَاذِبًا (٦)؛ فَصَارَ كَمَا إِذَا قَالَ الْأَجَنَّبِيُّ ذَلِكَ أَوْ قَالَ الْعَبْدُ ارْتَهَنِي فَإِنِّي عَبْدٌ (٧)، وَهِيَ الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَّةُ (٨)، وَلَهُمَا: (٩) أَنَّ الْمُشْتَرِي شَرَعَ فِي الشِّرَاءِ مُعْتَمِدًا عَلَى مَا أَمَرَهُ (١٠) وَإِقْرَارِهِ (١١) أَنِّي عَبْدٌ،

إِذِ الْقَوْلُ لَهُ فِي الْحُرِّيَةِ (١)؛ فَيُجْعَلُ الْعَبْدُ بِالْأَمْرِ بِالشِّرَاءِ (٢) ضَامِنًا لِلثَّمَنِ لَهُ عِنْدَ تَعَذُّرِ رُجُوعِهِ عَلَى الْبَائِعِ دَفْعًا لِلْغُرُورِ وَالضَّرَرِ (٣) وَلَا تَعَذُّرٌ إِلَّا فِيمَا لَا يُعْرَفُ مَكَانُهُ، وَالْبَيْعُ عَقْدٌ مُعَاوَضَةٌ فَأَمَّا كُنْ

(١) يعني: رجع المشتري على العبد بالثمن على العبد؛ لأنه غره حيث أمره بالشراء وأتلف ماله. البناية على الهداية (٢٠٦/٨).

(٢) يعني: رجع العبد على البائع. المصدر السابق.

(٣) يعني: إن ارتهن رجل عبداً قد أقر بأنه عبد للمرتهن؛ فوجد فوجد المرتهن العبد وهو حر ؛ لم يرجع المرتهن على العبد بشيء على كل حال، أي سواء كان الراهن حاضراً أو غائباً أية غيبة كانت. المصدر السابق.

(٤) أي إن كل واحد من البائع والمرتهن لا يرجع على العبد في البيع والرهن. المصدر السابق.

(٥) أي: لأن الرجوع إنما يكون بالمعوضة في المبايعه، أو بكفالة العبد بالثمن، ولم يوجد واحد منهما. المصدر السابق.

(٦) يعني: أن الواقع وحقيقة الأمر ليس إلا إخباره كاذباً بأنه عبد. ينظر: المصدر السابق.

(٧) فظهر حرّاً؛ ليس له عليه شيء. المصدر السابق.

(٨) وهي قوله: وإن ارتهن عبداً مقراً بالعبودية. المصدر السابق.

(٩) يعني: دليل الإمامين أبي حنيفة ومحمد -رحمهما الله.

(١٠) أي أمر العبد حيث قال: اشتري فأنا عبد. البناية على الهداية (٢٠٧/٨).

(١١) بقوله: إني عبد. .

(١) أي لأن القول في الحرية للعبد؛ لأنه متمسك بالأصل؛ إذ الأصل الحرية. البناية على الهداية (٢٠٧/٨).

(٢) أي بقوله: اشتري.

(٣) أي ولأجل الغرور من جهته، والغرور في المعاولات التي تقتضي سلامة العوض يجعل سبباً للضمان؛ دفعاً للضرر بقدر الإمكان . البناية على الهداية (٢٠٧/٨).

أَنْ يُجْعَلَ الْأَمْرُ بِهِ ضَامِنًا لِلْسَّلَامَةِ (١)، كَمَا هُوَ مُوجِبُهُ (٢)، بِخِلَافِ الرِّهْنِ لِأَنَّهُ لَيْسَ بِمُعَاوَضَةٍ بَلْ هُوَ وَثِيقَةٌ لِاسْتِيفَاءِ عَيْنِ حَقِّهِ حَتَّى يَجُوزَ الرِّهْنُ بِبَدْلِ الصَّرْفِ وَالْمُسْلَمِ فِيهِ مَعَ حُرْمَةِ الْإِسْتِبْدَالِ (٣)، فَلَا يُجْعَلُ الْأَمْرُ بِهِ ضَامِنًا لِلْسَّلَامَةِ (٤)، وَبِخِلَافِ الْأَجْنَبِيِّ لِأَنَّهُ لَا يُعْبَأُ بِقَوْلِهِ فَلَا يَتَحَقَّقُ الْغُرُورُ (٥)، وَنَظِيرُ مَسْأَلَتِنَا (٦) قَوْلُ الْمَوْلَى بَايَعُوا عَبْدِي هَذَا فَإِنِّي قَدْ أَذْنْتُ لَهُ ثُمَّ ظَهَرَ الْإِسْتِحْقَاقُ (٧)؛ فَإِنَّهُمْ (٨) يَرْجِعُونَ عَلَيْهِ بِقِيَمَتِهِ (٩)، ثُمَّ فِي وَضْعِ الْمَسْأَلَةِ ضَرْبُ إِشْكَالٍ عَلَى قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ ، لِأَنَّ الدَّعْوَى شَرْطٌ فِي حُرِّيَةِ الْعَبْدِ عِنْدَهُ (١٠)، وَالتَّنَاقُضُ يُفْسِدُ الدَّعْوَى. إِذَا كَانَ الْوَضْعُ فِي حُرِّيَةِ الْأَصْلِ فَالدَّعْوَى فِيهَا لَيْسَ بِشَرْطٍ عِنْدَهُ (١)؛ لِتَضَمُّنِهِ تَحْرِيمَ فَرْجِ الْأُمِّ (٢)، وَقِيلَ: هُوَ شَرْطٌ (٣)، لَكِنَّ التَّنَاقُضَ غَيْرُ مَانِعٍ لِحِفَاءِ الْعُلُوقِ (٤)، وَإِنْ كَانَ الْوَضْعُ فِي الْإِعْتِقَاقِ

(١) أي سلامة المبيع للمشتري. البناية على الهداية (٢٠٧/٨).

(٢) أي موجب البيع، لأن موجب سلامة المبيع للمشتري. البناية على الهداية (٢٠٧/٨).

(٣) حتى إذا هلك يقع الاستيفاء، ولو كان معاوضة لكان استبدالاً برأس مال السلم أو بالمسلم فيه وهو حرام، وكذا في بدل الصرف؛ فلم يكن هذا غروراً في عقد المعاوضة، فلا ينتهض سبباً للضمان، المصدر السابق.

(٤) فلا يجب عليه شيء، المصدر السابق.

(٥) يعني: لا يتحقق الغرور بقول الأجنبي؛ لعدم الاكتراث به. المصدر السابق.

(٦) وهي أن الغرور في المعاوضات التي تقتضي سلامة العوض جعل سبباً للضمان، نظير : قول المولى: للناس من أهل السوق بايعوا عبدي هذا؛ فإنني قد أذنت له في التجارة، فبايعوه ولحقه ديون. البناية على الهداية (٢٠٧/٨).

(٧) أي ثم ظهر أنه حر. المصدر السابق.

(٨) أي فإن الذي بايعوه. المصدر السابق.

(٩) أي بقدر قيمته بحكم الغرور. المصدر السابق.

(١٠) أي عند أبي حنيفة. وقوله: أنا حر بعد قوله: أنا عبد متناقض. المصدر السابق.

(١) أي عند أبي حنيفة رحمه الله.

(٢) أي لتضمن الدعوى، أي دعوى حرية الأصل، وذكر الضمير الراجع إلى الدعوى على معنى الادعاء. المصدر السابق.

(٣) أي الدعوى شرط على تأويل الادعاء. المصدر السابق.

(٤) أي حال العلوق، وكل ما كان مبناه على الخفاء فالتناقض معفو. المصدر السابق.

فَالْتَنَافُضُ (١) لَا يَمْنَعُ (٢)؛ لَاسْتِبْدَادِ الْمَوْلَى بِهِ (٣)؛ فَصَارَ كَالْمُخْتَلَعَةِ (٤) تُقِيمُ الْبَيِّنَةَ عَلَى الطَّلَاقِ الثَّلَاثِ قَبْلَ الْخُلْعِ (٥)، وَالْمَكَاتِبِ يُقِيمُهَا (٦) عَلَى الْإِعْتَاقِ قَبْلَ الْكِتَابَةِ (٧) قَالَ: (٨): وَمَنْ ادَّعَى حَقًّا فِي دَارٍ مَعْنَاهُ حَقًّا مَجْهُولًا (٩) فَصَالَحَهُ الَّذِي فِي يَدِهِ عَلَى مِائَةِ دِرْهَمٍ فَاسْتُحِقَّتِ الدَّارُ إِلَّا ذِرَاعًا مِنْهَا (١٠) لَمْ يَرْجِعْ بِشَيْءٍ؛ لِأَنَّ لِلْمُدَّعِي أَنْ يَقُولَ دَعْوَايَ فِي هَذَا الْبَاقِي (١١).

قَالَ: (١) وَإِنْ ادَّعَاهَا كُلَّهَا (٢) فَصَالَحَهُ عَلَى مِائَةِ دِرْهَمٍ فَاسْتُحِقَّتْ مِنْهَا شَيْءٌ رَجَعَ بِحِسَابِهِ؛ لِأَنَّ التَّوْفِيقَ غَيْرُ مُمَكِّنٍ (٣)؛ فَوَجَبَ الرُّجُوعُ بِبَدَلِهِ (١) عِنْدَ فَوَاتِ سَلَامَةِ الْمُبْدَلِ (٢)، وَذَلِكَ الْمَسْأَلَةُ

(١) في الدعوى.

(٢) صحة الدعوى في المعنق؛ لأنه أمر يجري فيه الخفاء. المصدر السابق.

(٣) أي لتفرد المولى بالإعتاق، فريما لا يعلم العبد إعتاقه ثم يعلم بعد ذلك. البناية على الهداية (٢٠٩/٨)

(٤) أي كالمرأة التي اختلعت.

(٥) فإنه يقبل ذلك منها وإن تناقضت؛ للخفاء في تطليقة؛ لاستبداده به، وإنما قيد بالثلاث؛ لأن فيما وراءها يمكن أن يقيم الزوج بيعة أنه قد تزوجها بعد الطلاق الذي قد أثبتته المرأة قبل يوم أو يومين. وأما في الثلاث؛ فلا يمكنه ذلك..

(٦) أي يقيم البيعة.

(٧) فإنها تقبل منه؛ لاستبداد سيده بالتحريم، ثم المرأة والمكاتب يستردان بدل الخلع والكتابة بعد إقامتهما البيعة على ما ادعياه. المصدر السابق.

(٨) أي الإمام محمد رحمه الله في الجامع الصغير.

(٩) فأنكر المدعى عليه.

(١٠) أي موضع ذراع منها.

(١١) فلا يثبت حق الرجوع بالشك.

(١) أي الإمام محمد رحمه الله في الجامع الصغير

(٢) أي كل الدار.

(٣) لأنه ادعى كل الدار؛ فصالح على ذلك؛ فاستحق بعض الدار، والمائة كانت وقعت بدلا عن كل

الدار؛ لأن البذل يقسم على أجزاء المبدل، فلما استحق بعض المبدل تعين الرجوع. البناية على الهداية (٢١٠/٨) ..

عَلَى أَنَّ الصُّلْحَ عَنِ الْمَجْهُولِ عَلَى مَعْلُومٍ جَائِزٍ لِأَنَّ الْجَهَالََةَ فِيمَا يَسْقُطُ لَا تُفْضِي إِلَى الْمُنَازَعَةِ (٣)
وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ بِالصَّوَابِ.

(١) أي بحصته. البناية على الهداية (٢١٠/٨) ..

(٢) لأنه أخذ ذلك القدر من البذل بغير حق. البناية على الهداية (٢١٠/٨) ..

(٣) ودلت المسألة أيضا على أن صحة الدعوى ليست بشرط لصحة الصلح، لأن دعوى الحق في الدار لا تصح للجهالة، ولهذا لا تقبل البينة على ذلك، إلا إذا ادعى إقرار المدعى عليه بالحق؛ فحينئذ تصح الدعوى وتقبل البينة، والإقرار عن المجهول جائز عندنا. البناية على الهداية (٢١٠/٨).

القسم الثاني

الدراسة الموضوعية

الفصل التمهيدي (الفصل الأول) التعريف بالمال وأقسامه والعقد وأنواعه

أهداف الدرس

بدراسة هذا الجزء من قسم المعاملات يكتسب الطالب ما يلي:
أولاً: المعلومات والمفاهيم:

معرفة ما هو المال وما هي أقسامه، وفائدة كل تقسيم.

معرفة أنواع التعاقد: بالأقوال، والأفعال، والإشارة، والكتابة.

معرفة صيغة العقد، وشروط الإيجاب والقبول، وما هي أهلية العاقد؟

معرفة تقسيمات العقود باعتباراتها المختلفة.

ثانياً: المهارات الذهنية:

يحلل أحكام فقه المعاملات في ضوء فقه الواقع.

يستنبط الصحيح والفاقد من العقود.

يستطيع أن يفرق بين العقد والتصرف.

يستطيع التفريق بين كامل الأهلية وفاقدها وناقصها من العاقدين، ويستنتج حكم تصرفات

كل واحد منهم.

يستطيع الحكم على صحة العقد أو فسادة أو بطلانه من خلال معرفته بمقدار أهليته.

يستطيع أن يصنف العقود باعتبار وصف العقد شرعاً، أو بالنظر إلى غاية العقد

وأغراضه، أو بالنظر إلى العينية وعدمها، أو بالنظر إلى اتصال الأثر بالعقد وعدم اتصاله.

أهداف الدرس

بدراسة هذا الجزء من قسم المعاملات يكتسب الطالب ما يلي:

أولاً: المعلومات والمفاهيم:

معرفة ما هو المال وما هي أقسامه، وفائدة كل تقسيم.

معرفة أنواع التعاقد: بالأقوال، والأفعال، والإشارة، والكتابة.

معرفة صيغة العقد، وشروط الإيجاب والقبول، وما هي أهلية العاقد؟

معرفة تقسيمات العقود باعتباراتها المختلفة.

ثانياً: المهارات الذهنية:

يحلل أحكام فقه المعاملات في ضوء فقه الواقع.

يستنتج الصحيح والفاقد من العقود.

يستطيع أن يفرق بين العقد والتصرف.

يستطيع التفريق بين كامل الأهلية وفاقدها وناقصها من العاقدين، ويستنتج حكم تصرفات

كل واحد منهم.

يستطيع الحكم على صحة العقد أو فساده أو بطلانه من خلال معرفته بمقدار أهليته.

يستطيع أن يصنف العقود باعتبار وصف العقد شرعاً، أو بالنظر إلى غاية العقد

وأغراضه، أو بالنظر إلى العينية وعدمها، أو بالنظر إلى اتصال الأثر بالعقد وعدم اتصاله

الفصل التمهيدي

التعريف بالمال وأقسامه، والعقود وأنواعها.

ويشتمل على أربعة مباحث:

المبحث الأول: التعريف بالمال وأقسامه.

المبحث الثاني: التعريف بالعقد في الفقه والقانون.

المبحث الثالث: أركان العقد.

المبحث الرابع: تصنيف العقود.

المبحث الأول: التعريف بالمال وأقسامه.

خلق الإنسان على نحو لا يستطيع به أن يعيش وحده مكتفياً بنفسه، بل لا بد له من أن يعيش في مجتمع يفيد منه، ويتأثر به ويؤثر فيه.

وإذا كان الأمر كذلك، كان لا بد من أن تكون معاملات وتصرفات تجرى بين أفراد المجتمع - كبيراً كان هذا المجتمع أو صغيراً - وهذه المعاملات موضوعها في الغالب المال، كما في البيع والإجارة والوصية ونحوها. لهذا، كان من الضروري وموضوع دراستنا هو المعاملات كما جاءت في الإسلام، بيان المعنى المراد من كلمة: "مال" (١).

وإذا كان موضوع المعاملات في الفقه الإسلامي هو المال، فالمال هو موضوع القانون المدني أيضاً بقسميه: الالتزامات أو الحقوق الشخصية، والحقوق العينية؛ فهذه وتلك حقوق ذات قيمة مالية (٢).

المال في اللغة: ما يُقْتَنَى ويُتَمَلَك من كل شيء، سواء كان عيناً أم منفعة، فهو شامل لكل ما يملكه الإنسان ويستولي عليه بالفعل من ذهب أو فضة أو حيوان أو منافع.

أما ما لا يملكه الإنسان ويحوزه بالفعل فلا يسمى مالاً في اللغة، وذلك كالطير في الهواء، والصيد في الفلاة، والسماك في الماء (٣).

المال في اصطلاح الفقهاء:

عرفه الحنفية بأنه: ما يمكن حيازته وإحرازه والانتفاع به في العادة (٤).

وعرفه المالكية بأنه: ما يقع عليه الملك ويستبد به المالك عن غيره إذا أخذه من وجهه (٥).

وقال الشافعية: لا يقع اسم مال إلا على ماله قيمة يباع بها ويلزم متلفه، وإن قلت، وما لا يطرحه الناس مثل الفلس وما أشبه ذلك (٦).

(١) د/ محمد يوسف موسى: الأموال ونظرية العقد في الفقه الإسلامي مع مدخل لدراسة الفقه وفلسفته دراسة مقارنة ص ١٤٩. طبعة ١٤١٧هـ = ١٩٩٦م دار الفكر العربي.

(٢) د/ شفيق شحاته: شرح القانون المدني الجديد في الأموال ص ٢.

(٣) ابن منظور: لسان العرب ١١/٦٣٥، ٦٣٦، مادة مول، الطبعة الثالثة - ١٤١٤هـ - ١٩٩٤م. دار صادر - بيروت، علي حيدر: درر الحكام ج ١ ص ١٠٠، ١٠١.

(٤) ابن نجيم: البحر الرائق ج ٢ ص ٢١٧.

(٥) الشاطبي: الموافقات ج ٢ ص ١٧ دار الفكر العربي.

(٦) السيوطي الأشباه والنظائر ص ٣٢٧.

وعرفه الحنابلة بأنه: ما فيه منفعة مباحة من غير حاجة أو ضرورة كعقار وجماد(١).

فالشيء لا يعد مالاً في نظر الفقهاء إلا إذا تحقق فيه أمران:

أحدهما: إمكان حيازته وإحرازه.

وثانيهما: إمكان الانتفاع به انتفاعاً معتاداً، وعلى هذا لا تعتبر الأشياء التي لا يمكن حيازتها مالاً عندهم، وذلك كالهواء(٢) المطلق، وحرارة الشمس وضوء القمر، والأشياء التي يمكن حيازتها ولكن لا ينتفع بها أصلاً كالحم الميتة والطعام الفاسد، والأشياء التي يمكن الانتفاع بها ولكنه انتفاع لا يعتد به عند الناس كحبة القمح أو الأرز.

والمالية لا تثبت للشيء إلا بتمول الناس كلهم أو بعضهم، وينبني على ذلك أمران:

الأول: أن الخمر والخنزير يعتبر كل منهما مالاً لإمكان حيازتهما وتمول بعض الناس لهما وانتفاعهم بهما.

والثاني: أن الشيء إذا ثبتت ماليته لا تزول عنه إلا إذا ترك الناس كلهم تموله ولم تكن له منفعة أصلاً، أما إذا ترك بعضهم تموله وبقي مالاً في نظر بعضهم فلا يحكم بزوال ماليته، وذلك كالملايس القديمة التي لا تصلح بالنسبة لبعض الناس، وتصلح بالنسبة لبعضهم، فإنه لا يزول اسم المال عنها لبقاء الانتفاع بها بالنسبة لبعض الناس(٣).

المال في القانون: هو الحق ذو القيمة المالية، وبعبارة أخرى كل ماله قيمة مادية يعتبر في النظر القانوني مالاً، عينا كان أو منفعة أو حقاً من الحقوق العينية أو الشخصية، وذلك كحق الامتياز وحق استعمال عناوين المحلات التجارية وحقوق الابتكار " حقوق الملكية الأدبية والفنية والصناعية للمخترعين والمؤلفين"(٤).

(١) المنجي: الممتع في شرح المقنع ج ٣ ص ١٤، ١٥. تحقيق عبد الملك بن عبد الله بن داهش طبعة ١٤١٨ هـ - ١٩٩٧م دار خضر - بيروت..

(٢) ولكن إذا ضغط الهواء وعبئ في أنابيب صار مالاً.

(٣) علي حيدر: درر الحكام شرح مجلة الأحكام العدلية ج ١ ص ١٠٠، د/ عبد الحكيم علي المغربي: المعاملات في الفقه الإسلامي ج ١ ص ٧، ٨. الطبعة الثانية ١٤٠٢ هـ - ١٩٨٢م دار الطباعة المحمدية. درب الأتراك بالأزهر، د / أحمد فرج حسين: الملكية ونظرية العقد ص ٦ - ١٠ - مؤسسة الثقافة الجامعية بالإسكندرية .

(٤) د/ أحمد فرج حسين: الملكية ونظرية العقد ص ١١.

أقسام المال:

المال صنوف مختلفة، ولكل منها مقوماته وخواصه التي تستتبع أحكاماً خاصة في الفقه كما في القانون؛ لذا عني الفقهاء ببيان أنواع المال وقسموه عدة تقسيمات باعتبار ما يكون له من حرمة وحماية إلى متقوم وغير متقوم، وقسموه باعتبار استقراره في محله وعدم استقراره إلى عقار ومنقول، وقسموه باعتبار تماثل أحاده وعدم تماثلها إلى مثلي وقيمي.

القسم الأول من أقسام المال: متقوم، وغير متقوم:

فالمال المتقوم: هو ما حيز بالفعل وأباح الشارع الانتفاع به في حال السعة والاختيار، كالنقود والدور والأراضي المملوكة لأصحابها.

والمراد بحال السعة والاختيار: الحالة التي لا يكون الإنسان فيها مضطراً إلى الانتفاع بالشيء، ويقابلها حال الاضطرار، وهي التي يكون الإنسان فيها مضطراً إلى الانتفاع بالشيء.

والمال غير المتقوم: هو ما لم يحز بالفعل أو حيز ولكن حرم الشارع الانتفاع به في حالة السعة والاختيار، فهو شامل للمال الذي يجوز شرعاً الانتفاع به قبل حيازته مثل السمك في الماء، والطير في الهواء، والمال الذي حيز بالفعل ولكن حرم الشارع الانتفاع به في حالة السعة والاختيار، كالخمر والخنزير بالنسبة للمسلم، فإن كل منهما لا يجوز للمسلم الانتفاع به، إلا في حالة الاضطرار، وذلك كأن يصيب الإنسان جوع أو عطش يخشى فيه الهلاك ولا يجد إلا الخمر أو الخنزير فيباح له في هذه الحالة أن يتناول منهما بقدر ما يدفع به الهلاك عن نفسه، أما بالنسبة لغير المسلم: فهما من الأموال المنقومة (١).

فائدة هذا التقسيم: وفائدة هذا التقسيم تظهر في كثير من الأحكام عند التطبيق، نذكر منها ما يأتي:

(١) المال المتقوم يضمن بالإتلاف: إذا أتلفه شخص لزمه الضمان، مثله إذا كان مثلياً، أو قيمته إن كان قيمياً، والمال غير المتقوم لا يضمن متلفه شيئاً؛ لأنه لا حرمة له ولا حماية، فلو أراق أحد خمر المسلم أو أعدم خنزيراً له: لا يضمن شيئاً بما صنع بل حسناً

(١) - السرخسي: المبسوط ج ١١ ص ١٠٢ - ١٠٥، ابن حزم: المحلى ج ٨ ص ١٤٧، ١٤٨، الطبري اختلاف الفقهاء ص ١٦٠ - ١٦١، الشيخ محمد أبو زهرة: الملكية ونظرية العقد ص ٤٩ وما بعدها طبعة دار الفكر العربي.

فعل، ولكنهما لو كانا لغير مسلم ضمن ما أُلّف؛ لأنهما مال متقوم عندهم، في رأي جمهور الفقهاء، إذ يستحلون تملكها والانتفاع بها.

(٢) المال المتقوم يصح التصرف فيه بالبيع والهبة والوصية والرهن وما أشبه ذلك، والمال غير المتقوم لا يصح التصرف فيه، فلا يصح أن يكون محلاً للبيع ونحوه، وإذا بيع كان العقد باطلاً، والاعتبار بالنسبة للتقوم وعدمه، هو لشرعة واضع اليد عليه (١). وقبل أن نترك الكلام في حقيقة المال في نظر فقهاء الشريعة نعرض للمنافع أتعبر مالاً متقوماً أم لا تعتبر كذلك؟

قال مالك والشافعي: إنها أموال متقومة مضمونة، والدليل على ذلك:

(أ) أن الطبع يميل إليها، ويسعى في ابتغائها وطلبها، وتتفق في سبيلها الأموال، ويقدم في سبيلها نفيس الأشياء ورخيصها.

وأن المصلحة في التحقيق تقوم بمنافع الأشياء لا بذواتها؛ فالذوات لا تصير أموالاً إلا بمنافعها، فلا تقوم إلا بمقدار ما فيها من منفعة، وما تشبعه من حاجة نافعة؛ إذ كل شيء لا منفعة فيه لا يكون مالاً، وإذا كان الشأن كذلك فكيف تسلب المالية والتقوم عما كان سببهما ومناطهما والعلة في وجودهما في الذوات والأشياء.

(ب) وإن العرف العام في الأسواق والمعاملات المالية يجعل المنافع غرضاً مالياً، ومتجراً يتجر فيه، فالخانات والأسواق، والبيوت التي تعد للاستغلال بسكناها، إنما تتخذ فيها المنافع متجراً ومستغلاً تدر على أصحابها الدر الوفير، فدل هذا على أن العرف العام يعتبر المنافع أموالاً تبتغى.

(ج) والشارع الإسلامي اعتبر المنافع أموالاً؛ لأنه أجاز أن تكون مهراً في الزواج ولا يكون مهراً في الزواج إلا المال كما قال تعالى: ﴿وَأَحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكَ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ﴾ (٢).

(١) د / أحمد فرج حسين: الملكية ونظرية العقد ص ١٢ وما بعدها، د محمد يوسف موسى: الأموال ونظرية العقد في الفقه الإسلامي مع مدخل لدراسة الفقه وفلسفته دراسة مقارنة ص ١٥٢ وما بعدها، الإمام محمد أبو زهرة: الملكية ونظرية العقد ص ٤٩ وما بعدها، محمد خالد الأتاسي: شرح مجلة الأحكام العدلية ج ٢ ص ١٨، حاشية ابن عابدين ج ٥ ص ١٦٧ .

(٢) سورة النساء آية ٣٤.

فاتفاق الفقهاء على جواز أن تكون المنفعة التي تقدر بمال مهراً دليلاً على اعتبارها مالاً، ومن لم يعتبرها كذلك فهو متناقض في آرائه.

د - ولقد ورد العقد عليها وتصير مضمونة به سواء أكان العقد صحيحاً أم فاسداً، وضمانيها دليل على أنها تكون مالاً بالعقد عليها، ولو لم تكن أموالاً في ذاتها ما قلبها العقد مالاً؛ لأن العقود لا تقلب حقائق الأشياء، بل تقرر خواصها.

وقال الحنفية: إن المنافع ليست أموالاً متقومة بنفسها، وإنما تقومها بالعقد، وقد استدلوا على ذلك بأن صفة المالية للشيء لا تثبت إلا بالتمول.

والتمول صيانة الشيء وإحرازه، ولذا لا يقال لمن ينتفع بشيء مستهلكاً له أنه متمول له، فلا يقال لمن يأكل شيئاً أنه يتمول ذلك المأكول، وإذا كان التمول كذلك، فالمنافع لا يمكن تمولها؛ لأنه لا يمكن إحرازها؛ إذ أنها لا تبقى زمانين بل تكتسب آناً بعد آناً، وبعد الاكتساب تتلاشى وتنفى فلا يبقى لها وجود، وإذن فهي ليست بمال؛ لأن المالية بالتمول كما ذكرنا.

والمنافع قبل كسبها معدومة، والمعدوم لا يطلق عليه اسم المال، وبعد كسبها لا يمكن إحرازها، والنقوم من أسبابه الإحراز فليس غير المحرز مالاً متقوماً، كالصيد في الفلاة، والحشيش في الكلاء المباح^(١)، وإذا كانت المنافع حتى بعد وجودها لا يمكن إحرازها، فعلى ذلك لا يمكن أن تعتبر مالاً متقوماً.

لهذا كانت المنافع في ذاتها وفي القياس والنظر لا تعتبر مالاً متقوماً، ولكن ورد النص، وجرى العرف بعقد الإجارة وما يشبهها من العقود التي ترد على المنافع فقومت بهذا النوع من العقود استحساناً، وعلى غيرها القياس، وما جاء على غير القياس يقتصر فيه على مورد النص، لا يعمده ولا يتجاوزه إلى غيره؛ لذلك كانت المنافع مقومة بالعقود، وليست مقومة بذاتها^(٢).

القسم الثاني: العقار والمنقول:

اتفق الفقهاء على أن المال إذا كان لا يمكن نقله وتحويله من مكان إلى آخر أصلاً فإنه يسمى عقاراً.

وإذا كان يمكن نقله وتحويله من مكان إلى آخر مع بقاء صورته وهيئته فإنه يسمى منقولاً.

(١) الكلاء المباح: هو الحشيش الذي ينبت بغير إنبات الإنسان.

(٢) - الإمام محمد أبو زهرة: الملكية ونظرية العقد ص ٥٢ - ٥٤ وما أشار إليه من مراجع

والأول: هو الأرض.

والثاني: كل ما عليها من زرع وشجر وحيوان ومتاع.

غير أن الأمام مالك بن أنس يجعل الشجر من العقار؛ لأن المنقول في رأيه هو ما أمكن نقله مع الاحتفاظ بصورته التي كان عليها، وغير ذلك هو العقار، ولا ريب أن الشجر بعد قطعه يصير أخشاباً، وهذا هو الرأي الذي يتفق مع القانون المدني الجديد كما جاء بالفقرة الأولى من المادة ٨٢ منه.

وفائدة تقسيم المال إلى عقار ومنقول تظهر فيما يأتي:

(١) لا تثبت الشفعة - عند الجمهور - في المبيع إلا إذا كان عقاراً، أما المنقول فلا تثبت فيه الشفعة إذا بيع استقلالاً.

(٢) ليس للوصي بيع ما يملك القاصر من عقار إلا بسبب يجيز له ذلك، كإيفاء دين أو دفع حاجة ضرورية، ولكن له أن يبيع من المنقول ما يرى المصلحة في بيعه.

(٣) لا خلاف في جواز وقف العقار، وفي صحة وقف المنقول خلاف وتفصيل.

(٤) يجوز بيع العقار قبل قبضه عند الإمام أبي حنيفة وأبي يوسف، وخالفهما محمد والشافعي، ومنعاً التصرف فيه قبل القبض، بخلاف المنقول فلا يجوز التصرف فيه قبل قبضه حتى على مذهب الإمام وصاحبه.

(٥) بيع أموال المدين المحجور عليه بسبب الدين لوفاء دينه، فعند من يرى جواز هذا البيع يبدأ أولاً ببيع المنقول، فإن لم يف ثمنه بالدين ينتقل إلى العقار لما في ذلك من مصلحة للمدين.

(٦) وفي القانون المدني لا تنتقل ملكية العقار إلا بالتسجيل، والرهن التأميني وحق الاختصاص (١) لا يكونان إلا في العقار.

(١)- حق الاختصاص عند الحنفية: عبارة عما يختص به الإنسان انتفاعاً وارتفاقاً لا تصرفاً كاملاً كطريق الدار، ومسيل الماء، والشرب وطريق، فإنه قد ينتفع بمسيل مائه على سطح جاره وبطريق داره، ولو أراد أن يتصرف بالتمليك فيه بيعاً أو هبة أو نحوه لا يمكنه ذلك، وكذا المسلمون ينتفون بالشارع مشياً عليه، لو تصرفوا فيه غير ذلك لا ينفذ تصرفهم وكذا حق الشرب وأمثاله. البدائع ج ٦/١٩٥.

وفي الفقه المالكي: إن الاختصاص يكون بالمنافع كالإقطاع والسبق المباحات ومقاعد الأسواق والمساجد ومواضع النسك والسقي وعرفه ومزدلفة ورمي الجمار والمدارس والأوقاف / الذخيرة ج ٥ ص ١٣٠.

(٧) والعقار لا تثبت بوضع اليد عليه - بسند وبحسن نية - الملكية فيه إلا بعد مضي خمس سنوات بينما المنقول تثبت الملكية فيه بوضع اليد في الحال إلا في حالة السرقة أو الضياع.

القسم الثالث: المثلي والقيمي:

المثلي: هو ما يكون له نظير في الأسواق بدون تفاوت في أجزائه ووحداته، تفاوتٌ يعتد به في المعاملات، كالمكيلات والموزونات والمعدودات المتحدة في النوع والتي تتقارب أحادها في الحجم كالليمون والبيض وغيرهما مما يباع عادة بالعدد باعتباره واحدًا في القيمة؛ لأن التفاوت بين أحادها زهيد لا يعبأ به.

والقيمي: ما لا يكون له نظير في الأسواق أصلاً كالأثار القديمة والتحف النادرة، أو يكون له نظير في الأسواق ولكن مع التفاوت في القيمة تفاوتًا يعتد به في المعاملات كالحيوانات بجميع أنواعها، والأشجار والأحجار الكريمة، وأراضي الزرع والبناء (١).

وتظهر فائدة هذا التقسيم فيما يلي:

- (١) إذا تعدى إنسان على مالٍ مثليٍّ لآخر يكون عليه مثل ما أتلّف، حتى يكون التعويض على أكمل وجه، أما في القيمي: فيضمن قيمته ما دام لا مثل له.
- (٢) تدخل القسمة جبرًا في المال المثلي المشترك، وليس كذلك في المال القيمي.

وفرق الشافعية بين الملك والاختصاص فقالوا: إن الملك يتعلق بالأعيان والمنافع، والاختصاص إنما يكون في المنافع، وبأن الاختصاص أوسع، ولهذا شواهد منها أنه يثبت فيما لا يملك من النجاسات كالكلب والزيت والنجس وجلد الميتة ونحوه.

ومنها أن من قعد بنحو مسجد أو شارع بأنه لا يزج عنه، واعتبروا أن قوله - صلى الله عليه وسلم -: " من سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم فهو له " وفي رواية أخرى فهو أحق به. / حاشية الجمل ج ٣ ص ٥٦٧ هو على سبيل الاختصاص لا الملك من غير اختصاصاً لا ملكاً ومحل الاختصاص:

أولاً: الأشياء المحرمة والنجسة إذا جاز الانتفاع بها بشكل محدود، وذلك كما في جلد الميتة فإنه يطهر بالدبغ، فيجوز الانتفاع به ويكون لصاحبه حق الاختصاص به، وكما في الكلب المعين لصيد أو حراسة حيث يختص به صاحبه ولا يجوز له بيعه.

ثانيًا: منافع الأسواق والطرق والمساجد، دون سائر المرافق العامة.

ثالثًا: الأراضي الموات مقدمة للإحياء.

وأما الملك فمحل جميع الأشياء التي أجاز الشارع الانتفاع بها وثبت للشخص عليها الحق في التصرف والانتفاع الكامل. / د/ أحمد فرج حسين: الملكية ونظرية العقد في الشريعة الإسلامية ص ٩٣ - ٩٥.

(١)-علي حيدر: درر الحكام شرح مجلة الأحكام ج ١ ص ١٠١ - ١٠٥.

(٣) يصح في البيع أن يكون المثلي ثمنًا لأنه متعين تمامًا، كما يصح طبعًا أن يكون مبيعًا، أما القيمي فلا يصح أن يكون ثمنًا (١).

المبحث الثاني **التعريف بالعقد في الفقه والقانون.**

تعريف العقد:

العقد في لغة العرب: معناه الربط (أو الإحكام والإبرام) بين أطراف الشيء، سواء كان ربطاً حسيًا أم معنويًا، من جانب واحد، أم من جانبين. فيقال: عقد الحبل، أو البيع، أو العهد فانهقد. ويقال: عقد النية والعزم على شيء، وعقد اليمين أي ربط بين الإرادة وتنفيذ ما التزم به. وعقد البيع والزواج والإجارة أي ارتبط مع شخص آخر (٢).

وهذا المعنى اللغوي داخل في المعنى الاصطلاحي الفقهي لكلمة العقد.

وللعقد عند الفقهاء معنيان: عام وخاص:

أما المعنى العام: الأقرب إلى المعنى اللغوي والشائع عند فقهاء المالكية والشافعية والحنابلة (٣) فهو: كل ما عزم المرء على فعله، سواء صدر بإرادة منفردة كالوقف والإبراء والطلاق واليمين، أم احتاج إلى إرادتين في إنشائه كالبيع والإيجار والتوكيل والرهن، أي أن هذا المعنى يتناول الالتزام مطلقًا، سواء من شخص واحد أو من شخصين، ويشمل حينئذ ما يسمى في المعنى الضيق أو الخاص عقداً، كما يشمل ما يسمى تصرفاً أو التزاماً. فالعقد بالمعنى العام ينتظم جميع الالتزامات الشرعية، وهو بهذا المعنى يرادف كلمة الالتزام.

وأما المعنى الخاص الذي يراد هنا حين الكلام عن نظرية العقد فهو: ارتباط إيجاب بقبول على وجه مشروع يثبت أثره في محله (٤)

أو بعبارة أخرى: تعلق كلام أحد العاقدين بالآخر شرعاً على وجه يظهر أثره في المحل (٥).

(١)-د/ محمد يوسف موسى الأموال ونظرية العقد في الفقه الإسلامي ص ١٥٠ - ١٥٢، د / عبد الحكيم المغربي:

المعاملات في الفقه الإسلامي ج ١ ص ٩ - ١١، الإمام محمد أبو زهرة: الملكية ونظرية العقد ص ٥٥ - ٦٢.

(٢)- المقرئ: المصباح المنير ج ٢ ص ٤٢١، ابن منظور: لسان العرب ج ٣ ص ٢٩٦.

(٣)-ابن تيمية: نظرية العقد ص ١٨ - ٢١، ٧٨. ومن هؤلاء الذين يجعلون العقد عامًا هكذا، الإمام أبو بكر الرازي

الجصاص: أحكام القرآن ج ٢ ص ٢٩٤.

(٤)-المادة ١٠٤، ١٠٣ من مجلة الأحكام العدلية، رد المحتار لابن عابدين ج ٢ ص ٣٥٥.

(٥)-العناية بهامش فتح القدير ج ٥ ص ١٧٤.

وهذا التعريف هو الغالب الشائع في عبارات الفقهاء.

فإذا قال شخص لآخر: بعثك الكتاب، فهو الإيجاب، وقال الآخر: اشتريت، فهو القبول، ومتى ارتبط القبول بالإيجاب، وكنا صادرين من ذوي أهلية معتبرة شرعاً، ثبت أثر البيع في محله (وهو الكتاب هنا): وهو انتقال ملكية المبيع للمشتري، واستحقاق البائع الثمن في ذمة المشتري.

والإيجاب أو القبول: هو الفعل الدال على الرضا بالتعاقد والتقييد بكونه (على وجه مشروع) لإخراج الارتباط على وجه غير مشروع، كالاتفاق على قتل فلان، أو إتلاف محصوله الزراعي، أو سرقة ماله، أو الزواج بالأقارب المحارم، فكل ذلك غير مشروع لا أثر له في محل العقد. والتقييد بكونه (يثبت أثره في محله) لإخراج الارتباط بين كلامين لا أثر له، كالاتفاق على بيع كل شريك حصته من دار أو أرض لصاحبه بالحصصة الأخرى المساوية لها، فهذا لا فائدة منه ولا أثر له.

والعقد قانوناً يلتقي مع هذا التعريف الثاني عند الفقهاء: وهو "توافق إرادتين على إحداث أثر قانوني من إنشاء التزام أو نقله، أو تعديله أو إنهائه"^(١). فإنشاء الالتزام كالبيع والإجارة، ونقله كالحالة، وتعديله كتأجيل الدين، وإنهاؤه كالإبراء من الدين، وفسخ الإجارة قبل أوانها، فالتعريفان متقاربان^(٢).

المبحث الثالث:

أركان العقد

الركن في اصطلاح علماء الأصول من الحنفية: هو ما يتوقف عليه وجود الشيء وكان جزءاً داخلاً في حقيقته.

ففي العبادات: يعد الركوع والسجود وقراءة القرآن أركاناً للصلاة.

وفي المعاملات: الإيجاب والقبول أو ما يقوم مقامهما هو ركن العقد.

(١) د / السنهوري: الوسيط ص ١٣٨، د / عبد الحي حجازي: النظرية العامة للالتزام ص ٣٥ وما بعدها.

(٢) -الأستاذ الزرقا: المدخل الفقهي ص ١٣٤، الأستاذ مصطفى شلبي: المدخل ص ٣١٥، د / عبد الحكيم المغربي:

المعاملات في الفقه الإسلامي ج ١ ص ٢٨ ن ٣٩، د / وهبة الزحيلي: الفقه الإسلامي وأدلته ج ٤ ص

٢٩٢٠، ٢٩٢١، د / أحمد فرج حسين: الملكية ونظرية العقد ص ١٤٠، ١٤١.

فركن العقد: هو كل ما يعبر به عن اتفاق الإرادتين أو ما يقوم مقامهما من فعل أو إشارة أو كتابة (١).

هذا هو مذهب الحنفية، وأما بقية العناصر أو المقومات التي يقوم عليها العقد من محل معقود عليه وعاقدين، فهي لوازم لا بد منها لتكوين العقد؛ لأنه يلزم من وجود الإيجاب والقبول وجود عاقدين، ولا يتحقق ارتباط العاقدين إلا بوجود محل يظهر فيه أثر الارتباط. وغير الحنفية "الجمهور" يقولون:

إن للعقد أركاناً ثلاثة إجمالاً هي: عاقد، ومعقود عليه، وصيغة.

سنة تفصيلاً: فالعاقد في البيع هو: البائع والمشتري، والمعقود عليه: هو الثمن والمثمن، والصيغة: هي الإيجاب والقبول (٢)، باعتبار أن الركن عند الجمهور: هو ما يتوقف عليه وجود الشيء وإن لم يكن جزءاً داخلياً في حقيقته.

وأياً كان هذا الاختلاف فهو اصطلاح لا تأثير له من حيث النتيجة.

تعريف الإيجاب والقبول:

الإيجاب والقبول يكونان صيغة العقد، أي العبارات الدالة على اتفاق الطرفين المتعاقدين. وتعريفهما عند الحنفية (٣) ما يأتي:

الإيجاب: إثبات الفعل الخاص الدال على الرضا الواقع أولاً من كلام أحد المتعاقدين، أو ما يقوم مقامه، سواء وقع من المملك أو الممتلك (٤). فقول العاقد الأول في البيع هو الإيجاب، سواء صدر من البائع أو من المشتري. فإذا قال البائع أولاً (بعت) فهو الإيجاب. وإذا ابتدأ المشتري الكلام فقال: (اشتريت بكذا) فهو الإيجاب.

والقبول: ما ذكر ثانياً من كلام أحد المتعاقدين، دالاً على موافقته ورضاه بما أوجبه الأول (٥).

(١)-حاشية رد المحتار لابن عابدين ج ٤ ص ٥.

(٢)-الشرح الكبير وحاشية الدسوقي ج ٣ ص ٢، غاية المنتهي ج ٢ ص ٣، القوانين الفقهية ص ٢٤٥.

(٣)-ابن عابدين: رد المحتار ج ٤ ص ٦ والمراجع السابقة.

(٤)-ورد تعريف الإيجاب في المجلة (م ١٠١) " فالإيجاب أول كلام يصدر من أحد المتعاقدين لأجل إنشاء التصرف وبه يوجب ويثبت التصرف.

(٥)-عرفت المجلة في المادة (١٠٢) القبول بما يأتي: " القبول: ثاني كلام يصدر من أحد العاقدين لأجل إنشاء التصرف، وبه يتم العقد ".

فالمعتبر إذن: أولية الصدور وثانويته فقط، سواء أكان من جهة البائع أم من جهة المشتري في عقد البيع؟.

وعند الجمهور:

الإيجاب: هو ما صدر ممن يكون منه التملك، وإن جاء متأخراً.

والقبول: هو ما صدر ممن يصير له الملك، وإن صدر أولاً.

ففي عقد البيع: إذا قال المشتري: اشتريت منك هذه البضاعة بكذا، وقال البائع: بعته لك بهذا الثمن، انعقد البيع، وكان الإيجاب ما صدر عن البائع؛ لأنه المملك، والقبول ما صدر من المشتري، وإن صدر أولاً^(١).

والواقع أن تسمية إحدى عبارتي العاقلين إيجاباً، والأخرى قبولاً هي تسمية اصطلاحية، ليس لها أثر يذكر، والأصل العام في الإيجاب أن يقع من البائع أولاً، ويقع القبول من المشتري ثانياً^(٢).

شروط انعقاد العقد:

لكي ينعقد العقد وتترتب عليه آثاره لابد أن تتوفر في أركانه بعض الشروط وهذا ببيانها:
أولاً: ما يختص:

صيغة العقد: هي ما صدر من المتعاقدين دالاً على توجه إرادتهما الباطنة لإنشاء العقد وإبرامه، وتعرف تلك الإرادة الباطنة بواسطة اللفظ أو القول أو ما يقوم مقامه من الفعل أو الإشارة أو الكتابة.

وهذه الصيغة هي الإيجاب والقبول. والبحث فيها يكون ببيان أساليب الصيغة، وشروطها.

أساليب صيغة الإيجاب والقبول:

التعبير عن الإرادة العقدية الجازمة يكون بأي صيغة تدل عرفاً أو لغة على إنشاء العقد، سواء بالقول أو بالفعل أو بالإشارة أو بالكتابة، وقد نصت على هذه الأساليب المادة (١٧٣) و (١٧٤) من المجلة^(٣).

(١)-الشرح الكبير وحاشية الدسوقي عليه ج ٣ ص ٣، الأنصاري: شرح المنهج ج ٢ ص ١٨٠، غاية المنتهى ج ٢ ص ٣، كشف القناع ج ٢ ص ٣.

(٢)-د/ وهبة الزحيلي: الفقه الإسلامي وأدلته ج ٤ ص ٢٩٣٠ - ٢٩٣٢، د/ محمد يوسف موسى: الأموال ونظرية العقد في الفقه الإسلامي ص ٢٣٣، ٢٣٤.

(٣)-مجلة الأحكام العدلية مادة: ١٧٣، ١٧٤.

(أ) اللفظ (أو القول):

اللفظ هو الأداة الطبيعية الأصلية في التعبير عن الإرادة الخفية وهو الأكثر استعمالاً في العقود بين الناس لسهولة وقوة دلالاته ووضوحه، فيلجأ إليه متى كان العاقد قادراً عليه، وبأي لغة يفهمها المتعاقدان. ولا يشترط فيه عبارة خاصة، وإنما يصح بكل ما يدل على الرضا المتبادل بحسب أعراف الناس وعاداتهم؛ لأن الأصل في العقود هو الرضا، لقوله تعالى: ﴿إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ﴾ (١)، ولقوله عليه الصلاة والسلام: "إنما البيع عن تراض" (٢).

مادة اللفظ: لا يشترط في العقود كالبيع والإيجار والرهن والهبة ونحوهما لفظ معين أو عبارة مخصوصة، كأن يقول البائع: بعت بكذا، أو ملكته لك بكذا أو أعطيته لك بكذا، أو وهبته بثلث كذا. ويقول المشتري: اشتريت، أو قبلت، أو رضيت، أو خذ الثمن وهات المبيع. أما عقد الزواج فاختلف الفقهاء في شأن الألفاظ المستعملة فيه، نظراً لخطورته وقداسته.

صيغة اللفظ أو نوع الفعل:

اتفق الفقهاء على صحة انعقاد العقد بالفعل الماضي؛ لأن صيغته أدل على المراد وهو إنشاؤها في الحال، فينعقد بها العقد من غير توقف على شيء آخر كالنية أو القرينة، وقد تعارف الناس استعمال هذه الصيغة (٣).

واتفق الفقهاء أيضاً على الانعقاد بصيغة المضارع إذا توافرت نية الحال أو دلت القرينة على إرادة إنشاء العقد حالاً؛ لأن المضارع يدل على الحال والاستقبال، ففيه احتمال الوعد والمساومة، فكان لا بد من النية لتعيين المراد في الحال، وإنشاء العقد حالاً، مثل أبيع وأشتري وأزوجك وأقبل وأرضى.

وينعقد العقد بالجملة الاسمية على الأصح، مثل أنا بائع لك كذا، أو واهب لك كذا، فقال آخر: أنا قابل، أو قال: نعم.

(١)-سورة النساء من الآية ٢٩..

(٢)-البيهقي: السنن الكبرى - كتاب البيوع - باب ما جاء في بيع المضطر وبيع المكره ج ٦ ص ١١٧.

(٣)-نصت المادة ١٦٨ من المجلة على ما يأتي: الإيجاب والقبول في البيع عبارة عن كل لفظتين مستعملتين لإنشاء البيع في عرف البلدة.

واختلف الفقهاء في انعقاد العقد بلفظ الأمر الذي يعبر به عن المستقبل، مثل: بعني، أو اشتر مني، أو أجرني، أو خذه بكذا.

فقال الحنفية: إن ما عدا عقد الزواج لا ينعقد بلفظ الأمر، ولو نوى ذلك، ما لم يقل القائل الأمر مرة أخرى في المثال السابق: اشتريت، أو بعت، أو استأجرت؛ لأن لفظ الأمر مجرد طلب وتكليف، فلا يكون قبولاً ولا إيجاباً.

وأما عقد الزواج فيصح بصيغة الأمر مثل: زوجيني نفسك، فقالت: زوجتك؛ لأن لفظ الأمر للمساومة، وعقد الزواج يسبق عادة بالخطبة، فلا يقصد بهذا الأمر الوعد والمساومة، وإنما المقصود به إنشاء العقد، لا مقدمات العقد وهي الخطبة، فيحمل على الإيجاب والقبول. أما غير الزواج كالبيع مثلاً، فإنه يحصل فجأة بدون مقدمات غالباً، فيكون الأمر فيه مساومة، عملاً بحقيقة لفظ الأمر، ويكون المراد به العدة أو المساومة، ولا يعدل عن المعنى الحقيقي للفظ إلى شيء آخر إلا بدليل، ولم يوجد الدليل في البيع، بخلاف الزواج، كما تقدم (١).

وقال جمهور الفقهاء غير الحنفية: ينعقد العقد بلفظ الأمر بدون حاجة للفظ ثالث من الأمر، سواء أكان بيعاً أم زواجاً؛ لأن أساس العقد هو التراضي، وقد جرى العرف على استعمال صيغة الأمر في إنشاء العقود كالماضي والمضارع فينعقد بها العقد، ويكون الأمر أو المستدعي عاقداً فعلاً: بائعاً أو مشترياً مثلاً (٢).

وهذا الرأي هو الأرجح لما فيه من تحقيق مصالح الناس ومراعاة أعرافهم وعاداتهم دون مصادمة النصوص الشرعية.

واتفق الفقهاء على عدم انعقاد العقد بصيغة الاستقبال: وهي صيغة المضارع المقرون بالسين أو سوف مثل: سأبيعك؛ لأن ذكر السين يدل على إرادة العقد في المستقبل، فهو وعد بالعقد وليس عقداً، أي أنه يدل على عدم إرادة الحال، فلا ينعقد بها العقد، حتى لو نوى بها العاقد الإيجاب والقبول.

(١) - البدائع ج ٢ ص ٤٨٨، حاشية ابن عابدين ج ٤ ص ٩، المجلة م ١٦٩ - ١٧٢..

(٢) الحطاب: مواهب الجليل ج ٤ ص ٢٢٨ - ٢٤٠، بداية المجتهد ج ٢ ص ١٦٨، مغني المحتاج ج ٢ ص ٣٢٤،

ابن قدامة: المغني ج ٣ ص ٣٩٧.

كذلك لا ينعقد العقد بصيغة الاستفهام؛ لدلالاتها على المستقبل؛ لأنها سؤال الإيجاب والقبول، وليست إيجاباً ولا قبولاً، كأن يقول المشتري: أتبيع مني هذا الشيء؟ فقال البائع: بعت، لا ينعقد العقد إلا إذا انضم لذلك لفظ، يقول المشتري مرة أخرى: اشتريت؛ لأن لفظ الاستفهام لا يستعمل للحال حقيقة (١).

بـ التعاقد بالأفعال (العقد بالمعاطاة)

قد ينعقد العقد بدون قول أو لفظ، وإنما بفعل يصدر من المتعاقدين ويسمى في الفقه بالمعاطاة أو التعاطي أو المراوضة: وهو التعاقد بالمبادلة الفعلية الدالة على التراضي دون تلفظ بإيجاب أو قبول (٢).

مثل أن يأخذ المشتري المبيع، ويدفع للبائع الثمن، أو يدفع البائع المبيع، فيدفع له الآخر ثمنه من غير تكلم ولا إشارة، سواء أكان المبيع حقيراً أم نفسياً.

ففي البيع لو وجد الرجل سلعة مسعرة كتب عليها الثمن كساعة أو حلي، فناول الثمن للبائع وأخذ السلعة دون إيجاب وقبول لفظيين، انعقد البيع لدلالته على التراضي في عرف الناس. كذلك ينعقد لو اقتصر المشتري على دفع عربون؛ لأنه جزء من الثمن.

وفي الإجارة: لو ركب الإنسان سيارة من وسائل النقل، ثم دفع ثمن التذكرة إلى الكساري دون كلام متبادل صح الإيجار عرفاً.

لكن الفقهاء اختلفوا في التعاقد بالتعاطي في العقود المالية على أقوال ثلاثة:

الأول: مذهب الحنفية والحنابلة "في رواية" قالوا: ينعقد العقد بالتعاطي فيما تعارفه الناس، سواء أكان الشيء يسيراً كالبيضة والرغيف والجريدة، أم نفسياً (كثير الثمن) كالدار والأرض والسيارة؛ لأن تعارف الناس دليل ظاهر على التراضي، سواء تمت المبادلة الفعلية من الجانبين، أو من جانب واحد ومن الآخر اللفظ على الأصح المفتى به، وسواء في ذلك البيع والإجارة والإعارة والهبة والرجعة.

وذلك بشرط أن يكون ثمن المعقود عليه معلوماً تماماً، وإلا فسد العقد، وألا يصرح العاقد مع التعاطي بعدم الرضا بالعقد (١).

(١) د/ وهبة الزحيلي: الفقه الإسلامي وأدلته ج ٤ ص ٢٩٣٤ - ٢٩٣٧، د / محمد يوسف محمد: الأموال ونظرية العقد

في الفقه الإسلامي ص ٢٤٣ وما بعدها.

(٢) نصت المادة (١٧٥) من المجلة على ما يأتي: "حيث إن المقصد الأصلي من الإيجاب والقبول هو تراضي الطرفين، فينعقد البيع بالمبادلة الفعلية الدالة على التراضي، ويسمى هذا بيع التعاطي"، وذكرت المادة أمثلة لذلك.

الثاني: مذهب مالك وأصل مذهب أحمد قالوا: ينعقد العقد بالفعل أو بالتعاطي متى كان واضح الدلالة على الرضا، سواء تعارفه الناس أم لا (٢).

الثالث: مذهب الشافعية والظاهرية والشيعة قالوا: لا تنعقد العقود بالأفعال أو بالمعاطاة؛ لعدم قوة دلالتها على التعاقد؛ لأن الرضا أمر خفي، لا دليل عليه إلا باللفظ، وأما الفعل فقد يحتمل غير المراد من العقد، فلا يعقد به العقد، وإنما يشترط أن يقع العقد بالألفاظ الصريحة أو الكنائية، أو ما يقوم مقامها عند الحاجة كالإشارة المفهمة أو الكتابة.

ونظراً لما يشتمل عليه هذا المذهب من تشدد وشككية محدودة ومجافاة لمبدأ المرونة والسماحة واليسر، فقد اختار جماعة من الشافعية منهم النووي والبعثي والمتولي، صحة انعقاد بيع المعاطاة في كل ما يعده الناس بيعاً؛ لأنه لم يثبت اشتراط لفظ، فيرجع للعرف كسائر الألفاظ المطلقة، وبعض الشافعية كابن سريج والرويانى خصص جواز بيع المعاطاة بالمحقرات أي غير النفيسة، هي ما جرت العادة فيها بالمعاطاة كرطل خبز، أو رغيف، وحزمة بقل ونحوها (٣).

عقد الزواج: وبغض النظر عن الاختلاف السابق في التعاقد بالمعاطاة، أجمع الفقهاء على أن الزواج لا ينعقد بالفعل، كإعطاء المهر مثلاً، بل لابد من القول للقادر عليه؛ لأن عقد الزواج خطير مقدس له آثار دائمة على المرأة، فكان لابد من الاحتياط له، وإتمامه بأقوى الدلالات على الإرادة وهو القول؛ حفاظاً على كرامة المرأة ومستقبلها، وصوناً لها عن الابتذال، ولأن عقد الزواج يتطلب الإشهاد عليه؛ تمييزاً له عن السفاح أو الزنا، ولا يتمكن الشهود من معرفة عقد الزواج إلا بسماع لفظ الإيجاب والقبول (٤).

وكالزواج عند الإمام الشافعي: الطلاق والخلع والرجعة، لا تجوز إلا بالقول.

ج - التعاقد بالإشارة:

-
- (١) الكاساني: البدائع ج ٤ ص ٣١٩، ابن قدامة: المغني ج ٣ ص ٣٩٧، غاية المنتهي ج ٢ ص ٥.
- (٢) الحطاب: مواهب الجليل ج ٤ ص ٢٢٨، ابن رشد: بداية المجتهد ج ٢ ص ١٦١، الخرشي ج ٥ ص ٥، ابن قدامة: المغني ج ٣ ص ٣٩٧، فتاوى ابن تيمية ج ٣ ص ٢٦٧.
- (٣) الخطيب الشربيني: مغني المحتاج ج ٢ ص ٣٢٤ - ٣٢٦، الرملي: نهاية المحتاج ج ٣ ص ٣٧٥، الشيرازي: المهذب ج ١ ص ٢٥٧، ابن حزم: المحلى ج ٨ ص ٤٠٤، المختصر النافع في فقه الإمامية ص ١٤٢.
- (٤) الدر المختار ج ٢ ص ٣٦٤، د / أحمد فرج حسين: الملكية ونظرية العقد ص ١٥٣ - ١٥٦.

وكما ينعقد العقد بالقول، ينعقد أيضاً بالإشارة من غير القادر على الكلام. أما القادر على النطق: فلا تنفع إشارته بالإيجاب أو القبول في انعقاد العقد، بل عليه أن يعبر بلسانه لفظاً أو كتابة، وإلا لم ينشأ العقد بإشارته عند الأحناف والشافعية؛ لأن الإشارة - مهما كانت دلالتها على الإرادة - لا تفيد اليقين الذي يفيد التعبير اللفظي أو المكتوب.

والخرس: أي عدم استطاعة النطق، قد يكون أصلياً خلقه بأن ولد بهذه الآفة، وقد يكون عارضاً، فإن كان أصلياً: قامت إشارته المفهومة دائماً مقام عبارته، وإن كان عارضاً: بأن طرأ عليه الخرس، فلا تفيد إشارته في إنشاء العقد إلا إذا يئسنا من عودة النطق إليه وصارت إشارته مفهومة تدل على إرادته حقاً فيلحق بالأخرس الأصلي (١).

وإذا كان الأخرس قادراً على الكتابة، كان عليه أن يعبر بها ولا تفيد إشارته في عقد العقد.

والعلة في هذا: أن الكتابة هي الطريق الطبيعي الثاني، أي بعد التعبير اللفظي للدلالة على إرادة صاحبها دلالة لا شك فيها، فهي لذلك أدل على المراد بيقين أكثر من دلالة الإشارة، وإذا فلا يصار إلى هذه إلا بعد تعذر التعبير بالكتابة متى كان الذي لا يستطيع النطق قادراً عليها (٢).

د - التعاقد بالكتابة:

يصح التعاقد بالكتابة بين طرفين، ناطقين أو عاجزين عن النطق، حاضرين في مجلس واحد أو أحد غائبين، وبأي لغة يفهمها المتعاقدان، بشرط أن تكون الكتابة مستبينة (بأن تبقى صورتها بعد الانتهاء منها) ومرسومة (مسطرة بالطريقة المعتادة بين الناس بذكر المرسل إليه وتوقيع المرسل) فإذا كانت غير مستبينة كالرقم أو الكتابة على الماء أو في الهواء، أو غير مرسومة كالرسالة الخالية من التوقيع مثلاً، لم ينعقد بها العقد، وهذا رأى الحنفية والمالكية (٣).

(١) الكاساني: البدائع ج ٤ ص ٣٢٢، الخطيب الشربيني: مغني المحتاج ج ٢ ص ٣٣٢، الدردير: الشرح الكبير وحاشية الدسوقي عليه ج ٣ ص ٣، وفيه عدم اشتراط أن يكون صاحبه الإشارة المفهومة أخرس.

(٢) البهوتي: كشاف القناع ج ٢ ص ١٧٣.

(٣) الكاساني: البدائع ج ٤ ص ٣٢٥، الدر المختار وحاشية ابن عابدين ج ٤ ص ١٠، الدردير: الشرح الكبير ج ٣

وذلك كأن يرسل شخص خطاباً لآخر يقول فيه: (بعثك سيارتي بكذا) فإذا وصله الكتاب، فقال في مجلس قراءة الكتاب: قبلت، انعقد البيع، فإن ترك المجلس، أو صدر منه ما يدل على الإعراض عن الإيجاب، كان قبوله غير معتبر.

وفي حال إرسال رسول إلى آخر مثل إرسال الكتاب، يعتبر مجلس وصول الرسول هو مجلس العقد، فيلزم أن يقبل فيه، فإن قام من المجلس قبل أن يقبل انتهى مفعول الإيجاب، فالمعتبر هو مجلس بلوغ الرسالة أو الكتابة. وصورة الإرسال: أن يقول شخص: بعث لفلان كذا، فاذهب يا فلان وقل له، فذهب الرسول، فأخبره، فقبل المشتري في مجلسه ذلك: صح العقد "(١).

لكن عقد الزواج لا يصح انعقاده بالكتابة إذا كان العاقدان حاضرين في مجلس واحد، إلا حال العجز عن النطق كالخرس؛ لأن الزواج يشترط لصحته حضور الشهود وسماعهم كلام العاقدين، وهذا لا يتيسر في حال الكتابة.

وقيد الشافعية والحنابلة صحة التعاقد بالكتابة أو الرسالة فيما إذا كان العاقدان غائبين، أما في حال الحضور فلا حاجة إلى الكتابة؛ لأن العاقد قادر على النطق، فلا ينعقد العقد بغيره (٢).

ثانياً: شروط (٣) الإيجاب والقبول:

اشتراط الفقهاء لانعقاد العقد شروطاً ثلاثة في الإيجاب والقبول هي (٤):

الشرط الأول: وضوح دلالة الإيجاب والقبول: أي أن يكون كل من الإيجاب والقبول واضح الدلالة على مراد العاقدين.

(١) الكاساني: البدائع ج ٤ ص ٣٢٥.

(٢) الشيرازي: المهذب ج ١ ص ٢٥٧، غاية المنتهي ج ٢ ص ٤.

(٣) الشرط: ما يتوقف عليه وجود الشيء، ويكون جزءاً خارجاً عن حقيقته، كالوضوء أو الطهارة للعبادات، لا تصح الصلاة بدون الطهارة، لكنها غير داخلية في تكوين الصلاة. وكالقدرة على التسليم في المعاملات لا بد منها لانعقاد العقد، لكنها ليست جزءاً داخلية في تكوين العقد. وبذلك يظهر أن الركن والشرط يتوقف عليهما وجود الشيء. إلا أن الركن داخل في حقيقة الشيء وجزء منه، أما الشرط فخارج عن الحقيقة ولا يعد جزءاً منها.

(٤) البدائع ج ٤ ص ٣٢٤، ٣٢٥، حاشية ابن عابدين ج ٤ ص ٥، حاشية الدسوقي ج ٣ ص ٥، مغني المحتاج ج ٢ ص ٣٢٩ وما بعدها، غاية المنتهي ج ٢ ص ٤، الشيخ على الخفيف: أحكام المعاملات الشرعية ص ٦٩، ٧٠.

ولا يشترط لهذه الدلالة لفظ أو شكل معين؛ لأن العبرة في العقود للمعاني، لا للألفاظ والمباني.

الشرط الثاني: تطابق القبول والإيجاب: بأن يكون القبول موافقاً للإيجاب، بأن يرد على كل ما أوجبه الموجب وبما أوجبه، أي على كل محل العقد، ومقدار العوض في عقود المعاوضات، سواء أكانت الموافقة حقيقية، كما لو قال البائع: بعثك الشيء بعشرة، فيقول المشتري: اشتريته بعشرة، أو ضمنية كما لو قال المشتري في المثال السابق: اشتريته بخمس عشرة. أو أن تقول المرأة: زوجتك نفسي بمائة، فيقول الزوج: قبلت الزواج بمائة وخمسين، فالتوافق متحقق ضمناً، وهذه المخالفة خير للموجب. لكن العقد لا يلزم إلا بالمقدار الذي وجهه الموجب أي مائة في المثال الأخير، وأما الزيادة فموقوفة على قبول الموجب في مجلس العقد، فإن قبل به الموجب لزم القابل؛ لأن المال لا يدخل في ملك إنسان بغير اختياره إلا في الميراث.

فإن لم يتطابق القبول مع الإيجاب، وحدثت مخالفة بينهما، لا ينعقد العقد (١).

الشرط الثالث: اتصال القبول بالإيجاب:

بأن يكون الإيجاب والقبول في مجلس واحد إن كان الطرفان حاضرين معاً، أو في مجلس علم الطرف الغائب بالإيجاب.

ويتحقق الاتصال بأن يعلم كل من الطرفين بما صدر عن الآخر بأن يسمع الإيجاب ويفهمه، وبألا يصدر منه ما يدل على إعراضه عن العقد، سواء من الموجب أو من القابل.

ومجلس العقد: هو الحال التي يكون فيها المتعاقدان مشغولين فيه بالتعاقد، وبعبارة أخرى: اتحاد الكلام في موضوع التعاقد.

ويشترط لتحقيق معنى اتصال القبول بالإيجاب الأمور التالية:

الأول: أن يكونا في مجلس واحد، ما عدا ثلاثة: الوصية، والإيصاء، والوكالة.

الثاني: ألا يصدر من أحد العاقدين ما يدل على إعراضه.

الثالث: ألا يرجع الموجب في إيجابه قبل قبول القابل الآخر (٢).

العدول عن الإيجاب في مجلس العقد:

(١) حاشية ابن عابدين ج ٢ ص ٢٧٤.

(٢) د / السنهوري: مصادر الحق ج ٢ ص ٥٧، د / محمد يوسف موسى: الأموال ونظرية العقد ص ٢٥٩، د /

وهبة الزحيلي: الفقه الإسلامي ج ٤ ص ٢٩٥٤، ٢٩٥٥.

ذهب جمهور الفقهاء (الحنفية وبعض المالكية والشافعية والحنابلة) إلى أن للموجب أن يرجع عن إيجابه قبل صدور القبول من الطرف الآخر، ويبطل الإيجاب حينئذ؛ لأن الالتزام بالعقد لم ينشأ بعد، ولا ينشأ إلا بارتباط القبول بالإيجاب (١).

وقال أكثرية المالكية: ليس للموجب الرجوع عن إيجابه، وإنما يلتزم بالبقاء على إيجابه حتى يعرض الطرف الآخر عنه، أو ينتهي المجلس ما لم تكن هناك مدة محددة أكثر من المجلس كأن يقول: أنا على إيجابي مدة أسبوع مثلاً؛ لأن الموجب قد أثبت للطرف الآخر حق القبول والتملك، فله استعماله وله رفضه، فإذا قبل ثبت العقد، وإذا أعرض عن الإيجاب لم ينشأ العقد. وعليه لا يكون الرجوع مبطلا للإيجاب (٢).

الرأي الراجح: هو رأي الجمهور لتأكيد على حرية الموجب وحقوقه، وهذا لا يضر الطرف الآخر، إذا كان له - لو أراد - أن يبادر في الفترة المناسبة بالقبول قبل عدول صاحبه، ولا سيما، وحق الملكية أقوى من حق التملك فيجب أن يقدم عليه عند التعارض؛ لأن الأول ثابت لصاحبه أصالة، والثاني لا يكون للطرف الآخر إلا برضاء الطرف الأول.

مبطلات الإيجاب: يبطل الإيجاب بالأمر التالية:

رجوع الموجب عنه قبل القبول في المجلس، على رأي الجمهور.
رفض الإيجاب من الطرف الآخر، إما صراحة كأن يقول: لا أقبل، أو ضمناً كأن يعرض عنه إما بالقيام عن المجلس بعد القعود، أو بالاشتغال بعمل آخر كأكل، أو سماع حديث آخر، أو قراءة خبر صحفي ونحوه.

انتهاء مجلس العقد، بتفرق العاقدین عرفاً؛ لأن الإيجاب يظل قائماً في المجلس، فلما انتهى بطل مفعوله؛ لأن المجلس يجمع المتفرقات.

خروج الموجب عن أهليته قبل القبول بالموت أو بالجنون أو بالإغماء ونحوه وكذا فقد القابل أهليته بهذه الأسباب؛ لأن انعقاد العقد يتوقف على توافر الأهلية، فإذا فقدت لم ينعقد العقد، لاحتمال وجود الرجوع عن الإيجاب، أو لعدم فهم القبول، أو لعدم صدور قبول معتبر شرعاً.

(١) شرح فتح القدير ج ٦ ص ٢٥٦، البدائع ج ٥ ص ١٥، مغني المحتاج ج ٢ ص ٣٣١، غاية المنتهي ج ٢ ص

(٢) الخطاب: مواهب الجليل ج ٤ ص ٢٤١.

هلاك محل العقد قبل القبول، أو تغييره بما يصيره شيئاً آخر، مثل قلع عين حيوان، أو انقلاب عصير العنب خمراً، ونحو ذلك(١).

الركن الثاني: العاقد.

الإيجاب والقبول اللذان يكونان ركن العقد كما تقدم، لا يتصور وجودهما من غير عاقد، فالعاقد ركيزة التعاقد الأصلية.

غير أنه ليس كل واحد من الناس يصلح أن يكون عاقداً؛ فمن الناس من لا يصلح لإنشاء أي عقد فإيجابه أو قبوله لغو لا قيمة له، ومنهم من يعتبر كلامه وفعله في بعض التصرفات دون البعض، ومنهم من يعتبر كل ذلك منه، ثم منهم من يتصرف أصيلاً عن نفسه، ومن يتصرف بالنيابة عن غيره على اختلاف ضروب النيابة.

ومرد ذلك كله إلى أهلية المرء الذي يصدر منه التصرف أو عدم أهليته، وإلى ولايته عن غيره أو عدم ولايته، ولهذا يجب يشترط في العاقدين ما يلي:

أولاً: الأهلية

الأهلية في اللغة: الصلاحية، فيقال: فلان أهل لهذا العمل، أي صالح له، كما يقال: فلان أهل لأن يحفظ أمانات الناس أو يتولى شئونهم أي صالح لذلك وكفاء له(٢). وفي اصطلاح الفقهاء: هي صلاحية الإنسان لثبوت الحقوق المشروعة له، وعليه، وصحة تصرفاته بعد تعلق الخطاب والتكليف به(٣).

والأهلية تنقسم إلى قسمين:

- ١ - أهلية وجوب.
- ٢ - أهلية أداء.

(١) أهلية الوجوب: هي صلاحية الشخص لأن تجب له الحقوق قبل الغير وتجب عليه الواجبات للغير، أو بمعنى آخر هي صلاحية الشخص للإلزام والالتزام، ومناطق هذه الأهلية هو الحياة أو الصفة الإنسانية، فكل إنسان حتى الجنين في بطن أمه له أهلية وجوب، تبدأ منذ بدء تكوين الجنين في الرحم، وتنتهي بالموت.

(١) فتح القدير ج ٦ ص ٢٥٣، ٢٥٦، البدائع ج ٤ ص ٣٢٣. حاشية ابن عابدين ج ٤ ص ٢١، الشرح الكبير ج ٣ ص ٥، مغني المحتاج ج ٢ ص ٣٣٠ وما بعدها، غاية المنتهي ج ٢ ص ٥٠ د / محمد يوسف موسى: الأموال ونظرية العقد ص ٢٤٠ وما بعدها، د / وهبة الزحيلي: الفقه الإسلامي وأدلته ج ٤ ص ٢٩٥٨، د / أحمد فرج حسين: الملكية ونظرية العقد ص ١٦٧، ١٦٨.

(٢) ابن منظور: لسان العرب ج ١١ ص ٢٩. مادة أهل، المعجم الوسيط ج ١ ص ٣٢.

(٣) مُثلاً خُسر: مرآة الأصول ٥٩٠ - ٥٩١، التقرير والحبير ج ٢ ص ١٦٤.

وأهلية الوجوب نوعان: ناقصة وكاملة.

أهلية الوجوب الناقصة: هي صلاحية الشخص لثبوت الحقوق له فقط أى تؤهله للإلزام ليكون دائماً لا مديناً. وتثبت للجنين في بطن أمه قبل الولادة.

وأهلية الوجوب الكاملة: هي صلاحية الشخص لثبوت الحقوق له، وتحمل الواجبات (أو الالتزامات). وتثبت للشخص منذ ولادته حياً، دون أن تفارقه في جميع أدوار حياته، فيصلح لاكتساب الحقوق والالتزام بالواجبات. ولا يوجد إنسان فاقد لهذه الأهلية (١).

(٢) أهلية الأداء: هي صلاحية الشخص لصدور التصرفات منه (أو لممارستها ومباشرتها) على وجه يعتد به شرعاً، وهي مترادفة للمسؤولية، وتشمل حقوق الله من صلاة وصوم وحج وسواها، والتصرفات القولية أو الفعلية الصادرة عن الشخص. فالصلاة ونحوها التي يؤديها الإنسان تسقط عنه الواجب والجناية على مال الغير توجب المسؤولية. ومناطق هذه الأهلية: هو التمييز والبلوغ أو العقل والإدراك، فمن ثبتت له أهلية الأداء صحت عباداته الدينية كالصلاة والصوم، وتصرفاته المدنية كالعقود (٢).

ولا وجود لهذه الأهلية للجنين أصلاً، ولا للطفل قبل بلوغ سن التمييز وهو تمام سن السابعة، فقبل التمييز تكون هذه الأهلية منعدمة، والمجنون مثل غير المميز لا تترتب على تصرفاتهما آثار شرعية، وتكون عقودهما باطلة، إلا أنهما يؤخذان مالاً بالجناية أو الاعتداء على نفس الغير أو على ماله. ويقوم الولي (الأب أو الجد) أو الوصي بمباشرة العقود والتصرفات التي يحتاجها الطفل غير المميز أو المجنون.

وأهلية الأداء نوعان: ناقصة وكاملة.

أهلية الأداء الناقصة: هي صلاحية الشخص لصدور بعض التصرفات منه دون البعض الآخر، وهي التي يتوقف نفاذها على رأى غيره، وهذه الأهلية تثبت للشخص في دور التمييز بعد تمام سن السابعة إلى البلوغ، ويعد في حكم المميز: الشخص المعتوه الذي لم يصل به العتة إلى درجة اختلال العقل وفقده، وإنما يكون ضعيف الإدراك والتمييز.

(١) د / محمد يوسف موسى: الأموال ونظرية العقد ص ٢٩٤، ٢٩٥، د / وهبة الزحيلي: الفقه الإسلامي ج ٤ ص

(٢) التلويح على التوضيح ج ٢ ص ١٦٤، البزدوى: كشف الأسرار ص ١٣٦٨.

وأهلية الأداء الكاملة: هي صلاحية الشخص لمباشرة التصرفات على وجه يعتد به شرعاً وقانوناً، دون توقف على رأى غيره.

وتثبت لمن بلغ الحلم عاقلاً أي للبالغ الرشيد، فله بموجبها ممارسة كل العقود، من غير توقف على إجازة أحد.

ولكن جعل الشارع مناطها البلوغ، بالسن أو العلامات المعتادة المعروفة؛ لأنه مظنة العقل، ولأنه أمر ظاهر لا يخفي، والأحكام يجب أن ترجع إلى علل وأسباب مضبوطة واضحة.

ثانياً: الولاية

تعريف الولاية:

الولاية في اللغة: هي تولى الأمر والقيام به أو عليه. وفي اصطلاح الشرع: هي سلطة شرعية يتمكن بها صاحبها من إنشاء العقود والتصرفات وتنفيذها، أي ترتيب الآثار الشرعية والقانونية عليها. وهذه السلطة، قد تكون أصلية فيما إذا تولى الإنسان عقداً أو تصرفاً من التصرفات لنفسه، بأن كان بالغاً عاقلاً، فيلي أمور نفسه بنفسه؛ لأنه كامل أهلية الأداء وقد تكون نيابية، إذا ولى شخص ما أمور غيره من ناقصي هذه الأهلية وكان له من السلطة ما يبيح له القيام بعقوده وتصرفاته.

صلة الولاية بالعقد والفرق بينها وبين الأهلية:

يتطلب العقد لوجوده ونفاذه وترتيب آثاره الشرعية أن يكون العاقد ذا أهلية أداء، وذا ولاية على العقد بأن يكون أصيلاً عن نفسه أو ولياً أو وصياً على غيره، فإن لم يكن أصيلاً أو ولياً أو وصياً كان فضولياً.

وأهلية الأداء شرط انعقاد العقد ووجوده، فإن لم تتوافر كان العقد باطلاً. أما الولاية فهي شرط لنفاذ العقد (١) وترتب الآثار الشرعية عليه. وهي لا تثبت إلا لكامل أهلية الأداء. أما ناقص أهلية الأداء فلا ولاية له على نفسه ولا على غيره.

وبناء عليه يكون للعقد بالنظر للأهلية والولاية أحوال ثلاثة:

(١) النفاذ في الأصل: المضي والجواز، ثم أطلق عند الفقهاء على مضي العقد دون توقف على الإجازة أو الإذن.

أن العاقد كامل الأهلية وله ولاية العقد: وهنا يكون العقد صحيحا نافذا، إلا إذا كان فيه ضرر بآخر، وحينئذ لهذا " الآخر " أن يجيزه أو يعترض عليه فيصير موقوفا، وهذه حالة المستأجر أو المرتهن إذا بيعت العين قبل انتهاء مدة الإجازة أو قبل أداء الدين، فإن أجاز العقد، نفذ، وإلا توقف نفاذه حتى تنتهي المدة أو يؤدي البائع الدين الذي عليه للمرتهن، وهي كذلك حالة المدين الذي يضر تصرفه الدائن، وأيضا حالة المريض مرض الموت، على ما تقدم بيانه.

أن يصدر العقد ممن ليس له أهلية أداء مطلقا ولا ولاية: وحينئذ يكون باطلاً، كما في أحوال المجنون والصبي قبل سن التمييز، ممن تكون أهليته ناقصة كالصبي المميز أو السفهية وذي الغفلة عند الصاحبين (١) وحينئذ يكون التصرف صحيحا نافذا إن كان نافعا بلا ريب، وباطلا إن كان ضارا بلا ريب، وموقوفا على إجازة الولي أو الوصي إن كان محتملا للنفع والضرر.

أن يصدر العقد ممن له أهلية الأداء كاملة، ولكن ليس له ولاية عقده باسم من عُقد له، وهذه حالة الفضولي، فيتوقف على إجازة الذي عقد له (٢).

ثالثا: أنواع الولاية:

الولاية أما أن تكون أصلية: بأن يتولى الشخص عقدا أو تصرفا لنفسه، بأن يكون كامل أهلية الأداء (بالغا عاقلا راشداً) أو نيابية: بأن يتولى الشخص أمور غيره. والولاية النيابية أو النيابة الشرعية عن الغير: إما أن تكون اختيارية أو إجبارية: الاختيارية: هي الوكالة أي تفويض التصرف والحفظ إلى الغير على ما سيأتي. والإجبارية: هي تفويض الشرع أو القضاء التصرف لمصلحة القاصر، كولاية الأب أو الجد أو الوصي على الصغير، وولاية القاضي على القاصر. فمصدر ولاية الأب أو الجد أو القاضي هو الشرع. ومصدر ولاية الوصي إما اختيار الأب أو الجد، أو تعيين القاضي. والولاية النيابية الإجبارية: إما أن يكون ولاية على النفس أو ولاية على المال. الولاية على النفس: هي الإشراف على شئون الطفل والقاصر الشخصية كالحضانة والتزويج والتعليم والتأديب والتطبيب والتشغيل في حرفة ونحو ذلك.

(١) لأن أبا حنيفة: كما علمنا لا يجيز الحجر للدين أو السفه.

(٢) د / محمد يوسف موسى: الأموال ونظرية العقد ص ٣٢٢.

والولاية على المال: هي الإشراف على شئون القاصر المالية من حفظ المال واستثماره وإبرام العقود والتصرفات المتعلقة بالمال، وهي محل البحث هنا.

رابعاً: من يحتاج إلى الولاية:

تنبت الولاية على الصغير القاصر والمجنون والمعتوه، والمغفل، والسفيه.

خامساً: شروط الولي:

الولاية مسئولية كبرى في إدارة أموال وأعمال الغير، ويترتب عليها نفاذ التصرفات غالباً، لذا يشترط في الولي الخاص كالأب أو الجد أو الولي العام كالقاضي وناظر الوقف ومدير المؤسسة الخيرية شروط إما في شخصه أو في تصرفاته (١).

كمال أهلية الأداء بالبلوغ والعقل، فلا ولاية للمجنون ولا للصغير؛ لأنه لا ولاية لهما على أنفسهما، فلا تكون لهما ولاية على غيرهما، إذ فاقد الشيء لا يعطيه.

اتحاد الدين بين الولي والمولى عليه، فلا تنبت ولاية لغير المسلم على المسلم، كما لا ولاية للمسلم على غير المسلم؛ لأن اتحاد الدين باعث غالباً على الشفقة ورعاية المصلحة.

العدالة: أي الاستقامة على أمور الدين والأخلاق والمروءات، فلا ولاية للفاسق؛ لأن فسقه يجعله متهماً في رعاية مصالح غيره.

القدرة على التصرف مع الأمانة: لأن المقصود من الولاية تحقيق مصلحة المولى عليه، وهي لا تتحقق مع العجز وعدم الأمانة.

رعاية مصلحة المولى عليه في التصرفات، لقوله تعالى: ﴿وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ﴾ (٢)، فليس للولي سلطة في مباشرة التصرفات الضارة بالمولى عليه ضرراً محضاً، كالتبرع من مال القاصر بالهبة أو الصدقة، أو البيع أو الشراء بغبن فاحش، أو الطلاق، فإن أمكن تنفيذها على الولي نفسه نفذت وإلا كانت باطلة.

أما التصرفات النافعة نفعاً محضاً كقبول الهبة والوصية والكفالة بالمال، والتصرفات المترددة بين الضرر والنفع كالبيع والشراء بغبن يسير أو بمثل القيمة، فتكون صحيحة نافذة.

(١) مختصر الطحاوى ص ١٦٠، الدر المختار ورد المختار ج ٥ ص ٤٩٥.

(٢) سورة الإسراء، من الآية ٣٤.

إذا أخل الولي بأحد هذه الشروط، جاز للقاضي تبديله بسبب نقص الأهلية أو الكفر أو الفسق، فإن صار الولي غير أمين ضم القاضي إليه مساعداً آخر يعينه (١).

الركن الثالث: محل العقد

يراد بمحل العقد ما وقع عليه التعاقد، فهو الغرض من العقد والمقصود منه، والذي به تتعلق أحكامه وآثاره.

ففي البيع: موضوع العقد هو الشيء المبيع والثمن؛ وفي الرهن هو الشيء المرهون، وفي الإجارة هو منفعة الشيء المستأجر شخصاً أو داراً أو أرضاً مثلاً، وفي الزواج هو المرأة، وهكذا إلى سائر ضروب العقود.

وقد يكون شيء ما صالحاً بطبيعته لأن يكون محل عقد من العقود، ولكن قد يعرض له شرعاً أو قانوناً أو عرفاً ما يجعله غير صالح لأن يكون كذلك، فالخمر مثلاً، صالحة بطبيعتها لأن تكون محلاً للبيع لأنها مال متقوم عند غير المسلمين، إلا أن الشارع الإسلامي منع من ذلك إذ حرم على المسلم تملكها بالبيع وتملكها بالشراء، وأية امرأة، باعتبارها امرأة، صالحة لأن تكون موضوع عقد الزواج، إلا أنها ليست صالحة لذلك لأخيها من النسب أو الرضاع وغيره ممن لا يصح شرعاً تزوج بعضهم ببعض، لذلك، نجد الخمر صالحة لأن تكون موضوع عقد البيع بين الذميين، كما نجد تلك المرأة صالحة لأن تكون زوجة لمن لا تربطها به رابطة من النسب أو الرضاع تجعل الزواج بينهما محرماً تحريماً مؤبداً.

ومن أجل هذا، نرى الفقهاء ورجال التشريع والقانون قد عنوا ببيان الشروط التي يجب توافرها في هذا الشيء أو ذاك، حتى يصلح لأن يكون محل عقد من العقود.

وليس من هدفنا الآن بيان ذلك بالنسبة لكل عقد على حدة، فهذا موضعه عند دراسة كل من العقود المختلفة تفصيلاً، ولكننا الآن بصدد دراسة نظرية الشروط في العقود بصفة عامة، ولهذا لن نتعرض إلا للأصول والشروط العامة التي يجب رعايتها في موضوع العقد أياً كان نوعه.

لذا اشترط الفقهاء أربعة شروط في محل العقد، وهي ما يأتي:

أن يكون موجوداً وقت التعاقد، أو متوقعاً وجوده في المستقبل حتى تحصل الفائدة المرجوة منه، وإذا، فالمعدوم لا يصح أن يكون محلاً للعقد، عند أكثر الفقهاء، ومنهم

(١) د / وهبة الزحيلي: الفقه الإسلامي وأدلته ج٤ ص ٢٩٩٣ - ٢٩٩٤، د / محمد يوسف موسى: الأموال ونظرية العقد ص ٣٢٢ وما بعدها.

الأحناف؛ إذ من غير الممكن أن يتعلق حكم العقد وآثاره بشيء معدوم، ومن ثم نراهم يجعلون صحة عقود السلم (١) والإجارة والاستصناع، ونحوها مستثناة من هذه القاعدة العامة، مادام موضوع كل منها لا يمكن أن يكون موجوداً حال صدور العقد، وإنما أجازها الشارع من باب الاستحسان للحاجة وجريان العرف بها. (٢).

٢ - أن يكون المعقود عليه مشروعاً:

يشترط أن يكون محل العقد قابلاً لحكمه شرعاً، باتفاق الفقهاء، بأن يكون مالا مملوكا متقوماً، فإن لم يكن كذلك، كان العقد عليه باطلاً، فبيع غير المال كالميتة والدم (٣)، أو هبتها أو رهنها أو وقفها أو الوصية بها باطل؛ لأن غير المال لا يقبل التملك أصلاً، وذبيحة الوثني والملحد والمجوسي والمرتد كالميتة (٤).

٣ - أن يكون محل العقد مقدوراً على تسليمه وقت التعاقد:

يشترط باتفاق الفقهاء توافر القدرة على التسليم وقت التعاقد، فلا ينعقد العقد إذا لم يكن العاقد قادراً على تسليم المعقود عليه، وإن كان موجوداً ومملوكاً للعاقد، ويكون العقد باطلاً (٥).

٤ - أن يكون محل العقد معيناً معروفاً للعاقدين:

لابد عند الفقهاء أن يكون محل العقد معلوماً علماً يمنع من النزاع؛ للنهي الوارد في السنة عن بيع الغرر وعن بيع المجهول (٦)، والعلم يتحقق إما بالإشارة إليه إذا كان موجوداً، أو بالرؤية عند العقد أو قبله بوقت لا يحتمل تغييره فيه، ورؤية بعضه كافية إذا كانت أجزأه

(١) هو بيع أجل بعاجل، أي بيع شيء غير موجود بعد بثمن حال، كما يفعل الزارع مع التجار في بيع المحصولات الزراعية قبل وجودها، والاستصناع عقد على عمل الصانع، كما نفعله مع الخياطين والنجارين مثلاً.

(٢) البدائع ج ٤ ص ٣٢٦.

(٣) أجاز الشافعية والحنابلة خلافاً لأبي حنيفة ومالك بيع حليب المرضع للحاجة إليه وتحقيق النفع به.

(٤) د / وهبة الزحيلي: الفقه الإسلامي وأدلته ج ٤ ص ٣٠٢٤، ٣٠٢٥، د / محمد يوسف موسى: الأموال ونظرية العقد: ص ٢٨٥ وما بعدها.

(٥) د / أحمد فرج حسين: الملكية ونظرية العقد ص ٢١٧، د / محيى الدين إسماعيل: نظرية العقد ص ٣٢٤ وما بعدها.

(٦) روى الجماعة عن أبي هريرة: " أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيعه الحصة وعن بيع الغرر " وبيع الحصة: أن يقول: بعثك من هذه الأثواب ما وقعت عليه هذه الحصة، ويرمى الحصة، أو يقول: من هذه الأرض ما انتهت إليه في الرمي، نيل الأوطار ج ٥ ص ١٤٧.

متماثلة، أو بالوصف المانع للجهالة الفاحشة، وذلك ببيان الجنس والنوع والمقدار، كأن يكون المبيع حديداً من الصلب من حجم معين.

فلا يصح التصرف بالمجهول جهالة فاحشة: وهي التي تقضي إلى المنازعة. ويكون العقد فاسداً عند الحنفية، باطلاً عند غير الحنفية، وتغتفر الجهالة اليسيرة، وهي التي لا تؤدي إلى المنازعة ويتسامح الناس فيها عادة (١). وهذا الشرط مطلوب في المعاوضات المالية كالبيع والإيجار باتفاق الفقهاء، أما اشتراطه في غيرها فمحل اختلاف.

فالشافعية والحنابلة يشترطونه في عقود المعاوضات المالية وفي غير المالية كعقد الزواج، وفي عقود التبرعات كالهبة والوصية والوقف (٢). وقصره الحنفية على المعاوضات المالية وغير المالية، ولا يشترطونه في عقود التبرعات كالوصية والكفالة، فيصح التبرع مع جهالة المحل؛ لأن الجهالة فيه لا تؤدي إلى النزاع، كأن يوصى شخص بجزء من ماله، ويكون البيان متروكاً للورثة، وكأن يقول الكفيل: أنا ضامن ما على فلان من مال (٣).

المبحث الرابع :

تصنيف العقود.

العقود أقسام متعددة باعتبارات مختلفة، أهمها النظر إلى العقد بحسب إقرار الشرع له وعدم إقراره، أو بالنظر إلى كون العقود مسماة أو غير مسماة، أو بالنظر إلى غاية العقد وأغراضه، أو لكون العقد عينياً أو غير عينياً، أو باعتبار اتصال الأثر به وعدم اتصاله.

التقسيم الأول – بحسب وصف العقد شرعاً:

ينقسم العقد بحسب الوصف الذي يعطيه الشرع له بناء على مقدار استيفائه لأركانه وشروطه إلى صحيح تترتب عليه آثاره، وغير صحيح لا تترتب عليه آثاره.

العقد الصحيح:

(١) القرافي: الفروق ج ٣ ص ٢٦٥، تهذيب الفروق بهامشه ج ٣ ص ٢٧٠ وما بعدها.

(٢) مغني المحتاج ج ٢ ص ١٦، المهذب ج ١ ص ٢٦٣، ٢٦٦، غاية المنتهى ج ٢ ص ١١، ٣٣٢ وما بعدها، ج ٣ ص ١٨، ٦٠.

(٣) المبسوط ج ١٣ ص ٢٦، ٤٩، الدر المختار ج ٤ ص ٣٠، ١٢٥.

هو الذي استكمل عناصره الأساسية من (صيغة وعاقدين ومحل عقد) وشرائطه الشرعية: فيصبح صالحاً لترتب حكمه وأثاره عليه، ويعرفه الحنفية بقولهم: هو ما كان مشروعاً بأصله ووصفه (١).

وحكم العقد الصحيح: ثبوت أثره في الحال، فالبيع الصادر من كامل الأهلية على مال متقوم شرعاً، ولغاية مشروعة، يترتب عليه ثبوت ملك المبيع والتمن للمشتري والبائع فور انتهاء الإيجاب والقبول إذا لم يكن في البيع خيار.

العقد غير صحيح:

هو ما اختل فيه أحد عناصره الأساسية أو شرط من شروطه، وحكمه: أنه لا يترتب عليه أثر كبيع الميتة والدم والخمر والخنزير، وكبيع فاقد الأهلية، ويشمل غير الصحيح عند جمهور الفقهاء غير الحنفية: الباطل والفساد، وهما بمعنى واحد.

وأما الحنفية: فيقسمون غير الصحيح إلى باطل وفساد. فلكل واحد معنى مختلف عن الآخر، وتلك القسمة محصورة في العقود الناقلة للملكية أو العقود التي توجب التزامات متقابلة من العاقدين، كالبيع والإجارة والهبة والقرض والحوالة والشركة والمزارعة والمساقاة والقسمة. أما العقود غير المالية كالوكالة والوصاية والزواج على الأصح والعقود المالية التي ليس فيها التزامات متقابلة كالإعارة والإيداع، والعبادات، والتصرفات المنفردة كالطلاق والوقف والكفالة والإقرار ونحوها، فهذه لا فرق فيها بين الفاسد والباطل (٢).

فالباطل عند الحنفية: هو ما اختل ركنه أو محله، أو ما لم يشرع بأصله ولا بوصفه، كأن يكون أحد العاقدين فاقد الأهلية، كالمجنون وغير المميز، والمميز فيما يضره ضرراً محضاً، أو أن تكون الصيغة غير سليمة، أو يكون محل العقد غير قابل لحكم العقد شرعاً، كبيع ما ليس بمال، أو ما ليس مائلاً متقوماً كالخمر والخنزير والسّمك في الماء، وكبيع شيء من الأموال العامة كجزء من الطريق أو من مستشفى أو مسجد، وكالبيع الذي جعل الثمن فيه

(١) أصل العقد أي ركنه (الإيجاب والقبول) وعاقده ومحلّه. ووصف العقد: هو ما كان خارجاً عن الركن والمحل

كالشرط المخالف لمقتضى العقد أو كون المبيع غير مقدور التسليم، وكالثمنية فإنها صفة تابعة للعقد

(٢) رد المحتار لابن عابدين ج ٤ ص ١٠٤، بداية المجتهد ج ٢ ص ١٦٦، المستصفي ج ١ ص ٦١، الإحكام

للأمدي ج ١ ص ٦٨، شرح جمع الجوامع للمطلى ج ١ ص ٨٠، المدخل إلى مذهب الإمام أحمد ص ٦٩،

الإبهاج ج ١ ص ٤٤.

غير مال أصلاً كالميتة (١)، أو الشيء المباح. وفي الزواج كالعقد على إحدى المحارم أو التي لم تنته عدتها من مطلقها، أو المتزوجة بزواج آخر، فكل هذه العقود باطلة. وحكم الباطل: أنه لا يعد منعقداً أصلاً، وإن وجدت صورته في الظاهر، فلا يترتب عليه أي أثر شرعي، فلا يفيد نقل الملكية أصلاً؛ إذ لا يعد موجوداً بحال.

وأما العقد الفاسد (٢): فهو ما كان مشروعاً بأصله دون وصفه، أي كان صادراً ممن هو أهل له، والمحل قابل لحكم العقد شرعاً، والصيغة سليمة، ولكن صاحب ذلك وصف منهى عنه شرعاً، كبيع المجهول جهالة فاحشة تؤدي للنزاع، مثل بيع دار من دور أو سيارة من سيارات دون تعيين، وكإبرام صفقتين في صفقة، كبيع دار على أن يبيعه سيارته، وكبيع مال متقوم جعل ثمنه مالاً غير متقوم كخمر مثلاً، وكبيع بقرة على أنها حامل.

وحكم الفاسد: ثبوت الملك فيه بالقبض بإذن المالك صراحة، أو دلالة كأن يقبضه في مجلس العقد أمام البائع، دون أن يعترض عليه.

والعقد الفاسد واجب الفسخ شرعاً، إما من أحد العاقلين أو من القاضي إذا علم بذلك؛ لأنه منهى عنه شرعاً. وإمكان الفسخ مشروط بشرطين:

الأول: بقاء المعقود عليه على ما كان قبل القبض، فلو تغير شكله بأن هلك أو استهلك، أو كان غزلاً فنسجه، أو قمحاً فطحنه، أو دقيقاً فخبزه، امتنع الفسخ.

والثاني: عدم تعلق حق الغير به، فلو تصرف به المشتري لآخر بالبيع أو بالهبة وتم قبضه من الموهوب له، امتنع الفسخ (٣).

أقسام العقد الصحيح:

ينقسم العقد الصحيح عند الحنفية والمالكية إلى نافذ وموقوف:

(١) إذا كان الفساد يرجع للمبيع فالبيع باطل كبيع الخمر والخنزير والميتة والدم، وإن كان الفساد يرجع للثمن: فإن كان الثمن مالاً عند بعض الناس كالخمر والخنزير فالبيع فاسد، وإن كان الثمن ليس مالاً أصلاً كالميتة والدم فالبيع باطل.

(٢) الفساد مرتبة متوسطة بين البطلان والصحة، وليس له نظير في القوانين.

(٣) د / محمد يوسف موسى: الأموال ونظرية العقد ص ٤٠٤ وما بعدها، د / وهبة الزحيلي: الفقه الإسلامي وأدلته ج ٤ ص ٣٠٨٦ وما بعدها، الإمام محمد أبو زهرة: الملكية ونظرية العقد ص ٣٦٩ وما بعدها.

النافذ: هو ما صدر ممن له أهلية وولاية على إصداره، كأغلب عقود الناس مثل العقد الصادر من الرشيد في ماله، أو الولي أو الوصي للقاصر، أو الوكيل لموكله. وحكمه: أنه تترتب عليه آثاره فور صدوره، من غير توقف على إجازة أحد.

والموقوف: هو ما صدر من شخص له أهلية التعاقد، من غير أن يكون له ولاية إصداره. كعقد الفضولي، وعقد الصغير المميز فيما يتردد بين الضرر والنفع، وحكمه: أنه لا تترتب عليه آثاره إلا إذا أجازاه صاحب الشأن الذي يملك إصداره، فإن لم يجزه بطل العقد.

وهذا العقد عند الشافعية والحنابلة باطل.

أنواع العقد النافذ:

ينقسم العقد النافذ إلى لازم وغير لازم:

اللازم: هو ما ليس لأحد عاقديه فسخه دون رضا الآخر، كالبيع والإجارة. والأصل في العقود للزوم؛ لأن الوفاء بالعقود واجب شرعاً لقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ (١).

وثبت صفة للزوم عند الحنفية والمالكية بمجرد صدور العقد من العاقدين وعند الشافعية والحنابلة: لا يلزم العقد إلا بتفرق العاقدين بأبدانهما، أو إذا تخايروا، فاخترارا لزومه، عملاً بحديث خيار المجلس: (البيعان بالخيار إذا لم ينفقا، أو يقول أحدهما للآخر: اختر). وغير اللازم أو الجائز كما يسميه بعض الفقهاء: هو ما يملك كل من طرفيه أو أحدهما فقط فسخه دون رضا الآخر، إما عملاً بطبيعة العقد نفسه كالوكالة والإعارة والإيداع، أو لمصلحة العاقد كالعقد المشتتل على الخيار.

(١) سورة المائدة، من الآية: ١.

والعقود بالنسبة إلى اللزوم وقابلية الفسخ وعدمه أربعة أنواع:

. عقود لازمة لا تقبل الفسخ: كالزواج لا يقبل الفسخ ولو باتفاق العاقدین بطريق الإقالة أى لا يقبل الإلغاء الاتفاقي، وإنما يقبل الإنهاء بطرق شرعية كالطلاق والخلع (١) والتفريق القضائي لعدم الإنفاق أو للعيب أو للضرر وسوء العشرة أو للغيبة أو للحبس والاعتقال ونحو ذلك.

وكل ما لا يقبل الفسخ لا يثبت فيه خيار؛ لأن الخيار يعطى حق الفسخ لصاحبه. . عقود لازمة تقبل الفسخ: أي تقبل الإلغاء بطريق الإقالة أي باتفاق العاقدین، وهي عقود المعاوضات المالية كالبيع والإيجار والصلح والمزارعة والمساقاة ونحوها. وهذه العقود تقبل الفسخ بالخيار أيضاً.

. عقود لازمة لأحد الطرفين: كالرهن والكفالة: فإنهما لازمان بالنسبة إلى الراهن و الكفيل، وغير لازمين بالنسبة للدائن المرتهن، والمكفول له؛ لأن العقد لمصلحتهما الشخصية توثيقاً للحق، فلهما التنازل عنه.

عقود غير لازمة للطرفين: وهي التي يملك كل من العاقدین فيها حق الفسخ والرجوع، كالإيداع والإعارة والوكالة والشركة والمضاربة والوصية والهبة، فالعقود الخمسة الأولى يجوز لكل من العاقدین فسخ العقد متى شاء، والوصية والهبة يصح للموصي والواهب الرجوع عنها، كما يصح للموصي له والموهوب له ردها وإبطالها بعد وفاة الموصي، وفي حال حياة الواهب (٢).

التقسيم الثاني: بالنظر إلى غاية العقد وأغراضه [العقد من ناحية آثاره]

تنقسم العقود بحسب أغراضها وغاياتها إلى مجموعات سبع، فقد تكون غاية العقد هي تمليك شيء، أو الاستيثاق، أو الحفظ، أو التفويض ونحو ذلك.

(١) الطلاق ليس فسخاً للزواج، بل إنهاء له بوضع حد لحكمه وآثاره. والخلع: هو إنهاء الزواج لقاء مال تدفعه الزوجة لزوجها. والطلاق أو الخلع أو التفريق ليست إلغاء للعقد، وإنما هي إنهاء بدليل بقاء حرمة المصاهرة وثبوت النسب بعد الإنهاء، فأم الزوجة مثلاً تبقى محرمة على زوج ابنتها أبداً ولو طلق البنت.

(٢) د / وهبة الزحيلي: الفقه الإسلامي ج ٤ ص ٣٠٩٣ - ٣٠٩٥، د / محمد يوسف موسى: الأموال ونظرية العقد ص ٤١٤، ٤١٥، الإمام محمد أبو زهرة: الملكية ونظرية العقد ص ٣٧٩.

١ - التمليكات: وهي ما يقصد بها تمليك شيء، عين أو منفعة، فإن كان التملك بعوض فهي عقود المعاوضات كالبيع والإجارة، والصرف والصلح، والقسمة، والاستصناع، والمزارعة والمساقاة، والزواج، ونحوها مما فيه معاوضة ومبادلة بين طرفين. وإن كان التملك مجاناً بغير عوض فهي عقود التبرعات، كالهبة والصدقة والوقف والإعارة وحالة الدين.

وقد يكون التبرع في ابتداء العقد كالقرض والكفالة بأمر المدين، والهبة بشرط العوض، ثم يلزم الطرف الآخر بدفع البذل، فهي تبرع ابتداءً، معاوضة انتهاءً.

٢ - الإسقاطات: وهي ما يقصد بها إسقاط حق من الحقوق، سواء ببذل، أم بدون بدل. فإن كان الإسقاط بدون بدل من الطرف الآخر فهو الإسقاط المحض، كالطلاق المجرد عن المال، والعفو عن القصاص، والإبراء عن الدين، والتنازل عن حق الشفعة. وإن كان الإسقاط ببذل أو عوض من الطرف الآخر، فهو إسقاط المعاوضة، كالطلاق على مال، والعفو عن القصاص بالدية.

٣ - الإطلاقات: وهي إطلاق الشخص يد غيره في العمل، كالوكالة وتولية الولاية والقضاء، والإذن للمحجور عليه بالتصرف أو للصغير المميز بالتجارة، والإيصاء: وهو أن يعهد شخص لآخر في أن يتولى شئون أولاده القصر بعد وفاته.

٤ - التقييدات: وهي منع الشخص من التصرف، كعزل الولاية والقضاء، ونظار الوقف، والأوصياء، والقوام على المحجور عليهم، والوكلاء، وحجر الشخص عن التصرف بسبب الجنون أو العته أو السفه أو الصغر.

٥ - التوثيقات: (أو التأمينات أو عقود الضمان): وهي التي يقصد بها ضمان الديون لأصحابها وتأمين الدائن على دينه، وهي الكفالة والحالة والرهن.

٦ - الاشتراك: وهي التي يقصد بها المشاركة في العمل والربح، كعقود الشركات بأنواعها، ومنها المضاربة: وهي أن يدفع شخص لآخر مبلغاً من المال ليتجر فيه على أن يشتركا في الربح، والخسارة على رب العمل، ومنها المزارعة (تعهد الأرض بالعناية) والمساقاة (تعهد الأشجار بالسقي ونحوه).

٧ - **الحفظ:** وهي التي يراد منها حفظ المال لصاحبه، كعقد الإيداع، وبعض خصائص الوكالة (١).

التقسيم الثالث: بالنظر إلى العينية وعدمها:

تنقسم العقود إلى عينية وغير عينية.

فالعقد العيني: هو الذي لا بد فيه لتمام انعقاده وترتيب أثره من تسليم الشيء المعقود عليه عيناً. وهو يشمل عقوداً خمسة: هي الهبة والإعارة والإيداع والرهن والقرض (٢)، فهذه العقود لا بد لتمامها وترتب أثرها عليها من قبض المعقود عليه؛ لأن هذه العقود ما عدا الرهن من التبرعات، والتبرع إحسان، فلا بد له من شيء يؤكد، وهو القبض. وأما الرهن أي الرهن الحيازي فإنه شرع موصوفاً بالقبض في قوله تعالى: ﴿فرهان مقبوضة﴾ (٣) والقبض عند الحنفية: يتم بالتخلية أي بأن يخلى المالك بين المعقود عليه والطرف الآخر، برفع الحائل بينهما، على وجه يتمكن الآخر من الحياة والتصرف في الشيء (٤).

والعقد غير العيني: هو الذي يتم بمجرد الصيغة السليمة من العيوب ويترتب عليه أثره بدون حاجة إلى القبض. وهذا يشمل جميع العقود ما عدا العقود الخمسة السابقة (٥).

التقسيم الرابع - باعتبار اتصال الأثر بالعقد وعدم اتصاله:

ينقسم العقد بحسب ترتب أثره عليه بمجرد انعقاده وعدم ترتب أثره في الحال إلى أنواع ثلاثة: هي منجز، ومضاف، ومعلق.

(١) د / محمد يوسف موسى: الأموال ونظرية العقد ص ٤٣٠ - ٤٣٢. د / وهبة الزحيلي: الفقه الإسلامي ج ٤ ص ٣٠٩٧، ٣٠٩٨.

(٢) يشترط منعا من الوقوع في الربا والاستغلال قبض كل من العوضين في مجلس العقد في مبادلة الأموال الربوية ببعضها (وهي عند الحنفية كل ما يباع كيلا أو وزنا) كبيع النقود ببعضها وهو عقد الصرف، وكبيع الحنطة بالحنطة أو الحنطة بالشعير. ويشترط أيضا قبض الثمن (رأس مال السلم) في عقد السلم: وهو بيع آجل بعاجل كبيع المنتجات الزراعية قبل حصادها في الموسم، وذلك في مجلس العقد ذاته.

(٣) سورة البقرة، من الآية: ٢٨٣.

(٤) البدائع: ٤ / ٣٩٤، وقال المالكية والشافعية: قبض العقار كالأرض والدور يتم بالتخلية، وقبض المنقول كالأمتعة والدواب يتم بحسب العرف الجاري بين الناس (الشرح الكبير للدردير: ٣ / ١٤٥، المجموع: ٩ / ٣٠١ - ٣٠٩، المهذب: ١ / ٢٦٣) وقال الحنابلة: قبض كل شيء بحسبه، ويرجع فيه إلى العرف (المغني: ٤ / ١١١ وما بعدها).

(٥) د / وهبة الزحيلي: الفقه الإسلامي ج ٤ ص ٣٠٩٨، ٣٠٩٩.

١ - العقد المنجز: وهو ما صدر بصيغة غير معلقة على شرط ولا مضافة إلى المستقبل. وحكمه: ترتب الآثار عليه في الحال مادام مستوفياً لأركانه وشروطه المطلوبة فيه. مثل: بعثك هذه الأرض بكذا، وقبل الآخر. يترتب على هذا البيع تحقق أثره عليه في الحال: وهو انتقال الملكية في العوضين.

والأصل في العقود التتجيز في الحال أي أن آثارها تترتب عليها فور إنشائها ما عدا الوصية والإيصاء، فلا يمكن بطبيعتها أن يكون ناجزين، لإضافتهما حتماً لما بعد وفاة الموصي. أما الوصية: فهي تمليك مضاف لما بعد الموت بالتبرع بشئ لجهة أو شخص ما. وأما الإيصاء: فهو إقامة وصى على أبنائه القاصرين بعد وفاة الولي.

٢ - العقد المضاف للمستقبل: ما صدر بصيغة أضيف فيها الإيجاب إلى زمن مستقبل. مثل: آجرتك داري لسنة من مطلع الشهر القادم، أنت طالق غداً أو بعد أسبوع.

وحكمه: أنه ينعقد في الحال، ولكن أثره لا يوجد إلا في الوقت المحدد الذي أضيف إليه.

العقود بالنسبة للإضافة:

العقود عند الحنفية بالنسبة لقبولها للإضافة، أو عدم قبولها لثلاثة أنواع:

الأول: عقود لا تكون إلا مضافة بطبيعتها: وهي الوصية والإيصاء كما تقدم، سواء أكانت منجزة مثل: أوصيت بكذا للفقراء أو لمسجد البلدة، أم معلقة مثل: إن نجحت في المشروع الفلاني فقد أوصيت بمبلغ كذا للمستشفى الفلاني، فإذا تحقق النجاح، لم يثبت حكم الوصية إلا بعد الوفاة.

الثاني: عقود لا تقبل الإضافة، وإنما تكون دائماً ناجزة: وهي عقود تمليكات الأعيان، كالبيع والهبة والصلح على مال والإبراء عن الدين. ويلحق بها الزواج والشركة والقسمة والرجعة؛ لأنها تتطلب شرعاً ثبوت آثارها في الحال، فإذا أضيفت للمستقبل تأخرت آثارها عنها، وذلك ينافي أصل وضعها الشرعي. فالبيع يوجب نقل الملكية في الحال، والزواج يفيد حل الاستمتاع حالاً، فلا يصح تأخير الأثر عنهما.

الثالث: عقود تصح منجزة ومضافة للمستقبل: فإذا كانت منجزة ترتب عليها أثرها في

الحال، وإن كانت مضافة تأخر أثرها إلى زمن الإضافة، وهي (١):

أولاً: العقود الواردة على المنافع: كالإجارة والإعارة والمزارعة والمساقاة.

ثانياً: الالتزامات أو التوثيقات: كالكفالة والحوالة.

(١) تبين الحقائق ج ٤ ص ١٣٤.

ثالثاً: الإطلاقات: كالوكالة والقضاء والوظائف والإدارات والإذن بالتجارة.

رابعاً: الإسقاطات: كالطلاق والخلع من جانب الزوج، والوقف.

٣ - العقد المعلق على شرط: هو ما صدر معلقا وجوده على أمر آخر بأحد أدوات الشرط. مثل: إن سافرت فأنت وكيلي. إذا قدم فلان من الحجاز فقد بعثك الشيء الفلاني. ويختلف المعلق على شرط عن المضاف للمستقبل في أن العقد المعلق لا ينعقد إلا حين وجود الشرط المعلق عليه. أما المضاف للمستقبل فهو منعقد في الحال، ولكن آثاره لا يسرى مفعولها إلا في المستقبل المضاف إليه.

العقود بالنسبة للتعليق عند الحنفية:

تنقسم العقود من هذه الناحية إلى ثلاثة أنواع هي (١):

النوع الأول: عقود لا تقبل التعليق وهي:

أولاً: التملكيات ماعدا الوصية، سواء أكانت واردة على الأعيان كالبيع والإبراء، أم على المنافع كالإجارة والإعارة، بطريق المعاوضة أم بطريق التبرع كالهبة، لا يصح تعليقها على شرط متردد بين الوجود والعدم؛ لأن الملكية لا بد أن تكون مستقرة جازمة لا تردد فيها، وإلا شابها القمار.

ثانياً: المبادلات غير المالية: كالزواج والخلع لا يصح تعليقهما على شرط، مثل: تزوجتك إن نجحت في شهادة كذا، وخالعتك إن رضي أخي؛ لأنه لا بد من تحقق أثرها في الحال.

ثالثاً: التقييدات: كالرجعة وعزل الوكيل والحجر على الصبي المأذون له في التجارة.

رابعاً: الرهن والإقالة (فسخ العقد بالتراضي): لا يصح تعليقهما، مثل: رهنتك هذه الدار إن رضي والدي. أقلتلك من البيع إن وجدت مشترياً بثمن أعلى.

وقد عرفنا سابقاً في بحث حرية الاشتراط أن ابن تيمية وابن القيم من الحنابلة قالوا: يصح تعليق العقود والفسوخ والتبرعات والالتزامات بالشروط ولا يمنع منها إلا ما ورد بالنهاي عنه نص من الشارع.

(١) تبين الحقائق ج ٤ ص ١٣٤، الدر المختار ج ٤ ص ٢٧٧.

النوع الثاني: عقود يصح فيها التعليق بأى شرط ملائم أم غير ملائم وهي:

أولاً: الإسقاطات المحضنة: كالطلاق (١) والتنازل عن حق الشفعة (٢).

ثانياً: الوكالة والوصية والإيصاء (٣).

ثالثاً: الالتزامات التي يراد منها تقوية إرادة الملتزم، كالنذر واليمين، مثل: إن نجحت في الامتحان فله على صوم أسبوع ولأصدقن بمبلغ كذا، ووالله لأفعلن كذا إن انتصرنا على العدو.

النوع الثالث: عقود يصح تعليقها بالشرط الملائم دون سواء، وهي الكفالة والحالة والإذن للصبي بالتجارة.

والشرط الملائم: هو ما كان مناسباً لمقتضى العقد، عرفاً أو شرعاً، بأن يكون أساساً لوجوده، أو سبباً لثبوت الحق، مثل: إن أقرضت فلاناً فأنا كفيله، إن لم أدفع دينك بعد شهر فقد أحلتك به على فلان، إن أحسنت التجارة فقد أذنت لك بها.

أما غير الملائم فمثل: إن نزل المطر فقد كفلت فلاناً، أو أحلتك بدينك على فلان، أو أذنت لك بالتجارة، وإن نجح ابني في شهادة كذا فقد كفلتك، فمثل هذه الشروط غير المفيدة أو التي لا يظهر فيها غرض صحيح تعد نوعاً من العبث أو الهزل واللهو، ولا تصح العقود مع الهزل (٤).

(١) كالطلاق إذا قال الزوج لامرأته إن خرجت متبرجة للسوق فأنت طالق.

(٢) والنزول عن الشفعة لمن يستحقها كما إذا قال إن كان المشتري هو فلان، أو إذا كان الثمن هو كذا. فقد أسقط حقي فيها.

(٣) ومنها الوكالة والوصية والإيصاء. أما الأولى فلأنها بطبيعتها لا تنقيد آثارها وقت صدورها، بل حين مزاولة العمل أنا، فأننا، كالوكيل في الشراء لا يعمل إلا حين يجد السلعة، وفي الدفاع لا يعمل إلا حين ترفع الدعوى. وأما الوصية والإيصاء فلأنهما لا يترتب عليهما آثارهما إلا بعد وفاة الموصى فعلاً، ولهذا لا عبرة برد الموصى له قبل الوفاة أو قبله.

(٤) د / وهبة الزحيلي: الفقه الإسلامي ج ٤ ص ٣٠٩٩ - ٣١٠٣، د / محمد يو

من خلال دراستك لماسبق في الفصل التمهيدي أجب عما يلي:

عرف المال واذكر أقسامه، واذكر فائدة كل تقسيم.

عرف بالعقد في الفقه والقانون.

اذكر شروط الإيجاب والقبول.

ما هو محل العقد؟ واذكر ما يشترط فيه.

اذكر المراد بالعائد واذكر شروطه.

اذكر أقسام العقود باعتبار وصف العقد شرعاً.

اذكر أقسام العقود بالنظر إلى غاية العقد وأغراضه.

اذكر أقسام العقود بالنظر إلى العينية وعدمها.

اذكر أقسام العقود بالنظر إلى اتصال الأثر بالعقد وعدم اتصاله.

عرف المال واذكر أقسامه، واذكر فائدة كل تقسيم.

عرف بالعقد في الفقه والقانون.

اذكر شروط الإيجاب والقبول.

ما هو محل العقد؟ واذكر ما يشترط فيه.

اذكر المراد بالعائد واذكر شروطه.

اذكر أقسام العقود باعتبار وصف العقد شرعاً.

اذكر أقسام العقود بالنظر إلى غاية العقد وأغراضه.

اذكر أقسام العقود بالنظر إلى العينية وعدمها.

اذكر أقسام العقود بالنظر إلى اتصال الأثر بالعقد وعدم اتصاله.

كتبه

أ.د/ هناء فهمي أحمد عيسى. أستاذ ورئيس قسم الفقه بكلية الدراسات الإسلامية

والعربية للبنات بالمنصورة

د/ أحمد محمد السيد المرسي العفيفي. مدرس الفقه بكلية الشريعة والقانون بطنطا

الفصل الثاني

الربا

بسم الله الرحمن الرحيم

المقدمة

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:

فقد بين الحق سبحانه وتعالى في كتابه الكريم للناس، ما يحل لهم وما يحرم عليهم، في سائر أمورهم، حتى يكون المرء على بينة من أمره، فيتعاطى الحلال البين، ويجتنب الحرام البين، ويجتنب كذلك ما كان مشتبهاً لا يدري أحلال هو أم حرام؛ لأنه إن كان في نفس الأمر حراماً، فقد برئ من التبعة، وإن كان حلالاً فقد استحق الأجر على الترك لهذا القصد. يؤيد ذلك ما روي أن النبي ﷺ قال: (إن الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتهيات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب)(١).

قال النووي في هذا الحديث: " أجمع العلماء على عظم وقع هذا الحديث وكثرة فوائده، وأنه أحد الأحاديث التي عليها مدار الإسلام " (٢) .

وقال ابن العربي في عارضته على صحيح الترمذي: " تكلم الناس على هذا الحديث، فمنهم من جعله ثلث الإسلام، ومنهم من جعله رُبعه وأكثروا التقسيمات، ثم قال: والحلال ما

(١) الحديث أخرجه الإمام مسلم في صحيحه عن زكريا عن الشعبي عن النعمان بن بشير تحت رقم ١٠٧-١٥٩٩: ص ٦١٣؛ وانظر صحيح مسلم بشرح النووي. تحقيق عصام الصباطي وحازم محمد وعماد عامر ، ط دار الحديث ؛ كما أخرجه الترمذي في صحيحه عن النعمان بن بشير من طريق آخر بلفظ " الحلال بين ، وبين ذلك أمور مشتهيات لا يدري كثير من الناس أمن الحلال هي أم من الحرام ، فمن تركها استبرأ لعرضه ودينه ، فقد سلم ومن واقع شيئاً منها يوشك أن يواقع الحرام ، كما أنه من يرعى حول الحمى يوشك أن يواقعها ، ألا وإن لكل ملك حمى ، ألا وإن حمى الله محارمه " ، انظر عارضة الأحوذى بشرح صحيح الترمذي ، أبواب البيوع ، باب ما جاء في ترك الشبهات : ص ١٩٩/٥ ، ط دار الكتب العلمية، بيروت لبنان ؛ كما أخرجه الشوكاني : ص ٢٠٨/٥ ، انظر نيل الأوطار ، ط مكتبة دار التراث.

(٢) شرح النووي على صحيح مسلم. المرجع السابق.

أُذِنَ في تعاطيه، والحرام ما منع منه، وأن الحق تبارك وتعالى ببديع حكمته لَمَّا خلق لنا ما في الأرض جميعاً كما أخبرنا، قسم الحال فيه ، فمنه ما أباحه بإطلاق، ومنه ما أباحه بحال دون حال، ومنه ما أباحه على وجه دون وجه، فلذلك تمت هذه النعمة واستقرت بها المنة قال تعالى: ﴿ هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً ﴾، وما فصل سبحانه في القول فصلاً وتمت به الكلمة صدقاً وعدلاً فقد فصله تفصيلاً، وبيّن ما أحل وحرم أما ما اضطررنا إليه فإنه يعود بالضرورة مباحاً بعد أن كان حراماً. وكل شيء تعتريه الأحكام بالحلال والحرام إلا التوحيد، فإنه لا تدخله إحالة ولا ينزل عن درجة الفريضة، ومنزلة الوجوب والختم في حالة، فتبارك الله الصمد الواحد(١) .

واستطرد قائلاً: " فقد بيّن الله سبحانه ما أباح، وبيّن ما حرم في كتابه وعلى لسان نبيه"(٢).

قال النووي وقال العلاء: " وسبب عظم موقعه أنه ﷺ نبه فيه على إصلاح المطعم والمشرب والملبس وغيرها، وإنه ينبغي ترك المشتبهات فإنه سبب لحماية دينه وعرضه حذراً من مواقعة الشبهات "(٣) .

وأما قوله: (الحلال بيّن والحرام بيّن)، فمعناه أن الأشياء ثلاثة أقسام: حلال بيّن واضح لا يخفى حله، كالخبر، والفواكه، والزيت، والعسل، والسمن، ولبن مأكول اللحم وبيضه، وغير ذلك من المأكولات والمطعومات .

وكذلك الكلام والنظر والمشى، وغير ذلك من التصرفات فيها حلال بيّن واضح لا شك في حله.

وأما الحرام البيّن: فالخمر، والخنزي، والميتة، والدم المسفوح، وكذلك الزنا والكذب والغيبة والنميمة، والنظر إلى الأجنبية وأشباه ذلك.

وأما المشتبهات: فمعناها أنها ليست بواضحة الحل ولا الحرمة، فهذا لا يعرفها كثير من الناس ولا يعلمون حكمها(٤).

(١) عارضة الأحوذى بشرح صحيح الترمذي: ٥/١٩٨.

(٢) المرجع السابق: ص ٥/٢٠٠.

(٣) شرح النووي على صحيح مسلم: ص ٦/٣٢.

(٤) المرجع السابق: ص ٦/٣٢.

وإذا كان المسلم مطالب بتجنب المحرم والابتعاد عنه حفظاً لدينه وعرضه، كان عليه أن يتجنب الربا باعتباره من المحرمات بل ومن أعظم المحرمات، وأكبر الكبائر وأفظع الجرائم. ومن المعروف أنه لا يمكن تجنب الشيء إلا بمعرفته، ومعرفته لا تحصل إلا بمعرفة أحكامه، والتي يستطيع المرء من خلال الإلمام بها معرفة ما يحل له وما يحرم عليه، خاصة في عصرنا هذا الذي كثرت فيه المعاملات وتنوعت أشكالها ووسائلها، والتي استبيح بها أكل الحرام من الربا وغيره بسبب عدم معرفة الأحكام.

هذا وإنني لأرجو المولى سبحانه وتعالى التوفيق، إنه نعم المولى ونعم النصير. تنبيه: لما كان موضوع الربا من الموضوعات المهمة لطالب الشريعة، وبخاصة علة الربا وما يتعلق بها، رأيت التوسع في توضيحه، فلم اقتصر فيه على مذهب الحنفية، إنما بينته في المذاهب الأربعة، زيادة في الفائدة، وإمكان الأخذ بما يناسب الحال من الأقوال. والله ولي التوفيق

د. أحمد عبد العليم عبد اللطيف أبوعليو

كلية الشريعة والقانون بأسسيوط

المبحث الأول في تعريف الربا، وحكمه، وأنواعه، والأموال التي يحرم فيها المطلب الأول تعريف الربا

أولاً: في اللغة:

الربا في اللغة الزيادة والنماء، يقال ربا الشيء يربوا ربواً ورباء أي زاد ونما، وأربيته نميته، وفي التنزيل العزيز: ﴿وَيُرِي الصَّدَقَاتِ﴾ (١).

ومنه أخذ الربا الحرام. قال الله تعالى: ﴿وَمَا آتَيْتُمْ مِّن رَّبًّا لِّيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِنْدَ اللَّهِ﴾ (٢).

ويقال: ربا المال إذا زاد وارتفع (٣).

كذلك يقال: أربى الرجل بالألف دخل في الربا، وأربى على الخمسين إذا زاد عليها (٤).

ثانياً: تعريف الربا في اصطلاح الفقهاء

عرفه بعض الحنفية بأنه: فضل مال بلا عوض في معاوضة مال بمال (٥).

وعرفه البعض الآخر منهم بأنه: بيع فيه فضل مستحق لأحد المتعاقدين خال عما يقابله من عوض شرط في هذا العقد (٦).

وعرفه الكاساني، فقال: الربا نوعان: ربا فضل، وربا ونسيئة. أما ربا الفضل: فهو زيادة عين مال شرطت في عقد البيع على المعيار الشرعي، وهو الكيل، أو الوزن في الجنس عندنا، وعند الشافعي: هو زيادة مطلقة في المطعوم خاصة عند اتحاد الجنس خاصة. وأما ربا النساء: فهو فضل الحلول على الأجل، وفضل العين على الدين في المكيلين، أو الموزونين عند اختلاف الجنس، أو في غير المكيلين أو الموزونين عند اتحاد الجنس

(١) سورة البقرة: الآية ٢٧٦.

(٢) سورة الروم: الآية ٣٩.

(٣) لسان العرب للإمام ابن منظور المتوفى ٧١١هـ، ط دار إحياء التراث العربي ومؤسسة التاريخ العربي بيروت لبنان ط/ثانية: ص ١٢٦/٥، مادة ربا.

(٤) المصباح المنير للعلامة أحمد بن محمد بن علي الفيوم المقرئ، ط مكتبة لبنان: ص ٨٣، مادة ربا.

(٥) فتح القدير على الهداية للكمال بن الهمام، ط أولى مصطفى الحلبي بمصر، ١٩٧٠: ص ٧/٣.

(٦) البحر الرائق شرح كنز الدقائق للعلامة زين الدين بن نجيم الحنفي، ط دار المعرفة للطباعة والنشر، بيروت: ص ١٣٤/٦.

عندنا، وعند الشافعي رحمه الله هو فضل الحلول على الأجل في المطعومات والأثمان خاصة.

والناظر في هذه التعريفات يرى: أنها وإن اختلفت في ألفاظها وعبارتها إلا أنها تفيد معنى واحد وهو الزيادة الحقيقية كالتى في ربا الفضل في حالة ما إذا كان البدلان من جنس واحد، كبيع قمح بقمح وأحدهما أزيد من الآخر، أو الزيادة الحكمية التى تكون في حالة بيع متحدي الجنس نساء بزيادة أو بدون زيادة في أحدهما، أو مختلفي الجنس كالذهب بالفضة مع تأخير في تسليم أو قبض أحد البديلين.

وعلى ما تقدم يكون الربا في البيع هو: الزيادة الحقيقية أو الحكمية التى تكون في أحد البديلين عند معاوضة مال مخصوص بمال مخصوص.

هذا هو تعريف الربا في اللغة واصطلاح الفقهاء، وإليك حكمه ودليل الحكم.

المطلب الثاني

حكم الربا وأدلة تحريمه

أولاً : حكم الربا

لا اختلاف بين الفقهاء في أن الربا من المعاملات المحرمة تحريماً قاطعاً، وهو من أكبر الكبائر، وقد ورد تحريمه في الكتاب والسنة والإجماع.

ثانياً: أدلة تحريم الربا

أدلة تحريم الربا من الكتاب

ورد تحريم الربا في كتاب الله تعالى في كثير من الآيات القرآنية منها:

قوله تعالى : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً ﴾ (١).

ومعنى قوله تعالى: ﴿ أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً ﴾ أي أضعاف الحق الذي دفعتم، لأن في الجاهلية كان الواحد منهم إذا حل دينه قال لغريمه: إما أن تعطي أو تربى، فإن أعطاه وإلا أضعف عليه الحق وأضعف له الأجل ، ثم يقول كذلك إذا حل الأجل الآخر، وهكذا حتى يصير الحق أضعافاً مضاعفة ، فحظر الحق تبارك وتعالى ذلك لما فيه من الفساد، ثم أكد سبحانه وتعالى الزجر عليه بقوله: ﴿ وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ ﴾ (٢) .

(١) سورة آل عمران : الآية ١٣٠ .

(٢) سورة آل عمران : الآية ١٣١ .

فأخبر سبحانه وتعالى أن نار أكل الربا كنار الكافر (١) .
قوله تعالى: ﴿ ذَلِكْ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ﴾ (٢).
قال السرخسي في المبسوط بعد ذكر هذه الآية: وقد ذكر الله تعالى لأكل الربا خمساً من العقوبات:

إحداها: التخبُّط:

قال تعالى: ﴿ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ﴾ (٣).

وقيل معناه ينتفخ بطنه يوم القيامة بحيث لا تحمله قدماء وكلما رام القيام يسقط ، فيكون بمنزلة الذي أصابه مس من الشيطان ، فيصير كالمصرع الذي لا يقدر على أن يقوم ، والمراد أن أمره يفتضح على رؤوس الأشهاد (٤).

وقال بعض المفسرين: ﴿ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا ﴾ معناه يتعاملون به بيعاً وشراءً ، وإنما خص الأكل بالذكر ؛ لأنه معظم المقصود (٥).

كما قال تعالى : ﴿ إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا ﴾ (٦).
وقيل معنى قوله تعالى: ﴿ لَا يَقُومُونَ ﴾ أي يوم القيامة من قبورهم ﴿ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ﴾ .

المس عند أهل التفسير الضرب على غير الاستواء ، يقال خبط البعير أي ضرب بإخفاقه، فمعنى ذلك أن الشيطان يصيبه بالجنون حين يقوم من قبره فيبعث مجنوناً فيعرف أهل الموقف أنه من أكلة الربا (٧).

(١) الحاوي ابكير للإمام أبي الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي ، ط دار الكتب العلمية ، بيروت لبنان : ص ٥٧٣ .

(٢) سورة البقرة : الآية ٢٧٥ .

(٣) سورة البقرة : الآية ٢٧٥ .

(٤) المبسوط للإمام السرخسي المتوفى سنة ٤٩٠ هـ ، ط دار الكتب العلمية ، بيروت لبنان : ص ١٢/١٠٩ .

(٥) المجموع شرح المذهب للإمام أبي زكريا محي الدين بن شرف النووي ، ط مكتبة الإرشاد ، جدة - المملكة العربية السعودية : ص ٩/٤٨٦ .

(٦) سورة النساء : الآية ١٠ .

(٧) تفسير القرطبي المسمى بالجامع لأحكام القرآن لشمي الدين أبي عبد الله محمد بن أحمد القرطبي ، ط دار الغد الغربي .

والثاني: المحق:

قال الله تعالى: ﴿يَمَحَقُ اللَّهُ الرِّبَا﴾ (١).

والمراد بالمحق الهلاك والاستئصال، وقيل ذهاب البركة والاستمتاع حتى لا ينتفع هو به

ولا ولده بعده (٢).

والثالث: الحرب:

قال الله تعالى: ﴿فَأُذِّنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ﴾ (٣).

والمعنى بالقراءة بالمد هو: أعلموا الناس أكلة الربا إنكم حرب الله ورسوله بمنزلة قطاع

الطريق .

والمعنى من القراءة بالقصر: اعلموا أن أكلة الربا حرب الله ورسوله (٤).

والرابع: الكفر:

قال الله تعالى: ﴿وَدَرُّوْا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُّؤْمِنِينَ﴾ (٥).

والمعنى يعني إذا أسلموا كان عليهم أن يتركوا ما لم يقبضوه، وأما ما قبضوه قبل الإسلام

لم يلزمهم أن يردوه (٦).

وقال الله تعالى: ﴿وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ﴾ (٧) أي كفار باستحلال الربا أثيم فاجر

يأكل الربا (٨).

والخامس: الخلود في النار:

قال الله تعالى: ﴿وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾ (٩).

وكما ترى فإن الآيات قد قضت بالتحريم وقرنت به أشد العقوبات. ففي الآية الأولى نص

على تحريم الربا إذا كان أضعافاً مضاعفة.

وفي الآية الثانية جاء التحريم قاطعاً.

(١) سورة البقرة : الآية ٢٧٦ .

(٢) المبسوط : ٩/١٠٩ ؛ البحر الرائق : ٦/١٣٧ .

(٣) سورة البقرة : الآية ٢٧٩ .

(٤) المبسوط : ٩/١٠٩ ؛ البحر الرائق : ٦/١٣٧ .

(٥) سورة البقرة : الآية ٢٧٨ .

(٦) الحاوي للماوردي : ص ٥/٧٤ .

(٧) سورة البقرة : الآية ٢٧٦ .

(٨) المبسوط : ٩/١١٠ ؛ البحر الرائق : ٦/١٣٧ .

(٩) سورة البقرة : الآية ٢٧٥ .

وفي الآية الثالثة ذكر التخبط، وهو عقوبة من عقوبات الربا.
وفي الآية الرابعة يتوعد الحق تبارك وتعالى أكل الربا بمحق ماله.
وفي الآية السادسة يصف المولى تبارك وتعالى أكل الربا بالكفر.
وفي الآية السابعة يتوعد الحق تبارك وتعالى أكل الربا بالخلود في النار.
وما كانت تلك العقوبات بهذه الأوصاف إلا لبشاعة الربا وفضاعته وشدة حرمة، وغلظ قلب آكله وضعف إيمان موكله . ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم .

أدلة تحريم الربا من السنة

وردت أخبار كثيرة عن رسول الله ﷺ في شأن تحريم الربا أذكر منها:
ما روي أن النبي ﷺ قال: (أكل درهم واحد من الربا أشد من ثلاث وثلاثين زنية يزنيها الرجل من بنت لحمه من حرام فالنار أولى به) (١).
ما روي عن عبد الله بن حنظلة غسيل الملائكة ، قال قال رسول الله ﷺ : (درهم ربا يأكله الرجل وهو يعلم أشد من ست وثلاثين زنية) (٢) .
ما روي عن ابن مسعود ؓ أن النبي ﷺ قال: (اجتنبوا السبع الموبقات قيل يا رسول الله ما هي قال الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل

مال اليتيم ، والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات) (٣) .
ما روي عن ابن مسعود ؓ أن النبي ﷺ (لعن أكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه ") (١)
وفي رواية للنسائي : (أكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه إذا علموا ذلك ملعونون على لسان محمد ﷺ يوم القيامة) (٢) .

(١) الحديث أخرجه صاحب كنز العمال بلفظ " درهم من الربا كبضع وثلاثين زنية " وذكره صاحب مجمع الزوائد بلفظه ، وقال فيه هو ضعيف ، انظر كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال لعلاء الدين المتقي بن حسان الدين الهندي البرهان فوري ، ط مؤسسة الرسالة : ص ١٩٣/٤ برقم ١٠١١٤ ؛ وانظر مجمع الزوائد للهيثمي : ٤/١٢٠ ، ط مؤسسة المعارف ، بيروت لبنان .

(٢) الحديث أخرجه الدارقطني في سننه عن عبد الله بن حنظلة ، وفي رواية أخرى من نفس الطريق عن كعب قال : " لأن أزني ثلاثة وثلاثين زنية أحب إلي من أن أكل درهما من ربا يعلم الله تعالى أنني أكلته أو أخذته وهو ربا " ، وقال فيه صاحب التعليق : وهذا أصح من المرفوع ، وقال صاحب مجمع الزوائد رواه أحمد في المسند ، ورجال أحمد رجال الصحيح ، مجمع الزوائد : ص ٤/١٢٠ .

(٣) الحديث أخرجه مسلم في باب بيان أكبر الكبائر برقم ١٤٥-٨٩ : ص ١/٣٥٩ ، مسلم بشرح النووي .

وكما ترى فإن الحديثين الأول والثاني يدلان على فظاعة ارتكاب الربا فهو أشد من ارتكاب جريمة الزنا، ولهذا يقول الشوكاني: وهو يدل على أن معصية الربا من أشد المعاصي؛ لأن المعصية التي تعدل معصية الزنا التي هي غاية الفظاعة والشناعة بمقدار العدد المذكور بل أشد منها، لا شك أنها قد تجاوزت الحد في القبح، وأقبح منها استطالة الرجل في عرض أخيه المسلم، ولهذا جعلها الشرع أرى الربا (٣) .

وفي الحديث الثالث: عد رسول الله ﷺ الربا من أعظم الكبائر ، وما كان ذلك إلا لعظيم خطره، وكبير ضرره .

وفي الحديث الرابع: دلالة على تحريم الربا بقوله: أكل الربا وموكله، وسمى آخذ المال آكلاً ودافعه موكلًا؛ لأن المقصود منه الأكل وهو أعظم منافعه وسببه إتلاف أكثر الأشياء. وقوله شاهديه وكاتبه: فيه دلالة على تحريم كتابة الربا إذا علم ذلك ، وكذلك الشاهد تحرم عليه الشهادة مع العلم فإما من كتب أو شهد غير عالم فلا يدخل في الوعيد (٤). هذه هي أدلة تحريم الربا من السنة، وهي كما ترى تبين مدى فظاعة وبشاعة هذه الجريمة التي تعد من أعظم الجرائم .

(١) الحديث أخرجه الترمذي في صحيحه في أبواب البيوع باب ما جاء في أكل الربا عن ابن مسعود ، وقال فيه الترمذي حديث حسن صحيح ، انظر عارضة الأحوزي بشرح صحيح الترمذي : ص ٢٠٧/٥ ، ط دار الكتب العملية ، بيروت لبنان .

(٢) الحديث ذكره صاحب مجمع الزوائد ، وقال رواه أحمد وأبو يعلى والطبراني في الكبير ، وقال فيه الحارث الأعور وهو ضعيف وقد وثقه ، مجمع الزوائد : ٤/١٢١ .

(٣) نيل الأوطار للشوكاني : ص ١٩٠/٥ .

(٤) المرجع السابق .

دليل الإجماع على تحريم الربا

لبشاعة هذه الجريمة وفضاعتها وعظم خطرها وما يترتب عليها من مفساد ومضار تعصف بالفرد والمجتمع بأسره، أجمع المسلمون من عهد النبي ﷺ إلى يومنا هذا على تحريم الربا وجعلوه من الكبائر، وقيل إنه كان محرماً في جميع الشرائع السماوية (١) .

وكما ترى فإن تحريم الربا لا مرأ فيه ولا جدال، ومن ثم فمن يتعامل به بعد ما سبق من أدلة التحريم يكون قد ارتكب كبيرة من الكبائر مستحقاً لغضب الله تعالى وللعقوبات التي سبق ذكرها، والله هو الهادي إلى سواء السبيل وهو حسبنا ونعم الوكيل.

المبحث الثاني

أنواع الربا

اتفق الفقهاء على أن الربا يوجد في شيئين في البيع ، وفيما تقرر في الذمة من بيع أو سلف أو غير ذلك.

المطلب الأول: في أنواع الربا فيما تقرر في الذمة.

المطلب الثاني: في أنواع الربا في البيع .

المطلب الأول

الربا فيما تقرر في الذمة

الربا فيما تقرر في الذمة صنفان:

الأول: متفق على تحريمه، وصورته أن يكون للرجل دين على آخر فإذا حل الأجل قال له: أنظرني أزدك في دينك، وهذا النوع كان الناس يتعاملون به في الجاهلية حيث كانوا يسلفون بالزيادة وينظرون، فكانوا يقولون: أنظرني أزدك في دينك .

وقال ابن حجر كان الواحد من أهل الجاهلية يدفع ماله لغيره إلى أجل على أن يأخذ منه كل شهر قدرًا معيناً ورأس المال باق بحاله، فإذا حل طالبه برأس ماله فإن تعذر عليه الأداء زاد في الحق والأجل (٢) .

وهذا النوع من الربا مشهور بين الناس وواقع كثيراً وهو ربا النسيئة، وسمي نسيئة مع أنه يصدق عليه ربا الفضل أيضاً؛ لأن النسيئة هو المقصود فيه بالذات .

(١) المجموع شرح المذهب : ٩/٤٨٧ ؛ المغني لابن قدامة : ص ٦/٥٢ .

(٢) بداية المجتهد ونهاية المقتصد لمحمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن رشد ، تحقيق رضوان جامع رضوان ، نشر دار الحرم للتراث سوق الكتاب الجديد بالدراسة : ص ٢/١٥٥ ؛ حاشية الرهوني : ص ٥/٩٢ .

وقد نهى عنه رسول الله ﷺ في حجة الوداع بقوله : (ألا وإن ربا الجاهلية موضوع وأول ربا أضعه ربا عباس بن عبد المطلب) (١) .

والثاني : مختلف في تحريمه ، وصورته أن يكون لرجل على آخر دين ، وقبل حلول الأجل يقول المدين : ضع عني بعض الدين وأعجل لك دينك .

وقد أجاز هذا النوع ابن عباس من الصحابة والإمام زفر من فقهاء الأمصار ، ومنعه كثير من الصحابة كابن عمر وغيره ، ومنعه أبو حنيفة ، ومالك والثوري ، وكثير من فقهاء الأمصار .

مع أن من منعه أجاز أن يتعجل الرجل في دينه المؤجل عرضاً يأخذه ، وإن كانت قيمة ذلك العرض أقل من الدين .

ووجه من لم يجز هذا النوع : هو أن هذا النوع شبيه النوع الأول من جهة الزيادة مع النظرة المجمع على تحريمها ، ووجه الشبه بينهما : أنه جعل للزمان مقداراً من المال بدلاً منه في الصورتين جميعاً ؛ وذلك لأنه في الصورة الأولى لما زاد له في الزمان زاد له في مقابله مالا ، وفي الصورة الثانية لما حط عنه من الزمان حط عنه في مقاله مالا (٢) .

ووجه من أجاز هذا النوع الثاني : ما وري عن ابن عباس : أن النبي ﷺ لما أمر بإخراج بني النضير جاءه ناس منهم فقالوا يا نبي الله إنك أمرت بإخراجنا ولنا على الناس ديون لم تحل ، فقال رسول الله ﷺ : (ضعوا وتعجلوا) (٣) .

المطلب الثاني : الربا في البيع أنواع الربا في البيع

الربا في البيع على ضربين :

الأول : ربا الفضل : وهو زيادة في أحد البديلين المتحدي الجنس كبيع درهم بدرهمين ، أو صاع بصاعين نقداً .

(١) الحديث أخرجه الإمام مسلم في صحيحه تحت رقم ١٤٧ ، ١٢١٨ : ص ٤٣٢ ؛ صحيح مسلم بشرح النووي .

(٢) بداية المجتهد : ص ١٧٣/٢ .

(٣) الحديث أخرجه الدارقطني في سننه عن ابن عباس بلفظه ، وقال فيه هو مضطرب في إسناده مسلم بن خالد وهو سيء الحفظ ، انظر سنن الدارقطني : ص ٤٦/٣ ، ط دار المحاسن ؛ كما أخرجه صاحب السنن الكبرى : ص ٢٨/٦ ، السنن الكبرى للبيهقي ، وقال في مجمع الزوائد مسلم بن خالد ثقة إلا أنه سيء الحفظ ، وقد اضطرب في هذا الحديث ، مجمع الزوائد : ٤/١٣٠ .

والثاني: ربا النساء: وهو التأخير في قبض أحد بدلي العقد في أموال الربا.

والنوع الثاني وهو ربا النسيئة قد أجمعت الأمة على تحريمه.

أما النوع الأول وهو ربا الفضل، فجمهور الصحابة وكافة الفقهاء متفقون على تحريمه كتحريم النساء، لكن نقل عن بعض الصحابة القول بإباحته وهؤلاء هم : عبد الله بن عباس، وعبد الله بن الزبير، وأسامة بن زيد ، وزيد بن أرقم والبراء ابن عازب (١).

أما ابن عباس فقد روي عن أبي صالح الزيات أنه قال : سمعت أبا سعيد الخدري رضي الله عنه يقول: (الدينار بالدينار والدرهم بالدرهم)، فقلت له إن ابن عباس لا يقوله ، فقال أبو سعيد سألته فقلت شيئاً سمعته من النبي ﷺ أو وجدته في كتاب الله تعالى، فقال كل ذلك لا أقول، وأنتم أعلم برسول الله ﷺ مني، ولكن أخبرني أسامة بن زيد أن النبي ﷺ قال: (لا ربا إلا في النسيئة)(٢) .

وأما عبد الله بن الزبير، فقال السبكي في المجموع: لم أقف على إسناد إليه بذلك ، وإنما حكى عنه ، وممن حكوه الشيخ أبو حامد الماوردي، وأبو محمد المقدسي الحنبلي(٣).
وأما البراء بن عازب ، وزيد بن أرقم ، فقد روي عمرو بن دينار عن أبي المنهال قال : باع شريك لي دراهم بدراهم بالكوفة وبينهما فضل، فقلت ما أراه يصلح، فقال لقد بعتها في السوق فما عاب علي ذلك أحد، فأتيت البراء بن عازب فسألته فقال: قدم رسول الله ﷺ المدينة وتجارنتا كذا، فقال النبي ﷺ : (ما كان يداً بيد فلا بأس به وما كان نسيئة فلا خير فيه)، وأتيت زيد بن أرقم فإنه كان أعظم تجارة منا ، فسألته فقال لي مثل ذلك(٤) .

(١) الحاوي للماوردي : ٥/٧٦ ؛ حاشية الرهوني : ص ٥/٩٢ ؛ المغني : ٦/٥٢ ؛ البحر الرائق : ٦/١٣٧ .

(٢) الحديث أخرجه الإمام مسلم في صحيحه عن أبي صالح عن أبي سعيد بلفظ " الربا في النسيئة " وفي رواية " إنما الربا في النسيئة " ، وفي رواية " إلا إنما الربا في النسيئة " ، صحيح مسلم بشرح النووي : ص ٦/٢٧ تحت رقم ١٠١/١٥٦٩ ، ١٠٢ ، ١٠٣ ، ١٠٤ ، وأخرجه الإمام البخاري في صحيحه بلفظ " لا ربا إلا في النسيئة " ، صحيح البخاري بحاشية السندي : ص ٢/٢١ باب بيع الدينار بالدينار ، طبعة مكتبة زهران .

(٣) المجموع لنقي الدين علي بن عبد الكافي السبكي ، ط مكتبة الإرشاد ، جدة - المملكة العربية السعودية : ص ١٠/٣ وما بعدها .

(٤) الحديث أخرجه البخاري في كتاب الشركة ٥/١٥٩ - ٢٤٩٧ ، ٢٤٩٨ ، كما أخرجه مسلم في صحيحه تحت رقم ٨٦ - ١٥٨٩ : ص ٦/١٩ ، مسلم بشرح النووي .

وأما أسامة بن زيد، فقال السبكي: لا أعلم في ذلك شيئاً عنه إلا روايته عن النبي ﷺ: (إنما الربا في النسيئة) (١) .

هذا ما نقل عن بعض الصحابة الذين قالوا بحل التفاضل (٢).

أدلة من قالوا بحل ربا الفضل

الذين قالوا بحل التفاضل تعلقوا بخبرين: الأول : ما رواه أسامة رضي الله عنه أن النبي ﷺ قال: إنما الربا في النسيئة (وقد سبق ذكره .

والثاني: (وقد سبق ذكره أيضاً) وهو ما رواه عمرو بن دينار عن أبي المنهال، قال: باع شريك لي دراهم بدراهم بالكوفة وبينهما فضل، فقلت ما أراه يصلح، فقال لقد بعته في السوق فما عاب علي ذلك أحد، فأتيت البراء بن عازب فسألته فقال قدم رسول الله ﷺ المدينة وتجارنتا كذا، فقال النبي ﷺ : (ما كان يداً بيد فلا بأس به وما كان نسيئة فلا خير فيه)، وأتيت زيد بن أرقم فإنه كان أعظم تجارة منا ، فسألته فقال لي مثل ذلك (٣). وقد أجيب عن هذين الخبرين بالآتي.

الأول: الجواب عما استدلل به ابن عباس ومن وافقه:

يجاب عما استدلل به ابن عباس ومن وافقه بالآتي:

إن قول النبي ﷺ: (إنما الربا في النسيئة) جواب من النبي ﷺ لسائل سألته عن التفاضل في جنسين مختلفين فقال: إنما الربا في النسيئة، فنقل أسامة جواب النبي ﷺ وأغفل سؤال السائل

إن الحديث محمول على الجنس الواحد حيث يجوز عند التماثل فيه نقداً، ولا يجوز نسيئة (٤)

إن الحديث يحمل على غير الربويات، كبيع الدين بالدين مؤجلاً ، وذلك بأن يكون له عنده نقد موصوف فيبيعه بعرض موصوف مؤجلاً.

إن هذا الحديث قد أجمع المسلمون على ترك العمل بظاهره وهذا يدل على نسخه.

(١) المجموع شرح المذهب للسبكي : ١٠/٣٠ .

(٢) الحاوي الماوردي : ٥/٧٦ .

(٣) الحديث أخرجه البخاري في كتاب الشركة ٥/١٥٩ - ٢٤٩٧ ، ٢٤٩٨ ، كما أخرجه مسلم في صحيحه تحت رقم

٨٦ - ١٥٨٩ : ص ٦/١٩ ، مسلم بشرح النووي .

(٤) الحاوي الماوردي : ٥/٧٧ .

إن حديث أسامة مجمل والأحاديث المحرمة مبينة، فوجب العمل بالمبين وتنزيل المجمل عليه (١).

وقيل المراد بقوله ﷺ : لا ربا، أي الربا الأغلظ الشديد التحريم المتوعد عليه بالعقاب الشديد، كما تقول العرب لا عالم في البلد إلا زيد، مع أن فيها علماء غيره، والقصد نفى الأكمل لا نفى الأصل.

إن مفهوم حديث أسامة عام ، لأنه يدل على نفى ربا الفضل عن كل شيء، سواء كان من الأجناس المذكورة في أحاديث الباب أم لا ، فهو أعم منها مطلقاً فيخصص هذا المفهوم بمنطوقها (٢) .

هذا بالنسبة لحديث أسامة ، أما حديث البراء فيجواب عنه بالآتي :

إن هذا الحديث منسوخ ، لأنه مروى قبل تحريم الربا (٣) .

إن هذا الحديث معلول فيمتنع الحكم بصحته ، وذلك لأن لفظه عن أبي المنهال، قال : سألت البراء بن عازب وزيد بن أرقم عن الصرف فقالا : كنا تاجرين على عهد رسول الله ﷺ فسألنا رسول الله ﷺ عن الصرف فقال : إن كان يداً بيد فلا بأس به ، وإن كان نساء فلا يصلح . وعلى هذا فلا حجة لمتعلق به؛ لأنه يمكن حمله على أمرين :

الأول : إما أن يكون المراد بيع دراهم بشيء ليس ربوياً ويكون الفساد لأجل التأخير بالمواسم أو الحج فإنه غير محرم ، ولا سيما على ما كانت العرب تفعل.

الثاني: أن يحمل ذلك على اختلاف الجنس وبديل له رواية أخرى عن أبي المنهال قال: سألت البراء بن عازب وزيد بن أرقم عن الصرف فكلاهما يقول: نهى رسول الله ﷺ عن بيع الذهب بالورق ديناً، فهو يبين أن المراد صرف الجنس بجنس آخر (٤) .

هذا ما يتعلق بأدلة ابن عباس ومن وافقه ، وهي لا تخلو من نسخ أو تأويل أو احتمال، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على ضعف التعلق بها ، الأمر الذي يجعل هذا القول ضعيفاً ولا يعتد به في مقابلة من قال بالحرم.

(١) شرح النووي على صحيح مسلم ، ط دار الحديث ، القاهرة : ص ٦/٣٠ .

(٢) نيل الأوطار للشوكاني : ١٩١ ، ٥/١٩٢ .

(٣) الحاوي للماوردي : ص ٥/٧٧ .

(٤) المجموع شرح المذهب : ١٠/٥٦ .

ومما يقوي قول من قال بالحرمة ويجعل القول به إجماعاً، ما ثبت من رجوع قول من قال بالحل، وإليك ما ورد فيه من أقوال وآثار.

أولاً : ما ثبت من رجوع ابن عباس ومن وافقه من القول بحل التفاضل.

وردت آثار تدل على رجوع ابن عباس ومن وافقه من القول بحل التفاضل ، أذكر منها :
ما روي عن حبان بن عبيد الله العدوي قال : (سألت أبا مجلز عن الصرف فقال : كان ابن عباس لا يرى به بأساً زماناً من عمره ما كان منه عيناً " يعني يداً بيد ، وكان يقول : إنما الربا في النسيئة ، فلقية أبو سعيد الخدري فقال له : يا ابن عباس إلا تتقي الله ، إلى متى تؤكل الناس الربا ، أما بلغك أن رسول الله ﷺ قال ذات يوم وهو عند زوجته أم سلمة : (إني لاشتهي تمر عجوة ، فبعثت صاعين تمر إلى رجل من الأنصار، فجاءت بدل صاعين صاعاً من تمر عجوة، فقامت فقدمته إلى رسول الله ﷺ ، فلما رآه أعجبه فتناول تمره ، ثم أمسط فقال : من أين لكم هذا ؟ فقالت أم سلمة : بعثت صاعين من تمر إلى رجل من الأنصار فأتى بدل صاعين هذا الصاع الواحد، وها هو كل ، فألقى التمر بين يديه وقال : ردوه لا حاجة لي فيه ، التمر بالتمر ، والحنطة بالحنطة ، والشعير بالشعير ، والذهب بالذهب ، والفضة بالفضة ، يداً بيد ، عيناً بعين ، مثلاً بمثل، فمن زاد فهو ربا. فقال ابن عباس : جزاك الله يا أبا سعيد الجنة فإنك ذكرتني أمراً كنت نسيته، أستغفر الله وأتوب إليه، فكان ينهي عنه بعد ذلك أشد النهي (١) .

ما روي عن أبي الشعثاء قال : (سمعت ابن عباس يقول : اللهم أني أتوب إليك من الصرف ، إنما هذا من رأيي ، وهذا أبو سعيد الخدري يرويه عن النبي ﷺ (٢) .
ما روي عن عطية العوفي قال : قال أبو سعيد الخدري لابن عباس : تب إلى الله تعالى ، فقال : استغفر الله وأتوب إليه ، قال : (ألم تعلم إن رسول الله ﷺ نهى عن الذهب بالذهب ، والفضة بالفضة ، وقال : إني أخاف عليكم الربا) (٣) .

(١) الحديث أخرجه الحاكم في المستدرک ، وقال هذا حديث صحيح الإسناد ، انظر المستدرک على الصحيحين لأبي عبد الله الحاكم النيسابوري : ص ٢/٤٣ ؛ كما أخرجه البيهقي في سننه في كتاب البيوع ، باب جريان الربا في كل ما يكال أو يوزن ، سنن البيهقي : ص ٥/٢٨٦ ، ط دار المعرفة ، بيروت لبنان .

(٢) الحديث أخرجه الطبراني في الكبير تحت رقم ٤٥٤ ، ٤٥٧ : ص ١/١٧٧ باب البيان في نسخ ذلك ورجوع ابن عباس عن الصرف ونهيه ﷺ . انظر المعجم الكبير للحافظ أبي القاسم سليمان بن أحمد الطبراني ، تحقيق حمدي عبد المجيد السلفي ، ط انية.

(٣) الحديث أخرجه الطبراني في الكبير تحت رقم ٤٥٨ : ص ١/١٧٧ .

وغير ذلك روايات كثيرة ، تدل على رجوع ابن عباس ، لا يتسع المقام لذكرها .
هذا بالنسبة لما ثبت من رجوع ابن عباس ، وأما بالنسبة لأسماء بن زيد ، فكما سبق لا يعلم في نسبة القول إليه سوى روايته عن النبي ﷺ : (إنما الربا في النسيئة) ، وهذا لا يكفي في نسبة القول إليه ، فإنه لا يلزم من الرواية القول بحفظ ظواهرها لجواز أن يكون معناها عنده على خلاف ذلك أو يون عنده معارض راجح (١) .

وأما عبد الله بن الزبير ، والبراء بن عازب ، وزيد بن أرقم فلم ينقل عنهم سوى ما روي عنهم ، وقد سبق الجواب عنه ، والله أعلى وأعلم .

دعوى الإجماع في هذه المسألة وانقراض الخلاف فيها
جاء في المجموع للسبكي إن ابن المنذر قال : أجمع علماء الأمصار مالك ابن أنس ومن تبعه من أهل المدينة ، وسفيان الثوري ومن وافقه من أهل العراق ، والأوزاعي ومن قال بقوله من أهل الشام ، والليث بن سعد ومن وافقه من أهل مصر والشافعي وأصحابه ، وأحمد وإسحاق وأبو ثور ، والنعمان ويعقوب ، ومحمد بن الحسن على أنه لا يجوز بيع ذهب بذهب ، ولا فضة بفضة ، ولا بُر بْبُر ، ولا شعير بشعير ، ولا تمر بتمر ، ولا ملح بملح متفاضلاً ، يداً بيد ولا نسيئة ، وأن من فعل ذلك فقد أربى ، والبيع مفسوخ ، قال : وقد روينا هذا القول عن جماعة من أصحاب رسول الله ﷺ يكثر عددهم (٢) .
وعلى هذا وما تقدم يكون ربا الفضل محرم بالاتفاق .

أدلة القائلين بتحريم ربا الفضل

ما سبق هو أدلة استدلت بها البعض على إباحة ربا الفضل ، وتبين ضعف تمسكهم بها ، وهنا أذكر الأدلة التي تمسك بها الذين قالوا بالتحريم ، والتي تدل صراحة على تحريم التفاضل ، وهي كثيرة أذكر منها :

ما روي عن عبادة بن الصامت ؓ أنه قال : سمعت رسول الله ﷺ يقول : (الذهب بالذهب ، والفضة بالفضة ، والبُر بالبُر ، والشعير بالشعير ، والتمر بالتمر ، والملح بالملح ،

(١) المجموع للسبكي : ص ١٠/٣٠ .

(٢) المجموع للسبكي : ص ١٠/٣٨ .

مثلاً بمثل ، سواء بسواء ، يداً بيد ، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يداً بيد (١) .

ما روي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال : قال رسول الله ﷺ : (الذهب بالذهب ، والفضة بالفضة ، والبر بالبر ، والشعير بالشعير ، والتمر بالتمر ، والملح بالملح ، مثلاً بمثل ، يداً بيد ، فمن زاد أو استزاد فقد أربى الآخذ والمعطي فيه سواء) (٢) .

ما روي عن أبي هريرة قال : قال رسول الله ﷺ : (التمر بالتمر ، والحنطة بالحنطة ، والشعير بالشعير ، والملح بالملح ، مثلاً بمثل ، يداً بيد ، فمن زاد أو استزاد فقد أربى إلا ما اختلفت ألوانه) (٣) .

ما روي عن مالك بن أوس أنه سمع عمر بن الخطاب يقول : قال رسول الله ﷺ : (الذهب بالذهب ربا إلا هاء وهاء ، والورق بالورق ربا إلا هاء وهاء ، والشعير بالشعير ربا إلا هاء وهاء ، والتمر بالتمر ربا إلا هاء وهاء) (٤) .

ما روي عن مالك أبي بكر رضي الله عنه أنه قال : سمعت النبي ﷺ يقول : (الذهب بالذهب وزناً بوزن ، والفضة بالفضة وزناً بوزن ، والزائد والمستزاد في النار) (٥) .

ما روي عن عثمان بن عفان رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قال : (لا تبيعوا الدينار بالدينارين ولا الدرهم بالدرهمين) (١) .

(١) الحديث أخرجه مسلم في صحيحه عن أبي الأشعث عن عبادة بن الصامت تحت رقم ٨١ ، باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقداً ، صحيح مسلم بشرح النووي : ص ٦/١٦ .

(٢) الحديث أخرجه مسلم في صحيحه تحت رقم ٨٣-١٥٨٨/١٥٨٤ عن أبي زرعة عن أبي هريرة ، صحيح مسلم بشرح النووي : ص ٦/١٧ .

(٣) الحديث أخرجه مسلم في صحيحه عن أبي المتوكل الناجي عن أبي سعيد تحت رقم ٨٢/١٥٨٤ ، صحيح مسلم بشرح النووي : ص ٦/١٧ ، ١٦ .

(٤) الحديث أخرجه الإمام البخاري في صحيحه ، باب بيع الشعير بالشعير تحت رقم ٢١٧٤ ، انظر فتح الباري بشرح صحيح البخاري لابن حجر العسقلاني ، ط مكتبة الكليات الأزهرية : ص ٩/٢٤١ ؛ وأخرجه مالك في الموطأ تحت رقم ٨١٧ : ص ٢٦٣ عن مالك بن أوس ؛ وأخرجه الترمذي باب ما جاء في الصرف ، وقال فيه حديث حسن صحيح ، عارضة الأحوذ بشرح صحيح الترمذي : ص ٥/٢٥٢ .

(٥) الحديث أخرجه الإمام البخاري ابن أبي شيبة في مصنفه عن أبي رافع عن أبي بكر تحت رقم ٢٢٤٩٤ ، مصنف ابن أبي شيبة في الأحاديث والآثار للحافظ أبي بكر عبد الله بن محمد بن أبي شيبة الكوفي العباسي : ص ٢/٥٠٠ ، ط دار الكتب العلمية ، بيروت لبنان .

ما روي عن علي بن أبي طالب عليه السلام قال : قال رسول الله ﷺ : (الدينار بالدينار ،
والدرهم بالدرهم لا فضل بينهما من كانت له حاجة بذهب فليصرفها بورق الصرف هاء وهاء
(٢) هذه هي أدلة تحريم الربا بنوعيه ، وكما ترى فهي صريحة في التحريم ، كما أنها مروية
عن كبار الصحابة رضوان الله عليهم ، فليس هناك مجال لمخالفة هذه الروايات ، كما أنها
تقطع الطريق على من يدعي حل ربا الفض في أي عصر من العصور . والله تعالى أعلم .

المبحث الثالث

الأموال التي يحرم فيها الربا

تقدمت رواية الصحابي الجليل عبادة بن الصامت رضي الله عنه ، ورواية أبو سعيد الخدري رضي الله عنه ، عن
رسول الله ﷺ ، والتي ذكرا فيها الذهب والفضة والبُر والشعير والتمر والملح ، فقد جمعت كلتا
الروايتين ستة أصناف اتفق الفقهاء على اعتبارها أموال الربا ، وأنه يحرم فيها التفاضل
والنساء قولاً واحداً بلا خلاف .

فهل هذه الأصناف الستة التي تعتبر الأصل في أموال الربا يقتصر تحريم الربا عليها ، أم
أن هناك أصنافاً أخرى لم تذكر في الحديث تأخذ حكم هذه الأصناف الستة ، ومن ثم يحرم
فيها التفاضل والنساء كالأصناف الستة ؟ .

وبعبارة أخرى هل الأصناف الستة التي وردت في الحديث ، وردت على سبيل الحصر
بمعنى أنها فقط التي يحرم فيها الربا بطريق الفضل والنساء ولا يحرم في غيرها ، أم أن ذكرها
ورد في الحديث على سبيل التمثيل أو التنبيه ، ومن ثم يقاس عليها غيرها مما يجتمع معها
في علة التحريم ؟ . هذا ما سيتضح من التفصيل الآتي .

(١) الحديث أخرجه صاحب كنز العمال عن عثمان بن عفان رضي الله عنه ، بلفظه ، انظر كنز العمال ، حديث رقم ٩٧٩٥ :
ص ٤/١١١ .

(٢) الحديث أخرجه الدارقطني في سننه عن عمر بن محمد عن أبيه عن جده عن علي رضي الله عنه ، انظر سنن الدارقطني :
ص ٣/٢٥ .

المطلب الأول

حكم الربا في الأصناف الستة المنصوص عليها

لا خلاف بين الفقهاء في ثبوت الربا في هذه الأصناف الستة الوارد ذكرها في الحديث (١) ، ومن ثم يحرم بيع بعضها ببعض متفاضلاً ونسيئة ، فيحرم بيع الذهب بالذهب متفاضلاً ونسيئة ، وكذلك الفضة، والبُر، والشعير، والتمر، والملح، وفي حالة اختلاف الجنس كذهب بفضة ، أو قمح بتمر أو ملح، فإنه يجوز البيع متفاضلاً ولا يجوز نسيئة.

المطلب الثاني

حكم الربا في غير الأصناف الستة

اختلف العلماء في ثبوت الربا في غير الأصناف الستة التي ورد ذكرها في الحديث على قولين:

الأول : وهو مروي عن عثمان البتي، وطاووس ، وقتادة ، ومسروق ، والشعبي ، وداود الظاهري، ونفاة القياس ، حيث ذهبوا إلى القول بقصر حكم الربا على الأصناف الستة ، وإن ما عدا هذه الأصناف الستة باق على أصل الإباحة ، فهو من باب الخاص الذي أريد به الخاص.

القول الثاني: وهو لجمهور الفقهاء والقائلين بالقياس، ويرون ثبوت الربا في الأصناف الستة المنصوص عليها وفي غيرها، وإن حكم الربا ليس مقصوراً على الأصناف الستة ، بل وإن فيها معنى يتعدى به الحكم إلى غيرها من الأموال، فهو من باب الخاص الذي أريد به العام (٢) .

سبب الاختلاف

يمكن رد سبب الاختلاف بين جمهور الفقهاء ومخالفهم في تعدية الحكم المنصوص عليه في الأصناف الستة الواردة في الحديث إلى غيرها، وعدم تعديه ، إلى أمور منها:

الأول : أن أهل الظاهر ومن وافقهم لا يقولون بالقياس، فهم ينفون القياس ولا يثبتون به الأحكام، فهو ليس بحجة عندهم.

(١) البدائع للكاساني : ص ٢٧٢/٥ ؛ حاشية الدسوقي على الشرح الكبير : ص ٤٤/٤ وما بعدها ؛ المجموع للنووي :

ص ٤٨٩/٩ وما بعدها ؛ المغني لابن قدامة : ٥٤ ، ٦/٥٥ وما بعدها ؛ المحلي لابن حزم الظاهري : ص ٤٦٧/٨ ، ط دار الآفاق الجديدة ، بيروت .

(٢) المبسوط للسرخسي : ١٢/١١٢ ؛ بداية المجتهد : ٢/١٥٧ ؛ الحاوي للماوردي : ٥/٨١ ؛ ؛ المغني لابن قدامة :

٦/٥٤ ؛ شرح النووي على صحيح مسلم : ص ٦/١٣ ؛ المجموع : ص ٤٨٩/٩ .

وأما جمهور الفقهاء فهم يقولون بالقياس، وهو حجة عندهم لتعدية الحكم الثابت بالنص.

الثاني: أن عثمان البتي وإن كان يقول بالقياس ويعتبره حجة، إلا أن من أصله أنه لا يجوز القياس على الأصول إلا أن يقوم دليل في كل أصل على جواز القياس، ولم يقد ذلك الدليل في رواية أموال الربا.

أما عند جمهور الفقهاء فإن القياس على الأصول جائز، إلا أن يقوم دليل يمنع من القياس على كل أصل (١) .

الأدلة على قصر حكم الربا على الأصناف الستة

الأدلة على قصر حكم الربا على الأصناف الواردة في الحديث، أو تعديه إلى غيرها عند الفقهاء.

أولاً : أدلة أصحاب القول الأول الذين يرون قصر تحريم الربا على المنصوص عليه وهو الأصناف الستة:

استدل أصحاب هذا القول بالكتاب وهو قوله تعالى: ﴿ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ ﴾ .

وجه الدلالة من الآية

إن الآية تدل على أن الأصل هو حل البيع ولا يحرم إلا بدليل، ولا دليل فيبقى على الأصل، ولا يجوز تخطي التحريم إلى ما سوى هذه الأصناف تمسكاً بالنص، ونفيًا للقياس وإطراحاً للمعاني.

ثانياً: أدلة أصحاب القول الثاني، وهم جمهور الفقهاء

استدلوا أصحاب هذا القول بأدلة من الكتاب والسنة :

أما الكتاب فقوله تعالى : ﴿ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ﴾ .

وجه الدلالة : إن الربا في اللغة والشرع اسم للزيادة والفضل:

أما اللغة : فكقولهم ربا السويق إذا زاد، وقد أرى علي في الكلام إذا زاد علي في السب،

وهذه ربوة من الأرض إذا زادت على ما جاورها.

(١) المراجع السابقة .

وأما الشرع : فكقوله تعالى: ﴿ يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُزِيلُ الصَّدَقَاتِ ﴾ (١) أي يضاعف ويزيد فيها ، وقوله تعالى: ﴿ فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ وَأَنْبَتَتْ ﴾ (٢) أي زادت ونمت .

وإذا كان الربا ما ذكر اسماً للزيادة لغة وشرعاً، دل عموم الآية على تحريم الفضل والزيادة إلا ما خص بدليل (٣) .

وأما السنة : فهي ما روي أن النبي ﷺ (نهى عن بيع الطعام بالطعام إلا مثلاً بمثل) (٤) .

وجه الدلالة من الحديث

أن الطعام اسم لكل مطعوم من بُر وغيره في اللغة والشرع .
أما اللغة : فكقول الشخص: طعمت الشيء أطعمه ، وأطعمت فلانا كذا إذا كان الشيء مطعوماً وإن لم يكن بُراً .

وأما الشرع : فلقوله تعالى: ﴿ كُلُّ الطَّعَامِ كَانَ حِلاًّ لِّبَنِي إِسْرَائِيلَ ﴾ (٥) .

وجه الدلالة : أن الآية تدل على أن المراد بالطعام كل مطعوم .
وما روي أن عائشة رضي الله عنها قالت : (عشنا دهنراً وما لنا طعام إلا الأسودان التمر والماء) (٦) .

وجه الدلالة : أنها رضي الله عنها أطلقت اسم الطعام على التمر والماء؛ لأن كل منهما اسم لما يطعم (٧) .

(١) سورة البقرة : الآية ٢٧٦ .

(٢) سورة الحج : الآية ٥ .

(٣) الحاوي للماوردي : ٥/٨١ ؛ المغني : ٦/٥٤ .

(٤) الحديث أخرجه الإمام مسلم في صحيحه ٩٣-١٥٩٢ : ص ٦/٢٣ ، صحيح مسلم بشرح النووي ؛ كما أخرجه البيهقي في سننه : ص ٥/٢٨٣ .

(٥) سورة آل عمران : الآية ٩٣ .

(٦) الحديث أخرجه مسلم في كتاب الزهد بلفظ " إنا كنا آل محمد ﷺ لنمكث شهراً ما نستوقد بنار إن هو إلا التمر والماء ، صحيح مسلم بشرح النووي رقم ٢٩٧٢/٢٦ ، ص ٩/٣٢٩ .

(٧) الحاوي للماوردي : ص ٥/٨٢ .

وإذا كان اسم الطعام بما وصفنا من شواهد اللغة والشرع يتناول كل مطعوم من بُر أو غيره، كان نهيه ﷺ عن بيع الطعام محمولاً على عمومه في كل مطعوم إلا ما خُص بدليل (١) .

حجية القياس : ثبت أن القياس حجة عند جمهور الفقهاء بالأدلة الدالة عليه ، وإذا ثبت كونه حجة فإن الربا يتجاوز المنصوص عليه إلى ما كان في معناه (٢) . وعلى ما تقدم من أقوال الفقهاء وأدلتهم ، يتبين أن تحريم الربا ليس مقصوراً على الأصناف الستة المنصوص عليها، وإنما يتعداها إلى غيرها مما يجتمع معها في معنى العلة ، والله تعالى أعلم.

هذا ورغم اتفاق جمهور الفقهاء على تحريم الربا في الأصناف الستة وغيرها مما يجتمع معها في علة التحريم ، إلا أنهم قد اختلفوا في المعنى الذي يتعدى به حكم هذه الأصناف الستة إلى غيرها ، مما يستدعي بيان هذه العلة عند جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة .

المبحث الرابع في علة الربا عند القائلين بها

ذكرت أن جمهور الفقهاء قد اتفقوا على أن الأصناف الستة الواردة في الحديث معللة بعلة ، إلا أنهم اختلفوا في معنى هذه العلة ، وهي في ربا الفضل تختلف عنها في ربا النساء، وفي الأصناف الأربعة تختلف عنها في الذهب والفضة. والذي يعيننا هنا هو قول الحنفية.

وقبل أن أوضح المراد بالعلة عند جمهور الفقهاء، أود أن أبين معنى العلة عند علماء الأصول ، والفرق بينها وبين الحكمة ، وعليه فأتناول الكلام في هذا الفصل في مبحثين :

(١) المرجع السابق .

(٢) الحاوي للماوردي : ص ٨٢/ ٥ ؛ المبسوط للسرخسي : ص ١١٢/ ١٢ .

المطلب الأول
في تعريف العلة والفرق بينها وبين الحكمة
الفرع الأول
في تعريف العلة

أولاً : تعريف العلة في اللغة

العلة في اللغة هي المرض، وحدث يشغل صاحبه عن وجهه كأن تلك العلة صارت شغلاً ثانياً منعه عن شغله الأول ، واعتل أي مرض فهو عليل ، ولا أهلك أي لا أصابك بعلة ، واعتل عليه بعلة ، واعتله اعتافه عن أمر تجنى عليه ، وعلله بالشيء تعليلاً أي لهاه به كما يعلل للصبي بشيء من الطعام يجتزأ به عن اللبن .

والعلة الضرة ، وبنو العلات بنو رجل واحد من أمهات شتى ، والعلة موضوع العذر، وفي المثل لا تعدم خرقاء علة ، يقال هذا لكل معتل ومعتذر وهو يقدر .

ثانياً : تعريف العلة في اصطلاح علماء الأصول

للعلة تعريفات كثيرة عند علماء الأصول ، فعرفها الحنفية بأنها : الوصف المعروف للحكم ، وقيل الوصف المؤثر في الحكم ، وقيل هي الباعث على الحكم لا على سبيل الإيجاب (١) .

وعرفها غير الحنفية بأنها : الوصف الظاهر المنضبط الذي يلزم من ترتيب الحكم على وفقه، حصول ما يصلح أن يكون مقصوداً من شرع ذلك الحكم ، سواء كان ذلك الحكم نفيّاً أو إثباتاً ، وسواء كان ذلك المقصود جلب مصلحة أو دفع مفسدة (٢) ، وقيل هي الوصف المعروف للحكم (٣) .

وعلى هذا فالعلة هي الوصف الجامع أو المعنى الجامع بين حكم الأصل والفرع (٤) .

(١) مختار الصحاح للإمام محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي ، ط مكتبة لبنان : ص ١٨٩ مادة علل ؛ لسان العرب لابن منظور ، مادة علل : ص ٣٦٥ وما بعدها .

(٢) التوضيح على التنقيح لصدر الشريعة ، ط دار الكتب العلمية ، بيروت لبنان : ص ٢/١٣٢ وما بعدها ، وهو مطبوع مع شرح التلويح على التوضيح .

(٣) شرح مختصر ابن الحاجب لقطب الدين محمود بن مسعود الشيرازي ، رسالة ماجستير ، تحقيق الباحث عبد النعيم محمود : ص ٥٧

(٤) شرح مختصر ابن الحاجب ، المرجع السابق : ص ٥٥ .

والتعريف المختار عند أكثر علماء الأصول هو أن العلة وصف ظاهر منضبط مناسب
لتشريع الحكم (١).

شرح التعريف

ولما كان التعريف الأخير هو الذي عليه غالبية علماء الأصول ، كان من الضروري
اعتباره للتعريف المختار، ومن ثم يتعين التعرض لشرحه .

فقولهم (الوصف) أي المعنى ويطلق في مقابلة الذات ، و (الظاهر) أي المعلوم
الذي يمكن إدراكه في المحل الذي ورد فيه من غير خفاء، و (المنضبط) أي المحدد الذي
لا يختلف باختلاف الأفراد بل ينطبق عليهم جميعاً، و (مناسب لتشريع الحكم) يعني أن
هذا الوصف هو المناسب لتشريع الحكم .

فمثلاً القتل العدوان هو وصف ظاهر منضبط مشتمل على إزهاق الروح البريئة ، إذاً
فإزهاق الروح يكون معنى مناسباً لتشريع الحكم ، وهو القصاص من الجاني بإزهاق روحه
كذلك صيانة للأرواح .

كذلك السفر وصف ظاهر منضبط مشتمل على المشقة ، والمشقة معنى يناسب تشريع
الحكم وقصر الصلاة الرباعية ، وإباحة الفطر في رمضان ، وغير ذلك من الأحكام الخاصة
بالسفر (٢) .

ثالثاً : تعريف الحكمة

الحكمة هي المصلحة التي يراد تحقيقها بتشريع الحكم، سواء أكان ذلك عن طريق دفع
المفاسد عن العباد ، أم كان عن طريق جلب مصالحهم لهم (٣) .

الفرع الثاني

في الفرق بين العلة والحكمة

وبعد أن عرفنا تعريف العلة والحكمة ، يمكن القول بأن هناك فارقاً بينهما يتمثل في
الآتي :

(١) انظر أصول الفقه للأستاذ الدكتور عبدالرحمن محمد عبد القادر : ص ٣٣٦ ، مطبعة الليثي بأسبوط .

(٢) انظر المرجع السابق .

(٣) انظر المرجع السابق .

أن العلة هي الوصف المشتمل على المعنى المناسب لتشريع الحكم المحقق للحكمة، وذلك كالإسكار بالنسبة للخمر. فالإسكار وصف مشتمل على ذهاب العقل، وهذا معنى لتحريم الخمر، والعقاب على شربه .

إما الحكمة في هذا المثال فهي تتمثل في: صيانة العقول وحفظها ، الأمر الذي يترتب عليه دفع العداوة وترك البغضاء والصد عن ذكر الله . إذاً فالحكمة هي الفائدة أو الغرض الذي يجنيه المجتمع من خلال تطبيق الأحكام الشرعية .

أن العلة لا بد وأن تكون ظاهرة منضبطة لا تختلف باختلاف الأحوال والأشخاص والأوقات، بخلاف الحكمة التي قد تكون خفية غير ظاهرة، وفي بعض الأحوال غير منضبطة ، ولذلك اختلف العلماء في جواز ربط الحكم بالحكمة من تشريعه.

فجمهور الأصوليين يرون: عدم جواز تعليل الأحكام بالحكمة من تشريعها مطلقاً، أي سواء كانت هذه الحكمة ظاهرة أم خفية، وسواء كانت منضبطة أم غير منضبطة؛ وذلك لأنه يغلب في الحكمة الخفاء وعدم الانضباط والعبرة بالغالب، والنادر لا يعتد به.

مثال ذلك: البيع شرع لحكمة وهي تلبية احتياجات الناس، والحاجة غير ظاهرة، ومضطربة بحسب أحوال الناس .

أن الحكم مرتبط بالعلة، وقد اتفق العلماء على لزوم ارتباط الحكم بعلة، بحيث يوجد الحكم بوجود العلة ، ومن ثم قالوا: إن الحكم يدور مع علته وجوداً وعدمًا (١)، وهذا بخلاف الحكمة. والله أعلم .

المطلب الثاني **في علة الربا عند الفقهاء**

نظرا لحاجة الطالب إلى الإحاطة بموضوع العلة لأهميته في فهم الكثير من احكام المعاملات، رأيت أن اتوسع في بيان العلة من المذاهب الأربعة، هذا وقد ذكرت فيما سبق أن العلة تختلف في ربا الفضل عنها في ربا النساء، وهي في الذهب والفضة تختلف عنها في الأصناف الأربعة، وبيان ذلك على النحو التالي:

الفرع الأول: في علة ربا الفضل

علة ربا الفضل في الذهب والفضة تختلف عنها في الأصناف الأربعة، ومن ثم فسوف أبدأ بالكلام عن العلة في الذهب والفضة، ثم أتלוه بالكلام عن العلة في الأصناف الأربعة.

(١) المرجع السابق .

وقبل أن أبين هذا أود أن أذكر الأصل الذي استتبط الفقهاء منه علة الربا، وهذا الأصل هو الحديث الذي رواه الصحابييان عبادة بن الصامت، وأبو سعيد الخدري رضي الله عنهما، والذي ذكرنا فيه أن النبي ﷺ قال: (الحنطة بالحنطة مثلاً بمثل يداً بيد والفضل ربا، والتمر بالتمر مثلاً بمثل يداً بيد والفضل ربا، والملح بالملح مثلاً بمثل يداً بيد والفضل ربا، والذهب بالذهب مثلاً بمثل يداً بيد والفضل ربا)(١).

هذا هو الأصل الذي استتبط الفقهاء منه علة الربا، وهذا الحديث قال فيه العلماء: إن حد شهرته وصل إلى أن بعض العلماء ظنّ أنه متواتر، وليس كذلك؛ لأنه لا يصدق عليه حد التواتر، وقال البعض أنه يقرب من المتواتر؛ لكثرة روايته، وهو مروي عن ستة عشر صحابياً هم: عمر، وعبادة بن الصامت، وأبو سعيد الخدري، وسارية بن أبي سفيان وبلال، وأبو هريرة، ومعمر بن عبد الله، وأبو بكر، وعثمان، وهشام بن عامر، والبراء بن عازب، وزيد بن أرقم، وخالد بن أبي عبيد، وأبو بكرة، وابن عمر، وأبوه الدرداء، رضي الله عنهم أجمعين(٢).

هذا ما يتعلق بهذا الأصل، وإليك بيان أقوال الفقهاء في علة ربا الفضل.

علة ربا الفضل عند الحنفية

يرى الحنفية: أن علة ربا الفضل في الأشياء الأربعة المذكورة في الحديث (البر، والشعير، والتمر، والملح) هي: الكيل مع الجنس، وفي الذهب والفضة هي الوزن مع الجنس(٣)، ومن ثم فلا يتحقق الربا إلا باجتماع هذين الوصفين: الكيل والجنس في المكيل، والوزن والجنس في الموزون(٤).

وعلى هذا يجري الربا في كل ما يكال أو يوزن إذا بيع بجنسه متفاضلاً عند الحنفية، فلا يجوز بيع الذرة إلا مثلاً بمثل، وكذا الأرز والعدس، وغير ذلك مما يكال قياساً على: القمح،

(١) الحديث سبق تخريجه عن عبادة بن الصامت، ورواية عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنهما: ص ٢٩.

(٢) البحر الرائق شرح كنز الدقائق: ٦/١٣٨؛ نيل الأوطار للشوكاني.

(٣) بدائع الصنائع للكاظمي: ص ٥/٢٧٢؛ فتح القدير والعناية على الهداية: ص ٤، ٥/٧؛ البحر الرائق شرح كنز الدقائق: ٦/١٣٨.

(٤) فلو باع مكيلاً كالقمح بقمح آخر، فقد وجد الكيل ووجد الجنس وهو أن كلا من القمحين من جنس واحد، وهكذا الموزونات.

والشعير، والتمر، كذلك لا يجوز بيع الحديد بالحديد، والأسمنت بالأسمنت، والجبس بالجبس، وغيرهما من الموزونات إلا مثلاً بمثل باعتبارهما موزونات.

دليل الحنفية

استدل الحنفية على أن علة ربا الفضل هي الكيل مع الجنس في المكيلات، والوزن مع الجنس في الموزونات، بالسنة والمعقول.

أما السنة فمنها:

ما روي عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه، أن النبي ﷺ قال: (الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلاً بمثل، سواء بسواء، يداً بيد، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يداً بيد) (١).

ما روي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قال: (الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلاً بمثل، يداً بيد، فمن زاد أو استزاد فقد أربى، الآخذ والمعطي فيه سواء) (٢).

ما روي عن أبي سعيد أيضاً أن النبي ﷺ قال: (لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلاً بمثل، ولا تشفوا (٣) بعضها على بعض، ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلاً بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا منها غائباً بناجز) (٤).

أوجه الدلالة من الأحاديث:

أن الجنسية عرفت بقوله ﷺ: (الذهب بالذهب، والحنطة بالحنطة). والقدر (أي الكيل أو الوزن) عرف بقوله ﷺ: (مثلاً بمثل).

كما أن الأحاديث رويت بالنصب "مثلاً بمثل"، ورويت بالرفع "مثل بمثل". وعلى رواية النصب يكون المعنى "بيعوا الحنطة بالحنطة، مثلاً بمثل، يداً بيد". وعلى رواية الرفع يكون المعنى المراد: أن بيع الحنطة بالحنطة مثل بمثل يداً بيد جائز. فالأحاديث لا بد فيها من إضمار لفظ: بيعوا، حيث انتصب مثلاً.

(١) الحديث سبق تخريجه ص ١٧.

(٢) الحديث سبق تخريجه ص ١٧.

(٣) الشف يكون للزيادة والنقصان، أي لا تزيدوا في أحدهما على الآخر، لسان العرب، مادة شف.

(٤) الحديث أخرجه الإمام مالك في الموطأ في كتاب الصرف وأبواب الريا عن أبي سعيد الخدري: ص ٢٦٣ برقم ٨١٥، موطأ مالك برواية محمد بن الحسن، ط المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، وزارة الأوقاف، القاهرة.

وعلى هذا تكون الأحاديث قد أوجبت التماثل شرطاً للبيع بقوله: " مثلاً بمثل " فيكون المقصود من سوق الأحاديث إيجاب المماثلة (١) .

وأما المعقول: فوجهه:

أن الفضل على المعيار الشرعي من الكيل والوزن في الجنس، إنما كان رباً في المطعومات والأثمان من الأشياء الستة المنصوص عليها، لكونه فضل مال خال عن العوض يمكن التحرز عنه في عقد المعاوضة، وهذا المعنى قد وجد في الجص والحديد ونحوهما، فورود الشرع ثمة يكون ورداً ههنا دلالة، وبيان ذلك:

أن البيع في اللغة والشرع مبادلة المال بالمال، وهذا يقتضي التساوي في البديلين على وجه لا يخلو كل جزء من البديل من هذا الجانب عن البديل من ذلك الجانب؛ لأن هذه هي حقيقة المبادلة، ولهذا لا يملك الأب والوصي بيع مال اليتيم بغبن فاحش، ولا يصح من المريض إلا من التلث.

أن القفيز (٢) من الحنطة مثل القفيز من الحنطة صورة ومعنى، وكذلك الدينار مع الدينار، أما الصورة فلأنهما متماثلان في القدر، وأما المعنى فلأن المجانسة في الأموال عبارة عن تقارب المالية، فكان القفيز مثلاً للقفيز والدينار مثلاً للدينار، ولهذا لو أتلّف على آخر قفيزاً من حنطة يلزمه قفيز مثله ولا يلزمه قيمته.

وإذا كان القفيز من الحنطة مثل القفيز من الحنطة، كان القفيز الزائد فضل مال خال عن العوض يمكن التحرز عنه في عقد المعاوضة فكان ربا، وهذا المعنى يوجد في كل مكيل بجنسه وموزون بجنسه (٣) .

هذا ما استدل به فقهاء الحنفية على أن علة ربا الفضل هي الكيل أو الوزن مع الجنس.

(١) بدائع الصنائع للكاساني : ص ٢٧٤/٥ .

(٢) القفيز : مكيال وهو ثمانية مكايك ، والمكوك صاع ونصف الصاع ، المغرب في ترتيب المعرب للمطرزي : ص ٤٢٥ ، ط دار الكتب العربي ، بيروت لبنان ؛ مختار الصحاح : ص ٢٢٨ .

(٣) بدائع الصنائع للكاساني : ص ٢٧٤/٥ .

المراد بالمماثلة عند الحنفية

يرى الحنفية: أن المراد بالمماثلة، المماثلة من حيث: الكيل في المكيل والوزن في الموزون، فيكون المراد ما يدخل تحت الكيل والوزن ، لا ما ينطبق عليه اسم الحنطة والذهب.

ما يترتب على معنى المماثلة

يترتب على معنى المماثلة السابق ذكره، أنه لو باع شخص حبات من حنطة بحبات أكثر منها، فإنه يجوز؛ لأن لا يعد بيعاً؛ لأن الحبات لا تدخل تحت الكيل، وكذا لو باع ذرة من ذهب بذرة أكبر منها، لأنها لا تدخل تحت الوزن .

ولأن الحبة والذرة ليست بمال متقوم ، فعلم من هذا أن المراد الحنطة التي هي مال متقوم، ولا تعلم ماليتها إلا بالكيل ، فصارت صفة الكيل ثابتة بمقتضى النص، وكذلك الذرة من الذهب لا تعرف ماليتها إلا بالوزن، فصارت صفة الوزن ثابتة بمقتضى النص، فكان النبي ﷺ قال: (يبيعوا الذهب الموزون بالذهب الموزون، والحنطة المكيلة بالحنطة المكيلة).

ما يخرج من المماثلة

يخرج عن المماثلة المذكورة، المماثلة من حيث الوصف، حيث لا يعتبر التفاوت في الوصف؛ لأنه لا يعد تفاوتاً عرفاً، فإن استوت الذاتان صورة ومعنى تساويا في المالية ، والفضل من حيث الجودة ساقط الاعتبار.

دليل عدم اعتبار الوصف في أموال الربا

ما روي أن النبي ﷺ قال: (جيدها ورديئها سواء) (١)؛ ولأن الناس يعدون ذلك من باب اليسير؛ ولأن في اعتباره سد باب البياعات في الربويات (٢) .

ويترتب على اعتبار المماثلة من حيث الكيل أو الوزن في المكيل والموزون ، وعدم اعتبار الوصف، أن بيع ما لا يدخل تحت الكيل أو الوزن متفاضلاً جائز، وذلك كبيع تفاحة

(١) الحديث أخرجه الزيلعي في نصب الراية عن أبي سعيد الخدري ؓ ، وقال فيه أنه غريب ومعناه يؤخذ من إطلاق حديث أبي سعيد الخدري ؓ . انظر نصب الراية لأحاديث الهداية للعلامة جمال الدين أبي محمد عبد الله بن يوسف الحنفي الزيلعي المتوفى سنة ٧٦٢ : ص ٣٤٤ ، ط سلسلة مطبوعات المجلس العلمي بداهيل سورت الهند ، ومطبعة دار المأمون بشبرا شارع الأزهر ، رقم ١ .

(٢) فتح القدير ، والعناية على الهداية : ص ٧/٨ وما بعدها .

بتفاحتين، وحفنة من القمح بحفنتين ، وذلك لعدم وجود المعيار المعروف للمساواة، فلا يتحقق الفضل ، ولهذا كان مضموناً عند الإلتلاف بالقيمة لا بالمثل (١) .

ومعنى هذا أن المحل الذي لا يقبل المماثلة لا يكون مال الربا أصلاً ، والحفنة ، والتفاحة ، لا تقبل المماثلة بالاتفاق فلم يكن مال الربا، والدليل على هذا أن النبي ﷺ ما نص على حكم الربا إلا مقروناً بالمخلص، وكل علة توجب الحكم في محل لا يقبل المخلص أصلاً فهي علة باطلة (٢) .

وكذلك بيع الجيد بالرديء لا يجوز إلا متساوياً، وذلك كبيع ذهب جديد بقديم، وذهب مصوغ بهذب خام، وكبيع فضة قديمة بجديدة، وفضة مصوغة بفضة خام. لما سبق من دليل.

هذه هي علة ربا الفضل عند الحنفية، وإليك ما ورد عليها من مناقشات.

مناقشات علة الحنفية

ناقش فقهاء الشافعية ما ذهب إليه الحنفية من اعتبارهم علة منع التفاضل هي الكيل مع الجنس أو الوزن مع الجنس بالآتي :

أن النبي ﷺ لو أراد الكيل ، أو الوزن بمجرد لاكتفى بالنص على واحد منها إذ الكيل متساو في جميعها (٣) .

الجواب : أن هذا يرجع عليكم في القوت، لأن الأربعة مقتاتة كما تقولون، ولو أراد المقتات لاكتفى بذكر أحدها، وكذلك يرجع عليكم في الطعم لأن الأصناف الأربعة كلها مأكولة أو مطعومة، ولو أراد الطعم أو الأكل لاكتفى بذكر أحدها (٤) .

أن التفاضل يحرم عندنا في قليل المنصوص عليه وكثيره، وعندكم لا يحرم إلا فيما يتأتى كيله، فيجوز عندكم الكف من الحنطة بالكفين والعموم يمنعه (٥) .

(١) المرجع السابق .

(٢) المبسوط للسرخسي : ص ١١٧/ ١٢ .

(٣) المعونة للقاضي عبد الوهاب : ص ٦/ ٢ .

(٤) هذا المعنى في الحاوي بتصرف : ص ٨٧/ ٥ .

(٥) المعونة : ص ٧/ ٢ ؛ الحاوي : ص ٨٨/ ٥ .

الجواب: أن النبي ﷺ قال: (الحنطة بالحنطة، مثلاً بمثل) فقد أوجب المماثلة لجواز العقد، ثم حرم الفضل بعد تلك المماثلة بقوله ﷺ : (والفضل ربا)، وفي الحديث الآخر قال : (لا تبيعوا البُرَّ بالبُرِّ، إلا سواء بسواء).

ولما كان الإجماع منعقد على أن المراد بالمساواة، المساواة في الكيال، عرفنا أن المراد: اشتراط المماثلة، وإذا ثبت أن الحكم وجوب المماثلة ولا يتصور ثبوت الحكم بدون محله، عرفنا أن المحل الذي لا يقبل المماثلة لا يكون مال الربا أصلاً، والحنفة والتفاحة لا تقبل المماثلة بالاتفاق، فلم يكن مال الربا (١) .

أن علتكم فاسدة؛ لأنها ترفع الأصل الذي انتزعت منه، وهو عموم الخبر في معنى التفاضل، والعلة إذا عادت لمخالفة أصلها وجب فسادها؛ ولأن الشيء الواحد إذا كان علماً على حكم لم يجز أن يكون علماً على ضده ، والكيل علم على التحليل فلا يكون علة للتحريم (٢) .

الجواب : أن علة الحظر: هي زيادة الكيل لا ذات الكيل، إذاً فلا تناقض (٣) .
تقولون: إن العلة في الذهب والفضة الوزن، وهذا لا يصح ، لأنه لو صح لم يجز إسلام الذهب والفضة في غيرهما من الموزونات وهو جائز بالإجماع (٤) .
الجواب : أن الوزن في الذهب والفضة مختلف عنه في غيرهما من الموزونات، صورة ومعنى وحكما.

وجه الاختلاف في الصورة : أن الوزن في الذهب والفضة يكون بالمثاقيل (٥)
والصنجات (٦)، أما في الحديد والزعفران (٧) وغيرهما فهو بالأمناء (٨) والقبان .
ووجه الاختلاف في المعنى: أن النقود لا تتعين بالتعيين ، والزعفران وغيره يتعين.

(١) المبسوط للسرخسي : ١٢/١١٧ .

(٢) المعونة للقاضي عبد الوهاب : ٢/٦ .

(٣) الحاوي للماوردي بتصرف : ٥/٨٨ .

(٤) المغني لابن قدامة : ص ٦/٥٦ ؛ المجموع للنووي : ص ٩/٤٨٩ ؛ الحاوي للماوردي : ٥/٩١ .

(٥) المتقال : هو واحد مثاقيل الذهب ، مختار الصحاح : ص ٣٦ .

(٦) الصنجات : واحدة صنجة الميزان ما يوزن به ، مختار الصحاح : ص ١٥٥ .

(٧) الزعفران : هو نوع من الطيب ، ويصبغ به ، لسان العرب : ص ٦/٤٥ ، مادة زعف .

(٨) الأمناء : المن رطلان والجمع أمنان ، والمنا عيار قديم والجمع أمناء ، مختار الصحاح : ص ٢٦٥ .

وجه الاختلاف الحكمي: أنه لو اشترى الدراهم أو الدنانير موازنة فوزنها البائع بغيبة المشتري، وسلمها فقبضها، جاز له أن يتصرف فيها قبل وزنها. وفي الحديد والزعفران ونحوهما يشترط إعادة الوزن فيهما.

فإذا اختلفا في الوزن (أي وحدة الوزن) صورة ومعنى وحكماً، لم يجمعهما الوزن من كل وجه فتنزل الشبهة فيه إلى شبهة الشبهة وهي غير معتبرة، وذلك لأن الموزونين إذا اتفقا فالمنع للشبهة، فإذا لم يتفقا كان ذلك لشبهة الوزن والوزن وحده شبهة، فكان ذلك شبهة الشبهة وهي غير معتبرة (١).

وخلاصة ذلك ما قاله ابن الهمام في فتح القدير: (إن المتناظرين لم يتواردا على محل واحد ، فإن الشافعي وكذا مالك عینوا العلة بمعنى الباعث على شرع الحكم ، وهؤلاء عینوا العلة بمعنى المعرف للحكم ، فإن الكيل يعرف المماثلة فيعرف الجواز ، وعدمها يعرف الحرمة ، فالوجه أن يتحد المحل وذلك بجعلها الطعم والاقتيات إلى آخر ما ذكره عندهم ، وعندنا هي قصد صيانة أموال وحفظها عليهم ، هذا ما ذكره ابن الهمام (٢).

علة ربا الفضل عند المالكية

علة ربا الفضل عند المالكية في الأصناف الأربعة تختلف عنها في الذهب والفضة .

أولاً: العلة في الأصناف الأربعة :

تعددت الأقوال في مذهب المالكية في علة ربا الفضل في الأصناف الأربعة ، وأكتفي بذكر قولين :

الأول: ويرى: أن العلة هي الأقتيات والادخار مع اتحاد الجنس ، وهذا القول هو المشهور والمعمول عليه عندهم .

الثاني : أن العلة هي الأقتيات والادخار، وكونه متخذاً للعيش غالباً مع اتحاد الجنس، وهذا القول للقاضيين أبي الحسين القصار، وعبد الوهاب .

المراد بالأقتيات والادخار

المراد بالاقتيات: أن يكون الطعام مقتاتاً، أي تقوم به بنية الإنسان.

والمراد بالادخار: أن لا يفسد بتأخيرهِ ، إلا أن يخرج التأخير عن المعتاد .

(١) فتح القدير والعناية على الهداية : ص ٧/١٣ .

(٢) المرجع السابق : ص ٧/٨ .

ومن شرط الادخار أن يكون في الأكثر، وقيل يجري الربا فيه، وإن كان نادر الادخار (١). وظاهر المذهب على أنه لا حد له ، بل هو في كل شيء يحسبه (٢). وعلى هذا فيجري الربا في المنصوص عليه كالبر، والشعير ، وغيرهما، كالأرز، والذرة، والدخن (٣) والقطنية (٤) ، واللحوم والألبان، والخلول (٥)، وسائر الفواكه المدخرة للقوت والزبيب ، والزيتون والعسل والسكر، وسائر ما في معناها . ولا ربا في تفاح ولا بطيخ ولا خيار ولا قثاء ولا ما لا يدخر (٦) .

دليل المالكية

استدل المالكية لما ذهبوا إليه من أن العلة هي: الاقتيات والادخار مع اتحاد الجنس بالسنة والمعقول .

فأما السنة: فهي ما روي أن عبادة بن الصامت قال: (سمعت رسول الله ﷺ ينهي عن بيع الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر ، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح إلا سواء بسواء، عيناً بعين ، فمن زاد أو استزاد فقد أربى) (٧) .

وجه الدلالة من الحديث

أن النبي ﷺ ذكر أصنافاً فعلم أنه قصد بكل واحد التنبيه على ما في معناه، وهي كلها يجمعها الاقتيات والادخار.

(١) بداية المجتهد ونهاية المقتصد لابن رشد : ص ١٥٧/٢ ؛ مواهب الجليل للحطاب : ص ٤٥٣/٤ وما بعدها ، ط دار الفكر .

(٢) حاشية الدسوقي والشرح الكبير لمحمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي ، والشيخ الدردير ، ط دار الكتب العلمية ، بيروت لبنان : ص ٧٤/٤ .

(٣) الخن : نبات عشبي من النجيليات حبه صغير أملس كحب السمسم ، المعجم الوجيز : ص ٢٢٣ ، ط مجمع اللغة العربية .

(٤) هي كل ما له غلاف من الحبوب كالعدس واللوبيا والحمص والترمس والفاول والجلبان والبسلة ؛ حاشية الدسوقي والشرح الكبير : ص ٧٥/٤ ؛ المغرب : ص ٣٨٨ .

(٥) نوع من أنواع الزيوت.

(٦) المعونة على مذهب عالم المدينة للقاضي أبي محمد عبد الوهاب علي بن ناصر المالكي المتوفى سنة ٤٢٢ هـ ، تحقيق محمد حسن محمد حسن إسماعيل الشافعي ، نشر محمد علي بيضون ، دار الكتب العلمية ، بيروت لبنان : ص ٧/٢ .

(٧) الحديث سبق تخريجه : ص ١٧ .

أما البر والشعير فنبه بهما على أصناف الحبوب المدخرة ، وأما التمر فنبه به على جميع الحلاوات المدخرة، كالسكر، والعسل، والزبيب، وأما الملح فنبه به على جميع التوابل المدخرة لإصلاح الطعام .

وأما المعقول: فوجهه أنه لما كان الوصف الجامع معقول المعنى في الربا وهو أن لا يغبن بعض الناس بعضاً وأن نحفظ أموالهم ، فإن من الواجب أن يكون ذلك في أصول المعاش وهي الأقوات.

ثانياً : العلة في الذهب والفضة:

أما علة منع التفاضل في الذهب والفضة، فهي الصنف الواحد مع كونهما أصول الأثمان وقيم المتلفات، وهذه العلة تعرف عند المالكية بالقاصرة، لأنها ليست موجودة عندهم في غير الذهب والفضة(١) .

ودليل هذا: هو ما روي عن عبادة بن الصامت من الحديث المتقدم .
ووجه الدلالة منه: أنه ﷺ لما نص على الذهب والفضة ولم ينص على ما سواهما دل على أنهما مختصان بذلك ، لأنه ليس مشارك لهما في وضعهما الأخص(٢) .
هذه هي علة ربا الفضل عند المالكية ، وإليك ما ورد عليها .

تقولون إن العلة هي الأقتيات والادخار، لأنها تشابه الأصل بأوصاف، وما كان أكثر شبيهاً بالأصل، كان أولى، ونقول إن هذا منتقض بعدم هذه الأوصاف في الأصل لأن الملح ليس بقوت، وقد جاء النص بثبوت الربا فيه فبطل اعتبار القوت.

الجواب : أن العلة هي القوت أو ما يصلح به القوت فلا نقض.
سلمنا بهذا ولكن إن أردتم اجتماع ذلك في الأربعة لم يصح؛ لأن الملح ليس بقوت وليس التمر مما يصلح به القوت(٣) .

الجواب : سلمنا بعدم اجتماع القوت في الأربعة، وكذلك ما يصلح به القوت، ولكننا نقول بأن القوت في الثلاثة علة، وما يصلح القوت في الملح علة.

سلمنا بما تقولون ، ولكن يترتب على هذا التفرقة بين الأصل وعلته بعلتين مختلفتين، وقد اتفقت على أنه معلل بعللة واحدة، ولو جاز تعليل الأصل بعلتين لجاز إسلاف الملح في

(١) بداية المجتهد ونهاية المقتصد لابن رشد : ص ١٥٩/٢ ؛ مواهب الجليل للحطاب : ص ٣٤٧/٤ ؛ المعونة : ٢/٦

(٢) المعونة للقاضي عبد الوهاب : ص ٢/٦ .

(٣) الحاوي للماوردي : ص ٨٥/٥ .

الثلاثة لاختلافهما في العلة ، كما يجوز إسلاف الذهب والفضة في الأربعة لاختلاف العلة، وقد جاءت السنة وانعقد الإجماع على خلاف هذا(١)، ولم أعثر على جواب في كتب المالكية عن هذا الاعتراض.

علة ربا الفضل عند الشافعية

علة الربا عند الشافعية في الذهب والفضة تختلف عنها في الأصناف الأربعة، وفي الأصناف الأربعة في الجديد، تختلف عنها في القديم.

أولاً : علة ربا الفضل في الذهب والفضة

يرى الشافعية: أن العلة في الذهب والفضة، هي الصنف الواحد مع كونهما أصول الأثمان وقيم المتلفات غالباً، وهي تعرف عندهم بالقاصرة، فهي قاصرة عليهما لا تتعداهما، إذ لا توجد في غيرهما من الموزونات لعدم المشاركة(٢) .

وعلى هذا فإن ربا الفضل يجري في الجنس الواحد من الذهب والفضة ، ولا يجري فيما سواهما من: الحديد، والنحاس، والرصاص، وغير ذلك ، وعلى ذلك فلا يجوز بيع الذهب بالذهب متفاضلاً، وكذلك الفضة بالفضة

دليل الشافعية

استدل الشافعية على مذهبهم بالسنة ودلالة الإجماع.

فأما السنة: فهي حديث عبادة وأبو سعيد اللذين تقدم ذكرهما.

ووجه الدلالة: أن النبي ﷺ علق الحكم عليهما، والأصول مقررة على أن الحكم إذا علق على الذهب والفضة اختص بهما، ولم يقس غيرهما عليهما، قياساً على الزكاة لما تعلقت بهما لم يتعد حكمها إلى غيرهما من: صفر، أو نحاس، أو أي شيء من الموزونات.

ولما حرم الشرب في أواني الفضة والذهب اختص النهي بهما دون سائر الأواني من غيرهما، كذلك وجب أن يكون الربا المعلق عليهما مختصاً بهما، وأن العلة فيهما غير متعدية إلى غيرهما.

(١) المرجع السابق .

(٢) الحاوي الكبير للماوردي : ص ٥/٨٦ ؛ مغني المحتاج : ص ٢/٢٢ .

وأما دلالة الإجماع: فمؤداها: أن الإجماع منعقد على جواز إسلام الذهب والفضة في غيرهما من الموزونات كالحديد، والنحاس، وغيرهما، فلو كان الوزن علة لم يجز، كما لا يجوز إسلام الحنطة في الشعير، والدرهم في الدنانير (١) .

العلة في الأصناف الأربعة عند الشافعية في المذهب الجديد

يرى الشافعية في الجديد أن علة ربا الفضل في الأصناف الأربعة، كونها مطعوم جنس. وعلى هذا فإن الربا يجري في كل مطعوم بيع بجنسه، سواء كان مما يكال أو يوزن أم لا، وذلك كالبطيخ، والرمان، والبقول (٢)، والسفرجل (٣)، وغير ذلك من المطعومات (٤)

المراد بالطعام

المراد بالطعام ما يعد للطعم غالباً تقوياً وتأديماً، أو تفكهاً، أو تداولياً، أو غيرها، فيحرم الربا في: الحبوب، والأدام، والحلاوات، والفواكه، والبقول، والتوابل، والأدوية، وكل ما يؤكل غالباً، وكذلك يحرم الربا فيما يؤكل نادراً كالبلوط (٥) والطرثوث (٦) ، وكذلك يستوي في هذا ما يؤكل وحده أو مع غيره (٧).

دليل هذا: حديث عبادة بن الصامت المتقدم، فإنه صلى الله عليه وسلم نص فيه على الثبر والشعير، والمقصود منها التقوت، فألحق بهما ما في معناهما كالأرز والذرة، ونص على التمر، والمقصود منه التفكه والتأديم، فألحق به ما في معناه كالتين والزبيب، ونص على الملح، والمقصود منه الإصلاح فألحق به ما في معناه كالمصطكي (٨) والسقمونيا (٩) والطين

(١) المجموع: ص ٩١/٩؛ الحاوي الكبير: ص ٩١، ٩٢/٥.

(٢) البقول : هو نبات يؤكل كالكرات أو الكرفس والسداب ونحوها ، وقيل هو نبات عشبي حولي تؤكل قروونه مطبوخة ، وكذلك بذوره مثل الفول واللوبياء ، المغرب : ص ١٤٧ ؛ المعجم الوجيز : ٥٨ .

(٣) السفرجل : نوع فاكهة ؛ مختار الصحاح ، مادة فر : ص ١٢٧ .

(٤) المجموع : ص ٩٦/٩ ؛ الحاوي للماوردي : ص ٨٣/٥ .

(٥) البلوط : ثمر شجر يؤكل ويدبغ بقشره ، المغرب : ص ٤٩ .

(٦) الطرثوث : نبت يؤكل ويتخذ للأدوية ، وقيل لا يأكلها إلا الجائع لمرارتها ، لسان العرب ، مادة طرب .

(٧) المجموع للنووي : ص ٩٦ ، ٩٧/٩ ؛ الحاوي الكبير : ١٠٤/٥ .

(٨) المصطكي : شجر مهن فصيلة البطميات ويستخرج منه العلك المعروف ، المعجم الوجيز : ٥٨٤ .

(٩) السقمونيا : نبات يستخرج منه دواء مسهل للبطن ومزيل لدوده ، المعجم : ٣١٤ .

الأرمني(١) والزنجبيل، ولا فرق بين ما يصلح الغذاء أو يصلح البدن، فإن الأغذية لحفظ الصحة والأدوية لرد الصحة(٢) .

دليل علة ربا الفضل في الأصناف الأربعة عند الشافعية

استدل الشافعية على أن الطعم علة ربا الفضل في الأصناف الأربعة، بالسنة والمعقول.

فأما السنة: فما روى بشير بن سعد عن معمر بن عبد الله أن النبي ﷺ نهى عن بيع الطعام بالطعام إلا مثلاً بمثل(٣).

وجه الدلالة: أن الطعام اسم لكل مطعم من بُر وغيره في اللغة والشرع.

أما اللغة فكقولهم طعمت الشيء أطعمه، وأطعمت فلاناً كذا إذا كان الشيء مطعوماً وإن لم يكن بُراً.

وأما الشرع فكقوله تعالى: ﴿كُلُّ الطَّعَامِ كَانَ حِلاًّ لِّبَنِي إِسْرَائِيلَ﴾ (٤)، والمراد كل مطعم فأطلق عليه اسم الطعام.

وما روي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: (عِشْنَا ذَهْرًا وَمَا لَنَا طَعَامٌ إِلَّا الْأَسْوَدَانِ التَّمْرُ وَالْمَاءُ). ووجهه: أنه إذا كان اسمُ الطَّعَامِ بِمَا وَصَفْنَا مِنْ شَوَاهِدِ اللَّغَةِ وَالشَّرْعِ يَتَنَاقَلُ كُلُّ مَطْعُومٍ مِنْ بُرٍّ وَغَيْرِهِ. كَانَ نَهْيُهُ عَنْ بَيْعِ الطَّعَامِ بِالطَّعَامِ مَحْمُولًا عَلَى عُمُومِهِ فِي كُلِّ مَطْعُومٍ إِلَّا مَا خُصَّ بِدَلِيلٍ (٥) .

وإذا كان اسم الطعام يتناول ما ذكر فكان عموم هذا الخبر إشارة إلى أن علة الربا الطعم.

ولأن الحكم إذا علق باسم مشتق من معنى كان ذلك المعنى علة لذلك الحكم، كحد الزنا؛ لأن اسمه مشتق من الزنا، وقطع يد السارق؛ لأن اسمه مشتق من السرقة، والطعام مشتق من الطعم.

(١) الطين الأرمني : بالفتح منسوب إلى أرمن وهم جيل من الناس سمي به بلدهم ، المغرب : ١٩٩ .

(٢) مغني المحتاج للخطيب الشربيني : ص ٥/٢٢ .

(٣) الحديث سبق تخريجه : ص ٢٠ .

(٤) سورة آل عمران : الآية ٩٣ .

(٥) الحديث أخرجه الإمام مسلم في الزهد ٢٩٧٢ ، وقد سبق تخريجه : ص ٢١ .

وأما المعقول: فوجهه أن علة الشيء في ثبوت حكمه، ما كان مقصوداً من أوصافه، ومقصود البر هو الأكل فاقتضى أن يكون علة الحكم (١).

هذه هي علة ربا الفضل عند الشافعية في المذهب الجديد، وإليك ما ورد عليها من مناقشات:

مناقشات على الربا عند الشافعية

تقولون إن الأكل أو الطعم علة، ولو كان الشارع يريد مجرد الأكل أو الطعم لاكتفى بالنص على واحد منها، إذ الأكل متساو في جميعها (٢).

الجواب: لا نسلم بأن الأكل في الأربعة لا يختلف، لأن البر يؤكل في حال الاختيار، والشعير يؤكل في حال الاضطرار، والتمر يؤكل حلواً، والملح يؤكل استطابة، فلم يكن ذكر أحدها كافياً لتفرده بإحدى الصفات (٣).

تقولون إن الأصل في الطعام الحرمة، لأن النبي ﷺ نهى عن بيع الطعام بالطعام، ونص على شرطين التقابض والمماثلة بقوله: (يداً بيد، مثلاً بمثل)، وكل من الشرطين يشعر بالعزة والخطر كاشتراط الشهادة في النكاح، فوجب أن يعلل بعلة تناسب العزة والخطر وهي الطعم لبقاء الإنسان به، والتمنية في الأثمان لبقاء الأموال التي هي مناط المصالح، فكان الأصل هو الحرمة وهو لا يصلح لأمر:

الأول: أن النص أوجب التماثل شرطاً للبيع وإيجاب المماثلة، وهو المقصود بسوق الحديث، إذ لا بد فيه من إضمار لفظ: "بيعوا" أي: بيعوا هذه الأشياء مثلاً بمثل، وبهذا تبين أن الإباحة في بيع الأموال الربوية بعضها ببعض هي الأصل (٤).

والثاني: أن قوله ﷺ: (لا تبيعوا الطعام)، إنما ينصرف النهي إلى ما بعد إلا، وذلك نحو ما جاء زيد إلا راكباً، وحاصله الأمر بالتسوية عند بيعها.

والثالث: أنه لما كان الطعام مما تشتد الحاجة إليه اشتداداً تاماً، كان السبيل في مثله الإطلاق بأبلغ الوجوه دون التضييق، لأن السنة الإلهية جرت في حق جنس الإنسان، أن ما كانت الحاجة إليه أكثر كان إطلاق الشرع فيه أوسع، كالماء، والكلاء للدواب.

(١) الحاوي الكبير: ص ٨٢-٨٦، ٥/٨٧؛ مغني المحتاج / ٢٢، ٢/٢٣؛ المجموع للنووي: ص ٤٩٠، ٩/٤٩٦

(٢) المعونة للقاضي عبد الوهاب: ٢/٥ .

(٣) الحاوي للماوردي: ٥/٨٧ .

الجواب: أنه قد دل الترتيب على المشتق عليه.

سلمنا بما قلتم ولكن إنما يكون هذا إذا كان صالحاً مناسباً للحكم.

الجواب: إننا نمنع أن يكون الطعام مشتق، لأن الطعام هو اسم لبعض الأعيان الخاصة وهي البُر والشعير، ولا يعرف المخاطبون بهذا الخطاب غيره، بل التمر وهو غالب مأكولهم لا يسمونه طعاماً ولا يفهمون منه لفظ الطعام.

والرابع: أن إلحاق الأموال بالبضع لا يصح، لأن البضع مصون شرعاً وعرفاً وعادةً عن الابتذال والإباحة، فكان الاشتراط فيه تحقيق غرض الصيانة، بخلاف باقي الأموال فإن أصلها الإباحة، ويوجد كثير منها مباحاً حتى الذهب والفضة (١).

علة ربا الفضل في المذهب القديم للشافعي

يرى الشافعية في هذا القول، أن العلة في الأصناف الأربعة هي مطعموم جنس مكيل أو موزون.

وعلى هذا القول فإن الربا لا يجري إلا في مطعموم يكال أو يوزن، ومن ثم فلا ربا في: السفرجل، والرمان، والبيض، والجوز، والبقول، والخضروات، وغيرها مما لا يكال ولا يوزن، فيجوز بيع بعضه ببعض متفاضلاً مع اتحاد الجنس (٢).

دليل هذا القول: ما روي أن النبي ﷺ قال: (الطعام بالطعام مثلاً بمثل) (٣).

وجه الدلالة : أن المماثلة لا تكون إلا بالكيل أو الوزن، فدل على أنه لا يحرم إلا في مطعموم يكال أو يوزن (٤).

علة ربا الفضل عند الحنابلة

للحنابلة في علة ربا الفضل ثلاث روايات:

الأولى: والعلة فيها قريبة من العلة في مذهب الحنفية، وهي الوزن مع الجنس في الذهب والفضة، والكيل مع الجنس في الأصناف الأربعة.
وأقول قريبة؛ لأن الجنس عند الحنفية علة، كما سبق وعند الحنابلة شرط (٥).

(١) فتح القدير والعناية على الهداية : ص ٨ ، ٧/٩ .

(٢) الحاوي للماوردي : ص ٨٣/٥ ؛ المجموع للنووي : ص ٤٩٤ ، ٩/٤٩٥ .

(٣) الحديث أخرجه الإمام مسلم في صحيحه ، وقد سبق تخريجه : ص ٢٠ .

(٤) المجموع للنووي : ص ٩/٤٩٥ .

(٥) شرح منتهى الإرادات : ص ٢/١٩٣ .

والثانية: والعلة فيها قريبة من العلة في مذهب الشافعية، في الجديد وهي الثمنية في الأثمان، والطعم في المطعومات مع اتحاد الجنس. كذلك أقول قريبة من مذهب الشافعية؛ لأن الثمنية عند الشافعية جعلوها مقصورة كما سبق.

أما الحنابلة فجعلوها الثمنية بإطلاق. والثالثة: العلة فيها فيما عدا الذهب والفضة كونه مطعوم جنس مما يكل أو يوزن (١) وهذه العلة قريبة من العلة عند الشافعية في القديم. أما العلة في الذهب والفضة فهي الثمنية، والثمنية ليست قاصرة على الذهب والفضة في هذه الرواية. وحاصل هذه الروايات أن العلة فيها كالعلة في مذهب الحنفية والشافعية في الجديد والقديم. هذا ولما كانت الأدلة هي نفس الأدلة عند الحنفية والشافعية، فنكتفي بها، ولا داعي لتكرارها مرة أخرى. وعلى كل حال فالرواية المشهورة في هذا المذهب، هي الرواية التي توافق مذهب الحنفية هذه هي أقوال الفقهاء وأدلتهم في علة ربا الفضل، وإليك أقوالهم في علة النساء.

الفرع الثاني

علة ربا النساء (٢)

قبل أن أبين علة النساء عند الفقهاء، أود القول: بأن الفقهاء قد اتفقوا على أن النساء لا يجوز في كل ما لا يجوز فيه ربا الفضل من الصنف الواحد، كما أنهم متفقون على أن النساء لا يجوز في الصنفين اللذين يجتمعان في علة واحدة، وإن كان يجوز الفضل، كما أنهم متفقون على أن التفاضل والنساء يجوزان في مختلفي الجنس ومختلفي العلة، وإليك أقوال الفقهاء في علة النساء، وأتناوله في أربعة فروع: الفرع الأول: في علة النساء عند الحنفية.

(١) المغني لابن قدامة : ص ٦/٥٦ .

(٢) المراد بالنساء هو التأخير في قبض أحد البدلين ، وأما التأخير في قبض البدلين فهو بيع دين بدين ، وهو لا يجوز .

الفرع الثاني: في علة النساء عند المالكية.

الفرع الثالث: في علة النساء عند الشافعية.

الفرع الرابع : في علة النساء عند الحنابلة.

علة النساء عند الحنفية

يرى الحنفية: أن علة النساء هي أحد وصفي علة ربا الفضل، إما الكيل أو الوزن المتفق، وإما الجنس(١)، وذلك كبيع الحنطة بالشعير إلى أجل، وكبيع البيض بالبيض عشرة بعشرة إلى أجل، ففي المثال الأول اختلف الجنس ووجد الكيل فيحرم النساء؛ لاجتماع البديلين في علة الكيل، وفي المثال الثاني لم يوجد الكيل ولا الوزن، ووجد الجنس، وهو أن كلا البديلين من جنس البيض، فيحرم النساء أيضاً، وإن كان يحل التفاضل في المثالين؛ لأن علة النساء هي أحد وصفي علة الفضل.

وعلى هذا فيحرم النساء في: أي مال يكال أو يوزن أو غيره، إذا جمع بين البديلين: الكيل، أو الوزن، أو الجنس، فلا يجوز إسلام الجوز في الجوز والبيض في البيض؛ لوجود الجنس رغم أنها ليست مكيلة ولا موزونة، كذلك لا يجوز إسلام القمح في الشعير؛ لأن الكيل يجمعهما، وهو أحد أوصاف العلة، كذلك لا يجوز إسلام الذهب في الفضة؛ لأن الوزن يجمعهما وهو أحد أوصاف العلة.

الأدلة على علة النساء

استدل الحنفية على أن علة النساء هي: القدر المتفق، وهو الكيل، أو الوزن، أو الجنس المتحد، بالسنة والمعقول.

فأما السنة: فما روي عن حديث عبادة المتقدم أن النبي ﷺ قال في آخر الحديث: (فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم بعد أن يكون يداً بيد) (٢) .

وجه الدلالة من الحديث: أن النبي ﷺ ألزم بالتقايض عند اختلاف الجنس، وهو تحريم النساء.

وما روي أن النبي ﷺ: (نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة) (٣) .

ففي هذين الحديثين دليل على أن أحد وصفي علة ربا الفضل، علة لتحريم النساء.

(١) فتح القدير والعناية على الهداية : ص ٧/١١ .

(٢) الحديث سبق تخريجه : ص ١٧ .

(٣) الحديث أخرجه الإمام البيهقي في سننه في كتاب البيوع ، باب جواز التفاضل في الجنسين : ص ٥/٢٨٣ .

وأما المعقول: فوجهه: أن نقد أحد البدلين، وتأخير البذل الآخر يوجب فضلاً في المالية حتى تعورف البيع بالحال بأنقص منه بالمؤجل، وبوجود ذلك الفضل تتحقق شبهة علة الربا، وشبهة الربا مانعة كحقيقة الربا، بالإجماع على منع بيع الأموال الربوية مجازفة وإن ظن التساوي (١)

هذه هي علة ربا النساء ودليلها عند الحنفية، واليك ما ورد عليها من مناقشات والتي تزيد الأمر إيضاحاً.

مناقشات وردت على علة ربا النساء عند الحنفية

أولاً: لا نسلم بقولكم: إن الجنس بانفراده (٢) يحرم النساء؛ لأنه لا دليل عليه، بل قد دل الدليل على نفيه (٣) وهو ما روي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: (إن النبي ﷺ جهز جيشاً فأمرني أن اشتري البعير ببعيرين إلى أجل) (٤) .

وما روي أن علياً رضي الله عنه: (باع جملاً له يقال له العصيفر بعشرين جمل إلى أجل) (٥) . وما روي عن ابن عمر رضي الله عنهما: (أنه باع بعيراً بأربعة أبعرة مضمونة بالريذة) (٦) (٧) وليس لهما من الصحابة مخالف، فكان إجماعاً (٨) .

الجواب: أن النبي ﷺ ألزم بالتقايض عند اختلاف الجنس، وهو تحريم النساء (١)، وذلك بقوله ﷺ في آخر الحديث: (فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم بعد أن يكون يداً بيد) (٢) .

(١) فتح القدير والعناية على الهداية : ص ١١ ، ٧/١٢ .

(٢) ليس في تخصيص الجنس بالذكر في عدم تحريم النساء زيادة ، فإن القدر عند الشافعي كذلك حيث يجوز عنده إسلام الموزونات في الموزونات كالحديد والرصاص وغيرهما من الموزونات من غير الذهب والفضة . العناية مع الهداية مع فتح القدير : ص ٧/١١ .

(٣) الحاوي للماوردي : ص ٥/١٠٠ ؛ وفتح القدير : ص ٧/١١ .

(٤) الحديث أخرجه أبو داود في سننه عن عبد الله بن عمرو برقم ٣٣٥٧ : ص ٣/٢٥٠ . سنن أبي داود ، ط دار إحياء السنة النبوية .

(٥) الأثر أخرجه الإمام مالك في الموطأ : ص ٢٥٧ تحت رقم ٨٠٠ . موطأ مالك برواية محمد بن الحنين ، باب بيع الحيوان بالحيوان نقداً ونسيئة .

(٦) الريذة : بفتحيتين ، قرية بها قبر أبي ذر الغفاري رضي الله عنه ، المغرب : ١٨٠ .

(٧) الأثر أخرجه الإمام مالك في الموطأ ، وزاد يومها إياه بالريذة . موطأ مالك برواية محمد بن الحسن : ص ٢٥٧ تحت رقم ٨٠١ .

(٨) الحاوي للماوردي : ص ١٠٠ ، ٥/١٠١ .

أنه قد قام الدليل على أن وجود أحد جزئي علة الربا، علة لتحريم النساء، وهو ما روي أن النبي ﷺ قال: (ولا بأس ببيع البُر بالشعير والشعير أكثرهما يداً بيد، وأما النسيئة فلا) (٣)

وما روي أن النبي ﷺ: (نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة) (٤) .
سلمنا بالجواب الأول والثاني، ولكن لا نسلم بالجواب الثالث؛ لأن النهي يحمل على دخول الأجل في كلا العوضين، وهو عندنا جائز (٥).
الجواب: سلمنا بالاحتمال، ولكن يقدم حديث النهي عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة على حديث البعير بالبعيرين، لأنه محرم وذلك مبيح.

إن ما رويتم محمول على ما قبل تحريم الربا جمعاً بين الأدلة (٦) بقدر الإمكان.

علة النساء عند المالكية

يرى المالكية: أن علة ربا النساء في الذهب والفضة هي الثمنية ، اتحد الجنس أم اختلف.

وفي الأصناف الأربعة هي: الطعم دون الادخار ودون اتفاق الصنف على غير وجه التداولي، وفي غير المطعومات الصنف الواحد المتفق المنافع مع التفاضل (٧).
وعلى هذا يجوز التفاضل عندهم في المطعومات التي ليست مدخرة وكانت صنفاً واحداً، ولا يجوز فيها النساء، وذلك كالبيض، والبطيخ، والرمان، أو نحوها، أما جواز التفاضل فلكونها ليس مدخرة، وقد تقدم أن الادخار شرط في تحريم التفاضل في الصنف الواحد، وأما منع النساء فيها، فلكونها مطعومة، فالطعم بإطلاق علة لتحريم النساء في المطعومات (٨)، كذلك إذا اتفقت المنافع لا يجوز بيع اثنين بواحد من النوع الذي اتفقت فيه

(١) فتح القدير على الهداية : ٧/١٢ .

(٢) الحاوي للماوري : ص ١٠٠ ، ٥/١٠١ .

(٣) الحديث سبق تخريجه : ص ١٧

(٤) الحديث سبق تخريجه : ص ٣٠ .

(٥) الحاوي للماوري : ص ٥/١٠١ .

(٦) فتح القدير والعناية على الهداية : ١٢ ، ٧/١٣ .

(٧) بداية المجتهد : ص ١٥٨ ، ١٦١ ، ٢/١٦٢ ؛ مواهب الجليل : ٤/٣٠ ؛ الخرشي على مختصر خليل لأبي عبد الله بن عبد الله بن علي الخرشي المالكي ، ط دار الفكر : ص ٣/٥٦ .

(٨) بداية المجتهد : ص ٢/١٥٨ وما بعدها .

أدلة المالكية

أولاً : دليل العلة في الذهب والفضة

دليل العلة في الذهب والفضة، قد سبق إيضاحه في علة ربا الفضل، فيكتفى به حيث لا فرق.

ثانياً : دليل العلة في الأصناف الأربعة

ما روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (الذهب بالذهب ربا إلا هاء وهاء ، والبر بالبر ربا إلا هاء وهاء ، والتمر بالتمر ربا إلا هاء وهاء ، والشعير بالشعير ربا إلا هاء وهاء) (١)، وما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إنما الربا في النسيئة) (٢) ، وما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لا تتبعوا الذهب بالذهب ولا الورق بالورق ولا البر بالبر ولا شعير بالشعير ولا الملح بالملح ولا التمر بالتمر إلا سواء بسواء عيناً بعيناً يداً بيد) (٣).

ولأن كل شيئين لا يجوز أن يسلم أحدهما في الآخر مع جواز السلم، فلا يجوز بيعه به إلا يداً بيد أصله الذهب والفضة، ولأنه بيع عين بعين يفسده دخول الأجل ، فكان التقابض شرطاً فيه (٤).

ثالثاً : دليل العلة في غير المطعومات:

قوله تعالى: ﴿ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ﴾ والربا هو الزيادة، وما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم (نهى عن بيع الحيوان نسيئة) (٥) .

ولأن البيع من الذرائع الربوية، وهي أن يمنع الشيء الجائز إذا قويت التهمة في التطرق به والتذرع إلى الأمر المحظور، ووجه التذرع أن يكون قرضاً يجر نفعاً كأن يقول أحد الرجلين للآخر: أقرضني فرساً أو ثوباً من صفة كذا وأرد عليك ثوبين مثله إلى شهر، فيقول: إن هذا قرضاً يجر نفعاً وذلك ممنوع، ولكن أبيعك ثوباً بثوبين فيحصل من ذلك استعمال القرض في الباطن بلفظ البيع، فمتى أجزناه حصل منه ذريعة إلى الممنوع لقوة التهمة فيه (٦).

(١) الحديث سبق تخريجه ص ١٧ .

(٢) تقدم تخريجه : ص ١٤ .

(٣) تقدم تخريجه : ص ٢٦ .

(٤) المعونة للقاضي عبد الوهاب: ٢/١٣ .

(٥) الحديث سبق تخريجه : ص ٣٨ .

(٦) المعونة : ص ٢/٣٣ .

هذه هي على النساء عند المالكية، واليك العلة عند الشافعية.

علة ربا النساء عند الشافعية

تختلف علة النساء عند فقهاء الشافعية في الذهب والفضة، عنها في الأصناف الأربعة.

أولاً: في الذهب والفضة

علة النساء في الذهب والفضة كونهما جنس الأثمان غالباً دون اتفاق الجنس.

ثانياً: في الأصناف الأربعة

علة النساء في الأصناف الأربعة عند الشافعية، هي الطعم دون اتفاق الجنس، سواء كان

مما يكال أو يوزن أم لا، وفي غير الطعام يجوز البيع حالاً ومؤجلاً (١).

أدلة الشافعية على علة النساء

استدل الشافعية على قولهم بما جاء في آخر حديث عبادة المتقدم : (فإذا اختلفت هذه

الأنصاف فبيعوا كيف شئتم بعد أن يكون يداً بيد) (٢) .

ومن الواضح أن الفرق بين علة الفضل والنساء عند الشافعية، هو اتحاد الجنس وعدمه،

ففي حالة اتحاد الجنس في المطعوم يحرم التفاضل والنساء، وفي حالة اختلاف الجنس في

المطعوم يحل التفاضل ويحرم النساء.

كذلك في الذهب والفضة إذا اتحد الجنس حرم التفاضل والنساء، وإذا اختلف الجنس حل

التفاضل وحرم النساء. فالجنس عندهم شرط وليس علة.

وعلى ما تقدم فإنه يجوز عند الشافعية بيع ما سوى الذهب والفضة، والمأكول

والمشروب، متفاضلاً ونسيئاً، لعدم وجود العلة، فيجوز بيع بغير بأعرة، وشاة بشياه، وثوب

بثياب.

ولما كان الطعم هو علة النساء عند المالكية والشافعية، وقد سبق ذكره، فيكتفى بما ورد

من مناقشات على علة الطعم التي قال بها الشافعية في ربا الفضل، حيث لا فرق.

علة النساء عند الحنابلة

للحنابلة في علة النساء خمس روايات:

الأولى: وهي الكيل أو الوزن فيما يكال أو يوزن، وهذه الرواية شبيهة بقول الحنفية.

(١) المجموع شرح المذهب : ص ٩/٥٠٥ .

(٢) الحديث سبق تخريجه : ص ١٧ .

والثانية: الطعم في المطعومات، وهذه العلة هي علة النساء عند الشافعية في الأصناف الأربعة.

والثالثة: الجنس مطلقاً فيما لا يكال ولا يوزن، والعلة في هذه الرواية تشبه قول الحنفية في قولهم الجنس بانفراده يحرم النساء.

والرابعة: الجنس مع التفاضل، فلا يحرم النساء إذا اتحد الجنس ولم يكن هناك تفاضل، في غير المكيل والموزون، وهي تشبه قول للمالكية.

والخامسة: تحريم النساء في كل مال بيع بجنسه، أو بغير جنسه، إذا لم يكن مكيلاً أو موزوناً (١).

دليل الحنابلة على علة النساء

دليل الرواية الأولى: ما روي أن النبي ﷺ قال: (إذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم يداً بيد) (٢). وقد تم الاستدلال لهذه الرواية في مذهب الحنفية فيكتفى به (٣).

دليل الرواية الثانية: وقد سبق في الاستدلال للعلة عند الشافعية، فليراجع (٤).

دليل الرواية الرابعة: ما روي عن جابر أن النبي ﷺ قال: (الحيوان اثنان بواحد لا يصلح نساء ولا بأس به يداً بيد) (٥).

وما روى ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلاً قال: يا رسول الله أرأيت الرجل يبيع الفرس بالأفراس والنحبية (٦) بالإبل؟ فقال: (لا بأس إذا كان يداً بيد) (٧). وهذا يدل على إباحة النساء مع التماثل بمفهومه.

دليل الرواية الخامسة: لأنه بيع عرض بعرض فحرم النساء بينهما كالجنسين من أموال الربا.

(١) المغني لابن قدامة : ٦/٦٢ وما بعدها .

(٢) الحديث سبق تخريجه : ص ١٧ .

(٣) انظر : ص ٢٦ وما بعدها .

(٤) انظر : ص ٣٢ وما بعدها .

(٥) الحديث أخرجه الترمذي في صحيحه ، باب في كراهية بيع الحيوان بالحيوان نسيئة عن أبي الزبير عن جابر ، وقال فيه حديث حسن صحيح . عارضة الأحوزي بشرح صحيح الترمذي : ص ٥/٢٤٧ .

(٦) النجبية من الإبل القوي منها الخفيف السريع . لسان العرب ، مادة نجب .

(٧) الحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده عن ابن عمر رضي الله عنهما : ص ٢/١٠٩ . مسند الإمام أحمد ، ط دار الفكر .

وقال في المغني وهذه الرواية ضعيفة جداً، لأن فيها إثبات حكم يخالف الأصل بغير نص ولا إجماع ولا قياس صحيح. لأن في المحل المجمع عليه أو المنصوص عليه أوصافاً لها أثر في تحريم الفضل، فلا يجوز حذفها عن درجة الاعتبار، وما هذا سبيله لا يجوز إثبات الحكم فيه (١).

هذه هي الروايات التي وردت في كتب الحنابلة وأدلتها، وذكر صاحب المغني أن أشهر هذه الروايات الرواية الأولى التي تشبه قول الحنفية في العلة، فيمكن جعلها قول الحنابلة دون غيرها.

وحاصل ما تقدم ذكره من أقوال الفقهاء في العلة ما يأتي:

أن علة ربا الفضل في الذهب والفضة عند فقهاء الحنفية، هي الوزن مع الجنس، وعلة النساء فيهما هي إما الوزن وإما الجنس.

والعلة فيما سواهما هي الكيل أو الوزن مع الجنس، وعلة النساء إما الكيل وإما الوزن وإما الجنس.

كما أن علة الفضل في الذهب والفضة عند الشافعية، هي غلبة الثمنية مع اتحاد الجنس، وعلة النساء فيهما غلبة الثمنية دون اتحاد الجنس.

وفي الأصناف الأربعة العلة هي الطعم مع اتحاد الجنس، وعلة النساء فيها الطعم دون اتحاد الجنس.

كذلك فإن علة ربا الفضل عند المالكية في الذهب والفضة، هي غلبة الثمنية مع اتحاد الجنس، وعلة النساء فيهما غلبة الثمنية دون اتحاد الجنس.

وفي الأصناف الأربعة العلة هي: الاقتيات والادخار مع اتحاد الجنس، وعلة النساء هي: الطعم دون اتحاد الجنس، أو تقارب المنافع مع التفاضل أيضاً، مع ملاحظة أن الحنفية يعتبرون الجنس علة وهم يعتبرونه شرطاً.

وفي الرواية الثانية العلة فيها كالعلة عند الشافعية في الحديد، وفي رواية ثالثة كمذهب الشافعية في القديم.

ويلاحظ أن قول الحنابلة في الرواية الثانية والثالثة، وإن كان كما قال الشافعية، إلا أن هناك فارق بين قولهم وبين قول الشافعية في علة الذهب والفضة، وهذا الفارق مؤداه أن

(١) المغني لابن قدامة : ص ٦٢/٦ وما بعدها .

الشافعية يرون: أن العلة في الذهب والفضة غالبية الثمنية، مع كونها قاصرة على الذهب والفضة لا تتعداهما. أما الحنابلة فجعلوا العلة هي الثمنية فيهما ولم يجعلوها قاصرة. والناظر في هذه الأقوال يخلص بالآتي:

أولاً: أنه على قول الحنفية يجري الربا في كل مكيل أو موزون بيع بجنسه، مطعوماً كان أو غير مطعوم كالحبوب، والأشنان، والنورة^(١)، والقطن، والصوف، والكتان، والورس^(٢)، والحناء، والعصفر، والحديد، والنحاس ونحو ذلك، ولا يجري في مطعوم لا يكال ولا يوزن. وعلى ما ذهب إليه الشافعية، فإن تحريم الربا يقتصر على: الذهب والفضة، والمطعومات فقط، ويخرج منه ما عدا ذلك من: الحديد، والنحاس، والجص، والرصاص، أو نحو ذلك. وعلى ما ذهب إليه المالكية فإن تحريم التفاضل يقتصر على الذهب والفضة وما هو من المأكولات المقتاتة المدخرة عند اتحاد الجنس، ويقتصر تحريم النساء على ما هو من جنس المطعومات فقط، ويخرج ما عدا ذلك مما كان من غير المأكولات.

ثانياً: إن نطاق التحريم على ما ذهب إليه الحنفية أوسع، حيث يشمل كل ما يكال أو يوزن، سواء كان مطعوماً بخلاف ما ذهب إليه المالكية والشافعية، حيث يجعل نطاق التحريم أضيق.

العلة المختارة

أولاً: في الأصناف الأربعة:

بعد عرض أقوال الفقهاء وأدلتهم في علة الربا، أجد نفسي مطمئن للعمل بما ذهب إليه الحنفية من أن العلة في الأصناف الأربعة هي الكيل مع الجنس في المكيل، والوزن مع الجنس في الموزون لتحريم ربا الفضل، وإما الكيل وإما الوزن وإما الجنس لتحريم ربا النساء وذلك للأمور الآتية:

أن العمل بما ذهب إليه الحنفية، هو الذي يتفق مع معنى الربا، وما حرم من أجله، وهو الفضل الخالي عن العوض، لأن هذا المعنى يوجد في غير المطعومات كما يوجد فيها. أن العمل به فيه تحقيق الحكمة من تحريم الربا: لأن فيه حفظ أموال الناس وصيانتها من الاعتداء.

(١) النورة: مجر الكلس، المعجم الوجيز: ص ٦٣٩.

(٢) الورس: نبت أصفر يكون باليمن، مختار الصحاح: ص ١٨٣، وقيل صبغ أصفر، وقيل نبت طيب الرائحة، المغرب: ٤٨١.

كذلك فإن العمل بما ذهب إليه الحنفية، يتفق مع معنى المعاوضة التي تنبئ عن التساوي والتقابل.

إن ما ذهب إليه الحنفية، فيه العمل بالأحوط في المعاملات أكبر مما ذهب إليه غيرهم. يؤيد ما سبق ما أورده الطحاوي في مشكل الآثار تعقيباً على ما رواه الإمام مالك عن أبي الزناد: أنه سمع سعيد بن المسيب يقول: (لا ربا إلا في ذهب أو فضة، أو فيما يكال أو يوزن، مما يؤكل أو يشرب) (١) .

وذكر رواية أخرى عن عمار بن يسار رضي الله عنه أنه قال: (العبد خير من العبدین، والأمة خير من الأمتين، والبعير خير من البعيرين، والثور خير من الثورين، مما كان يداً بيد فلا بأس به، إنما الربا في النسيء إلا فيم كيل أو وزن)، وذكر رواية أخرى عن عمار بلفظ: (الثوب خير من الثوبين) مكان قوله: (الثور خير من الثورين) (٢).

ثم قال تعليقاً على الروايات الثلاث: " فلما كان أؤكد الأشياء في دخول الربا عليها الذهب والفضة ليسا بمأكولين ولا مشروبين، عقلنا بذلك أن العلة التي بها دخول الربا هي: الوزن فيما يوزن، والكيل فيما يكال، مأكولاً كان ذلك أو مشروباً، أو غير مشروب أو غير مأكول " (٣) .

ثانياً: بالنسبة لليلة في الذهب والفضة:

أيضاً بعد بيان آراء الفقهاء في علة الذهب والفضة، يمكن اختيار ما ذهب إليه الحنابلة، في الرواية الثانية والتي فيها: أن العلة فيهما هي الثمنية، وذلك للآتي: أن الثمنية علة متعدية وغير مقصورة على نقد بذاته، فمعناها يشمل الذهب والفضة وغيرهما من النقود الورقية وغيرها.

أن علة الثمنية علة مرنة، فهي صالحة لتعليل سائر النقود في سائر الأزمان. إن الأخذ بالثمنية كعلة فيه العمل بالأحوط في أموال الربا، حيث إن غير الثمنية من الأوصاف الأخرى التي قال بها بعض الفقهاء، لا تنطبق على النقود المضروبة من غير

(١) مُشكل الآثار للإمام أبي جعفر الطحاوي أحمد بن محمد بن سلامة بن سلمة الأزدي المصري الحنفي ، ط مجلس

دائرة المعارف النظامية الكائنة في الهند ، سنة ١٣٣٣هـ : ص ٢/١٢٤ .

(٢) المرجع السابق.

(٣) المرجع السابق.

الذهب والفضلة، ومن ثم لا يجري فيها التحريم عند التفاضل والنساء، فكان الأخذ بالثمنية
كعلة فيه تغليب لجانب التحريم على جانب الحل، في حالة اجتماع المحرم والمحل.

الفصل الثالث
باب السلم
المبحث الأول
تعريف السلم، وركنه، ودليله
المطلب الأول
تعريف السلم

السلم والسَّلْفُ: نوع من البيوع يُعَجَّل فيه الثمن وتُضَبَطُ فيه السلعة بالوصف إلى أجلٍ معلوم. وقال أبو عبيد الهروي: السَّلْفُ في المعاملات له معنيان: أحدهما القرض الذي لا مُنْعَةَ فيه للمقرض؛ وعلى المقرض رده كما أخذه؛ والعرب تسميه سَلْفًا، والمعنى الثاني في السَّلْفِ السَّلْمُ؛ وهو اسم من أَسْلَمْتُ.

والسلم في اللغة: عبارة عن الاستعجال، والسلم والسلف، بمعنى واحد، وخص هذا النوع بهذا الاسم؛ لأن شرعيته كانت لمعنى يخص رأس المال وهو استعجاله وتحصيله قبل وجود المبيع، لأن الحاجة إليه.

وقيل: سمي به لكون معجلا على وقته، فإن أوان البيع عند وجود المبيع المعقود عليه في ملك العاقد، والسلم عادة إنما يكون فيما ليس بموجود في ملكه فيكون معجلا على وقته. والسلم في اصطلاح الفقهاء: أخذ أجل بعاجل. والعاجل هو رأس المال، والأجل هو المسلم فيه.

المطلب الثاني
ركن السلم، وحكمه
الفرع الأول: ركن السلم

ركن السلم الإيجاب والقبول، وهو ينعقد بلفظ السلم أو السلف، بأن يقول رجل لآخر: أسلمت إليك عشرة دراهم في كر حنطة، أو يقول أسلفت، ويقول الآخر: قبلت فيتم الركن. ويسمى صاحب الدراهم رب السلم، ويسمى المسلم أيضا (المشتري)، ويسمى الآخر المسلم إليه (البائع) وتسمى الحنطة المسلم فيه (المبيع).

انعقاد السلم بلفظ البيع

اختلف فقهاء الحنفية في انعقاد السلم بلفظ البيع، بأن قال: المسلم إليه لآخر: بعت منك كر حنطة هكذا، ويذكر شرائط السلم، وقال المسلم قبلت، ينعقد أيضا عند أبي حنيفة، وأبي يوسف، ومحمد.

ووجه قولهم: أن السلم نوع بيع، فينعقد بلفظ البع، والدليل على أنه بيع ما روي أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (نهى عن بيع ما ليس عند الإنسان ورخص في السلم)، وجه الدلالة: إن نهيه - عليه الصلاة والسلام - عن بيع ما ليس عند الإنسان عام، وخص السلم بالرخصة فيه، دل على أن السلم بيع ما ليس عند الإنسان، وذلك ليستقيم تخصيصه عن عموم النهي بالترخص فيه.

ولا يصح السلم عند زفر رحمه الله، إلا بلفظ السلم.

ووجه قوله: أن السلم بيع ما ليس عند الإنسان، وهو بيع المعدوم، إذ المبيع، وهو المسلم فيه معدوم، وبيع موجود غير مملوك، أو مملوك غير مقدور التسليم لا يصح، فبيع المعدوم أولى وأجدر وأنه منهي عنه، فلا يجوز.

نعم القياس أن لا ينعقد أصلاً، لأنه بيع ما ليس عند الإنسان، وأنه منهي عنه، إلا أن الشرع ورد بجوازه بلفظ السلم بطريق الرخصة دفعا لحاجة الناس، بقوله: ورخص في السلم.

الفرع الثاني

حكم السلم

حكم السلم: هو ثبوت الملك لرب السلم في المسلم فيه، وهو العين الموصوف مؤجلاً، بمقابلة ثبوت الملك في رأس المال للمسلم إليه معجلاً.

المطلب الثالث

دليل مشروعية السلم

السلم عقد مشروع بالكتاب، والسنة والإجماع.

دليل مشروعية السلم من الكتاب

استدل الحنفية على مشروعية السلم من القرآن الكريم: بقوله تعالى: لَيَّا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ {البقرة: ٢٨٢} (١)، فقد قال ابن عباس رضي الله

(١) . رواه الحاكم في مستدركه في تفسير سورة البقرة عن أيوب عن قتادة عن أبي حسان الأعرج عن ابن عباس قال: أشهد أن السلف المضمون إلى أجل مسمى قد أحله الله في كتابه وأذن فيه، قال الله تعالى: لَيَّا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ {البقرة: ٢٨٢} الآية، وقال: حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. وكذلك رواه الشافعي في مسنده ومن طريقه رواه البيهقي في المعرفة ورواه عبد الرزاق وابن أبي شيبة في مصنفيهما وقال مخرج الأحاديث: ورأيت بعض مصنف زماننا أسندوا هذا الحديث إلى البخاري وهو غلط ولم يخرج البخاري في صحيحه لأبي حسان الأعرج شيئاً واسمه مسلم.

عنهما: أشهد أن الله أحل السلف المضمون، وأنزل فيها أطول آية في كتابه، وتلا قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ﴾ [البقرة: ٢٨٢] (١).

وفائدة قوله تعالى: مسمى هي الإعلام بأن من حق الأجل أن يكون معلوماً، ومعنى تداينتم بدين، إذا دابن بعضكم بعضاً، يقال: دابنت الرجل إذا عاملته بدين معطياً أو آخذاً، كما تقول بايعته إذا بعته أو باعك.

وقوله: أحل السلف المضمون، أي المؤجل، وهذا جاء في رواية أخرى أنه تعالى أحل السلف المؤجل، وقيل السلف الواجب في الذمة.

دليل مشروعية السلم من السنة

استدل الحنفية على مشروعية السلم من السنة بأدلة منها:

ما روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: (نهى عن بيع ما ليس عند الإنسان ورخص في السلم) (٢).

ما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قدم النبي ﷺ المدينة والناس يسلفون في التمر السنتين والثلاث، فقال ﷺ: (من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم إلى أجل معلوم)، أخرجه الأئمة الستة في كتبهم عن أبي المنهال (٣).

دليل الإجماع على مشروعية السلم

(١) . رواه الحاكم في مستدركه في تفسير سورة البقرة عن أيوب عن قتادة عن أبي حسان الأعرج عن ابن عباس قال: أشهد أن السلف المضمون إلى أجل مسمى قد أحله الله في كتابه وأذن فيه، قال الله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ﴾ [البقرة: ٢٨٢] الآية، وقال: حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. وكذلك رواه الشافعي في مسنده ومن طريقه رواه البيهقي في المعرفة ورواه عبد الرزاق وابن أبي شيبة في مصنفيهما وقال مخرج الأحاديث: ورأيت بعض مصنفي زماننا أسندوا هذا الحديث إلى البخاري وهو غلط ولم يخرج البخاري في صحيحه لأبي حسان الأعرج شيئاً واسمه مسلم.

(٢) . هذا غريب بهذا اللفظ. وقوله ورخص في السلم من تمام الحديث لا من كلام المصنف. ولفظ الحديث "لا «تبع ما ليس عندك» . والصحابة رضي الله عنهم روه بهذا اللفظ، والمراد بما ليس عندك ما ليس في ملكه، فإنه لو كان في ملكه يجوز وإن لم يكن حاضراً إذا كان المشتري رآه قبل ذلك، انتهى. قلت: الظاهر أن هذا الحديث مركب من حديثين فحديث النهي عن بيع ما ليس عند الإنسان أخرجه أصحاب السنن الأربعة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع ولا ربح ما لم يضمن ولا تبع ما ليس عندك» . وقال الترمذي: حديث حسن صحيح.

(٣) . أخرجه الستة، متفق عليه

أجمع المسلمون منذ عهد رسول الله ﷺ على مشروعية السلم، لحاجة الناس الداعية إليه، فإن الفقير والغني يحتاج إليه؛ لأن الفقير ربما لا يكون عنده عين مال يبيعها وينفق على نفسه، فيحتاج إلى أخذ السلم، والغني يحتاج إلى أن ينفق على نفسه وعياله، فيحتاج إلى الاسترباح، والاسترباح يحصل بهذا الطريق أكثر مما يحصل بشراء الأعيان، لأن في بيع العين، الأعيان تشتري بمثلها، وفي الدين تشتري بأقل من مثلها، فجوز باعتبار الحاجة. أما القياس فهو وإن كان يأبى جواز السلم، ولكننا تركناه للحديث. ووجه القياس: أن السلم بيع المعدوم، إذ المبيع وهو المسلم فيه معدوم، وبيع موجود غير مملوك، أو مملوك غير مقدور التسليم لا يصح، فبيع المعدوم أولى وأجدر.

أسئلة على المبحث الأول

ما هو السلم لغة واصطلاحاً

ما حكم السلم مع التوجيه

عقد السلم بلفظ الهبة، بأن قال المسلم إليه: وهبت لك عشرة آلاف جنيه مقابل عشرة أرباب قمح إلى ستة شهور، وهل يختلف الحكم لو عقده بلفظ البيع، وضح ذلك مع التوجيه لكل ما تذكر.

أسلم زيد عشرة إلى عمرو آلاف جنيه، في عشرة أرباب شعير، ولما حل موعد تسليم المسلم فيه، باع عمرو الشعير لمحمد، ولما طالبه زيد بالشعير، قال زيد ليس لك إلا الثمن الذي دفعت لأن العقد لا يلزمني بتسليم الشعير، وضح ذلك مع التوجيه.

المبحث الثاني

شروط السلم

شروط السلم نوعان: نوع يرجع إلى نفس العقد، ونوع يرجع إلى رأس المال، ونوع يرجع إلى المسلم فيه.

المطلب الأول

شرط السلم الذي يرجع إلى نفس العقد

أن يكون العقد باتاً عارياً عن شرط الخيار للعاقدين أو لأحدهما المراد بالخيار هنا: خيار الشرط، وذلك للآتي:

أن جواز البيع مع شرط الخيار في الأصل، ثبت معدولاً به عن القياس، لأنه شرط يخالف مقتضى العقد بثبوت الحكم وهو الملك للحال، وشرط الخيار يمنع انعقاد العقد في حق الحكم، ومثل هذا الشرط مفسد للعقد في الأصل، إلا أننا عرفنا جوازه بالنص، والنص ورد في بيع العين، فبقي ما وراءه على أصل القياس، خصوصاً إذا لم يكن في معناه، والسلم ليس في معنى بيع العين فيما شرع له الخيار، لأن الخيار شرع لدفع الغبن، والسلم مبناه على الغبن ووكد الثمن، لأنه بيع المفاليس فلم يكن في معنى مورد النص، فورود النص هناك لا يكون وروداً ههنا دلالة، فبقي الحكم فيه للقياس، فلا يصح فيه خيار الشرط.

أن قبض رأس المال من شرائط الصحة، ولا صحة للقبض إلا في الملك، وخيار الشرط يمنع ثبوت الملك فيمنع صحة القبض، بخلاف المستحق أنه لا يبطل السلم حتى لو استحق رأس المال وقد افترقا عن القبض، وأجاز المستحق فالسلم صحيح؛ لأنه لما أجاز تبين أن العقد وقع صحيحاً من حين وجوده، وكذا القبض، إذ الإجازة اللاحقة بمنزلة الوكالة السابقة.

خيار الرؤية والعيب في عقد السلم

تبين أنه لا يصح السلم إذا كان فيه خيار الشرط للعاقدين أو لأحدهما؛ لأنه يمنع تمام القبض فيكون مانعا من الانعقاد في حق الحكم، وهو ثبوت الملك في البديلين، أما خيار الرؤية والعيب؛ فلا يمنعان صحة السلم؛ لأنهما لا يمنعان ثبوت الملك فلا يمنعان صحة القبض.

وعلى ذلك فلا مانع من اشتراط خيار العيب في السلم؛ لأنه لا يمنع تمام القبض؛ لأن تمام العقد يتعلق بتمام الصفقة، وتمام الصفقة يتعلق بتمام الرضا، والرضا تام وقت العقد. وكذلك لا حاجة إلى إثبات خيار الرؤية في السلم؛ لأن إثباته في السلم غير مفيد، إذ فائدة الخيار رد المبيع والمسلم فيه دين في الذمة، فلا فائدة.

إسقاط رب السلم خيار الشرط

ولو أسقط رب السلم خيار الشرط قبل الافتراق عن المجلس، ورأس المال قائم في يد المسلم إليه جاز السلم عند أبي حنيفة، وأبي يوسف ومحمد. ولا بد من كون رأس المال قائما؛ لأنه إذا أسقط خياره بعد هلاك رأس المال في يد المسلم إليه وإنفاقه، فإنه لا يعود السلم جائزا بالإجماع.

وذهب زفر والشافعي ومالك أيضا، إلى عدم الجواز.

المطلب الثاني

شروط السلم التي ترجع إلى رأس المال

حتى يبقى السلم صحيحا، يشترط في رأس ماله شروطا، منها:

الأول: بيان جنسه: كقولنا: دراهم أو دنانير أو حنطة أو تمر.

الشرط الثاني: بيان نوعه: إذا كان الثمن من غير النقود، أو كان في البلد نقودا مختلفة كقولنا: جنيهات مصرية، أو دولارات أمريكية، أو قمح مصري، أو تمر صقعي، أو برحي، أو نحو ذلك.

الشرط الثالث: بيان صفته: كقولنا: جيد أو وسط، أو رديء؛ لأن جهالة الجنس والنوع والصفة، مفضية إلى المنازعة، وأنها مانعة من صحة البيع.

الشرط الرابع: بيان قدره: إذا كان مما يتعلق العقد بقدره، من: المكيلات والموزونات والمعدودات المتقاربة، ولا يكتفى بالإشارة إليه، وهذا في قول أبي حنيفة، وسفيان الثوري، وأحد قولي الشافعي.

وقال أبو يوسف ومحمد: بيان القدر ليس بشرط، والتعيين بالإشارة كاف، وهو أحد قولي الشافعي، رحمه الله.

وصورة المسألة: إذا قال: أسلمت إليك هذه الدراهم أو هذه الدنانير، ولا يعرف وزنها، أو هذه الصبرة ولا يعرف كيلها، لا يجوز عند أبي حنيفة، وعندهما يجوز.

الأدلة

وجه قول الصحابين: إن العاقدين يحتاجان إلى تعيين رأس المال، وأنه حصل بالإشارة إليه، فلا حاجة إلى إعلام قدره، ولهذا لم يشترط إعلام قدر الثمن في بيع العين، ولا في السلم إذا كان رأس المال ممالا يتعلق العقد بقدره، كالثياب والعدييات المتفاوتة.

وجه قول أبي حنيفة - رحمه الله - : أن جهالة قدر رأس المال تؤدي إلى جهالة قدر المسلم فيه، وأنها مفسدة للعقد، فيلزم إعلام قدره صيانة للعقد عن الفساد ما أمكن، كما إذا أسلم في المكيل بمكيال نفسه بعينه.

جواب أبي حنيفة عن قياس الصحابين: (إعلام رأس المال في السلم عليه في بيع العين، أو في السلم إذا كان رأس المال ممالا يتعلق العقد بقدره، كالثياب والعدييات المتفاوتة)، وقد أجاب بالآتي:

إن قياس إعلام رأس مال السلم، على إعلام قدر الثمن في بيع العين، لا يصح؛ لأن السلم يختلف عن بيع العين؛ فإن الزيف والاستحقاق في بيع العين لا يؤثر في العقد؛ لأن قبض الثمن غير مستحق.

أن قياس السلم في هذه الصورة، على حالة ما إذا كان رأس المال ممالا يتعلق العقد بقدره، كالثياب، والعدييات، المتفاوتة، لا يصح أيضا؛ لأن القدر فيها ملحق بالصفة، ألا ترى أنه لو قال: أسلمت إليك هذا الثوب على أنه عشرة أذرع، فوجده المسلم إليه أحد عشر سلمت الزيادة له، فثبت أن الزيادة فيها تجري مجرى الصفة، وإعلام صفة رأس المال ليس بشرط لصحة السلم، إذا كان معينا مشارا إليه. ولأن إعلام قدر الثمن في بيع العين ليس بشرط، والإشارة كافية بالإجماع.

أما لو كان رأس المال ممالا لا يتعلق العقد بقدره، من: الذرعات، والعدييات المتفاوتة، فلا يشترط إعلام قدره، ويكتفى بالإشارة بالإجماع.

فلو قال أسلمت إليك هذا الثوب، ولم يعرف ذرعه، أو هذا القطيع من الغنم، ولم يعرف عدده، جاز بالإجماع.

الشرط الخامس: قبض رأس المال في مجلس العقد:

تسليم رأس مال السلم في مجلس العقد قبل المفارقة شرط، فلا يصح السلم حتى يقبض المسلم إليه رأس المال قبل أن يفارقه المسلم.

والمراد بالافتراق: المفارقة بالأبدان، سواء أكان رأس المال ديناً أم عيناً، ففي الحالتين يشترط القبض للآتي:

أولاً: إذا كان رأس المال من النقود مثل: الجنيهات والريالات، وافتراقاً قبل قبض رأس مال السلم، فإنه لا يصح؛ لأنه يكون افتراقاً عن دين بدين، وقد (نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الكالئ بالكالئ) (١) (أي النسيئة بالنسيئة).

ثانياً: إن كان رأس المال عيناً، كالتبر، والمصوغ، والثوب، والحيوان؛ فلا يصح أيضاً؛ لأن السلم أخذ عاجل بآجل، لأنه عقد يثبت الملك في الثمن عاجلاً، وفي المسلم فيه آجلاً، فاشتراط تعجيل رأس المال ليستحق به المعنى الذي وضع له الاسم، إذ الإسلام والإسلاف ينبئان عن التعجيل، فلا بد من قبض أحد العوضين ليتحقق معنى الاسم. فيجب أن يكون رأس المال عاجلاً ليكون حكمه على وفق ما يقتضيه اسمه، كما في الصرف والحوالة والكفالة. فإن هذه العقود تثبت أحكامها بمقتضيات أساميها لغة، فلا بد من قبض أحد العوضين ليتحقق معنى الاسم، أي اسم السلم أو السلف.

ثالثاً: ولأنه لا بد من تسليم رأس المال ليتقلب المسلم إليه فيه، أي ليتصرف أي في رأس المال، فيقدر على التسليم.

(١) . أخرجه الحاكم في المستدرک، والدارقطني في سننه، عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر، أن النبي صلى الله عليه وسلم: نهى عن بيع الكالئ بالكالئ، وقال: هو النسيئة بالنسيئة. قال الحاكم: حديث صحيح على شرط مسلم، ولم يخرجاه، انتهى. وغلطهما البيهقي، وقال: إنما هو موسى بن عبيدة. أنظر نصب الراية: باب الربا ٤٠/٤.

اشتراط قبض رأس المال في السلم هل هو: شرط صحة العقد أو شرط بقائه على الصحة

قبض رأس المال في عقد السلم، شرط بقاء العقد على الصحة، لا شرط الصحة، وعلى هذا فإن العقد ينعقد صحيحا بدون قبض، ثم يفسد بالافتراق لا عن قبض، وبقاء العقد صحيحا يعقب العقد ولا يتقدمه فيصلح القبض شرطا له، وسواء كان رأس المال ديناً أو عينا عند عامة العلماء استحساناً.

المطلب الثالث شروط السلم التي ترجع إلى المسلم فيه

يشترط في المسلم فيه شروطاً، منها:

الأول: أن يكون الجنس معلوماً: كقولنا: قمح أو شعير.

والثاني أن يكون النوع معلوماً: كقولنا: قمح مصري، أو أرز مصري، أو بسمتي.

الثالث: أن تكون الصفة معلومة: كقولنا: قمح جيد أو رديء.

الرابع: أن يكون المقدار معلوماً: كقولنا: كذا كيلاً بمكيال معروف، أو كذا وزناً بميزان

معروف.

والأصل في هذه الشروط، قوله ﷺ: (من أسلم منكم فليسلم في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم) (١)، فقد نص الحديث على شرطي: القدر المعلوم والأجل المعلوم، وثبت الباقي بالدلالة لظهور إرادة الضبط المنافي للمنازعة. والوجه في اشتراط هذه الشروط: هو الخروج من الجهالة المفضية إلى النزاع، والتي تقسد العقد.

الخامس: أن يكون المسلم فيه موجوداً من حين العقد إلى حين المحل:

هذا الشرط لفقهاء الحنفية. وعلى هذا فلا يجوز السلم حتى يكون المسلم فيه موجوداً في زمان العقد، وزمان محل التسليم، وفيما بينهما، وعلى هذا فما الحكم لو كان المسلم فيه منقطعاً عند العقد موجوداً عند المحل، أو على العكس، بأن كان موجوداً عند العقد، ومنقطعاً عند المحل، أو كان منقطعاً فيما بين وقت العقد ووقت المحل. وبيان ذلك في الحاليين الآتيين:

الأول: انقطاع المسلم فيه وقت الأجل، ووجوده عند المحل

(١) . سبق تخريجه.

إذا كان المسلم فيه منقطعا عند العقد موجودا عند المحل، لم يجز السلم عند فقهاء الحنفية.

ويرى الشافعي: أن السلم يجوز إذا كان المسلم فيه موجودا وقت المحل. وجه قول الشافعي: أن المسلم فيه مقدور التسليم حال وجوبه، وهو زمان حلول الأجل والعجز عن التسليم قيل ذلك لا يعتبر، لأنه ليس بأوان توجيه المطالبة. دليل الحنفية: استدلال الحنفية لقولهم، بالسنة والمعقول.

فأما السنة فقوله عليه السلام: (لا تسلفوا في الثمار حتى يبدو صلاحها)(١). وأما المعقول فوجهه: أن القدرة على تسليم المسلم فيه، تكون بتحصيل المسلم فيه، فلا بد من استمرار الوجود في مدة الأجل ليتمكن المسلم إليه من التحصيل، ولا يقدر المسلم إليه على اكتساب المنقطع.

الثاني: وجود المسلم فيه حين العقد، وانقطاعه عند المحل

لو انقطع المسلم فيه عند محل الأجل، بأن كان موجودا من وقت العقد إلى وقت حلول الأجل، فرب السلم بالخيار: إن شاء فسخ السلم، وإن شاء انتظر وجوده، وبه قال الشافعي في قول.

ووجهه: أن السلم قد صح، والعجز الطارئ على شرف الزوال، فصار كإباق المبيع قبل القبض.

وقال زفر: يبطل العقد (وبه قال الشافعي في قول، وهو رواية عن الكرخي)، ويسترد رأس المال للعجز عن التسليم، فصار كما لو هلك المبيع قبل القبض في بيع العين. الجواب عن قياس زفر: أجاب الحنفية عن قياس زفر المتنازع فيه، وهو (بطلان السلم للعجز عن التسليم، على بطلان البيع بهلاك المبيع، في بيع العين، للعجز عن التسليم)، وذلك بقولهم: بأن العجز عن التسليم إذا كان على شرف الزوال، لا يكون كالعجز بالهلاك، لأنه غير ممكن الزوال عادة، فكان القياس فاسدا.

حد انقطاع المسلم فيه

(١) . هذا الحديث أخرجه أبو داود وابن ماجه واللفظ له عن أبي إسحاق عن رجل، قال قلت لعبد الله بن عمر رضي الله عنه ... الحديث، وفي آخره: «ولا تسلفوا في نخل حتى يبدو صلاحها» انتهى.

وقال المنذري: في إسناده رجل مجهول، وذكره عبد الحق في "أحكامه" من جهة أبي داود وقال: إسناده منقطع. وأخرج الطبراني في "الأوسط" حديثا عن أبي هريرة وفي آخره «لا تسلموا في ثمرة حتى يأمن عليها صاحبها العاهة» م:

قال الفقيه أبو بكر البلخي: إن حد انقطاع المسلم فيه: أن لا يوجد المسلم فيه في سوقه الذي يباع فيه، وإن كان قد يوجد في البيوت.

المطلب الرابع **شروط السلم: التي ترجع إلى البدلين**

الأول: أن يكون السلم مؤجلاً

صورة السلم الحال أن يقول: أسلمت إليك عشرة آلاف جنيه في عشرة أرادب قمح، ولا يذكر الأجل.

فيرى فقهاء الحنفية: أن السلم لا يجوز في هذه الحالة، وأن السلم إلا مؤجلاً، فإن عقدا السلم حالا، فلا يجوز، وبه قال مالك وأحمد، رحمهما الله تعالى.

وقال الشافعي: يجوز السلم حالا ومؤجلاً. واستدل بما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم: (نهى عن بيع ماليس عند الإنسان، ورخص في السلم)، وجه الدلالة: أن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز السلم مطلقاً، فاشتراط التأجيل زيادة على النص.

والمعنى: من أراد سلماً مؤجلاً فليسلم إلى أجل معلوم، وبه نقول، والحصص ممنوع، وحينئذ لم يبق مفيداً فيحمل عليه المطلق، والدليل على ذلك قوله: (في كيل معلوم ووزن معلوم)، فإنه لا يجوز اجتماع الكيل والوزن في شيء واحد، فكان معناه في كيل معلوم إن كان كيلياً، ووزن معلوم إن كان وزنياً، فيقدر إلى أجل معلوم إن كان مؤجلاً.

أدلة الحنفية

استدل الحنفية لقولهم بالسنة والمعقول:

فأما السنة فقوله ﷺ: (من أسلم منكم فليسلم في كيل معلوم إلى أجل معلوم إلى أجل معلوم).

وأما المعقول فوجهه: أن السلم شرع رخصة دفعا لحاجة المفاليس، فلا بد فيه من الأجل ليقدر المسلم على التحصيل فيه فيسلم المعقود عليه، ولو كان قادراً على التسليم في الحال لم يوجد المرخص، لأن الرخصة شرعت لعذر مع قيام المانع، وهو بيع المعلوم والعذر هو العجز عن التسليم، ولو قدر على تسليمه لم يوجد المرخص. فبقي على النافي وهو قوله عليه الصلاة والسلام: (لا تبع ما ليس عندك).

جواب الحنفية عند استدلال الشافعي

أجاب الحنفية عن استدلال الشافعي بإطلاق الحديث، بأن قضية العقد كفت مؤنة التمييز، فلا حاجة إلى التقدير؛ لأنه خلاف الأصل، لأن قوله: رخص في السلم يدل على جوازه بطريق الرخصة، وهي إنما تكون لضرورة، ولا ضرورة في السلم الحال.

اعتراض: اعترض الشافعية على قول الحنفية: أن السلم شرع لحاجة المفاليس، بقولهم: لا نسلم بأن شرعية السلم دفعا لحاجة المفاليس، فلو كانت شرعية السلم دفعا لحاجة المفاليس، لاختص السلم بحالة الإفلاس؛ لأنه ثبت على خلاف القياس، فيقتصر عليه، وليس كذلك، ألا ترى أنه يجوز للشخص بيع الحنطة سلما ولو كان عنده أكرار حنطة.

جواب الحنفية على الاعتراض: وقد أجاب الحنفية على الاعتراض بقولهم: إن الشيء لا يباع سلما إلا بأدنى الثمنين، والتاجر لا يبيع إلا للربح، فكان البيع بأدنى للتمييز على أنه لا يبيع إلا للعجز عن الربح، ولا عجز إلا بأن يجعل ما عنده مستغرقا لحاجته.

ولأن حقيقة العدم أمر باطني لا يمكن الوقوف عليه حقيقة، والشرع بنى هذه الرخصة على العدم، فبيني على السبب الظاهر الدال على العدم، ليتمكننا تعليق الحكم به والبيع بالخسران دليل العدم.

الشرط الثاني: أن يكون الأجل في السلم معلوما

تبين مما سبق أن السلم لا يصح إلا مؤجلا، وحتى يتم إعمال هذا الشرط، اشترط أن يكون الأجل معلوما، فلا يصح السلم إلا بأجل معلوم، وبه قال الشافعي وأحمد. وقال مالك: يجوز الأجل إلى الحصاد، لعدم إفضائه إلى المنازعة غالبا.

دليل اشتراط العلم بالأجل

يستدل لشرط العلم بالأجل، بالسنة، والمعقول.

فأما السنة: فقوله صلى الله عليه وسلم: (من أسلم منكم ... إلى أجل معلوم).

وأما المعقول: فلأن الجهالة في السلم مفضية إلى المنازعة، كما في البيع، وهي مفسدة للعقد.

أقل الاجل: والأجل أدناه شهر، وقيل: ثلاثة أيام، وقيل: أكثر من نصف اليوم، والأول أصح.

الشرط الثالث: أن يكون السلم بمعيار معلوم

خروجاً من الجهالة عند تسليم المسلم فيه، فإنه يشترط أن يكون المعيار معلوماً، سواء أكان المعيار: مكيالاً، أو ميزاناً، أو ذراعاً، ففي حالة الكيل، لابد أن يكون بمكيال معلوم، وكذلك في حالة الوزن، والذرع، فلا يجوز السلم بمكيال رجل بعينه، ولا بذراع رجل بعينه، لا يعرف مقداره؛ ولا بحجر لا يعرف وزنه، لأن تسليم المسلم فيه يتأخر، فربما يضيع المعيار فيعجز عن التسليم، فيؤدي إلى المنازعة.

ويشترط في المكيال: أن يكون المكيال مما لا ينقبض ولا ينبسط كالقصاص مثلاً، فإن كان ما ينكبس بالكبس كالزنبيل والجراب لا يجوز الطكيل به للمنازعة، إلا في قرب الماء للتعامل فيه، كذا روي عن أبي يوسف.

كذلك لا يجوز في طعام قرية بعينها؛ أو ثمرة نخلة بعينها؛ لأنه قد يعتريه آفة فلا يقدر المسلم إليه على التسليم، وإليه أشار صلى الله عليه وسلم، بقوله: (أرأيت لو أذهب الله تعالى الثمر بم يستحل أحدكم مال أخيه؟).

الشرط الرابع: بيان مكان الإيفاء

أولاً : بيان مكان الإيفاء إن كان للمسلم فيه حمل ومؤنة

اختلف فقهاء الحنفية في بيان المكان الذي يوفي فيه المسلم فيه إذا كان له حمل، (بالفتح أي ما له ثقل يحتاج في حمله إلى ظهر وأجرة حمال)، ومؤنة (أي كلفة). فيرى الإمام أبي حنيفة: أنه يشترط بيان مكان إيفاء المسلم فيه، وأن السلم لا يصح إذا لم يبين مكان تسليم المسلم فيه.

ويرى: أبو يوسف ومحمد -رحمهما الله- : أن العاقدين في السلم لا يحتاجان إلى بيان مكان التسليم، ويصح تسليم المسلم فيه في موضع العقد، وبه قال أبو حنيفة أولاً والشافعي -رحمهم الله- في الأصح واختاره المزني.

وجه قول أبي يوسف ومحمد -رحمهما الله-: يرى صاحبان عدم الجواز لأمرين: الأول: أن سبب وجوب الإيفاء هو العقد، والعقد وجد في هذا المكان، فيتعين مكان العقد للإيفاء، كما في بيع العين، فإن التسليم يجب في موضع العقد، وصار كالقرض والغصب، فإنه يتعين مكان القرض والغصب للتسليم بالإجماع.

الأمر الثاني: أن مكان العقد لا يزاحمه مكان آخر فيه، فيصير نظير أول أوقات الإمكان في الأوامر، وما كان كذلك يتعين.

وجه قول أبي حنيفة - رحمه الله - : يرى الإمام أبو حنيفة: أن مكان العقد لا يصلح للإيفاء إذا لم يبين عند العقد، لأمرين:

الأمر الأول: أن العقد وجد مطلقا عن تعيين مكان الإيفاء، فلا يتعين مكان العقد للإيفاء، والدليل على إطلاق العقد عن تعيين مكان الإيفاء: شيئان: الحقيقة، والحكم.

أما من حيث الحقيقة: فلأنه لم يوجد ذكر لمكان التسليم في العقد نصا، فالقول بتعيين مكان العقد للإيفاء شرعا من غير تعيين العاقلين، تقييد المطلق، ولا يجوز إلا بدليل.

وأما من حيث الحكم: فإن العاقلين لو عينا مكانا آخر جاز، ولو كان تعيين مكان العقد من مقتضيات العقد شرعا، لكان تعيين مكان آخر تغييرا لمقتضى العقد، وإنه يعتبر فيه حكم الشرع، فينبغي أن لا يجوز.

وعلى هذا: إذا لم يتعين مكان العقد للإيفاء، بقي مكان الإيفاء مجهولا جهالة مفضية إلى المنازعة؛ لأن في الأشياء التي لها حمل ومؤنة تختلف باختلاف الأمكنة، لما يلزم في حملها من مكان إلى مكان آخر من المؤنة، فيتنازعان.

الأمر الثاني: أن التسليم غير واجب في الحال لاشتراط الأجل بالاتفاق، وكل ما هو تسليمه غير واجب في الحال، فلا يتعين مكان العقد فيه للتسليم.

جواب أبي حنيفة عن قياس صاحبين تسليم المسلم فيه في السلم على: القرض والغصب:

أجاب أبوحنيفة عن قياس صاحبين يقوله: إن تسليم المسلم فيه في السلم، يختلف عن القرض والغصب، والاستهلاك، فإن تسليمها يستحق بنفس الالتزام، فيتعين موضعه، وإذا لم يتعين مكان العقد للإيفاء بقي مكان الإيفاء مجهولا؛ لأن قيم الأشياء تختلف باختلاف المكان ورب السلم يطالبه في موضع يكثر فيه الثمن، والمسلم إليه يسلمه في اختلاف القيم ذلك، فلا بد من البيان دفعا للمنازعة، فصار كجهالة الصفة فإن باختلاف الصفة في المسلم فيه تختلف القيمة، فكذاك باختلاف المكان تختلف أيضا، ثم مع جهالة الصفة لا يجوز السلم، فكذاك لا يجوز مع جهالة المكان لهذا المعنى فلا بد من البيان.

ثانيا: بيان مكان إيفاء المسلم فيه فيما ليس له حمل ومؤنة

ما ليس له حمل ومؤنة: ما كان خفيفا يمكن للشخص حمله دون مشقة: كالمسك، والكافور، والزعفران، وصغار اللؤلؤ. وقيل هو الذي لو أمر إنسانا بحمله إلى مجلس القضاء، يحمله مجانا، وقيل: هو ما يمكن رفعه بيد واحدة.

وما ليس له حمل ومؤنة، لا يحتاج فيه إلى بيان مكان الإيفاء بإجماع الأئمة الأربعة وتلاميذهم.

لأنه لا تختلف قيمته، ويوفيه في المكان الذي أسلم فيه، وقيل يوفيه في أي مكان شاء، وهو الأصح؛ لأن الأماكن كلها سواء، ولا وجوب في الحال. ولو عينا مكانا، قيل لا يتعين؛ لأنه لا يفيد. وقيل: يتعين؛ لأنه يفيد سقوط خطر الطريق.

ولو عين المصر فيما له حمل ومؤنة، فيكتفى به، لأنه مع تباين أطرافه كبقعة واحدة فيما ذكرنا.

المبحث الثالث

ما يجوز السلم فيه وما لا يجوز

المطلب الأول

السلم في المثليات

المراد بالمثليات: المثلي: هو كل ما له مثل في السوق، من: المكيلات، والموزونات، كالقمح والشعير، والأرز، والذرة، أو نحو ذلك، والمعدودات، وكذلك المتقاربة التي لا تتفاوت أحادها، كالبيض، والجوز، والبرتقال، أو نحوها.

الفرع الأول: السلم في المكيلات والموزونات

المراد: بالمكيلات والموزونات التي يجوز فيها السلم

أولاً: المراد بالمكيلات التي يجوز فيها السلم

المراد بالمكيلات التي يجوز فيها السلم: المكيلات المختلفة الجنس والقدر، أي التي لا تجمع بيت المسلم فيه ورأس المال على ربا النساء، وعلى ذلك فلا يجوز إسلام قمح في شعير، أو العكس، ولا قمح في ذرة، أو شعير في ذرة، أو العكس، وهكذا في سائر المكيلات التي يجمع بينها أحد أوصاف علة ربا الفضل.

وعلة ربا النساء كما سبق بيانه، هي القدر المتفق والجنس المتحد. فالقمح والشعير وإن لم يجمع بينهما الجنس، فإن القدر وهو الكيل يجمع بينهما. وإذا كان لا يجوز إسلام القمح في الشعير أو الذرة، فمن الأولى أن لا يجوز إسلام القمح في القمح ولا الشعير في الشعير، وإن اختلف النوع كقمح مصري بقمح روسي، أو شعير مصري بشعير مغربي، أو أرز مصري بأرز بسمتي، وهكذا. فيشترط أن لا يجمع بين الثمن والمثلن (المسلم والمسلم فيه) أحد وصفي علة ربا الفضل.

أمثلة على إسلام المكيلات والموزونات

لو أسلم زيد عشرة آلاف جنيه في عشرة أرادب قمح إلى ستة شهور، فإن هذا سلم جائز بلا اختلاف بين الفقهاء؛ لأن الثمن من الموزونات، والمثمن من المكيلات، فلا مانع من الجواز، حيث لاتجمع بين الثمن والمثمن علة الربا لا الفضل ولا النسيئة.

وكذلك لو أسلم عشرة آلاف جنيه في عشرة أرادب من الشعير، إلى ستة شهور، فإنه سلم جائز بلا اختلاف بين الفقهاء أيضا؛ لأن الثمن من الموزونات، والمثمن من المكيلات، فلا مانع من الجواز، حيث لاتجمع بين الثمن والمثمن علة الربا لا الفضل ولا النسيئة.

لو أسلم عشرة أرادب قمح في خمسة عشر أردبا من الشعير، إلى ستة شهور، فإنه لايجوز؛ لأن الثمن من المكيلات والمثمن من المكيلات، فقد اتفق القدر بينهما وهو الكيل، وهو أحد أو صاف علة ربا الفضل التي تحرم النساء.

لو اسلم عشرة أرادب قمح مصري بعشرة أرادب قمح فرنسي، إلى ستة شهور، فإنه لايجوز؛ وذلك لأن الثمن والمثمن من جنس واحد، واتحاد الجنس يحرم النساء، لأنه أحد اوصاف

علة ربا الفضل التي تحرم النساء.

ثانيا: المراد بالموزونات التي يجوز السلم فيها

المراد بالموزونات التي يجوز السلم فيها في الحديث، الموزونات من غير الدراهم والدنانير؛ لأن الدراهم والدنانير أثمان، والمسلم فيه لا بد أن يكون مثمنا، فلا يصح السلم فيها. ثم قيل: يكون باطلا.

صورة المسألة

وصورته أن يسلم طنا من الأرز، أو عشرة أرادب من القمح، في عشرة آلاف جنيه، فهذا جائز.

أما لو أسلم عشرة أواقي من الفضة، في عشر جرامات من الذهب، فإنه لا يجوز بالإجماع؛ لأنه من الربا المحرم.

ضابط معرفة المكيل والموزون

ذهب أبو حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى إلى القول بأن: كل شيء نص رسول الله ﷺ على تحريم التفاضل فيه كيلا، فهو مكيل أبدا، وإن ترك الناس الكيل فيه، مثل: الحنطة، والشعير، والتمر، والملح.

حاصله: أن ما كان مكيلا على عهد رسول الله ﷺ، لا يغير أبداً عن ذلك، بل يعتبر ما كان مكيلا في عهده.

ويشترط فيه التساوي بالكيل ولا يلتفت إلى التساوي في الوزن دون الكيل، حتى لو تساوى الحنطة بالحنطة وزنا لا كيلا لم يجز.

وكل ما نص أي رسول الله ﷺ: على تحريم التفاضل فيه وزنا، فهو موزون أبداً، وإن ترك الناس الوزن فيه، مثل: الذهب، والفضة، كذلك يعتبر فيه التساوي بالكيل دون الوزن، حتى لو تساوى الذهب بالذهب كيلا لا وزنا، لم يجز.

وكذلك الفضة بالفضة، وذلك لأن طاعة النبي ﷺ واجبة علينا، لأن النص أقوى من العرف، لكون النص حجة على من تعارف وعلى من لم يتعارف، والمعروف ليس بحجة إلا على من تعارف به، والأقوى لا يترك بالأدنى.

وما لم ينص من النبي ﷺ عليه، فهو محمول على عادات الناس؛ لأن العادات دالة على جواز الحكم فيما وقعت عليه العادة، لقوله ﷺ: (ما رآه المسلمون حسناً فهو عند الله حسن)، وقوله ﷺ: (لا تجتمع أمتي على الضلالة).

وروي عن أبي يوسف رحمه الله: أنه يعتبر العرف على خلاف المنصوص عليه أيضاً؛ لأن النص على ذلك أي على الكيل في المكيل والوزن في الموزون، في ذلك الوقت إنما كان، لمكان العادة فيه، فكانت العادة هي المنظور إليها في ذلك الوقت، وقد تبدلت أي تلك العادة، فيجب أن يكون الحكم على وفاق ذلك.

فعلى هذا: لو باع الحنطة بجنسها متساوياً وزناً، أو باع ذهباً بجنسه متماثلاً كيلاً، لا يجوز عند أبي حنيفة، ومحمد رحمهما الله، وإن تعارفوا ذلك، وكلمة إن واصله بما قبلها.

وعند أبي يوسف رحمه الله: يجوز إذا تعارفوا ذلك، لتوهم الفضل.

حكم السلم في المكيلات والموزونات

السلم في المكيلات والموزونات، وكذلك العكس، جائز بلا خلاف بين الفقهاء، لقوله عليه الصلاة والسلام: (من أسلم منكم فليسلم في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم) (١)، معناه إذا أسلف أحدكم في كيل، فليسلف في كيل معلوم، وإن أسلف فليسلف في وزن معلوم، وإذا سمى أجلاً فليسلم في أجل معلوم.

(١) . سبق تخريجه.

وعلى ذلك: فإسلام المكيل في الموزون جائز بلا خلاف بين الفقهاء، بشرط أن لا يجمع بين الثمن والمثمن (المسلم والمسلم فيه) أحد وصفي علة ربا الفضل.

الفرع الثاني: السلم في العدديات المتقاربة

المراد بالعددي المتقارب: هو الذي لاتفاوت بين أحاده، ولو كان هناك تفاوت فهو غير معتبر، والعددي المتقارب مثل: البيض، والجوز، واللوز، وغيرهما من العدديات المتقاربة، ولو وجد تفاوت بين بيضة وبيضة فهو تفاوت يسير لا يعتد به عرفاً، ولا يكون له مقابل من الثمن في البيع.

حكم السلم في المعدودات المتقاربة

يجوز السلم في المعدودات التي لا تتفاوت، كالجوز والبيض؛ لأن العددي المتقارب معلوم، مضبوط الوصف، مقدور التسليم، فيجوز السلم فيه، والصغير والكبير فيه سواء باصطلاح الناس على إهدار التفاوت.

واستثنى الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى السلم في بيض النعام، فقال بأنه لا يجوز السلم في بيض النعام؛ لأن أحاده يتفاوت في المالية.

أمثلة على السلم في المعدود المتقارب

لو أسلم زيد إلى علي، ألف جنيه في ثلاثمائة بيضة، إلى ثلاثة شهور، فإنه يجوز، لأن الثمن معلوم، و(المثمن)المسلم فيه معلوم ومضبوط بالوصف، والأجل معلوم، ولا يجمع بين الثمن والمثمن أحد أوصاف على ربا الفضل، فيجوز السلم بلا خلاف.

لو أسلم سعد إلى محمد، ألف جنيه في مائة جوزة، إلى خمسة شهور، فإنه يجوز السلم في هذه الحالة، فكما جاء في المثال السابق؛ لأن الثمن معلوم، و(المثمن)المسلم فيه معلوم ومضبوط بالوصف، والأجل معلوم، ولا يجمع بين الثمن والمثمن أحد أوصاف على ربا الفضل، فيجوز السلم بلا خلاف.

الفرع الثالث

السلم في العددي المتفاوت

المراد بالعددي المتفاوت: هو ما لايمكن ضبطه ضبطاً يمنع من الجهالة، حيث يكون التفاوت بين أحاده بعد الوصف فاحشاً، ويكون معتبراً في الثمن عند تقديره، وله مقابل فيه، مثل البطيخ، والرمان، وغيرهما مما تتفاوت أحاده تفاوتاً فاحشاً، فالتفاوت بين بطيخة وبطيخة معتبر وله مقابل في الثمن. فبطيخة تباع بخمسين جنيه، وبطيخة تباع بعشرين، وهكذا.

حكم السلم في العددي المتفاوت

لاخلاف بين فقهاء الحنفية، في أنه لا يجوز السلم في العددي المتفاوت، كالبطيخ والرمان؛ لأنه يتفاوت أحاده تفاوتاً فاحشاً، فإنك ترى بطيخاً بدرهم وبطيخاً بدرهمين.

أمثلة على السلم في العددي المتفاوت

لو أسلم بكر ألف جنيه في خمسين بطيخة، إلى ستة أشهر، فإنه لايجوز؛ وذلك لأن المسلم في وهو البطيخ، تتفاوت أحاده فلا يمكن ضبطه ضبطاً يمنع من الجهالة.

لماذا يجوز السلم في المكيلات والموزونات والمعدودات المتقاربة

يجوز السلم في المثليات من: المكيلات والموزونات والمعدودات المتقاربة؛ لأمرين:

الأول: أنه يمكن ضبط المكيل والموزون ضبطاً دقيقاً يمنع من الجهالة، ولو بقي تفاوت فهو تفاوت غير معتبر، ولا يعتد به عرفاً، ولا يقابل بالثمن.

الأمر الثاني: أن المسلم فيه إذا هلك، أمكن الحصول على مثله من السوق، بالأوصاف التي تم التعاقد عليها بين رب السلم والمسلم إليه.

السلم في الجواهر

لا يجوز السلم في الجواهر، نحو الياقوت، والبلخش، واللؤلؤ، ونحو ذلك، ولا يجوز السلم أيضاً في الخرز (بفتح الخاء والراء ثم الزاي) (١)؛ لأن كل أحاده تتفاوت في المالية، فلا يجوز السلم فيه كالبطيخ والرمان.

أما الذي لا تتفاوت أحاده في المالية، فيجوز السلم فيه، كالجوز، والبيض إذا كان من جنس واحد.

وفي صغار اللؤلؤ التي تباع وزناً، يجوز السلم فيها؛ لأنها مما يعلم بالوزن، لأنها تدق وتجعل في الدواء ولا خلاف فيها للفقهاء.

السلم في الآجر

لا بأس بالسلم في الآجر (٢)، واللبن (٣)، إذا سمي ملبناً معلوماً، (الملبن يحتمل أن يكون اسم ما يصنع فيه اللبن، ويحتمل أن يكون المراد به الآلة).

وقيل يشترط بيان مكان الملبن والآلة، وقيل: لا يشترط بيان مكانه، وبه قال الشافعي رحمه الله؛ لأن كل واحد من الآجر واللبن، عددي متقارب لا سيما إذا سمي الملبن.

(١) . الخرز بالتحريك الذي ينظم، والواحدة خرزة، وخرزات الملك جواهر تاجه

(٢) . بفتح الهمزة وضم الجيم وتشديد الراء وهو الطوب المشوي

(٣) . اللبن: بفتح اللام وكسر الباء الموحدة وبالنون، وهو الطوب النيئ.

ضابط العددي المتفاوت والمتقارب

الضابط في معرفة العددي المتفاوت عن المتفاوت، هو تفاوت الآحاد في المالية، أي بتفاوت آحاد العددي في المالية دون الأنواع، وتفاوت الآحاد في المالية يعرف العددي المتفاوت، فكل ما يتفاوت أحاده في المالية، فهو متفاوت، ومالا فلا.

رأي الإمام الشافعي في السلم في العددي يرى الشافعي رحمه الله تعالى: أنه يجوز السلم في كل المعدودات، المتقاربة والمتفاوت وزنا، وهل يجوز كيلا له، فيه وجهان.

وقال في الجوز واللوز: يجوز وزنا ولا يجوز كيلا، ولا يكفي عند الشافعية العد في المعدودات، بل لا بد من ذكر الموزون.

الفرع الرابع: السلم في الذرعات

المراد بالذرعات: الذرعي هو ما يقاس بالذراع، وهوما يقاس بالمتري في عصرنا، كسائر أنواع الأقمشة، والموكيت، أونحو ذلك.

حكم السلم في الذرعات

أجاز الحنفية السلم في الذرعات، واستدلوا على جواز السلم في الذرعات، بالإجماع، ودلالة النص، والاستحسان.

أولا الإجماع: فأما الإجماع فقد أجمع الفقهاء على جواز السلم في الذرعات؛ لأنه يمكن ضبطها بذكر الذرع أي: طولاً وعرضاً، والصفة والصناعة، ولا بد من ذكر هذه الأمور لترتفع الجهالة، فيتحقق شرط صحة السلم، والتفاوت ليسير بعدها غير معتبر؛ لأنه لا يفضي إلى المنازعة المانعة من التسليم والتسلم.

ثانياً دلالة النص: ووجهها: أن المذروعات ألحقت بالمكيلات والموزونات بدلالة النص، لأن قوله عليه السلام: (من أسلم منكم.. الحديث)، يقتضي الجواز في: المكيلات والموزونات، باعتبار التسوية في التسليم على ما وصف في المسلم فيه، والتسوية تتحقق في المذروعات، فيجوز إلحاقها بهما بطريق الدلالة.

ثالثاً الاستحسان: ووجهه: أن الذرعات مصنوع العبد، والعبد يصنع بالآلة، فإذا اتحدت الآلة والصانع فإنه يتحد المصنوع، فلا يبقى بعد ذلك إلا قليل تفاوت، وذا يحتمل في المعاملات دون الاستهلاكات، ألا ترى أن الأب إذا باع مال ولده الصغير بغبن يسير كان متحملاً، ولو استهلك شيئاً يسيراً يجب عليه ضمانه.

والقياس: أن لا يجوز السلم في المذروعات: كالثياب، والحصر، والبواري.
وجه القياس: هو تعذر قبول هذا الأشياء في الذمة، ولهذا لا يضمن بالمثل بالاستهلاك
كالجواهر، لكن ترك ذلك بإجماع الفقهاء.

مناقشة الاستدلال بإلحاق الذرعيات بالمكيلات والموزونات، بدلالة النص
يقول البعض: إنما يجوز العمل بالدلالة إذا لم تعارضه عبارة النص، وهاهنا عبارة قوله
عليه أفضل الصلاة والسلام: (لا تبع ما ليس عندك)، نافية لإلحاقها بهما، لأن تلك العبارة
لما خصصت بالكيلى والوزنى بالحديث، انحصر الجواز فيهما وبقي ما وراءهما تحت نفي
عبارة قوله عليه السلام: لا تبع ... الحديث، والمذروع فيما وراءهما فلا يصح العمل بالدلالة.

الجواب

إن ما ذكرتموه حجة عليكم، لأن العام من الكتاب إذا خص منه البعض، لا يبقى الباقي
حجة أصلا عند الكرخي، فيكيف في السنة؟!، وعلى القول المختار إن بقي حجة ولكن مرتبته
دون مرتبة القياس، وخبر الواحد، ولا شك أن دلالة النص أقوى من القياس وخبر الواحد، فلم
يكن ذلك العام معارضا للدلالة، فبقيت الدلالة سالمة عن المعارض، فيجوز السلم في
الذرعيات.

أمثلة على السلم في الذرعيات

السلم في الثياب

السلم في الثياب جائز، إذا بين العاقدان المسلم فيه، من حيث: الطول، ومن حيث
العرض، ومن حيث الغلظة والثخانة؛ لأن السلم الإسلام في معلوم مقدور التسليم، وهو
متحقق في المذروعات.

وإن كان المسلم ثوب حرير، فلا بد من بيان وزنه أيضا؛ لأن الوزن مقصود في السلم في
الثوب الحرير، وإذا كان كذلك فلا بد من بيان الوزن.
وعند الشافعي ومالك وأحمد رحمهم الله: بيان الوزن ليس بشرط.

المطلب الثاني

السلم في القيميات

المراد بالقيميات

جاء في التعريفات الفقهية أن القيمي: غير المثلي وهو شرعا، ما لا يوجد له مثل في السوق، أو يوجد لكن مع التفاوت المعتد به في القيمة (١).

وجاء في معجم الفقهاء: أن القيمي: بكسر القاف والميم وتشديد الياء، نسبة إلى لفظ القيمة. ما ليس له مثل متداول بين الناس (٢).

القيمي: هو غير المثلي، كالعروض، والحيوانات، والعددي المتفاوت (٣)؛ وهو الذي تجب فيه القيمة عند الهلاك، أو يضمن بالقيمة عند الهلاك؛ لأنه لا مثل.

السلم في الحيوان

اختلف الحنفية والشافعي في حكم السلم في الحيوان، فالحنفية يرون: أنه لا يجوز السلم في الحيوان، سواء كان دابة أو رقيقا، وبه قال: الثوري، والأوزاعي، ويرى الشافعي: جواز السلم في الحيوان.

وجه قول الشافعي: أن المسلم فيه يصير معلوما ببيان: الجنس بأن يقول إبل، والسن بأن يقول: بنت مخاض أو جذع، أو نحو ذلك، والنوع بأن يقال: بختي أوعربي، والصفة بأن يقال: سمين أو هزيل، وبعد بيان تلك الأمور يكون التفاوت يسيرا فأشبهه الثياب.

وقد ثبت: (أن النبي ﷺ أمر عمرو بن العاص أن يشتري بعيرا ببعيرين في تجهيز الجيش إلى أجل)، وأنه عليه السلام استقرض بكرا وقضاه رباعيا) والسلم أقرب إلى الجواز من الاستقراض.

وجه قول الحنفية: أنه بعد ذكر: الجنس، والسن، والنوع، والصفة، يبقى فيه الحيوان تفاوت فاحش في المالية، وذلك باعتبار المعاني الباطنة، كالصباحة، والملاحاة، والخلق الحسن، والذهن، والكياسة، وحسن الشهرة، والهملجة في الدواب (سرعة المشي)، وغير ذلك، فإنك ترى عبيدين متفقين في الأوصاف المذكورة، ومع ذلك يساوي أحدهما ألفا وآخر لايساويها.

الجواب على القياس على الثياب

أجاب الحنفية على قياس الشافعي الحيوان على الثياب في جواز السلم فيه، بأن هذا القياس غير صحيح، لأن الثياب؛ مصنوع العباد، فقلما يتفاوت الثوبان إذا نسجا على منوال

(١) . التعريفات الفقهية ، مادة :

(٢) . معجم الفقهاء: ص ٣٧٤.

(٣) . التجريد للقدوري : ٢٦٣/٢.

واحد، لأن العبد إنما يصنع بآلة، فإذا اتحد الصانع والآلة، اتحد المصنوع، ولا يتفاوت في المالية إلا يسيرا، ولا يعتبر بذلك القدر.

والحيوان صنع الله تعالى، وذلك يكون على ما يريده تعالى، فقد كان على وجه لا يوجد له نظير، وفي مثله لا يجوز.

السلم في اللحم

اختلف فقهاء الحنفية في السلم في اللحم، فيرى الإمام أبي حنيفة: أن السلم في اللحم لا يجوز.

ويرى أبو يوسف ومحمد: جوازه، إذا بين: جنسه، ونوعه، وصفته، وقدره، وسنه، وموضعه.

وجه قول صاحبين: أن الفساد لمكان الجهالة، وقد زالت ببيان هذه الأشياء، ولهذا كان مضمونا بالمثل في ضمان العدوان.

وجه قول أبي حنيفة: أن الجهالة تبقى بعد بيان ما ذكر، من جهتين:

إحداهما: من جهة السمن والهزال.

والثانية: من قلة العظم وكثرته. وكل واحدة منهما مفضية إلى المنازعة.

السلم في أطراف الحيوان

لا يجوز السلم في أطراف الحيوان، كالرؤوس والأكارع (١) للتفاوت فيها، إذ هو عددي متفاوت لا مقدار لها. أي لا مقدر له، لاختلافها بالصغر والكبر والسمن والهزال، وتذكير الضمائر باعتبار المذكور، وبقولنا قال الشافعي في الأظهر.

السلم في الجلود عدد

كذلك لا يجوز السلم في الجلود عددا، لأن فيها الصغير والكبير، فيفضي السلم فيها إلى المنازعة، ولا يتوهم أنه يجوز وزنا، لأن معناه أنه عددي، فحيث لم يجز عددا لم يجز وزنا بالطريق الأولى؛ لأنه لا يوزن عادة، وبه قال الشافعي رحمه الله في الأظهر،

وقال مالك وأحمد في قول: يجوز السلم في الجلود والرؤوس والأكارع عددا أو وزنا.

السلم في الإلية

يجوز السلم في الشحم والإلية وزنا بالإجماع؛ لأنه موزون معلوم الوصف، ولأنه لا يختلف بالسمن والهزال إلا يسيرا.

(١) . هو جمع كراع الشاة والبقر، ويجمع على كراع أيضا

أمثلة مختلفة

السلم في السمك المالح

يجوز السلم في السمك المالح وزنا معلوما وضربا معلوما؛ بعد أن يكون في حيزه، لأنه: معلوم القدر، مضبوط الوصف، مقدور التسليم، إذ هو غير منقطع، ولا يجوز السلم فيه عددا للتفاوت بين أحاده. ويجوز في الصغار منه كيلا، لأن الصغار منه لا يتحقق فيه اختلاف السمن والهزال ولا اختلاف العظم.

والصحيح من المذهب أن السلم يجوز في السمك الصغار وزنا وكيلا، ويستوي فيه المالح والطري في حينه، وفي رواية أخرى عنهما لا يجوز.

وأما السلم في السمك الكبار، ففيه روايتان عن أبي حنيفة في ظاهر الرواية، إحداهما يجوز كيفما كان، وفي رواية أبي يوسف في كتب "الأمالى" عنه، أنه لا يجوز، وعلى قول أبي يوسف ومحمد، يجوز في ظاهر الرواية كما في اللحم.

السلم في السمك الطري

السلم في السمك الطري لايجوز إلا في حينه وزنا معلوما وضربا معلوما؛ لأنه ينقطع في زمان الشتاء، حتى لو كان في بلد لا ينقطع يجوز مطلقا، وإنما يجوز وزنا لا عددا للتفاوت بين أحاده.

السلم في الحطب والبرسيم

لا يجوز السلم أيضا في الحطب من حيث الحزم، وهو جمع حزمة، وذلك لأنه مجهول من حيث طوله وعرضه وغلظه، فإن عرف ذلك جاز، ولا يجوز السلم أيضا في الرطبة من حيث الجرز بضم الجيم وفتح الراء بعدها الزاي، أي جمع جرزة، وهي أي الحزمة والرطبة هي التي تسميها أهل مصر برسيمًا.

ضابط ما يجوز السلم فيه وما لا يجوز

كل ما أمكن ضبط صفته ومعرفة مقداره جاز السلم فيه؛ لأنه لا يفضي إلى المنازعة، وما لا تضبط صفته ولا يعرف مقداره، لا يجوز السلم فيه؛ لأنه دين، والدين يعرف بوصفه، وبدون الوصف يبقى مجهولا جهالة تقضي إلى المنازعة، فلا يجوز لأن جهالة المعقود عليه تفسد العقد.

وذلك كما في الأجناس الأربعة من: المكيلات، والموزونات، والمذروعات، والعديدات المتقاربة.

وعلى هذا فالسلم جائز في: المكيلات والموزونات، لقوله عليه الصلاة والسلام: (من أسلم منكم فليسلم في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم) (١)، معناه إذا أسلف أحدكم في كيل، فليسلف في كيل معلوم، وإن أسلف فليسلف في وزن معلوم، وإذا سمى أجلا فليسلم في أجل معلوم.

وقد ألحق الفقهاء المعدود المتقارب، والمذروع بالمكيل والموزون، بجامع إمكان ضبطهما ضبطا يمنع من الجهالة التي تفسد العقد.

قال الكاكي: لاختلاف للفقهاء في جواز السلم في كل ما هو من ذوات الأمثال، كالقطن، والكتان، والإبريسم، والنحاس، والتبر، والحديد، والرصاص، والصفرة، والحناء، والوسمة، والرياحين اليابسة.

هذا أصل كلي يتخرج منه المسائل.

وفي الجدوع: البائن الطول، والعرض، والغلط، وكذا الساج، وصنوف العيدان، والخشب، والقصب، والغزل، ويجوز السلم في التبن كيلا وكيله الغرائر، وقيل: إنه موزون، وقيل: المعتبر هو المتعارف.

وما لا يضبط صفته ولا يعرف مقداره لا يجوز السلم فيه؛ لأن السلم دين، والدين يعرف بوصفه، وبدون الوصف يبقى مجهولا جهالة تقضي إلى المنازعة، فلا يجوز؛ لأن جهالة المعقود عليه تفسد العقد.

(١) . سبق تخريجه.

المبحث الرابع التصرف في رأس مال السلم، والمسلم فيه المطلب الأول التصرف في رأس مال السلم

التصرف في رأس مال السلم قبل القبض لايجوز، وهذا باتفاق الفقهاء؛ وذلك لما فيه من تفويت القبض المستحق بالعقد؛ لأن قبض رأس المال في المجلس حق الله تعالى، والتصرف يبطله، وإنما شرط القبض احترازاً عن الكالئ بالكالئ، فلو جاز التصرف فيه بالبيع، والهبة، والوصية، ونحوها فأت الشرط، فيفسد العقد. وكذلك لايجوز الإبراء عن رأس المال؛ لأنه مستحق القبض حقا للشرع، فلا يملك إسقاطه بنفسه بالإبراء.

شراء رب السلم شيئاً برأس المال بعد الإقالة

إذا تقايل العاقدان السلم، لم يكن لرب السلم أن يشتري من المسلم إليه برأس المال شيئاً، حتى يقبضه كله، استحساناً؛ لقوله عليه السلام: (لا تأخذ إلا سلمك أو رأس مالك) (١) أي عند الفسخ.

صورة المسألة فيه

رجل أسلم إلى رجل عشرة دراهم في أردب قمح، ثم تقايل السلم، فأراد رب السلم أن يشتري برأس المال شيئاً قبل أن يقبضه، ليس له ذلك ولا يجوز شراؤه. وقال زفر والشافعي يجوز، وهو القياس؛ لأنهما لما تقايل بطل السلم، وبقي رأس المال ديناً في حصته، فيصح الاستبدال به كسائر الديون؛ لأنه لا يجب قبضه في المجلس. واستدل الحنفية بقول النبي ﷺ: (لا تأخذ إلا سلمك أو رأس مالك)، وبما روي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: (من أسلم في شيء فلا يصرفه إلى غيره) (٢).

(١) . أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه، إباب من كره أن يأخذ بعض سلمه وبعضاً طعاماً، برقم: ٢٠٠٠٢.

(٢) . ورواه الترمذي في علله الكبير، وقال: لا أعرفه مرفوعاً إلا من هذا الوجه، وهو حديث حسن.

المطلب الثاني

التصرف في المسلم فيه

هناك تصرفات قد يأتيها المسلم إليه في المسلم فيه، وهذه التصرفات، منها: ما يكون قبل قبض المسلم فيه، ومنها ما يكون بعد قبضه، وفي الحالتين منها: ما يجوز ومنها ما لا يجوز، وبيان ذلك:

الفرع الأول

صور التصرف في المسلم فيه

أولاً: بيع المسلم فيه قبل القبض

لا يجوز التصرف بالبيع في المسلم فيه قبل القبض؛ لأن المسلم فيه مبيع، والتصرف في المبيع قبل القبض لا يجوز.

أما لو دفع إليه أردأ أو أجود برضا المسلم إليه جاز؛ لأنه جنس حقه، فلم يكن استبدالاً. ولو أبرأه عنه فقبل: يبطل العقد لعدم القبض، ولو رد البراءة لم تبطل.

ثانياً: الشركة والتولية في المسلم فيه

الشركة والتولية في المسلم فيه قبل قبضه، لا تجوز؛ لأن كل واحد من الشركة والتولية تصرف في المسلم فيه، والتصرف فيه قبل القبض لا يجوز.

ثالثاً: استبدال المسلم فيه

استبدال المسلم فيه قبل قبضه، بأن يأخذ رب السلم مكانه من غير جنسه، لا يجوز؛ لأن المسلم فيه وإن كان ديناً فهو مبيع، ولا يجوز بيع المبيع المنقول قبل القبض.

رابعاً: الإبراء عن المسلم فيه

الإبراء عن المسلم فيه جائز قبل القبض؛ لأن قبضه ليس بمستحق على رب السلم، فكان هو بالإبراء متصرفاً في خالص حقه بالإسقاط، فله ذلك. أما الإبراء عن رأس المال فلا يجوز؛ لأنه مستحق القبض حقا للشرع فلا يملك إسقاطه بنفسه بالإبراء.

خامساً: الحوالة والكفالة بالمسلم فيه

الحوالة بالمسلم فيه جائزة؛ لوجود ركن الحوالة مع شرائطه، وكذلك الكفالة به. وفي الحوالة يبرأ المسلم إليه، وفي الكفالة لا يبرأ، ورب السلم بالخيار إن شاء طالب المسلم إليه، وإن شاء طالب الكفيل؛ لأن الحوالة مبرئة، والكفالة ليست بمبرئة، إلا إذا كانت بشرط براءة المكفول عنه؛ لأنها تكون حوالة معنى.

ولا يجوز لرب السلم الاستبدال مع الكفيل، كما لا يجوز ذلك مع المسلم إليه؛ لأنه كفيل بما على المسلم إليه لا بدين آخر؛ إذ الدين واحد، وإنما تعددت المطالبة بالكفالة، وهو الصحيح.

ويجوز للكفيل أن يستبدل مع المسلم إليه عند الرجوع عليه بما أدى، فيأخذ بدل ما أدى إلى رب السلم؛ لأن الكفالة إذا كانت بأمر المكفول عنه، كانت إقراضا واستقراضا، كأن الكفيل أقرض المسلم إليه واستبدال القرض قبل القبض جائز.

سادسا: الرهن بالمسلم فيه

الرهن بالمسلم فيه جائز؛ لأنه دين حقيقة، والرهن بالدين، أي دين كان جائز.

الفرع الثاني

الإقالة في المسلم فيه

الإقالة في المسلم فيه جائزة، كما تجوز في بيع العين.

الأدلة على جواز الإقالة في المسلم فيه

استدل الحنفية على جواز الإقالة في السلم، بالسنة، والمعقول،

أولا: من السنة: وهي قوله: ﷺ (من أقال نادما أقال الله عثرته يوم القيامة)، وجه الدلالة: أن الحديث يدل على جواز الإقالة في المسلم فيه، والجواز مطلق لم يفصل بين الإقالة في بيع العين، وبين السلم.

ثانيا: من المعقول: ووجهه: أن الإقالة في بيع العين إنما شرعت نظرا للعاقدين دفعا لحاجة الندم، واعتراض الندم في السلم ههنا أكثر؛ لأنه بيع بأوكس الأثمان فكان أدعى إلى شرع الإقالة فيه.

الإقالة في كل المسلم فيه

إذا تقابل العاقدان السلم في كل المسلم فيه، جازت الإقالة؛ لأن الإقالة في بيع العين إنما شرعت نظرا للعاقدين دفعا لحاجة الندم، واعتراض الندم في السلم ههنا أكثر؛ لأنه بيع بأوكس الأثمان فكان أدعى إلى شرع الإقالة فيه، سواء كانت الإقالة بعد حلول الأجل أو قبله؛ لأن نص الإقالة مطلق لا يفصل بين حال وحال.

وكذا جواز اعتراض الندم قائم في الحاليين، وسواء كان رأس المال قائما في يد المسلم إليه أو هالكا، أما إذا كان قائما فلا شك فيه، وكذا إذا كان هالكا؛ لأن رأس مال السلم ثمن

والمبيع هو المسلم فيه، وقيام الثمن ليس بشرط لصحة الإقالة إنما الشرط قيام المبيع، وقد وجد.

رد رأس المال والمسلم فيه بعد الإقالة

أولاً: رد المسلم إليه رأس المال إلى رب السلم:

إذا جازت الإقالة، يفرق بين حالتين:

الحالة الأولى: إذا كان رأس المال مما يتعين بالتعيين

إن كان رأس المال في السلم مما يتعين بالتعيين، وهو قائم فعلى المسلم إليه رد عينه إلى رب السلم لقوله: ﷺ (من وجد عين ماله فهو أحق به)، وإن كان هالكا، فإن كان مما له مثل فعليه رد مثله، وإن كان مما لا مثل له فعليه رد قيمته.

الحالة الثانية: إذا كان رأس المال مما لا يتعين بالتعيين

فإن كان رأس المال مما لا يتعين بالتعيين، فعلى المسلم إليه، رد مثله هالكا كان أو قائما؛ لأنه قبضه عن عقد صحيح.

ثانياً: رد رب السلم المسلم فيه

إذا قبض رب السلم المسلم فيه، ثم تقايلا والمقبوض قائم في يده، جازت الإقالة، وعلى رب السلم رد عين ما قبض؛ لأن المقبوض في يده بعد السلم كأنه عين ما ورد عليه عقد السلم، ألا ترى أنه يجوز لرب السلم أن يبيع المقبوض مرابحة على رأس المال؟

إذا تقايل العاقدان في بعض المسلم فيه دون بعض

إذا تقايل العاقدان السلم في بعض المسلم فيه، يفرق بين حالتين:

الحالة الأولى: إذا كانت الإقالة بعد حلول الأجل

إن كانت الإقالة بعد حلول الأجل: جازت الإقالة فيه بقدره، إذا كان الباقي جزءا معلوما من النصف والتثلث، ونحو ذلك من الأجزاء المعلومة؛ عند غالبية الفقهاء.

وجه قولهم: أن الإقالة شرعت نظرا، وفي إقالة البعض دون البعض ههنا نظر من الجانبين؛ لأن السلم يبيع بأبخس الأثمان لهذا سماه ابن عباس - رضي الله عنهما - حسنا جميلا فقال - رضي الله عنه - : (ذلك المعروف الحسن الجميل)، والسلم في الباقي إلى أجله عند عامة العلماء.

ويرى ابن أبي ليلى: أن العقد يفسخ في الكل.

والصحيح قول العامة؛ لأن الإقالة وجدت في البعض لا في الكل، فلا توجب انفساخ العقد في الكل؛ لأن الحكم يثبت بقدر العلة هذا هو الأصل.

الحالة الثانية

إن كانت الإقالة قبل حلول الأجل

إذا كان قبل حلول الأجل: ينظر إن لم يشترط في الإقالة تعجيل الباقي من المسلم، جازت الإقالة أيضاً، والسلم في الباقي إلى أجله، وإن اشترط فيها تعجيل الباقي، لم يصح الشرط، والإقالة صحيحة. وذلك لأن فساد الشرط؛ فيه اعتياض عن الأجل، وأنه لا يجوز؛ لأن الأجل ليس بمال فلا يجوز الاعتياض عنه.

وأما صحة الإقالة؛ فلأن الإقالة لا تبطلها الشروط الفاسدة، فبطل الشرط وصحت الإقالة، وهذا على قياس قول أبي حنيفة ومحمد؛ لأن الإقالة عندهما فسخ. وأما على قياس قول أبي يوسف، فإن الإقالة والسلم على حاله إلى أجله؛ لأن الإقالة عنده بيع جديد،

الفصل الرابع
عقد الاستصناع
المبحث الأول
تعريف الاستصناع، ودليله، وركنه، ومشروعيته، وحكمه
صورة الاستصناع

أن يجيء رجل إلى صانع الأثاث: فيقول له: اصنع لي غرفة نوم صفتها كذا وكذا، أو يجيء إلى صانع أحذية، ويقول له: اصنع لي حذاء صفته كذا بكذا، أو يقول اصنع لي حقيبة صفتها كذا بكذا، أو نحو ذلك، ويسلم الثمن أو بعضه أولاً يسلم.

أطراف الاستصناع

الأول : البائع: وهو الصانع، والثاني: المشتري: وهو المستصنع، والثالث: العين محل العقد، وهي التي تتم صناعتها.

المطلب الأول
تعريف الاستصناع

الاستصناع في اللغة: مشتق من الصنعة، يقال: صنعه أصنعه صنعا، والاسم الصناعة، والفاعل صانع، والجمع صناع.

والصنعة عمل الصانع. والصنعة ما اصطنعه من خير. والمصنع ما يصنع لجمع الماء نحو: البركة والصهريج.

والمصنعة بالهاء لغة والجمع مصانع (١).

وفي القاموس: الصناعة: ككتابة حرفة الصانع وعمله الصنعة، فالصنعة عمل الصانع في صناعته أي حرفته.

وعلى هذا فالاستصناع لغة: هو طلب الصنعة، أي أن يطلب من الصانع العمل، والاستصناع شرعا: هو طلب العمل من الصانع، في شيء خاص على وجه مخصوص.

(١) . المصباح المنير : مادة : صنع

المطلب الثاني دليل شرعية الاستصناع

استدل الحنفية على شرعية الاستصناع بالسنة والإجماع:
فأما السنة: فمنها:

ما روي أن رسول الله ﷺ: (قد استصنع خاتما).
ما روي أنه ﷺ: (قد احتجم وأعطى الحمام). ووجهه: أن مقدار عمل الحمامة، وعدد كرات وضع المحاجم ومصها، غير لازم عند أحد، ومثله شرب الماء من السقاء.
ما روي أنه ﷺ: سمع بوجود الحمام، فأباحه بمئزر، ولم يبين له شرطا. وتعامل الناس بدخوله من لدن الصحابة والتابعين على هذا الوجه الآن، وهو: أن لا يذكر عدد ما يستهلكه من ماء أو نحوه، فقصرناه على ما فيه تعامل الناس.
وفيما لا تعامل فيه، كأن يستصنع حائكا، أو خياطا، لينسج له، أو يخطط له قميصا بغزل نفسه، رجعنا فيه إلى القياس.
وأما الإجماع: فهو الإجماع العملي، ووجهه: أن الناس قد تعاملوه في سائر الأعصار، من لدن رسول الله ﷺ إلى اليوم من غير نكير، فكان إجماعا منهم على الجواز، فيترك القياس بمثله كدخول الحمام، والتعامل بهذه الصفة أصل مندرج في قوله صلى الله عليه وسلم: (لا تجتمع أمتي على ضلالة).

المطلب الثالث ركن الاستصناع، وحكمه

أولا: ركن الاستصناع

الاستصناع ينعقد بالإيجاب والقبول كأى عقد، كأن يقول طالب الصنعة لصانع: اصنع لي كذا أو كذا، فإذا قال الصانع: قبلت انعقد الاستصناع.
غير أنه في الاستصناع تتعين التفرقة بين حالتين الأولى: إذا ذكر العاقدان الأجل في العقد، والثانية إذا لم يذكر العاقدان الأجل.

ثانيا: حكم الاستصناع

وأما حكم الاستصناع: فهو ثبوت الملك للمستصنع في العين المباعة في الذمة، وثبوت الملك للصانع في الثمن، ملكا غير لازم.

المطلب الرابع مشروعية الاستصناع

الاستصناع قد يذكر فيه الأجل عند التعاقد، وقد لا يذكر، والاستصناع بغير ذكر الأجل، مشروع استحسانا، للإجماع الثابت بالتعامل فيه، ولا يجوز قياسا؛ لأنه بيع المعدوم. أما الاستصناع مع ذكر الأجل، فقد عدوه سلما فيأخذ حكمه.

أولا: الاستصناع بغير ذكر أجل

اختلف فقهاء الحنفية فيما لو قال رجل لآخر: استصنع لي غرفة نوم صفتها كذا بكذا، أو اصنع لي حذاء صفته كذا بكذا، أو يقول اصنع لي حقيبة صفتها كذا بكذا، أو نحو ذلك، ويسلم الثمن أو بعضه أو لا يسلم، دون ذكر الأجل، على قولين. الأول: وهو لجمهور الحنفية عدا زفر، ويرى أصحابه: أن الاستصناع يجوز استحسانا، ولا يجوز قياسا.

القول الثاني: وهو لزفر والشافعي، ويرى عدم جوازه، لأن القياس يأبى جواز الاستصناع في هذه الحالة.

وجه من قال بالقياس: اعتمد القائلون بالقياس على أمرين:

الأول: أن الاستصناع: بيع المعدوم كالسلم، بل هو أبعد جوازا من السلم؛ لأن المسلم فيه تحتمله الذمة؛ لأنه دين حقيقة، والمستصنع عين توجد في الزمن الثاني، والأعيان لا تحتملها الذمم، فكان جواز هذا العقد أبعد عن القياس عن السلم، وقد (نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع ما ليس عند الإنسان)، ووجهه: أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في السلم، والمستصنع ليس بمسلم؛ لأنه لم يضرب له أجلا.

والثاني: أن الاستصناع استتجار على العمل في ملك الأجير، وذلك لا يجوز؛ وذلك كما لو قال: احمل طعامك من هذا المكان إلى مكان كذا بكذا، أو اصبغ ثوبك أحمر بكذا، فإنه لا يصح إجارة، وكذا لا يصح بيعا؛ لأنه بيع معدوم، ولو كان موجودا مملوكا لغير العاقد لم يجز، فإذا كان معدوما فهو أولى بعدم الجواز.

وجه من قال بالاستحسان: استند القائلون بالاستحسان على جواز الاستصناع بأمور، منها:

الأول: أن الناس تعاملوه في سائر الأعصار من لدن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليوم من غير نكير، فكان إجماعا منهم على الجواز، فيترك القياس بمثله كدخول الحمام،

والتعامل بهذه الصفة أصل مندرج في قوله صلى الله عليه وسلم: (لا تجتمع أمتي على ضلالة).

الأمر الثاني: أن رسول الله ﷺ قد استصنع خاتما، كما أنه صلى الله عليه وسلم قد احتجم وأعطى الحمام). ووجهه: أن مقدار عمل الحمامة، وعدد كرات وضع المحاجم ومصها، غير لازم عند أحد، ومثله شرب الماء من السقاء.

الأمر الثالث: أنه صلى الله عليه وسلم سمع بوجود الحمام، فأباحه بمنزلة، ولم يبين له شرطا. وتعامل الناس بدخوله من لدن الصحابة والتابعين على هذا الوجه الآن، وهو أن لا يذكر عدد ما ماء أو نحوه، فقصرناه على ما فيه تعامل. وفيما لا تعامل فيه رجعنا فيه إلى القياس كأن يستصنع حائكا أو خياطا لينسج له أو يخيظ له قميصا بغزل نفسه.

ثانيا: الاستصناع مع ذكر الأجل

اختلف الفقهاء فيما لو عقدا الاستصناع على شيء وضربا فيه الأجل، وكان الشيء المستصنع فيما فيه تعامل للناس، على قولين:

الأول: ويرى: أنه يصير سلما، وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى، وعلى ذلك: فلا يجوز الاستصناع في هذه الحالة إلا بشرائط السلم، والتي منها: تعجيل رأس المال، واستقصاء الوصف، وخلوه من خيار الرؤية. وبهذا القول قال: الشافعي رحمه الله، ومالك، وأحمد -رحمهم الله- لأنهم لا يجوزون الاستصناع أصلا.

القول الثاني: ويرى: أنه يكون استصناعا لا سلما، وهو لأبي يوسف ومحمد.

وجه قول أبي يوسف ومحمد: أن لفظ الاستصناع حقيقة للاستصناع فيحافظ على الاستصناع أو اللفظ، ويحمل الأجل على التعجيل؛ لأن ذكر الأجل محتمل، فإنه يحتمل أن يكون للتعجيل، ويحتمل أن يكون للاستمهال، ولفظ الاستصناع محكم في تناوله ما وضع له غير محتمل لشيء آخر، فيحمل المحتمل على المحكم، فيقال: إن ذكر الأجل للتعجيل.

وجه قول أبي حنيفة: أن المستصنع المبيع وهو دين، والمبيع الدين يحتمل السلم، كما لو ذكر لفظ السلم: وجواز السلم حاصل بإجماع لا شبهة فيه، لأنه ثابت بآية المداينة، وثابت بالسنة، وفي تعامل الناس الاستصناع نوع شبهة، لكونه مجتهد فيه؛ ولأنه لو ضرب الأجل فيما لا تعامل فيه، يصير سلما بالاتفاق.

ولأن في القول بعده استصناعا خلاف زفر والشافعي -رحمهما الله-، فكان الحمل على السلم أولى، لكونه أقرب إلى الجواز وأحق بالرخصة.

جواب الصاحبين على قول أبي حنيفة: (لأنه لو ضرب الأجل فيما لا تعامل فيه، يصير سلماً بالاتفاق).

أجاب الصحبان: بأن القياس على ما لا تعامل للناس فيه لا يصح؛ لأن ذلك استصناع فاسد، فيحمل على السلم الصحيح، بدلالة الأجل، تصحيحاً لتصرف العاقل ما أمكن.

ثالثاً: المراد بضرب الأجل

المراد بضرب هو ما يذكر على سبيل الاستمهال كشهر أو نحوه، أما ما يذكر على سبيل الاستعجال، كقول المستصنع: على أن تفرغ غداً أو بعد غد، فإنه لا يصير سلماً. ووجهه: أن ذكر الأجل بهذه الصور إنما يكون للفراغ لا لتأخير المطالبة بالتسليم. ويرى البعض: أن ذكر المدة إن كان من قبل المستصنع فهو الاستعجال، ولا يصير به سلماً، وإن كان من الصانع، فهو سلم؛ لأنه يذكره على سبيل الاستمهال. وقيل: إن ذكروا فيه مدة يتمكن فيها من العمل فهو استصناع، وإن كان أكثر من ذلك فهو سلم، لأن ذلك يختلف باختلاف المدة فلا يمكن تقديره بشيء معلوم.

المبحث الثاني

محل عقد الاستصناع، وهل هو بيع أو وعد

المطلب الأول

محل العقد في الاستصناع

اختلف فقهاء الحنفية في محل عقد الاستصناع (المعقود عليه)، هل هو العين أو العمل، على قولين:

الأول: ويرى: أن المعقود عليه في الاستصناع هو العين، وهو لبعض الحنفية. القول الثاني: ويرى: أن المعقود عليه في الاستصناع هو العمل، وهو لأبي سعيد البردعي.

وجه القول الأول: أن المقصود هو المستصنع بالفتح، دون العمل، والمعقود عليه العين دون العمل.

وجه القول الثاني: أن الاستصناع استفعال من الصنع، وهو العمل، فتسمية العقد بالمعقود به، دليل على أن المستصنع وهو العين، هو المعقود عليه، وأن الأدوات والصناعة فيه، هي بمنزلة الآلة للعمل.

والأصح: أن المعقود عليه هو العين؛ لأن المقصود هو المستصنع فيه، وذكر الصفة لبيان الوصف، والدليل عليه أن محمدا أثبت خيار الرؤية فيه، وخيار الرؤية إنما يكون في بيع العين.

وأرى التفرقة بين حالتين:

الأولى: إذا كانت المواد من عند الصانع، كان المعقود عليه هو العين والعمل.
الحالة الثانية: إذا كانت المواد من عند المستصنع كان المعقود عليه هو العمل.

المطلب الثاني

الاستصناع هل هو بيع أو وعد

اختلف مشايخ الحنفية في الاستصناع، هل هو مواعدة أو معاقدة أي بيع، فالحاكم الشهيد، والصفار، ومحمد بن سلمة، وصاحب المنثور، يرون أنه: مواعدة.
وعامة مشايخ الحنفية، يرون أن الاستصناع بيع.

وجه قول العامة: يعتمد عامة فقهاء الحنفية على قولهم بأمر، منها:

الأول: أن محمد بن الحسن ذكر القياس والاستحسان في جواز الاستصناع، وذكر القياس والاستحسان لا يليق بالعداء.

الأمر الثاني: أن خيار الرؤية ثابت في الاستصناع، وهو ثابت للمستصنع، وخيار الرؤية من خصائص البيوع.

الأمر الثالث: أن من شرط جواز الاستصناع: أن يكون فيما للناس فيه تعامل، والعداء لا يتقيد جوازها بهذه الشرائط، فدل أن جوازه جواز البياعات لا جواز العداء.

الأمر الرابع: أن محمدا سماه شراء فقال: إذا رآه المستصنع فهو بالخيار، لأنه اشترى ما لم يره، ولأن الصانع يملك الدراهم بقبضها، ولو كانت مواعدة لم يملكها.

وجه قول البعض: أن للصانع أن لا يعمل ولا يجبر عليه بخلاف السلم، وللمستصنع أن لا يقبل ما يأتي به الصانع ويرجع عنه، ولا تلزمه المعاملة.

اعتراض: كيف يجوز أن يكون بيعا والمعدوم لا يصلح أن يكون مبيعا.

الجواب: أن المعدوم قد يعتبر موجودا حكما، أي من حيث الحكم، كالناسي للتسمية عند الذبح، فإن التسمية جعلت موجودة لعذر النسيان، والطهارة للمستحاضة فقد جعلت موجودة لعذر جواز الصلاة؛ لئلا تتضاعف الواجبات، فكذلك المستصنع المعدوم جعل موجودا حكما

لتعامل الناس، وقد يكون الشيء موجودا حقيقة، ويجعل معدوما حكما، كالماء المستحق للعطش، حيث يجوز التيمم مع وجوده.

اعتراض: إنما يصح ذلك لو كان المعقود عليه هو المستصنع، والمعقود عليه هو الصنع.

الجواب: أن المعقود عليه هو العين لا الصنعة؛ لأن المقصود هو المستصنع. والصحيح أنه يجوز بيعا لا عدة.

المبحث الثالث

شروط جواز الاستصناع، وصفته، والاختلاف فيه

المطلب الأول

شروط الاستصناع

يشترط لجواز الاستصناع شروطا من أهمها:

بيان جنس المستصنع، ونوعه، وقدره، وصفته، وذلك لأنه مبيع فلا بد أن يكون معلوما. أن يكون مما للناس فيه تعامل: كأثاث المنازل الذي يصنع من الأخشاب، والمكاتب، والأواني ونحوها والتي تصنع من: الحديد، والرصاص، والنحاس والزجاج، والخفاف والنعال، ولجم الحديد للدواب، ونصول السيوف، والسكاكين والقسي، والنبل والسلاح كله، وغير ذلك. ولا يجوز الاستصناع في الثياب؛ لأن القياس يأبى جوازه، وإنما جوازه استحسانا لتعامل الناس، ولا تعامل في الثياب، والجباب، فيختص بما لهم فيه تعامل. ويبقى الأمر فيما وراء ذلك موكولا إلى القياس.

ولأن جوازه فيما للناس فيه تعامل، إنما يكون فيما يمكن بيان وصفه، ليتمكن التسليم، وإلا فلا.

وعلى ذلك: فإن الاستصناع لا يجوز فيما لا تعامل فيه للناس، كالثياب، والجباب، وصورته أن يدفع إلى خياطا جنيها ليحيك له ثوبا من غزل نفسه.

وهذا كان في الزمن الماضي مسلم، أما في عصرنا فإن الاستصناع في الثياب ممكن، وذلك كأن يأتي التاجر إلى صاحب مصنع ملابس ويطلب منه أن يصنع له ثيابا بأوصاف محددة وأجر محدد.

أن لا يكون فيه أجل، فإن ضرب للاستصناع أجلا؛ صار سلما حتى يعتبر فيه شرائط السلم، وهو قبض البذل في المجلس، ولا خيار لواحد منهما إذا سلم الصانع المصنوع على

الوجه الذي شرط عليه في السلم. وهذا قول أبي حنيفة رحمه الله، وقال أبو يوسف ومحمد: هذا ليس بشرط، وهو استصناع على كل حال، سواء ضرب فيه أجل أم لا، ولو ضرب للاستصناع فيما لا يجوز فيه الاستصناع - كالثياب ونحوها - أجل؛ ينقلب سلما في قولهما جميعا، وقد سبق بيان هذا عند الحديث عن المشروعية في حال ما إذا ضر للاستصناع أجل.

المطلب الثاني **صفة عقد الاستصناع**

صفة الاستصناع: أنه عقد غير لازم قبل العمل في الجانبين جميعا، بلا خلاف، حتى كان لكل واحد منهما خيار الامتناع قبل العمل، كالبيع المشروط فيه الخيار للمتبايعين: أن لكل واحد منهما الفسخ؛ لأن القياس يقتضي أن لا يجوز. فإذا أتى الصانع بالمستصنع على الصفة المشروطة، ثبت للمستصنع ملك غير لازم، حتى يثبت له خيار الرؤية إذا رآه، إن شاء أخذه، وإن شاء تركه، وفي حق الصانع: ثبوت ملك لازم إذا رآه المستصنع ورضي به، ولا خيار له، وهذا في ظاهر الرواية. وروى عن أبي حنيفة: أنه غير لازم في حق كل واحد منهما، حتى يثبت لكل واحد منهما الخيار.

وروي عن أبي يوسف - رحمه الله - : أنه لازم في حقهما، حتى لا خيار لأحدهما، لا للصانع ولا للمستصنع أيضا.

وجه رواية أبي يوسف: أن في إثبات الخيار للمستصنع، إضرار بالصانع؛ لأنه قد أفسد متاعه بالتقطيع والخياطة مثلا، وأتى بالمستصنع على الصفة المشروطة، فلو ثبت له الخيار، لتضرر به الصانع، فيلزم دفعا للضرر عنه.

وجه رواية أبي حنيفة: أن في اللزوم إضرار بهما جميعا، أما إضرار الصانع، فلأنه قد أفسد متاعه، وأتى بالمستصنع على الصفة المشروطة، وأما إضرار المستصنع: فلأن الصانع متى لم يصنعه، واتفق له مشتر يبيعه، فلا تندفع حاجة المستصنع، فيتضرر به فوجب أن يثبت الخيار لهما دفعا للضرر عنهما.

أما ظاهر الرواية: والتي تعطي الخيار للمستصنع لا للصانع: فلها وجهان:

الأول: أن المستصنع مشتر شيئا لم يره؛ لأن المعقود عليه، وهو المستصنع، وإن كان معدوما حقيقة لكنه جعل موجودا شرعا حتى جاز العقد استحسانا، ومن اشترى شيئا لم يره فهو بالخيار إذا رآه، والصانع بائع شيئا لم يره فلا خيار له.

والوجه الثاني: أن في إلزام حكم العقد في جانب المستصنع إضرارا به؛ لأن من الجائز أن لا يلائمه المصنوع ولا يرضى به، فلو لزمه وهو مطالب بثمنه واحتاج إلى بيعه من غيره، وفي الغالب لن يجد من يشتريه منه بمثل قيمته، فيتضرر به، وليس في الإلزام في جانب الصانع ضرر؛ لأنه إن لم يرض به المستصنع، فإنه يبيعه من غيره بمثل قيمته، وذلك ميسور عليه لكثرة ممارسته.

المطلب الثالث اختلاف الصانع والمستصنع

الاختلاف بين الصانع والمستصنع قد يكون في أصل الأمر، وقد يكون في نوعه أو صفته، وقد يكون في الأجر، وقد يكون في تقدير الأجل، وغير ذلك، وتوضيح ذلك: إذا اتفقا على أصل الأمر واختلفا في نوعه أو صفته، فالقول قول المستصنع. مثال ذلك: اختلاف الصباغ ورب الثوب فيما أمره أن يصبغه به، بأن صبغه بعصفر فقال: رب الثوب أمرتك أن تصبغه بالزعفران، فالقول قول رب الثوب مع يمينه عندنا، لأن الإذن يستفاد من من جهة من له الإذن.

وقال ابن أبي ليلى - رحمه الله - : القول قول الصباغ؛ لأنهما اتفقا على الإذن في الصبغ، ثم اختلفا، ورب الثوب يدعي عليه خلافا ليضمنه، أو ليثبت الخيار لنفسه وهو منكر لذلك، فالقول قول المنكر.

وأجيب عن قول ابن أبي ليلى: بأن الإذن يستفاد من جهة رب الثوب، ولو أنكر الإذن له في الصبغ أصلا، كان القول قوله، فكذا إذا أنكر الإذن فيما صبغه به.

وإذا استصنع الرجل عند الرجل خفين، فلما فرغ منهما، قال المستصنع: ليس هكذا أمرتك، وقال الإسكاف: بهذا أمرتني، فالقول قول المستصنع؛ لما بينا أن الإذن يستفاد من جهته، ولا يمين عليه؛ لأن توجه اليمين ينبنى على دعوى تلزمه الجواب، وذلك لا يوجد هنا فإن للمستصنع أن يأبى، وإن لم يكن الصانع مخالفا فلا فائدة في استحلافه، وكذلك لو أقام العامل البينة لم يلزم الأمر؛ لأن الثابت بالبينة كالثابت بإقرار الخصم.

ولوقال المستصنع للصانع: بهذا أمرتك ولكن لا أريده، كان له ذلك؛ لأن خيار الرؤية ثابت للمستصنع بسبب عدم الرؤية.

ولو سلم إليه خفه بنعله بأجر مسمى، فهو جائز للعرف الظاهر، فإذا نعله بنعل لا ينعل بمثله الخفاف، فصاحب الخف بالخيار: إن شاء ضمنه قيمة الخف بغير نعل، وإن شاء أخذه وأعطاه أجر مثله وقيمة النعل لا يجاوز به ما سمى. لأنهما قد اتفقا على الأمر في أصل العمل، واختلفا في الصفة.

وإن كان ينعل بمثله الخفاف فهو لازم عليه، وإن لم يكن جيدا؛ لأن المستحق بمطلق العقد صفة السلامة، فأما صفة الجودة فلا تستحق إلا بالشرط كما في بيع العين.

ولو شرط عليه أن ينعله بنعل جيد، فنعله بنعل غير جيد، فلصاحب الخف الخيار؛ لأن فوات الوصف المشروط بمنزلة العيب في إثبات الخيار، كما إذا اشترى عبدا بشرط أنه كاتب فوجده لا يحسن الكتابة يثبت له الخيار بمنزلة ما لو وجد العيب في المعقود عليه فهذا مثله ولو اختلفا في الأجر: وقد عمله عملا على ما وصفه له، فإن أقاما البينة، فالبينة بينة العامل؛ لأنه يثبت الزيادة في حقه وهو الأجر، فنترجح بينته بذلك.

وإن قال رب الخف عملته لي بغير أجر، وقال العامل عملته بدرهم، ولا بينة بينهما، فعلى رب الخف اليمين لله ما شارطه على درهم؛ لأن العامل يدعي عليه الدرهم دينا في الذمة، وهو منكر، فالقول قول المنكر مع اليمين، فإذا حلف غرم له ما زاد النعل.

ولو اختلفا في تحديد الأجل، بأن قال: أحدهما أجلناه إلى هبوب الريح، وقال الآخر إلى شهر، فالقول لمدعي التحديد، لأن التأجيل بهبوب الريح فاسد بمنزلة العدم.

ولو اختلفا في أصل وجود الأجل، بأن قال: المستصنع لم أحدد أجلا، وقال الصانع بل حددته بشهر، فالقول قول الصانع إذا كان المعقود عليه يحتاج على زمن لصنعه، لأن الظاهر يشهد له، أما إذا كان لا يحتاج إلى زمن لانتهاء من الصنعة، فالقول قول المستصنع، لأن الأمر يستفاد منه، وكذلك الاختلاف في مقداره.

وهكذا، وبهذه القواعد: من: المدعي والمنكر، والبينة واليمين، ومن يشهد له الظاهر وترجيح بينة من يثبت الزيادة على الأخرى، ترجيح قول من يملك الإذن، من يملك الإذن بالأصل يملك ما دونه، يتم النظر في الاختلاف بين المستصنع والصانع. والله أعلم

الاستصناع المعاصر: (أو ما يسمى بالموازي)

والاستصناع المعاصر يتم في الغالب في البنوك الإسلامية، من خلال إبرام عقدين:
الأول: ويتم بين البنك وبين المستصنع، ويكون فيه البنك هو الصانع. والعقد الثاني: يتم بين البنك وبين صانع، ويكون فيه البنك مستصنعا، ومن خلال الفارق في القسمة بين العقدين يستفيد البنك ربحا، كما يستفيد المستصنع الأول (العميل)، بتأخير الثمن أو دفعه على أقساط. ويصير العقد على المربحة بحصول البنك على فارق الثمن بين العقدين. ويصح ذلك طالما ان المستصنع لم يطلب الصنعة من شخص محدد او معين.

حكم الاستصناع الموازي

قد أجاز مجمع الفقه الإسلامي الدولي عقد الاستصناع الموازي، فقد جاء في قراره رقم: ١٢٩ (١٤/٣)، الصادر بشأن: عقد المقاولة والتعمير: (عقد المقاولة عقد يتعهد أحد طرفيه بمقتضاه أن يصنع شيئا، أو يؤدي عملا مقابل بدل يتعهد به الطرف الآخر، وهو عقد جائز سواء قدم المقاول العمل والمادة، وهو المسمى عند الفقهاء بالاستصناع)، فينطبق عليه قرار المجمع رقم: ٦٥ (٧/٣)، الصادر بشأن موضوع الاستصناع والذي ينص على: (إذا شرط رب العمل على المقاول أن يقوم بالعمل بنفسه فلا يجوز له ان يتفق مع مقاول من الباطن، وإذا لم يشترط رب العمل على المقاول أن يقوم بالعمل مع نفسه، جاز له أن يتفق مع مقاول من الباطن، مال لم يكن العمل بعينه مقصودا ادأؤه من المقاول نفسه لوصف مميز فيه مما يختلف باختلاف الأجراء).

فوائد الاستصناع الموازي

يمكن الاستفادة من الاستصناع الموازي في عمليات التمويل، ومن ثم يسهم عقد الاستصناع في المنها ما يكون فتنمية الاقتصادية، كما يمكن أن يساعد في تنمية المهن والصناعات الصغيرة.

تطبيقات الاستصناع في المصارف الإسلامية

للاستصناع تطبيقات متعددة في البنوك الإسلامية، من خلال:
إصدار صكوك استصناع وطرحها للعملاء من المستصنعين، ليستفيدوا منها في الحصول على المصنوعات، وكذلك المشاركة في الربح. وذلك بأن يعلن الطرف المصدر عن إصدار صكوك لصناعة عدد ممن السفن، يشارك فيها العملاء من حملة الصكوك بقدر عدد صكوك كل منهم، ويستفيدون من الناتج.

التمويل بالمشاركة بالاستصناع لبناء المساكن على أرض تكون مملوكة للمستصنعين. وذلك بأن يعلن الطرف المصدر عن إصدار صكوك لبناء مئة وحدة سكنية مثلا، يشارك فيها العملاء ويستفيدون من الربح، بقدر عدد صكوك كل منهم، ويستفيد منها البنك، بجزء من الربح بحسب ما تم الاتفاق عليه في نشرة الإصدار.

التمويل بالمربحة بالاستصناع لصغار الحرفيين، وذلك بأن يطلب منهم البنك صناعات بعينها، بأسعار محددة، يكون قد اتفق مع العملاء المستصنعين على بيعها لهم، وهذا يساعد صغار الحرفيين في تنشيط صناعاتهم، ويساعد العملاء المستصنعين في الحصول على سلع مصنوعة بأسعار مؤجلة، ويعطي البنك ربحا بالفارق بين السعرين، سعر الشراء من الصناع، وسعر البيع للمستصنعين، بالإضافة إلى ما يفيد البنك من أرباح التمويل المؤجل السداد. التمويل بالمشاركة (المضاربة) بعقود المقاولات للإنشاءات، وذلك بأن يقوم البنك بتمويل شركات المقاولات لإنشاء المصانع أو المساكن، أو نحو ذلك، على أن يكون الربح مشاركة بين البنك وشركة المقاولات.

وغير ذلك من تطبيقات الاستصناع التي لايتسع المجال لذكرها. والله الموفق والمعين.

وكتبه د. أحمد عبد العليم أبو عليو

الفصل الخامس

باب المضاربة

المبحث الأول

تعريف المضاربة، ومشروعيتها، وركنها، وأحوالها، وشروطها المطلب الأول: تعريف المضاربة، ومشروعيتها

المضاربة في اللغة: على وزن مفاعلة، مشتقة من الضرب في الأرض؛ وهو السير فيها، سمي بها هذا العقد؛ لأن المضارب يستحق الربح بسعيه وعمله.

وأهل المدينة يسمون هذا العقد: معاوضة، وقراضا مشتقا من القرض وهو القطع، وصاحب المال يقطع قدرًا من المال عن تصرفه، ويجعل التصرف فيه للعامل بهذا العقد، واختار هذا أصحاب الأئمة الثلاثة، وقالوا: كتاب القراض، واختار فقهاء الحنفية لفظ المضاربة، لموافقة القرآن الكريم، قال تعالى: {وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله} (١).

وفي اصطلاح الفقهاء: المضاربة هي: إعارة المال إلى من يتصرف فيه، ليكون الربح بينهما على ما شرطاً.

وعرفها البعض بأنها: عقد يقع على الشركة بمال من أحد الجانبين.
وعرفها البعض الآخر بأنها: شركة في الربح بمال من جانب وعمل من جانب.
وعلى هذا فلو شرط كل الربح لأحدهما لا يكون مضاربة، ويجوز التفاوت في الربح.
وإذا كان المال من اثنين، فلا بد من تساويهما فيما فضل من الربح، حتى لو شرط لأحدهما الثلثان ولآخر الثلث فيما فضل، فهو بينهما نصفين؛ لاستوائهما في رأس المال.

ثانياً: دليل مشروعية المضاربة

المضاربة مشروعة بأدلة من: الكتاب، والسنة، والإجماع، والمعقول.

مشروعية المضاربة بالقرآن الكريم

فأما الكتاب الكريم فأيات، منها:

قوله تعالى: {وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله} (٢).

وجه الدلالة: أن المضارب يضرب في الأرض يبتغي من فضل الله عز وجل. والمراد بالضرب السفر للتجارة، لأن المضارب يسير في الأرض غالبًا طلبًا للربح.

(١) . المزمّل الآية : ٢٠.

(٢) . المزمّل الآية : ٢٠.

قوله تعالى: {فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله} (١).

وجه الدلالة: أن المضارب بعمله يبتغي من فضل الله.

قوله تعالى: {ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم} (٢).

مشروعية المضاربة بالسنة المطهرة

وأما السنة: فقد دلت على مشروعية المضاربة بروايات منها:

ما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: (كان سيدنا العباس بن عبد المطلب إذا دفع المال مضاربة، اشترط على صاحبه أن لا يسلك به بحرا ولا ينزل به واديا، ولا يشتري به دابة ذات كبد رطبة، فإن فعل ذلك ضمن، فبلغ شرطه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأجاز شرطه) (٣).

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث والناس يتعاقدون المضاربة، فلم ينكر عليهم، وذلك تقرير لهم على ذلك؛ والتقرير أحد وجوه السنة.

مشروعية المضاربة بالإجماع

وأما الإجماع: فمن وجوه، منها:

ما روي عن جماعة من الصحابة - رضي الله تعالى عنهم - أنهم دفعوا مال اليتيم، مضاربة منهم: سيدنا عمر، وسيدنا عثمان، وسيدنا علي، وعبد الله بن مسعود، وعبد الله بن عمر، وعبيد الله بن عمر، وسيدتنا عائشة رضي الله عنهم، ولم ينقل أنه أنكر عليهم من أقرانهم أحد، ومثله يكون إجماعا.

ما روي أن عبد الله، وعبيد الله ابني سيدنا عمر، قدما العراق وأبو موسى الأشعري أمير بها، فقال لهما: لو كان عندي فضل لأكرمتكما، ولكن عندي مال لبيت المال أدفعه إليكما، فابتاعا به متاعا واحملاه إلى المدينة وبيعه، وادفعا ثمنه إلى أمير المؤمنين، فلما قدما المدينة، قال لهما سيدنا عمر رضي الله عنه: هذا مال المسلمين فاجعلا ربحه لهم، فسكت عبد الله، وقال عبيد الله: ليس لك ذلك، لو هلك منا لضمنا، فقال بعض الصحابة: يا أمير المؤمنين، اجعلهما كالمضاربين في المال، لهما النصف وليبيت المال النصف، فرضي به سيدنا عمر رضي الله عنه.

(١) . الجمعة الآية : ١٠ .

(٢) . البقرة الآية: ٢٩٨ .

(٣) .

إن الناس يتعاملون المضاربة من لدن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا، في سائر الأعصار من غير إنكار من أحد.

ترك القياس بالكتاب والسنة والإجماع على مشروعية المضاربة

القياس: أن لا تجوز المضاربة؛ لأنها استئجار بأجر مجهول، بل بأجر معدوم، ولعمل مجهول، لكننا تركنا القياس بالكتاب العزيز، والسنة، والإجماع، وإجماع أهل كل عصر حجة، فترك به القياس.

دلالة العقل على مشروعية المضاربة

وجه المعقول: أن الناس يحتاجون إلى عقد المضاربة؛ لأن الإنسان قد يكون له مال لكنه لا يهتدي إلى التجارة، وقد يهتدي إلى التجارة لكنه لا مال له، فكان في شرع هذا العقد دفع الحاجتين، والله تعالى ما شرع العقود إلا لمصالح العباد ودفع حوائجهم. وقد بعث النبي ﷺ والناس يباشرونه فقرهم عليه، وتعاملت به الصحابة رضوان الله عليهم.

حكمة مشروعية المضاربة

المضاربة شرعت للحاجة إليها، فإن الناس بين: غني بالمال لكنه لا يملك القدرة استثماره والتصرف فيه، وبين: مهتد في التصرف صفر اليد عنه، فمست الحاجة إلى شرع هذا النوع من التصرف لينتظم مصلحة الغني والذكي، والفقير والغني.

المطلب الثاني

ركن المضاربة، وأحوال المضارب فيها

أولاً: ركن المضاربة

ركن المضاربة الإيجاب والقبول، فتتعد المضاربة بكل لفظ يدل عليها، كقول رب المال للمضارب: دفعت إليك هذا المال على أن تعمل به مضاربة على كذا، أو كذا من النصف والربع، أو قوله: خذ هذا المال مضاربة على كذا، أو قوله خذ هذا المال مضاربة، على أن ما رزق الله عز وجل وأطعم الله تعالى منه من ربح، فهو بيننا على كذا من: نصف، أو ربع، أو ثلث، أو غير ذلك من الأجزاء المعلومة. فكل لفظ يدل عليها تتعد به المضاربة.

والإيجاب كما يكون بلفظ المضاربة، يكون كذلك بلفظ: المقارضة، والمعاملة، وما يؤدي معاني هذه الألفاظ، بأن يقول رب المال: دفعت إليك هذا المال مفاوضة، أو معاملة، أو خذ هذا المال واعمل به على أن لك من الربح نصفه أو ثلثه.

أو يقول: ابتع به متاعاً، فما كان من فضل فلك كذا، أو خذ ذلك بالنصف.

وكذا إذا قال: مقارضة أو: معاملة ويقول المضارب: أخذت أو: رضيت أو: قبلت ونحو ذلك، فيتم الركن بينهما.

ولو قال: خذ هذه الألف واشتر بها ثيابا مصرية بالنصف، ولم يزد عليه فليس بمضاربة، بل إجارة فاسدة له أجر مثله إن اشترى.

ولفظ المضاربة: صريح مأخوذ من الضرب في الأرض، وهو السير فيها، سمي هذا العقد مضاربة؛ لأن المضارب يسير في الأرض ويسعى فيها لابتغاء الفضل.

وكذلك لفظ المقارضة: صريح في عرف أهل المدينة؛ لأنهم يسمون المضاربة مقارضة كما يسمون الإجارة بيعا، ولأن المقارضة مأخوذة من القرض، وهو القطع، سميت المضاربة مقارضة لما أن رب المال يقطع يده عن رأس المال ويجعله في يد المضارب، ولفظ المعاملة: يشتمل على البيع والشراء، وهذا معنى هذا العقد.

ولو قال: خذ هذا المال واعمل به على أن ما رزق الله عز وجل من شيء فهو بيننا على كذا، ولم يزد على هذا فهو جائز؛ لأنه أتى بلفظ يؤدي معنى هذا العقد، والعبرة في العقود لمعانيها لا لصور الألفاظ ومبانيها، حتى ينعقد البيع بلفظ التملك بلا خلاف، وينعقد النكاح بلفظ: البيع، والهبة، والتمليك عندنا.

ولو قال: خذ هذه الألف فابتع بها متاعا، فما كان من فضل فلك النصف ولم يزد على هذا، فقبل هذا، كان مضاربة استحسانا، والقياس أن لا يكون مضاربة. وجه القياس: أنه ذكر الشراء ولم يذكر البيع، ولا يتحقق معنى المضاربة إلا بالشراء والبيع.

وجه الاستحسان: أنه ذكر الفضل، ولا يحصل الفضل إلا بالشراء والبيع، فكان ذكر الابتياح ذكرا للبيع، وهذا معنى المضاربة.

ولو قال: خذ هذه الألف بالنصف ولم يزد عليه، كان مضاربة استحسانا، والقياس أن لا يكون.

وجه القياس: لأنه لم يذكر الشراء والبيع، فلا يتحقق معنى المضاربة.

وجه الاستحسان: أنه لما ذكر الأخذ، والأخذ ليس عملا يستحق به العوض، وإنما يستحق بالعمل في المأخوذ وهو الشراء والبيع، فتضمن ذكره ذكر الشراء والبيع.

ولو قال: خذ هذا المال فاشتر به كتباً، أو هاتفا بالنصف، ولم يزد على هذا شيئا، فاشترى كما أمره، فهذا فاسد.

ثانياً: أحوال المضارب في عقد المضاربة

المضارب بعد قبضه المال بقصد المضاربة، له أحوال:

الأول: قبل البدء بالعمل: يكون المضارب أميناً، ويكون المال أمانة في يده؛ لأنه قبضه بأمر مالكة لا على وجه البذل والوثيقة.

الحال الثاني: بعد بدء العمل وقبل الربح: بأن اشترى بالمال شيئاً، يكون المضارب وكيلاً، لأنه يتصرف في المال بأمر مالكة، وهو معنى التوكيل، وصار بمنزلة الوكيل بالبيع والشراء.

الحال الثالث: بعد تحقيق ربح: إذا ربح المضارب، صار شريكاً في الربح بقدر حصته والباقي لرب المال، لأنه نماء ملكه، ويظل جميع رأس المال لرب المال.

الحال الرابع: إذا فسدت المضاربة: صارت إجارة، وصار بمنزلة الأجير، حتى يستوجب أجر مثله. والمال في المضاربة الفاسدة غير مضمون بالهلاك اعتباراً بالصحيحة.

الحال الخامس: بعد المخالفة: إذا خالف المضارب شروط رب المال، بأن تصرف في المال تصرفاً مخالفاً لشروط رب المال، كان غاصباً، لوجود التعدي منه على مال غيره، ويكون ربح المال كله له؛ لأن المال صار مضموناً عليه.

الحال السادس: إذا شرط الربح كله لرب المال: لو شرط الربح كله لرب المال، كان رأس المال بضاعة، لأن الربح يستحق بالمال من أحد الجانبين، والعمل من الجانب الآخر.

الحال السابع: إذا شرط الربح كله للمضارب: لو شرط جميع الربح للمضارب، كان رأس المال قرضاً.

المطلب الثالث

شروط المضاربة

أولاً: الشروط التي ترجع إلى العاقدین

العاقدان في المضاربة هما: رب المال والمضارب، ويشترط فيهما: أن يكونا من أهل التوكيل والوكالة: وذلك لأن المضارب يتصرف بأمر رب المال، وهذا معنى التوكيل، ولتحقق ذلك، يشترط أن يكون الموكل ممن يملك التصرف وتلزمه الأحكام، أي أحكام التصرف الذي وكل به، ويشترط في الوكيل أن يكون ممن يعقل البيع ويقصده.

وعلى هذا فيشترط في كل منهما: أن يكون: عاقلاً، بالغاً، أو مأذوناً، فلا تصح المضاربة من غير العاقل كالمجنون، والصبي الذي لا يعقل، كما لا تصح من الصبي غير المأذون له في التجارة.

ثانياً: الشروط التي ترجع إلى رأس المال

يشترط في المال الذي تصح به المضاربة، شروطاً منها:
الأول: أن يكون رأس المال من النقود: (الجنیهات أو الريالات، مثلاً)، عند عامة العلماء، فلا تجوز المضاربة بالعروض. وعند مالك رحمه الله: هذا ليس بشرط وتجاوز المضاربة بالعروض، والصحيح قول العامة، للآتي:

أن العروض تتعين عند الشراء بها، والمعين غير مضمون، فريحه لا يكون مضموناً، حتى لو هلكت العروض قبل التسليم فلا شيء على المضارب، فالربح عليها يكون ربح ما لم يضمن، وقد: (نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربح ما لم يضمن).

أن المضاربة بالعروض تؤدي إلى جهالة الربح وقت القسمة؛ لأن قيمة العروض تعرف بالحرز والظن، وتختلف باختلاف المقومين، والجهالة تقضي إلى المنازعة، والمنازعة تقضي إلى فساد العقد، وهذا لا يجوز.

وعلى ذلك: لو دفع رب المال إلى المضارب عروضاً، وقال له: بعها واعمل بئمنها مضاربة فباعها بجنیهات أو نحوها وتصرف فيها جاز؛ لأنه لم يصف المضاربة إلى العروض وإنما أضافها إلى الثمن، والثمن تصح به المضاربة.

الشرط الثاني: أن يكون رأس المال معلوماً: فإن كان مجهولاً، فلا تصح المضاربة؛ لأن جهالة رأس المال تؤدي إلى جهالة الربح، والعلم بالربح شرط صحة المضاربة.

الشرط الثالث: أن يكون رأس المال عيناً لا ديناً: فإن كان ديناً فالمضاربة فاسدة، وعلى هذا يخرج ما إذا كان لرب المال على رجل دين، فقال له: عمل بديني الذي في ذمتك مضاربة بالنصف، أن المضاربة فاسدة بلا خلاف، فإن اشترى هذا المضارب وباع، فإن ربحه يكون له، وتكون عليه وضيعته، والدين في ذمته بحاله، عند أبي حنيفة.

وعندهما ما اشترى وباع يكون لرب المال، له ربحه وعليه وضيعته، بناء على أن من وكل رجلاً يشتري له بالدين الذي في ذمته، لم يصح عند أبي حنيفة، حتى لو اشترى لا يبرأ عما في ذمته عنده.

الشرط الرابع: تسليم رأس المال إلى المضارب: لأن رأس المال أمانة فلا يصح إلا بالتسليم، وهو التخلية كالوديعة، ولا يصح مع بقاء يد الدافع على المال؛ لعدم التسليم مع بقاء يده، حتى لو شرط بقاء يد المالك على المال، فسدت المضاربة، لأنه يمنع خلوص يد المضارب، فلا يتمكن من التصرف فلا يتحقق المقصود، سواء كان المالك عاقداً أو غير عاقد كالصغير؛ لأن يد المالك ثابتة له، وبقاء يده يمنع التسليم إلى المضارب.

ثالثاً: الشروط التي ترجع إلى الربح للمضاربة شروطاً ترجع إلى الربح، منها:

الأول: إعلام مقدار الربح: لأن المعقود عليه هو الربح، وجهالة المعقود عليه توجب فساد العقد، ولو دفع إليه ألف جنيه على أنهما يشتركان في الربح ولم يبين مقدار الربح، جاز ذلك، والربح بينهما نصفان؛ لأن الشركة تقتضي المساواة، قال تعالى: {فهم شركاء في الثلث}، ولو قال: على أن للمضارب شركاً في الربح، جاز في قول أبي يوسف، والربح بينهما نصفان، وقال محمد: المضاربة فاسدة.

وجه قول محمد: أن الشركة هي النصيب، قال الله تعالى: {أم لهم شرك في السماوات} [الأحقاف: ٤] أي نصيب.

وقال تعالى: {وما لهم فيها من شرك} [سبأ: ٢٢] أي نصيب، فقد جعل له نصيباً من الربح، والنصيب مجهول، فصار الربح مجهولاً.

وجه قول أبي يوسف: أن الشرك بمعنى الشركة، يقال: شركته في هذا الأمر أشركه شركة وشركاً قال القائل: وشاركنا قريشاً في بقاها ... وفي أحسابها شرك العنان ويذكر بمعنى النصيب أيضاً، لكن في الحمل على الشركة تصحيح للعقد فيحمل عليها.

الشرط الثاني: أن يكون المشروط لكل واحد منهما من المضارب ورب المال من الربح جزءاً شائعاً: نصفاً أو ثلثاً أو ربعاً، فإن شرطاً عدداً مقدراً، بأن شرطاً أن يكون لأحدهما مائة جنيه من الربح أو أقل أو أكثر، والباقي للآخر لا يجوز، والمضاربة فاسدة؛ لأن المضاربة نوع من الشركة، وهي الشركة في الربح، وهذا شرط يوجب قطع الشركة في الربح؛ لجواز أن لا يربح المضارب إلا هذا القدر المذكور، فيكون ذلك لأحدهما دون الآخر، فلا تتحقق الشركة، فلا يكون التصرف مضاربة.

وكذلك إن شرطاً أن يكون لأحدهما النصف أو الثلث ومائة جنيه، أو قالوا: إلا مائة جنيه، فإنه لا يجوز كما ذكرنا أنه شرط يقطع الشركة في الربح؛ لأنه إذا شرطاً لأحدهما النصف

ومائة، فمن الجائز أن يكون الربح مائتين، فيكون كل الربح للمشروط له، وإذا شرطاً له النصف إلا مائة، فمن الجائز أن يكون نصف الربح مائة، فلا يكون له شيء من الربح.

لو شرطاً أن تكون الخسارة عليهما

لو شرطاً في العقد أن تكون الوضعية عليهما، بطل الشرط، والمضاربة صحيحة.

والأصل في الشرط الفاسد إذا دخل في هذا العقد، أنه ينظر إن كان يؤدي إلى جهالة الربح، يوجب فساد العقد؛ لأن الربح هو المعقود عليه، وجهالة المعقود عليه توجب فساد العقد، وإن كان لا يؤدي إلى جهالة الربح، يبطل الشرط وتصح المضاربة، وشرط الوضعية عليهما شرط فاسد؛ لأن الوضعية جزء هالك من المال، فلا يكون إلا على رب المال، لا أنه يؤدي إلى جهالة الربح، فلا يؤثر في العقد فلا يفسد به العقد.

المبحث الثاني

أنواع المضاربة

المضاربة نوعان: مطلقة، ومقيدة.

فأما المطلقة: فهي التي يدفع فيها رب المال رأس المال إلى العامل، دون أن يقيد به بأي قيد، فلا يزيد على قوله: دفعت إليك هذا المال مضاربة، ولا يعين له المكان الذي يعمل فيه، ولا الزمان الذي يعمل خلاله، ولا صفة العمل، ولا من يعامله، فإذا كان الأمر كذلك كانت مضاربة مطلقة.

أما المقيدة: فهي التي يدفع فيها رب المال رأس المال إلى العامل، ويقيد به بما يراه مفيداً للمضاربة، سواء كان القيد يتعلق بالمكان الذي يعمل فيه، أو الزمان الذي يعمل خلاله، أو جنس أو نوع العمل، ومن يتعامل المضارب معه، فإذا كان الأمر كذلك كانت مضاربة مقيدة. وتصرفات المضارب في كل نوع من النوعين، له أربعة أقسام:

الأول: وهو ما يكون للمضارب أن يعمل به من غير حاجة إلى التنصيص عليه، ولا إلى قول: اعمل برأيك فيه.

القسم الثاني: ما ليس له أن يعمل به ولو قيل له: اعمل فيه برأيك، فلا يعمل فيه إلا بالتنصيص عليه.

القسم الثالث: ما له أن يعمل به إذا قيل له: اعمل فيه برأيك، وإن لم ينص عليه.

القسم الرابع: ما ليس له أن يعمل به رأساً وإن نص عليه.

المطلب الأول

المضاربة المطلقة

المضاربة وإن كانت مطلقة، إلا أن هنالك بعض التصرفات التي لا يملكها المضارب فيها، إلا بالإذن أو النص على فعلها، وبيان ذلك في الأقسام الأربعة الآتية:

القسم الأول: وهو ما يكون للمضارب أن يعمل من غير الحاجة إلى التصخيص عليه، ولا إلى قول رب المال: اعمل برأيك فيه.

وذلك حالة ما إذا كانت المضاربة مطلقة عن أي قيد، كما لو دفع إليه المال، وقال: خذ هذا المال واعمل به، على أن ما رزق الله من ربح فهو بيننا على كذا، أوقال خذ هذا المال مضاربة على كذا، ففي هذه الحالة: يكون للمضارب التصرفات الآتية:

أن يبيع، وأن يشتري، وأن يوكل غيره، وأن يسافر بالمال، وأن يبضعه، وأن يودعه؛ وذلك لإطلاق عقد المضاربة؛ ولأن المقصود من المضاربة، وهو الاسترباح لا يتحصل إلا بالتجارة، فينتظم العقد المطلق صنوف التجارة، وما هو من صنيع التجار، والتوكيل من صنيعهم، وكذا الإيداع، والإبضاع، والسفر، وكل ما هو متعارف لدى التجار.

أن يبيع نقدا ونسيئة، وبغبن فاحش في قول أبي حنيفة رحمه الله؛ لأنه إذا كان يملك البيع بالتوكيل في هذه الأحوال، فبالمضاربة أولى، لأن المضاربة أعم من الوكالة، وعندهما لا يملك البيع بالنسيئة، ولا بما لا يتغابن الناس في مثله.

أن يشتري ما بدا له من سائر أنواع التجارات، في سائر الأمكنة مع سائر الناس؛ لإطلاق العقد.

أن يدفع المال بضاعة؛ لأن الإبضاع من عادة التجار، ولأن المقصود من هذا العقد هو الربح، والإبضاع طريق إلى ذلك، ولأنه يملك الاستئجار، فالإبضاع أولى؛ لأن الاستئجار استعمال في المال بعوض، والإبضاع استعمال فيه بغير عوض، فكان أولى، وله أن يودع؛ لأن الإيداع من عادة التجار ومن ضرورات التجارة.

أن يستأجر من يعمل في المال؛ لأنه من عادة التجار وضرورات التجارة أيضا؛ لأن الإنسان قد لا يتمكن من جميع الأعمال بنفسه فيحتاج إلى الأجير.

أن يستأجر البيوت ليجعل المال فيها؛ لأنه لا يقدر على حفظ المال إلا به، وله أن يستأجر السفن والدواب للحمل؛ لأن الحمل من مكان إلى مكان طريق يحصل الربح، ولأنه لا يمكنه النقل بنفسه.

أن يوكل بالشراء والبيع؛ لأن التوكيل من عادة التجار، ولأنه طريق الوصول إلى المقصود وهو الربح، فكان بسبيل منه كالشريك، ولأن المضاربة أعم من الوكالة، ويجوز أن

يستفاد بالشيء ما هو دونه، بخلاف الوكالة المفردة، حيث إن الوكيل لا يملك أن يوكل غيره بمطلق الوكالة، إلا إذا قيل له: اعمل برأيك؛ لأن المقصود من ذلك ليس هو التجارة وحصول الربح، بل إدخال المبيع في ملكه، وكذا الوكالة الثانية مثل الأولى، والشيء لا يستتبع مثله. وضابط هذا: أن كل ما للمضارب أن يعمل بنفسه، فله أن يوكل فيه غيره، وكل ما لا يكون له أن يفعله بنفسه، لا يجوز فيه وكالته على رب المال؛ لأنه لما لم يملك أن يعمل بنفسه فبوكيله أولى.

أن يرهن بدين عليه في المضاربة من مال المضاربة، وأن يرتهن بدين له منها على رجل؛ لأن الرهن بالدين والارتهان من باب الإيفاء والاستيفاء، وهو يملك ذلك، فيملك الرهن والارتهان.

وليس للمضارب أن يرهن بعد نهى رب المال عن العمل ولا بعد موته؛ لأن المضاربة تبطل بالنهي والموت، إلا في تصرف ينضر به رأس المال، والرهن ليس تصرفا ينضر به رأس المال، فلا يملكه المضارب.

البيع مع تأخير الثمن

لو باع المضارب شيئا وآخر الثمن جاز باتفاق الائمة؛ لأن التأخير للثمن عادة التجار. وهذا يتفق مع أصل أبي حنيفة في الوكالة، ويخالف أصل أبي يوسف. فعلى أصل أبي حنيفة رحمه الله: أن الوكيل بالبيع يملك تأخير الثمن، فالمضارب أولى؛ لأن تصرفه أعم من تصرف الوكيل، إلا أن الوكيل بالبيع إذا أخر الثمن يضمن عندهما والمضارب لا يضمن؛ لأن المضارب يملك أن يستقيل ثم يبيع نسيئة، فيملك التأخير ابتداء فلم يضمن.

فأما الوكيل فلا يملك الإقالة، ثم البيع بالنسيئة، فإذا أخر ضمن.

وعلى أصل أبي يوسف ومحمد رحمهما الله: فإنما جاز تأخير المضارب دون الوكيل لهذا المعنى أيضا، وهو أن المضارب يملك أن يشتري السلعة أو يستقيل فيها، ثم يبيعها نساء، فيملك تأخير ثمنها، والوكيل لا يملك ذلك.

الحالة بالثمن على الغير

وللمضارب أن يحتال بالثمن على رجل، موسرا كان المحتال عليه أو معسرا؛ لأن الحالة من عادة التجار؛ لأن الوصول إلى الدين قد يكون أيسر من ذمة المحال عليه منه

من ذمة المحيل، بخلاف الوصي إذا احتال بمال اليتيم إن ذلك إن كان أصلح جاز، وإلا فلا؛ لأن تصرف الوصي في مال اليتيم مبني على النظر، وتصرف المضارب مبني على عادة التجار.

خط المضارب مال نفسه بمال المضاربة

إذا خط المضارب مال نفسه بمال المضاربة، ولم يقل له رب المال: اعمل برأيك، يضمن، وصار كأجنبي خط المال. وإن كان قال له: اعمل برأيك فلا ضمان عليه؛ لأنه إذا قال ذلك، فله أن يخط مال نفسه بمال المضاربة.

استئجار المضارب أرض بيضاء

للمضارب أن يستأجر أرضا بيضاء، ويشترى ببعض المال طعاما فيزرعه فيها، وكذلك له أن يقلبها ليغرس فيها نخلا أو شجرا أو رطبا، فذلك كله جائز، والريح على ما شرط؛ لأن الاستئجار من التجارة؛ لأنه طريق حصول الربح، وكذا هو من عادة التجار فيملكه المضارب.

سفر المضارب بالمال

وللمضارب أن يسافر بالمال؛ لأن المقصود من هذا العقد استئماء المال، وهذا المقصود بالسفر أوفر، ولأن العقد صدر مطلقا عن المكان، فيجري على إطلاقه، ولهذا جاز للمودع أن يسافر، على أنه في معنى المودع؛ لأنه مؤتمن في مال المضاربة كالمودع في مال الوديعة، مع ما أن المضارب يملك أمرا زائدا لا يملكه المودع، وهو التصرف، فلما ملك المودع السفر؛ فلأن يملكه المضارب أولى.

ولأن مأخذ الاسم دليل عليه؛ لأن المضاربة مشتقة من الضرب في الأرض، وهو السير، قال الله تبارك وتعالى: {وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله} [المزمل: ٢٠].

ولأن المضاربة طلب الفضل، وقد قال الله تعالى عز شأنه: {وابتغوا من فضل الله} [الجمعة: ١٠]، وهذا قول أبي حنيفة ومحمد، وهو قول أبي يوسف في رواية محمد عنه. وفي رواية أصحاب الإماء عن أبي يوسف: ليس له أن يسافر، وروي عنه أنه فرق بين الذي يثبت في وطنه، وبين الذي لا يثبت، وبين ما له حمل ومؤنة، وبين ما لا حمل له ولا مؤنة في الشركة، فالمضارب على ذلك.

وروي عن أبي حنيفة رحمه الله: أنه ليس للشريك والمضارب أن يسافر، وهو قول أبي يوسف، وروي عن أبي يوسف: أن له المسافرة إلى موضع لا يبيت فيه عن منزله، وروي عنه يسافر أيضا بما لا حمل له ولا مؤنة، ولا يسافر بما له حمل ومؤنة.

وجه ظاهر قول أبي يوسف: أن السفر له خطر، فلا يجوز في ملك الغير إلا بإذنه رب المال نصا أو دلالة، فإذا دفع المال إليه في بلدهما فلم يأذن له بالسفر نصا ولا دلالة، لم يكن له أن يسافر، وإذا دفع إليه في غير بلدهما، فقد وجد دلالة الإذن بالرجوع إلى الوطن؛ لأن العادة أن الإنسان لا يأخذ المال مضاربة ويترك بلده، فكان دفع المال في غير بلدهما رضا بالرجوع إلى الوطن، فكان إذنا دلالة.

وجه الرواية التي فرق فيها بين القريب والبعيد: أنه إذا كان قريبا بحيث لا يبيت عن منزله، كان في حكم المصر.

وجه الرواية التي فرق فيها بين ما له حمل ومؤنة، وما ليس له حمل ومؤنة: أن ما له حمل إذا احتاج شريكه إلى رده، يلزمه مؤنة الرد فيتضرر به، ولا مؤنة تلزمه فيما لا حمل له.

الجواب عن قول أبي يوسف: (أن المسافرة بالمال مخاطرة به)، إن هذا مسلم، إذا كان الطريق مخوفا، فأما إذا كان آمنا، فلا خطر فيه بل هو مباح؛ لأن الله سبحانه وتعالى أمر بالابتغاء في الأرض من فضل الله، ورفع الجناح عنه، بقوله تعالى عز شأنه: {فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله} [الجمعة: ١٠].

دفع المال إلى مضاربين

لو دفع رب المال المال إلى رجلين مضاربة، فليس لأحدهما أن يبيع ويشترى بغير إذن صاحبه، ولا أن يعمل أحدهما شيئا مما للمضارب الواحد أن يعمل، سواء قال لهما: اعملا برأيكما أو لم يقل؛ لأنه رضي برأيهما ولم يرض برأي أحدهما، فصارا كالوكيلين. وإذا أذن له الشريك في شيء من ذلك، جاز في قولهم جميعا؛ لأنه لما أذن له فقد اجتمع رأيهما، فصار كأنهما عقدا جميعا.

القسم الثاني: ما ليس للمضارب أن يعمله إلا بالتنصيص عليه

في هذا القسم لا يملك المضارب التصرفات الآتية، إلا بالنص على فعلها من رب المال، منها:

أولاً: الاستدانة على مال المضاربة

ليس للمضارب أن يستدين على مال المضاربة، ولو استدان لم يجز على رب المال، ويكون ديناً على المضارب في ماله؛ لأن الاستدانة إثبات زيادة في رأس المال من غير رضا رب المال، بل فيه إثبات زيادة ضمان على رب المال من غير رضاه؛ لأن ثمن المشتري برأس المال في باب المضاربة مضمون على رب المال، فلو جوزنا الاستدانة على المضاربة، لألزمناه زيادة ضمان لم يرض به، وهذا لا يجوز.

صورة الاستدانة

الاستدانة هي: أن يشتري المضارب شيئاً بثمن دين ليس في يده من جنسه. وعلى هذا: لو لم يكن في يده شيء من رأس المال من الجنيهاً أو نحوها، بأن كان اشترى برأس المال سلعة، ثم اشترى شيئاً بالجنيهاً، لم يجز على المضاربة، وكان المشتري له، وعليه ثمنه من ماله؛ لأنه اشترى بثمن ليس في يده من جنسه، فكان مستديناً على المضاربة، فلم تجز على رب المال وجاز عليه؛ لأن الشراء وجد نفاذاً عليه، كالوكيل بالشراء إذا خالف.

الاستدانة للشراء بثمن مؤجل

أيضاً المضارب لا يملك الاستدانة، سواء كان الشراء بثمن حال أو مؤجل؛ لأنه لما اشترى بما ليس في يده من جنسه صار مستديناً على المضاربة، وهو لا يملك ذلك.

اشترى بثمن مؤجل لبيع ما في يده ويؤدي ثمنه ولو كان في يد المضارب عرضاً يساوي رأس المال أو أكثر، فاشترى شيئاً للمضاربة بالجنيهاً لبيع العرض ويؤدي ثمن ما اشتراه من العرض الذي باعه، لم يجز، لأنه استدانة على رأس المال.

وكذلك لو باع ما في يده من العرض بالجنيهاً، وحصل ذلك في يده قبل حل الأجل، لم ينتفع بذلك؛ لأنه لما خالف في حالة الشراء لزمه الثمن وصارت السلعة له؛ لأنه لم يملك الشراء للمضاربة فوق العقد له، فلا يصير بعد ذلك للمضاربة.

الشراء بأكثر من رأس المال

وكذا إذا قبض المضارب مال المضاربة، ليس له أن يشتري بأكثر من رأس المال الذي في يده؛ لأن الزيادة تكون ديناً، وليس في يده من مال المضاربة ما يؤديه، حتى لو اشترى سلعة بألفي جنيه ومال المضاربة ألف، كانت حصة الألف من السلعة المشتراة للمضاربة، وحصة ما زاد على الألف للمضارب خاصة، وله ربح ذلك، وعليه وضيعته، والزيادة دين عليه في ماله؛ لأنه يملك الشراء بالألف ولا يملك الشراء بما زاد عليها للمضاربة، ويملك الشراء لنفسه فوق له.

الشراء بجنس ثمن ليس في يد المضارب شيئاً منه

إذا قبض المضارب رأس المال وهو قائم في يده، فليس له أن يشتري للمضاربة بغير النقود من: المكيل والموزون، والمعدود، والثوب الموصوف المؤجل، إذا لم يكن في يده شيء من ذلك؛ لأن الشراء بغير المال يكون استدانة على المال.

ولو كان ما في يده من مال المضاربة: مكيل أو موزون، فاشترى ثوباً بمكيل أو موزون موصوف في الذمة، كان المشتري للمضاربة؛ لأن في يده من جنسه، فلم يكن استدانة. ولو كان في يده جنيهات، فاشترى سلعة بجنيهات نسيئة، لم يكن استدانة؛ لأن في يده من جنسه.

ولو كان في يده جنيهات فاشترى بريالات، أو كان في يده ريالات فاشترى بجنيهات، فالقياس أن لا يجوز على رب المال، وهو قول زفر، وفي الاستحسان يجوز. وجه القياس: أن الجنيهات والريالات جنسان مختلفان حقيقة، فقد اشترى بما ليس في يده من جنسه، فيكون استدانة، كما لو اشترى بالعروض.

وجه الاستحسان: أن الجنيهات والريالات عند التجار كجنس واحد؛ لأنهما أثمان الأشياء، بهما تقدر النفقات، وأروش الجنايات، وقيم المتلفات، ولا يتعذر نقل كل واحد منهما إلى الآخر، فكانا بمنزلة شيء واحد، فكان مشترياً بثمن في يده من جنسه.

اشترى بثمن من جنس رأس المال، لكنه يخالفه في الصفة

لو اشترى المضارب بثمن هو من جنس رأس المال، لكنه يخالفه في الصفة، بأن اشترى بدراهم بيض ورأس المال دراهم سود، أو اشترى بصحاح ورأس المال غلة، أو اشترى بدراهم سود ورأس المال دراهم بيض، أو اشترى بدراهم غلة ورأس المال صحاح، فذلك جائز على المضاربة، عند أبي حنيفة وأبي يوسف.

وقال زفر: لا يجوز شيء من ذلك على المضاربة، ويكون استدانة، ويجعل اختلاف الصفة كاختلاف الجنس، وإذا اختلف جنسان، يكون قد اشترى بما ليس في يده من جنسه، فيكون استدانة، كما لو اشترى بالعروض.

وقال محمد: إن اشترى بما صفته أنقص من صفة رأس المال جاز، وهذا يشير إلى أنه لو اشترى بما صفته أزيد من صفة رأس المال، أنه لا يجوز على المضاربة. وجهه قول محمد: أنه إذا اشترى بما صفته أنقص من صفة رأس المال، كان في يده ذلك القدر الذي اشترى به ذلك القدر وزيادة فجاز، وإذا اشترى بما صفته أكمل لم يكن في يده القدر الذي اشترى به، فلا يجوز على المضارب.

وجه قول أبي حنيفة وأبي يوسف: أنه لما جاز الشراء عند اختلاف الجنس، فلأن يجوز عند اختلاف الصفة أولى؛ لأن تفاوت الصفة دون تفاوت الجنس. والصحيح قول أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله.

الشراء بزيادة على قيمة ما معه من رأس المال

ولو كان رأس المال ألف درهم، فاشترى سلعة بألف، أو بدنانير، أو بفلوس، قيمة ذلك ألف، لا يملك أن يشتري بعد ذلك على ألف المضاربة شيئاً بألف أخرى، أو غير ذلك؛ لأن مال المضاربة كان مستحقاً بالثمن الأول، فلو اشترى بعد ذلك لصار مستديناً على مال المضاربة، فلا يملك ذلك، فإن اشترى عليها أولاً سلعة بخمسائة، لا يملك بعد ذلك أن يشتري إلا بقدر خمسمائة؛ لأن الخمسمائة خرجت من المضاربة، وكذلك كل دين يلحق رأس المال؛ لأن ذلك صار مستحقاً من رأس المال، فيخرج القدر المستحق من المضاربة، فإذا اشترى بأكثر مما بقي صار مستديناً على مال المضاربة فلا يصح.

الشراء بثلثين وما في يده من أموال ليست من جنسه

ولو باع المضارب واشترى وتصرف في مال المضاربة، فحصل في يده صنوف من الأموال، من: المكيل، والموزون، والمعدود، وغير ذلك من سائر الأموال، ولم يكن في يده دراهم ولا دنانير ولا فلوس، فليس له أن يشتري متاعاً بثلثين ليس في يده مثله من جنسه وصفته وقدره، بأن اشترى: شاة بأردب حنطة موصوفة، فإن اشترى بأردب حنطة وسط وفي يده الوسط، أو بكر حنطة جيدة وفي يده جاز.

وإن كان في يده أجود مما اشترى به أو أدون، لم يكن للمضاربة وكان للمضارب؛ لأنه إذا لم يكن في يده مثل الثمن، صار مستديناً على المضاربة، فلا يجوز.

وليس اختلاف الصفة هنا كاختلاف الصفة في الدراهم؛ لأن اختلاف الجنس هناك بين الدراهم والدنانير لا يمنع الجواز، فاختلاف الصفة أولى؛ لأنه دونه، واختلاف الجنس هنا يمنع الجواز، فكذا اختلاف الصفة.

ولا فرق في جميع ما ذكرنا من أنه لا يجوز للمضارب الاستدانة على رب المال، بين ما إذا قال له رب المال: اعمل برأيك أو لم يقل؛ لأن قوله: اعمل برأيك تفويض إليه، فيما هو من المضاربة، والاستدانة لم تدخل في عقد المضاربة، فلا يملكها المضارب إلا بإذن رب المال بها نصاً.

الاستدانة لإصلاح مال المضاربة

كما لا يجوز للمضارب الاستدانة على مال المضاربة، لا يجوز له الاستدانة على إصلاح مال المضاربة، حتى لو اشترى المضارب بجميع مال المضاربة ثياباً، ثم استأجر على حملها، أو على قصارتها، أو نقلها، كان متطوعاً في ذلك كله؛ لأنه إذا لم يبق في يده شيئاً من رأس المال، صار بالاستئجار مستديناً على المضاربة، فلم يجز عليها، فصار عاقدا لنفسه متطوعاً في مال الغير، كما لو حمل متاعاً لغيره، أو قصر ثياباً لغيره بغير أمره.

إذا أذن رب المال للمضارب بالاستدانة

إذا أذن رب المال للمضارب أن يستدين على مال المضاربة، جاز له الاستدانة، وما يستدينه يكون شركة بينهما شركة وجوه، وكان المشتري بينهما نصفين؛ لأنه لا يمكن أن يجعل المشتري بالدين مضاربة؛ لأن المضاربة لا تجوز إلا في مال عين فتجعل شركة وجوه، ويكون المشتري بينهما نصفين؛ لأن مطلق الشركة يقتضي التساوي.

وسواء كان الربح بينهما في المضاربة نصفين أو أثلاثاً؛ لأن هذه شركة على حدة، فلا يبنى على حكم المضاربة.

فإن شرطاً التفاضل في الضمان، كان الربح كذلك، وإن أطلقا كان المشتري نصفين، لا يجوز فيه التفاضل في الربح.

وإذا صارت هذه شركة وجوه، صار الثمن دينا عليهما من غير مضاربة، فلا يملك المضارب أن يرهن به مال المضاربة، إلا بإذن رب المال، فإن أذن له أن يرهن بجميع الثمن، فقد أعاره نصف الرهن ليرهن بدينه، وإن هلك صار مضموناً عليه.

إقراض المضارب مال المضاربة وهبته والتصدق به

ليس للمضارب أن يقرض مال المضاربة؛ لأن القرض تبرع في الحال، إذ لا يقابله عوض للحال، وإنما يصير مبادلة في الثاني، ومال الغير لا يحتمل التبرع. وكذلك الهبة والصدقة؛ لأن كل واحد منهما تبرع.

أخذ المضارب بالسفينة

أيضا ليس للمضارب أن يأخذ سفينة؛ لأن أخذها استدانة، وهو لا يملك الاستدانة. وكذا ليس له أن يعطى سفينة؛ لأن إعطاء السفينة إقراض وهو لا يملك الإقراض إلا بالتنصيص عليه، لأن قوله: اعمل في ذلك برأيك، تفويض الرأي إليه في المضاربة، والتبرع ليس من عمل المضاربة، وكذا الاستدانة، بل هي عند الإذن شركة وجوه، وهي عقد آخر وراء المضاربة، وهو إنما فوض إليه الرأي في المفاوضة خاصة، لا في عقد آخر لا تعلق له بها، فلا يدخل في ذلك.

شراء المضارب بما لا يتغابن الناس في مثله

ليس للمضارب أن يشتري بما لا يتغابن الناس في مثله، وإن قال له رب المال: اعمل برأيك.

ولو اشترى يصير مخالفا؛ لأن المضاربة توكيل بالشراء، والتوكيل بالشراء مطلقا ينصرف إلى المتعارف، وهو أن يكون بمثل القيمة، أو بما يتغابن الناس في مثله.

ولأن الشراء بما لا يتغابن في مثله محاباة، والمحاباة تبرع، والتبرع لا يدخل في عقد المضاربة.

إنفاق المضارب رأس المال لمصلحة نفسه

ولو أخذ المضارب: نخلا، أو شجرا، أو رطوبة معاملة، على أن ينفق عليها من رأس المال، لم يجز على رب المال، وإن كان قال له رب المال حين دفع إليه المال: اعمل فيه برأيك؛ لأن الأخذ منه معاملة عقد على منافع نفسه، ومنافع نفس المضارب لا تدخل تحت عقد المضاربة، فصار كما لو أجر نفسه للخدمة، ولا يعتبر ما شرط من الإنفاق؛ لأن ذلك ليس بمعقود عليه، بل هو تابع للعمل، كالخييط في إجارة الخياط والصبغ في الصباغة.

وقوله: اعمل برأيك إنما يفيد تفويض الرأي إليه في المضاربة، والمضاربة تصرف في المال، وهذا عقد على منافع نفسه، ومنافع نفس المضارب لا يجوز أن يستحق بدلها رب المال.

القسم الثالث: ما للمضارب أن يفعله بقول رب المال اعمل برأيك

إذا قال رب المال للمضارب: اعمل برأيك ولم ينص عليه، فإن المضارب يملك: المضاربة بالمال، والشركة، والخلط، فله أن يدفع مال المضاربة مضاربة إلى غيره، وأن يشارك غيره في مال المضاربة شركة عنان، وأن يخلط مال المضاربة بمال نفسه، وليس له أن يعمل شيئاً من ذلك، إذا لم يقل له ذلك.

فأما المضاربة: فلأن المضاربة مثل المضاربة، والشيء لا يستتبع مثله، فلا يستفاد بمطلق عقد المضاربة مثله، ولهذا لا يملك الوكيل التوكيل بمطلق العقد كذا هذا. وأما الشركة: فلا يملكها؛ لأنها أعم من المضاربة، والشيء لا يستتبع مثله، فما فوقه أولى.

وأما الخلط: فلأنه يوجب في مال رب المال حقاً لغيره، فلا يجوز إلا بإذنه.

القسم الرابع: ما ليس للمضارب أن يفعله أصلاً ولا رأساً

في هذا القسم: لا يملك المضارب: شراء ما لا يملك بالقبض، وما لا يجوز بيعه فيه إذا قبضه.

أما ما لا يملك بالقبض: فنحو شراء: الميتة، والدم، والخمر، والخنزير، أو نحو ذلك مما لا يملك بالقبض؛ لأن المضاربة تتضمن الإذن بالتصرف الذي يحصل به الربح، والربح لا يحصل إلا بالشراء والبيع، فما لا يملك بالشراء لا يحصل فيه الربح، وما يملك بالشراء لكن لا يقدر على بيعه، لا يحصل فيه الربح أيضاً، فلا يدخل تحت الإذن.

فإن اشترى شيئاً من ذلك كان مشترياً لنفسه لا للمضاربة، فإن دفع فيه شيئاً من مال المضاربة، يضمن.

وإن اشترى ثوباً، أو عرضاً من العروض بشيء مما ذكرنا سوى الميتة. والدم، فالشراء على المضاربة؛ لأن المبيع هنا مما يملك بالقبض ويجوز بيعه، فكان هذا شراء فاسداً والإذن بالشراء المستفاد بعقد المضاربة يتناول الصحيح والفاقد.

وأما إذا كان الثمن ميتة أو دماً، فما اشترى به لا يكون على المضاربة؛ لأن الميتة والدم لا تملك بالقبض أصلاً.

وأما ما لا يجوز بيعه: فنحو: أن يشتري ذا رحم محرم من رب المال، فلا يكون المشتري للمضاربة، بل يكون مشترياً لنفسه؛ لأنه لو وقع شراؤه للمضاربة لعق على رب المال، فلا يقدر على بيعه بعد ذلك، ولا يحصل المقصود من الإذن، فلا يدخل تحت الإذن.

ولو اشترى ذا رحم محرم من نفسه، فإن لم يكن في المال ربح، فالشراء على المضاربة؛ لأنه لا ملك له فيه فيقدر على بيعه فيحصل المقصود، وإن كان في المال ربح لم يكن الشراء على المضاربة؛ لأنه إذا كان في المضاربة ربح يملك قدر نصيبه من الربح فيعتق ذلك القدر عليه، فلا يقدر على بيعه ولا على بيع الباقي لأنه معتق البعض، وما لا يقدر على بيعه لا يكون للمضاربة لما قلنا.

المطلب الثاني **المضاربة المقيدة**

المضاربة المقيدة لا تختلف في حكمها عن المضاربة المطلقة في جميع ما وصفنا، إلا في قدر القيد، والأصل فيه: أن القيد إن كان مفيدا يثبت؛ لأن الأصل في الشروط اعتبارها ما أمكن، وإذا كان القيد مفيدا وكان يمكن اعتباره فيعتبر؛ لقول النبي عليه أفضل الصلاة والسلام: (المسلمون عند شروطهم)، فيتقيد المضارب بالمذكور، ويبقى مطلقا فيما وراءه على الأصل المعهود في المطلق إذا قيد ببعض المذكور، إنه يبقى مطلقا فيما وراءه، كالعام إذا خص منه بعضه، إنه يبقى عاما فيما وراءه، وإن لم يكن مفيدا لا يثبت بل يبقى مطلقا؛ لأن ما لا فائدة فيه يلغو ويلحق بالعدم.

مسائل على المضاربة المقيدة

أولا: مسائل على التقيد بالمكان

إذا دفع رجل إلى رجل مالا مضاربة على أن يعمل به في القاهرة، فليس له أن يعمل به في غير القاهرة؛ لأن قوله: على أن، من ألفاظ الشرط وأنه شرط مفيد؛ لأن الأماكن تختلف بالرخص والغلاء، وكذا في السفر فيعتبر.

وحقيقة الفقه في ذلك: أن الإذن كان عدما وإنما يحدث بالعقد، فيبقى فيما وراء ما تناوله العقد على أصل العدم.

كذلك ليس للمضارب أن يعطيها بضاعة لمن يخرج بها من القاهرة؛ لأنه إذا لم يملك الإخراج بنفسه، فلائ لا يملك الأمر بذلك أولى.

وإن أخرجها من القاهرة، فإن اشترى بها وباع ضمن؛ لأنه تصرف لا على الوجه المأذون، فصار فيه مخالفا، فيضمن، وكان المشتري لنفسه، له ربحه وعليه وضيعته، لكن لا يطيب له الربح عند أبي حنيفة، ومحمد.

وعند أبي يوسف يطيب وإن لم يشتر بها شيئاً، حتى ردها إلى القاهرة، برئ من الضمان، ورجع المال مضاربة على حاله؛ لأنه عاد إلى الوفاق قبل تقرر الخلاف، فببراً عن الضمان، كالمودع إذا خالف ثم عاد إلى الوفاق.

ولو لم يرده حتى هلك قبل التصرف، لا ضمان عليه؛ لأنه لما لم يتصرف لم يتقرر الخلاف، فلا يضمن.

ولو اشترى ببعضه ورد بعضه فما اشتراه فهو له، وما رد رجع على المضاربة؛ لأنه تقرر الخلاف في القدر المشتري، وزال عن القدر المردود.

ولو دفع إليه على أن يعمل في سوق القاهرة، فعمل في القاهرة في غير سوقها، فهو جائز على المضاربة استحساناً، والقياس أن لا يجوز.

وجه القياس: أنه شرط عليه العمل في مكان معين، فلا يجوز في غيره، كما لو شرط ذلك في بلد معين.

وجه الاستحسان: أن التقييد بسوق القاهرة غير مفيد؛ لأن البلد الواحد بمنزلة بقعة واحدة، فلا فائدة في التعليق بهذا الشرط، فيلغو الشرط.

ولو قال له: اعمل به في سوق القاهرة، أو لا تعمل به إلا في سوق القاهرة، فعمل في غير سوق القاهرة يضمن؛ لأن قوله: لا تعمل إلا في سوق القاهرة حبر له، فلا يجوز تصرفه بعد الحجر وفي الفصل الأول ما حبر عليه، بل شرط عليه أن يكون عمله في السوق، والشرط غير مفيد فلغا.

ولو قال له: خذ هذا المال تعمل به في القاهرة، لم يجز له العمل في غيرها؛ لأن في: كلمة ظرف، فقد جعل القاهرة ظرفاً للتصرف الذي أذن له فيه، فلو جاز في غيرها لم تكن القاهرة ظرفاً لتصرفه.

وكذلك إذا قال له: فاعمل به في القاهرة لما قلنا، ولأن الفاء من حروف التعليق، فتوجب تعلق ما قبلها بما بعدها، وإنما يتعلق إذا لم يجز التصرف في غيرها.

وكذلك إذا قال خذ هذا المال بالتصرف بالقاهرة؛ لأن الباء حرف إصاق فتقتضي التصاق الصفة بالموصوف، وهذا يمنع جواز التصرف في غيرها.

ولو قال: خذ هذا المال مضاربة، واعمل به في القاهرة فله أن يعمل بالقاهرة، وحيث ما بدا له، لأن قوله: خذ هذا المال مضاربة، إذن له في التصرف مطلقاً وقوله: واعمل به في القاهرة إذن له بالعمل في القاهرة، فكان له أن يعمل في أي موضع شاء.

ولو دفع إليه المال وقال له: إن عملت في مصر فلك ثلث الربح، وإن سافرت فلك النصف جاز، والربح بينهما على ما شرطاً، فإن عمل في مصر فله الثلث، وإن سافر فله النصف.

ولو اشترى في مصر وباع في السفر، أو اشترى في السفر وباع في مصر، فقد روي عن محمد أنه قال: المضاربة في هذا على الشراء، فإن اشترى في مصر فما ربح في ذلك المتاع، فهو على ما شرط في مصر. سواء باعه في مصر أو في غيره؛ لأن المضارب إنما يستحق الربح بالعمل، والعمل يحصل بالشراء، فإذا اشترى في مصر تعين أحد العاملين، فلا يتغير بالسفر، وإن عمل ببعض المال في السفر وبالبعض في الحضر، فربح كل واحد من المالين على ما شرط.

ولو دفع إليه المال وقال له: على أن تشتري به من أهل القاهرة وتبيع، فاشترى وباع من رجال بالقاهرة من غير أهلها، فهو جائز؛ لأن هذا الشرط لا يفيد إلا ترك السفر، كأنه قال: على أن تشتري ممن بالكوفة.

أمثلة على التقييد بالزمان

لو قال: خذ هذا المال مضاربة إلى سنة، جازت المضاربة عند علماء الحنفية، وقال الشافعي رحمه الله: المضاربة فاسدة.

وجه قول الشافعي: أنه إذا وقت للمضاربة وقتاً، فيحتمل أنه لا يجوز كونها في الوقت، فلا يفيد العقد فائدة.

وجه قول الحنفية: أن المضاربة توكيل، والتوكيل يحتمل التخصيص بوقت دون وقت.

أمثلة على التقييد بالتجارة في جنس أو نوع معين

لو قال: خذ هذا المال مضاربة بالنصف، على أن تشتري به الطعام أو قال: فاشتر به الطعام، أو قال: تشتري به الطعام، أو قال: خذ هذا المال مضاربة بالنصف في الطعام، فذلك كله سواء، وليس له أن يشتري سوى الطعام بالإجماع لأن إن للشرط، والأصل في الشرط المذكور في الكلام اعتباره، والفاء لتعليق ما قبلها بما بعدها.

وقوله: يشتري به الطعام تفسير التصرف المأذون به، وقوله في الطعام ففي كلمة ظرف، فإذا دخلت على ما لا يصلح ظرفاً تصير بمعنى الشرط، وكل ذلك يقتضي التقييد بالشرط المذكور، وأنه شرط مفيد؛ لأن بعض أنواع التجارة يكون أقرب إلى المقصود من بعض.

وكذا الناس مختلفون في ذلك، فقد يهتدي الإنسان إلى بعض التجارة دون بعض، فكان الشرط مفيدا فينقيد به، ولا يملك أن يشتري غير الطعام، والطعام هو الحنطة ودقيقها، إذ لا يراد به كل ما يتطعم، بل البعض دون البعض، والأمر يختلف باختلاف عادة البلدان، فاسم الطعام في عرفهم لا ينطلق إلا على الحنطة ودقيقها.

التقييد بالجنس

لو قال له: خذ هذا المال مضاربة بالنصف، على أن تشتري به الدقيق، أو الخبز، أو البر، أو غير ذلك، ليس له أن يعمل في غير ذلك الجنس بلا خلاف، لكن له أن يشتري ذلك الجنس في المصر وغيره، وأن يبضع فيه، وأن يعمل فيه جميع ما يعمله المضارب في المضاربة المطلقة؛ لأن اللفظ المطلق إذا قيد ببعض الأشياء يبقى على إطلاقه فيما وراءه.

التقييد بالأشخاص

لو قال رب المال للمضارب خذ هذا المال، على أن تشتري من فلان وتبيع منه، جاز عند فقهاء الحنفية، وهو على فلان خاصة، ليس له أن يشتري ويبيع من غيره. وقال الشافعي رحمه الله: المضاربة فاسدة.

وجه قول الشافعي: أن في تعيين الشخص تضيق طريق الوصول إلى المقصود من التصرف، وهو الربح، وتغيير مقتضى العقد؛ لأن مقتضى العقد التصرف مع من شاء. وجه قول الحنفية: أن هذا شرط مفيد لاختلاف الناس في الثقة والأمانة؛ لأن الشراء من بعض الناس قد يكون أربح لكونه أسهل في البيع، وقد يكون أوثق على المال، فكان التقييد مفيدا، كالتقييد بنوع دون نوع.

وقد أجاب الحنفية عن قول الشافعي: (التعيين يغير مقتضى العقد)، بأن الأمر ليس كذلك، بل هو مباشرة العقد مفيدا من الابتداء، وإنه قيد مفيد، فوجب اعتباره. لو دفع إليه مالا مضاربة في الصرف، على أن يشتري من الصيارفة ويبيع، كان له أن يشتري من غير الصيارفة ما بدا له من الصرف؛ لأن التقييد بالصيارفة لا يفيد إلا تخصيص البلد، أو النوع، فإذا حصل ذلك من صيرفي أو غيره، فهو سواء.

المبحث الثالث

ما يجوز لرب المال عمله وما لا يجوز، والمراوحة بينه وبين المضارب

المطلب الأول: ما يجوز لرب المال عمله وما لا يجوز

يجوز لرب المال: أن يبيع مال المضاربة بمثل قيمته أو أكثر. وإذا باع بأقل من قيمته لم يجز، إلا أن يجيزه المضارب، سواء باع بأقل من قيمته مما لا يتغابن الناس فيه، أو مما

يتغابن الناس فيه؛ لأن جواز بيع رب المال من طريق الإعانة للمضارب، وليس من الإعانة إدخال النقص عليه، بل هو استهلاك فلا يتحمل قل أو كثر.

لو كان المضارب اثنين، فباع أحدهما بإذن رب المال، لم يجز أن يبيعه، إلا بمثل القيمة، أو أكثر إلا أن يجيزه المضارب الآخر؛ لأن أحد المضاربين لا ينفرد بالتصرف بنفس العقد، بل بإذن رب المال، وهو لا يملك التصرف بنفسه إذا كان فيه غبن فلا يملك الأمر به.

إذا اشترى المضارب بمال المضاربة متاعا وفيه فضل، أولا فضل فيه، فأراد رب المال بيع ذلك فأبى المضارب، وأراد إمساكه حتى يجد ربحا، فإن المضارب يجبر على بيعه، إلا أن يشاء أن يدفعه إلى رب المال؛ لأن منع المالك عن تنفيذ إرادته في ملكه لحق يحتمل الثبوت والعدم، وهو الريح لا سبيل إليه، ولكن يقال له: إن أردت الإمساك فرد عليه ماله، وإن كان فيه ربح يقال له: ادفع إليه رأس المال، وحصته من الريح، ويسلم المتاع إليك.

ولو أخذ رجل مالا ليعمل لأجل ابنه مضاربة، فإن كان الابن صغيرا لا يعقل البيع، فالمضاربة للأب، ولا شيء للابن من الريح؛ لأن الريح في باب المضاربة يستحق بالمال أو بالعمل، وليس للابن واحد منهما.

فإن كان الابن يقدر على العمل فالمضاربة للابن والريح له إن عمل، فإن عمل الأب بأمر الابن فهو متطوع، وإن عمل بغير أمره صار بمنزلة الغاصب؛ لأنه ليس له أن يعمل فيه بغير إذنه، فصار كالأجنبي.

ويجوز شراء رب المال من المضاربة، وشراء المضارب من رب المال، وإن لم يكن في المضاربة ربح في قول أصحابنا الثلاثة، وقال زفر رحمه الله: لا يجوز الشراء بينهما في مال المضاربة.

وجه قول زفر: أن هذا بيع ماله بماله، وشراء ماله بماله، إذ المالان جميعا لرب المال، وهذا لا يجوز كالوكيل مع الموكل.

وجه قول الأئمة الثلاثة: أن لرب المال في مال المضاربة ملك رقبة لا ملك تصرف، وملكه في حق التصرف كملك الأجنبي، وللمضارب فيه ملك التصرف لا الرقبة، فكان في حق ملك الرقبة كملك الأجنبي، حتى لا يملك رب المال منعه عن التصرف، فكان مال المضاربة في حق كل واحد منهما كمال الأجنبي، لذلك جاز الشراء بينهما.

أخذ رب المال والمضارب بالشفعة وعدمه

لو اشترى المضارب دارا، ورب المال شفيعتها بدار أخرى بجنبها، فله أن يأخذ بالشفعة؛ لأن المشتري وإن كان له في الحقيقة، لكنه في الحكم كأنه ليس له، بدليل أنه لا يملك انتزاعه من يد المضارب، ولهذا جاز شراؤه من المضارب.

لو باع المضارب دارا من المضاربة، ورب المال شفيعتها، فلا شفعة له، سواء كان في الدار المبيعة ربح وقت البيع، أو لم يكن.

أما إذا لم يكن فيها ربح؛ فلأن المضارب وكيله بالبيع، والوكيل ببيع الدار إذا باع لا يكون للموكل الأخذ بالشفعة، وإن كان فيها ربح، فأما حصة رب المال فكذلك هو وكيل بيعها. وأما حصة المضارب فلأننا لو أوجبنا فيها الشفعة، لتفرقت الصفقة على المشتري، ولأن الربح تابع لرأس المال، فإذا لم تجب الشفعة في المتبوع، لا تجب في التابع.

ولو باع رب المال دارا لنفسه، والمضارب شفيعتها بدار أخرى من المضاربة، فإن كان في يده من مال المضاربة وفاء بثلث الدار، لم تجب الشفعة؛ لأنه لو أخذ بالشفعة لوقع لرب المال والشفعة لا تجب لبائع الدار، وإن لم يكن في يده وفاء، فإن لم يكن في الدار ربح، فلا شفعة؛ لأنه أخذها لرب المال، وإن كان فيها ربح، فللمضارب أن يأخذها لنفسه بالشفعة؛ لأن له نصيبا في ذلك، فجاز أن يأخذها لنفسه.

ولو أن أجنبيا اشترى دارا إلى جانب دار المضاربة، فإن كان في يد المضارب وفاء بالثلث، فله أن يأخذها بالشفعة للمضاربة، وإن سلم الشفعة بطلت، وليس لرب المال أن يأخذها لنفسه؛ لأن الشفعة وجبت للمضاربة، ومالك التصرف في المضاربة للمضارب، فإذا سلم جاز بتسليمه على نفسه وعلى رب المال، وإن لم يكن في يده وفاء، فإن كان في الدار ربح، فالشفعة للمضارب ولرب المال جميعا، فإن سلم أحدهما، فلا آخر أن يأخذها جميعا لنفسه بالشفعة، كدار بين اثنين وجبت الشفعة لهما وإن لم يكن في الدار ربح، فالشفعة لرب المال خاصة؛ لأنه لا نصيب للمضارب فيه.

المطلب الثاني

المراوحة بين رب المال والمضارب، وصورها

أولا: حكم المراوحة بين رب المال والمضارب، وشرطها

المراوحة بين رب المال والمضارب، جائزة استحسنا، ولا يبيع كل منهما إلا على أقل الثمنين.

وجه الاسحسان: أن حق المضارب متعلق بالمال، وهو ملك التصرف، فيجعل ذلك بيعا في حقهما لا في حق غيرهما، بل يجعل في حق غيرهما ملحقا بالعدم.

ولأن المراجعة بيع يجريه البائع من غير بينة واستخلاف، فتجب صيانتة عن الجنائية، وعن شبه الجنائية ما أمكن، وقد تمكنت التهمة في البيع بينهما؛ لجواز أن رب المال باعه من المضارب بأكثر من قيمته ورضي به المضارب؛ لأن الجود بمال الغير أمر سهل، فكأن تهمة الجنائية ثابتة، والتهمة في هذا الباب ملحقة بالحقيقة، فلا يبيع مراجعة إلا على أقل الثمنين.

والقياس: أن لا تجوز المراجعة، بين رب المال والمضارب.

وجه القياس: أن رب المال في هذا البيع والشراء، يكون قد اشترى مال نفسه بمال نفسه، والمضارب يبيع مال رب المال من رب المال إذ المالان ماله، والقياس يأبى ذلك. إلا أن الجواز قد استحسّن لما ذكر.

وصورة المراجعة بين رب المال والمضارب: أن يشتري رب المال من مضاربه، فيبيعه مراجعة، أو يشتري المضارب من رب المال، فيبيعه مراجعة.

شرط المراجعة بين رب المال والمضارب

شرط المراجعة بين رب المال والمضارب هو: أن يتم البيع فيما بينهما، وفيما بين أحدهما والغير على أقل الثمنين؛ ذلك لأن المراجعة بيع يجريه البائع من غير بينة واستخلاف، فتجب صيانتة عن الجنائية، وعن شبه الجنائية ما أمكن، وقد تمكنت التهمة في البيع بينهما؛ لجواز أن رب المال باعه من المضارب بأكثر من قيمته ورضي به المضارب؛ لأن الجود بمال الغير أمر سهل، فكان تهمة الجنائية ثابتة، والتهمة في هذا الباب ملحقة بالحقيقة، فلا يبيع مراجعة إلا على أقل الثمنين

صور البيع بأقل الثمنين في المراجعة في المضاربة

إذا دفع إلى رجل ألف درهم مضاربة، فاشترى رب المال عبدا بخمسمائة، فباعه من المضارب بألف، فإن المضارب يبيعه مراجعة على خمسمائة؛ لأنها أقل الثمنين، إلا إذا بين الأمر على وجهه، فيبيعه كيف شاء؛ لأن المانع هو التهمة وقد زالت.

إذا اشترى المضارب عرضا بألف من المضاربة، ثم باعها من رب المال بألف ومائتين، فإن رب المال يبيعه مراجعة بألف ومائة، وإن كانت المضاربة بالنصف؛ لأن الربح ينقسم بين رب المال والمضارب، ولا شبهة في حصة المضارب؛ ولا شيء لرب المال؛ لأنه لا حق فيه

لرب المال، فصار كأن رب المال اشترى ذلك من أجنبي، وإنما تمكنت الشبهة في حصة رب المال؛ لأنه ماله بعينه، فكأنه اشترى من نفسه، فتسقط حصته من الربح، إلا إذا بين الأمر على وجهه فيبيعه كيف شاء.

لو اشترى رب المال سلعة بألف درهم، وهي تساوي ألفا وخمسمائة، فباعها من المضارب بألف وخمسمائة، فإن المضارب يبيعها مربحة بألف ومائتين وخمسين، إلا إذا بين الأمر على وجهه، لما ذكرنا.

ولو اشترى رب المال سلعة بخمسمائة، فباعها من المضارب بألف ومائة، فإنه يبيعها مربحة على خمسمائة وخمسين؛ لأن المائة الزيادة على الألف ربح، فنصفها للمضارب، وما اشتراه المضارب من رب المال لنفسه لا تهمة فيه، فيضم حصته من الربح إلى القدر الذي اشترى رب المال به، ويسقط خمسمائة؛ لأنها نصيب رب المال، ويسقط خمسون؛ لأنها حق رب المال من الربح، فيبيعه مربحة على خمسمائة وخمسين.

قال محمد في الأصل: إذا دفع الرجل إلى رجل ألف درهم مضاربة بالنصف، ودفع إلى رجل آخر ألف درهم مضاربة بالنصف، فاشترى أحد المضاربين شيئاً بخمسمائة من المضاربة، فباعه من المضارب الآخر بألف، فأراد الثاني أن يبيعه مربحة، باعه على خمسمائة، وهو أقل الثمنين؛ لأن مال المضاربين لرجل واحد، فصار بيع أحدهما من الآخر في حق الأجانب، كبيع الإنسان ملكه بماله، فيبيعه مربحة على أقل الثمنين.

ولو باعه الأول من الثاني بألفين، ألف من المضاربة وألف من مال نفسه، فإن الثاني يبيعه مربحة على ألف ومائتين وخمسين؛ لأن الثاني اشترى نصفه لنفسه، وقد كان الأول اشترى ذلك النصف بمائتين وخمسين، فيبيعه الثاني مربحة على ألف؛ لأنه لا نصيب لواحد منهما في شراء صاحبه فصارا كالأجنيين، فأما النصف الذي اشتراه الثاني بألف المضاربة، فقد كان الأول اشتراه بمائتين وخمسين، وهو مال واحد فيبيعه على أقل الثمنين.

ولو كان الأول اشتراه بألف المضاربة فباعه من الثاني بألفين للمضاربة، ألف رأس المال وألف ربح، فإن الثاني يبيعه مربحة بألف وخمسمائة؛ لأنه يبيعه على أقل الثمنين وعلى حصته من الربح وأقل الثمنين ألف، وحصة المضارب خمسمائة.

ولو كان الأول اشتراه بخمسمائة، والمسألة بحالها باعه الثاني على ألف؛ لأن أقل الثمنين خمسمائة، وحصة المضارب خمسمائة، فيبيعه مربحة على أقل الثمنين وحصة من

الربح والربح في المضاربة بينهما على الشرط، والوضعية على رب المال، والقول قول المضارب في دعوى الهلاك؛ لأن المال أمانة في يده.

وعلى هذا القياس تجرى المسائل، فمتى كان شراء المضارب بأقل الثمنين، فإن كان للمضارب حصة ضمها إلى أقل الثمنين، وإذا اشترى رب المال من المضارب، يبيعه على أقل الثمنين، ويضم إليه حصة المضارب.

وإنما يكون البيع بأقل الثمنين، لأن البيع بأقل الثمنين لا تهمة فيه.

المبحث الرابع **في النفقة، والربح، والمضاربة الفاسدة** **المطلب الأول في: النفقة**

أولاً: حكم النفقة

استحقاق المضارب النفقة في المضاربة أمر واجب، ويدل للوجوب أمرين:

الأول: أن الربح في باب المضاربة يحتمل الوجود والعدم، والعاقلة لا يسافر بمال غيره لفائدة تحتل الوجود والعدم، مع تعجيل النفقة من مال نفسه، فلو لم تجعل نفقته من مال المضاربة لامتنع الناس من قبول المضاريات مع مساس الحاجة إليها، فكان إقدامهما على هذا العقد، والحال ما وصفنا إذنا من رب المال للمضارب بالإنفاق من مال المضاربة، فكان مأذونا في الإنفاق دلالة، فصار كما لو أذن له به نصاً.

الأمر الثاني: أن المضارب يسافر لأجل المال على سبيل التبرع، ولا ببذل واجب له لا محالة، فتكون نفقته في المال.

ثانياً: شرط وجوب النفقة في المضاربة

يشترط لوجوب النفقة في المضاربة: خروج المضارب بالمال من المصر الذي أخذ المال فيه مضاربة، سواء كان المصر مصره أو لم يكن، فما دام يعمل بالمال في ذلك المصر، فإن نفقته في مال نفسه لا في مال المضاربة، وإن أنفق شيئاً منه ضمن؛ لأن دلالة الإذن لا تثبت في المصر.

ولأن إقامته في الحضر لا تكون لأجل المال؛ لأنه كان مقيماً قبل ذلك، فلا يستحق النفقة ما لم يخرج من ذلك المصر.

السفر الذي يستحق به المضارب النفقة

يستحق المضارب النفقة بمطلق السفر، سواء كان خروجه بالمال مدة سفر أو أقل من ذلك، حتى لو خرج من المصر يوما أو يومين، فله أن ينفق من مال المضاربة، كذا ذكر محمد عن نفسه، وعن أبي يوسف: من مكان المضاربة؛ لوجود الخروج من المصر لأجل المال.

وإذا انتهى إلى المصر الذي قصده، فإن كان ذلك مصر نفسه، أو كان له في ذلك المصر أهل، سقطت نفقته حين دخل؛ لأنه يصير مقيما بدخوله فيه لا لأجل المال، وإن لم يكن ذلك مصره، ولا له فيه أهل، لكنه أقام فيه للبيع والشراء، لا تسقط نفقته ما أقام فيه، وإن نوى الإقامة خمسة عشر يوما فصاعدا، ما لم يتخذ ذلك المصر الذي هو فيه دار إقامة؛ لأنه إذا لم يتخذ دار إقامة، كانت إقامته فيه لأجل المال، وإن اتخذ وطنا كانت إقامته للوطن لا للمال فصار كالوطن الأصلي.

فالحاصل: أن نفقة المضاربة لا تبطل بعد المسافرة بالمال، إلا بالإقامة في مصره، أو في مصر يتخذ دار إقامة، لما قلنا.

استحقاق المضارب نفقة الذهاب والإياب من المصر الذي دخله للمضاربة إلى مصره

لو خرج المضارب من المصر الذي دخله للبيع والشراء بنية العود إلى المصر الذي أخذ المال فيه مضاربة، فإن نفقته من مال المضاربة حتى يدخله، فإذا دخله فإن كان ذلك مصره، أو كان له فيه أهل، سقطت نفقته وإلا فلا، حتى لو أخذ المضارب مالا بالقاهرة وهو من أهل الإسكندرية، وكان قد قدم القاهرة مسافرا، فلا نفقة له في المال ما دام في القاهرة، لما قلنا، فإذا خرج منها مسافرا، فله النفقة حتى يأتي الإسكندرية؛ لأن خروجه لأجل المال، ولا ينفق من المال ما دام بالإسكندرية؛ لأن الإسكندرية وطن أصلي له، فكانت إقامته فيها لأجل الوطن لا لأجل المال، فإذا خرج من الإسكندرية، فله أن ينفق من المال حتى يأتي القاهرة؛ لأن خروجه من الإسكندرية لأجل المال.

وله أن ينفق أيضا ما أقام بالقاهرة حتى يعود إلى الإسكندرية؛ لأن وطنه بالقاهرة كان وطن إقامة، وأنه يبطل بالسفر، فإذا عاد إليها وليس له وطن، فكان إقامته فيها لأجل المال، فكان نفقته فيه.

نفقة المعاونين

كل من كان مع المضارب ممن يعينه على العمل، فنفقته من مال المضاربة، كأجير يخدمه، أو يخدم أعمال المضاربة، كالسائقين، والبائعين، والحراس، أو نحوهم؛ لأن نفقتهم كنفقة نفسه؛ لأنه لا يتهياً له السفر إلا بهم.

ما تكون فيه النفقة

نفقة المضارب وأعوانه تكون في مال المضاربة، وله أن ينفق من مال نفسه، ما له أن ينفق من مال المضاربة على نفسه، ويكون ديناً في المضاربة حتى كان له أن يرجع فيها؛ لأن الإنفاق من المال وتدبيره إليه، فك

أن له أن ينفق من ماله، ويرجع به على مال المضاربة، كالوصي إذا أنفق على الصغير من مال نفسه، أن له أن يرجع بما أنفق على مال الصغير، كذا هذا له أن يرجع بما أنفق في مال المضاربة.

وشرط الرجوع على رب المال في هذه الحالة: هو بقاء المال، حتى لو هلك المال لم يرجع على رب المال بشيء؛ لأن نفقة المضارب من مال المضاربة، فإذا هلك هلك بما فيه كالدين يسقط بهلاك الرهن، والزكاة تسقط بهلاك النصاب، وحكم الجناية يسقط بهلاك الجاني.

صفة النفقة

المراد بالنفقة التي في مال المضاربة، هي: الكسوة، والطعام والإدام، وكذلك اللحم، ويأكل منه كما كان يأكل؛ لأنه من المأكل المعتاد، وكذلك الفاكهة، فإنه يأكل منها ما يجري مجرى الطعام والإدام.

وكذلك الشراب، وأجر الأجير، والفراش الذي ينام عليه، ومتطلبات أدوات النقل التي يركبها في سفره، ويتصرف عليها في حوائجه، وغسل ثيابه، أو نحو ذلك. ولا خلاف بين الحنفية في هذه الجملة؛ لأن المضارب لا بد له منها، فكان الإذن ثابتاً من رب المال دلالة.

نفقات العلاج

نفقات العلاج وما يحتاجه المضارب من أدوية لتقوية بدنه، وجميع ما يرجع إلى التداوي، وصلاح البدن، يكون في ماله خاصة لا في مال المضاربة. وهو الصحيح؛ لأن وجوب النفقة للمضارب في المال لدلالة الإذن الثابت عادة، وهذه الأشياء غير معتادة، وإذا قضى القاضي بالنفقة، فإنه يقضي بالطعام والكسوة، ولا يقضي بهذه الأشياء.

مقدار النفقة

قدر النفقة يكون بالمعروف عند التجار من غير إسراف، فإن جاوز ذلك ضمن الفضل؛ لأن الإذن ثابت بالعادة، فيعتبر القدر المعتاد، وسواء سافر برأس المال أو بمتاع عن المضاربة؛ لأن سفره في الحالين لأجل المال.

كذلك يستحق النفقة لو سافر فلم يتفق له شراء متاع من حيث قصد، وعاد بالمال فنفقته ما دام مسافراً في مال المضاربة؛ لأن عمل التجارة على هذا، وهو أن يتفق الشراء في وقت دون وقت، ومكان دون مكان، وسواء سافر بمال المضاربة وحده، أو بماله ومال المضاربة، ومال المضاربة لرجل أو رجلين، فله النفقة، غير أنه إذا سافر بماله ومال المضاربة، أو بمالين لرجلين، كانت النفقة من المالين بالحصص؛ لأن السفر لأجل المالين، فتكون النفقة فيهما.

محل حساب النفقة من المال

تحتسب النفقة في المضاربة من الربح أولاً إن كان في المال ربح، فإن لم يكن فهي من رأس المال؛ لأن النفقة جزء هالك من المال، والأصل أن الهالك ينصرف إلى الربح. ولأننا لو جعلناها من رأس المال خاصة، أو في نصيب رب المال من الربح، لازداد نصيب المضارب في الربح على نصيب رب المال.

فإذا رجع المضارب إلى مصره، فما يكون قد فضل عنده من: الكسوة والطعام رده إلى المضاربة؛ لأن الإذن له بالنفقة كان لأجل السفر، فإذا انقطع السفر لم يبق الإذن، فيجب رد ما بقي إلى المضاربة.

المطلب الثاني الربح في المضاربة الصحيحة

أولاً: ما يستحقه المضارب من الربح، وشرطه

الربح المسمى: هو ما يستحقه المضارب بعمله في المضاربة الصحيحة، إن كان في المضاربة ربح.

والمراد بالربح المسمى: هو النسبة التي اتفق عليها رب المال والمضارب عن التعاقد، كالنصف والربح ...، وغير ذلك. فإذا حصل ربح في المضاربة استحق العامل ما تم الاتفاق عليه. غير أن الربح لا يتبين إلا بقسمة مال المضاربة، وإخراج رأس المال منه وتسليمه لرب المال، وما يتبقى بعد إخراج رأس المال يكون ربحاً، يقتسمه المضارب ورب المال بناء على ما اتفقا عليه.

ثانياً: القسمة شرط لحصول المضارب على الربح

يشترط لحصول المضارب على الربح، قسمة مال المضاربة، فإن الربح لا يظهر إلا بقسمة المال وإخراج رأس المال وعزله، وما يتبقى بعد عزل رأس المال، يكون ربحاً يقسم بين رب المال وبين المضارب على ما شرطاً. فلا تصح قسمة الربح قبل أن يقبض رب المال رأس ماله.

وعلى ذلك: لو دفع إلى رجل ألف درهم مضاربة بالنصف، فربح ألفاً فاقسما الربح، ورأس المال في يد المضارب لم يقبضه رب المال، فهلك الألف التي في يد المضارب بعد قسمتهما الربح، فإن القسمة الأولى لا تصح، وما قبض رب المال يحسب عليه من رأس ماله، وما قبضه المضارب دين عليه يرده إلى رب المال، حتى يستوفي رب المال رأس ماله، ولا تصح قسمة الربح حتى يستوفي رب المال رأس المال.

دليل اشتراط القسمة

الأصل في اعتبار هذا الشرط: ما روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (مثل المؤمن مثل التاجر، لا يسلم له ربحه حتى يسلم له رأس ماله، كذلك المؤمن لا تسلم له نوافله حتى تسلم له عزائمه)، فدل الحديث على أن قسمة الربح قبل قبض رأس المال لا تصح. ولأن الربح زيادة، والزيادة على الشيء لا تكون إلا بعد سلامة الأصل.

ولأن المال إذا بقي في يد المضارب فحكم المضاربة بحالها، فلو صححنا قسمة الربح لثبتت قسمة الفرع قبل الأصل، وهذا لا يجوز.

هلاك باقي المال حال فساد القسمة

إذا لم تصح القسمة، وهلك ما في يد المضارب من المال، صار الذي اقتسماه هو رأس المال، فوجب على المضارب أن يرد منه تمام رأس المال، فإن قبض رب المال رأس ماله أولاً، ثم اقتسما الربح، صحت القسمة وتنتهي المضاربة.

فإذا رد رب المال ما قبضه بعينه إلى يد المضارب بعد القسمة في مضاربة سابقة، على أن يعمل بها مضاربة بالنصف، فإن هذه تكون مضاربة مستقبلية، فإن هلك في يده لم تنتقض القسمة الأولى؛ لأن رب المال لما استوفى رأس المال فقد انتهت المضاربة، وصحت القسمة، فإذا رد المال فهذا عقد آخر، وهلاك المال فيه لا يبطل القسمة في غيره.

أما لو كان الربح في المضاربة الأولى ألفين، واقتسما الربح، فأخذ رب المال ألفاً والمضارب ألفاً، ثم هلك ما في يد المضارب، فإن القسمة تكون باطلة، وما قبضه رب المال محسوب من رأس المال، ويرد المضارب نصف الألف الذي قبض؛ لأنه لما هلك ما في يد المضارب من رأس المال قبل صحة القسمة، صار ما قبضه رب المال رأس ماله، وإذا صار ذلك رأس المال، تعين الربح فيما قبضه المضارب بالقسمة، فيكون بينهما على الشرط، فيجب عليه أن يرد نصفه.

وكذلك إن كان قد هلك ما قبضه المضارب من الربح، يجب عليه أن يرد نصفه؛ لأنه تبين أنه قبض نصيب رب المال من الربح لنفسه، فصار ذلك مضموناً عليه، ولو هلك ما قبض رب المال لم يتعين بهلاكه شيء؛ لأن ما هلك بعد القبض يهلك في ضمان القابض، فبقاؤه وهلاكه سواء.

المطلب الثالث: المضاربة الفاسدة

المضاربة الفاسدة: هي التي تخلفت فيها شروط الصحة، مثل: أن يشترط رب المال العمل مع المضارب، أو يشترط مبلغاً محدداً من الربح، أو نحو ذلك من الشروط التي تفسدها.

حكم المضاربة الفاسدة

إذا فسدت المضاربة، فإن المضارب بمقتضاها لا يملك أن يعمل شيئاً مما له أن يعمل في المضاربة الصحيحة، ولا يثبت له بها شيء مما ذكرنا عن أحكام المضاربة الصحيحة، ولا يستحق النفقة، ولا الربح المسمى، وإنما له أجر مثل عمله، سواء كان في المضاربة ربح أو لم يكن؛ لأن المضاربة الفاسدة في معنى الإجارة الفاسدة، والأجير لا يستحق النفقة ولا المسمى في الإجارة الفاسدة، وإنما يستحق أجر المثل، والربح كله يكون لرب المال؛ لأن

الربح نماء ملكه، وإنما يستحق المضارب شطرا منه بالشرط، ولم يصح الشرط فكان كله لرب المال، والخسران عليه.

والقول قول المضارب في دعوى الهلاك، والضياع، في المضاربة الفاسدة مع يمينه، في ظاهر الرواية، وجعل المال في يده أمانة كما في المضاربة الصحيحة، وذكر الطحاوي فيه اختلافا، وقال: لا ضمان عليه في قول أبي حنيفة، وعندهما يضمن، قياسا على الأجير المشترك إذا هلك المال في يده.

المبحث الخامس

صفة عقد المضاربة، والاختلاف فيها، وبطلانها

المطلب الأول: صفة عقد المضاربة

عقد المضاربة عقد غير لازم، ولكل من رب المال والمضارب فسخه، لكن لا يمكن لكل واحد منهما فسخ العقد إلا عند وجود شرطه.

شرط فسخ عقد المضاربة

إعلام أحد الطرفين الآخر بإرادته فسخ العقد، فإن كان الفسخ من جهة رب المال، كان عليه إعلام المضارب؛ لأنه وكيل من جهته، والفسخ بمنزلة العزل للمضارب، وعزل الوكيل قصدا يتوقف على علمه، وإن كان الفسخ من جهة المضارب، كان عليه إعلام رب المال؛ لأنه يعمل بماله، فلا بد من إعلامه.

أن يكون رأس المال وقت الفسخ نقودا: حتى لو نهى رب المال المضارب عن التصرف، ورأس المال عروض وقت النهي، لم يصح نهيه وله أن يبيعها؛ لأنه يحتاج إلى بيعها بالنقود؛ ليظهر الربح، فكان النهي والفسخ إبطالا لحقه في التصرف، فلا يملك ذلك، وإن كان رأس المال نقودا وقت الفسخ والنهي، صح الفسخ والنهي.

المطلب الثاني

اختلاف المضارب ورب المال

اختلاف رب المال والمضارب له أحوال، من أهمها:

الأول: الاختلاف في العموم والخصوص: فإذا اختلف المضارب ورب المال في العموم والخصوص، بأن ادعى أحدهما المضاربة في عموم التجارات، أو في عموم الأمكنة، أو مع عموم الأشخاص، وادعى الآخر نوعا دون نوع، ومكانا دون مكان، وشخصا دون شخص، فالقول قول من يدعي العموم.

ووجه ذلك: أن قول: من يدعي العموم موافق للمقصود بالعقد، إذ المقصود من العقد هو الربح، وهذا المقصود في العموم أوفر.

الحال الثاني: الاختلاف في الإطلاق والتقييد: إذا اختلف المضارب ورب المال في الإطلاق والتقييد، كما لو قال رب المال: أذنت لك أن تتجر في الحنطة دون ما سواها، وقال المضارب: ما سميت لي تجارة بعينها، فالقول قول من يدعي الإطلاق، وهو المضارب مع يمينه؛ لأن الإطلاق أقرب إلى المقصود بالعقد، إذ المقصود من العقد هو الربح، وهذا المقصود في العموم أوفر.

وقال الحسن بن زياد: إن القول قول رب المال في الفصلين جميعا، وقيل: إنه قول زفر. **ووجه هذا القول:** أن الإذن يستفاد من رب المال، فكان القول في ذلك قوله، فإن قامت لهما بينة، فالبينة بينة مدعي العموم في دعوى العموم والخصوص؛ لأنها تثبت زيادة، وفي دعوى التقييد والإطلاق، البينة بينة مدعي التقييد؛ لأنها تثبت زيادة فيه، وبينة الإطلاق ساكتة.

ولو اتفقا على الخصوص؛ لكنهما اختلفا في ذلك الخاص، فقال رب المال: دفعت المال إليك مضاربة في البز، وقال المضارب: في الطعام، فالقول قول رب المال في قولهم جميعا؛ لأنه لا يمكن الترجيح هنا بالمقصود من العقد، لاستوائهما في ذلك، فترجح بالإذن، وإنه يستفاد من رب المال.

فإن أقاما البينة فالبينة بينة المضارب؛ لأن بينته مثبتة وبينة رب المال نافية؛ لأنه لا يحتاج إلى الإثبات، والمضارب يحتاج إلى الإثبات لدفع الضمان عن نفسه، فالبينة المثبتة للزيادة أولى.

وقد قالوا في البينتين إذا تعارضتا في صفة الإذن وقد وقتتا: إن الوقت الأخير أولى؛ لأن الشرط الثاني ينقض الأول، فكان الرجوع إليه أولى.

الحال الثالث: الاختلاف في قدر رأس المال: إذا اختلفا في قدر رأس المال والربح، فقال رب المال: كان رأس مالي ألفين، وشرطت لك ثلث الربح، وقال المضارب: رأس المال ألف، وشرطت لي نصف الربح، فإن كان في يد المضارب ألف جنيه يقر أنها مال المضاربة، فالقول قول المضارب في أن رأس المال ألف، والقول قول رب المال أنه شرط ثلث الربح. وهذا قول أبي حنيفة الآخر، وهو قول أبي يوسف، ومحمد. وكان قول أبي حنيفة الأول: أن القول قول رب المال في الأمرين جميعا، وهو قول زفر.

وجه القول الأول لأبي حنيفة: أن الريح يستفاد من أصل المال، وقد اتفقا على أن جملة المال مضاربة، وادعى المضارب استحقاقا فيها، ورب المال ينكر ذلك، فكان القول قوله. وجه قوله الآخر: أن القول في مقدار رأس المال قول المضارب؛ لأنهما اختلفا في مقدار المقبوض، فكان القول قول القابض، ألا ترى أنه لو أنكر القبض أصلا، وقال لم أقبض منك شيئا كان القول قوله، فكذا إذا أنكر البعض دون البعض.

وإنما كان القول قول رب المال في مقدار الريح؛ لأن شرط الريح يستفاد من قبله، فكان القول في مقدار المشروط قوله، ألا ترى أنه لو أنكر الشرط رأسا، فقال لم أشرط لك ربحا، وإنما دفعت إليك بضاعة كان القول قوله، فكذا إذا أقر بالبعض دون البعض، وإذا كان القول قول المضارب في قدر رأس المال في قوله الأخير، فالقول قول رب المال في مقدار الريح في قولهم: يجعل رأس المال ألف جنيه، ويجعل للمضارب ثلث الألف الأخرى، فلا يقبل قول رب المال في زيادة رأس المال، ولا يقبل قول المضارب في زيادة شرط الريح وعلى قوله الأول يأخذ رب المال الألفين جميعا.

الحال الرابع: الاختلاف حال جحود المضارب المضاربة: لو جحد المضارب المضاربة أصلا، ورب المال يدعي دفع المال إليه مضاربة، فالقول قول المضارب؛ لأن رب المال يدعي عليه قبض ماله، وهو ينكر، فكان القول قوله.

الحال الخامس: لو اختلفا في الريح، فقال رب المال: شرطت لك الثلث وقال المضارب: شرطت لي النصف، ثم هلك المال في يد المضارب، قال محمد: يضمن المضارب السدس من الريح، يؤديه إلى رب المال من ماله خاصة، ولا ضمان عليه فيما سوى ذلك؛ لأن القول في شرط الريح قول رب المال، وإذا كان كذلك فنصيب المضارب الثلث، وقد ادعى النصف، ومن ادعى أمانة في يده ضمنها، لذلك يضمن سدس الريح.

المطلب الثالث

ما يبطل به عقد المضاربة

عقد المضاربة يبطل بأمر من أهمها:

الأول: الفسخ، والنهي عن التصرف: إذا أراد رب المال أو المضارب فسخ المضارب، أو أراد رب المال أن ينهى المضارب عن العمل، فإنه يشترك لتحقيق ذلك: وجود شرط الفسخ والنهي، وهو علم صاحبه بالفسخ والنهي.

أن يكون رأس المال عينا وقت الفسخ والنهي، فإن كان متاعا لم يصح، وله أن يبيعه بالدرهم والدنانير حتى ينض، وإن كان عينا صح.

الأمر الثاني: موت أحد العاقدين: إذا مات المضار أو رب المال بطلت المضاربة؛ لأن المضاربة تشتمل على الوكالة، والوكالة تبطل بموت الموكل أو الوكيل، سواء علم المضارب بموت رب المال أو لم يعلم، لأنه عزل حكمي فلا يقف على العلم كما في الوكالة، إلا أن رأس المال إذا صار متاعا، فللوكيل أن يبيع حتى يصير ناضا.

الأمر الثالث: جنون أحد العاقدين: إذا جن رب المال أو المضارب بطلت المضاربة؛ إذا كان الجنون مطبقا؛ لأن الجنون المطبق يبطل أهلية الأمر للأمر، وأهلية التصرف للمأمور، وكل ما تبطل به الوكالة تبطل به المضاربة.

الأمر الرابع: ردة رب المال: لو ارتد رب المال فباع المضارب واشترى بالمال بعد الردة، فذلك كله موقوف في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى، إن رجع إلى الإسلام بعد ذلك نفذ كله، والتحققت ردة بالعدم في جميع أحكام المضاربة، وصار كأنه لم يرتد أصلا. وكذلك إن لحق بدار الحرب، ثم عاد مسلما قبل أن يحكم بلحاقه بدار الحرب، على الرواية التي يشترط حكم الحاكم بلحاقه للحكم بموته وصيرورة أمواله ميراثا لورثته.

فإن مات أو قتل على الردة، أو لحق بدار الحرب، وقضى القاضي بلحاقه بطلت المضاربة من يوم ارتد على أصل أبي حنيفة رحمه الله تعالى: أن ملك المرتد موقوف إن مات أو قتل، أو لحق فحكم بالحق، يزول ملكه من وقت الردة إلى ورثته، ويصير كأنه مات في ذلك الوقت، فيبطل تصرف المضارب بأمره لبطان أهلية الأمر، ويصير كأنه تصرف في ملك الورثة.

فإن كان رأس المال يومئذ قائما في يده لم يتصرف فيه ثم اشترى بعد ذلك، فالمشتري وربحه يكون له؛ لأنه زال ملك رب المال عن المال فينعزل المضارب عن المضاربة، فصار متصرفا في ملك الورثة بغير أمرهم.

وإن كان صار رأس المال متاعا فبيع المضارب فيه وشراؤه جائز، حتى ينض رأس المال لما ذكرنا في هذه الحالة، أنه لا ينعزل بالعزل والنهي، ولا بموت رب المال، فذلك رده. فإن حصل في يد المضارب دنانير ورأس المال دراهم، أو حصل في يده دراهم ورأس المال دنانير، فالقياس أن لا يجوز له التصرف؛ لأن الذي حصل في يده من جنس رأس المال معنى لاتحادهما في الثمنية، فيصير كأن عين المال قائم في يده إلا أنهم استحسنا،

فقالوا: إن باع بجنس رأس المال جاز؛ لأن على المضارب أن يرد مثل رأس المال، فكان له أن يبيع ما في يده كالعروض.

وأما على أصل أبي يوسف ومحمد: فالردة لا تقدر في ملك المرتد، فيجوز تصرف المضارب بعد ردة رب المال، كما يجوز تصرف رب المال بنفسه عندهما، فإن مات رب المال أو قتل كان موته كموت المسلم في بطلان عقد المضاربة، وكذلك إن لحق بدار الحرب وحكم بلحاظه؛ لأن ذلك بمنزلة الموت، بدليل أن ماله يصير ميراثا لورثته، فبطل أمره في المال.

فإن لم يرتد رب المال ولكن المضارب ارتد، فالمضاربة على حالها في قولهم جميعا؛ لأن وقوف تصرف رب المال بنفسه لوقوف ملكه، ولا ملك للمضارب فيما يتصرف فيه، بل الملك لرب المال، ولم توجد منه الردة، فبقيت المضاربة إلا أنه لا عهدة على المضارب، وإنما العهدة على رب المال في قياس قول أبي حنيفة رحمه الله؛ لأن العهدة تلزم بسبب المال، فتكون على رب المال، وصار كما لو وكل صبيا محجورا أو عبدا محجورا، فأما على قولهما فالعهدة عليه؛ لأن تصرفه كتصرف المسلم.

وإن مات المضارب أو قتل على الردة بطلت المضاربة؛ لأن موته في الردة كموته قبل الردة، وكذا إذا لحق بدار الحرب وقضي بلحاظه؛ لأن رده مع اللحاق، والحكم به بمنزلة موته في بطلان تصرفه.

فإن لحق المضارب بدار الحرب بعد رده فباع واشترى هناك، ثم رجع مسلما، فجميع ما اشترى وباع في دار الحرب يكون له، ولا ضمان عليه في شيء من ذلك؛ لأنه لما لحق بدار الحرب صار كالحربي إذا استولى على مال إنسان، ولحق بدار الحرب، إنه يملكه، فكذا المرتد، وأما ارتداد المرأة أو عدم ارتدادها سواء في قولهم جميعا، سواء كان المال لها أو كانت مضاربة؛ لأن ردها لا تؤثر في ملكها، إلا أن تموت، فتبطل المضاربة كما لو ماتت قبل الردة، أو لحقت بدار الحرب، وحكم بلحاظها، لما ذكرنا أن ذلك بمنزلة الموت.

هالك مال المضاربة في يد المضارب

أولاً: هالك مال المضاربة في يد المضارب قبل الشراء

لو هلك مال المضاربة في يد المضارب قبل أن يشتري به شيئاً، بطلت المضاربة في قول أصحابنا؛ لأنه تعين لعقد المضاربة بالقبض، فيبطل العقد بهلاكه كالوديعة، وكذلك لو استهلكه المضارب أو أنفقه أو دفعه إلى غيره، فاستهلكه؛ لما قلنا. حتى لا يملك أن يشتري به شيئاً للمضاربة به.

فإن أخذ مثله من الذي استهلكه، كان له أن يشتري به على المضاربة، كذا روى الحسن عن أبي حنيفة؛ لأنه أخذ عوض رأس المال، فكان أخذ عوضه بمنزلة أخذ ثمنه، فيكون على المضاربة.

وروى ابن رستم عن محمد أنه لو أقرضها المضارب رجلاً، فإن رجع إليه الدراهم بعينها، رجعت على المضاربة؛ لأنه وإن تعدى يضمن، لكن إذا زال التعدي فيزول الضمان المتعلق به، وإن أخذ مثلاً لم يرجع في المضاربة؛ لأن الضمان قد استقر بهلاك العين، وحكم المضاربة مع الضمان لا يجتمعان.

ولهذا يخالف ما رواه الحسن بن زياد عن أبي حنيفة في الاستهلاك، هذا إذا هلك مال المضاربة قبل أن يشتري المضارب شيئاً.

ثانياً: الهالك بعد الشراء

إن هلك مال المضاربة بعد الشراء، بأن كان مال المضاربة ألفاً، فاشتري بها عرضاً، ولم ينقد الثمن البائع حتى هلكت الألف، فقد قال أصحابنا: العرض على المضاربة ويرجع على رب المال بالألف، فيسلمها إلى البائع، وكذلك إن هلكت الثانية التي قبض يرجع بمثلها على رب المال، وكذلك سبيل الثالثة والرابعة، وما بعد ذلك أبداً حتى يسلم إلى البائع، ويكون ما دفعه أولاً رب المال، وما غرم كله من رأس المال، وإنما كان كذلك لأن المضارب متصرف لرب المال، فيرجع بما لحقه من الضمان بتصرفه كالوكيل.

الفرق بين تكرار رجوع المضارب، وعدم تكرار رجوع الوكيل في هذه الحالة

الفرق بين الوكيل والمضارب في تكرار رجوع المضارب على رب المال، أن الوكيل إذا هلك الثمن في يده فرجع بمثله إلى الموكل، ثم إذا هلك الثاني لم يرجع على الموكل، والمضارب يرجع في كل مرة.

ووجه الفرق أن الوكالة قد انتهت بشراء الوكيل؛ لأن المقصود من الوكالة بالشراء استفادة ملك المبيع لا الربح، فإذا اشترى فقد حصل المقصود فانتهى عقد الوكالة بانتهائه، ووجب على الوكيل الثمن للبائع، فإذا هلك في يده قبل أن ينقده البائع، وجب للوكيل على الموكل مثل ما وجب للبائع عليه، فإذا قبضه مرة فقد استوفى حقه، فلا يجب له عليه شيء آخر.

فأما المضاربة فإنها لا تنتهي بالشراء؛ لأن المقصود منها الربح، ولا يحصل إلا بالبيع والشراء مرة بعد أخرى، فإذا بقي العقد فكان له أن يرجع ثانيا وثالثا. وما غرم رب المال مع الأول يصير كله رأس المال؛ لأنه غرم لرب المال بسبب المضاربة، فيكون كله من مال المضاربة، ولأن المقصود من هذا العقد هو الربح، فلو لم يصر ما غرم رب المال من رأس المال ويهلك مجانا، يتضرر به رب المال؛ لأنه يخسر ويربح المضارب، وهذا لا يجوز.

انفساخ المضاربة والمال ديون على الناس

إذا انفسخت المضاربة، ومال المضاربة ديون على الناس، وامتنع عن التقاضي والقبض، فإنه يفرق بين حالتين: إن يكون في المال ربح، وأن لا يكون في المال ربح. الأولى: إذا كان في المال ربح: أجبر المضارب على التقاضي والقبض؛ لأنه إذا كان هناك ربح، كان له فيه نصيب، فيكون عمله عمل الأجير، والأجير مجبور على العمل فيما التزم.

والحالة الثانية: إذا لم يكن في المال ربح: إذا لم يكن هناك ربح لم تسلم له منفعة، فكان عمله عمل الوكلاء، فلا يجبر على إتمام العمل، كما لا يجبر الوكيل على قبض الثمن، غير أنه يؤمر المضارب أو الوكيل أن يحيل رب المال على الذي عليه الدين حتى يمكنه قبضه؛ لأن حقوق العقد راجعة إلى العاقد، فلا يثبت ولاية القبض للأمر إلا بالحوالة من العاقد، فيلزمه أن يحيله بالمال حتى لا يتوى حقه.

ولو ضمن العاقد لرب المال هذا الدين الذي عليه، لم يجز ضمانه؛ لأن العاقد قد جعله أمينا، فلا يملك أن يجعل نفسه ضميئا فيما جعله العاقد أمينا.

موت المضارب دون بيان لمال المضاربة فيما خلف

لو مات المضارب ولم يوجد مال المضاربة فيما خلف، فإنه يعود دينا فيما خلف المضارب، وكذا المودع، والمستعير، والمستبضع، وكل من كان المال في يده أمانة، إذا

مات قبل البيان ولا تعرف الأمانة بعينها، فإنه يكون عليه ديناً في تركته؛ لأنه صار بالتجهيل مستهلكاً للوديعة، ولا تصدق وراثته على الهلاك والتسليم إلى رب المال.

ولو عين الميت المال في حال حياته، أو علم ذلك، يكون ذلك أمانة في وصية، أو في يد وارثه، كما كان في يده، ويصدقون على الهلاك والدفع إلى صاحبه، كما يصدق الميت في حال حياته والله عز وجل أعلم. والحمد لله رب العالمين.

المضاربة في المؤسسات المالية الإسلامية وتطبيقاتها

في هذا المبحث، وبناء على ما تتبين من أحكام المضاربة في الفقه الإسلامي، أقدم صورة مختصرة عن ما عليه العمل بالمضاربة في المصارف الإسلامية، وهي في حقيقتها تمثل تطبيقاً عملياً لأحكام المضاربة الواردة في الفقه الإسلامي، لاتخرج عنها، ليس فيها من جديد إلا بعض الطرق والإجراءات التي تتسق مع أحوال العصر، والتجمعات المالية.

علاقة البنك بالمودين في الاستثمار بالمضاربة

تقوم علاقة البنك بالمودين في الاستثمار بالمضاربة الشرعية، على الشراكة بالمضاربة، حيث يعمل البنك بصفة الشريك المضارب، وفي تلك العلاقة يكون البنك الشريك المضارب بعمله، والمودون هم المضاربون برؤوس أموالهم.

وتوزع الأرباح الناتجة عن التشغيل بالنسب المتفق عليها بين البنك وبين الأصحاب الأموال، أما الخسارة فهي على رأس المال، ما لم يثبت تقصير المضارب، وهذه المضاربة وتتخذ هذه المعاملة صورتين:

الأولى: المضاربة العامة: وهي التي يستثمر فيها البنك رأس مال المضاربة في كافة أوجه الاستثمار، حيث تصب كل الأموال في وعاء استثماري واحد هو حساب الاستثمار العام الذي يقوم البنك باستخدامه في كافة أوجه التمويل والاستثمار. مضاربة خاصة: وهي التي تكون خاصة بمشروع معين أو قطاع استثماري معين، ويتخذ التمويل في هذه المضاربة صورة التصكيك، بأن يصدر البنك صكوكاً لتمويل أحد المشاريع.

أنواع الاستثمار بالمضاربة في المصارف الإسلامية بالنظر إلى وقت تنفيذه

يتنوع الاستثمار بالمضاربة في المصارف الإسلامية، إلى الأنواع الآتية:

استثمارات قصيرة الأجل: وهي التي يضارب المصرف فيها على صفقة واحدة، وهي تختص بدورة واحدة محددة من دورات رأس المال.

استثمارات متوسطة الأجل: وهي التي يضارب فيها في سلعة يشتريها ثم يبيعها في مدد ليست بالطويلة.

استثمارات طويلة الأجل: وهي التي يعمل فيها المصرف مع آخرين، من خلال تمويل رأس مال مشروع بالكامل لفترة طويلة، وتتميز بدوران راس المال عدة دورات. وغالبا ما يكون نشاط المصارف في المجالات التجارية، ومن أهم نشاطاته فيها: شراء السلع من مصادر انتاجها وبيعها بالأسواق المحلية.

أنواع: المضاربة بالنظر إلى تصرف المضارب

تتنوع المضاربة بالنظر إلى ما يملكه المضارب من التصرف إلى: المضاربة المطلقة، والمضاربة والمقيدة. وبناء على موافقة أصحاب الأموال يستطيع المصرف العمل بالمضاربة بنوعيتها. بما يحقق مصلحة أصحاب الأموال ومصرف.

ومن الناحية العملية فإن المصارف الإسلامية تستفيد من التعامل بنوعي المضاربة، المطلقة والمقيدة، فكل النوعين يلائم الاستثمار بالمضاربة في المصارف الإسلامية: مع ملاحظة أن التعامل بالمضاربة المطلقة، في المصارف الإسلامية أو سع نطاقا، عنه في المضاربة المقيدة.

وذلك لكون المضاربة المطلقة تتيح للمصرف القيام بمباشرة جميع التصرفات التي يرى أنها تفيد المضاربة، وتحقق الهدف من المضاربة.

لكن هذا ليس على إطلاقه، فالاستثمار بالمضاربة يتم بحسب أحوال المصرف في العمل بالمضاربة، فإذا كان المصرف يعمل في المضاربة بصفته مضاربا كما هو الحال في الصناديق الاستثمارية، تناسبه المضاربة المطلقة، وإذا كان المصرف يعمل بصفته صاحب المال، أو وكيله، تناسبه المضاربة المقيدة.

المجال المناسب للمضاربة في الأنشطة التجارية

المضاربة في السلع التي يمكن شراؤها من مصادر انتاجها وبيعها بالأسواق المحلية، هي المجال الذي يناسب المضاربة التجارية، لكن الاستثمار بالمضاربة في هذا المجال يحتاج إلى أن يكون لدى المتعامل في الأنواع المختلفة من السلع، الخبرة الكافية.

ولعدم استيعاب المتعاملين لأسلوب تطبيق هذه الصيغة، وعدم توافر ذوي الأمانة والثقة في المتعاملين في المضاربة التجارية في السلع، إضافة إلى المخاطر المترتبة على قيام المصرف بتمويل كافة العملية، دون أن يدفع العميل حصة في التمويل.

امتنعت بعض المصارف الإسلامية عن التعامل بصيغة المضاربة.

أنواع المضاربة بالنظر إلى أطرافها، في المصارف الإسلامية

الصور التي تتخذها المصارف الإسلامية للاستثمار في المضاربة، قد تكون: بين رب المال والعامل فقط، وهي ما يطلق عليها: المضاربة الثنائية، وقد يتعدد أصحاب الأموال في المضاربة، وهو ما يطلق عليها المضاربة المشتركة، أو المضاربة الجماعية.

ويعد الاستثمار بالمضاربة المشتركة، أو الجماعية، الصورة الشرعية الأبرز في الاستثمار المصرفي، وتقوم هذه الصيغة على أساس تعدد العلاقة بين أصحاب رؤوس الأموال والمضاربين، وتتخذ المضاربة المشتركة في الناحية العملية صوراً من أهمها:

توصيف دور المصرف الإسلامي في العمل بالمضاربة

بعد أن يقوم المصرف بدراسة الفرص الاستثمارية، المتاحة، للعمل بالمضاربة، يتخذ التمويل بالمضاربة في المصرف الإسلامي إحدى صورتين:

الصورة الأولى: وهي التي يقوم المصرف فيها باستثمار أموال المساهمين والمودعين استثماراً مباشراً، دون الاستعانة بمضاربين آخرين.

وفي هذا الصورة يعمل المصرف بصفته: مضارباً، ورب مال في نفس الوقت.

الصورة الثانية: وهي التي يقوم المصرف فيها باستثمار ودائع العملاء التي لديه بعد موافقتهم، بالاستعانة بعدد من رجال الأعمال، وإعطائهم الأموال، وفي هذه الصورة يكون عمل المصرف بصفته رب المال.

وفيها يكون المشروع ممول بالكامل بالودائع الاستثمارية المخصصة لحساب الاستثمار المخصص،) وينفذ من قبل رجال الأعمال من عملاء المصرف على أساس المضاربة.

وفي الصورتين يتم الاتفاق على أن توزع الأرباح بين الأطراف الثلاثة، والخسارة على صاحب المال. ويتم تحديد طرق توزيع الأرباح على أساس الربح الذي تحصل فعلياً، ولا يجوز الاتفاق على توزيع الربح في صورة: مبالغ محددة، أو نسبة إلى رأس المال.

صيغ الاستثمار بالمضاربة في المصارف الإسلامية

تتنوع صيغ الاستثمار بالمضاربة في المصارف الإسلامية إلى:

الأولى: المضاربة المشتركة:

وفيها يتكون رأس مال المضاربة، من: الودائع الاستثمارية المخصصة لحساب الاستثمار المخصص، وأموال أصحاب الأسهم، فيكون البنك شريكاً في رأس المال، ومضارباً. وهذه الصورة محل نظر حيث إن البنك يضع يده على مال المضاربة، رغم أنه رب مال.

الثانية: صكوك المضاربة:

وهي التي يقوم فيها البنك بتجزئة رأس المال المعد للمضاربة، من خلال إصدار صكوك ملكية برأس مال المضاربة، بوحدات متساوية القيمة، كالف جنيه للوحدة، أو أكثر أو أقل، حسب ما يتم عملاً.

والثالثة: المضاربة المنتهية بالتمليك:

وتتم على اعتبار أن المصرف هو رب المال، والعميل هو المضارب، حيث يقدم المصرف المال للعميل، ويعطيه إمكانية أن يشتري حصة البنك كاملة، سواء كان هذا مرة واحدة، أو أكثر من مرة. حسب ما يتم به الاتفاق بين المصرف والعميل.
تم بحمد الله وتوفيقه

وكتبه : د. أحمد عبد العليم أبو عليو
كلية الشريعة والقانون بأسسيوط

الفصل السادس الصرف

أهداف الفصل :

يتوقع من الدارس بعد دراسته لهذه الفصل أن:

يبين المراد بالصرف ودليل مشروعيته.

يذكر شروط الصرف.

يوضح الأحكام المتعلقة بالصرف.

الصرف وما يتعلق به من أحكام

وفيه ثلاثة مباحث:

المبحث الأول: تعريف الصرف ودليل مشروعيته.

المبحث الثاني: شروط الصرف.

المبحث الثالث: الأحكام المتعلقة بالصرف.

المبحث الأول

تعريف الصرف ودليل مشروعيته

أولاً: تعريف الصرف لغة وشرعاً:

الصرف في اللغة: صرف صرفاً، وصرف المال أنفقه، وصرف النقد بنقد غيره إذا بدله، وله استعمالات أخرى كثيرة مثل الفضل والنقل والتحويل وغيرها والمراد به هنا التحويل والتغير (١).

ثانياً: تعريف الصرف شرعاً:

الصرف هو البيع إذا كان كل واحد من عوضيه من جنس الأثمان، أو هو مبادلة الأثمان بعضها ببعض كالذهب والفضة إذا بيع أحدهما بالآخر أو بجنسه (٢).

ثالثاً: دليل مشروعيته:

من الكتاب:

قوله تعالى: "وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا" [البقرة: ٢٧٥] من غير فصل، والصرف نوع من أنواع البيع التي أحلها الله.

(١) معجم اللغة العربية المعاصر مادة صرف.

(٢) فتح القدير ٧ / ١٣٤.

وأما السنة:

فقوله صلى الله عليه وسلم: (الذهب بالذهب مثلاً بمثل يداً بيدي، والفضل ربا، والفضة بالفضة مثلاً بمثل يداً بيدي، والفضل ربا، والحنطة بالحنطة مثلاً بمثل يداً بيدي، والفضل ربا، والملح بالملح مثلاً بمثل يداً بيدي، والفضل ربا، والشعير بالشعير مثلاً بمثل يداً بيدي، والفضل ربا، والتمر بالتمر مثلاً بمثل يداً بيدي، والفضل ربا) (١).

وقوله صلى الله عليه وسلم: (لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلاً بمثل، ولا تبيعوا الورق بالذهب أحدهما غائب والآخر ناجز، وإن استنظر أن يلج بيته فلا تنتظره إلا يداً بيدي هاتٍ وهاتٍ، إني أخشى عليكم الربا) (٢).

وأما المعقول:

فلا يطلب بعقد الصرف إلا زيادة تحصل فيما يقابلها من الجودة والصياغة؛ إذ النقود لا ينتفع بعينها كما ينتفع بغيرها مما يقابلها من المطعوم والملبوس؛ فلو لم يطلب به الزيادة والعين حاصلة في يدي ما كان فيه فائدة فلا يكون مشروع، فالصيرفي يحقق ربحاً من المصارفات المعالجة؛ لأن التفاضل بين البدلين جائز إذا اختلفت العملات.

المبحث الثاني

شروط الصرف

شروط الصرف إجمالاً ثلاثة:

الأول: التقابض قبل افتراق المتعاقدين.

الثاني: التماثل.

الثالث: ألا يكون فيه خيار ولا تأجيل.

التقابض قبل الافتراق بالأبدان بين المتعاقدين:

يشترط في عقد الصرف قبض البدلين جميعاً قبل مفارقة أحد المتصارفين للآخر افتراقاً بالأبدان، منعاً من الوقوع في ربا النسئة، ولقوله صلى الله عليه وسلم: «الذهب

(١) أخرجه الإمام الزيلعي في نصب الراية كتاب البيوع باب الربا.

(٢) المرجع السابق نفس الموضع.

بالذهب مثلاً بمثل، يداً بيد، والفضة بالفضة مثلاً بمثل، يداً بيد» (١) وقوله صلى الله عليه وسلم: «لا تبيعوا منهما غائباً بناجز» (٢) فإن افترق المتعاقدان قبل قبض العوضين أو أحدهما، فسد العقد عند الحنفية وبطل عند غيرهم؛ لفوات شرط القبض، ولئلا يصير العقد بيعاً للكالي بالكالي أي الدين بالدين فيحصل الربا: وهو الفضل في أحد العوضين، والتقابض شرط سواء اتحد الجنس أو اختلف.

تفسير الافتراق بالأبدان:

هو أن يفترق العاقدان بأبدانهما عن مجلس العقد، فيتجه هذا في جهة، وهذا في جهة، أو يذهب أحدهما ويبقى الآخر، فإن بقيا في مجلسهما لم يبرحا عنه، لم يحصل الافتراق وإن طال مجلسهما لانعدام التفرق بالأبدان، كذلك لا يحصل التفرق إن ناما في المجلس أو أغمي عليهما أو قاما عن المجلس فذهبا معاً في جهة واحدة وطريق واحدة ومشياً ميلاً أو أكثر ولم يفارق أحدهما صاحبه، فلا يعتبران مفترقين؛ لأن العبرة لتفرق الأبدان ولم يوجد ذلك (٣).

التماثل عند اتحاد الجنس:

إذا بيع الجنس بالجنس كفضة بفضة، أو ذهب بذهب، فلا يجوز إلا مثلاً بمثل وزناً، وإن اختلفا في الجودة والصياغة بأن يكون أحدهما أجود من الآخر أو أحسن صياغة لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث السابق: «الذهب بالذهب مثلاً

(١) رواه الجماعة إلا البخاري من حديث عبادة بن الصامت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «الذهب بالذهب والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح مثلاً بمثل، سواءً بسواء، يداً بيد، وإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يداً بيد» (راجع نصب الراية: ٤ / ٤).

(٢) لهذا اللفظ رواية عند مالك في الموطأ عن عمر رضي الله عنه قال: (لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلاً بمثل، ولا تبيعوا الورق بالذهب أحدهما غائب والآخر ناجز) وورد نص الحديث عند أحمد والشيخين عن أبي سعيد الخدري بلفظ «لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلاً بمثل ولا تُشَفَّوْا (أي لا تفضلوا) بعضها على بعض، ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلاً بمثل، ولا تُشَفَّوْا بعضها على بعض، ولا تبيعوا منهما غائباً بناجز» (راجع نصب الراية: ٥٦ / ٤، نيل الأوطار: ١٩٠ / ٥).

(٣) الفقه الإسلامي وأدلته ٣٦٦١/٥.

بمثل» (١) أي يباع الذهب بالذهب مثلاً بمثل في القدر، لا في الصفة، للقاعدة الشرعية: «جيدها ورديئها سواء» (٢).

أن يكون العقد باتاً أو ألا يكون فيه خيار شرط:

لا يجوز في عقد الصرف اشتراط الخيار لكل من المتعاقدين أو لأحدهما؛ لأن القبض في هذا العقد شرط. وخيار الشرط يمنع ثبوت الملك أو تمامه على الخلاف الذي ذكر في مبحثه، والخيار يخل بالقبض المشروط: وهو القبض الذي يحصل به التعيين، فلو شرط هذا الخيار فسد العقد. ولو أسقط صاحب الخيار خياره في المجلس، ثم افترق المتعاقدان عن تقابض، ينقلب العقد إلى الجواز، خلافاً لزفر، فإذا بقي حتى افترقا تقرر الفساد.

المبحث الثالث

الأحكام المتعلقة بالصرف

أولاً: حكم التصرف في ثمن الصرف قبل قبضه:

لا يصح التصرف في ثمن الصرف قبل قبضه، فلو باع ديناراً بدراهم ثم اشترى بها ثوباً فسد البيع في الثوب، أي في أحد بدلي الصرف؛ لأن كلا منهما ثمن، فلا تجوز هبته ولا صدقته ولا ببيع شيء به، وقدمنّا أنه إن وهب أو تصدق به أو أبرأه: فإن قبل الآخر انفسخ الصرف؛ لتعذر وجود القبض وإلا فلا، وأما البيع: فصورته كما إذا باع ديناراً بعشرة دراهم ولم يقبضها حتى اشترى بها ثوباً أو مكياً أو موزوناً فالبيع في الثوب فاسد؛ لأن قبض العشرة مستحق حقاً لله تعالى فلا يسقط بإسقاط المتعاقدين، فلم يجز بيع الثوب والصرف على حاله يقبض بدله من عاقده معه، وأورد عليه أن فساد الصرف حينئذ حق الله تعالى وصحة بيع الثوب حق العبد فتعارضاً فيقدم حق العبد لتفضل الله بذلك، وأجيب بأن ذلك بعد ثبوت الحقين ولم يثبت حق العبد بعد؛ لأنه

(١) قال الزيلعي عن هذا الحديث: غريب ومعناه يؤخذ من إطلاق حديث أبي سعيد الخدري الذي أخرجه مسلم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلاً بمثل، يداً بيد فمن زاد أو استزاد فقد أربى، الآخذ والمعطي فيه سواء» (راجع نصب الراية: ٣٦/٤).

(٢) المرجع السابق نفس الصفحة.

يفوت حق الله بعد تحققه فيمتنع لا أنه يرتفع، وقد نقل عن زفر صحة بيع الثوب؛ لأن الثمن في بيعه لم يتعين كونه بدل الصرف؛ لأن العقد لا يتعين إضافة العقد إلى بدل الصرف كعدم إضافته فيجوز شراء ثوب بدراهم لم يصفها، وجوابه: أن قبض بدل الصرف واجب والاستبدال يفوته، فكان شرط إيفاء ثمن الثوب من بدل الصرف شرطاً فاسداً فيمتنع الجواز (١).

ثانياً: حكم بيع سيفٍ حليته خمسون بمائة ونقد خمسين:

من باع سيفاً حليته خمسون بمائة ونقد خمسين فهي حصتها وإن لم يبين، أو قال: من ثمنهما، أما إذا لم يبين يحمل على الصلاح، وأما إذا قال: خذ هذا من ثمنهما فلأن التثنية قد يراد بها الواحد منهما قال الله تعالى {نَسِيًا حُوتَهُمَا} (٢) والناسي أحدهما، وقال تعالى {يَخْرُجُ مِنْهُمَا اللُّؤْلُؤُ وَالْمَرْجَانُ} (٣) والمراد أحدهما، وفي الحديث فأذننا وأقيما والمراد أحدهما فيحمل عليه لظاهر حالهما بالإسلام، ونظيره في الفقه إذا حضمتا حيضة أو ولدتما ولدا علق بأحدهما للاستحالة، بخلاف ما إذا لم يذكر المفعول به للإمكان، وقد فاتت صورتان الأولى أن يبين ويقول خذ هذا نصفه من ثمن الحلية ونصفه من ثمن السيف، الثانية أن يجعل الكل من ثمن السيف وفيهما يكون المقبوض ثمن الحلية لأنهما شيء واحد فيجعل عن الحلية لحصول مراده.

ولو قال: خذ هذه الخمسين من ثمن السيف خاصة، وقال الآخر: نعم، أو قال: لا، وتفرقا على ذلك انتقض البيع في الحلية؛ لأن الترجيح بالاستحقاق عند المساواة في العقد أو الإضافة، ولا مساواة بعد تصريح الدافع بكون المدفوع ثمن السيف خاصة، والقول في ذلك قوله؛ لأنه هو المملك فالقول له في بيان جهته (٤)

ثالثاً: حكم الزيادة في بيع الجنس المختلفين بمثلها:

يصح بيع درهمين ودينار بدرهم ودينارين وكر بر وشعير بضعفهما أي بأن يبيعهما بكري بر وكري شعير وإنما جاز؛ لأنه يجعل كل جنس مقابلاً بخلاف جنسه تصحيحاً للعقد، ولو صرف إلى جنسه فسد؛ لأن العقد يقتضي مطلق المقابلة من غير تعرض

(١) البحر الرائق شرح كنز الدقائق ٢١٢/٦.

(٢) سورة الكهف الآية (٦١).

(٣) سورة الرحمن الآية (٢٢).

(٤) (٤) البحر الرائق شرح كنز الدقائق ٢١٣/٦.

لقيد لا مقابلة الكل بالكل شائعاً ولا فرداً معيناً، فصار كما لو باع نصف عبد مشترك بينه وبين غيره فإنه ينصرف إلى نصيبه تصحيحاً للعقد وكانصراف النقد إلى المتعارف، ولا يرد علينا ما لو اشترى قلباً بعشرة وثوباً بعشرة ثم باعهما مربحة بخمسة وعشرين فإنه لا يصح وإن أمكن صرف الربح إلى الثوب؛ لأننا لو صرفناه لصار تولية في القلب وهو خلاف المربحة فكان إبطالاً له، وكذا لا يرد لو اشترى عبداً بألف ثم باعه قبل النقد مع آخر من البائع بألف وخمسمائة فإنه لا يصح في المشتري بألف؛ لأن طريق التصحيح غير متعين لإمكان صرف الألف ومائة إليه أو مائتين إلى غير ذلك من الصور وأورد عليه أن الطرق متعددة في مسألة الكتاب لجواز أن يصرف الدينار إلى الدينار والدرهم إلى الدرهم والدينار إلى الدرهم كما يجوز أن يصرف الدرهمان إلى الدينارين والدينار إلى الدرهم وأجيب عنه بأنه أقل تغييراً فكان أولى وكذا لا يرد علينا ما لو جمع بين عبده وعبد غيره، وقال بعثك أحدهما فإنه لا يصح للتكرير، وإن أمكن تصحيحه بصرفه إلى عبده وأجيب بأن البيع أضيف إلى منكر فلا ينصرف إلى المعين للتضاد إذ المنكر ليس بمحل للبيع ورد بأنه ليس بشيء؛ لأن المعرفة من مكيا النكرة فإن زيدا يصدق عليه رجل ولا شك أنه يحتمله فيجب حمله عليه، وقد قال أبو حنيفة في قوله عبدي أو حماري حر أنه يعتق العبد ويجعل استعارة المنكر للمعرف، وكذا ما قيل إن تصحيح العقد يجب في محل العقد وهو لم يضاف إلى المعين. وفي "فتح القدير": واعلم أن ما أورد على دفع النقوض المذكورة أن الخط له جواب فذاك وإلا فلا يضررك النقض في إثبات المطلوب إذ غايته أنه خطأ في محل آخر إذا اعترف بخطئه في محل النقض وذلك لا يوجب خطأ في محل النزاع (١)

رابعاً: حكم بيع الذهب بالفضة متفاضلاً ومجازفةً:

وإن باع الذهب بالفضة متفاضلاً جاز لاختلاف الجنس ووجب التقابض لقوله .

صلى الله عليه وسلم: (الذهب بالورق ربا إلا هاء وهاء) (٢).

(١) البحر الرائق شرح كنز الدقائق ٢١٦/٦.

(٢) أخرجه البخاري في صحيحه كتاب البيوع باب بيع الشعر بالشعر .

وأما إن باع الذهب بالفضة مجازفة جاز أيضاً؛ لأنه ليس في المجازفة أكثر من التفاضل، والتفاضل بين الذهب والفضة جائز فكذا المجازفة، إلا أنه يشترط القبض في المجلس.

خامساً: حكم البيع بالفلوس النافقة وإن لم تتعين:

يصح البيع بالفلوس النافقة وإن لم تتعين؛ لأنها أموال معلومة وصارت أثماناً بالاصطلاح فجاز بها البيع، ووجبت في الذمة كالنقدين، ولا تتعين وإن عينها كالنقد إلا إذا قالوا: أردنا تعليق الحكم بعينها، فحينئذ يتعلق العقد بعينها، بخلاف ما إذا باع فلساً بفلسين بأعيانها حيث يتعين من غير تصريح؛ لأنه لو لم يتعين لفسد البيع وهذا على قولهما، وأما على قول محمد: لا يتعين وإن صرحا، وأصله: أن اصطلاح العامة لا يبطل باصطلاحهما على خلافه عنده، وعندهما يبطل في حقهما (١).

سادساً: حكم بيع إثناء فضة وقبض بعض ثمنه واقتراقا:

صح فيما قبض والإثناء مشترك بينهما، يعني إذا باعه بفضة أو ذهب لأنه صرف وهو يبطل بالاقتراق قبل القبض، فيتقدر الفساد بقدر ما لم يقبض ولا يشيع؛ لأنه طارئ ولا يكون هذا تفريق الصفقة أيضاً؛ لأن التفريق من جهة الشرع باشتراط القبض لا من العاقد، ولا يثبت للمشتري خيار عيب الشركة؛ لأنها حصلت منه وهو عدم النقد قبل الاقتراق، بخلاف ما إذا هلك أحد العبدین قبل القبض حيث ثبت الخيار في أخذ الباقي لعدم الصنع منه.

وإن استحق بعض الإثناء أخذ المشتري ما بقي بقسطه أو رد؛ لأن الشركة في الإثناء عيب؛ لأن التشقيص يضره وهذا العيب كان موجوداً عند البائع مقارناً، فإن أجاز المستحق قبل أن يحكم له بالاستحقاق جاز العقد وكان الثمن له يأخذه البائع من المشتري ويسلمه إليه إذا لم يفترقا بعد الإجازة، ويصير العاقد وكيلاً للمجيز فتتعلق حقوق العقد بالوكيل دون المجيز، حتى لو افترق المتعاقدان قبل إجازة المستحق بطل العقد، وإن فارقه المستحق قبل الإجازة والمتعاقدان باقيان في المجلس بطل العقد، كذا في السراج الوهاج أطلق الخيار فشمّل ما قبل القبض وبعده، ولو باعه قطعة فاستحق بعضها أخذ ما بقي بقسطه بلا خيار؛ لأن الشركة فيها ليست بعيب إذ التشقيص فيها لا يضرها بخلاف الإثناء أطلقه وهو محمول على ما إذا كان بعد قبضها أما إذا استحق بعض النقرة قبل قبضها فإن له الخيار لتفرق الصفقة عليه قبل التمام، بخلاف ما بعد القبض لتمامها. وفي "المغرب": النقرة القطعة المذابة من الذهب أو الفضة ويقال نقرة فضة على الإضافة للبيان (٢).

(١) البحر الرائق شرح كنز الدقائق ٢٢١/٦.

(٢) البحر الرائق شرح كنز الدقائق ٢١٥/٦.

سابعاً: حكم الإقالة في الصرف:

الإقالة في الصرف كالإقالة في البيع، أي يشترط فيها التقابض من الجانبين قبل الافتراق كما في ابتداء عقد الصرف؛ فلو تقايلا الصرف، وتقابضا قبل الافتراق، مضت الإقالة على الصحة.

وإن افتراقاً قبل التقابض بطلت الإقالة، سواء اعتبرت بيعاً أم فسخاً، فعلى اعتبارها بيعاً: كانت المصارفة مبتدأة، فلا بد من التقابض يداً بيد، ما دامت الإقالة بيعاً مستقلاً يحلها ما يحل البيوع، ويحرمها ما يحرم البيوع، فلا تحصل الإقالة إذا حصل الافتراق قبل القبض على اعتبارها فسخاً في حق المتعاقدين، فهي بيع جديد في حق ثالث، واستحقاق القبض حق للشرع، وهو هنا ثالث، فيعتبر بيعاً جديداً في حق هذا الحكم فيشترط فيه التقابض .

وهلاك البدلين في الصرف لا يعد مانعاً من الإقالة؛ لأنه في الصرف لا يلزمه رد المقبوض بعد الإقالة، بل رده أو رد مثله، فلم تتعلق الإقالة بعينهما، فلا تبطل بهلاكهما.

من خلال دراستك لباب الصرف أجب عما يلي:

عرف الصرف لغة وشرعاً، واذكر أدلة مشروعيته.

اذكر شوط الصرف إجمالاً، ثم تحدث عن شرط التقابض قبل الافتراق بالأبدان، واذكر تفسير هذا الافتراق.

كتبه

أ.د/ إبراهيم رمضان عطايا. أستاذ ورئيس قسم الفقه بكلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بمدينة السادات

د/ أحمد محمد السيد المرسي العفيفي. مدرس الفقه بكلية الشريعة والقانون بطنطا

الفصل السابع الكفالة.

مناسبة الكفالة للبيع أنها غالباً يكون تحققها في الوجود عقب البيع؛ فإنه قد لا يطمئن البائع إلى المشتري فيحتاج إلى من يكفله بالثمن، أو لا يطمئن المشتري إلى البائع فيحتاج إلى من يكفله في المبيع وذلك في السلم، فلما كان تحققها في الوجود غالباً بعدها أوردتها في التعليم بعدها.

ولها مناسبة خاصة بالصرف، وهي أنها تصير بالآخرة معاوضة عما ثبت في الذمة من الائتمان وذلك عند الرجوع على المكفول عنه، ثم لزم تقديم الصرف لكونه من أبواب البيع السابق على الكفالة.

وتشمل ما يلي:

أولاً: تعريف الكفالة وحكمها.

ثانياً: ركن الكفالة.

ثالثاً: شرائط الكفالة.

رابعاً: حكم الكفالة.

خامساً: ما يخرج به الكفيل عن الكفالة.

سادساً: رجوع الكفيل.

أهداف الدرس

بدراسة باب الكفالة يكتسب الطالب ما يلي:

أولاً: المعلومات والمفاهيم:

معرفة مفهوم الكفالة وحكمها وأدلة مشروعيتها.

معرفة أنواع الكفالة وركناتها.

معرفة شرائط الكفالة.

معرفة حكم الكفالة.

معرفة ما يخرج به الكفيل عن الكفالة.

ثانياً: المهارات الذهنية:

يحلل أحكام الكفالة في ضوء فقه الواقع.

يستنبط الصور الحديثة للكفالة ويلحقها بالنوع المناسب من أنواعها.

بدراسة شروط الكفالة يستطيع التمييز بين صحيحها وباطلها.

يفرق بين الكفالة بالمال وبالنفس والدرك.

يعرف الفرق بين الكفالة والضمان والقبالة والحوالة.

أولاً: تعريف الكفالة:

الكفالة لغة: الضم قال تعالى ﴿ وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا ﴾ (١) أي ضمها إلى نفسه.

وقال عليه الصلاة والسلام (أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة) (٢) قرن بين

إصبعيه الوسطى والتي تلي الإبهام. أي ضم اليتيم إلى نفسه.

والكفيل الضامن والأنثى كفيل أيضاً وجمع الكافل كُفْل، وجمع الكفيل كُفْلَاء،

وقد يقال للجمع كفيل كما قيل في الجمع صديق ﴿ وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا ﴾ أي ضمَّنها إياه

حتى تكفل بحضانتها، ومن قرأ (وكفَّلها زكريا) فالمعنى ضمن القيام بأمرها وكفل المال

وبالمال ضمَّنه.

ويكفل ويكفل كفلاً وكُفُولاً وكفالة وكفل وكفل وتكفل به كله ضمَّنه وأكفله إياه

وكفله ضمَّنه وكفلت عنه بالمال لغريمه وتكفل بدينه تكفلاً، وكفيل وكافل وضمين

وضامن بمعنى واحد، وأما الكافل فهو الذي كفل إنساناً يعوله ويُنفق عليه (٣).

وفي الشرع: ضم ذمة، إلى ذمة، في المطالبة بالحق (٤).

والكفالة أنواع منها:

كفالة بالنفس: ككفالة شخص بالعودة إلى السجن.

والكفالة بالمال: كالكفالة بأداء ثمن السلعة التي اشتراها ديناً.

(١) سورة آل عمران: الآية ٣٧.

(٢) سنن أبي داود (٣٥) كتاب الأدب . ١٣١ باب في ضم اليتيم رقم ٥١٥٠ ج ٢ ص ٧٦٠ ، وقال الشيخ الألباني:

صحيح.

(٣) لسان العرب - (ج ١١ / ص ٥٨٨). معجم لغة الفقهاء - (ج ١ / ص ٣٨٢).

(٤) تحفة الفقهاء - (ج ٣ / ص ٢٣٧).

والكفالة بالدرك: الكفالة بالتسليم: كالكفالة بتسليم العين المؤجرة حين انتهاء مدة الإجارة، والكفالة بتسليم الولد حين انتهاء مدة الحضانة.

والكفالة المنجزة: وهي الكفالة التي لم تعلق بزمان معين، ولا تكون مضافة إلى المستقبل. والكفالة المعلقة: وهي الكفالة التي علفت على زمن، أو علفت على تصرف معين (١). والكفالة مشروعة بالكتاب والسنة، والمعقول.

فأما الكتاب:

فقول الله تعالى ﴿ قَالَ لَنْ أَرْسِلَهُ مَعَكُمْ حَتَّى تُؤْتُوا مَوْثِقًا مِنْ اللَّهِ لَتَأْتُنَّنِي بِهِ إِلَّا أَنْ يُحَاطَ بِكُمْ ﴾ (٢).

وقوله تعالى: ﴿وَلَمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ﴾ (٣) وما ثبت في شريعة من قبلنا فهو ثابت في شريعتنا ما لم يظهر نسخه.

وأما السنة:

فإن النبي ﷺ بعث والناس يكفلون فأقرهم على ذلك وقال النبي ﷺ: "الزَّعِيمُ غَارِمٌ، وَالْدَيْنُ مَقْضِيٌّ" (٤).

ولأبي داود في رجل لزم غريباً له حتى يقضي، أو يأتي بحميل، فقال ﷺ: «أنا أحمل»

وأما المعقول:

فالحاجة داعية إلى الاستيثاق بضمان المال أو البدن، وضمان المال يمتنع منه كثير من الناس، فلو لم تجز الكفالة بالنفس لأدى إلى الحرج، وعدم المعاملات المحتاج إليها (٥).

(١) معجم لغة الفقهاء - (ج ١ ص ٣٨٢).

(٢) سورة يوسف: من الآية ٦٦.

(٣) سورة يوسف: من الآية ٧٢.

(٤) سنن ابن ماجه (٩) باب الكفالة رقم ٢٤٠٥ ج ٢ ص ٨٠٤ [ش - (الزعيم) أي الكفيل. (غارم) أي ضامن.

(مقضى) أي يجب قضاؤه. قال الشيخ الألباني: صحيح.

(٥) السرخسي: المبسوط ج ١٩ / ص ٢٩٠.

ثانياً: ركن الكفالة.

ركن الكفالة: الإيجاب والقبول، الإيجاب من الكفيل، والقبول من الطالب وهذا عند أبي حنيفة ومحمد وهو قول أبي يوسف الآخر.

وفي قول أبي يوسف الأول الركن هو الإيجاب فحسب فأما القبول فليس بركن وهو أحد قولي الشافعي لما روي عَنْ سَلَمَةَ ابْنِ الْأَكْوَعِ رضي الله عنه، قَالَ: كُنَّا جُلُوسًا عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ، إِذْ أَتَى بِجَنَازَةٍ، فَقَالُوا: صَلِّ عَلَيْهَا، فَقَالَ: «هَلْ عَلَيْهِ دَيْنٌ؟»، قَالُوا: لَا، قَالَ: «فَهَلْ تَرَكَ شَيْئًا؟»، قَالُوا: لَا، فَصَلَّى عَلَيْهِ، ثُمَّ أَتَى بِجَنَازَةٍ أُخْرَى، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، صَلِّ عَلَيْهَا، قَالَ: «هَلْ عَلَيْهِ دَيْنٌ؟» قِيلَ: نَعَمْ، قَالَ: «فَهَلْ تَرَكَ شَيْئًا؟»، قَالُوا: ثَلَاثَةٌ دَنَانِيرَ، فَصَلَّى عَلَيْهَا، ثُمَّ أَتَى بِالثَّالِثَةِ، فَقَالُوا: صَلِّ عَلَيْهَا، قَالَ: «هَلْ تَرَكَ شَيْئًا؟»، قَالُوا: لَا، قَالَ: «فَهَلْ عَلَيْهِ دَيْنٌ؟»، قَالُوا: ثَلَاثَةٌ دَنَانِيرَ، قَالَ: «صَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ»، قَالَ أَبُو قَتَادَةَ صَلِّ عَلَيْهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَعَلَيَّ دَيْنُهُ، فَصَلَّى عَلَيْهِ (١)، ولم ينقل قبول الطالب، ولأن الكفالة ضم والتزام المطالبة بما على الأصيل شرعاً لا تمليك، ألا يرى أنه يحتمل الجهالة والتعليق بالشرط، والتمليك لا يحتمل ذلك، ومعنى الضم والالتزام بإيجاب الكفيل فأشبهه النذر.

دليل آخر على أن الركن هو الإيجاب من الكفيل:

أن المريض إذا قال عند موته لورثته: اضمنوا عني ما علي من الدين لغرمائي وهم غيب فضمنوا ذلك فهو جائز ويلزمهم وأي فرق بين المريض والصحيح. ولأبي حنيفة ومحمد: أن الكفالة ليست بالتزام محض، بل فيها معنى التمليك، والتمليك لا يتم إلا بالإيجاب والقبول كالبيع.

والجواب عن مسألة المريض: فقد قال بعض مشايخ الحنفية: إن جواز الضمان بطريق الإيصاء بالقضاء عنه بعد موته لا بطريق الكفالة ويكون قوله اضمنوا عني إيصاء منه إليهم بالقضاء عنه، حتى لو مات ولم يترك شيئاً لا يلزم الورثة شيء فعلى هذا لا يلزم. وبعضهم: أجازوه على سبيل الكفالة، ووجهه أنه بمنزلة المعبر عن غرمائه، فأن المريض مرض الموت يتعلق الدين بماله ويصير بمنزلة الأجنبي عنه حتى لا ينفذ منه

(١) صحيح البخاري - بَابُ إِنْ أَحَالَ دَيْنَ الْمَيِّتِ عَلَى رَجُلٍ جَارٍ - رقم ٢٢٨٩ ج ٣ ص ٩٤ ، ٩٥ .

التصرف المبطل لحق الغريم، ولو قال أجنبي للورثة: اضمنوا لغرماء فلان عنه. فقالوا: ضمنا يكتفى به فكذا المريض.

فإذا عرفنا أن ركن الكفالة الإيجاب والقبول، فالإيجاب من الكفيل أن يقول: أنا كفيل، أو ضمين، أو زعيم، أو غريم، أو قبيل، أو حميل، أو لك علي، أو لك قبلي، أو لك عندي.

وأما لفظ الكفالة والضمان فصريحان، وكذلك الزعامة بمعنى الكفالة، والغرامة بمعنى الضمان لقول رسول الله ﷺ: «الزَّعِيمُ غَارِمٌ، وَالذَّيْنُ مَقْضِيٌّ» (١)، أي الكفيل ضامن.

وكذلك القبالة بمعنى الكفالة أيضاً، يقال: قبلت به أقبل قبالة وتقبلت به أي كفلت قال الله تعالى: ﴿أَوْ تَأْتِي بِاللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ قَبِيلًا﴾ (٢) أي كفيلاً يكفلوني بما يقول. والحميل بمعنى المحمول فعيل بمعنى المفعول كالقتيل بمعنى المقتول وأنه ينبئ عن تحمل الضمان.

وقوله علي كلمة إيجاب، عن أبي هريرة رضي الله عنه: عن النبي ﷺ أنه قال: "أَنَا أُولَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ، فَمَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ وَلَمْ يَتْرُكْ وَفَاءً فَعَلَيْنَا قَضَاؤَهُ، وَمَنْ تَرَكَ مَالًا فَلِوَرَثَتِهِ" (٣).

وكذا قوله إلي لقوله ﷺ: "مَنْ تَرَكَ مَالًا، فَلِأَهْلِهِ، وَمَنْ تَرَكَ دَيْنًا، فَإِلَيَّ وَعَلَيَّ" (٤). وقوله: قبلي ينبئ عن القبالة، وهي الكفالة، وقوله عندي وإن كانت مطلقة للوديعة لكنه بقرينة الدين يكون كفالة؛ لأن قوله عندي يحتمل اليد ويحتمل الذمة؛ لأنها كلمة قرب وحضرة وذلك يوجد فيهما جميعاً، فعند الإطلاق يحمل على اليد لأنه أدنى وعند قرينة الدين يحمل على الذمة أي في ذمتي لأن الدين لا يحتمله إلا الذمة.

(١) سنن ابن ماجه (٩) باب الكفالة رقم ٢٤٠٥ ج ٢ ص ٨٠٤. [ش - (الزعيم) أي الكفيل. (غارم) أي ضامن. (مقضى) أي يجب قضاؤه. قال الشيخ الألباني: صحيح.

(٢) سورة الإسراء: الآية ٩٢.

(٣) صحيح البخاري (٨٨) كتاب الفرائض. ٣. بَابُ قَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ: «مَنْ تَرَكَ مَالًا فَلِأَهْلِهِ» رقم ٦٧٣١ ح ٨ ص ١٥٠.

(٤) صحيح ابن حبان - مخرجا (٤٣٨ / ١١).

وأما القبول من الطالب فهو أن يقول: قبلت أو رضيت أو ما يدل على هذا المعنى.
وركن الكفالة في الأصل لا يخلو عن أربعة أقسام:
إما أن يكون مطلقاً، أو مقيداً بوصف، أو معلقاً بشرط، أو مضافاً إلى وقت.
فإن كان مطلقاً: فلا شك في جوازه إذا استجمع شرائط الجواز.
غير أنه إن كان الدين على الأصيل حالاً كانت الكفالة حالة، وإن كان الدين عليه
مؤجلاً كانت الكفالة مؤجلة؛ لأن الكفالة بمضمون على الأصيل فتتقيد بصفة
المضمون.

وأما المقيد: فلا يخلو إما إن كان مقيداً بوصف التأجيل، أو بوصف الحلول، فإن
كانت الكفالة مؤجلة، فإن كان التأجيل إلى وقت معلوم بأن كفل إلى شهر أو سنة جاز،
ثم إن كان الدين على الأصيل مؤجلاً إلى أجل مثله يتأجل إليه في حق الكفيل أيضاً.
وإن سمي الكفيل أجلاً أزيد من ذلك أو أنقص جاز؛ لأن المطالبة حق الطالب فله
أن يتبرع على كل واحد منهما بتأخير حقه، وإن كان الدين عليه حالاً جاز التأجيل إلى
الأجل المذكور، ويكون ذلك تأجيلاً في حقهما جميعاً في ظاهر الرواية.
وروى عن محمد: أنه يكون تأجيلاً في حق الكفيل خاصة.

وجه هذه الرواية: أن الطالب خص الكفيل بالتأجيل فيخص به، كما إذا كفل حالاً
أو مطلقاً ثم أخر عنه بعد الكفالة.

وجه ظاهر الرواية: أن التأجيل في نفس العقد يجعل الأجل صفة للدين، والدين
واحد، وهو على الأصيل فيصير مؤجلاً عليه ضرورة، بخلاف ما إذا كان بعد تمام
العقد؛ لأن التأجيل المتأخر عن العقد يؤخر المطالبة وقد خص به الكفيل فلا يتعدى
إلى الأصيل.

ولو كان الدين على الأصيل مؤجلاً إلى سنة فكفل به مؤجلاً إلى سنة أو مطلقاً، ثم
مات الأصيل قبل تمام السنة: يحل الدين في ماله وهو على الكفيل إلى أجله، وكذا لو
مات الكفيل دون الأصيل يحل الدين في مال الكفيل وهو على الأصيل إلى أجله؛ لأن
المبطل للأجل وجد في حق أحدهما دون الآخر.

وإن كان التأجيل إلى وقت مجهول:

فإن كان يشبه آجال الناس كالحصاد والدياس والنيروز ونحوه فكفل إلى هذه الأوقات جاز عند الحنفية.

وعند الشافعي: لا يجوز.

وجه قول الشافعي: أن هذا عقد إلى أجل مجهول فلا يصح كالبيع.

وللحنفية: أن هذا ليس بجهالة فاحشة فتحملها الكفالة، وهذا لأن الجهالة لا تمنع من جواز العقد لعينها بل لإفضائها إلى المنازعة بالتقديم والتأخير، وجهالة التقديم والتأخير لا تفضي إلى المنازعة في باب الكفالة؛ لأنه يسامح في هذا العقد ما لا يسامح في غيره لإمكان استيفاء الحق من جهة الأصيل بخلاف البيع، ولأن الكفالة جوازها بالعرف، والكفالة إلى هذه الآجال متعارفة.

ولو كانت الكفالة حالة فأخر إلى هذه الأوقات جاز أيضاً.

وإن كان لا يشبه آجال الناس: كمجيء المطر، وهبوب الريح فالأجل باطل، والكفالة صحيحة؛ لأن هذه جهالة فاحشة فلا تتحملها الكفالة، فلم يصح التأجيل فبطل وبقيت الكفالة صحيحة.

*** وكذا لو كان على رجل دين فأجله الطالب إلى هذه الأوقات جاز، وإن كان ثمن مبيع، ولا يوجب ذلك فساد البيع؛ لأن تأجيل الدين ابتداء بمنزلة التأخير في الكفالة وذا لا يؤثر في البيع فكذا هذا، هذا إذا كانت الكفالة مؤجلة.

*** فأما إذا كانت الكفالة حالة: فإن شرط الطالب الحلول على الكفيل جاز سواء كان الدين على الأصيل حالاً أو مؤجلاً؛ لأن المطالبة حق المكفول له فيملك التصرف فيه بالتعجيل والتأجيل.

*** ولو كفل حالاً ثم أجله الطالب بعد ذلك يتأخر في حق الكفيل إذا قبل التأخير دون الأصل، بخلاف ما إذا كان التأجيل في العقد.

*** ولو كان الدين على الأصل حالاً فأخره الطالب إلى مدة وقبله المطلوب جاز التأخير ويكون تأخيراً في حق الكفيل، هذا إذا كانت مقيدة بوصف.

فأما إذا كانت معلقة بشرط فإن كان المذكور شرطاً، أو سبباً لظهور الحق أو لوجوبه أو وسيلة إلى الأداء في الجملة جاز، بأن قال: إن استحق المبيع فأنا كفيل؛

لأن استحقاق المبيع سبب لظهور الحق، وكذا إذا قال إذا قدم زيد فأنا كفيل؛ لأن قدومه وسيلة إلى الأداء في الجملة لجواز أن يكون مكفولاً عنه أو يكون مضاربة.

وإن لم يكن الشرط المعلق عليه سبباً لظهور الحق، ولا لوجوبه، ولا وسيلة إلى الأداء في الجملة: لا يجوز، بأن قال: إذا جاء المطر أو هبت الريح أو إن دخل زيد الدار فأنا كفيل؛ لأن الكفالة فيها معنى التملك، والأصل أن لا يجوز تعليقها بالشرط إلا شرطاً ألحق به تعلق بالظهور أو التوصل إليه في الجملة فيكون ملائماً للعقد فيجوز، ولأن الكفالة جوازها بالعرف، والعرف في مثل هذا الشرط دون غيره.

**** ولو قال: إن قتلك فلان، أو إن شجك فلان، أو إن غصبك فلان، أو إن بايعت فلاناً فأنا ضامن لذلك جاز؛ لأن هذه الأفعال سبب لوجوب الضمان.

**** ولو قال: إن غصب فلان ضيعتك فأنا ضامن لم يجز عند أبي حنيفة وأبي يوسف، وجاز عند محمد، بناء على أن غصب العقار لا يتحقق عند أبي حنيفة وأبي يوسف، وعند محمد: يتحقق.

**** ولو قال من قتلك من الناس أو من غصبك من الناس أو من شجك من الناس أو من بايعك من الناس لم يجز؛ لأن المضمون عنه مجهول وجهالة المضمون عنه تمنع صحة الكفالة.

**** ولو قال ضمنت لك ما على فلان إن نوى جاز؛ لأن هذا شرط ملائم للعقد؛ لأنه مؤكد لمعنى التوصل إلى ما هو المقصود، وكذا لو قال: إن خرج من المصر ولم يعطك فأنا ضامن.

**** ولو شرط في الكفالة بالنفس تسليم المكفول به في وقت بعينه جاز؛ لأن هذا تأجيل الكفالة بالنفس إلى وقت معلوم فيصح كالكفالة بالمال، وكذا سائر أنواع الكفالات في التعليق بالشرط والتأجيل والإضافة إلى الوقت سواء؛ لأن الكل في معنى الكفالة على السواء.

قال القدوري: "فإن شرط في الكفالة تسليم المكفول به في وقت بعينه: لزمه إحضاره إذا طالبه به في ذلك الوقت، فإن أحضره وإلا حبسه الحاكم حتى يحضره، وإذا أحضره وسلمه في مكان يقدر المكفول له على محاكمته برئ الكفيل من الكفالة، وإذا تكفل به

على أن يسلمه في مجلس القاضي فسلمه في السوق برئ وإن سلمه في برية لم يبرأ" (١).

**** ولو قال كفلت لك مالك على فلان حالاً على أنك متى طلبته فلي أجل شهر: جاز، وإذا طلبته منه فله أجل شهر ثم إذا مضى الشهر فله أن يأخذ متى شاء، ولو شرط ذلك بعد تمام الكفالة بالمال حالاً: لم يجز وله أن يطالبه متى شاء.

والفرق أن الموجود ههنا كفالتان:

إحدهما: حالة مطلقة. والثانية: مؤجلة إلى شهر، معلقة بشرط الطلب، فإذا وجد الشرط ثبت التأجيل إلى شهر، فإذا مضى الشهر انتهى حكم التأجيل فيأخذه بالكفالة الحالة، بخلاف ما إذا كان التأجيل بالشرط بعد تمام العقد؛ لأن ذلك تعليق التأجيل بالشرط لا تعليق العقد المؤجل بالشرط، والتأجيل نفسه لا يحتمل التعليق بالشرط فبطل، وإذا كفل إلى قدوم زيد جاز، ولو كفل مطلقاً ثم آخر إلى قدوم زيد لم يجز كذا هذا. ولو كفل بنفس المطلوب على أنه إن لم يواف به غداً فعليه ما عليه، وهو الألف فمضى الوقت ولم يواف به، فالمال لازم للكفيل؛ لأن هنا كفالتان بالنفس، وبالمال إلا أنه كفل بالنفس مطلقاً، وعلق الكفالة بالمال بشرط عدم الموافقة بالنفس فكل ذلك جائز. أما الكفالة بالنفس فلا شك فيها وكذا الكفالة بالمال؛ لأن هذا شرط ملائم للعقد، محقق لما شرع له وهو الوصول إلى الحق من جهة الكفيل عند تعذر الوصول إليه من قبل الأصل، فإذا لم يوجد الشرط لزمه المال وإذا أداه لا يبرأ عن الكفالة بالنفس لجواز أن يدعي عليه ما لا آخر فيلزمه تسليم نفسه.

قال القدوري: "الكفالة ضريان: كفالة بالنفس وكفالة بالمال، فالكفالة بالنفس جائزة والمضمون بها إحضار المكفول به، وتتعدد إذا قال: تكفلت بنفس فلان أو برقبته أو بروحه أو بجسده أو برأسه أو بنصفه أو بثلثه، وكذلك إن قال: ضمنته أو هو علي أو إلي أو أنا زعيم به أو قبيل" (٢).

(١) مختصر القدوري ص ١١٨.

(٢) مختصر القدوري ص ١١٨.

وكذا إذا قال فعلية ما عليه وعليه ألف ولم يسم؛ لأن جهالة قدر المكفول به لا تمنع صحة الكفالة ويلزمه جميع الألف؛ لأنه أضاف الكفالة إلى ما عليه، والألف عليه.

ولو كفل بنفس رجل وقال: إن لم أوافك به غداً فعلي ألف درهم ولم يقل: الألف التي عليه أو الألف التي ادعيت، والمطلوب ينكر: فالمال لازم للكفيل عند أبي حنيفة وأبي يوسف. رحمهما الله.، وعند محمد. رحمه الله. لا يلزمه.

ولو شرط في الكفالة بالنفس أن يسلمه إليه في مجلس القاضي جاز؛ لأن هذا شرط مفيد ويكون التسليم في المصر، أو في مكان يقدر على إحضاره مجلس القاضي تسليمًا إلى القاضي.

قال القدوري: "وإذا تكفل به على أن يسلمه في مجلس القاضي فسلمه في السوق برئ وإن سلمه في برية لم يبرأ" (١).

ولو شرط أن يسلمه إليه في مصر معين يصح التقييد بالمصر بالإجماع إلا أنه لا يصح التعيين عند أبي حنيفة.

وعند أبي يوسف ومحمد: يصح.

ولو شرط أن يدفعه إليه عند الأمير لا يتقيد به حتى لو دفعه إليه عند القاضي أو عزل الأمير وولي غيره فدفعه إليه عند الثاني جاز؛ لأن التقييد غير مفيد.

فأما إذا كانت مضافة إلى وقت بأن ضمن ما أدان له على فلان، أو ما قضى له عليه، أو ما دأين فلاناً، أو ما أقرضه، أو ما استهلك من ماله، أو ما غصبه، أو ثمن ما بايعه صحت هذه الكفالة؛ لأنها أضيفت إلى سبب الضمان، وإن لم يكن الضمان ثابتاً في الحال والكفالة إن كان فيها معنى التمليك فليست بتمليك محض فجاز أن يحتمل الإضافة.

ولو قال كلما بايعت فلاناً فثمنه علي أو ما بايعت أو الذي بايعت يؤخذ الكفيل بجميع ما بايعه.

(١) مختصر القدوري ص ١١٨.

شرائط الكفالة أنواع بعضها يرجع إلى الكفيل، وبعضها يرجع إلى الأصل، وبعضها يرجع إلى المكفول له، وبعضها يرجع إلى المكفول به، ثم منها ما هو شرط الانعقاد ومنها ما هو شرط النفاذ:

فأما الذي يرجع إلى الكفيل فأنواع منها:

١ . ٢ . العقل ، والبلوغ وإنهما من شرائط الانعقاد، فلا تتعقد كفالة الصبي والمجنون؛ لأنها عقد تبرع فلا تتعقد ممن ليس من أهل التبرع، إلا أن الأب أو الوصي لو استدان ديناً في نفقة اليتيم وأمر اليتيم أن يضمن المال عنه جاز .

٣ . الحرية: وهي شرط نفاذ هذا التصرف فلا تجوز كفالة العبد محجوراً كان أو مأذوناً له في التجارة؛ لأنها تبرع، والعبد لا يملكه بدون إذن مولاه، ولكنها تتعقد حتى يؤاخذ به بعد العتاق؛ لأن امتناع النفاذ ما كان لانعدام الأهلية، بل لحق المولى وقد زال بخلاف الصبي؛ لأنها غير منعقدة منه لعدم الأهلية فلا تحتل النفاذ بالبلوغ.

وأما صحة بدن الكفيل فليس بشرط لصحة الكفالة، فتصح كفالة المريض لكن من التلث لأنها تبرع.

وأما الذي يرجع إلى الأصل (المكفول عنه) فنوعان:

أحدهما: أن يكون قادراً على تسليم المكفول به إما بنفسه وإما بنائبه عند أبي حنيفة فلا تصح الكفالة بالدين عن ميت مفلس عنده، وعند أبي يوسف ومحمد: تصح.

وجه قولهما: أن الموت لا ينافي بقاء الدين؛ لأنه مال حكمي فلا يفتقر بقاؤه إلى القدرة، ولهذا بقي إذا مات ملياً حتى تصح الكفالة به وكذا بقيت الكفالة بعد موته مفلساً، وإذا مات عن كفيل تصح الكفالة عنه بالدين فكذا يصح الإبراء عنه والتبرع.

وجه قول أبي حنيفة: أن الدين عبارة عن الفعل، والميت عاجز عن الفعل، فكانت هذه كفالة بدين ساقط فلا تصح، وإذا مات ملياً فهو قادر بنائبه، وكذا إذا مات عن كفيل؛ لأنه قائم مقامه في قضاء دينه.

والثاني: أن يكون معلوماً بأن كفل ما على فلان، فأما إذا قال على أحد من الناس أو بعين أو بنفس أو بفعل فلا يجوز؛ لأن المضمون عليه مجهول، ولأن الكفالة جوازها بالعرف، والكفالة على هذا الوجه غير معروفة.

فأما حرية الأصيل وعقله وبلوغه فليست بشرط لجواز الكفالة؛ لأن الكفالة بمضمون ما على الأصل مقدور الاستيفاء من الكفيل وقد وجد، أما العبد فلأن الدين واجب عليه ويطالب به في الجملة، فأشبه الكفالة بالدين المؤجل، وأما الصبي والمجنون، فلأن الدين في ذمتهم والولي مطالب به في الحال ويطالبان أيضاً في الجملة، وهو ما بعد البلوغ والإفاقة فتجوز الكفالة عن العبد وإن كان محجوراً وعن الصبي والمجنون، إلا أن الكفيل لا يملك الرجوع عليهم بما أدى وإن كانت الكفالة بإذنهم.

وكذا لا يشترط حضرته فتجوز الكفالة عن غائب أو محبوس؛ لأن الحاجة إلى الكفالة في الغالب في مثل هذه الأحوال فكانت الكفالة فيهما أجوز ما يكون.

وأما الذي يرجع إلى المكفول له فأنواع منها:

١. أن يكون معلوماً حتى أنه إذا كفل لأحد من الناس لا تجوز؛ لأن المكفول له إذا كان مجهولاً لا يحصل ما شرع له الكفالة وهو التوثق.

٢. أن يكون في مجلس العقد، وأنه شرط الانعقاد عند أبي حنيفة ومحمد إذا لم يقبل عنه حاضر في المجلس حتى أن من كفل لغائب عن المجلس فبلغه الخبر فأجاز لا تجوز عندهما إذا لم يقبل عنه حاضر.

وعن أبي يوسف روايتان.

ولمحمد في قوله الآخر: أنها جائزة يدل على أن المجلس عنده ليس شرطاً أصلاً، لا شرط النفاذ، ولا شرط الانعقاد؛ لأن محمداً ربما يطلق الجواز على النافذ، فأما الموقوف فنسميه باطلاً إلا أن يجيز وهذا الإطلاق صحيح؛ لأن الجائز هو النافذ في اللغة يقال جاز السهم إذا نفذ.

وجه قول أبي يوسف الآخر: أن معنى هذا العقد لغة وشرعاً هو الضم والالتزام يتم بإيجاب الكفيل فكان إيجابه كل العقد.

وجه قولهما: أن فيه معنى التملك، والتمليك لا يقوم إلا بالإيجاب والقبول، فكان الإيجاب وحده شطر العقد فلا يقف على غائب عن المجلس كالبيع.

٣. أن يكون عاقلاً فلا يصح قبول المجنون والصبي الذي لا يعقل؛ لأنهما ليسا من أهل القبول ولا يجوز قبول وليهما عنهما؛ لأن القبول يعتبر ممن وقع له الإيجاب،

ومن وقع له الإيجاب ليس من أهل القبول، ومن قبل لم يقع الإيجاب له فلا يعتبر قبوله.

وأما حرية المكفول له فليست بشرط لأن العبد من أهل القبول.

وأما الذي يرجع إلى المكفول به فنوعان:

أحدهما: أن يكون المكفول به مضموناً على الأصيل سواء كان ديناً أو عيناً أو نفساً أو فعلاً ليس بدين ولا عين ولا نفس، إلا أنه يشترط في الكفالة بالعين أن تكون مضمونة بنفسها.

وجملة الكلام فيه أن المكفول به أربعة أنواع: عين، ودين، ونفس، وفعل ليس بدين ولا عين ولا نفس.

أما العين فنوعان: عين: هي أمانة، وعين: هي مضمونة.

فأما العين التي هي أمانة: فلا تصح الكفالة بها سواء كانت أمانة غير واجبة التسليم كالودائع، ومال الشركات، والمضاربات، أو كانت أمانة واجبة التسليم كالعارية والمستأجر في يد الأجير؛ لأنه أضاف الكفالة إلى عينها، وعينها ليست بمضمونة. ولو كفل بتسليم المستعار والمستأجر عن المستعير والمستأجر جاز، لأنهما مضمونا التسليم عليهما فالكفالة أضيفت إلى مضمون على الأصيل وهو فعل التسليم فصحت.

وأما العين المضمونة فنوعان:

مضمون بنفسه: كالمغصوب، والمقبوض بالبيع الفاسد، والمقبوض على سوم الشراء.

ومضمون بغيره: كالمبيع قبل القبض، والرهن.

فتصح الكفالة بالنوع الأول؛ لأنه كفالة بمضمون بنفسه؛ لأنه يجب رد عينه حال قيامه، ورد مثله أو قيمته حال هلاكه فيصير مضموناً على الكفيل على هذا الوجه. ولا تصح بالنوع الثاني؛ لأن المبيع قبل القبض مضمون بالثمن لا بنفسه؛ لأنه إذا هلك في يد البائع لا يجب عليه شيء ولكن يسقط الثمن عن المشتري.

وكذا الرهن غير مضمون بنفسه بل بالدين؛ لأنه إذا هلك لا يجب على المرتهن شيء، ولكن يسقط الدين عن الراهن بقدره.

وأما الفعل: فهو فعل التسليم في الجملة فتجوز الكفالة بتسليم المبيع والرهن؛ لأن المبيع مضمون التسليم على البائع، والرهن مضمون التسليم على المرتهن في الجملة بعد قضاء الدين، فكان المكفول به مضموناً على الأصيل وهو فعل التسليم فصحت الكفالة به، لكنه إذا هلك لا شيء على الكفيل؛ لأنه لم يبق مضموناً على الأصيل فلا يبقى على الكفيل.

والنوع الثاني: أن يكون المكفول به مقدور الاستيفاء من الكفيل ليكون العقد مفيداً. فلا تجوز الكفالة بالحدود والقصاص لتعذر الاستيفاء من الكفيل فلا تفيد الكفالة فائدتها، وتجوز الكفالة بنفس من عليه القصاص في النفس وما دونها وبحد القذف والسرقة إذا بذلها المطلوب فأعطاه بها كفيلاً بلا خلاف؛ لأنها كفالة بمضمون على الأصيل مقدور الاستيفاء من الكفيل فتصح كالكفالة بتسليم نفس من عليه الدين. وإنما الخلاف أنه إذا امتنع من إعطاء الكفيل عند الطلب هل يجبره القاضي عليه؟ قال أبو حنيفة: لا يجبره. وقال أبو يوسف ومحمد: يجبره.

وجه قولهما: أن نفس من عليه القصاص والحد مضمون التسليم عليه عند الطلب كنفس من عليه الدين، ثم تصح الكفالة بنفس من عليه الدين ويجبر عليها عند الطلب فكذا هذا.

ولأبي حنيفة: أن الكفالة شرعت وثيقة، والحدود مبناها على الدرع فلا يناسبها التوثيق بالجبر على الكفالة.

وأما الدين فتصح الكفالة به بلا خلاف؛ لأنه مضمون على الأصيل مقدور الاستيفاء من الكفيل.

ولو مات الكفيل عاجزاً مفلساً لم يبطل عنه الدين فكان الحق على الكفيل ألزم منه على الأصيل، وهذا خلاف ما توجبه الأصول.

ولو كفل عن رجل بما لفلان عليه أو بما يدركه في هذا البيع: جاز؛ لأن جهالة قدر المكفول به لا تمنع صحة الكفالة قال الله تعالى جل شأنه ﴿قَالُوا نَفَقْدُ صَوَاعَ الْمَلِكِ

وَلَمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ ﴿١﴾ أجاز الله تعالى عز شأنه الكفالة بحمل البعير، مع أن الحمل يحتمل الزيادة والنقصان.

ما حكم الكفالة بالعهد:

لو ضمن رجل بالعهد فضمانه باطل عند أبي حنيفة.

وعند أبي يوسف ومحمد: صحيح.

وجه قول أبي يوسف ومحمد: أن ضمان العهدة في متعارف الناس ضمان الدرك (٢)، وهو ضمان الثمن عند استحقاق المبيع وذلك جائز بلا خلاف بين الحنفية. ولأبي حنيفة: أن العهدة تحتل الدرك وتحتل الصحيفة وهو الصك، وأحدهما وهو الصك غير مضمون على الأصيل فدارت الكفالة بالعهد بين أن تكون بمضمون وغير مضمون فلا تصح مع الشك، فلم يكن عدم الصحة عنده لجهالة المكفول به بل لوقوع الشك في وجود شرط الجواز وهو كونه مضموناً على الأصيل.

رابعاً: حكم الكفالة:

للكفالة حكمان:

أحدهما: ثبوت ولاية مطالبة الكفيل بما على الأصيل، ويترد هذا الحكم في سائر أنواع الكفالات؛ لأن الكل في احتمال هذا الحكم على السواء، وإنما يختلف محل الحكم من العين والدين والفعل.

فيطالب الكفيل بالدين، بدين واجب على الأصيل لا عليه، فالدين على واحد والمطالب به اثنان، غير أن الكفيل إن كان واحداً يطالب بكل الدين، وإن كان به كفيلا والدين ألف، يطالب كل واحد منهما بخمسمائة إذا لم يكفل كل واحد منهما عن صاحبه؛ لأنهما استويا في الكفالة والمكفول به يحتمل الانقسام، فينقسم عليهما في حق المطالبة كما في الشراء.

(١) سورة يوسف الآية ٧٢..

(٢) ضمان الدرك هو ضمان الثمن عند استحقاق المبيع.

ويطالب الكفيل بالنفس بإحضار المكفول بنفسه إن لم يكن غائباً، وإن كان غائباً يؤخذ الكفيل إلى مدة يمكنه إحضاره فيها، فإن لم يحضر في المدة ولم يظهر عجزه للقاضي حبسه إلى أن يظهر عجزه له، فإذا علم القاضي ذلك بشهادة الشهود أو غيرها أطلقه وأنظره إلى حال القدرة على إحضاره؛ لأنه بمنزلة المفلس، لكن لا يحول بين الطالب والكفيل بل يلزمه من الطالب، ولا يحول الطالب أيضاً بينه وبين أشغاله ولا يمنعه من الكسب وغيره.

ويطالب الكفيل بالعين بتسليم عينها إن كانت قائمة ومثلها أو قيمتها إن كانت هالكة، ويطالب الكفيل بتسليم العين وبالفعل بهما.

والحكم الثاني: ثبوت ولاية مطالبة الكفيل الأصيل إذا كانت الكفالة بأمره في الأنواع كلها، ثم إذا كانت الكفالة بالنفس فطالب الكفيل بتسليم نفسه إلى الطالب إذا طالبه، وإن كانت بالعين المضمونة يطالب بتسليم عينها إذا كانت قائمة وتسليم مثلها أو قيمتها إذا كانت هالكة إذا طوّل به، وإن كانت بفعل التسليم والحمل يطالب بهما، وإن كانت بدين يطالبه بالخلاص إذا طوّل فكما طوّل الكفيل طالب هو المكفول عنه بالخلاص.

وإن حبس فله أن يحبس المكفول عنه، لأنه هو الذي أوقعه في هذه العهدة، فكان عليه تخليصه منها.

وإن كانت الكفالة بغير أمره فليس للكفيل حق ملازمة الأصيل إذا لزم، ولا حق الحبس إذا حبس، وليس له أن يطالب بالمال قبل أن يؤدي هو، وإن كانت الكفالة بأمره؛ لأن ولاية المطالبة إنما تثبت بحكم القرض والتمليك، وكل ذلك يقف على الأداء ولم يوجد.

بخلاف الوكيل بالشراء أن له ولاية مطالبة الموكل بالثمن بعد الشراء قبل أن يؤدي هو من مال نفسه؛ لأن هناك الثمن يقابل المبيع، والملك في المبيع كما وقع وقع للموكل فكان الثمن عليه فكان له أن يطالب به، وهنا المطالبة بسبب القرض أو التملك ولم يوجد هنا، وإذا أدى كان له أن يرجع عليه إذا كانت الكفالة بأمره؛ لأن الكفالة بالأمر في حق المطلوب استقراض، وهو طلب القرض من الكفيل.

والكفيل بأداء المال مقرض من المطلوب ونائب عنه في الأداء إلى الطالب، وفي حق الطالب تمليك ما في ذمة المطلوب من الكفيل بما أخذ منه من المال والمقرض يرجع على المستقرض بما أقرضه والمشتري يملك الشراء بالبيع لا غير هذا..
خامساً: ما يخرج به الكفيل عن الكفالة:

الكفيل بالمال يخرج عن الكفالة بأحد أمرين:

أحدهما: أداء المال إلى الطالب أو ما هو في معنى الأداء سواء كان الأداء من الكفيل أو من الأصيل؛ لأن حق المطالبة للتوصل إلى الأداء فإذا وجد فقد حصل المقصود فينتهي حكم العقد.

***وكذا إذا وهب الطالب المال من الكفيل أو من الأصيل لأن الهبة بمنزلة الأداء.

وكذا إذا تصدق به على الكفيل أو على الأصيل لأن الصدقة تمليك كالهبة فكان هو وأداء المال سواء كالهبة.

والثاني: الإبراء وما هو في معناه، فإذا أبرأ الطالب الكفيل أو الأصيل خرج عن الكفالة، غير أنه إذا أبرأ الكفيل لا يبرأ الأصيل، وإذا أبرأ الأصيل يبرأ الكفيل؛ لأن الدين على الأصيل لا على الكفيل، إنما عليه حق المطالبة فكان إبراء الأصيل إسقاط الدين عن ذمته، فإذا سقط الدين عن ذمته يسقط حق المطالبة ضرورة؛ لأن المطالبة بالدين ولا دين محال.

فأما إبراء الكفيل بإبرائه عن المطالبة لا عن الدين؛ إذ لا دين عليه، وليس من ضرورة إسقاط حق المطالبة عن الكفيل سقوط أصل الدين عن الأصيل، لكن يخرج الكفيل عن الكفالة؛ لأن حكم الكفالة حق المطالبة عن الكفيل، فإذا سقط تنتهي.

ولو أحال الكفيل الطالب بمال الكفالة على رجل وقبله الطالب، فالمحتال عليه يخرج عن الكفالة عند أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد؛ لأن الحوالة مبرئة عن الدين والمطالبة جميعاً عند عامة مشايخ الحنفية، وعند بعضهم مبرئة عن المطالبة. وإبراء الكفيل والأصيل مخرج عن الكفالة.

وعند زفر: لا يخرج الكفيل عن الكفالة بالحوالة؛ لأن الحوالة عنده ليست بمبرئة أصلاً.

وكذلك الكفيل يخرج عن الكفالة بالصلح كما يخرج بالحوالة بأن يصلح الكفيل الطالب على بعض المدعى؛ لأن الصلح على جنس المدعى إسقاط بعض الحق، فكان فيه معنى الإبراء، وعلى خلاف الجنس معاوضة، فكان في معنى الإبراء، وكل ذلك يخرج عن الكفالة، غير أن في حالين يبرأ الكفيل والأصيل جميعاً وفي حال يبرأ الكفيل دون الأصيل.

أما الحالتان اللتان برئ فيهما الكفيل والأصيل جميعاً:

إحداهما: أن يقول الكفيل للطالب صالحتك من الألف على خمسمائة على أني والمكفول عنه بريئان من الخمسمائة الباقية، ويكون الطالب في الخمسمائة التي وقع عليها الصلح بالخيار إن شاء أخذها من الكفيل، ثم الكفيل يرفع بها على الأصيل وإن شاء أخذها من الأصيل.

والثانية: أن يقول صالحتك على خمسمائة مطلقاً عن شرط البراءة أصلاً؛ لأن الإبراء المضاف إلى المال المجرد عن شرط البراءة المضافة إلى الكفيل إبراء عن الدين، والدين واحد فإذا سقط عن الأصيل سقطت المطالبة عن الكفيل.

وأما الحوالة التي يبرأ الكفيل فيها دون الأصيل فهي: أن يقول الكفيل للطالب صالحتك على أني بريء من الخمسمائة، والطالب بالخيار إن شاء أخذ جميع دينه من الأصيل، وإن شاء أخذ من الكفيل خمسمائة ومن الأصيل خمسمائة ثم يرجع الكفيل على الأصيل بما أدى إن كان الصلح بأمره.

وأما الكفيل بالنفس فيخرج عن الكفالة بثلاثة أشياء

إحداها: تسليم النفس إلى الطالب، وهو التخلية بينه وبين المكفول بنفسه في موضع يقدر على إحضاره مجلس القاضي؛ لأن التسليم في مثل هذا الموضع محصل للمقصود من العقد، وهو إمكان استيفاء الحق بالمرافعة إلى القاضي، فإذا حصل المقصود ينتهي حكمه فيخرج عن الكفالة.

ولو سلمه في صحراء أو برية لا يخرج؛ لأنه لم يحصل المقصود ولو سلم في السوق أو في المصر يخرج، سواء أطلق الكفالة أو قيدها بالتسليم في مجلس القاضي، أما إذا أطلق فظاهر؛ لأنه يتقيد بمكان يقدر على إحضاره مجلس القاضي بدلالة الغرض وكذا إذا قيد؛ لأن التسليم في هذه الأمكنة تسليم في مجلس القاضي بواسطة. ولو شرط أن يسلمه في مصر معين فسلمه في مصر آخر يخرج عن الكفالة عند أبي حنيفة، وعند أبي يوسف ومحمد: لا يخرج عنها إلا أن يسلمه في المصر المشروط.

وجه قول أبي يوسف ومحمد: أن التقيد بالمصر مفيد لجواز أن يكون للطالب بينة يقدر على إقامتها فيه دون غيره، فكان التعيين مفيداً فيتقيد به. وجه قول أبي حنيفة: أن المقصود من تسليم النفس هو الوصول إلى الحق بالمرافعة إلى القاضي، وهذا الغرض ممكن الاستيفاء من كل قاض فلا يصح التعيين ولو سلمه في السواد ولا قاضي فيه لا يخرج عن الكفالة؛ لأن التسليم في مثل هذا المكان لا يصلح وسيلة إلى المقصود فكان وجوده وعدمه بمنزلة واحدة. ولو شرط أن يدفعه إليه عند الأمير فدفعه إليه عند القاضي يخرج عن الكفالة. وكذا إذا عزل الأمير وولي غيره فدفعه إليه عند الثاني؛ لأن التسليم عند كل من ولي ذلك محصل للمقصود فلم يكن التقيد مفيداً فلا يتقيد. ولو كفل جماعة بنفس رجل كفالة واحدة فأحضره أحدهم برئوا جميعاً، وإن كانت الكفالة متفرقة لم يبرأ الباقيون.

وجه الفرق: أن الداخل تحت الكفالة الواحدة فعل واحد وهو الإحضار، وقد حصل ذلك بواحد، والداخل تحت الكفالات المتفرقة أفعال متفرقة فلا يحصل بإحضار واحد الإبراء به فيبرأ هو دون الباقيين، وليس هذا كما إذا كفل جماعة بمال واحد كفالة واحدة أو متفرقة فأدى أحدهم برئ الباقيون؛ لأن الدين يسقط عن الأصيل بأداء المال فلا يبقى على الكفيل.

والثاني: الإبراء إذا أبرأ الطالب الكفيل من الكفالة بالنفس خرج عن الكفالة؛ لأن حكم الكفالة بالنفس حق المطالبة بتسليم النفس، وقد أسقط المطالبة عنه بالإبراء فينتهي الحق ضرورة، ولا يكون هذا الإبراء للأصيل؛ لأنه أسقط المطالبة عنه دون الأصيل. ولو أبرأ الأصيل برئاً جميعاً؛ لأن الكفالة بمضمون على الأصيل، وقد بطل الضمان بالإبراء فينتهي حكم الكفالة.

والثالث: موت المكفول بنفسه؛ لأن الكفالة بمضمون على الأصيل وقد سقط الضمان عنه فيسقط عن الكفيل.

قال القدوري: "وإن مات المكفول به برئ الكفيل بالنفس من الكفالة" (١). وأما الكفيل بالأعيان المضمونة بنفسها، والأفعال المضمونة تخرج عن الكفالة بأحد أمرين:

أحدهما: تسليم العين المضمونة بنفسها إن كانت قائمة وتسليم مثلها أو قيمتها إن كانت هالكة، ويحصل الفعل المضمون وهو التسليم والحمل.

والثاني: الإبراء، فلا يخرج بموت الغاصب والبائع والمكاري؛ لأن نفس هؤلاء غير مكفول بها حتى يسقط بموتهم.

سادساً: رجوع الكفيل.

الكلام في الرجوع في موضعين:

أحدهما: في شرائط ولاية الرجوع. والثاني: في بيان ما يرجع به.

فأما الشروط فأنواع، منها:

١. أن تكون الكفالة بأمر المكفول عنه؛ لأن معنى الاستقراض لا يتحقق بدونه، ولو كفل بغير أمره لا يرجع عليه عند عامة العلماء.

قال القدوري: "وتجوز الكفالة بأمر المكفول عنه وبغير أمره، فإن كفل بأمره رجع بما يؤدي عليه، وإن كفل بغير أمره لم يرجع بما يؤديه، وليس للكفيل أن يطالب

(١) مختصر القدوري ص ١١٨.

المكفول عنه بالمال قبل أن يؤدي عنه، فإن لوزم بالمال كان له أن يلزم المكفول عنه حتى يخلصه" (١).

٢ . أن يكون بإذن صحيح، وهو إذن من يجوز إقراره على نفسه بالدين حتى أنه لو كفل عن الصبي المحجور بإذنه فأدى لا يرجع؛ لأن إذنه بالكفالة لم يصح؛ لأنه من المكفول عنه استقراض واستقراض الصبي لا يتعلق به الضمان.

٣ . إضافة الضمان إليه، بأن يقول: اضمن عني، ولو قال: اضمن كذا، ولم يضيف إلى نفسه لا يرجع؛ لأنه إذا لم يضيف إليه فالكفالة لم تقع إقراضاً إياه، فلا يرجع عليه.

٤ . أداء المال إلى الطالب، أو ما هو في معنى الأداء إليه فلا يملك الرجوع قبل الأداء؛ لأن معنى الإقراض والتمليك لا يتحقق إلا بأداء المال فلا يملك الرجوع قبله.

٥ . أن لا يكون للأصيل على الكفيل دين مثله، فأما إذا كان فلا يرجع؛ لأنه إذا أدى الدين التقى الدينان قصاصاً، إذ لو ثبت للكفيل حق الرجوع على الأصيل لثبت للأصيل أن يرجع عليه أيضاً فلا يفيد فيسقطان جميعاً.

** ولو وهب صاحب الدين المال للكفيل يرجع على الأصيل؛ لأن الهبة في معنى الأداء؛ لأنه لما وهب منه فقد ملك ما في ذمة الأصيل فيرجع عليه كما إذا ملكه بالأداء، وإذا وهب الدين من الأصيل برئ الكفيل؛ لأن هذا وأداء المال سواء؛ لأنه لما وهبه منه فقد ملك ما في ذمته كما إذا أدى، ومتى برئ الأصيل برئ الكفيل؛ لأن براءة الأصيل توجب براءة الكفيل.

ولو مات الطالب فورثه الكفيل يرجع على الأصيل، ولو ورثه الأصيل يبرأ الكفيل؛ لأن الإرث من أسباب الملك فيملكه الأصيل، ومتى ملكه برئ فيبرأ الكفيل كما إذا أدى، ولو أبرأ الطالب الكفيل لا يرجع على الأصيل، لأن الإبراء إسقاط وهو في حق الكفيل إسقاط المطالبة لا غير، ولهذا لا توجب براءة الكفيل براءة الأصيل فلم يكن فيه معنى تمليك الدين أصلاً فلا يرجع.

(١) مختصر القدوري ص ١١٩.

ولو أبرأ الكفيل المكفول عنه مما ضمنه بأمره قبل أدائه أو وهبه منه جاز، حتى لو أداه الكفيل بعد ذلك لا يرجع عليه؛ لأن سبب وجوب الحق له على الأصيل وهو العقد بإذنه موجود، والإبراء عن الحق بعد وجود سبب الوجوب قبل الوجوب جائز كالإبراء عن الأجرة قبل مضي مدة الإجارة.

ولو لم يؤد الكفيل ما كفل به حتى عجل الأصيل لما كفل عنه، ودفع إلى الكفيل ينظر، إن دفعه إليه على وجه القضاء يجوز؛ لأن ولاية الرجوع على الأصيل إن لم تكن ثابتة له في الحال لكنها ثبتت بعد الأداء، فأشبه الدين المؤجل إذا عجله المطلوب قبل حل الأجل أنه يقبل منه ويكون قضاء، كذا هذا وبرئ الأصيل من دين الكفيل ولكن لا يبرأ عن دين المكفول له، وله أن يطالب أيهما شاء، فإن أخذ من الأصيل كان له أن يرجع على الكفيل بما أدى؛ لأنه تبين أنه لم يكن قضاء.

وإن كان الكفيل تصرف في ذلك المعجل وريح هل يطيب له الريح ينظر، إن كان الدين دراهم أو دنانير يطيب بالإجماع؛ لأنهما لا يتعينان في عقود المعاوضات فحصل التملك بإذن صاحبها فيطيب له الريح.

وإن كان الدين مكيلاً أو موزوناً مما يتعين في العقد يطيب له الريح أيضاً عند أبي يوسف ومحمد.

وعن أبي حنيفة . رحمه الله . ثلاث روايات:

ذكر في كتاب البيوع أنه يطيب له الريح ولم يذكر الخلاف، وفي رواية قال: يتصدق، وفي رواية قال: أحب إلي أن يرد الريح على المكفول عنه، هذا إذا دفعه إليه على وجه القضاء.

فأما إذا دفعه على وجه الرسالة ليؤدي الدين مما دفعه إليه لا على وجه القضاء فتصرف فيه الوكيل وريح، لا يطيب له الريح سواء كان الدين دراهم أو دنانير أو غيرهما من المكيلات والموزونات عند أبي حنيفة ومحمد.

وعند أبي يوسف: يطيب.

ولو قال الطالب للكفيل: برئت إلي من المال يرجع على الأصيل بالإجماع، لأن هذا إقرار بالقبض والاستيفاء.

وأما بيان ما يرجع به الكفيل:

فالكفيل يرجع بما كفل لا بما أداه حتى لو كفل عن رجل بدراهم صحاح جياد فأعطاه مكسرة أو زيوفاً، وتجاوز به المطالبة يرجع عليه بالصاح الجياد؛ لأنه بالأداء ملك ما في ذمة الأصل فيرجع بالمؤدى وهو الصاح الجياد، وليس هذا كالمأمور بأداء الدين له أن يرجع بالمؤدى لا بالدين؛ لأنه بالأداء ما ملك الدين بل أقرض المؤدى من الأمر فيرجع عليه بما أقرضه، وكذلك لو أعطى بالدراهم دنائير أو شيئاً من المكيل أو الموزون، فإنه يرجع عليه بما كفل لا بما أدى، بخلاف ما إذا صالح من الألف على خمسمائة أنه يرجع بالخمسمائة لا بالألف؛ لأنه بأداء الخمسمائة ما ملك ما في ذمة الأصل وهو الألف؛ لأنه لا يمكن إيقاع الصلح تمليكا ههنا؛ لأنه يؤدي إلى الربا فيقع إسقاطاً لبعض الحق، والساقط لا يحتل الرجوع به (١).

من خلال دراستك لفصل الكفالة أجب عما يلي:

عرف الكفالة واذكر حكمها وما ركنها وشرائطها؟

اذكر حكم الكفالة ثم اذكر ما يخرج به الكفيل عن الكفالة.

ما هي الحالات التي يخرج بها الكفيل بالنفس عن الكفالة؟.

كتبه

أ.د/ هناء فهمي أحمد عيسى. أستاذ ورئيس قسم الفقه بكلية الدراسات الإسلامية

والعربية للبنات بالمنصورة

د/ أحمد محمد السيد المرسي العفيفي. مدرس الفقه بكلية الشريعة والقانون بطنطا

(١) بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ج ٤/ ص ٦٠٠ وما بعدها.

الفصل الثامن الحَوَالَة .

ونتقع في أربعة مباحث:

المبحث الأول: تعريف الحوالة والأصل في جوازها .

المبحث الثاني: رُكْنُ الحَوَالَةِ وشَرَايِطُ الحَوَالَةِ.

المبحث الثالث: أنواع الحوالة وحُكْمُ الحَوَالَةِ .

المبحث الرابع: مَا يَخْرُجُ بِهِ الْمُحَالُ عَلَيْهِ مِنَ الحَوَالَةِ.

أهداف الدرس

بدراسة عقد الحوالة يكتسب الطالب ما يلي:

أولاً: المعلومات والمفاهيم:

التعرف على معنى الحوالة لغة وشرعاً وأدلة مشروعيتها.

التعرف على رُكْن الحوالة والآثار المترتبة عليها.

التعرف على شرائط الحوالة وأنواعها ..

التعرف على أبرز الأحكام الفقهية المتعلقة بالحوالة وآراء فقهاء الحنفية فيها وبيان ذلك بالأمثلة.

ثانياً: المهارات الذهنية:

يستطيع الطالب أن يقوم بتطبيق أحكام الحوالة على الواقع العملي في حياته العملية.

يستتبط الصور الحديثة لحل المشاكل إذا حدثت مشاكل بين المحيل والمحال عليه حالة الدين بينهما.

يحلل الفروق بين الحوالة وغيرها من الكفالة والإبراء.

يستطيع الطالب التمييز بين أنواع الحوالة .

المبحث الأول : تعريف الحوالة والأصل في جوازها .

أولاً : تعريف الحوالة :

الْحَوَالَةُ فِي اللُّغَةِ مَعْنَاهَا: التحول والانتقال ، مِنْ قَوْلِهِمْ : حَالَ عَنِ الْعَهْدِ : إِذَا انْتَقَلَ عَنْهُ وَتَغَيَّرَ . وَالْحَوَالَةُ بِفَتْحِ الْحَاءِ أَفْصَحُ مِنْ كَسْرِهَا .
الْحَوَالَةُ فِي الشَّرْعِ هِيَ : عَقْدٌ يَفْتَضِي نَقْلَ نَقْلِ الدَّيْنِ مِنْ ذِمَّةِ الْمُحِيلِ إِلَى ذِمَّةِ الْمُحَالِ عَلَيْهِ .

ثانياً : الأصل في جواز الحوالة :

الأصل في جواز الحوالة السُّنَّةُ .

ما روي عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ . رضي الله عنه . أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : (مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ فَإِذَا أُتْبِعَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيٍّ فَلْيَتَّبِعْ) (١) .
وفي رواية أخرى عن أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ : (إِذَا أُحِيلَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيٍّ فَلْيَحْتَلْ) .

المبحث الثاني : ركن الحوالة وسرايط الحوالة .

أولاً : ركن الحوالة .

رُكْنُ الْحَوَالَةِ عِنْدَ الْحَنْفِيَّةِ : الإِجَابُ وَالْقَبُولُ كَسَائِرِ الْعُقُودِ عِنْدَهُمْ ، الإِجَابُ مِنَ الْمُحِيلِ ، وَالْقَبُولُ مِنَ الْمُحَالِ عَلَيْهِ وَالْمُحَالِ جَمِيعًا .
فَالِإِجَابُ : أَنْ يَقُولَ الْمُحِيلُ لِلطَّالِبِ : أَحَلَّتْكَ عَلَى فُلَانٍ .
وَالْقَبُولُ مِنَ الْمُحَالِ عَلَيْهِ وَالْمُحَالِ أَنْ يَقُولَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا : قَبِلْتُ أَوْ رَضِيتُ ، أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ مِمَّا يَدُلُّ عَلَى الْقَبُولِ وَالرِّضَا .
لَأَنَّ الْحَوَالَةَ تَصَرُّفٌ عَلَى الْمُحَالِ عَلَيْهِ ، بِنَقْلِ الْحَقِّ إِلَى ذِمَّتِهِ ، فَلَا يَتِمُّ إِلَّا بِقَبُولِهِ وَرِضَاهُ ، لِأَنَّ النَّاسَ فِي اقْتِضَاءِ الدِّيُونِ وَالْمُطَالَبَةِ بِهَا عَلَى التَّفَاوُتِ : بَعْضُهُمْ أَسْهَلُ مُطَالَبَةً وَاقْتِضَاءً ، وَبَعْضُهُمْ أَصْعَبُ ، فَلَا بُدَّ مِنْ قَبُولِهِ .

(١) أخرجه مالك في الموطأ ج ٢ ص ٦٧٤ في البيوع ، باب جامع الدين والحوالة ، والبخاري في صحيحه برقم

وَقَالَ الشَّافِعِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ - : إِنْ لَمْ يَكُنْ لِلْمُحِيلِ عَلَى الْمُحَالِ عَلَيْهِ دَيْنٌ فَكَذَلِكَ ، فَأَمَّا إِذَا كَانَ لَهُ عَلَيْهِ دَيْنٌ ؛ فَيَتِمُّ بِإِجَابِ الْمُحِيلِ وَقَبُولِ الْمُحْتَالِ .
 وَجْهُ قَوْلِ الشَّافِعِيِّ : أَنَّ الْمُحِيلَ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ مُسْتَوْفٍ حَقَّ نَفْسِهِ بِيَدِ الطَّالِبِ ؛ فَلَا يَقِفُ عَلَى قَبُولِ مَنْ عَلَيْهِ الْحَقُّ ، كَمَا إِذَا وَكَّلَهُ بِالْقَبْضِ ، وَلَيْسَ هُوَ كَالْمُحَالِ ؛ لِأَنَّ الْحَوَالَهَ تَصَرَّفُ عَلَيْهِ بِنَقْلِ حَقِّهِ مِنْ ذِمَّةٍ إِلَى ذِمَّةٍ مَعَ اخْتِلَافِ الذِّمِّ ؛ فَلَا يَصِحُّ مِنْ غَيْرِ رِضَا صَاحِبِ الْحَقِّ .
 أما عند الجمهور فأركان الحوالة أربعة : مُحِيلٌ ، وَمُحْتَالٌ ، وَمُحَالٌ عَلَيْهِ ، وَمُحَالٌ بِهِ .

المُحِيلُ : هُوَ الشَّخْصُ الَّذِي أَحَالَ أَيْ الْمَدِينُ .
 الْمُحَالُ لَهُ : هُوَ الدَّائِنُ .

المُحَالُ عَلَيْهِ : هُوَ الَّذِي قَبِلَ الْحَوَالَهَ عَلَى نَفْسِهِ ، وَيُقَالُ لَهُ مُحْتَالٌ عَلَيْهِ أَيْضًا .
 الْمُحَالُ بِهِ : هُوَ الْمَالُ الْمُحَالُ (١) .

ثَانِيًا : شَرَايِطُ الْحَوَالَهَ :

شَرَايِطُ الْحَوَالَهَ أَنْوَاعٌ : بَعْضُهَا يَرْجِعُ إِلَى الْمُحِيلِ ، وَبَعْضُهَا يَرْجِعُ إِلَى الْمُحَالِ ، وَبَعْضُهَا يَرْجِعُ إِلَى الْمُحَالِ عَلَيْهِ ، وَبَعْضُهَا يَرْجِعُ إِلَى الْمُحَالِ بِهِ .
 أَمَّا الَّذِي يَرْجِعُ إِلَى الْمُحِيلِ :

١ . الْعَقْلُ : أَنْ يَكُونَ عَاقِلًا ، فَلَا تَصِحُّ حَوَالَهُ الْمَجْنُونِ وَالصَّبِيِّ الَّذِي لَا يَعْقِلُ ؛ لِأَنَّ الْعَقْلَ مِنْ شَرَايِطِ أَهْلِيَّةِ التَّصَرُّفَاتِ كُلِّهَا .

٢ . الْبُلُوغُ : أَنْ يَكُونَ بَالِغًا ، وَهُوَ شَرْطُ النَّفَاقِ دُونَ الْإِنْعِقَادِ ، فَتَنْعَقِدُ حَوَالَهُ الصَّبِيِّ الْعَاقِلِ ؛ مَوْثُوقًا نَفَاقَهُ عَلَى إِجَازَةِ وَلِيِّهِ ؛ لِأَنَّ الْحَوَالَهَ إِبْرَاءٌ بِحَالِهَا ، وَفِيهَا مَعْنَى الْمَعَاوَضَةِ بِمَا لَهَا ، خُصُوصًا إِذَا كَانَتْ مُقَيَّدَةً ؛ فَتَنْعَقِدُ مِنَ الصَّبِيِّ كَالْبَيْعِ وَنَحْوِهِ .

٣ . رِضَا الْمُحِيلِ حَتَّى لَوْ كَانَ مُكْرَهًا عَلَى الْحَوَالَهَ لَا تَصِحُّ ؛ لِأَنَّ الْحَوَالَهَ إِبْرَاءٌ ، فِيهَا مَعْنَى التَّمْلِيكِ ، فَتَفْسُدُ بِالْإِكْرَاهِ كَسَائِرِ التَّمْلِكَاتِ .

فَأَمَّا حُرِّيَّةُ الْمُحِيلِ فَلَيْسَتْ بِشَرْطٍ لِصِحَّةِ الْحَوَالَةِ ، حَتَّى تَصِحَّ حَوَالَةُ الْعَبْدِ مَادُونًا كَانَ فِي التَّجَارَةِ أَوْ مَحْجُورًا ، لِأَنَّهَا لَيْسَتْ بِتَبَرُّعٍ بِالتَّزَامِ شَيْءٍ كَالْكَفَالَةِ ؛ فَيَمْلِكُهَا الْعَبْدُ ، غَيْرَ أَنَّهُ إِنْ كَانَ مَادُونًا فِي التَّجَارَةِ ؛ رَجَعَ عَلَيْهِ الْمَحَالُ عَلَيْهِ لِلْحَالِ إِذَا أَدَّى ، وَلَمْ يَكُنْ لِلْعَبْدِ عَلَيْهِ دَيْنٌ مِثْلُهُ ، وَيَتَعَلَّقُ بِرَقَبَتِهِ ، وَإِنْ كَانَ مَحْجُورًا ؛ يَرْجِعُ عَلَيْهِ بَعْدَ الْعِتْقِ وَكَذَا الصَّحَّةُ لَيْسَتْ بِشَرْطٍ لِصِحَّةِ الْحَوَالَةِ ؛ لِأَنَّهَا مِنْ قَبْلِ الْمُحِيلِ لَيْسَتْ بِتَبَرُّعٍ ؛ فَتَصِحُّ مِنَ الْمَرِيضِ (١).

وَأَمَّا الَّذِي يَرْجِعُ إِلَى الْمَحَالِ فَأَنْوَاعٌ :

١ . الْعَقْلُ ؛ لِأَنَّ الْعَقْلَ مِنْ شَرَائِطِ أَهْلِيَّةِ النَّصْرِفَاتِ كُلِّهَا ؛ وَلِأَنَّ قَبُولَهُ رُكْنٌ ، وَغَيْرُ الْعَاقِلِ لَا يَكُونُ مِنْ أَهْلِ الْقَبُولِ .

٢ . الْبُلُوغُ وَهُوَ شَرْطُ نَفَازٍ ، لَا شَرْطُ إِنْعِقَادٍ ، فَيَنْعَقِدُ اخْتِيَالُهُ مَوْفُوفًا عَلَى إِجَارَةِ وَلِيِّهِ إِنْ كَانَ الثَّانِي أَمْلًا مِنَ الْأَوَّلِ ، وَكَذَا الْوَصِيُّ إِذَا اخْتَالَ بِمَالِ الْيَتِيمِ ؛ لَا تَصِحُّ إِلَّا بِهِذِهِ الشَّرِيطَةِ ؛ لِأَنَّهُ مِنْهُيٌّ عَنْ قُرْبَانِ مَالِهِ ، إِلَّا عَلَى وَجْهِ الْأَحْسَنِ ؛ لِلْأَيَّةِ الشَّرِيفَةِ فِيهِ { وَلَا تَقْرُبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ } .

٣ . الرِّضَا ، فَلَوْ اخْتَالَ مُكْرَهًا ؛ لَا تَصِحُّ ؛ لِأَنَّ الْحَوَالَةَ إِبْرَاءٌ ، فِيهَا مَعْنَى التَّمْلِيكِ ، فَتَفْسُدُ بِالْإِكْرَاهِ كَسَائِرِ التَّمْلِيكَاتِ .

٤ . مَجْلِسُ الْحَوَالَةِ وَهُوَ شَرْطُ الْإِنْعِقَادِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَمُحَمَّدٍ ، وَعِنْدَ أَبِي يُوسُفَ شَرْطُ النَّفَازِ ، حَتَّى أَنْ الْمُحْتَالَ لَوْ كَانَ غَائِبًا عَنِ الْمَجْلِسِ ، فَبَلَغَهُ الْخَبَرُ فَأَجَارَ ؛ لَا يَنْفُذُ عِنْدَهُمَا ، وَعِنْدَ أَبِي يُوسُفَ يَنْفُذُ ، وَالصَّحِيحُ : قَوْلُهُمَا ؛ لِأَنَّ قَبُولَهُ مِنْ أَحَدِ الْأَرْكَانِ الثَّلَاثَةِ ؛ فَكَانَ كَلَامُهُمَا بِدُونِ شَرْطِ الْعَقْدِ ؛ فَلَا يَقِفُ عَلَى غَائِبٍ عَنِ الْمَجْلِسِ - كَمَا فِي الْبَيْعِ (٢) .

وَأَمَّا الَّذِي يَرْجِعُ إِلَى الْمَحَالِ عَلَيْهِ فَأَنْوَاعٌ.

١ . الْعَقْلُ ، فَلَا يَصِحُّ مِنَ الْمَجْنُونِ وَالصَّبِيِّ الَّذِي لَا يَعْقِلُ قَبُولَ الْحَوَالَةِ أَصْلًا ؛ لِأَنَّ الْعَقْلَ مِنْ شَرَائِطِ أَهْلِيَّةِ النَّصْرِفَاتِ كُلِّهَا .

(١) بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ج ٥ ص ٨ ، ٩ .

(٢) بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ج ٥ ص ٩ .

٢ . الْبُلُوعُ ، وَهُوَ شَرْطُ إِنْعِقَادِ أَيْضًا ؛ فَلَا يَصِحُّ مِنَ الصَّبِيِّ قَبُولُ الْحَوَالَةِ أَصْلًا ، وَإِنْ كَانَ عَاقِلًا ، سَوَاءً كَانَ مَحْجُورًا عَلَيْهِ أَوْ مَادُونًا فِي التَّجَارَةِ ، وَسَوَاءً كَانَتْ الْحَوَالَةُ بِغَيْرِ أَمْرِ الْمُحِيلِ ، أَوْ بِأَمْرِهِ .
أَمَّا إِذَا كَانَتْ بِغَيْرِ أَمْرِهِ فَظَاهِرٌ ؛ لِأَنَّهُ لَا يَمْلِكُ الرَّجُوعَ عَلَى الْمُحِيلِ ، فَكَانَ تَبَرُّعًا بِابْتِدَائِهِ وَانْتِهَائِهِ .

وَكَذَلِكَ إِذَا كَانَتْ بِأَمْرِهِ ؛ لِأَنَّهُ تَبَرُّعٌ بِابْتِدَائِهِ ، فَلَا يَمْلِكُهُ الصَّبِيُّ ، مَحْجُورًا كَانَ أَوْ مَادُونًا فِي التَّجَارَةِ ، كَالْكَفَالَةِ ، وَإِنْ قَبِلَ عَنْهُ وَلِيُّهُ لَا يَصِحُّ أَيْضًا ؛ لِأَنَّهُ مِنَ التَّصَرُّفَاتِ الضَّارَّةِ فَلَا يَمْلِكُهُ الْوَلِيُّ .

٣ . الرِّضَا ، حَتَّى لَوْ أُكْرِهَ عَلَى قَبُولِ الْحَوَالَةِ لَا يَصِحُّ .

٤ . الْمَجْلِسُ ، وَأَنَّهُ شَرْطُ الْإِنْعِقَادِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَمُحَمَّدٍ ؛ لِمَا ذَكَرْنَا فِي جَانِبِ الْمَحَالِ وَأَمَّا الَّذِي يَرْجِعُ إِلَى الْمَحَالِ بِهِ فَنَوْعَانِ :
أَحَدُهُمَا : أَنْ يَكُونَ دَيْنًا ؛ فَلَا تَصِحُّ الْحَوَالَةُ بِالْأَعْيَانِ الْقَائِمَةِ ، لِأَنَّهَا نَقْلٌ مَا فِي الدِّمَّةِ ، وَلَمْ يُوجَدْ .

وَالثَّانِي : أَنْ يَكُونَ لَازِمًا ؛ فَلَا تَصِحُّ الْحَوَالَةُ بِدَيْنٍ غَيْرِ لَازِمٍ ، - كَبَدْلِ الْكِتَابَةِ وَمَا يَجْرِي مَجْرَاهُ ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ دَيْنٌ تَسْمِيَةً لَا حَقِيقَةً ؛ إِذْ الْمَوْلَى لَا يَجِبُ لَهُ عَلَى عَبْدِهِ دَيْنٌ ، وَالْأَصْلُ : أَنَّ كُلَّ دَيْنٍ لَا تَصِحُّ الْكَفَالَةُ بِهِ ، لَا تَصِحُّ الْحَوَالَةُ بِهِ (١) .

وَأَمَّا وَجُوبُ الدَّيْنِ عَلَى الْمَحَالِ عَلَيْهِ لِلْمُحِيلِ قَبْلَ الْحَوَالَةِ ؛ فَلَيْسَ بِشَرْطٍ لِصِحَّةِ الْحَوَالَةِ ، حَتَّى تَصِحَّ الْحَوَالَةُ ، سَوَاءً كَانَ لِلْمُحِيلِ عَلَى الْمَحَالِ عَلَيْهِ دَيْنٌ ، أَوْ لَمْ يَكُنْ ، وَسَوَاءً كَانَتْ الْحَوَالَةُ مُطْلَقَةً أَوْ مُقَيَّدَةً .

المبحث الثالث : أنواع الحوالة وحكم الحوالة .

أولاً : أنواع الحوالة .

تتنوع الحوالة إلى نوعين :

أ- الحَوَالَةُ الْمُقَيَّدَةُ: هِيَ الْحَوَالَةُ الَّتِي قُيِّدَتْ بِأَنْ تُعْطَى مِنَ الْمَالِ الَّذِي لِلْمُحِيلِ بِذِمَّةِ الْمَحَالِ عَلَيْهِ أَوْ بِيَدِهِ .

((١)) بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ج ٥ ص ٩ ،

ب - الحَوَالَةُ الْمُطْلَقَةُ : هِيَ الَّتِي لَمْ تُقَيَّدَ بِأَنْ تُعْطَى مِنْ الْمَالِ الَّذِي لِلْمُحِيلِ بِيَدِ الْمُحَالِ عَلَيْهِ (١) .

إِذَا قَالَ الْمُحِيلُ لِذَانِهِ : أَحْلُتْكَ عَلَى فُلَانٍ وَقَبِلَ الْمُحَالُ لَهُ وَالْمُحَالُ عَلَيْهِ تَتَعَقَّدُ الْحَوَالَةُ .

هل تنعقد الحَوَالَةُ بَيْنَ الْمُحَالِ لَهُ وَالْمُحَالِ عَلَيْهِ فَقَطْ ؟

يَجُوزُ عَقْدُ الْحَوَالَةِ بَيْنَ الْمُحَالِ لَهُ وَالْمُحَالِ عَلَيْهِ فَقَطْ ، مَثَلًا لَوْ قَالَ شَخْصٌ لِآخَرَ : خُذْ عَلَيْكَ حَوَالَةَ دَيْنِي الْبَالِغِ كَذَا قَرْضًا عِنْدَ فُلَانٍ ، وَقَالَ ذَلِكَ الشَّخْصُ " قَبِلْتُ " ، أَوْ قَالَ لَهُ : أَقْبِلْ الدَّيْنَ الَّذِي لَكَ عِنْدَ فُلَانٍ بِكَذَا قَرْضًا حَوَالَةَ عَلَيَّ ، وَقَبِلَ الشَّخْصُ الْمَذْكُورُ تَكُونُ الْحَوَالَةُ صَحِيحَةً حَتَّى لَوْ نَدِمَ الْمُحَالُ عَلَيْهِ بَعْدَ ذَلِكَ لَا تُجْدِيهِ نَدَامَتُهُ نَفْعًا . أَمَّا الْحَوَالَةُ الَّتِي تَجْرِي بَيْنَ الْمُحِيلِ وَالْمُحَالِ عَلَيْهِ فَقَطْ تَتَعَقَّدُ مَوْفُوفَةً عَلَى قَبُولِ الْمُحَالِ لَهُ . وَالْحَوَالَةُ بِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنَ النَّوعَيْنِ جَائِزَةٌ ؛ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ { مَنْ أُحِيلَ عَلَى مَلِيٍّ فَلْيَتَّبِعْ } مِنْ غَيْرِ فَصْلِ .

إِلَّا أَنَّ الْحَوَالَةَ الْمُطْلَقَةَ ؛ تُخَالِفُ الْحَوَالَةَ الْمُقَيَّدَةَ فِي أَحْكَامِ مِنْهَا :

١ . أَنَّهُ إِذَا أَطْلُقَ الْحَوَالَةَ ، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ عَلَى الْمُحَالِ عَلَيْهِ دَيْنٌ ، فَإِنَّ الْمُحَالِ يَطْلُبُ الْمُحَالِ عَلَيْهِ بِدَيْنِ الْحَوَالَةِ لَا غَيْرُ ، وَإِنْ كَانَ لَهُ عَلَيْهِ دَيْنٌ ؛ فَإِنَّ الْمُحَالِ عَلَيْهِ يَطْلُبُ بِدَيْنَيْنِ : دَيْنِ الْحَوَالَةِ ، وَدَيْنِ الْمُحِيلِ ، فَيُطَالِبُهُ الْمُحَالُ بِدَيْنِ الْحَوَالَةِ ، وَيُطَالِبُهُ الْمُحِيلُ بِالَّذِي لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ ، وَلَا يَنْقَطِعُ حَقُّ الْمُطَالَبَةِ لِلْمُحِيلِ بِدَيْنِهِ بِسَبَبِ الْحَوَالَةِ ؛ لِأَنَّ الْحَوَالَةَ لَمْ تَتَقَيَّدْ بِالَّذِي لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ ؛ لِأَنَّهَا وَجِدَتْ مُطْلَقَةً عَنْ هَذِهِ الشَّرِيطَةِ ، فَيَتَعَلَّقُ دَيْنُ الْحَوَالَةِ بِنَعْتِهِ ، وَدَيْنُ الْمُحِيلِ بِقِيِّ عَلَى حَالِهِ .

وَإِذَا قَيَّدَهَا بِالَّذِي لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ ؛ يَنْقَطِعُ حَقُّ مُطَالَبَةِ الْمُحِيلِ ؛ لِأَنَّهُ قَيَّدَ الْحَوَالَةَ بِهِذَا الدَّيْنِ ، فَيَتَقَيَّدُ بِهِ ، وَيَكُونُ ذَلِكَ الدَّيْنُ بِمَنْزِلَةِ الرَّهْنِ عِنْدَهُ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ رَهْنًا عَلَى الْحَقِيقَةِ .

٢ . أَنَّهُ لَوْ ظَهَرَتْ بَرَاءَةُ الْمُحَالِ عَلَيْهِ مِنَ الدَّيْنِ الَّذِي فُيِّدَتْ بِهِ الْحَوَالَةُ ، بِأَنْ كَانَ الدَّيْنُ ثَمَنَ مَبِيعٍ فَاسْتَحَقَّ الْمَبِيعُ ؛ تَبْطُلُ الْحَوَالَةُ ، وَلَوْ سَقَطَ عَنْهُ الدَّيْنُ لِمَعْنَى عَارِضٍ ، بِأَنْ هَلَكَ الْمَبِيعُ عِنْدَ الْبَائِعِ قَبْلَ التَّسْلِيمِ بَعْدَ الْحَوَالَةِ ، حَتَّى سَقَطَ الثَّمَنُ عَنْهُ ؛ لَا تَبْطُلُ الْحَوَالَةُ عَنْهُ لَكِنْ إِذَا أَدَّى الدَّيْنُ بَعْدَ سَقُوطِ الثَّمَنِ يَرْجِعُ بِمَا أَدَّى عَلَى الْمُحِيلِ ؛ لِأَنَّهُ قَضَى دَيْنَهُ بِأَمْرِهِ .

وَلَوْ ظَهَرَ ذَلِكَ فِي الْحَوَالَةِ الْمُطْلَقَةِ ؛ لَا يَبْطُلُ ؛ لِأَنَّهُ لَمَّا قَيَّدَ الْحَوَالَةُ بِهِ فَقَدْ تَعَلَّقَ الدَّيْنُ بِهِ ، فَإِذَا ظَهَرَ أَنَّهُ لَا دَيْنَ ، فَقَدْ ظَهَرَ أَنَّهُ لَا حَوَالَةَ ؛ لِأَنَّ الْحَوَالَةَ بِالدَّيْنِ ، وَقَدْ تَبَيَّنَ أَنَّهُ لَا دَيْنَ ، فَتَبَيَّنَ أَنَّهُ لَا حَوَالَةَ ضَرُورَةً ، وَهَذَا لَا يُوْجَدُ فِي الْحَوَالَةِ الْمُطْلَقَةِ ؛ لِأَنَّ تَعَلُّقَ الدَّيْنِ بِهِ يُوجِبُ تَقْيِيدَ الْحَوَالَةِ ، وَلَمْ يُوْجَدْ ؛ فَلَا يَتَعَلَّقُ بِهِ الدَّيْنُ ؛ فَيَتَعَلَّقُ بِالذِّمَّةِ ؛ فَلَا يَظْهَرُ أَنَّ الْحَوَالَةَ كَانَتْ بَاطِلَةً ، وَكَذَلِكَ لَوْ قَيَّدَ الْحَوَالَةَ بِأَلْفٍ وَدِيعَةٍ عِنْدَ رَجُلٍ ، فَهَلَكَتْ الْأَلْفُ عِنْدَ الْمُودِعِ ؛ بَطَلَتْ الْحَوَالَةُ .

وَلَوْ كَانَتْ الْأَلْفُ عَلَى الْمُحَالِ عَلَيْهِ مَضمُونَةً ؛ لَا تَبْطُلُ الْحَوَالَةُ بِالْهَلَاكِ ؛ لِأَنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِ مِثْلُهَا .

٣ . أَنَّهُ إِذَا مَاتَ الْمُحِيلُ فِي الْحَوَالَةِ الْمُقَيَّدَةِ ، قَبْلَ أَنْ يُؤَدِّيَ الْمُحَالُ عَلَيْهِ الدَّيْنَ إِلَى الْمُحَالِ ، وَعَلَى الْمُحِيلِ دُيُونٌ سِوَى دَيْنِ الْمُحَالِ ، وَلَيْسَ لَهُ مَالٌ سِوَى هَذَا الدَّيْنِ ؛ لَا يَكُونُ الْمُحَالُ أَحَقَّ بِهِ مِنْ بَيْنِ سَائِرِ الْغُرَمَاءِ ، عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَبِي يُوسُفَ وَمُحَمَّدٍ ، وَعِنْدَ زُفَرٍ : يَكُونُ أَحَقَّ بِهِ مِنْ بَيْنِ سَائِرِ الْغُرَمَاءِ كَالرَّهْنِ .

وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَأَبُو يُوسُفَ وَمُحَمَّدٌ : بِالْفَرْقِ بَيْنَ الْحَوَالَةِ وَالرَّهْنِ ، وَهُوَ أَنَّ الْمُزْتَهِنَ أُخْتُصَّ بِغُرْمِ الرَّهْنِ مِنْ بَيْنِ سَائِرِ الْغُرَمَاءِ أَلَّا تَرَى أَنَّهُ لَوْ هَلَكَ يَسْقُطُ دَيْنُهُ خَاصَّةً ؟ وَلَمَّا أُخْتُصَّ بِغُرْمِهِ أُخْتُصَّ بِغُنْمِهِ ؛ لِأَنَّ الْخَرَاجَ بِالضَّمَانِ .

فَأَمَّا الْمُحَالُ فِي الْحَوَالَةِ الْمُقَيَّدَةِ ، فَلَمْ يَخْتَصَّ بِغُرْمِ ذَلِكَ الْمَالِ ؛ أَلَّا تَرَى أَنَّهُ لَوْ تَوَيَّ لَا يَسْقُطُ دَيْنُهُ عَلَى الْمُحِيلِ ، وَالتَّوَيَّ عَلَى الْمُحِيلِ دُونَهُ ، فَلَمَّا لَمْ يَخْتَصَّ بِغُرْمِهِ لَمْ يَخْتَصَّ بِغُنْمِهِ أَيْضًا ، بَلْ يَكُونُ هُوَ وَغُرَمَاءُ الْمُحِيلِ أَسْوَةً فِي ذَلِكَ ، وَإِذَا أَرَادَ الْمُحِيلُ أَنْ يَأْخُذَ الْمُحَالُ عَلَيْهِ بِبَقِيَّةِ دَيْنِهِ ، فَلَيْسَ لَهُ ذَلِكَ ؛ لِأَنَّ الْمَالَ الَّذِي فُيِّدَتْ بِهِ الْحَوَالَةُ أُسْتُحَقَّ مِنَ الْمُحَالِ عَلَيْهِ ؛ فَبَطَلَتْ الْحَوَالَةُ .

وَلَوْ كَانَتْ الْحَوَالَةُ مُطْلَقَةً ، وَالْمَسْأَلَةُ بِحَالِهَا ؛ يُؤْخَذُ مِنَ الْمُحَالِ عَلَيْهِ جَمِيعُ الدَّيْنِ الَّذِي عَلَيْهِ ، وَيُقَسَّمُ بَيْنَ غُرَمَاءِ الْمُحِيلِ ، وَلَا يَدْخُلُ الْمُحَالُ فِي ذَلِكَ ، وَإِنَّمَا يُؤْخَذُ مِنَ الْمُحَالِ عَلَيْهِ ؛ لِأَنَّ الْحَوَالَةَ لَمْ تَتَعَلَّقْ بِهِ ، فَذَلِكَ مِلْكُ الْمُحِيلِ وَلَا يُشَارِكُهُمُ الْمُحَالُ فِي ذَلِكَ ؛ لِأَنَّ حَقَّهُ ثَبَتَ عَلَى الْمُحَالِ عَلَيْهِ ، وَلَا يَعُودُ إِلَى الْمُحِيلِ ، وَلَكِنَّ الْقَاضِيَ يَأْخُذُ مِنْ غُرَمَاءِ الْمُحِيلِ كَفِيلًا ؛ لِأَنَّهُ ثَبَتَ الرُّجُوعُ إِلَيْهِمْ لِأَحَدِ رَجُلَيْنِ (١).

ثَانِيًا : حُكْمُ الْحَوَالَةِ .

الْحَوَالَةُ لَهَا أَحْكَامٌ :

الأول : بَرَاءَةُ الْمُحِيلِ ، وَهَذَا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَبِي يُوسُفَ وَمُحَمَّدٍ .
وَقَالَ زُفَرٌ : الْحَوَالَةُ لَا تُوجِبُ بَرَاءَةَ الْمُحِيلِ ، وَالْحَقُّ فِي ذِمَّتِهِ بَعْدَ الْحَوَالَةِ ، عَلَى مَا كَانَ عَلَيْهِ قَبْلَهَا ، كَالْكَفَالَةِ سَوَاءً .

وَجْهٌ قَوْلِ زُفَرٍ : أَنَّ الْحَوَالَةَ شُرِعَتْ وَثِيقَةً لِلدَّيْنِ ، كَالْكَفَالَةِ ، وَلَيْسَ مِنَ الْوَثِيقَةِ بَرَاءَةُ الْأَوَّلِ ، بَلْ الْوَثِيقَةُ فِي مُطَالَبَةِ الثَّانِي ، مَعَ بَقَاءِ الدَّيْنِ عَلَى حَالِهِ فِي ذِمَّةِ الْأَوَّلِ مِنْ غَيْرِ تَغْيِيرٍ ، كَمَا فِي الْكَفَالَةِ سَوَاءً .

وجه قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد: أَنَّ الْحَوَالَةَ مُشْتَقَّةٌ مِنَ التَّحْوِيلِ وَهُوَ النَّقْلُ ، فَكَانَ مَعْنَى الْإِنْتِقَالِ لَازِمًا فِيهَا ، وَالشَّيْءُ إِذَا انْتَقَلَ إِلَى مَوْضِعٍ لَا يَبْقَى فِي الْمَحَلِّ الْأَوَّلِ ضَرُورَةً ، وَمَعْنَى الْوَثِيقَةِ يَحْصُلُ بِسُهُولَةِ الْوُصُولِ مِنْ حَيْثُ الْمَلَاءَةُ وَالْإِنْصَافُ .
وَلَوْ كَفَلَ بِشَرْطِ بَرَاءَةِ الْأَصِيلِ ؛ جَازَ وَتَكُونُ حَوَالَةً ؛ لِأَنَّهُ أَتَى بِمَعْنَى الْحَوَالَةِ .

الثاني : ثُبُوتُ وَلَايَةِ الْمُطَالَبَةِ لِلْمُحَالِ عَلَى الْمُحَالِ عَلَيْهِ بِدَيْنٍ فِي ذِمَّتِهِ ، أَوْ فِي ذِمَّةِ الْمُحِيلِ ؛ لِأَنَّ الْحَوَالَةَ أُوجِبَتْ النَّقْلَ إِلَى ذِمَّةِ الْمُحَالِ عَلَيْهِ بِدَيْنٍ فِي ذِمَّتِهِ ، إِمَّا نَقْلَ الدَّيْنِ وَالْمُطَالَبَةِ جَمِيعًا ، وَإِمَّا نَقْلَ الْمُطَالَبَةِ لَا غَيْرَ ، وَذَلِكَ يُوجِبُ حَقَّ الْمُطَالَبَةِ لِلْمُحَالِ عَلَى الْمُحَالِ عَلَيْهِ .

الثالث : ثُبُوتُ حَقِّ الْمُلَازِمَةِ لِلْمُحَالِ عَلَيْهِ عَلَى الْمُحِيلِ إِذَا لَازَمَهُ الْمُحَالُ فَكُلَّمَا لَازَمَهُ الْمُحَالُ ؛ فَلَهُ أَنْ يُلَازِمَ الْمُحِيلَ لِيَتَخَلَّصَ عَنْ مُلَازِمَةِ الْمُحَالِ ، وَإِذَا حَبَسَهُ : لَهُ أَنْ

((١)) مجلة الأحكام العدلية - (ج ١ / ص ١٢٨) بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ج ٥ ص ١٠ ، ١١ .

يَحْبِسُهُ إِذَا كَانَتْ الْحَوَالَةُ بِأَمْرِ الْمُحِيلِ ، وَلَمْ يَكُنْ عَلَى الْمُحَالِ عَلَيْهِ دَيْنٌ مِثْلُهُ لِلْمُحِيلِ ؛ لِأَنَّهُ هُوَ الَّذِي أَوْقَعَهُ فِي هَذِهِ الْعَهْدَةِ ؛ فَعَلَيْهِ تَخْلِيصُهُ مِنْهَا ، وَإِنْ كَانَتْ الْحَوَالَةُ بِغَيْرِ أَمْرِهِ ، أَوْ كَانَتْ بِأَمْرِهِ ، وَلَكِنْ لِلْمُحِيلِ عَلَى الْمُحَالِ عَلَيْهِ دَيْنٌ مِثْلُهُ ، وَالْحَوَالَةُ مُقَيَّدَةٌ ؛ لَمْ يَكُنْ لِلْمُحَالِ عَلَيْهِ أَنْ يُلَازِمَ الْمُحِيلَ إِذَا لُوزِمَ ، وَلَا أَنْ يَحْبِسَهُ إِذَا حُبِسَ ؛ لِأَنَّ الْحَوَالَةَ إِذَا كَانَتْ بِغَيْرِ أَمْرِ الْمُحِيلِ ؛ كَانَ الْمُحَالُ عَلَيْهِ مُتَبَرِّعًا ، وَإِنْ كَانَ لِلْمُحِيلِ عَلَيْهِ دَيْنٌ مِثْلُهُ ، وَقَيَّدَ الْحَوَالَةَ بِهِ فَلَوْ لَازِمَهُ الْمُحَالُ عَلَيْهِ ؛ لَكَانَ لِلْمُحِيلِ أَنْ يُلَازِمَهُ أَيْضًا ؛ فَلَا يُقَيَّدُ (١).

المبحث الرابع : مَا يَخْرُجُ بِهِ الْمُحَالُ عَلَيْهِ مِنَ الْحَوَالَةِ.

يَخْرُجُ الْمُحَالُ عَلَيْهِ مِنَ الْحَوَالَةِ بِانْتِهَاءِ حُكْمِ الْحَوَالَةِ ، وَحُكْمُ الْحَوَالَةِ يَنْتَهِي بِأَشْيَاءَ مِنْهَا :

١ . فَسُخُ الْحَوَالَةِ ؛ لِأَنَّ فِيهَا مَعْنَى مُعَاوَضَةِ الْمَالِ بِالْمَالِ ، فَكَانَتْ مُحْتَمِلَةً لِلْفَسْخِ ، وَمَتَى فُسِخَ تَعَوَّدَ الْمُطَالِبَةُ إِلَى الْمُحِيلِ .

٢ . التَّوَى عِنْدَ الْحَنْفِيَّةِ (التَّوَى : الْهَلَاكُ) .

لَمَّا رُوِيَ عَنْ سَيِّدِنَا عُمَانَ . رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ . أَنَّهُ قَالَ فِي الْمُحَالِ عَلَيْهِ : إِذَا مَاتَ مُفْلِسًا عَادَ الدَّيْنُ إِلَى ذِمَّةِ الْمُحِيلِ ، وَقَالَ : (لَا تَوَى عَلَى مَالِ امْرِئٍ مُسْلِمٍ) (٢).

وَلِأَنَّ الدَّيْنَ كَانَ ثَابِتًا فِي ذِمَّةِ الْمُحِيلِ قَبْلَ الْحَوَالَةِ ، وَالْأَصْلُ أَنَّ الدَّيْنَ لَا يَسْقُطُ إِلَّا بِالْقَضَاءِ قَالَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ : { الدَّيْنُ مَقْضِيٌّ } إِلَّا أَنَّهُ أُلْحِقَ الْإِبْرَاءَ بِالْقَضَاءِ فِي السَّقُوطِ ، وَالْحَوَالَةُ لَيْسَتْ بِقَضَاءٍ ، وَلَا إِبْرَاءٍ ، فَبَقِيَ الدَّيْنُ فِي ذِمَّتِهِ عَلَى مَا كَانَ قَبْلَ الْحَوَالَةِ ، إِلَّا أَنَّ بِالْحَوَالَةِ انْتَقَلَتْ الْمُطَالِبَةُ إِلَى الْمُحَالِ عَلَيْهِ ، لَكِنْ إِلَى غَايَةِ التَّوَى ؛ لِأَنَّ حَيَاةَ الدَّيْنِ بِالْمُطَالِبَةِ ، فَإِذَا تَوَى ؛ لَمْ تَبْقَ وَسِيلَةٌ إِلَى الْإِحْيَاءِ ، فَعَادَتْ إِلَى

(١) بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ج ٥ ص ١١ .

(٢) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ج ٦ ص ٧١ وأخرجه الإمام مالك في الموطأ (كتاب الأقضية، باب القضاء في المصرع والمدير) «أن رسول الله ﷺ قال: لا توى على مال امرئ مسلم». وأخرجه الدارقطني في سننه (٤٤/٣). أقوال أهل العلم: قال ابن عبد البر في التمهيد (٢٦٨/١٠): هذا الحديث منقطع عند جميعهم، لم يسنده أحد يحتاج به. وقال البيهقي يروى مرسلاً، وإسناده ضعيف وذكره ابن قدامة في المغني (٤٥٢/٦) محتجاً به في باب الرهن، بمعنى: لا يبطل مال المسلم إذا كان مرهوناً أو متعلقاً بحق.

مَحَلِّهَا الْأَصْلِيَّ، وَلَا حُجَّةَ لَهُ فِي الْحَدِيثِ ؛ لِأَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَّقَ الْحُكْمَ بِشَرِيطَةِ الْمَلَاءَةِ ، وَقَدْ ذَهَبَتْ بِالْإِفْلَاسِ .

ثُمَّ التَّوَى عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ - رَحِمَهُ اللَّهُ - بِشَيْئَيْنِ لَا تَأْتِ لُهُمَا :
أَحَدُهُمَا : أَنْ يَمُوتَ الْمُحَالُ عَلَيْهِ مُفْلِسًا .

وَالثَّانِي : أَنْ يَجْعَلَ الْحَوَالَةَ وَيَخْلِفَ ، وَلَا بَيِّنَةٌ لِلْمُحَالِ .

وَقَدْ قَالَ أَبُو يُوسُفَ وَمُحَمَّدٌ : بِهِمَا وَبِثَالِثٍ ، وَهُوَ أَنْ يُفْلِسَ الْمُحَالُ عَلَيْهِ حَالِ حَيَاتِهِ ، وَيَقْضِيَ الْقَاضِي بِإِفْلَاسِهِ بِنَاءً عَلَى أَنَّ الْقَاضِيَ يَقْضِي بِالْإِفْلَاسِ حَالِ حَيَاتِهِ عِنْدَهُمَا .

وَعِنْدَهُ : لَا يَقْضِي بِهِ .

٣ . أَذَاءُ الْمُحَالِ عَلَيْهِ الْمَالُ إِلَى الْمُحَالِ ، فَإِذَا أَدَّى الْمَالُ خَرَجَ عَنِ الْحَوَالَةِ ؛ إِذْ لَا فَائِدَةَ فِي بَقَائِهَا بَعْدَ انْتِهَاءِ حُكْمِهَا .

٤ . أَنْ يَهَبَ الْمُحَالُ الْمَالُ لِلْمُحَالِ عَلَيْهِ وَيَقْبَلَهُ .

٥ . أَنْ يَتَّصِدَّقَ بِهِ عَلَيْهِ ، وَيَقْبَلَهُ ؛ لِأَنَّ الْهَبَةَ وَالصَّدَقَةَ فِي مَعْنَى الْإِبْرَاءِ .

٦ . أَنْ يَمُوتَ الْمُحَالُ ؛ فَيَرِثُهُ الْمُحَالُ عَلَيْهِ ، لِأَنَّ الْإِرْثَ مِنْ أَسْبَابِ الْمُلْكِ فَإِذَا وَرِثَهُ فَقَدْ مَلَكَهُ ؛ فَكَانَ لَهُ حَقُّ الرُّجُوعِ .

٧ . أَنْ يُبْرِئَهُ مِنَ الْمَالِ . وَلَوْ أَبْرَأَ الْمُحَالُ الْمُحَالُ عَلَيْهِ مِنَ الدَّيْنِ لَا يَرْجِعُ عَلَى الْمُحِيلِ ؛ لِأَنَّ الْإِبْرَاءَ إِسْقَاطُ حَقِّهِ ؛ فَلَا يُعْتَبَرُ فِيهِ جَانِبُ التَّمْلِيكِ إِلَّا عِنْدَ اشْتِعَالِهِ بِالرَّدِّ ، فَإِذَا لَمْ يُوْجَدْ بَقِيَ إِسْقَاطًا مَحْضًا ، فَلَمْ يَمْلِكِ الْمُحَالُ عَلَيْهِ شَيْئًا ؛ فَلَا يَرْجِعُ .

٨ . أَنْ تَكُونَ الْحَوَالَةُ بِأَمْرِ الْمُحِيلِ ، فَإِنْ كَانَتْ بِغَيْرِ أَمْرِهِ ؛ لَا يَرْجِعُ ، بِأَنْ قَالَ رَجُلٌ لِلطَّالِبِ : إِنَّ لَكَ عَلَى فُلَانٍ كَذَا وَكَذَا مِنَ الدَّيْنِ ، فَاحْتَلَّ بِهَا عَلَيَّ ، فَرَضِي بِذَلِكَ الطَّالِبُ ؛ جَارَتْ الْحَوَالَةُ ، إِلَّا أَنَّهُ إِذَا أَدَّى لَا يَرْجِعُ عَلَى الْمُحِيلِ ؛ لِأَنَّ الْحَوَالَةَ إِذَا كَانَتْ بِأَمْرِ الْمُحِيلِ صَارَ الْمُحَالُ مُمْلَكًا الدَّيْنِ مِنَ الْمُحَالِ عَلَيْهِ بِمَا أَدَّى إِلَيْهِ مِنَ الْمَالِ ؛ فَكَانَ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ بِذَلِكَ عَلَى الْمُحِيلِ ، وَإِنْ كَانَتْ بِغَيْرِ أَمْرِهِ لَا يُوْجَدُ مَعْنَى التَّمْلِيكِ ؛ فَلَا تَنْبُتُ وَلَايَةُ الرُّجُوعِ .

٩ . أَنْ لَا يَكُونَ لِلْمُحِيلِ عَلَى الْمُحَالِ عَلَيْهِ دَيْنٌ مِثْلُهُ ، فَإِنْ كَانَ : لَا يَرْجِعُ ؛ لِأَنَّ الدَّيْنَيْنِ التَّقْيَا قِصَاصًا ؛ لِأَنَّهُ لَوْ رَجَعَ عَلَى الْمُحِيلِ لَرَجَعَ الْمُحِيلُ عَلَيْهِ أَيْضًا ، فَلَا يُفِيدُ فَيَنْقَاصًا الدَّيْنَيْنِ ؛ فَبَطَلَ حَقُّ الرُّجُوعِ (١) .

وجاء في مختصر القدوري ما نصه "الحالة جائزة بالديون وتصح برضا المحيل والمحتال له والمحال عليه وإذا تمت الحالة برىء المحيل من الدين ولم يرجع المحتال على المحيل إلا أن يتوى حقه والتوى (٢) عند أبي حنيفة أحد أمرين: إما أن يجحد الحالة ويحلف ولا بينة عليه أو يموت مفلسا وقال أبو يوسف ومحمد هذان ووجه ثالث وهو أن يحكم الحاكم بإفلاسه في حال حياته وإذا طالب المحال عليه المحيل بمثل مال الحالة فقال المحيل: أحلت بدين لي عليك لم يقبل قوله وكان عليه مثل الدين وإن طالب المحيل المحتال بما أحاله به فقال: إنما أحلتك لتقبضه لي وقال المحتال: بل أحلتي بدين" (٣)

ومن خلال ما سبق يمكن أن نستنتج عدة نتائج على النحو التالي :

١- أن الحالة نقلُ الدين وتحويلُهُ مِنْ ذِمَّةِ الْمُحِيلِ (المدين) إِلَى ذِمَّةِ الْمُحَالِ عَلَيْهِ، والحالة عقدٌ مشروعٌ.

٢- أباحت الشريعة الإسلامية عقد الحالة رعاية لمصالح الناس ومحافظة على أموالهم.

٣- عقد الحالة يزيل التنازع والتشاجر بين المحيل والمحال له (الدائن والمدين) وبدونها قد يحدث ما لا يحمد عقباه.

٤- من المصطلحات المتعلقة بالدرس المحيل: وهو المدين، المحال له: الدائن، المحال عليه: المدين الثاني، الذي تم تحويل الدائن عليه، المحال به: المال أو الدين المحال به: وهو نفس الدين الذي للمحال على المحيل، الصيغة وهي الإيجاب والقبول.

(١) (بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ج ٥ ص ١٢ . ١٤ .

(٢) (والتوى: هلك المال وذهابه، يقال توى مال فلان، يتوى توى أى هلك. (المطلع على أبواب الفقه ص ١٧٦).

(٣) مختصر القدوري لأبي الحسين القدوري (المتوفى: ٤٢٨هـ) ص ١٢٠ ط: دار الكتب العلمية الطبعة: الأولى،

١٤١٨هـ - ١٩٩٧م .

٥- وجه الاتفاق بين الحوالة والكفالة أن كلاً منهما عَقْدُ التَزَامٍ مَا عَلَى الْأَصِيلِ لِلتَّوَثُّقِ، إِلَّا أَنَّ الْحَوَالََةَ تَتَضَمَّنُ بَرَاءَةَ الْأَصِيلِ بَرَاءَةً مُقَيَّدَةً بِخِلَافِ الْكَفَالَةِ.

٦- تختلف الحوالة عن الكفالة: أن الكفالة: ضم ذمّة إلى ذمّة في حق المُطَالِبَةِ، أما الحوالة فهي نقل الدَّيْنِ من ذمه الى ذمه أخرى.

٧- الفرق بين الحوالة والإبراء أن الإبراء إسْقَاطُ الشخص حقاً له لآخر، أما الحوالة نقل الحق من ذمه الى ذمه أخرى.

٨- الحوالة مشروعة بالسنة والإجماع والمعقول لحاجه الناس إليها في المعاملات.

٩- تنقسم الحوالة عند الحنفية إلى مطلقة، ومقيدة والمطلقة نوعان :مؤجلة وحالة والمقيدة ثلاثة أنواع:

أ- حوالة مقيدة بدين خاص.

ب- وحوالة مقيدة بعين مضمونة كالمغصوبة.

ج- وحوالة مقيدة بعين هي أمانة كالوديعة.

١٠- أركان الحوالة: الإيجابُ وَالْقَبُولُ، الإيجابُ مِنَ الْمُحِيلِ، وَالْقَبُولُ مِنَ الْمُحَالِ عَلَيْهِ وَالْمُحَالِ جَمِيعًا، فَأَلِإِجَابُ: أَنْ يَقُولَ الْمُحِيلُ لِلطَّالِبِ: أَحَلَّتْكَ عَلَى فُلَانٍ بَكْذَا، وَالْقَبُولُ مِنَ الْمُحَالِ عَلَيْهِ وَالْمُحَالِ أَنْ يَقُولَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا: قَبِلْتُ أَوْ رَضِيتُ، أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ مِمَّا يَدُلُّ عَلَى الْقَبُولِ وَالرِّضَا.

شروط صحة الحوالة:

١- أن يكون كلٌّ من المحيل، والمحال عليه، والمحال: عاقلًا، بالغًا

٢- أن يكون المحال عليه أملاً - أغنى - من المحيل؛ لأنه بدون ذلك لا يكون للحوالة فائدة.

٣- يشترط لصحة الحوالة: رضا الكل؛ المحيل والمحال عليه والمحال، وهناك من لم يشترط رضا المحال عليه.

٤- أن يكون هناك دين للمحال على المحيل.

٥- أن يكون المحال به معلومًا.

من أَحْكَامِ الْحَوَالََةِ إجمالاً:

١- حُكْمُ الْحَوَالَةِ هُوَ أَنْ يَكُونَ الْمُحِيلُ بَرِيئًا مِنْ دَيْنِهِ وَإِنْ كَانَ لَهُ كَفِيلٌ أَنْ يَبْرَأَ الْكَفِيلُ مِنَ الْكَفَالَةِ.

٢- يَتَبَيَّنُ حَقُّ مُطَالَبَةِ ذَلِكَ الدَّيْنِ مِنَ الْمُحَالِ عَلَيْهِ لِلْمُحَالِ لَهُ.

٣- إِذَا أَحَالَ الْمُحِيلُ بِصُورَةٍ مُطْلَقَةٍ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ دَيْنٌ عِنْدَ الْمُحَالِ عَلَيْهِ يَرْجِعُ الْمُحَالُ عَلَيْهِ بَعْدَ الْأَدَاءِ عَلَى الْمُحِيلِ .

٤- يَنْقَطِعُ فِي الْحَوَالَةِ الْمُقَيَّدَةِ حَقُّ مُطَالَبَةِ الْمُحِيلِ بِالْمُحَالِ بِهِ وَلَيْسَ لِلْمُحَالِ عَلَيْهِ أَنْ يُعْطِيَهُ ، وَإِذَا أَعْطَاهُ يَكُونُ ضَامِنًا .

- من أحكام الحوالة إذا فسخت الحوالة تعود المطالبة إلى المحيل.

٦- لا يشترط لصحة الحوالة أن يكون المحال عليه مدينًا .

أسباب فسخ الحوالة .

١- الإقالة في الحوالة .

٢- أداء المحال عليه مال الحوالة إلى المحال.

٣- إبراء المحال للمحال عليه.

٤- هبة المحال مال الحوالة للمحال عليه وقبوله إياها.

٥- تصدق المحال بمال الحوالة على المحال عليه.

٦- موت المحال عليه قبل الأداء .

٧- أن يموت المحال فيرثه المحال عليه .

أسئلة وتدريبات على الحوالة :

- س ١: ما الحوالة لغة وشرعاً؟ وما أدلة مشروعيتها؟ وما حكمتها؟
- س ٢- بين وجه الاتفاق والاختلاف بين الحوالة والكفالة.
- س ٣- ما أنواع الحوالة عند الحنفية ؟ وما الفرق بينها وبين الإبراء مع التمثيل؟
- س ٤- ما هي الحوالة المقيدة والمطلقة مع التمثيل؟
- س ٥- ما أركان الحوالة عند الحنفية؟ وما الآثار المترتبة عليها؟ وهل يشترط لصحتها أن يكون المحال عليه مديناً للمحيل؟ وما الحكم إذا فسخت؟ وما أسباب فسخها؟
- س ٦- ما هي شروط الحوالة إجمالاً

كتبه

أ.د/ هناء فهمي أحمد عيسى. أستاذ ورئيس قسم الفقه بكلية الدراسات الإسلامية
والعربية للبنات بالمنصورة

د/ أحمد سيد أحمد عبد المقصود الشافعي. مدرس الفقه بكلية الدراسات الإسلامية
والعربية للبنين بالديمامون شرقية

الفصل التاسع الشركة.

وتقع في أربعة مباحث:

المبحث الأول : تعريف الشركة والأصل في جوازها.

المبحث الثاني: أنواع الشركة وأنواع شركة الأملاك وحكمها .

المبحث الثالث: أنواع شركة العُقُود ، وَكَيْفِيَّةُ كُلِّ نَوْعٍ مِنْهَا، وشرائطه وَأَحْكَامُهُ.

المبحث الرابع :أحكام الشركة الفاسدة.

أهداف الدرس:

بدراسة عقد الشركة ينبغي على الطالب أن يستنتج ما يلي:

أولاً : المعلومات والمفاهيم :

التعرف على معنى الشركة لغة وشرعاً وأدلة مشروعيتها.

التعرف على حكم الشركة وحكمة مشروعيتها.

التعرف على أنواع الشركة وشروطها.

التعرف على الآثار المترتبة على فسخ الشركة .

التعرف على أبرز الأحكام الفقهية المتعلقة بالشركة وآراء فقهاء الحنفية فيها

وبيان ذلك بالأمثلة.

ثانياً: المفاهيم الذهنية :

يستطيع الطالب أن يميز بين الشركة الصحيحة والفاسدة.

يحلل الطالب أنواع الشركة.

يستطيع الطالب أن يقوم بالترجيح بناءً على أدلة كل رأي .

يستطيع الطالب أن يتصور الشركة الصحيحة في كل صورة تعرض عليه

المبحث الأول : تعريف الشركة والأصل في جوازها.

أولاً: تعريف الشركة

الشركة في اللغة: الاختلاط. يقال: شاركته في الأمر إذا خالطته فيه (١)..
الشركة اصطلاحاً: عرفها الكاساني بقوله:
"والشركة في الشرع: هي عبارة عن عقد بين المتعاقدين في المال والريح" (٢).
وعرفها السرخسي:
"الشركة عبارة عن الاجتماع في استحقاق أو تصرف" (٣)
وعرفها ابن عابدين
"الشركة عقد بين اثنين فصاعداً، على أن يشتركا في استحقاق أو تصرف" (٤)

ثانياً: الأصل في جوازها.

من القرآن: قوله تعالى:

﴿فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ﴾ (٥)

وقوله تعالى:

﴿وَإِنْ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ﴾ (٦)

استدل بها الحنفية على أصل ثبوت الشركة وجوازها.

من السنة:

حديث النبي ﷺ:

«قال الله تعالى: أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه، فإذا خانهُ خرجت

من بينهما» (٧)

(١) ابن منظور: لسان العرب مادة شرك ج ١٠ ص ٤٤٩ .

(٢) بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، علاء الدين الكاساني (ج ٦ ص ٥٨ ط. دار الكتب العلمية).

(٣) المبسوط، شمس الأئمة السرخسي (ج ١١ ص ١٤١ ط. دار المعرفة).

(٤) رد المحتار على الدر المختار، ابن عابدين ج ٤ ص ٢٩٢.

(٥) من سورة النساء ١١

(٦) من سورة ص ٢٤

(٧) سنن أبي داود (حديث رقم ٣٣٨٣، كتاب البيوع، باب في الشركة).

المستدرک للحاکم (٢/ ٢٨٨) وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه. البيهقي في السنن الكبرى (٦/ ٧٩).

ج- من الإجماع:

نقل السرخسي:

"والناس في الأعصار والأمصار يتعاملون بها من غير نكير، فكان ذلك إجماعاً" (١)

المبحث الثاني : أنواع الشركة وأنواع شركة الأملاك وحكمها .

أولاً : أنواع الشركة .

الشركة نوعان : شركة أملاك ، وشركة عقود.

ثانياً : أنواع شركة الأملاك.

شركة الأملاك على ضربين :

أحدهما: ما كان بفعل الشريكين.

والآخر: يثبت بغير فعلهما.

فأما الذي يثبت بفعلهما فنحو أن يشتري شيئاً، أو يوهب لهما، أو يوصى لهما، أو يتصدق عليهما، فيقبلا فيصير المشتري والموهوب والموصى به والمتصدق به مشتركاً بينهما شركة ملك.

وأما الذي يثبت بغير فعلهما : فال ميراث بأن ورثا شيئاً فيكون الموروث مشتركاً بينهما شركة ملك.

والحكم في الفصلين واحد وهو أن الملك مشترك بينهما ، وكل واحد منهما في نصيب شريكه كالأجنبي لا يجوز له التصرف فيه إلا بإذنه.

المعجم الكبير للطبراني (٢٢ / ٣٢٥). الحكم على الحديث: صححه الحاكم ووافقه الذهبي (انظر: صحيح أبي داود، رقم ٣٣٨٣). حسنه بعض أهل العلم كالمنذري في الترغيب والترهيب (٢ / ٢٢٧). إذن الحديث صحيح أو حسن بشواهد، وهو أصل في مشروعية الشركة، وأن البركة مرهونة بالأمانة والصدق.

(١) (المبسوط، شمس الأئمة السرخسي (ج ١١-ص ١٤٢).

المبحث الثالث : أنواع شركة العقود ، وَكَيْفِيَّةُ كُلِّ نَوْعٍ مِنْهَا ، وشرائطه وأحكامه .

شركة العقود على ثلاثة أوجه :

شركة بالأموال ، وشركة بالأعمال ، وشركة بالوجوه .

وَيَدْخُلُ فِي كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهَا شَرَكَةُ الْعَنَانِ وَشَرَكَةُ الْمُفَاوَضَةِ فَتُذَكَّرُ فِي كُلِّ نَوْعٍ كَيْفِيَّتُهُ وَشَرَائِطُهُ وَأَحْكَامُهُ .

شروط شركة الأموال ، عنانا كانت الشركة أو مُفَاوَضَةً مِنْهَا :

١ . أَنْ يَكُونَ مَالُ الشَّرَكَةِ حَاضِرًا إِمَّا عِنْدَ الْعَقْدِ أَوْ عِنْدَ الشِّرَاءِ وَلَا يَجُوزُ بِمَالٍ غَائِبٍ أَوْ دَيْنٍ فِي الْحَالِينِ لِهَذَا قَالُوا فَيَمَنَ دَفَعَ إِلَى رَجُلٍ أَلْفَ دِرْهَمٍ وَقَالَ اخْرُجْ مِثْلَهَا وَاشْتَرِ بِهَا وَبِعْ فَمَا رِبَحْتَ كَانَ بَيْنَنَا فَأَخْرَجَ أَلْفًا وَاشْتَرَى بِهَا جَارَ وَإِنْ لَمْ يُوْجَدْ الْمَالُ الْمَعِينُ عِنْدَ الْعَقْدِ وَإِنَّمَا وَجَدَ عِنْدَ الشِّرَاءِ ، وَإِنَّمَا كَانَ كَذَلِكَ لِأَنَّ الشَّرَكَةَ لَا تَتِمُّ إِلَّا بِالشِّرَاءِ فَوُجُودُ الْمَالِ عِنْدَهُ كَوُجُودِهِ فِي الْإِبْتِدَاءِ .

٢ . أَنْ يَكُونَ رَأْسُ مَالِ الشَّرَكَةِ أَثْمَانًا مُطْلَقَةً مِنَ الدَّرَاهِمِ وَالْدَنَانِيرِ عِنْدَ أَكْثَرِ الْعُلَمَاءِ وَيَصِحُّ عَقْدُ الشَّرَكَةِ فِيهِمَا بِالْإِجْمَاعِ وَلَوْ كَانَ مِنْ أَحَدِهِمَا دَرَاهِمٌ وَمِنْ الْآخَرِ دَنَانِيرٌ جَازَتْ الشَّرَكَةُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَبِي يُوسُفَ وَمُحَمَّدٍ .

وَعِنْدَ زُفَرٍ : لَا يَجُوزُ .

وَخَلَطَ الْمَالَيْنِ لَيْسَ بِشَرْطٍ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَبِي يُوسُفَ وَمُحَمَّدٍ .

وَعِنْدَ زُفَرٍ : شَرْطٌ .

حكم الشركة بالمكيل والموزون :

المكيل والموزون والعدييات المتقاربة ، لَا تَصِحُّ الشَّرَكَةُ بِهَا قَبْلَ الْخَلْطِ بِالْإِجْمَاعِ ، لِأَنَّهَا لَيْسَتْ بِأَثْمَانٍ عِنْدَ التَّعْيِينِ وَالشَّرَكَةُ لَا تَصِحُّ فِيهَا إِلَّا وَهِيَ ثَمَنٌ وَإِنَّمَا هِيَ أَثْمَانٌ فِي الدِّمَّةِ

أما بعد الخلط :

فَقَالَ أَبُو يُوسُفَ : لَا تَصِحُّ الشَّرَكَةُ وَإِنَّمَا صَارَتْ شَرَكَةً أَمْلاكًا .

وَقَالَ مُحَمَّدٌ : صَحَّتْ الشَّرَكَةُ بِالْخَلْطِ .

وَأَيْمًا يَظْهَرُ الْخِلَافَ فِيهَا إِذَا كَانَ الْمَكِيلُ نِصْفَيْنِ وَقَدْ شَرَطَا أَنْ يَكُونَ الرَّبْحُ أَثَلَاثًا فَخَلَطَاهُ وَاشْتَرِيَا بِهِ.

قَالَ أَبُو يُوسُفَ: الرَّبْحُ عَلَى قَدَرِ الْمَالَيْنِ.

وَقَالَ مُحَمَّدٌ : عَلَى مَا شَرَطَا.

حكم الشركة بالعروض :

الشَّرْكََةُ بِالْعُرُوضِ لَا تَجُوزُ عِنْدَ الْحَنْفِيَّةِ خِلَافًا لِمَالِكٍ ، لِأَنَّ الشَّرْكََةَ تَقْتَضِي الْوَكَالََةَ وَالتَّوَكِيلَ عَلَى الْوَجْهِ الَّذِي تَضُمُّهُ الشَّرْكََةُ لَا يَصِحُّ بِالْعُرُوضِ ، فَإِنَّهُ لَوْ قَالَ لغيره بَعِّ عَرْضِكَ عَلَى أَنْ ثَمَنُهُ بَيْنُنَا لَمْ يَصِحَّ .

وَلَوْ قَالَ لِرَجُلٍ اشْتَرِ بِأَلْفٍ مِنْ مَالِكَ عَلَى أَنْ مَا اشْتَرَيْتَهُ بَيْنُنَا وَأَنَا أَشْتَرِي بِأَلْفٍ مِنْ مَالِي عَلَى أَنْ مَا أَشْتَرِي بَيْنُنَا جَارَ فَلِهَذَا افْتَرَقَا.

وَأَمَّا شَرْكََةُ الْعَنَانِ فَتَفْسِيرُهَا أَنْ يُشَارَكَ صَاحِبُهُ فِي بَعْضِ الْأَمْوَالِ الَّتِي ذَكَرْنَا لَا فِي جَمِيعِ الْأَمْوَالِ ، وَيَكُونُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا وَكِيلًا عَنْ صَاحِبِهِ فِي التَّصَرُّفِ فِي النَّوعِ الَّذِي عِينَا مِنْ أَنْوَاعِ التَّجَارَةِ أَوْ فِي جَمِيعِ أَنْوَاعِ التَّجَارَةِ إِذَا عِينَا ذَلِكَ أَوْ أَطْلَقَا وَبَيِّنَانِ قَدَرِ الرَّبْحِ.

حكم شركة العنان :

شَرْكََةُ الْعَنَانِ جَائِزَةٌ بِلَا خِلَافٍ ، لِأَنَّهَا تَقْتَضِي الْوَكَالََةَ فِي التَّصَرُّفِ عَنْ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا لِمَالِكِهِ وَالتَّوَكِيلَ صَحِيحٌ ، وَلِهَذَا تَجُوزُ هَذِهِ الشَّرْكََةُ بَيْنَ كُلِّ مَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ التَّجَارَةِ مَا دُونَهَا فِيهَا كَالْعَبْدِ الْمَأْدُونِ وَالصَّبِيِّ الْمَأْدُونِ وَالْمَكَاتِبِ وَالذَّمِيِّ كَمَا تَجُوزُ بَيْنَ الْأَخْرَارِ الْبَالِغِينَ الْمُسْلِمِينَ ، لِأَنَّ قَبُولَ الْوَكَالََةِ صَحِيحٌ مِنْهُمْ .

وَيَجُوزُ أَنْ يَشْتَرِطَ الْعَمَلُ عَلَيْهِمَا بَأَنْ اشْتَرَكَا عَلَى أَنْ يَبِيعَا وَيَشْتَرِيَا عَلَى أَنْ مَا رَزَقَ مِنْ ذَلِكَ فَهُوَ بَيْنَهُمَا عَلَى كَذَا وَيَجُوزُ أَنْ يَشْتَرِطَا الْعَمَلَ عَلَى أَحَدِهِمَا دُونَ الْآخَرِ ، فَإِذَا شَرَطَا الرَّبْحَ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ جَارَ بِالْإِجْمَاعِ إِذَا كَانَ رَأْسُ مَالِهِمَا عَلَى السَّوَاءِ سَوَاءَ شَرَطَ الْعَمَلَ عَلَيْهِمَا أَوْ عَلَى أَحَدِهِمَا لِأَنَّ اسْتِحْقَاقَ الرَّبْحِ بِالْمَالِ أَوْ بِالْعَمَلِ وَقَدْ وَجَدَ النَّسَائِيُّ فِي الْمَالِ .

وَأِنْ شَرَطَا الرَّيْحَ بَيْنَهُمَا أَثْلَاثًا فَإِنْ كَانَ الْعَمَلُ عَلَيْهِمَا جَازَ سَوَاءً كَانَ فَضْلُ الرَّيْحِ لِمَنْ كَانَ رَأْسُ مَالِهِ أَكْثَرَ أَوْ أَقَلَّ لِأَنَّهُ يُجُوزُ أَنْ يَكُونَ لَهُ زِيَادَةٌ حَذَاقَةً فَيَكُونُ الرَّيْحُ بِزِيَادَةِ الْعَمَلِ.

وَأِنْ شَرَطَا الْعَمَلَ عَلَى أَحَدِهِمَا فَإِنْ شَرَطَا الْعَمَلَ عَلَى الَّذِي شَرَطَ لَهُ فَضْلُ الرَّيْحِ جَازٌ ، لِأَنَّهُ عَامِلٌ فِي مَالِهِ وَرَبِحُهُ لَهُ وَعَامِلٌ فِي مَالِ شَرِيكِهِ بِبَعْضِ رِبْحِهِ وَالرَّيْحُ يَسْتَحَقُّ بِالْعَمَلِ.

وَأِنْ شَرَطَا الْعَمَلَ عَلَى أَقْلَهُمَا رِبْحًا خَاصَّةً لَا يُجُوزُ ، لِأَنَّهُ شَرَطَ لِلْآخِرِ فَضْلَ رِبْحٍ بِغَيْرِ عَمَلٍ وَلَا ضَمَانٍ ، وَالرَّيْحُ لَا يَسْتَحَقُّ إِلَّا بِمَالٍ أَوْ عَمَلٍ أَوْ ضَمَانٍ وَلَا نَعْنِي بِقَوْلِنَا الْعَمَلَ وَجُودَهُ بَلْ نَعْنِي بِهِ شَرَطَ الْعَمَلِ.

وَإِذَا اشْتَرَكَ الرَّجُلَانِ بِمَالٍ عَلَى أَنْ يَشْتَرِيَا وَيَبِيعَا فَمَا كَانَ مِنَ الرَّيْحِ فَهُوَ بَيْنَهُمَا وَلَمْ يَخْلُطَا الْمَالَ فَضَاعَ مَالُ أَحَدِهِمَا قَبْلَ الشِّرَاءِ فَقَدْ انْتَقَضَتِ الشَّرْكَةُ لِأَنَّ الشَّرْكَةَ تَعَيَّنَتْ فِي الْمَالَيْنِ فَإِذَا هَلَكَ أَحَدُهُمَا قَبْلَ الشِّرَاءِ بَطَلَتِ الشَّرْكَةُ فِيهِ وَبَطَلَتْ فِي الْمَالِ الْآخِرِ ، لِأَنَّ صَاحِبَهُ لَمْ يَرْضَ بِمُشَارَكَةِ شَرِيكِهِ فِيهِ إِلَّا بِشَرَطِ الشَّرْكَةِ فِي مَالٍ وَإِذَا بَطَلَتِ الشَّرْكَةُ فَمَا يَشْتَرِيهِ بِمَالِهِ يَكُونُ لَهُ خَاصَّةً.

وَلَوْ اشْتَرَى بِأَحَدِ الْمَالَيْنِ ثُمَّ هَلَكَ الْمَالُ الْآخِرُ فَمَا اشْتَرَاهُ فَهُوَ بَيْنَهُمَا ، لِأَنَّهُ اشْتَرَاهُ مَعَ بَقَاءِ الشَّرْكَةِ فَلَمَّا اشْتَرَى فَهَلَكَ الْمَالُ بَعْدَهُ لَا يُغَيِّرُ حُكْمَ الْمَلِكِ.

ثُمَّ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْ شَرِيكِي الْعَنَانِ بَعْدَمَا اشْتَرَى بِرَأْسِ الْمَالِ أَعْيَانًا أَنْ يَبِيعَ مَالِ الشَّرْكَةِ بِالنَّقْدِ وَالنَّسِيبَةِ وَيَشْتَرِيَ بِالنَّقْدِ وَالنَّسِيبَةِ ، وَإِنَّمَا أَرَادَ بِالشِّرَاءِ بِالنَّسِيبَةِ فِيمَا إِذَا كَانَ فِي يَدِهِ دَرَاهِمٌ أَوْ دَنَانِيرٌ أَوْ مَكِيلٌ أَوْ مَوْزُونٌ فَاشْتَرَى بِذَلِكَ الْجِنْسِ شَيْئًا ، لِأَنَّ الشَّرِيكَ وَكَيلَ بِالشِّرَاءِ وَالْوَكِيلَ بِالشِّرَاءِ يَمْلِكُ الشِّرَاءَ بِالنَّسِيبَةِ.

فَإِذَا لَمْ يَكُنْ فِي يَدِهِ مَا ذَكَرْنَا وَصَرَّاحَ مَالِ الشَّرْكَةِ كُلِّهِ أَعْيَانًا وَأَمْتَعَةً فَاشْتَرَى بِدَرَاهِمٍ أَوْ دَنَانِيرٍ نَسِيبَةً فَالْمُشْتَرِي لَهُ خَاصَّةٌ دُونَ شَرِيكِهِ ، لِأَنَّهُ لَوْ صَحَّ فِي حَقِّ شَرِيكِهِ صَارَ مُسْتَدِينًا عَلَى مَالِ الشَّرْكَةِ ، وَالشَّرِيكَ شَرْكَةَ عَنَانٍ وَالْمُضَارِبُ لَا يَمْلِكُ الْإِسْتِدَانَةَ إِلَّا أَنْ يُؤْذَنَ لَهُمَا فِي ذَلِكَ.

ولكل واحد منهما أن يبضع ويودع ويوكل بالبيع ويحتال بالثمن ويستأجر ويسافر بمال الشركة عند أبي حنيفة ومحمد في أصح الروايات.

وكذا يقبض ما باع بنفسه ويخاصم فيه ولا يقبض ما باع صاحبه ولا يخاصم فيه إلا إذا قال كل واحد منهما لصاحبه اعمل فيه برأيك فلهما أن يعملوا في ذلك ما كان من التجارة وتوابعها من الرهن والارتهان ودفع المال مضاربة والسفر بالمال في قولهم إلا القرض والهبة والكتابة والتزويج ونحو ذلك لأن هذا من باب التبرع وليس من جنس التجارة.

وأما شركة المفاوضة:

فشرط صحتها أن تكون في جميع التجارات ولا يختص أحدهما بتجارة دون شريكه وأن يكون ما يلزم أحدهما من حقوق ما يتجران فيه لازما للآخر وما يجب لكل واحد منهما يجب للآخر.

ويكون كل واحد منهما فيما وجب لصاحبه بمنزلة الوكيل وفيما وجب عليه بمنزلة الكفيل عنه ويتساويان مع ذلك في رؤوس الأموال في قدرها وقيمتها ويتساويان في الربح فإن تفاوتا في شيء من ذلك لم تكن مفاوضة وكانت عانا فصارت المفاوضة مشتملة على الوكالة والكفالة والتساوي في الربح والمال الذي يقع به الشركة.

ولهذا لا تجوز إلا بين المسلمين الحرين البالغين العاقلين لتساويهما في أهلية الكفالة وأهلية سائر التصرفات بخلاف العبد والصبي والمكاتب والذمي والمجنون.

ثم كل ما يجوز لشريك العنان أن يفعله يجوز للمفاوض أن يفعله أيضا لأن شركة المفاوضة أعم.

ثم كل ما هو شرط في صحة شركة العنان فهو شرط في صحة

المفاوضة وكل ما فسدت به شركة العنان فهو مفسد لشركة المفاوضة.

ويجوز للمفاوض أيضا ما لا يجوز لشريك شركة عنان فمما يختص به المفاوض أن يجوز إقراره بالدين على نفسه وعلى شريكه ويطلب المقر له أيهما شاء ليكون كل واحد منهما كفيلًا عن صاحبه وكذلك كل ما وجب على كل واحد منهما من

دين سائر العقود التي تكون في التجارة من الشراء والبيع والاستتجار وغير ذلك من سائر ما يضمنه أحدهما من الأموال بالغصب والبيع الفاسدة والخلاف في الودائع والعواري والاستهلاكات والإجازات الرهن والارتهان والكفالة بالمال عند أبي حنيفة خلافاً لهما والقبض والخسومة وإقامة البيئة والاستحلاف على العلم والكتابة والإذن في التجارة لعبد الشركة وتزويج الأمة ونحو ذلك.

ولا يجوز أن يعتق شيئاً من عبيد التجارة ، ولا أن يزوجهم .

وإذا اشترى أحدهما طعاماً لأهله أو كسوة أو ما لا يتهم فيه فذلك جائز وهو له خاصة دون صاحبه ، وللبائع أن يطالب بثمن ذلك أيهما شاء إلا أنهم قالوا إن الشريك يرجع على شريكه بنصف ثمن ذلك ، لأنه قضى دينه من ماله بإذنه دلالة.

وأما الشركة بالوجوه فإن يشترك الرجلان ولا مال لهما على أن يشتريا ويبيعا بوجوههما ، على أن ما اشترى أو اشترى أحدهما فهو بينهما نصفان وسميت شركة الوجوه ، لأنه لا يشتري بالنسيئة إلا من له وجه عند الناس .

حكم الشركة بالوجوه:

الشركة بالوجوه : عقد جائز عند الحنفية خلافاً للشافعي لتعامل الناس في الأعصار من غير تكير .

ثم كيفما شرطاً وفُوع الملك في المشتري بينهما إما نصفان أو كان لأحدهما أكثر فهو جائز ويقع الملك بينهما كذلك ويكون الربح على قدر ملكهما ولا يجوز أن يفضل أحدهما على ربح حصته شيئاً لأن الربح يستحق في هذه الشركة بالضمان لا بالمال والعمل والضمان على قدر الحصة فيكون الربح كذلك إذ لو شرط زيادة الربح ، فإنه يشترط من غير عمل ومال وضمان وهذا لا يجوز .

ثم هما في جميع ما يجب لهما وما يجب عليهما وما يجوز فيه فضل أحدهما على شريكه وما لا يجوز بمنزلة شريكي العنان ، لأنهما أطلقا الشركة والشركة المطلقة تقتضي العنان فإذا اشتركا بوجوههما شركة مفاوضة فذلك جائز لأنهما ضما إلى الوكالة المطلقة الكفالة وذلك جائز إلا أنه لا بد من التساوي فيما يتبايعانه لأن المفاوضة تمنع من التفاضل .

وَأَمَّا الشَّرْكَةُ بِالْأَعْمَالِ فَهِيَ تَسْمَى شَرْكَةَ الصَّنَائِعِ وَتَسْمَى شَرْكَةَ الْأَبْدَانِ ، لِأَنَّ الْعَمَلَ بِالْبَدَنِ هُوَ أَنْ يَشْتَرِكَ اثْنَانِ فِي عَمَلِ الْقَصَارَةِ وَالصَّبَاغَةِ عَلَى أَنْ يَتَقَبَّلَا الْأَعْمَالَ وَيَعْمَلَا فَمَا أَخَذَا مِنَ الْأَجْرِ فَهُوَ بَيْنَهُمَا .

حكم شركة الأعمال:

جَائِزَةٌ عِنْدَ الْحَنْفِيَّةِ ، خِلَافًا لِلشَّافِعِيِّ ، وَهِيَ مِمَّا جَرَى بِهِ التَّعَامُلُ فِي جَمِيعِ الْأَعْصَارِ .

ثُمَّ هِيَ قَدْ تَكُونُ مُفَاوَظَةً وَقَدْ تَكُونُ عَنَانًا .

فَالْمُفَاوَظَةُ مَا ذَكَرْنَا فِيهِ لَفْظَةُ الْمُفَاوَظَةِ أَوْ ذَكَرْنَا مَا هُوَ فِي مَعْنَى الْمُفَاوَظَةِ بِأَنْ اشْتَرَطَ الصَّانِعَانِ عَلَى أَنْ يَتَقَبَّلَا جَمِيعًا الْأَعْمَالَ وَأَنْ يَضْمَنَا جَمِيعًا الْعَمَلَ عَلَى التَّسَاوِي وَأَنْ يَتَسَاوَيَا فِي الرِّبْحِ وَالْوَضِيعَةِ وَأَنْ يَكُونَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا كَفِيلًا عَنِ صَاحِبِهِ فِيمَا لِحَقِّهِ بِسَبَبِ هَذِهِ الشَّرْكَةِ فَهِيَ مُفَاوَظَةٌ .

وَأِنْ شَرَطَا عَلَى أَنْ مَا قَبْلًا مِنَ الْأَعْمَالِ وَضْمَنَا الْعَمَلَ فَعَلَى أَحَدِهِمَا التُّنْثَانُ مِنَ الْعَمَلِ وَعَلَى الْآخَرِ التُّلْثُ وَالْآخَرُ وَالْوَضِيعَةُ عَلَى قَدَرِ ذَلِكَ فَهَذَا شَرْكَةُ عَنَانٍ لَوْجُودِ مَعْنَى شَرْكَةِ الْعَنَانِ ، وَكَذَا إِذَا ذَكَرْنَا لَفْظَةَ الْعَنَانِ ، وَكَذَا لَوْ أَطْلَقْنَا فَهِيَ شَرْكَةُ عَنَانٍ أَيْضًا اسْتِحْسَانًا لِأَنَّهُمَا جَمِيعًا قَبْلًا الْأَعْمَالَ وَضْمَنَا تَسْلِيمَ ذَلِكَ إِلَى صَاحِبِهِ فَيَكُونُ ذَلِكَ جَارِيًا مَجْرَى الْمُفَاوَظَةِ فِي أَنْ الْعَمَلَ عَلَيْهِمَا وَلِصَاحِبِ الْعَمَلِ أَنْ يُطَالِبَ بِالْعَمَلِ أَيُّهُمَا شَاءَ وَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا أَنْ يُطَالِبَ بِأُجْرَةِ الْعَمَلِ وَإِلَى أَيُّهُمَا دَفَعَ صَاحِبُ الْعَمَلِ بَرَاءً وَعَلَى أَيُّهُمَا وَجِبَ ضَمَانُ الْعَمَلِ فَكَانَ لِصَاحِبِ الْعَمَلِ أَنْ يُطَالِبَ الْآخَرَ وَلَكِنْ لَا تَكُونُ مُفَاوَظَةً حَقِيقَةً مَا لَمْ تَذَكَرْ لَفْظَةَ الْمُفَاوَظَةِ أَوْ يُوجَدَ مَعْنَاهَا وَهُوَ مَا ذَكَرْنَا حَتَّى قَالُوا فِي الدِّينِ إِذَا أَقَرَّ بِهِ أَحَدُهُمَا مِنْ ثَمَنِ صَابُونَ أَوْ أَشْنَانُ أَوْ أَجْرُ أَجِيرٍ أَوْ حَانُوتٌ قَدْ مَضَى فَإِنَّهُ لَا يَصْدُقُ عَلَى صَاحِبِهِ إِلَّا بِإِقْرَارِهِ أَوْ بِبَيِّنَةٍ قَامَتْ عَلَيْهِ وَيَسْتَوِي أَنْ تَكُونَ الشَّرْكَةُ فِي نَوْعِ عَمَلٍ فَيَعْمَلَانِ ذَلِكَ أَوْ يَعْمَلُ أَحَدُهُمَا عَمَلًا وَالْآخَرُ غَيْرَ ذَلِكَ أَوْ لَمْ يَعْمَلْ بَعْدَ أَنْ ضَمْنَا جَمِيعًا الْعَمَلَيْنِ جَمِيعًا لِأَنَّ الْإِنْسَانَ قَدْ يَعْمَلُ بِنَفْسِهِ وَأَجِيرُهُ .

فَإِنْ عَمِلَ أَحَدُهُمَا دُونَ الْآخَرِ وَالشَّرَكَةُ عَنَانٌ أَوْ مُفَاوَضَةٌ فَالْأَجْرُ بَيْنَهُمَا إِنْ شَرَطَا الْعَمَلَ عَلَيْهِمَا وَالتَّزَمَا ذَلِكَ فَيَكُونُ أَحَدُهُمَا مَعِينًا لِلْآخَرِ كَالْقَصَارِ إِذَا اسْتَعَانَ بِرَجُلٍ فِي الْقَصَارَةِ.

وَكَذَلِكَ إِذَا شَرَطَا لِأَحَدِهِمَا زِيَادَةَ أَجْرٍ أَوْ شَرَطَا الْعَمَلَ عَلَى قَدْرِ الْأَجْرِ وَالْوَضِيعَةُ كَذَلِكَ فَهُوَ جَائِزٌ وَإِنْ كَانَ عَمَلُ الَّذِي شَرَطَ لَهُ الْأَجْرَ الْقَلِيلَ أَكْثَرَ لِأَنَّ الرِّبْحَ بِقَدْرِ ضَمَانِ الْعَمَلِ لَا بِحَقِيقَةِ الْعَمَلِ.

وَإِنْ شَرَطَا الْوَضِيعَةَ نِصْفَيْنِ لَا يَصِحُّ وَيَبْطُلُ وَتَكُونُ الْوَضِيعَةُ عَلَى مَا شَرَطَا مِنْ ضَمَانِ الْعَمَلِ وَالْأَجْرُ كَذَلِكَ.

وَلَوْ جَنَّتْ يَدُ أَحَدِهِمَا فَالضَّمَانُ عَلَيْهِمَا جَمِيعًا لِأَنَّ ذَلِكَ بِنَاءٌ عَلَى ضَمَانِ الْعَمَلِ وَقَدْ ضَمْنَا جَمِيعًا.

المبحث الرابع: أحكام الشَّرَكَةِ الْفَاسِدَةِ.

الشَّرَكَةُ الْفَاسِدَةُ.

وَهِيَ أَنْوَاعٌ مِنْهَا:

١ . الإِشْتِرَاكُ فِي جَمِيعِ الْمُبَاحَاتِ الَّتِي تَمْلِكُ بِالْأَخْذِ مِثْلَ الْإِصْطِيَادِ وَالِاحْتِطَابِ وَالِاحْتِشَاشِ وَالِاسْتِقَاءِ وَاجْتِنَاءِ الثَّمَارِ وَحَفْرِ الْمَعَادِينِ.

فَإِنْ اشْتَرَكَا عَلَى أَنْ مَا أَصَابَا مِنْ ذَلِكَ فَهُوَ بَيْنَهُمَا فَالشَّرَكَةُ فَاسِدَةٌ ، وَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مَا أَخَذَهُ لِأَنَّ الشَّرَكَةَ تَقْتَضِي الْوَكَالََةَ وَالْوَكَالََةُ فِي الْإِصْطِيَادِ وَنَحْوِهِ لَا تَصِحُّ وَإِذَا فَسَدَتْ فَالْأَخْذُ سَبَبُ الْمَلِكِ فَيَكُونُ مِلْكًا لَهُ، ثُمَّ يَنْظُرُ إِنْ أَخَذَا جَمِيعًا مَعًا فَهُوَ بَيْنَهُمَا لِاسْتِوَائِهِمَا فِي سَبَبِ الْمَلِكِ وَإِنْ أَخَذَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا شَيْئًا بِإِنْفِرَادِهِ وَخَلَطَاهُ وَبَاعَاهُ فَإِنْ كَانَ مِمَّا يُكَالُ وَيُوزَنُ يَقْسَمُ الثَّمَنُ عَلَى قَدْرِ الْكِيلِ وَالْوُزْنِ الَّذِي لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا وَإِنْ كَانَ مِمَّا لَا يُكَالُ وَلَا يُوزَنُ يَقْسَمُ الثَّمَنُ بَيْنَهُمَا بِالْقِيَمَةِ فَيَأْخُذُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِقِيَمَةِ الَّذِي لَهُ وَإِنْ لَمْ يَعْرِفِ الْكِيلُ وَالْوُزْنُ وَالْقِيَمَةُ يَصْدُقُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا فِيمَا يَدْعِي إِلَى النِّصْفِ وَإِنْ ادَّعَى أَكْثَرَ مِنَ النِّصْفِ فَعَلَيْهِ الْبَيِّنَةُ.

وَإِنْ عَمِلَ أَحَدُهُمَا وَأَعَانَهُ الْآخَرُ فِي عَمَلِهِ فَلَهُ أَجْرُ الْمِثْلِ بِالْغَا مَا بَلَغَ عِنْدَ مُحَمَّدٍ .

وَعِنْدَ أَبِي يُوسُفَ: لَهُ أَجْرٌ مِثْلُهُ لَا يُجَاوِزُ بِهِ نِصْفَ الْمُسَمَّى أَوْ قِيَمَتَهُ أَيْ نِصْفَ ذَلِكَ الشَّيْءِ الَّذِي أَعَانَهُ فِيهِ أَوْ قِيَمَتَهُ ، كَمَا قَالَ لِأَخْرَجَ بَعْضُ هَذَا الثَّوْبِ عَلَى أَنْ نِصْفَ ثَمَنِهِ لَكَ ، فَإِنَّهُ يَجِبُ أَجْرُ الْمِثْلِ مُقَدَّرًا بِنِصْفِ ذَلِكَ الثَّمَنِ .

٢ . أَنْ يَكُونَ لِأَحَدِهِمَا بَغْلٌ وَلِلْآخَرِ حِمَارٌ فَاشْتَرَا عَلَى أَنْ يَأْجُرَا ذَلِكَ فَمَا رَزَقَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ فَبَيْنَهُمَا ، فَأَجْرَاهُمَا جَمِيعًا بِأَجْرِ مَعْلُومٍ فِي عَمَلٍ مَعْلُومٍ وَحَمْلٍ مَعْلُومٍ ، فَإِنْ هَذِهِ الشَّرَكَةُ فَاسِدَةٌ ، لِأَنَّ الْوَكَالَةَ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ لَا تَصِحُّ بِأَنْ قَالَ الْآخَرُ أَجْرُ بَعِيرِكَ عَلَى أَنْ أَجْرَهُ بَيْنَنَا فَإِنَّهُ فَاسِدٌ فَكَذَا الشَّرَكَةُ .

وَإِذَا فَسَدَتِ الشَّرَكَةُ فَأَلْجَاةٌ صَحِيحَةٌ لَوُقِوعُهَا عَلَى مَنَافِعِ مَعْلُومَةٍ بِبَدَلِ مَعْلُومٍ فَيَقْسِمَانِ مَا أَخَذَا مِنَ الْأَجْرِ عَلَى قَدَرِ أَجْرِ مِثْلِ الْبُغْلِ وَالْحِمَارِ .

٣ . أَنَّهُ لَوْ دَفَعَ إِلَى رَجُلٍ دَابَّةً لِيَأْجُرَهَا عَلَى أَنْ الْأَجْرَ بَيْنَهُمَا كَانَ ذَلِكَ فَاسِدًا ، وَالْأَجْرَ لِمُتَصَلِّحِ الدَّابَّةِ وَكَذَلِكَ السَّفِينَةِ ، وَالذَّارِ ، لِأَنَّهُ عَقْدٌ عَلَى مَلِكٍ الْغَيْرِ بِإِذْنِهِ وَيَجِبُ أَجْرُ الْمِثْلِ ، لِأَنَّهُ اسْتَوْفَى مَنَفَعَةً بِعَقْدٍ فَاسِدٍ .

وَنَوْعٌ آخَرُ رَجُلٍ اشْتَرَى شَيْئًا فَقَالَ لَهُ الْآخَرُ أَشْرَكْنِي فِيهِ ، فَهَذَا بِمَنْزِلَةِ الْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ بِمِثْلِ مَا اشْتَرَى فِي النِّصْفِ وَالتَّوَلِيَةِ أَنْ يَجْعَلَ كُلُّهُ لَهُ بِمِثْلِ مَا اشْتَرَى عَلَى مَا مَرَّ فِي كِتَابِ الْبَيْعِ ، فَإِنْ كَانَ قَبْلَ أَنْ يَقْبِضَ الْأَوَّلُ لَمْ يَجِزْ ، لِأَنَّهُ بَيْعُ الْمُبِيعِ الْمُنْقُولِ قَبْلَ الْقَبْضِ وَإِنْ كَانَ بَعْدَهُ جَازَ وَيُلْزَمُهُ نِصْفُ الثَّمَنِ ، فَإِنْ كَانَ لَا يَعْلَمُ بِمِقْدَارِ الثَّمَنِ فَهُوَ بِالْخِيَارِ إِذَا عَلِمَ إِنْ شَاءَ أَخَذَ وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ .

وَلَوْ اشْتَرَى رَجُلَانِ عَبْدًا فَأَشْرَكَ فِيهِ رَجُلًا بَعْدَ الْقَبْضِ فَالْقِيَاسُ أَنْ يَكُونَ لِلشَّرِيكَ النِّصْفُ ، لِأَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا لَوْ أَشْرَكَهُ فِي نَصِيبِهِ عَلَى الْإِنْفِرَادِ اسْتَحَقَّ نِصْفَهُ فَكَذَا إِذَا أَشْرَكَاهُ جَمِيعًا مَعًا ، وَفِي الْإِسْتِحْسَانِ يَكُونُ لَهُ الثُّلُثُ لِأَنَّ الشَّرَكَةَ تَقْتَضِي الْمُسَاوَاةَ فَإِذَا قَالَا لَهُ أَشْرَكَكَ فِيهِ فَكَأَنَّهُمَا قَالَا شَارَكَكَ .

فَإِنْ أَشْرَكَ أَحَدُهُمَا فِي نَصِيْبِهِ وَنَصِيْب صَاحِبِهِ فَأَجَازَ شَرِيْكَهٗ ذَٰلِكَ كَانَ لِلدَّخْلِ
النَّصْفِ وَلِلْأَوَّلَيْنِ النِّصْفُ ، لِأَنَّهُ لَمَّا أَجَازَ شَرِيْكَهٗ فِي نَصِيْبِهِ صَارَ نَصْفُ نَصِيْبِهِ لَهُ
وَقَدْ أَشْرَكَهٗ فِي نَصِيْبِ نَفْسِهِ هَٰذَا فَيَكُونُ لِلثَّانِي النِّصْفُ وَبَقِيَ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا الرَّبْعُ (١)
جاء في مختصر القدوري

الشركة على ضربين: شركة أملاك وشركة عقود
فشركة الأملاك: العين يرثها رجلان أو يشتريانها فلا يجوز لأحدهما أن ينصرف
في نصيب الآخر إلا بإذنه وكل واحد منهما في نصيب صاحبه كالأجنبي
والضرب الثاني: شركة العقود

وهي على أربعة أوجه: مفاوضة وعنان وشركة الصنائع وشركة الوجوه
فأما شركة المفاوضة فهي: إن يشتري الرجلان فيستويان في مالهما وتصرفهما
ودينهما فتجوز بين الحرين المسلمين العاقلين البالغين ولا تجوز بين الحر والمملوك ولا
بين الصبي والبالغ ولا بين المسلم والكافر وتتعد على الوكالة والكفالة
وما يشتريه كل واحد منهما يكون على الشركة إلا طعام أهله وكسوتهم وما يلزم كل
واحد منهما من الديون بدلا عما يصح فيه الاشتراك فالآخر ضامن له فإن ورث
أحدهما مالا تصح فيه الشركة أو وهب له ووصل إلى يده بطلت المفاوضة وصارت
الشركة عنانا

ولا تتعد الشركة إلا بالدرهم والدنانير والفلوس
النافقة ولا يجوز بما سوى ذلك إلا أن يتعامل الناس بها كالتبر والنقرة فتصح
الشركة بهما وإذا أرادا الشركة بالعروض باع كل واحد منهما نصف ماله بنصف مال
الآخر ثم عقدا الشركة

وأما الشركة العنان: فتتعد على الوكالة دون الكفالة ويصح التفاضل في المال
ويصح أن يتساويا في المال ويتفاضلا في الربح

(١) السرخسي: المبسوط ج ١١ ص ١٥١ ، السمرقندي: تحفة الفقهاء ج ٣ ص ٥ - ١٧ ، الكاساني: بدائع الصنائع
ج ٦ ص ٥٦ وما بعدها .

ويجوز أن يعقدها كل واحد منهما ببعض ماله دون بعض ولا تصح إلا بما بينا أن
المفاوضة تصح به

ويجوز أن يشتركا ومن جهة أحدهما دراهم ومن جهة الآخر دنانير وما اشتراه كل
واحد منهما للشركة طوبى بثمانه دون الآخر ثم يرجع على شريكه بحصته منه
وإذا هلك مال الشركة أو أحد المالكين قبل أن يشتريا شيئا بطلت الشركة وإن اشترى
أحدهما بماله وهلك مال الآخر قبل الشراء فالمشتري بينهما على ما شرطا
ويرجع على شريكه بحصته من ثمنه

وتجوز الشركة وإن لم يخطا المالكين ولا تصح الشركة إذا شرطا لأحدهما دارهم
مسماة من الربح

ولكل واحد من المتفاوضين وشريكي العنان أن يبضع المال ويدفعه مضاربة ويوكل
من يتصرف فيه ويده في المال يد أمانة

وأما شركة الصنائع فالخياطان والصباغان يشتركان على أن يتقبلا الأعمال ويكون
اكسب بينهما فيجوز ذلك وما يتقبله كل واحد منهما من العمل يلزمه ويلزم شريكه
فإن عمل أحدهما دون الآخر فالكسب بينهما نصفان

وأما شركة الوجوه: فالرجلان يشتركان ولا مال لهما على أن يشتريا بوجهيهما ويبيعا
فتصح الشركة على هذا وكل واحد منهما وكيل الآخر فيما يشتريه فإن شرطا أن يكون
المشتري بينهما نصفين فالربح

كذلك ولا يجوز أن يتفاضلا فيه وإن شرطا أن يكون المشتري بينهما أثلاثا فالربح
كذلك

ولا تجوز الشركة في الاحتطاب والاحتشاش والاصطياد وما اصطاده كل واحد
منهما أو احتطبه فهو له دون صاحبه

وإذا اشتركا ولأحدهما بغل وللآخر رواية يستقي عليها الماء والكسب بينهما لم تصح
الشركة والكسب كله للذي استقى وعليه أجر مثل الراوية إن كان صاحب البغل وإن
كان صاحب الراية فعليه أجر مثل البغل

وكل شركة فاسدة فالربح فيها على قدر المال ويبطل شرط التفاضل

وإذا مات أحد الشريكين أو ارتد ولحق بدار الحرب بطلت الشركة وليس لواحد من الشريكين أن يؤدي زكاة مال الآخر إلا بإذنه فإن أذن كل واحد منهما لصاحبه أن يؤدي زكاته فأدى كل واحد منهما فالثاني ضامن علم بأداء الأول أو لم يعلم (١).

أسئلة وتدريبات

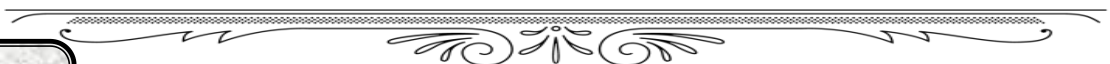
- س ١: عرف الشركة لغة واصطلاحاً، مبيناً أدلة مشروعيتها.
- س ٢: بين الحكم التكليفي للشركة، وما حكمة مشروعيتها
- س ٣: ما أنواع الشركة؟ وما أنواع شركة الأملاك مع التمثيل؟
- س ٤: ما أنواع شركة العقود مع التوضيح لكل نوع بمثال .
- س ٥: ما مسميات شركة الأعمال وما حكم شركة الأعمال ؟ وما شروط شركة الأموال عاننا كانت الشركة أو مفاوضة؟
- س ٦: ما شروط صحة شركة المفاوضة .
- س ٧: بين بعض صور الأحكام الفقهية المترتبة على فساد الشركة مع التوضيح بالأمثلة قدر الإمكان .

كتبه

أ.د/ هناء فهمي أحمد عيسى. أستاذ ورئيس قسم الفقه بكلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالمنصورة

د/ أحمد سيد أحمد عبد المقصود الشافعي. مدرس الفقه بكلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنين بالديمامون شرقية

(١) . مختصر القدوري ص ١٠١ وما بعدها



الفصل العاشر : عقد المزارعة

ويقع في ست مباحث:

المبحث الأول : تعريف عقد المزارعة وحكمها.

المبحث الثاني: ركن المزارعة وشروطها.

المبحث الثالث : أنواع المزارعة .

المبحث الرابع : الأثر المترتب على المزارعة الصحيحة.

المبحث الخامس : مفسدات عقد المزارعة والأثر المترتب عليها.

المبحث السادس : فسخ عقد المزارعة والأثر المترتب عليها.

أهداف الدرس :

بدراسة عقد المزارعة ينبغي على الطالب أن يستنتج ما يلي:

أولاً : المعلومات والمفاهيم :

التعرف على معنى المزارعة لغة وشرعاً وأدلة مشروعيتها.

التعرف على حكم المزارعة وحكمة مشروعيتها.

التعرف على ركن المزارعة وشروطها وصور المزارعة.

التعرف على الآثار المترتبة على انعقاد المزارعة وفسخها.

التعرف على أبرز الأحكام الفقهية المتعلقة بالمزارعة وآراء فقهاء الحنفية فيها

وبيان ذلك بالأمثلة.

ثانياً: المفاهيم الذهنية :

يستطيع الطالب أن يميز بين المزارعة الصحيحة والفاصلة.

يحلل الطالب لكل بيان طرق انعقاد المزارعة.

يستطيع الطالب أن يقوم بالترجيح بناءً على أدلة كل رأي .

يستطيع الطالب أن يتصور المزارعة الصحيحة في كل صورة تعرض عليه

المبحث الأول : تعريف عقد المزارعة وحكمها

تعريف المزارعة :

المزارعة في اللغة : مفاعلة من الزرع وهو الإنبات (١) .وتسمى مخابرة ومحاكلة .
وأما تسميتها مخابرة : فمن فعله صلى الله عليه وسلم بأرض خبير ، وأما تسميتها محاكلة: فلاشتقاقها من الحقل وهو الزرع قبل أن يغلط سوقه ، وقيل: الحقل الأرض الطيبة الخالصة من شائبة السبخ الصالحة للزراعة(٢).

ومما تجدر الإشارة إليه أن الإنبات المضاف إلى العبد معناه : مباشرة فعل أجرى الله - سبحانه وتعالى - العادة بحصول النبات عقيبه لا بتخليقه وإيجاده ، فلا تعارض بين هذا وبين قوله - سبحانه وتعالى " أَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ "(٣).

المزارعة في الشرع:

عبارة عن العقد على المزارعة ببعض الخارج بشرائطه الموضوعة له شرعاً(٤).

وعلى هذا فالمزارعة نوع من الشركة لأن أسمها مشتق من المفاعلة وهي لا تتحقق بالإفراد ، وإنها لا بد من المشاركة .

وقولنا في التعريف الشرعي: " ببعض الخارج " قيد في التعريف فلا توجد المزارعة بالمعنى الشرعي إلا إذا اشتركا - رب الأرض والمزارع - بالخارج من هذه الأرض، أما إذا لم يشتركا بالخارج فإن كان الخارج كله لرب الأرض فهذا ليس بمزارعة، وإنما يعد استعانة من صاحب الأرض بالمزارع، وكأن جهد المزارع تبرع منه. وإن كان الخارج كله للعامل ، المزارع - فهذا أيضا ليس مزارعة وإنما يعد إعارة من المالك للعامل ، فالعامل كأنه استعار تلك الأرض وقام بزراعتها بنفسه .

ومن خلال هذا التعريف يمكن القول أن الفرق بين المزارعة والإجارة واضح ، وهو:

(١) (المعجم الوجيز مادة " زرع " .

(٢) (الاختيار (٣٤٩/٢) ط/ قطاع المعاهد الأزهرية.

(٣) (سورة الواقعة . الآية "٦٤".

(٤) (بدائع الصنائع (٣٨٠٧/٨) ، مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر (٢/ ٤٩٨ ، ٤٩٩) .

إن المزارعة عبارة عن دفع الأرض إلى من يزرعها أو يعمل عليها والزرع بينهما، فهي شركة في الخارج بغض النظر عن مقداره.

وأما الإجارة: فهي تمليك المنافع بعوض ، ولا تصح إلا إذا كانت المنافع معلومة والأجرة معلومة أيضا، وأما الخارج من الأرض فلا علاقة للمالك - المؤجر - فليس له إلا أجرته سواء أنتجت الأرض أم لم تنتج ، طالما ثبت أن ضعف الإنتاج أو عدمه ليس بسبب راجع إلى الأرض ، أو بسبب راجع إلى الأرض ، لكن علم به المستأجر ورضي به لاعتبارات أخرى عنده كما هو مدون في باب الإجارة .

والذي يعنينا هنا هو أن المنفعة التي تعود إلى المستأجر لا بد وأن تكون معلومة الزمان حتى لا يوجد نزاع بين المالك والمستأجر .

والأجرة أيضا لا بد وأن تكون معلومة للمالك ، وأما المزارعة فعلى عكس الإجارة فلا تصح إلا إذا كان الخارج شائعا بينهما تحقيقا لمعنى المشاركة ، فإن شرط لأحدهما مقدار معين فهي باطلة .

هذا ولا يخفى تصور حقيقة المفاعلة في باب المزارعة بين المالك والعامل - المزارع - لأن الإنبات المتصور من العبد هو التسبب لحصول النبات كما ذكرت سابقا

وهذا الفعل وهو التسبب يوجد من كل واحد منهما ، فالتسبب من قبل المالك يحصل بالتمكين بأن يمكن العامل من الأرض ويعطيه الآلات والأسباب التي لا يحصل العمل بدونها عادة .

والتسبب من قبل العامل يحصل بالعمل .

فكان كل منهما - المالك والعامل - مزارعا حقيقة ؛ لوجود فعل الزرع منه بطريق التسبب، إلا أن العامل اختص بهذا الاسم في العرف (١) .

حكم المزارعة :

(١) بدائع الصنائع (٣٨٠٨/٨) .

عقد المزارعة من العقود المختلف في شرعيتها بين الفقهاء ، وسبب الاختلاف هو تعارض الأخبار والآثار في المزارعة :

فلقد جاء في جواز المزارعة : أن عبد الله بن عمر - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم : " عامل أهل خيبر على شطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع (١) فكان يعطي أزواجه مائة وسق (٢) ثمانون وسق من تمر وعشرون من شعير ". وقسم عمر خيبر فخير أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم - " أن يقطع لهن من الماء والأرض أو يمضي لهن ، فمنهن من اختارت الأرض ، ومنهن من اختارت الوسق ، وكانت عائشة ممن اختارت الأرض " (٣).

ومن هذا الحديث يتضح قول من جوز المزارعة ويعتبر هذا الحديث دليلا على مشروعيتها بطريق السنة التقريرية ، وهي إقرار النبي - صلى الله عليه وسلم - لذلك واستمرار هذا النظام من المزارعة على عهد سيدنا أبي بكر - رضي الله عنه - إلى أن أجلاهم عنها سيدنا عمر - رضي الله عنه .

هذا ولقد جاء في النهي عن المزارعة : ما روي عن عبد الله بن السائب قال : "دخلنا على عبد الله بن معقل فسألناه عن المزارعة ، فقال : زعم ثابت بن الضحاك أن رسول الله ﷺ نهى عن المزارعة وأمر بالمؤاجرة وقال : لا بأس بها " .

وبعد بيان سبب الاختلاف في مشروعية المزارعة ، أعرض الآراء على النحو التالي :

الرأي الأول : للإمام أبي حنيفة ومعه في هذا الإمام الشافعي - رحمهما الله - حيث قالوا : إن المزارعة غير مشروعة .

(١) (أخرجه البخاري في صحيحه كتاب المزارعة برقم " 2329 " . أخرجه مسلم في صحيحه كتاب المساقاة برقم " ١٥٥١ " .) ;

(٢) (الوسق : هو مكيال مقداره ستون صاعا ، والصاع خمسة أرتال وثلاث . المعجم الوجيز . مادة " وسق " ، والرتل في مصر اثنا عشرة أوقية ، والأوقية اثنا عشر درهما . المرجع السابق مادة " رطل " . والوسق ستون صاعا إذن الوسق ١٢٢ كيلوجرام تقريباً عند جمهور الفقهاء من القمح أو ما يقاربه في الكثافة . (المكاييل والموازين الشرعية دعلى جمعة ص ٢٣٧ ط : دار الكتب العلمية)

(٣) (أخرجه البخاري في صحيحه برقم " ٢٣٢٨ " .)

واستدل للإمام أبي حنيفة : بأن عقد المزارعة استتجار ببعض الخارج ، وهذا منهي عنه بالنص والمعقول :

أما النص : فما روي عن رسول الله ﷺ أنه قال لرافع بن خديج في حائط : " لا تستأجره بشيء منه " (١).

وروي عنه ﷺ أيضا: " أنه نهى عن قفيز الطحان " (٢) (٣) ، وهو أن يستأجر رجلا ليطحن له حنطة بقفيز من دقيقها .

والاستتجار ببعض في معناه فهو منهي عنه ، والمنهي عنه غير مشروع هذا من جهة النهي عن المزارعة بالنص .

وأما النهي من جهة المعقول : فهو أن الاستتجار ببعض الخارج من النصف والثلث والربع ونحوه استتجار ببذل مجهول ، وأنه لا يجوز كما في الإجارة (٤) .

الرأي الثاني : لصاحبي الإمام أبي حنيفة - الإمامان أبي يوسف ومحمد - رحمهما الله - حيث قالوا : المزارعة جائزة .

(١) (أخرج الطبراني في المعجم الكبير برقم (٤٣٥٤) .

(٢) (قفيز الطحان " مصطلح فقهي قديم جاء في أحاديث النهي عن بعض صور الإجارة والمعاملات .

المعنى

القفيز: مكيال كان يُستخدم في زمن العرب لوزن أو كيل الحبوب، يختلف مقداره باختلاف البلدان. (النهاية في غريب الحديث ابن الأثير، (١٩/٤).

قفيز الطحان: أن يتفق صاحب الحبوب مع الطحان (الذي يطحن الحبوب) على أن يكون أجره جزءًا من الدقيق الناتج، بمقدار قفيز معين. (شرح صحيح مسلم للنووي (٢٢٨/١٠).

سبب النهي:

نهى النبي ﷺ عن "قفيز الطحان" لأن فيه جهالة وربما ظلماً، إذ لا يُعرف بالضبط كم سيخرج من الدقيق بعد الطحن، وقد يختلف الناتج حسب جودة الحبوب، فيؤدي ذلك إلى غرر أو نزاع.

فالطحان قد يأخذ أجره أكثر أو أقل من العدل، بخلاف الأجرة المحددة بالمال أو الكيل المعلوم سلفاً.

القاعدة الفقهية:

النهي هنا يُحمل على المنع إذا كانت الأجرة جزءًا من الناتج المجهول، لكن لو كانت الأجرة معلومة بالكيل أو الوزن من غير الناتج فلا بأس. المغني ابن قدامة (٣٢١/٥).

(٣) (أخرج البيهقي في السنن الكبرى (٣٣٩/٥) برقم (١٠٦٣٦) .

(٤) (بدائع الصنائع (٣٨٠٨/٨) .

واستدلا لذلك بحديث خبير السابق ذكره قريبا عند بيان سبب الاختلاف ، وهذا من جهة النص .

وأما من جهة العقل ، فهو : أن المزارعة عقد شركة بين المالك والعامل فيجوز اعتبارا بالمزارعة .

جدير بالذكر : أن الإمام أبي حنيفة يرى أن حديث خبير ليس في جواز المزارعة ، وإنما هو محمول على الجزية ، والدليل على أنه لا يمكن حمله على المزارعة أنه - ﷺ - قال فيه : " أقركم ما أقركم الله " وهذا منه - ﷺ - تجهيل المدة وجهالة المدة تمنع صحة المزارعة بلا خلاف (١)

ورغم تطرق هذا التوجيه من الإمام أبي حنيفة إلى ما استدل به صاحبان إلا أن الفتوى في المذهب في هذا الموضع على قولهما لسببين رئيسيين هما من أصول المذهب الحنفي :

حاجة الناس الماسة إلى ذلك، وبقاء ترك الإنكار على التعامل في حديث خبير السابق .

ظهور تعامل الأمة بالمزارعة والقياس يترك بالتعامل كما في عقد الاستصناع الذي يأبى القياس جوازه ، ولكنه جائز استحسانا (٢) .

(١) (بدائع الصنائع (٣٨٠٨/٨) .

(٢) (مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر (٤٩٩/٢) ، الباب في شرح الكتاب (٢٢٩/٢) .

المبحث الثاني ركن المزارعة وشروطها

أولاً: ركن المزارعة :-

عقد المزارعة كسائر عقود المعاملات ، يتوقف وجوده على ركنين ، هما : الإيجاب والقبول هذا من حيث الإجمال ، وأما من حيث التفصيل فأركان العقد أربعة:
الأرض .

البذر .

العمل .

البقر للحرثة ، ومع تقدم وسائل الزراعة في هذا العصر يقوم مقام البقر الآن الآلات الزراعية .

وإذا عقدت المزارعة فهي غير لازمة من قبل صاحب البذر قبل إلقاء البذر في الأرض؛ لأنه لا يمكنه الوفاء بالعقد إلا بإتلاف ماله وهو البذر ، وبعد إلقاء البذر في الأرض يجبر على إتمام العقد .

وأن الآخر وهو من لا بذر له فالمزارعة بعد العقد لازمة في حقه فلا يفسخ بلا عذر؛ لأن منفعة العامل أو منفعة الأرض صارت مستحقة للآخر ، فيجب عليه تسليمها .

وإن امتنع هذا الطرف الثاني وهو من لا بذر له أجبر على إتمام العقد؛ لأنه لازم في حقه كالإجارة ولا ضرر عليه في الوفاء به ، فيلزمه الوفاء به ، إلا أن يكون عذرا تفسخ به المزارعة ؛ لأنها في معنى الإجارة (١) .

ثانياً: شروط المزارعة :-

أن يكون العاقدان عاقلين ، فلا تصح مزارعة المجنون والصبي الذي لا يعقل المزارعة ؛ لأن العقل شرط لأهلية التصرف .

(١) (الهداية (٥٧/٤) ، الاختيار (٣٥٣/٢) .

وأما البلوغ فليس بشرط ، فتجوز مزارعة الصبي المميز المأذون له في التصرفات المالية؛ لأن المزارعة استتجار ببيع الخارج ، والصبي المأذون يملك الإجارة ؛ لأنها تجارة ، فيملك المزارعة .

أن يكون الزرع معلوما ؛ لأن الأجر ببيع الخارج وإعلام جنس الأجر شرط ، ولأن بعض الزراعة تضر بالأرض ، فرب زرع يزيد في الأرض ورب زرع ينقصها ، وقد يقل النقصان أو يكثر فلا بد من البيان ليكون لزوم الضرر مضافا إلى التزامه إلا إذا قال له صاحب الأرض : ازرع فيها ما شئت ، فيجوز له أن يزرع فيها ما شاء ؛ لأنه لما فوض إليه فقد رضي بالضرر ، إلا أنه لا يملك الغرس ؛ لأن الداخل تحت العقد الزرع دون الغرس .

أن تكون الأرض صالحة للزراعة ، فلو كانت غير صالحة بأن كانت سبخة لا تجوز المزارعة ، لأن السبب الذي من أجله شرعت المزارعة وهو حصول الرياح والنماء والتيسير ورفع الحرج عن الناس لم يحصل بسبب عدم صلاحية الأرض وبالتالي فعمل العامل فيها قد يكون هدرًا.

أن تكون الأرض معلومة ، فإن كانت مجهولة لا تصح المزارعة ؛ لأنها تؤدي إلى المنازعة .

تخلية الأرض ، وهو أن يوجد من صاحب الأرض التخلية بين الأرض وبين العامل حتى لو شرط العمل على صاحب الأرض لا تصح المزارعة ؛ لانعدام التخلية. ذكر المدة ، بمعنى أن تكون المدة معلومة فلا تصح المزارعة إلا بعد بيان المدة ؛ لأنها استتجار ببيع الخارج ، ولا تصح الإجارة مع جهالة المدة ، في رواية عن محمد بن سلمة أن بيانه ليس بشرط .

أن يكون الخارج مشتركا بينهما أي بعد حصوله ؛ لأنه ينعقد شركة في الانتهاء ، فما يقطع هذه الشركة كان مفسدا للعقد .

أن يكون المعقود عليه في باب المزارعة مقصودا من حيث إنها إجارة أحد أمرين : إما منفعة العامل إن كان البذر من العامل ؛ لأن البذر إن كان من قبل رب الأرض يصير مستأجرا للعامل ، وإذا كان من قبل العامل يصير مستأجرا للأرض ، وإذا اجتمعا في الاستتجار فسدت المزارعة .

فأما منفعة البقر فإن حصلت تابعة صحت المزارعة ، وإن حصلت مقصودة فسدت (١).
وبيان هذا الشرط يحصل ببيان أنواع المزارعة ، وهذا ما نتناول في المبحث التالي - إن شاء الله تعالى .

المبحث الثالث أنواع المزارعة (صور المزارعة)

(١) أن تكون الأرض والبذر والبقر والآلة من جانب والعمل من جانب ، وهذا جائز ؛ لأن صاحب الأرض يصير مستأجرا للعامل لا غير ليعمل له في أرضه ببعض الخارج الذي هو نماء ملكه وهو البذر .

(٢) أن تكون الأرض من جانب والباقي كله من جانب ، وهذا أيضا جائز ؛ لأن العامل يصير مستأجرا للأرضى غير ببعض الخارج الذي هو نماء ملكه وهو البذر .

(٣) أن تكون الأرض والبذر من جانب والبقر والآلة والعمل من جانب، فهذا أيضا جائز ؛ لأن هذا استئجار للعامل غير مقصودا .

(٤) أن تكون الأرض والبقر من جانب والبذر والعمل من جانب وهذا لا يجوز في ظاهر الرواية ، وروي عن أبي يوسف أنه يجوز .

ووجه الجواز : أنه لو كان الأرض والبذر من جانب جاز وجعلت منفعة البقر تابعة لمنفعة العامل ، فكذا إذا كان الأرض والبقر من جانب يجب أن يجوز ويجعل منفعة البقر تابعة لمنفعة الأرض .

(٥) أن يكون البذر والبقر من جانب والأرض والعمل من جانب وهذا لا يجوز أيضا؛ لأن صاحب البذر يصير مستأجرا للأرض والعامل ببعض الخارج والجمع بينهما يمنع صحة المزارعة .

(٦) أن يكون البذر من جانب والباقي كله من جانب وهذا لا يجوز أيضا؛ لأن صاحب البذر هنا أيضا يكون مستأجرا للأرض والعمل والبقر جميعا ببعض الخارج ، والجمع بينهما يمنع صحة المزارعة - كما قلنا - .

وروي أن أبي يوسف في هذين النوعين - الخامس والسادس - أنه يجوز المزارعة فيهما ؛ لأن استئجار كل واحد منهما جائز على الانفراد ، فكذا عند الاجتماع .

(١) (بدائع الصنائع (٣٨١٢/٨) وما بعدها ، الاختيار (٣٥٠/٢) وما بعدها ، اللباب (٢٣٠/٢) وما بعدها .

والجواز عليه : أن الجواز الذي خالف القياس تثبت عند الانفراد فتبقى حالة الاجتماع على أصل القياس وهو المنع .

وطريق الجواز في هذين النوعين بالاتفاق :

أن يأخذ صاحب البذر الأرض مزارعة ثم يستعير من صاحبها ليعمل له فيجوز ، والخارج يكون بينهما على الشرط .

(٧) أن يشترك جماعة من أحدهم الأرض ومن الآخر البقر ، ومن الآخر البذر ، ومن الرابع العمل ، وهذا لا يجوز أيضا ، وعلى قياس ما روي عن أبي يوسف يجوز .

(٨) أن يشترط في عقد المزارعة أن يكون بعض البذر من قبل أحدهما والبعض من قبل الآخر وهذا لا يجوز ؛ لأن كل واحد منهما يصير مستأجرا صاحبه في قدر بذره فيجتمع استئجار الأرض والعمل من جانب واحد وأنه مفسد .

(٩) أن تكون الأرض من جانب والبذر والبقر من جانب دفع صاحب الأرض أرضه إليه على أن يزرعها ببذره وبقرة مع هذا الرجل الآخر على أن ما خرج من شيء فتلته لصاحب الأرض وتلتاه لصاحب البذر والبقر وتلته لذلك العامل ، وهذا صحيح في حق صاحب الأرض والعامل الأول فاسد في حق العامل الثاني ، ويكون ثلث الخارج لصاحب الأرض وتلتاه للعامل الأول وللعامل الثاني أجر مثل عمله .

وبالنظر للصورتين السابقتين كان ينبغي هنا أن تقسد المزارعة في حق الكل .

والدليل : أن صاحب البذر وهو العامل الأول جمع بين استئجار الأرض والعامل ، وقد تبين أن الجمع بينهما مفسد للعقد ؛ لكونه على خلاف مورد الشرع بالمزارعة ، ومع هذا الفرض حكم بصحة المزارعة ، والرد على هذا الفرض :

أنه هنا في هذه الصورة العقد في ما بين صاحب الأرض والعامل الأول وقع استئجارا للأرض لا غير وأنه صحيح .

وفيما بين العاملين وقع استئجار الأرض والعامل جميعا وأنه غير صحيح ، أو يجوز أن يكون العقد الواحد له جهتين : جهة الصحة ، وجهة الفساد خصوصا في حق شخصين فيكون صحيحا في حق أحدهما فاسدا في حق الآخر .

ولو كان البذر في هذه الصورة من صاحب الأرض صحت المزارعة في حق الكل والخارج بينهم على الشرط ؛ لأن صاحب الأرض في هذه الصورة يعد مستأجرا للعاملين

جميعا ، والجمع بين استئجار الاملين لا يقدح في صحة العقد ، وإذا صح العقد كان الخارج على الشرط (١).

المبحث الرابع الأثر المترتب على المزارعة الصحيحة

المزارعة الصحيحة : هي ما جاءت مستوفية الشروط الصحيحة السابق ذكرها في المبحث الثاني ، وخلت من أي مفسد من مفسدات عقد المزارعة التي أذكرها في المبحث التالي لهذا المبحث .

ويترتب على تلك المزارعة الصحيحة أثراً ، أوجزها فيما يلي:

أولاً: أن كل ما يحتاج إليه الزرع لإصلاحه من أعمال المزارعة فعلى المزارع - العامل - ؛ لأن عقد المزارعة يتناوله .

ثانياً : أن النفقة على الزرع والحصاد والحمل إلى مكان التذرية والتذرية عليهما - أي العامل وصاحب الأرض - ؛ لأن ذلك ليس من عمل المزارع.

ثالثاً : أن يكون الخارج بينهما على الشرط المذكور؛ لأن الشرط قد صح فيلزم الوفاء به ؛ لأن الشرط قد صح فيلزم الوفاء به (٢) .

رابعاً: إذا لم تخرج الأرض شيئاً فلا شيء لواحد منهما ، لا أجر العمل ولا أجر الأرض بغض النظر عما إذا كان البذر من قبل العامل أو من قبل رب الأرض.

خامساً: إذا امتنع المزارع عن السقي وقال: أدعها حتى تسقيها السماء ، فينظر إن كان الزرع مما يكتفي بماء السماء ويخرج زرعاً معتاداً بدونه لا يجبر المزارع على السقي ، وإن كان الزرع لا يكتفي بماء السماء ولا وجودها إلا بالسقي يجبر العامل على السقي؛ لأن السقي أصبح مما يحتاجه الزرع لإصلاحه وقد تناوله عقد المزارعة(٣).

سادساً: أن هذا العقد غير لازم في جانب صاحب البذر ، لازم في جانب الطرف الآخر.

سابعاً: وهذا الأثر يتعلق بالزيادة والحط من الخارج على الشرط المذكور عند العقد.

وهذا الأثر يتضح بالتفصيل التالي:

(١) بدائع الصنائع (٣٨٢٢/٨) وما بعدها ، مجمع الأنهر (٥٠٣/٢) وما بعدها .

(٢) بدائع الصنائع (٣٨٢٢/٨) ، مجمع الأنهر (٥٠٣/٢) وما بعدها .

(٣) مجمع الأنهر (٥٠٣-٥٠١/٢) .

الزيادة والحط في المزارعة إما أن تكون من المزارع ، وإما أن تكون من صاحب الأرض ولا يخلو الحال من أن يكون البذر من قبل المزارع أو من قبل صاحب الأرض، وأن يكون بعد حصاد الزرع أو قبل الحصاد ، فإن كان بعد الحصاد والبذر من قبل المزارع وكانت المزارعة على النصف مثلا فزاد المزارع صاحب الأرض السدس في نصيبه ، وجعل له الثلثين ورضي به صاحب الأرض لا تجوز الزيادة ، والخارج بينهما على الشرط نصفان؛ لأن السدس هنا أصبح زيادة على أجرة الأرض بعد انتهاء عمل المزارعة باستيفاء المعقود عليه وهو المنفعة ، وهذا لا يجوز لفوات بقاء المعقود عليه وهو شرط في هذه الحالة.

وإن كان على العكس بأن زاد صاحب الأرض المزارع السدس في نصيبه وتراضيا فالزيادة جائزة ؛ لأن هذا حط من الأجرة من قبل صاحب الأرض وهو لا يستلزم قيام المعقود عليه .

هذا إذا كان البذر من قبل العامل، أما إذا كان من قبل صاحب الأرض فعلى العكس إن زاد صاحب الأرض لا يجوز، وإن زاد العامل جاز للتعليل السابق .

وهذا كله فيما إذا زاد أحدهما بعدما استحق الزرع، فإن زاد قبل أن يستحصل جاز أيهما كان ؛ لأن الوقت يحتمل إنشاء العقد فيحتمل الزيادة بخلاف ما بعد الحصاد .

وخلاصة القول في هذا الأثر - كما جاء في البدائع - : " إن كل ما احتتمل إنشاء العقد عليه احتتمل الزيادة وما لا فلا ، والحط جائز في الحالين جميعا كما في الزيادة في الثمن في باب البيع" (١).

وهذا يصلح ضابطا في هذا الباب.

(١) (بدائع الصنائع) (٣٨٢٤ / ٨) .

المبحث الخامس مفسدات عقد المزارعة والأثر المترتب عليها

أولاً: مفسدات عقد المزارعة :

يفسد عقد المزارعة إذا اختلت الشروط المصححة - وهي التي سبق الحديث عنها في المبحث الثاني- أو اقترنت بشروط من شأنها أن لا تتفق مع حقيقة عقد المزارعة ، وقد أشرت إلى بعضها حين الحديث عن الشروط المصححة ، وهنا أتناول باختصار بعض هذه الشروط المفسدة :

شرط كون الخارج لأحدهما - المزارع أو رب الأرض - لأن عقد المزارعة عقد شركة وهذا الشرط يقطع الشركة فتفسد المزارعة .

شرط العمل على صاحب الأرض ؛ لأنه يناقض شرطاً من شروط صحة المزارعة وهو التخلية ، فالواجب على صاحب الأرض تخلية أرضه وتسليمها للمزارع حتى تتحقق المزارعة ، فإن لم يحصل هذا فسدت المزارعة .

شرط كون البقر على صاحب الأرض ؛ لأن فيه جعل منفعة البقر معقوداً عليها مقصودة في باب المزارعة ، والأصل أن تجعل تابعة لا مقصودة .

شرط العمل والحفظ على المزارع بعد القسمة ؛ لأنه ليس من عمل المزارعة. اشتراط الحصاد والتذرية على المزارع يفسد العقد؛ لأن الزرع لا يحتاج إليه ، إذ لا يتعلق به صلاحه ، فيكون الحصاد والتذرية علياً معاً ، إذ هذا الأمر من الآثار المترتبة على المزارعة الصحيحة كما سبق الإشارة إليه في المبحث السابق .

شرط التبن لمن لا يكون البذر من قبله ، وهذا الأمر لا يخلو من ثلاثة أوجه:

إما إن شرطاً أن يكون التبن بينهما .

وإما أن يكونا سكتاً .

وإما أن يكون قد اشترط لأحدهما دون الآخر .

فهذه الثلاثة أوجه:

فإن كان الوجه الأول : وهو أن يكون شرطاً أن يكون التبن بينهما فلا شك في جوازه؛

لأنه شرط يتفق مع مقتضى عقد المزارعة وهو المشاركة في الخارج.

وإن كان الوجه الثاني: وهو أن يكونا قد سكتا عن هذا الشرط فقد اختلف صاحبي أبي

حنيفة القائلين بجواز المزارعة على رأيين:

الرأي الأول : للإمام أبي يوسف حيث قال: يفسد المزارعة ، ودليله : أن كل واحد من الحب والتبن مقصود من العقد ، فكان السكوت عن التبن بمنزلة السكوت عن الحب والسكوت عن الحب مفسد بالاتفاق فكذا السكوت عن التبن .

الرأي الثاني: للإمام محمد حيث قال : لا يفسد العقد ، ويكون لصاحب البذر منهما ، ودليله : أن ما يستحقه صاحب البذر يستحقه بالبذر لا بالشرط ، فكان شرط التبن والسكوت عنه بمنزلة واحدة .

والفتوى في المذهب في هذا الموضع على قول أبي يوسف حيث جاء في " البدائع " ما نصه " وذكر الطحاوي أن محمدا رجع إلى قول أبي يوسف .

(ج) وإن كان الوجه الثالث : وهو أن يكون شرطا أن يكون لأحدهما التبن دون الآخر ، فإن شرطاه لصاحب البذر جاز ويكون له ؛ لأن صاحب البذر يستحقه من غير شرط لكونه نماء ملكه فالشرط لا يزيده إلا تأكيدا ، وإن شرطاه لمن لا بذر له فسدت المزارعة؛ لأن استحقاق صاحب البذر التبن بالبذر لا بالشرط لأنه نماء ملكه، ونماء ملك الإنسان ملكه ، فصار شرط كون التبن لمن لا بذر له بمنزلة شرط كون الحب له ، وشرط كون الحب لمن لا بذر له مفسد للمزارعة ، فاشتراط كون التبن له أيضا مفسد للمزارعة .

٧- من الشرائط المفسدة للمزارعة أيضا : أن يشترط صاحب الأرض على المزارع عملا يبقى أثره ومنفعته بعد مدة المزارعة مثل بناء الحائط ، واستحداث حفر النهر ونحو ذلك مما يبقى أثره ومنفعته إلى ما بعد انقضاء مدة عقد المزارعة ؛ لأن هذا الشرط لا يقتضيه العقد (١) .

ثانياً : الأثر المترتب على فساد عقد المزارعة :

إذا اقترنت المزارعة بشرط من الشروط المفسدة لها - السابقة - فسدت المزارعة ، وإذا فسدت المزارعة ترتب عليها الأمور التالية :

(١) (بدائع الصنائع (٣٨١٩/٨) ، مجمع الأنهر (٥٠٠/٢) ، الاختيار (٣٥٢/٢) .

أنه لا يجب على المزارع شيء من أعمال المزارعة ؛ لأن الوجوب يتقرر بالعقد والعقد لم يصح فينتفي ما وجب به .

أن الخارج يكون كله لصاحب البذر أيا كان - صاحب الأرض أو المزارع - لأنه سبق القول بأن استحقاق صاحب البذر الخارج لكونه نماء ملكه وليس بالشرط المقترن بالعقد ؛ فإذا لم يصح الشرط وفسد العقد استحققه صاحب الملك بملكه الأصلي ولا يؤثر فيه فساد العقد ويدخل في ملكه تبعا لأصله .

أن البذر إذا كان من قبل صاحب الأرض كان للعامل عليه أجر المثل ؛ لأن صاحب الأرض في هذه الحالة يعد مستأجرا للعامل، فإذا فسدت الإجارة وجب أجر مثل عمله ، وإن كان البذر من قبل العامل كان على العامل لصاحب الأرض أجر مثل أرضه؛ لأن العامل في هذه الحالة يعد مستأجرا للأرض ، فإذا فسدت الإجارة يجب عليه أجر مثل أرضه .

أن البذر إذا كان من قبل صاحب الأرض واستحق الخارج وغرم للعامل أجر مثل عمله فالخارج كله له يطيب له ؛ لأنه حاصل من ملكه وهو البذر في ملكه وهو الأرض ، وإن كان من قبل العامل واستحق الخارج وغرم لصاحب الأرض أجر مثل أرضه فالخارج كله لا يطيب له بل يأخذ من الزرع قدر بذره ، وقدر أجر مثل الأرض ويطيب ذلك له؛ لأنه سلم له بعوض ، ويتصدق بالفضل على ذلك ؛ لأنه وإن تولد من بذره في أرض غيره بعقد فاسد فتمكنت فيه شبهة الخبث فكان سبيله التصديق .

أن أجر المثل لا يجب فيه المزارعة الفاسدة إلا إذا وجد استعمال الأرض؛ لأن المزارعة إجارة والأجرة في الإجارة الفاسدة لا تجب إلا بحقيقة الاستعمال، ولا تجب التخلية ؛ لانعدامها في الإجارة حقيقة .

أن أجر المثل يجب في المزارعة الفاسدة ، وإن لم تخرج الأرض شيئا طالما استعملها المزارع ، ولا يخفى أن هذا الأجر لا يتقرر في المزارعة الصحيحة لا يجب أي أجر؛ لأن الأجر فيها من الخارج منها أما الفاسدة فيصار فيها إلى أجر المثل .

أيضا أجر المثل في المزارعة الفاسدة يجب مقدرا بالمسمى عند أبي يوسف ، ودليله : أن الأصل هو وجوب أجر المثل بدلا عن المنافع قيمة لها ؛ لأنه هو المثل بالقدر

الممكن ، لكن مقدرا بالمسمى لأنه كما يجب اعتبار الممالة في البديل في عقد المعاوضة بالقدر الممكن يجب اعتبار التسمية أيضا بالقدر الممكن ؛ لأن اعتبار تصرف العاقل واجب ما أمكن ، وأمكن ذلك بتقدير أجر المثل بالمسمى.

وبيان ذلك :

أن المستأجر ما رضي بالزيادة على المسمى ، والمؤجر ما رضي بالنقصان عنه ، فكان اعتبار التسمية في تقدير أجر المثل عملا بالدليلين ورعاية للجانبين وتصحيحا لتصرفات العاقل ما أمكن فكان أولى .

ويرى الإمام محمد - رحمه الله - أن أجر المثل في المزارعة الفاسدة يجب تاما ولا يلتفت إلى التسمية ، ودليله : أن الأصل في الإجارة وجوب أجر المثل ؛ لأنها عقد معاوضة ، ومبنى المفاوضات على المساواة بين البديلين ، وهذا لا يتحقق إلا في وجوب أجر المثل وأجر المثل الممكن في بابه هو قدر قيمة المنافع المستوفاة ، إلا أن فيه نوع جهالة وجاهالة المعقود عليه تمنع صحة العقد ، فلا بد من تسمية البديل تصحيحا للعقد ، فوجب المسمى على قدر قيمة المنافع أيضا ، فإذا لم يصح العقد لفوات شرط من شرائطه وجب المصير إلى البديل الأصلي للمنافع وهو أجر المثل (١) .

والفتوى بقول الإمام أبي يوسف أحوط خروجاً من الجهالة المفضية إلى المنازعة ورعاية للجانبين ، ولا يخفى أن هذا الخلاف فيما إذا كانت الأجرة وهي حصة كل واحد منهما مسماة في العقد ، فإن لم تكن مسماة وجب أجر المثل تاما بالإجماع (٢).

(١) (بدائع الصنائع (٣٨٢٥/٨) وما بعدها ، شرح فتح القدير (٣٩٣/٨) ، الاختيار (٣٥٢/٢) ، اللباب (٢٣٠/٢) .

(٢) (بدائع الصنائع (٣٨٢٦/٨) .

المبحث السادس فسخ عقد المزارعة والأثر المترتب عليها

أولاً : فسخ عقد المزارعة:

قد يطرأ لعقد المزارعة عذر يؤدي إلى فسخ هذا العقد ، قد يرجع إلى صاحب الأرض أو يرجع إلى المزارع على النحو التالي :

أولاً: عذر فسخ عقد المزارعة من قبل صاحب الأرض:

الدين الفادح الذي لا قضاء له إلا من ثمن هذه الأرض تباع فيه ويفسخ العقد بهذا العذر إذا أمكن الفسخ كالإجارة (١) .

ويحصل هذا في حالتين : إذا كان قبل الزراعة ، أو بعدها إذا أدرك الزرع وبلغ مبلغ الحصاد .

أما إذا كان بعد الزراعة والزرع لم يبلغ مبلغ الحصاد فلا تفسخ المزارعة ولا تباع الأرض في الدين .

أما في الحالة الأولى والثانية : فلا ضرر للعامل حيث في الأولى كأن شيئاً لم يكن فوق ما فيه من تأخير حق صاحب الدين ، وفي الثانية الغرض الذي من أجله عُقد عقد المزارعة - وهو سلامة الزرع وبلوغه مبلغ الحصاد - قد تحقق .

ثانياً: أعمار فسخ عقد المزارعة الراجعة إلى المزارع فمنها على سبيل المثال لا الحصر:

المر؛ لأنه معجز عن العمل ، والسفر ؛ لأنه يحتاج إليه ، وترك حرفة إلى حرفة ؛ لأن من الحرف ما لا يغني من جوع ، فيحتاج إلى الانتقال إلى غيره (٢).

وأما أسباب انفساخ عقد المزارعة فهي كالتالي :

الفسخ، وهو نوعان :

فسخ صريح ، وهو ما كان بلفظ الفسخ والإقالة ؛ لأن المزارعة مشتملة على الإجارة والشركة ، وكل واحد منهما قابل لصريح الفسخ والإقالة .

(١) (بدائع الصنائع (٣٨٢٦/٨ ، ٣٨٢٧) ، اللباب (١٠٥/٢) .

(٢) (بدائع الصنائع (٣٨٢٦، ٣٨٢٧/٨) ، اللباب (١٠٥/٢) .

فسخ دلالة مثل امتناع صاحب البذر عن المضي في العقد ؛ لأن العقد غير لازم في حقه ، كما أوضحت سابقا ، فكان بسبيل من الامتناع عن المضي فيه من غير عذر ، ويكون ذلك فسخا منه دلالة (١) .

انقضاء مدة المزارعة ؛ لأنها إذا انقضت فقد انتهى العقد وهو معنى الانفساخ. وهنا لابد من سوق بعض المسائل المتعلقة بالمدة وانقضائها في عقد المزارعة :

الأولى: هل للمزارع بالسنة زرع نوع آخر إذا هلك المزروع قبل انتهاء المدة؟

والجواب: إن كان الاتفاق بين صاحب الأرض والمزارع على نوع معين فليس للمزارع أن يزرع غيره، وقيل يزرع مثل الأول أو أقل منه في الضرر بالأرض ، وإن كان الاتفاق على أن يزرع ما شاء فله أن يزرع ما شاء في المدة الباقية (٢) .

الثانية : ما حكم انقضاء المدة قبل استواء الزرع:

والجواب : يبقى الزرع في الأرض إلى استوائه ويكون على المزارع أجر مثل الأرض بما يساوي قيمة حصته بمعنى أنه إن كان يزرع مناصفة مثلا كان عليه نصف أجر مثلها وهكذا؛ لأن العقد قد انتهى ، وعليه أجر لأنه استوفى منفعة الأرض بقدر المدة المقررة ، ولا يقال يقلع الزرع احتراما للعقد وذلك رفعا للضرر عن المزارع .

وطالما وجب على المزارع دفع قيمة أجر مثل الأرض فيكون العمل ونفقة الزرع ومؤنه الحفظ والتدريية عليهما - أي المزارع وصاحب الأرض - ؛ لأنه مال مشترك بينهما (٣) .

ولو أراد صاحب الأرض أن يأخذ الزرع بطلا - قبل بلوغ الحصاد - لم يكن له ذلك ؛ لأن فيه ضررا بالمزارع ، ولو أراد المزارع أن يأخذه بطلا فصاحب الأرض بين خيارات ثلاث : إن شاء قلع الزرع بينهما ، وإن شاء أعطى المزارع قيمة نصيبه من

(١) (بدائع الصنائع (٣٨٢٩/٨ ، ٣٨٢٨ ، الباب (٢/٢٣٢) .

(٢) (الفتاوى الهندية (٢٥٣/٥) .

(٣) (الاختيار (٣٥٥/٢) ، الباب (٢/٢٣٢) .

الزراع ، وإن شاء أنفق هو على الزرع من ماله ثم يرجع على المزارع بحصته ؛ لأن فيه رعاية للجانبين (١).

موت أحد المتعاقدين - رب الأرض أو المزارع - سواء مات قبل الزراعة أو بعدها بلغ الزرع حد الحصاد أو لم يبلغ يفسخ العقد؛ لأن عقد المزارعة لا يورث فهو قد أفاد الحكم لهما دون ورثتهما.

والضابط : أن من عقد لنفسه بطريق الأصالة فحكم تصرفه يقع له لا لغيره إلا لضرورة.

ثانياً : الأثر المترتب على فسخ عقد المزارعة :

فسخ عقد المزارعة لا يخلو من حالتين ، إما أن يكون قبل الزراعة أو بعدها :
الأولى : فإن كان الفسخ قبلها : فلا شيء للعامل ، وإن جهز الأرض وحفار الأنهار سواء تم الفسخ بصريحه أو بدليله أو بانقضاء المدة أو بموت أحد المتعاقدين ؛ لأن الفسخ يظهر أثره في المستقبل بانتهاء حكمه لا في الماضي فلا يتبين أن العقد لم يكن صحيحاً حتى يجب له أجر المثل كما في العقد الفاسد ، فكان الواجب في العقد الصحيح : المسمى وهو بعض الخارج ، ولم يوجد فلا شيء وهذا الحكم قضاءً ، وأما ديانة فيما بين صاحب الأرض وبين الله تعالى فعليه أن يرضي العامل (٢) .

الثانية : وإن كان الفسخ بعد المزارعة فينظر : فإن كان الزرع قد بلغ الحصاد ، فالحصاد والخارج بينهما على الشرط بأي طريق تم الفسخ من الطرق الثلاثة - صريح الفسخ ودلالته ، وانتهاء المدة ، وموت أحد المتعاقدين - وأما إذا لم يبلغ الزرع الحصاد فالحصاد والخارج بينهما على الشرط في طريقين فقط من طرق الفسخ وهما : طريق الفسخ ودلالته ، أو انتهاء المدة ؛ لأن الزرع بينهما على الشرط والعمل فيما بقي إلى وقت الحصاد عليهما وعلى المزارع أجر مثل نصف الأرض كما سبق بيانه .

(١) (الاختيار (٣٥٥/٢) ، الباب (٢٣٢/٢) ، تبين الحقائق (٢٨٣/٥) ، الفتاوى الهندية (٢٥٥/٥) ، حاشية رد المحتار (١٧٨/٥) .

(٢) (بدائع الصنائع (٣٨٢٨،٣٨٢٩/٨) ، الهداية (٥٧/٤) .

وأما الطريق الثالث من طريق الفسخ أو الوجه الثالث من أوجه الفسخ وهو موت أحد المتعاقدين فيترتب عليه أنه إذا مات صاحب الأرض والزرع لم يبلغ الحصاد يكون العمل على المزارع بخاصة ؛ لأن العقد قد انفسخ حقيقة لوجود سبب الفسخ وهو الموت ، إلا أنه بقي العقد تقديرا دفعا للضرر عن المزارع ، فإذا بقي العقد كان العمل على المزارع بخاصة كما كان قبل الموت.

ويقسم على الشرط المذكور؛ لأن في الترك إلى الحصاد رعاية للجانبين ، وفي قلع الزرع قبل الحصاد إضرارا بأحدهما وهو المزارع ، فرعاية الجانبين أولى (١).

وإن مات المزارع قبل بلوغ الزرع الحصاد ، وقال ورثته : نحن نعمل على شرط المزارعة وأبي صاحب الأرض ، فالأمر إلى ورثة المزارع ؛ لأن في القلع ضررا بالورثة ولا ضرر بصاحب الأرض في الترك إلى وقت الحصاد ، وإذا ترك لا أجر للورثة في عملهم لأنهم يعملون على حكم عقد أبيهم تقديرا فكأنه يعمل أبوهم

وإن أراد الورثة قلع الزرع لم يجبروا على العمل ؛ لأن العقد قد انفسخ حقيقة بموت أبيهم إلا أنه بقي باختيارهم رعاية لهم ، فإن امتنعوا عن العمل بقي الزرع مشتركا بينهم: فإما أن يقسم بينهم بالحصص أو يعطيهم صاحب الأرض حصتهم من الزرع أو ينفق من مال نفسه إلى وقت الحصاد ، ثم يرجع عليهم بحصتهم (٢) .

جاء في مختصر القدوري رحمه الله - ما يدل على ذلك حيث قال: "قال أبو حنيفة رحمه الله -: المزارعة بالثلث والربع باطلة وقال أبو يوسف ومحمد: جائزة، وهي عندهما على أربعة أوجه: إذا كانت الأرض والبذر لواحد والعمل والبقر لواحد جازت المزارعة، وإن كانت الأرض لواحد والعمل والبقر والبذر لآخر جازت، وإن كانت الأرض والبقر والبذر لواحد والعمل لآخر جازت، وإن كانت الأرض والبقر والبذر لواحد والعمل لآخر فهي باطلة، ولا تصح المزارعة إلا على مدة معلومة، ومن شرائطها: أن يكون الخارج مشاعا بينهما فإن شرطا لأحدهما قفزاناً مسماة فهي باطلة وكذلك إن شرطا ما على الماذينات والسواقي، وإذا صحت المزارعة فالخارج بينهما على الشرط

(١) (الهداية (٥٧/٤) .

(٢) (بدائع الصنائع (٣٨٣٠/٨) ، تبين الحقائق (٥ / ٢٨٢ ، ٢٨٣) .

فإن لم تخرج الأرض شيئاً فلا شيء للعامل، وإذا فسدت المزارعة فالخارج لصاحب البذر فإن كان البذر من قبل رب الأرض فللعامل أجر مثله لا يزداد على مقدار ما شرط له من الخارج وإن كان البذر من قبل العامل فلصاحب الأرض أجر مثلها، وإذا عقدت المزارعة فامتنع صاحب البذر من العمل لم يجبر عليه وإن امتنع الذي ليس من قبله البذر أجبره الحاكم على العمل، وإذا مات أحد المتعاقدين بطلت المزارعة وإذا انقضت مدة المزارعة والزرع لم يدرك كان على المزارع أجر مثل نصيبه من الأرض إلى أن يستحصد والنفقة على الزرع عليهما على مقدار حقوقهما وأجرة الحصاد (١)، والرفاع (٢) والدياس (٣) والتذرية (٤) عليهما بالحصص فإن شرطاه في المزارعة على العامل فسدت (٥).

ويمكن أن نستنتج من خلال ما سبق أبرز النقاط التالية :

- ١- المزارعة: عقد على الزرع ببعض الخارج منه وتسمى بالمخابرة والمحاكمة.
 - ٢- حكم المزارعة: اختلف فقهاء الحنفية في حكم المزارعة على رأيين: رأي يرى جوازها وهم جمهور الفقهاء والصاحبان من الحنفية ، ورأي لا يرى جوازها على هذا النحو وهو ما ذهب إليه أبو حنيفة وزفر. والراجح في حكم المزارعة هو الجواز كما قال الجمهور ومعهم أبو يوسف ومحمد أصحاب الإمام أبي حنيفة، فقد ذكر الموصلي في الاختيار: أن الفتوى في حكم المزارعة على قول الصاحبين، أي ما قال به الصاحبان وهو جوازها.
- شروط صحة المزارعة إجمالاً

-
- (١) - (حَصَدَ) الْحَاءُ وَالصَّادُ وَالذَّالُ أَصْلَانِ: [أَحَدُهُمَا] قَطَعَ الشَّيْءَ، وَالْآخَرُ إِحْكَامُهُ. وَهُمَا مُتَقَاوِمَانِ. فَأَلَوَّلُ حَصَدْتُ الزَّرْعَ وَغَيْرَهُ حَصْدًا. وَهَذَا زَمَنُ الْحَصَادِ وَالْحِصَادِ (معجم مقاييس اللغة ٧١/٢).
 - (٢) - الرَّفَاعُ وَالرَّفَاعُ: اكْتِنَاؤُ الزَّرْعِ وَرَفْعُهُ بَعْدَ الْحَصَادِ. وَرَفَعَ الزَّرْعَ يَرْفَعُهُ رَفْعًا وَرَفَاعًا: نَقَلَهُ مِنَ الْمَوْضِعِ الَّذِي يَحْصَدُهُ فِيهِ إِلَى الْبَيْدَرِ (لسان العرب فصل الراء ١٣١/٨).
 - (٣) - الدَّائِسُ الَّذِي يَدُوسُ الطَّعَامَ وَيَذْفُقُهُ لِيُخْرِجَ الْحَبَّ مِنْهُ، وَهُوَ الدِّيَاسُ. (لسان العرب فصل الدال ٩٠/٦).
 - (٤) - تَذْرِئَةُ الْحِنْطَةِ بِالْمِزْرَةِ: ذَرْوُهَا، أَيْ تَنْقِئْتُهَا مِنَ التُّرَابِ (القاموس المحيط فصل الفاء ١٠٤٤).
 - (٥) - مختصر القدوري ٢٤٣

١- التأقيت . ٢- صلاحية الأرض للزراعة. ٣- معرفة مقدار البذر . ٤- معرفة جنس البذر . ٥- معرفة نصيب الآخر . ٦- التخلية بين الأرض والعامل . ٧- أن يكون الخارج مشتركاً بينهما.

هناك شرطاً أضافه الإمام الكاساني إلى هذه الشروط وهو شرط جوهري وهو: أن يكون حصة كل واحد من المزارعين بعض الخارج حتى لو شرطاً أن يكون من غيره لا يصح العقد، لأن المزارعة استتجار ببعض الخارج بها، وهذا الشرط يميز عقد المزارعة عن الإجارة المحضة .

الآثار المترتبة على انعقاد المزارعة.

١- إذا صحت المزارعة فالخارج من الأرض يقسم بين مالك الأرض والمزارع على حسب ما اتفقا عليه في عقد المزارعة، عملاً بالتزامهما.

٢- المزارعة إجارة ابتداء شركة انتهاء فنسبة المحصول التي ارتضى به المزارع مقابل قيامه بأعمال المزارعة هي أجره لا أجر له سوى ذلك، وبالتالي إذا هلك المحصول فقد هلكت الأجرة، وأصبح المزارع في هذه الحالة كالمضارب إذا لم يحقق ربحاً.

ينفسخ عقد المزارعة بأحد الأسباب الآتية:

- ١- الفسخ الصريح أو الفسخ دلالة . ٢- انقضاء مدة العقد .
- ٣- موت أحد المتعاقدين . ٤- الأعذار القهرية.

أسئلة وتدريبات

- س ١: بين مفهوم المزارعة وأدلة مشروعيتها.
- س ٢: بين حكم المزارعة بالتفصيل المناسب مع بيان القول الراجح في نظرك .
- س ٣: ما أركان المزارعة ؟ وما شروط صحتها ؟.
- س ٤: ما هي الآثار المترتبة على فسخ عقد المزارعة ؟.
- س ٥: ما أنواع المزارعة.
- س ٦: بين ما يفسد عقد المزارعة ثم بين الأثر المترتب على فسخ عقد المزارعة .

كتبه

أ.د/ إبراهيم رمضان عطايا. أستاذ ورئيس قسم الفقه بكلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالسادات

د/ أحمد سيد أحمد عبد المقصود الشافعي. مدرس الفقه بكلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنين بالديمامون شرقية

الفصل الحادي عشر المساقاة

ويشتمل هذا الفصل على خمسة مباحث على النحو التالي:

المبحث الأول : التعريف بالمساقاة وحكمها .

المبحث الثاني : أركان المساقاة وشروط كل ركن .

المبحث الثالث : الآثار المترتبة على صحة المساقاة ووجه تمويلها

للنشاط الزراعي .

المبحث الرابع : ما يفسد المساقاة والأثر المترتب على فسادها .

المبحث الخامس : فسخ المساقاة والأثر المترتب عليه .

أهداف الدرس:

بدراسة عقد المساقاة ينبغي على الطالب أن يستنتج ما يلي:

أولاً : المعلومات والمفاهيم:

التعرف على معنى المساقاة لغة وشرعاً، وركنها، وأدلة مشروعيتها، وحكمة مشروعيتها.

التعرف على شروطها.

التعرف على شروط صحة المساقاة.

التعرف على أسباب فسخ المساقاة.

التعرف على أبرز الأحكام الفقهية المتعلقة بالمساقاة الصحيحة والفاصلة، وآراء فقهاء الحنفية فيها، وبيان ذلك بالأمثلة والآثار المترتبة على صحة المساقاة ووجه تمويلها للنشاط الزراعي.

ثانياً: المهارات الذهنية:

يستطيع الطالب أن يستنبط أن جواز المساقاة في النخل والشجر وكل ما يزيد بالعمل.

يحلل الطالب أن المساقاة إذا فسدت فللعامل أجر مثله.

يستطيع الطالب تطبيق ذلك عملياً إن أراد أن يعمل في هذا المجال.

المبحث الأول التعريف بالمساقاة وحكمها

أولاً : التعريف بالمساقاة :

أ - المساقاة في اللغة : هي مفاعلة من السقي وهو إشراب الشيء الماء وما أشبهه تقول سقيته بيدي أسقيه سقيا ، وأسقيته إذا جعلت له سقيا والسقي مصدر سقى ومنه قوله تعالى ﴿ فَسَقَى لَهُمَا ﴾ (١).

ويقال: أسقيتك هذا الجلد بمعنى وهبته لك تتخذ سقاء

والسقاية : الموضع الذي يتخذ فيه الشراب في الموسم والسقاية في قوله تعالى ﴿ جَعَلَ السَّقَايَةَ فِي رَحْلِ أَخِيهِ ﴾ (٢)، والصواع هو الذي كان يشرب فيه الملك. وقيل السقي والسقيا أن يعطيه ما يشرب والإسقاء أن يجعل له ذلك حتى يتناوله كيفما شاء، فالإسقاء أبلغ من السقي ، لأن الإسقاء هو أن تجعل له ما يسقى منه ويشرب ، واستقى فلانا أي طلب السقي واستسقى من النهر أو البئر أو الساقية أي أخذ من مائها

والمساقاة تسمى المعاملة أي مفاعلة من العمل وهي : أن يستعمل رجل رجلا في نخيل أو كروم ليقوم بإصلاحها على أن يكون له سهم معلوم مما تغله (٣)

ب - المساقاة في الاصطلاح :

عرفها الحنفية بقولهم : هي " عقد يتضمن دفع الأشجار إلى من يعمل فيها على أن الثمرة بينهما (٤).

أو هي "عبرة عن العقد على العمل ببعض الخارج مع سائر شرائط الجواز" (٥)

(١) سورة القصص الآية : (٢٤) .

(٢) سورة يوسف الآية : (٧٠) .

(٣) معجم مقاييس اللغة ٣ / ٨٤ ، ٨٥ ، والمفردات في غريب القرآن ص ٢١٧ ، وتاج العروس ١٩ / ٥٣٢ ، والمعجم

الوجيز مادة سقى

(٤) تبين الحقائق ٥ / ٢٨٤

(٥) بدائع الصنائع ٨ / ٣٨٣١

ثانيا : حكم المساقاة :

اختلفت كلمة الفقهاء في مشروعية المساقاة إلى ثلاثة مذاهب على النحو التالي :
المذهب الأول : الصحابين أبو يوسف ومحمد من الحنفية ، (١) حيث قالوا : إن المساقاة جائزة شرعا .

واستدلوا لقولهم بالسنة ، والأثر والإجماع والقياس :

أما السنة :

فيما ورد عن ابن عمر - رضي الله عنهما - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - عامل أهل خيبر على شطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع " (٢) .
ووجه الدلالة من الحديث : واضح من محل الشاهد وهو " على شطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع " وهذا هو معنى المساقاة وهو ظاهر الدلالة على جوازها لفعله صلى الله عليه وسلم لأنه عليه الصلاة والسلام لا يفعل إلا ما هو جائز شرعا .
وقد نوقش هذا الاستدلال بعدة مناقشات منها :

١ - إن حديث خيبر منسوخ بحديث رافع بن خديج الوارد فيه نهيه صلى الله عليه وسلم عن المخابرة ، وابن عمر راوي الحديث نفسه قد ترك العمل به وقد أجيب على هذه المناقشة من عدة وجوه :

أ - إن حديث خيبر لا يمكن القول بنسخه ، لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - استمر يعامل أهل خيبر حتى مات وكذا الخلفاء الراشدون والصحابة من بعده وكذا التابعون من بعدهم فكيف يتصور نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - ثم يخالفه ؟ أم كيف يعمل بذلك في عصر الخلفاء ولم يخبرهم من سمع النهي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو حاضر معهم وعالم بفعلهم (٣) .

ب - اتفق نقلة الحديث والسير والأخبار على استمراره صلى الله عليه وسلم على معاملة أهل خيبر منذ فتحت حتى قبض ، ثم مدة خلافة أبي بكر وصدرًا من خلافة عمر إلى أن أجلاهم عنها فتبين من هذا أن أحاديث النهي سابقة لفعل الرسول والصحابة مع أهل

(١) بدائع الصنائع ٨ / ٣٨٣١ ، واللباب ٢ / ٢٣٣ .

(٢) أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الحرث والمزاعة باب المزاعة بالشرط ونحوه

(٣) المغني ٥ / ٥٥٤

خيبر وشأن الناسخ أن يكون متأخر عن منسوخة ، لكن لما كان العكس ، فمن الأولى أن تكون أحاديث النهي هي المنسوخة بما علم تأخره قطعا من معاملة أهل خيبر (١) .

ج - إن النسخ لا يصار إليه إلا عند تعذر الجمع بين الأحاديث، ولكن الجمع بين الأحاديث ممكن هنا ، وطريقه: حمل أحاديث النهي على حالات خاصة من أنواع المساقاة الفاسدة كأن يشترطوا فيها شروط تفسد العقد كاستثناء ثمر ما على السواقي والجداول لرب الشجر (٢)

د - أن ترك ابن عمر هذا النوع من التعامل ليس دليلا على نسخ حديث خيبر ، لأن تركه على سبيل الورع والاحتياط الذي اشتهر به (٣)

٢ - ونوقش استدلال جواز المساقاة أيضا بأن النبي - صلى الله عليه وسلم - حين افتتح خيبر استرقهم وتملك أراضيهم ونخيلهم، ثم جعلها في أيديهم يعملون فيها بمنزلة العبيد في نخيل مواليتهم وكان في ذلك منفعة للمسلمين ليتفرغوا للجهاد بأنفسهم ، والذي قدره لهم من نصف الثمر يعد نفقة لهم ، لأنهم عبيد للمسلمين والعبد يحب نفقته على سيده ولم يكن ذلك على وجه المساقاة (٤)

وقد أجيب على هذه المناقشة بوجهين :

أ - أن القول بأن النبي - صلى الله عليه وسلم - استرق أهل خيبر يحتاج إلى دليل ، لأن الكفار لا يسترقون بمجرد الاستيلاء

ب - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يسترق أهل خيبر ، لأنه لو ثبت أنه استرقهم لما جاز لعمر بن الخطاب - رضي الله عنه - أن يأمرهم أن يجلوا عنها لما فيه من تقوية أملاك المسلمين لكونهم عبيدا لهم وفيهم يتامى وأرامل وهذا لا يليق بسيدنا عمر - رضي الله عنه - لأنه كان حريص كل الحرص على ما فيه مصلحة المسلمين (٥)

(١) فتح الباري بشرح صحيح البخاري، كتاب المزارعة، باب المزارعة بالشرط ونحوه، (ج ٥، ص ٢٤-٢٥ طبعة دار المعرفة

(٢) المجموع شرح المذهب، كتاب المساقاة، (ج ١٤، ص ٣١٩-٣٢٠ في طبعة دار الفكر) ..

(٣) المبسوط 13/ 23 ط : دار المعرفة

(٤) المبسوط ٢٣/ ٣

(٥) المرجع السابق نفس الصفحة

٣ - ونوقش استدلال جواز المساقاة أيضا: بأن حديث خبير لا يدل على مشروعية المساقاة، لأن الرسول - ﷺ - أقر أرض خبير ونخلها في يد اليهود وما كان يأخذه الرسول ﷺ لم يكن نصيب المسلمين بالمساقاة وإنما كان بمنزلة الجزية

وأجيب على هذه المناقشة : بأن المقدار الذي كان يأخذه الرسول - ﷺ - من ناتج نخل خبير لو كان على سبيل الجزية لكانت أرض خبير ونخلها ملكا لليهود ، ولكن الثابت أن أرض خبير ونخلها انتقلت بعد الفتح إلى المسلمين وقسمت بين الغانمين من المسلمين بناء على أن خبير فتحت كلها عنوة ، وعلى فرض التسليم بأن خبير فتح بعضها صلحا وبعضها عنوة ، فالمفتوح عنوه كان جميعه لله ولرسوله وللمسلمين والمفتوح صلحا كان لليهود ثم صار للمسلمين بعقد الصلح ، لأن الصلح كان من أهم بنوده : انتقال الملكية إلى المسلمين ، ولو لم يكن كذلك لما جاز لسيدنا عمر - رضي الله عنه - إجلاؤهم عنها (١)

واستدل جمهور الفقهاء على جواز المساقاة أيضا من السنة بما ورد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قالت الأنصار للنبي ﷺ اقسم بيننا وبين إخواننا النخل قال لا ، فقالوا تكفوننا المؤنة ونشرككم في الثمرة قالوا سمعنا وأطعنا " (٢)

ووجه الدلالة من هذا الحديث ظاهر وهو حدوث اتفاق بين المهاجرين والأنصار على أن يعمل المهاجرين في بساتين الأنصار على أن تكون الثمرة بينهم وكان هذا بحضور الرسول - ﷺ - ولم ينكره عليهم ، فدل ذلك على مشروعية المساقاة وقد نوقش الاستدلال بهذا الحديث : بأن ما أخذه المهاجرون من الأنصار من الأرض والمال كان باشتراط النبي - ﷺ - على الأنصار مواساة المهاجرين ليلة العقبة ولم يكن على سبيل المساقاة (٣).

وأجيب على هذه المناقشة : بأن المهاجرين قد ملكوا شيئا من أرض الأنصار وأموالهم ليلة العقبة ، ولا يلزم من اشتراط المواساة ثبوت الاشتراك في الأرض والمال ، ولو ثبت الاشتراك في الأرض والمال باشتراط النبي - ﷺ - المواساة ما كان هناك فائدة لسؤال

(١) فتح الباري ٥ / ٢٦

(٢) أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الحرث والمزارعة باب إذا قال اكفني مؤنة النخل غيره وتشركني في الثمر ، وأخرجه أيضا في كتاب الشروط باب الشروط في المعاملة

(٣) فتح الباري ٥ / ١٠

الأنصار النبي ﷺ - ليقسم أرضهم بينهم وبين المهاجرين ، ورفض رسول الله ﷺ ذلك ثم إقراره عليه الصلاة والسلام النخيل معاملة للمهاجرين ببعض ثماره " (١)

وأما استدلال صاحبين أبو يوسف ومحمد من الحنفية بجواز المساقاة بالأثر :
فبما ورد عن عمر بن عبد العزيز قال : " لما استخلف عمر أجلى أهل نجران وأهل فدك وتيماء وأهل خيبر ، واشترى عقارهم وأموالهم واستعمل يعلي بن منية فأعطى البياض - يعنى بياض الأرض - على إن كان البذر والبقر والحديد من عمر فلهم الثلث ولعمر الثلثان ، وإن كان منهم فلهم الشطر وله الشطر ، وأعطى النخل والعنب على أن لعمر الثلثين ولهم الثلث " (٢).

وجه الدلالة من هذا الأثر :

إن سيدنا عمر - رضي الله عنه - أمر عامله بإعطاء الأرض لمن يقوم عليها ويزرعها ببعض الخارج من الثمر وهذه هي المزارعة ، وأمر عامله أيضا أن يعطي النخل والعنب لمن يقوم عليه ويتعهد بالسقي ببعض الخارج منه وهذه هي المساقاة فدل هذا على مشروعيتها

وأما استدلال صاحبين أبو يوسف ومحمد من الحنفية بجواز المساقاة من الإجماع :
فهو إنه جرت عادة المسلمين في جميع الأعصار والأمصار على التعامل بالمساقاة منذ بعثته صلى الله عليه وسلم - إلى يومنا هذا ، ويؤيد هذا ما قاله بعض العلماء ومنهم الإمام أبو الحسن الماوردي حيث قال : " والمساقاة جائزة لا يعرف خلاف بين الصحابة والتابعين في جوازها وهو قول كافة الفقهاء إلا أبا حنيفة فإنه تفرد بإبطالها " (٣)
وقال أيضا : يدل على جواز المساقاة إجماع الصحابة على سيرة أبي بكر وعمر رضي الله عنهما في مساقاة أهل خيبر بعد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - اتباعا له إلى أن حدث من إجلائهم ما حدث (٤)

(١) المرجع السابق نفس الصفحة

(٢) المرجع السابق ٥ / ١٤ وقال ابن حجر وهذا مرسل وقواه بأثر آخر في معناه وقال عنه أيضا مرسل فيتقوى أحدهما بالآخر .

(٣) الحاوي ٩ / ١٦١ ط : دار الفكر .

(٤) المرجع السابق ٩ / ١٦٣ .

ونوقش هذا الإجماع :

إنه غير مسلم ، لأن سيدنا عبد الله بن عمر وهو من فقهاء الصحابة وراوي حديث
معاملة أهل خيبر قد رجع عنه وقال : كنا نخابر أربعين سنة حتى حدثنا رافع بن خديج أن
رسول الله - ﷺ - نهى عن المخابرة وهذا يمنع انعقاد الإجماع (١)
وأجيب على هذه المناقشة بما يلي :

أن رجوع سيدنا عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - يحتمل أنه كان عن شيء
من المعاملات الفاسدة كالمساقاة التي يشترط فيها ثمر شجر بعينه لرب الأرض ، ولم يكن
الرجوع عن كل أنواع المساقاة ، وعلى فرض أن سيدنا عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما -
- رجع عن كل أنواع المساقاة فليس فيه ما يثبت أن رجوعه لاعتقاد صحة خبر سيدنا رافع
- رضي الله عنه - وإنما كان على سبيل الزهد والورع الذي اشتهر به بين الصحابة -
رضي الله عنهم - يؤكد هذا إشارته رضي الله عنه إلى هذا المعنى وهو أن علة الترك عنده
حيثية مطلق النهي في المروى عن الرسول صلى الله عليه وسلم وهذا لا ينافي اعتقاد الجواز
عنده - رضي الله عنه - ، لأنه كم من معاملات يتركها المرء المؤمن على طريق الزهد وإن
كان يعتقد الجواز (٢)

واستدلوا بجواز المساقاة بالمعقول من وجهين :

أ - إن المساقاة عقد شركة في الخارج كالمضاربة ، والمضاربة جائزة فالمساقاة تكون
جائزة

ب - حاجة الناس الماسة إلى جواز المساقاة وهي : إن كثير من أهل النخيل
والشجر يعجزون عن عمارته وسقيه ، ولا يمكنهم الاستئجار عليه وكثير من الناس لا شجر
لهم ويحتاجون إلى الثمر ففي القول بجواز المساقاة دفع لحاجة رب الشجر والعامل ورعاية
لمصلحة الجانبين (٣)

(١) المغني ٥ / ٥٥٤ .

(٢) المبسوط ٢٣ / ١٣ .

(٣) المرجع السابق ٢٣ / ١٧ .

ونوقش هذا الاستدلال بالمعقول بما يلي :

إن قياس المساقاة على المضاربة قياس مع الفارق ، لأن المضاربة تصح بدون تحديد المدة ولا تتعقد لازمة أصلاً وليست المساقاة كذلك ، لأنها يشترط فيها تحديد المدة وتتعدّد لازمة كالإجارة والمزارعة (١)

ويمكن أن يجاب على هذه المناقشة :

إن الشرط في كل من المساقاة والمضاربة هو الشركة في الربح الناتج من عمل جانب ومال من جانب آخر مع حاجة الناس إلى كل منهما ، أما تحديد المدة أو عدمه ، واللزوم وعدمه فهي أوصاف ذكرت على أنها فروق فهي لا تؤثر في الحكم.

المذهب الثاني : للإمام أبي حنيفة ، حيث قال : إن المساقاة غير جائزة. (٢)

واستدل على ذلك بالسنة والمعقول :

أما السنة :

فبما رواه رافع بن خديج أن رسول الله - ﷺ - قال له في حائط - أي بستان - لا تستأجره بشيء منه " (٣)

ووجه الدلالة من هذا الحديث : ظاهر النهي الصريح منه ﷺ عن استئجار البستان بشيء من الخارج منه قل أو كثر وهذا عين المساقاة.

ونوقش هذا الاستدلال بعدة وجوه :

الأول : يمكن حمل النهي الوارد في حديث رافع على اقتران المساقاة ببعض الشروط التي تفسد عقد المساقاة ، كاشتراط صاحب البستان ثمر شجر معين له وقد بين هذا رافع نفسه حيث فسر المنهي عنه في حديثه بما لا يختلف في فسادة فإنه قال : " كنا أكثر أهل المدينة حقلاً ، وكان أحدنا يكري أرضه فيقول " هذه القطعة لي وهذه لك ، فربما أخرجت ذه ولم تخرج ذه ، فنهاء النبي ﷺ " (٤)

(١) تبين الحقائق ٥ / ٢٧٨.

(٢) المبسوط ٢٣ / ١٧ ، بدائع الصنائع ٨ / ٣٨٣١.

(٣) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير ٤ / ٢٦٣ عن رافع بن خديج بلفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مر بحائط فأعجبه فقال لمن هذا ؟ قلت هو لي : قال : " من أين لك هذا ؟ قلت استأجرته ، قال : " لا تستأجره بشيء

(٤) فتح الباري ٥ / ١٨ ، ١٩.

الثاني: أن الصحابة أنكروه على سيدنا رافع ، قال سيدنا زيد بن ثابت - رضي الله عنه - وقد حكى له حديث رافع : أنا أعلم بذلك منه، وإنما سمع النبي ﷺ رجلين قد اقتتلا فقال إن كان هذا شأنكم فلا تكروا المزارع(١).

الثالث : أنه لو قدر معارضة حديث رافع لأحاديث الجواز ، وامتنع الجمع بينهما لكان منسوخا قطعا بلا ريب ، لأنه لا بد من نسخ أحد الخبرين ، ويستحيل نسخ أحاديث الجواز لاستمرار العمل بها من النبي - ﷺ - إلى وفاته وكذلك الخلفاء الراشدين ، وهذا أمر معلوم عند من له علم بالسير كما تقدم ذكره فيتعين نسخ حديث رافع ، هذا فضلا عن أن الأحاديث إذا ظهر تعارض فيها عن النبي - ﷺ - فإن فعل الصحابة من بعده يصلح ترجيحاً لبعضها عن البعض الآخر وقد تقدم بيان عمل الخلفاء الراشدين وأهلهم وغيرهم من الصحابة بالمساقاة (٢).

وأستدل على عدم جواز المساقاة بالمعقول بما يلي :

١ - أن الاستئجار ببعض الخارج من النصف والثلث والربع ونحوه استئجار ببذل مجهول وأنه لا يجوز كما في الإجارة (٣)

ونوقش هذا الاستدلال: بأن قياس المساقاة على الإجارة قياس مع الفارق ، لأن الإجارة لا يصح عقدها إلا على موجود ومعلوم وأما المساقاة فلما لم يصح عقدها على موجود معلوم - كأن يكون التمر قد نضج بالفعل وليس في حاجة إلى المساقاة، أو أن يكون أجر العامل ليس شائعا - جاز عقدها على معدوم مجهول(٤).

٢ - واستدلوا أيضا بأنه لا تجوز قياسا على تنمية الماشية ببعض نمائها(٥).

ونوقش هذا الاستدلال بأنه قياس مع الفارق أيضا ، لأن الماشية لا يتعذر بيعها عند العجز عن القيام بها وأما الثمر فإنه يتعذر بيعه قبل نضجه عند العجز عن

(١) عون المعبود ٩ / ٢٠٠.

(٢) عون المعبود ٩ / ٢٠٢ ، والمغني ٥ / ٥٥٥ .

(٣) بدائع الصنائع ٨ / ٣٨٠٨ ، وحاشية رد المحتار ٦ / ٢٨٥ .

(٤) الحاوي ٩ / ١٦٤ .

((٥)) حاشية رد المحتار ٦ / ٢٨٥ .

القيام به وتعهده فجازت المساقاة رفعاً للضرر الواقع على صاحب الثمر وجلباً لمصلحة العامل وهذا الضرر غير متصور في الماشية كما تبين.(١)

المذهب الثالث : للإمام إبراهيم النخعي حيث يرى أن المساقاة مكروهة (٢) ولم أعثر على أدلة خاصة به والظاهر أنه استدل بما استدل به أبو حنيفة - القائل بعدم جواز المساقاة وأنها منهي عنها ويمكن استنباط وجه الدلالة عنده بحمل هذا النهي على الكراهة .

وبناقش بنفس المناقشة التي وجهت إلى القائلين بعدم الجواز .

الترجيح :

بعد عرض مذاهب الفقهاء في حكم عقد المساقاة وأدلة كل مذهب ومناقشته وما ورد على بعضها من أجوبة يتضح : أن مذهب جمهور الفقهاء القائل بمشروعية عقد المساقاة هو الراجح للأسباب الآتية :

- ١ - قوة أدلتهم ، وسلامتها من المناقشة .
- ٢ - في القول بمشروعية المساقاة تعاون على البر والتقوى المأمور به في قوله تعالى : ﴿ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى ﴾ .(٣)
- ٣ - القول بمشروعية المساقاة فيه القضاء على مشكلة البطالة وإيجاد فرص للأيدي العاملة التي تجيد الزراعة والعناية بالأشجار .
- ٤ - دفع حاجة أهل النخيل والشجر الماسة إلى ذلك .
- ٥ - ظهور تعامل الأمة بالمساقاة وإن كان على سبيل الاستحسان لأن القياس يترك بالتعامل كما في عقد الاستصناع الذي يأبى القياس جوازه لكنه جائز استحساناً(٤) .

(١) المرجع السابق نفس الصفحة.

(٢) (المجموع شرح المذهب ١٤ / ٤٠٢ ط : دار الفكر - المحلى لابن حزم ٧ / ٦٧ .

(٣) سورة المائدة الآية (٣) .

(٤) مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر ٢ / ٤٩٩ ط : دار إحياء التراث العربي ، واللباب في شرح الكتاب ٢ / ٢٢٩ .

المبحث الثاني أركان المساقاة وشروط كل ركن أولاً : أركان المساقاة :

عقد المساقاة مثل عقد المزارعة مثل سائر عقود المعاملات الأخرى خصوصاً من حيث الأركان فأركانها على سبيل الإجمال الإيجاب والقبول وهما يستلزمان صيغة ، وعاقدان ، ومعقود عليه ،

فالصيغة : هي العبارة التي تنظم عقد المساقاة وتعبر عن الإيجاب والقبول. والعاقدان هما رب الشجر والعامل الذي يسقى هذا الشجر ويقوم بإصلاحه ، والمعقود عليه هو الشجر المراد سقيه والعمل عليه ، والثمر الخارج من هذا الشجر المقدر فيه أجر هذا العامل

وفيما يلي تفصيل هذه الأركان مع بيان شروط كل ركن وآراء الفقهاء فيه :
الركن الأول : الصيغة ويقصد بها " الإيجاب والقبول " وتتعدد بكل صيغة تدل على دفع الشجر ونحوه إلى من يعمل فيه على أن الثمرة بينهما كأن يقول صاحب البستان : ساقيتك على هذا البستان بربع ثمرته ، أو عاملتك ، أو فالحتك ، أو اعمل في بستانني هذا حتى تكمل ثمرته وبكل لفظ يؤدي معناها ، لأن العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني وهذا عند أكثر الفقهاء القائلين بجواز المساقاة (١).

الركن الثاني : العاقدان (المالك - العامل) :

ويشترط فيهما :

أ - أهلية التصرف وتتحقق هذه الأهلية بكون العاقدين عاقلين ، فلا تصح مساقاة المجنون ولا الصبي الذي لا يعقل المساقاة ولا غير المالك للتصرف لأن العقل شرط أهلية التصرف باتفاق الفقهاء. (٢)

(١) الحاوي ٩ / ١٦٨ ، وكشاف القناع ٣ / ٥٣٣ وما بعدها ، والمغني لابن قدامة ٥ / ٥٦٤ ، وجواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام ٢٧ / ٥٥ .

(٢) بدائع الصنائع ٨ / ٣٨٣١ ، ومجمع الأنهر ٢ / ٥٣٢ .

وأما البلوغ فليس بشرط عند الحنفية ، وكذا الحرية فتجوز مساقاة الصبي المأذون، لأن المساقاة استئجار ببعض الخارج ، والصبي المأذون يملك الإجارة لأنها تجارة فيملك المساقاة.(١)

وكذا العبد المأذون له في التجارة يملك المساقاة قياسا على الصبي المأذون.(٢)

ب - الشرط الثاني من الشروط الواجب توافرها في العاقدين :

أن يكون مالك الشجر مسلما وهذا الشرط قال به الإمام مالك حيث يرى إنه إذا كان مالك الشجر غير مسلم والعامل مسلما يحرم ذلك ، لما فيه بعض إذلال للمسلم ، وقال ابن القاسم من المالكية بكرهه ذلك (٣)

ويمكن الرد على قول الإمام مالك بأن هذه الصورة في المساقاة ليس فيها إذلال للمسلم ، لأن العامل في المساقاة يجب أن يلتزم بالقيام بأعمال المساقاة بغض النظر عما إذا كان مالك الشجر مسلما أم غير مسلم وفي هذه الحالة ينتفي الإذلال للعامل لأنه قام بواجبه على أكمل وجه وليس لرب الشجر عليه إلا القيام بواجبه نحو عقد المساقاة وقد أتى به

مسألة: حكم مساقاة أحد الشريكين شريكة :

ذهب فقهاء الحنفية إلى القول بعدم جواز أن يساقي الشريك شريكه إذا شرط للشريك العامل جزء زائد عما يستحقه بالملك كأن كان له النصف فشرط له الثلثين ، لأن في المساقاة معنى الإجارة ، ولا يجوز الاستئجار لعمل فيه الأجير شريك المستأجر.

أما لو شرط أن يكون الخارج لهما على قدر ملكيهما تجوز المساقاة ويكون الشريك العامل هذا معين لصاحبه في العمل ومتبرع فلا يأخذ عوضا ، وفي هذه الحالة لم يتحقق الاستئجار فتجوز المساقاة كما بينا (٤).

(١) بدائع الصنائع ٨ / ٣٨٣١ ، مجمع الأنهر ٢ / ٤٩٩ .

(٢) المراجع السابقة نفس الموضع .

(٣) مواهب الجليل ٥ / ٣٨٣ .

(٤) بدائع الصنائع ٨ / ٣٨٣٣ .

الركن الثالث - المعقود عليه :

والمعقود عليه في المساواة يشمل :

١ - الشجر المساقى عليه .

٢ - عمل العامل في المساواة .

٣ - أجر العامل من الثمر الخارج من الشجر المساقى عليه .

ثانياً: شروط صحة المساواة:

شروط الشجر المساقى عليه :

أ - أن يكون الشجر المساقى عليه معلوماً فلا تجوز المساواة على شجر مجهول ؛ لأن العقد على مجهول يؤدي إلى التنازع والتخاصم بين المتعاقدين وهذا الشرط محل اتفاق بين القائلين بمشروعية عقد المساواة.(١)

ب - أن يكون الشجر المساقى عليه معيناً فإن كان مجهولاً بأن قال المالك للعامل قد ساقيتك على أحد حوائطي ، أو على ما شئت من الحوائط لا يصح ، لأن عقد المساواة من عقود المعاوضات وهذا الشرط باتفاق القائلين بمشروعية المساواة(٢)

ج - أن يكون الشجر مغروساً ، فلا تصح المساواة على غير مغروس ، كأن يأتي رب الشجر بصغار النخل ويسلمه للعامل ليغرسه ويتعهد على أن تكون الثمرة بينهما ؛ لأن الغرس ليس ممن عمل المساواة فضمه إليه يفسده .

د - ألا يكون الشجر قد بدا صلاح ثمرة ، لأن مساواة ما بدا صلاحه من الثمر ليس فيه عمل ولا ضرورة داعية إلى المساواة إذ لا ضرر على رب الشجر في ثمره بعد بدو الصلاح ، حيث يجوز بيعه في ذلك الوقت وإذا جاز بيعه جازت الإجارة به فأعطاء الثمر بعد بدو صلاحه لمن يقوم بما يحتاجه هذا الثمر مقابل جزء منها جائز على وجه الإجارة غير جائز على وجه المساواة (٣).

(١) المرجع السابق نفس الصفحة.

(٢) المرجع السابق نفس الصفحة ، والمغني ٥ / ٥٦٤.

(٣) بداية المجتهد ٢ / ٣٦٨.

وذهب الصاحبان إلى عدم اشتراط هذا الشرط في الشجر المساقى عليه ؛ لأنه إذا جازت المساقاة على الشجر قبل أن يخلق الثمر فهي بعد ظهور الصلاح أجوز لقلة الغرر إلا إذا كان قد تناهى صلاحه (١) .

وبترجح لدى اشتراط عدم ظهور صلاح الثمر لأن المساقاة جائزة على خلاف القياس لضرورة صلاح الثمر وعدم إهداره وما أبيع للضرورة يقدر بقدرها ولا ضرورة في عمل المساقاة بعد ظهور صلاح الثمر ، وإذا احتاج الثمر إلى عمل فإنه سيكون عملا خفيفا يمكن لرب الشجر القيام به عن طريق الإجارة المتفق على جوازها .

هـ- أن لا يكون الشجر المساقى عليه مما يخلف أي لا يثمر ثمر بعد أخرى قبل قطع الأولى في نفس العام كالنوز والقصب وهذا الشرط قال به فقهاء المالكية وحجتهم : أنه اجتمعت فيه معان مؤثرة في منع المساقاة من أنه ليس له ساق كالشجر الذي هو أصل في المساقاة ولا هو بمنزلة الزرع الذي يوجد مرة في السنة الذي إذا أخذ لم يبق أصل.

وبنظرة متأنية في شروط الشجر المساقى عليه يتبادر إلى الذهن سؤال مفاده : هل تجوز المساقاة في مطلق الأشجار أم أنها تجوز في شجر دون شجر آخر ؟
والجواب عنه :

يرى الصاحبان من الحنفية جواز المساقاة لمطلق الشجر سواء كان له ثمر كالنخل والتين والتفاح أو ليس له ثمر كالكاפור والسنط والصفصاف والجوز أو له ثمر غير مقصود كالصنوبر والرطاب وهو جمع رطبة وهي التي يسميها المصريون برسيم وأصول الباذنجان لأنها من أنواع الشجر ؛ لأن الشجر عندهما اسم لماله ساق فكل ماله ساق تجوز مساقاته (٢) .

واستدلوا على جواز المساقاة للشجر الذي لا ثمر له أولاً ثمر لكن لا يقصد عرفاً

(١) بدائع الصنائع ٨ / ٣٨٣٢ .

(٢) بدائع الصنائع ٨ / ٣٨٣٤ ، وشرح العيني على كنز الدقائق المسمى برمز الحقائق للشيخ المحدث بدر الدين أبي محمد محمود بن أحمد العيني المتوفى سنة ٨٥٥ هـ وبهامشه شرح الطائي للعلامة الشيخ مصطفى بن أبي عبد الله النعمان الطائف ٢٦ / ١٩٩ من منشورات إدارة القرآن والعلوم الإسلامية واللباب ٢ / ٢٣٤ .

أ - بأن الحاجة ماسة إلى جواز مساقاة هذا النوع من الشجر كما هي ماسة إلى جواز مساقاة الشجر المثمر المقصود عرفاً.

ب - أن خبير على سعتها يبعد أن تكون خالية من الشجر الذي لا يثمر أو يثمر ثمرة غير مقصودة (١) .

الشروط الواجب توافرها في عمل العامل :

من المتعارف عليه في عقد المساقاة أن العامل يقوم بالأعمال التي تزيد في نماء الثمر وتصلحه ، كسقي الشجر ، وتنقية الحشائش الضارة ، وإصلاح الحفر التي يجتمع فيها الماء حول جذوع الشجر وتفسده ، وأن يقوم بتلقيح الشجر والمحافظة على البستان وحفظ الثمر وغير ذلك من الأعمال (٢).

ويشترط في هذه الأعمال الشروط الآتية :

١ - أن تكون معلومة ؛ لأن العمل معقود عليه والعقد على المجهول لا يصح ؛ لأنه يؤدي إلى التنازع والتخاصم وبالتالي تنعدم الفائدة من المساقاة ، وهي التعاون وتحقق المصلحة بين طرفي العقد (المالك والعامل) (٣) .

٢ - أن لا يشترط رب الشجر على العامل عملاً ليس من جنس أعمال المساقاة مثل بناء الجدار وغيره (٤) .

٣ - التخلية بين العامل والأشجار ، وتتصور بتسليم رب الشجر أشجاره للعامل ليتمكن العامل من العمل متى شاء تحقيقاً لمقاصد العقد فلو شرطاً العمل عليهما فسدت المساقاة لانعدام التخلية.(٥)

(١) اللباب ٢ / ٢٣٤ ، مجمع الأنهر ٢ / ٥٠٥ .

(٢) بداية المجتهد ٢ / ٣٨٤ .

(٣) المرجع السابق نفس الصفحة .

(٤) بدائع الصنائع ٨ / ٣٨٣٣ .

(٥) بدائع الصنائع ٨ / ٣٨٣٢ .

الشروط الواجب توافرها في الثمر الخارج المعد أجرا للعامل :

يلزم في عقد المساواة اشتراط جزء من الثمر للعامل مقابل قيامه بالأعمال التي تلزم لنمو الثمر ونضجه فإذا لم يشترط للعامل جزء من الثمر كان عمله مع المالك على سبيل التطوع والتعاون لا يستحق عليه أجرا ، وليس على سبيل المساواة ؛ لأن من شروط صحة المساواة اشتراط جزء معين من الثمر للعامل ، ولصحة هذا الشرط وصحة المساواة يشترط لأجر العامل شروط هي :

١ - أن يكون الثمر الخارج لهما أي للعامل ورب الشجر ، فلو شرطا أن يكون لأحدهما فسدت المساواة لانعدام الشركة فيها ، والشركة أصل في المساواة ، أما لو كان الخارج للمالك فقط كان عمل العامل على سبيل التبرع وليس من المساواة في شيء ، وإن كان الخارج للعامل فقط كان تسليم المالك شجره للمالك على سبيل القرض ولم يكن مساواة (١) .

٢ - أن يكون نصيب كل منهما - المالك والعامل - معلوما كثيرا كان أو قليلا ، والمراد بكونه معلوما : العلم بالجزئية كالنصف والثلث والرابع ، فإذا كان نصيبهما أو أحدهما مبهما مثل السهم ، والجزء ، والنصيب ، والحظ ، ونحوه لا تجوز المساواة ، لأنه يقع على القليل والكثير فيتحقق الغرر المؤدي إلى المنازعة (٢) .

٣ - أن يكون نصيب كل من المالك والعامل جزءا شائعا في جميع البستان كنصف الخارج ، أو ربعه ، أو ثمنه ، لأحدهما فيفهم أن الباقي للآخر كما هو مبين في الشرط السابق ، فإذا عقدت المساواة على قنطار أو قنطارين من الثمر مثلا فلا تجوز المساواة لتوقع الضرر لأي منها فيتضرر العامل إذا لم ينتج الشجر هذا المقدار ، ويتضرر المالك إذا أنتج الشجر هذا المقدار المقدر للعامل فقط ، ولا يجوز أيضا أن تتم المساواة على أن يكون نصيب العامل ثمر شجر بعينه من البستان لتوقع حدوث ضرر أيضا لأحدهما ، فضرر العامل يتأتى من احتمال عدم خروج ثمار من هذا الشجر المعين فيعمل وينصرف بغير شيء ، وضرر المالك يتأتى من احتمال أن لا

(١) بدائع الصنائع ٨ / ٣٨٣٢ .

(٢) المراجع السابق .

ينتج في البستان سوى هذا الشجر المعين فيسلم الشجر للعامل ويأخذ العامل الثمر الخارج كله وينصرف المالك بغير شيء وهذا قطعاً يؤدي إلى المنازعة.

ولهذا نهى الرسول ﷺ - عن المزارعة والمساواة التي يجعل فيها للمالك ناحية بعينها وللعامل ناحية أخرى بعينها (١) وشاهد ذلك ما جاء عن سيدنا رافع بن خديج قال : حدثني عمي أنهم كانوا يكرون الأرض على عهد رسول الله - ﷺ - بما ينبت على الأربعة ، أو شيء يستثنيه صاحب الأرض ، فنهى النبي ﷺ عن ذلك ، فقلت لرافع فكيف هي بالدينار والدرهم ؟ فقال رافع : ليس بها بأس بالدينار والدرهم (٢)

٤ - أن يكون نصيب العامل من نفس ثمر الشجر المعقود عليه في المساواة ومن نفس ثمر السنة المساقي فيها ، فلا يصح أن يأخذ أجره من ثمر غير ثمر الشجر الذي ساقاه أو في سنة غير السنة التي ساقى فيها ؛ لأن محل المساواة وموضوعها هو الثمر الخارج نتيجة عمل العامل وجعل الأجر جزء من الخارج أصل في المساواة .
وبعد أن انتهيت بحمد الله وتوفيقه من بيان أركان المساواة وشروط كل ركن منها أرى أنه من الواجب أن أتحدث في هذا المبحث عقب هذه الشروط عن المدة في المساواة وما يلزم لها من شروط حيث إن ذكر المدة في المساواة يعد من شروط صحة المساواة.

المدة وشروطها في المساواة :

المدة تعنى الوقت والوقت في المساواة له اعتباران :

١ - وقت باعتبار أنه شرط في جواز المساواة ، وهذا النوع قد سبقت الإشارة إليه وذكر آراء الفقهاء فيه بالتفصيل أثناء الحديث عن الشروط التي ترجع إلى الشجر المساقي عليه - وهو شرط عدم بدو صلاح الثمر

(١) بدائع الصنائع ٨ / ٣٨٣٢ .

(٢) أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الحرث والمزارعة باب كراء الأرض بالذهب والفضة.

٢ - وأما الاعتبار الثاني للوقت في المساقاة فهو : وقت هو شرط في صحة العقد وهو المحدد لمدتها ، وهو ما أقصد تفصيل القول فيه في هذا الموضع بذكر شروط المدة المشترطة لصحة عقد المساقاة وهذه الشروط كالتالي :

أ - أن تكون المدة مقدرة معلومة البدء والانتهاه وهذا في القياس عند الصاحبين.

واستدلوا لهذا بما يلي :

إن المساقاة عقد لازم فوجب تقديره بمدة كالإجارة ، ولأن ترك المدة يؤدي إلى الجهالة المفضية إلى المنازعة وهذا منهي عنه شرعا (١) .

وأما وجه الاستحسان عندهما : فهو عدم اشتراط هذا الشرط ، فيجوز عندهم أن تكون المدة غير مقدرة وتقع على أول ثمرة وإلى الجذاذ وهو الحصاد.

واستدلوا على هذا : بأن العوض في المساقاة لما كان جزء من الثمر الخارج كان ذلك دليلا على أن العاقدين يريدان مدة تحصل الثمرة فيها .

كما استدلوا بأن الإدراك له أوان معلوم في العادة ، والمراد في المساقاة أن إيفاء العقد مقصود في المساقاة إلى إدراك الثمار والثابت بالعادة كالثابت بالشرط فصارت المدة معلومة ، وإن تقدم أو تأخر فذلك يسير لا تقع المنازعة بسببه (٢) .

والراجع :

بعد النظر في آراء الفقهاء وأدلتهم بشأن اشتراط المدة في المساقاة وعدمه يترجح لدى ما ذهب إليه أصحاب الرأي الأول من ضرورة اشتراط المدة وبيانها بتحديد موعد البدء والانتهاه وبخاصة إذا كانت مواعيد إدراك الثمر غير منتظمة حسما لمادة الخلاف والمنازعة بين المتعاقدين ، أما إذا كان موعد الإدراك منتظما فإن العرف الجاري يقوم مقام الاشتراط اللفظي في العقد فلا تحدث الجهالة المفضية إلى المنازعة ، وإذا حدث مع هذا العرف اشتراط جازت المساقاة أيضا ؛ لأنه يكون بمثابة التأكيد على ما عليه عرف إدراك الثمر.

(١) بدائع الصنائع ٨ / ٣٨١٩ .

(٢) المرجع السابق نفس الصفحة ، والمبسوط ٢٣ / ١٠٣ .

ب - أن لا تكون المدة قصيرة بحيث لا ينضج فيها الثمر فإن ساقاه على نخل أو شجر لمدة أشهر معلومة ويعلم أنها لا تخرج ثمر في هذه الأشهر لكون هذه الأشهر أقل من المدة التي ينضج فيها الثمر ، فهذه المساواة فاسدة ؛ لأن موضوع المساواة ومقصودها الشركة في الخارج ، وقصر المدة يمنع هذا المقصود فيكون مفسدا للعقد (١) .

ج- أن لا تكون المدة طويلة : بحيث لا تكون المدة التي لا يعيش إليها العاقدان غالبا (٢) .

المبحث الثالث الآثار المترتبة على المساواة

ووجه تمويلها للنشاط الزراعي

أولا : الآثار المترتبة على المساواة :

إذا عقدت المساواة مستوفية أركانها وشروطها فإنها تكون مساواة صحيحة وتترتب عليها الآثار الآتية :

١ - أن كل ما كان من عمل المعاملة مما يحتاج إليه الشجر من السقي وإصلاح النهر والحفظ والتلقيح للنخل فعلى العامل ؛ لأنها من توابع المعقود عليه فيتناوله العقد ، وكل ما كان من باب النفقة على الشجر والكرم وتقليب الأرض ونحو ذلك فعليهما على قدر حقيهما ، لأن عقد المساواة لم يتناوله لا مقصودا ولا ضرورة ، وكذلك ما يلزم لحصاد الثمر ، وبعبارة أدق تكاليف الحصاد كالجذاذ والقطاف ونحوهما ، وعلى هذا أكثر الفقهاء ؛ لأن الحصاد يكون بعد انتهاء عمل المساواة فلا يكون من حكمها (٣)

(١) المبسوط ٢٣ / ١٠٤ ، المهذب ١ / ٣٩٦ ، شرح منتهى الإرادات ٢ / ٤٨٢ ، جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام ٢٧ / ٦٥ .

(٢) تبين الحقائق ٥ / ٢٧٩ .

(٣) بدائع الصنائع ٨ / ٣٨٣٤ .

٢ - أن يكون الخارج بينها على الشرط المتفق عليه عند العقد ، وإذا لم يخرج الشجر شيئاً فلا شيء لواحد منهما (١)

٣ - أن العامل في المساقاة لا يملك أن يدفع الشجر إلى غيره معاملة إلا إذا قال له المالك : اعمل فيه برأيك ؛ لأن الدفع إلى غير العامل إثبات الشركة في مال الغير - وهو المالك هنا - بغير إذنه والتصرف في مال الغير بغير إذنه لا يصح ، أما إذا قال له المالك اعمل فيه برأيك فقد أذن له فصح ، ولو لم يقل له ذلك ودفع العامل إلى رجل آخر معاملة فعمل فيه وأسفر عمله عن وجود ثمر خارج فهذا الثمر الخارج يكون للمالك ولا أجر للعامل الأول على المالك ، ولأن استحقاق العامل الأول يكون بالشرط وهو شرط العمل ولم يوجد العمل من قبله لا بنفسه ولا بغيره أيضاً ؛ لأن المالك لم يأذن له بدفع الأشجار إلى غيره ، فلا يستحق العامل الأول الأجر من المالك ؛ لأن عقده معه لم يصح فلم يكن عمل العامل الثاني مضافاً إلى عمل العامل الأول ، ويرجع العامل الثاني بأجر مثل عمله يوم عمل على العامل الأول ؛ لأنه عمل له بأمره فاستحق أجر المثل (٢).

ومما تجدر الإشارة إليه هنا أن عدم إلزام المالك بأجر مثل العمل يوم تم هذا العمل قضاء فقط وأما ديانة أي فيما بينه وبين الله تعالى فيجب دفعه حتى لا يكون آكلاً مال غيره بدون وجه حق

هذا إذا كان هناك خارج عن طريق عمل العامل الثاني .

أما إذا هلك الثمر في يده من غير عمله وهو في رعوس النخل فلا ضمان على العامل الأول ولا على العامل الثاني ، لانعدام الغصب من واحد منهما وهو تقويت يد الملك ، ولو هلك من عمله في أمر خالف فيه أمر العامل الأول فالضمان على العامل الآخر لصاحب النخل ؛ لأن خلاف العامل الثاني لأمر العامل الأول قطع نسبة العمل إليه ، فبقى العامل الثاني متلفاً على المالك ماله فكان الضمان عليه .

(١) بدائع الصنائع ٨ / ٣٨٣٥ .

(٢) بدائع الصنائع ٨ / ٣٨٣٥ .

ولو هلك في يد العامل الثاني من عمله في أمر لم يخالف فيه أمر العامل الأول فلصاحب النخل أن يضمن أيهما شاء ؛ لأن العامل الثاني لما لم يوجد فيه خلاف لأمر العامل الأول بقي عمل العامل الثاني مضافا إلى الأول بأمره وصح نسبة العمل إلى الثاني ؛ لأنه المباشر فكان تضمين العامل الأول باعتبار إضافة العمل إليه لعدم مخالفة أمره في العمل ، وتضمين العامل الثاني على معنى غاصب الغصب ، فإذا اختار المالك تضمين الأول لم يرجع إلى الآخر بشيء ؛ لأنه عمل بأمر الأول ، فلو رجع المالك على العامل الثاني لرجع العامل الثاني على العامل الأول فلا يفيد ، وإذا اختار المالك تضمين الآخر يرجع على الأول ؛ لأنه غره في هذا العقد فيرجع عليه بضمان الغرر وهو ضمان السلامة

وهذا كله إذا لم يقل المالك للعامل اعمل فيه برأيك ، أما إذا قالها فيجوز أن يدفعها - أي الأشجار - إلى غيره ليعمل فيها (١) .

٤ - أن صفة عقد المساقاة الصحيح ، اللزوم فلا يجوز لأحد من العاقلين الانفراد بفسخه بدون رضا العاقد الآخر وهذا الأثر قال به الصحابان من الحنفية (٢)

واستدلوا لذلك بما يلي :

أ - من الكتاب :

قوله تعالى ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ (٣) فالأمر بالوفاء بالعقود أصل عام للزوم وعقد المساقاة عقد كسائر العقود فيكون لازما .

ب - من السنة :

ما ورد عن ابن عباس - رضي الله عنها - قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " لا ضرر ولا ضرار " (٤) .

(١) بدائع الصنائع ٨ / ٣٨٣٦ .

(٢) بدائع الصنائع ٨ / ٣٨٣٥ .

(٣) سورة المائدة الآية (١) .

(٤) مجمع الزوائد ٤ / ١١٠ باب لا ضرر ولا ضرار ط : دار الكتاب العربي سنة ١٤٠٧ هـ - وأخرجه أيضا الحاكم في المستدرک وقال هذا الحديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرج به برقم ٢٣٤٥ ط : دار الكتب العلمية - بيروت ط : الأولى سنة ١٤١١ هـ - ١٩٩٠ م .

ووجه الضرر في القول بعدم لزوم المساقاة :

أن العقد لو كان غير لازم لجاز لرب الشجر فسخه إذا أدركت الثمرة فيسقط حق العامل ، وهذا ضرر يتنافى مع النهي الوارد في الحديث ، فوجب الامتثال التام لهذا الحديث .

ج- واستدلوا أيضا بالمعقول : وهو أن عقد المساقاة عقد معاوضة فكان لازماً كالإجارة (١).

ونوقش هذا الاستدلال بأن قياس المساقاة على الإجارة قياس مع الفارق فالإجارة بيع للمنافع فلا بد من كونها لازمة ، ولأن العوض فيها مقدر معلوم فأشبهت البيع والمساقاة ليست كذلك (٢) .

ويمكن أن يجاب على هذه المناقشة بأن المساقاة يمكن عدها نوعاً من البيع فتكون لازمة أيضاً مثل الإجارة والبيع ؛ لأن المساقاة عقد على بيع منفعة العامل، أو عقد على بيع منفعة الشجر بجزء من الخارج فلا وجه لهذه المناقشة .

ثانياً : أوجه تمويل المساقاة للنشاط الزراعي:

يطيب لي أن أستهل هذا الموضوع بقوله تعالى: ﴿هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً ۖ لَكُمْ مِنْهُ شَرَابٌ وَمِنْهُ شَجَرٌ فِيهِ تُسِيمُونَ * يَقُولُ تَعَالَى ذِكْرُهُ: وَالَّذِي أَنْعَمَ عَلَيْكُمْ هَذِهِ النِّعَمَ... شَجَرٌ فِيهِ تُسِيمُونَ * يُنْبِتُ لَكُمْ بِهِ الزَّرْعَ وَالزَّيْتُونَ وَالنَّخِيلَ وَالْأَعْنَابَ وَمِنْ كُلِّ النَّمْرَاتِ ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ﴾ (٣) .

ففي هذه الآية الكريمة يذكر المولى عز وجل نعمة من أعظم النعم التي أنعم الله بها على عباده وهي نعمة الماء الذي يعد عنصر مهماً من عناصر الحياة لكل كائن حي - إنسان - حيوان - نبات ، فبه تستمر الحياة ، وتحضر الأرض، ويفقده يموت الإنسان والطير وتصبح الأرض جرداء بعد أن أصبح نباتها هشيماً تذروه الرياح

(١) المرجع السابق نفس الصفحة.

(٢) المرجع السابق نفس الصفحة.

(٣) النحل الآية ١٠ ، ١١ .

، يقول تعالى ﴿ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ ﴾ (١) ومن فضل الله تبارك وتعالى على عباده أن جعل الماء عذبا زلالا سائغا شرابه ، ولم يجعله ملحا أجابا ولينبت لهم به الزرع ، والزيتون ، والأعناب ، وسائر الثمرات على اختلاف صنوفها وطعومها وأشكالها ، وألوانها ، وروائحها ، ولهذا ختمت الآية بقوله تعالى : ﴿ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴾ أي في هذه النعم وهذا الامتتان من الله دلالة وحجة على أنه لا إله إلا الله (٢) .

ويقول سبحانه وتعالى مبينا حاجة البشر بصفة عامة إلى الماء : ﴿ وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ ۖ وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا * لِّنُحْيِيَ بِهِ بَلْدَةً مَّيْتًا وَنُسْقِيَهُ مِمَّا خَلَقْنَا أَنْعَامًا وَأَنْآسِيَّ كَثِيرًا * وَلَقَدْ صَرَّفْنَاهُ بَيْنَهُمْ لِيَذَكَّرُوا فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا ﴾ (٣) .

والمعنى - والله أعلم بمراده - تعدد الفوائد والأغراض المستفادة من إنزال الماء ، وهي على سبيل المثال لا الحصر : تطهير للإنسان من النجاسة ، وإحياء الأرض الموات التي كانت قبل نزول الماء عليها ووصوله إليها جرداء لا حياة فيها ، فلما جاءها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل الثمرات ، وازينت بأنواع الأزهار .

وفى قوله سبحانه وتعالى ﴿ وَنُسْقِيَهُ مِمَّا خَلَقْنَا أَنْعَامًا وَأَنْآسِيَّ كَثِيرًا ﴾ إشارة إلى مدى حاجة البشر إلى الماء لشربه وزراعته وثمره

ومن نعم الله سبحانه وتعالى على عباده ورحمته التي لا تعد ولا تحصى : أنه أنزل الماء من السماء بقدر أي بحسب الحاجة إليه ، فلا ينزله كثيرا يفسد الأرض والعمران ، ولا قليلا فلا يكفي الزروع والثمار بل جعله بقدر الحاجة إليه من السقي ، والشرب ، والانتفاع به حتى إن الأرض التي تحتاج ماء كثيرا لزراعتها ولا تحتتمل إنزال المطر عليها يسوق إليها الماء بطريق الأنهار من بلاد أخرى ، أو يفجر فيها العيون والآبار ، فتسقى به الزروع والثمار وتشرب منه الدواب والأنعام ، ويغتسل منه بني الإنسان

(١) جزء من الآية ٣٠ من سورة الأنبياء .

(٢) الفتوحات الإلهية بتوضيح تفسير الجلالين ٢ / ٥٦١ ، وتفسير ابن كثير ٢ / ٣٢٤ ط : دار القرآن - بيروت .

(٣) سورة الفرقان الآية ٤٨ ، ٤٩ ، ٥٠ .

ويتطهر(١)، ولا شك أن هذا كله فضل من الله ورحمة فهو سبحانه القادر على كل شيء ، فكما أنزل الماء وجعله صالحا لسائر وجوه الانتفاع فهو قادر أيضا على أن يحجب هذا الماء أيضا فلا ينزل ، وإذا أنزله يجعله أجابا لا ينتفع به ، وخير شاهد على هذا وجود النوعين من الماء بجوار بعضهما البعض ، ولا يختلطان ببعضهما قال تعالى: ﴿ وَهُوَ الَّذِي مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَخًا وَحِجْرًا مَحْجُورًا ﴾ (٢).

فالذي أجرى البحرين بهذا الإعجاز قادر على أن لا ينزل الماء وإن ينزله يجعله غير صالح للانتفاع به من باب أولى ، لكن سعة فضلة بعباده أن نظم لهم هذه النعم لينعموا بها ويسعدوا بما تحويه من ثروات وخبرات قال تعالى: ﴿ وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ فَأَسْكَنَاهُ فِي الْأَرْضِ ۖ وَإِنَّا عَلَىٰ ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ ﴾ (٣) .

وبعد بيان حاجة البشرية إلى الماء وأهميته لهم يمكن القول إننا قطعنا شوطا كبيرا في بيان وجه تمويل المساقاة الصحيحة المستوفية الأركان وشرائط الصحة للنشاط الزراعي ؛ لأن المساقاة لا يمكن تحقيقها بدونه ، فالمساقاة مشتقة من السقي بالماء . وعليه فالمساقاة تعد وسيلة مباشرة وفعالة في ازدهار النشاط الزراعي ويتمثل هذا على سبيل المثال لا الحصر في النقاط التالية :

١ - بتنظيم أحكام وضوابط المساقاة والعمل بها يتسنى للبشر عمارة الأرض ، ويسهل له الاستفادة مما خلق له فيها من خيرات ، ويتعرف على أسباب العيش والحياة ، ويدل على هذا قوله تعالى : ﴿ هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذُلُولًا فَأَمْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ ۖ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ ﴾ (٤) .

(١) ينظر بحث منشور بمجلة كلية الشريعة والقانون بطنطا بعنوان (تملك الماء والتصرف فيه) للدكتور / محمد عبد ربه السبحي- العدد الحادي عشر ص ١٩٢.

(٢) سورة الفرقان الآية ٥٣.

(٣) سورة المؤمنون الآية ١٨.

(٤) سورة الملك الآية ١٥.

٢ - العمل بالمساقاة يعنى وجود مجتمع قادر على مواجهة أعباء المعيشة ومسايرة ظروف الحياة ، وتحقيق معيشة راضية يتمتع فيها بالخيرات ، وينعم بالثمرات ، ويتسع نطاق النشاط الزراعي ، ومما لاشك فيه أن هذا يعود على المجتمع بالخير العظيم والفضل الكثير في الدنيا والآخرة لقوله صلى الله عليه وسلم " ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعاً فيأكل منه طيراً أو إنساناً أو بهيمة إلا كان له به صدقه " (١) .

٣ - العمل بالمساقاة يساعد صاحب الأشجار والأرض على الانتفاع بما يملكه من مال في الحدود التي رسمها الله تعالى له ، فإن كثير من أهل النخيل والشجر يعجزون عن عمارته وسقيه لعدم خبرتهم بمجال الزراعة ، وتعاهد الأشجار ، ولا يمكن لهؤلاء الملاك الاستئجار على عمل المساقاة لسبب أو لآخر مثل عدم جود رغبة لدى المزارعين من الإقبال على هذا النوع من العمل ، أو وجود الرغبة عند العمال ، لكن لا يخفى ما في الإجارة على العمل ما فيه من إهمال لهذه الأشجار نظراً لفساد الذمم التي ابتلى بها عدد غير قليل من الناس في هذا الزمان .

٤ - أيضاً كثير من الناس لا شجر لهم ولديهم الخبرة الكافية بأمور المساقاة وما يلزم لزيادة الإنتاج ويحتاجون للثمر فيحرصون على الوصول على إنتاج أفضل ليتضاعف دخلهم، وبهذا يصبح المجتمع مجتمع متكاملًا مصداقاً لقوله تعالى ﴿أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَةَ رَبِّكَ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ﴾ (٢).

المبحث الرابع الشروط المفسدة للمساقاة والأثر المترتب عليها أولاً : الشروط المفسدة للمساقاة :

من المسلم به أن ما كان وجوده شرطاً لصحة شيء كان انعدامه مفسداً لهذا الشيء، وسبق الحديث عن شروط صحة المساقاة ضمن دراسة أركان المساقاة وشروط

(١) أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الحرث والمزراعة باب فضل الزرع والغرس إذا أكل منه.

(٢) سورة الزخرف الآية ٣٢.

كل ركن ، وأعنى بهذا أن بعض الشروط المفسدة للمساقاة قد سبقت الإشارة إليها تلميحاً ، وفي هذا الموضع يمكن بيان تلك الشروط المفسدة بصفة عامة بالتصريح على النحو التالي :

١- اشتراط كون الخارج كله لأحد طرفي عقد المساقاة رب الشجر والعامل وفساد المساقاة باشتراط هذا الشرط نظراً لمخالفة هذا الشرط لحقيقة المشاركة التي هي أصل في الشركة (١)

٢ - اشتراط أن يكون لأحدهما ثمرة أشجار بعينها ، لاحتمال أن لا يخرج سائر البستان ولا تخرج سوى هذه الأشجار، أو العكس فيتضرر الطرف الآخر ، والضرر ممنوع (٢).

٣ - اشتراط كون العمل على صاحب الأرض ، لانعدام شرط من شروط الصحة وهو التخلية.(٣)

٤ - شرط كون حفظ الثمر وحمله بعد القسمة إلى السوق مثلاً على العامل ودليل فساد المساقاة باشتراط هذا الشرط أن عقد المساقاة لا يتناول هذه الأمور.(٤)

٥ - اشتراط رب الشجر على العامل أنه إن يسقى بكلفة فيكون له ، وإن يسقى بدون كلفة فيكون له كذا ، فهذا الشرط يفسد المساقاة ؛ لأنه يعود إلى جهالة المعقود عليه فأشبهه البيع بثمن مجهول وهو لا يصح (٥)

٦ - اشتراط كون الجذاذ والقطاف على العامل ؛ لأن هذا الشرط ليس من المعاملة في شيء ، ولانعدام التعامل به أيضاً ، وهذا عند القائلين بمشروعية المساقاة من الحنفية (٦) خلافاً للجمهور القائلين بالمساقاة (٧)

(١) بدائع الصنائع ٨ / ٣٨٣٢ .

(٢) المغني ٥ / ٥٩٣ .

(٣) بدائع الصنائع ٨ / ٣٨٣٢ .

(٤) بدائع الصنائع ٨ / ٣٨٣٢ .

(٥) المغني ٥ / ٥٩٣ .

(٦) بدائع الصنائع ٨ / ٣٨٣٣ .

(٧) المغني ٥ / ٥٦٧ .

٧ - اشتراط رب الأشجار على العامل عمل تبقى منفعتة بعد انقضاء مدة المساقاة ؛ لأنه لا يقتضيه العقد ، ولا هو من ضروريات المساقاة ومقاصدها (١).

٨ - ومن الشروط المفسدة للمساقاة أيضا : شركة العامل فيما يعمل فيه لأن العامل أجبر رب الأرض واستتجار الإنسان للعمل في شيء هو فيه شريك المستأجر لا يجوز ، حتى إن النخل لو كان بين رجلين فدفعه أحدهما إلى صاحبه معاملة مدة معلومة على أن الخارج بينهما أثلاثا : ثلثاه للشريك العامل وثلثه للشريك الآخذ ، فالمساقاة فاسدة ، والخارج بينهما على قدر الملك ، ولا أجر للعامل على شريكة لأن المساقاة في معنى الإجارة ، ولا يجوز الاستتجار لعمل فيه الأجير شريك المستأجر ، وإذا عمل لا يستحق الأجر على شريكه. (٢)

ثانيا : الأثر المترتب على فساد المساقاة :

إذا اقترن عقد المساقاة بأحد الشروط المفسدة السابقة ، فإن المساقاة تفسد ويترتب عليها الآثار الآتية :

١ - أن العامل لا يجبر على العمل ؛ لأن التزامه بالعمل كان بمقتضى العقد وفساد العقد ينتفي ما يترتب عليه وهو جبر العامل على العمل (٣) .

٢ - أن الخارج كله يكون لصاحب الأرض ؛ لأن مشاركة العامل له في الخارج كان بسبب العقد وقد فسد فلا يستحق العامل شيئا ويبقى نماء الملك لصاحب الملك (٤) .

٣ - إذا فسدت المساقاة فلا يجب أجر المثل للعامل إلا إذا وجد العمل وإذا وجد العمل ووجب أجر المثل فلا يقف على الخارج بل يجب وإن لم يخرج الشجر شيئا (٥)

(١) المرجع السابق ٥ / ٥٦٥.

(٢) بدائع الصنائع ٨ / ٣٨٣٣.

(٣) بدائع الصنائع ٨ / ٣٨٣٦ ، ٣٨٣٧ .

(٤) المراجع السابقة نفس المواضع.

(٥) المراجع السابقة نفس المواضع.

المبحث الخامس فسخ عقد المساقاة والأثر المترتب عليه

أولاً : فسخ عقد المساقاة :

قد يطرأ لعقد المساقاة عذر يؤدي إلى فسخ هذا العقد ، وهذا العذر إما أن يكون من جهة صاحب البستان ، وإما أن يكون من جهة العامل ، وقد يكون الفسخ راجياً بسبب آخر على النحو التالي :

أ - عذر فسخ عقد المساقاة من جهة صاحب البستان ويتمثل في :

الدين الفادح الذي لا قضاء له إلا من ثمن هذا البستان يباع فيه ، فيفسخ العقد ويبيع البستان ويقضي منه دين الغرماء ، وهذا إذا كان قبل عمل المساقاة ، أو بعد العمل وبلوغ الثمر مبلغ الحصاد ، لإمكان الفسخ في هاتين الحالتين بدون ضرر لأي منهما .

أما إذا كان بعد المساقاة ولم يبلغ الثمر مبلغ الحصاد فلا تفسخ المساقاة في هذه الحالة ، رعاية لجانب العامل الذي سيقع عليه ضرر بسبب الفسخ ولا ذنب له فيه (١)

ب - أعذار فسخ عقد المساقاة من جهة العامل :

وهذه الأعذار كثيرة منها على سبيل المثال لا الحصر :

مرض العامل؛ لأنه يضعفه عن العمل وقد يزيد العمل هذا المرض فيتأخر برؤه والسفر ؛ لأن العامل قد يضطر للسفر لاحتياجه إليه ، والمساقاة لا تقي بحاجته . وترك حرفة إلى حرفة أخرى ؛ لأن من الحرف ما لا يغني من جوع فيحتاج إلى الانتقال إلى غيرها .

ومن الأعذار أيضاً الرجعة إلى العامل: أن يكون العامل سارقاً معروفاً بالسرقة يخاف منه سرقة الثمر، أو الأغصان قبل الإدراك لأنه في هذه الحالة يلحق بصاحب الأرض ضرراً لا ذنب له فيه فيفسخ عقد المساقاة رفعا لهذا الضرر (٢)

(١) بدائع الصنائع ٨ / ٣٨٢٦ ، ٣٨٣٧ .

(٢) بدائع الصنائع ٨ / ٣٨٢٦ ، ٣٨٢٧ ، ٣٨٣٧ ، واللباب ٢ / ١٠٥ .

ج - وأما أسباب انفساخ عقد المساقاة فهي كما يلي :

الفسخ الصريح وهو ما كان بلفظ الفسخ كما في فسخ المزارعة والإجارة .
انقضاء المدة المتفق عليها ؛ لأنها إذا انقضت فقد انتهى العقد وهو معنى الانفساخ
موت أحد المتعاقدين سواء مات قبل العمل أو بعده بلغ الثمر مبلغ الحصاد أو لم
يبلغ (١)

ثانيا : الأثر المترتب على انفساخ عقد المساقاة :

فسخ عقد المساقاة إما أن يكون قبل عمل المساقاة أو بعدها ، فإن كان قبل
المساقاة فلا شيء للعامل ؛ لأن الفسخ يظهر أثره في المستقبل بانتهاء حكمه لا في
الماضي فلا يتبين أن العقد لم يكن صحيحا حتى يجب له أجر المثل كما في المساقاة
الفاصة فكان الواجب: المسمى في العقد الصحيح وهو الخارج ولم يخرج شيء (٢) .

وإن كان الفسخ بعد عمل المساقاة فهو على التفصيل التالي :

فإن كان الثمر الذي على الشجر قد بلغ مبلغ الحصاد فالحصاد والخارج بينهما
على الشرط سواء تم الفسخ بصريحه ، أو بانتهاء المدة ، أو بموت أحد المتعاقدين .
أما لو كان الثمر الذي على الشجر لم يبلغ مبلغ الحصاد بعد فالخارج بينهما على
الشرط إذا تم الفسخ بصريحه أو بانتهاء المدة فقط ؛ لأن الثمر بينهما على الشرط ،
والعمل فيما بقي إلى وقت الحصاد عليهما ، وعلى العامل أجرة مثل نصف الأرض
وأما موت أحد المتعاقدين فيتربط عليه : أنه إذا مات صاحب الشجر، ولم يبلغ
الثمر مبلغ الحصاد فيكون العمل على العامل بخاصة ؛ لأن العقد قد انفسخ حقيقة
لوجود سبب الفسخ وهو الموت ، إلا أنه بقي العقد تقديرا دفعا للضرر عن العامل فإذا
بقي العقد كان العمل على العامل بخاصة ، وأما الثمر فيقسم على الشرط المذكور ؛
لأن في الترك إلى الحصاد رعاية للجانبين ، وفي انتهاء المساقاة قبل الحصاد إضرار

(١) بدائع الصنائع ٨ / ٣٨٣٧ .

(٢) المرجع السابق ٨ / ٣٨٢٦ ، ٣٨٣٧ .

بالعامل حيث لا خارج من هذا الشجر الذي يحصل منه على أجره ، فرعاية الجانبين أولى (١) .

هذا إذا كان الميت هو المالك أما إذا مات العامل قبل بلوغ الثمر مبلغ الحصاد ، وقال ورثته نحن نعمل على شرط المساقاة وأبي صاحب الأرض ، فالأمر إلى ورثة العامل ؛ لأن في إتلاف الثمر إضرار بالورثة ، ولا ضرر بصاحب الشجر في ترك الثمر إلى وقت الحصاد لكن إذا ترك الثمر لوقت الحصاد وعملوا هم بالمساقاة فلا أجر للورثة على عملهم ؛ لأنهم يعملون على حكم عقد أبيهم تقديراً فكأن العامل أبوهم وهم يعملون بواسطته.

أما إن أراد الورثة إتلاف الثمر بامتناعهم عن العمل بالمساقاة لم يجبروا على العمل ؛ لأن العقد قد انفسخ حقيقة بموت أبيهم إلا أنه بقي باختيارهم رعاية لهم ، فإن امتنعوا عن العمل بقي الثمر مشتركاً بينهم وبين صاحب الثمر ، فإما أن يقسم بينهم بالحصص ، وإما أن يعطيهم صاحب الشجر قدر حصتهم من الثمر ويستقل به لنفسه ، أو ينفق هو من مال نفسه إلى وقت الحصاد ثم يرجع عليهم بما أنفقه على قدر حصتهم (٢)

و جاء في مختصر القدوري رحمه الله - ما يدل على ذلك حيث قال:
"المساقاة: قال أبو حنيفة: المساقاة بجزء من الثمرة باطلة وقال أبو يوسف ومحمد: جائزة إذا ذكرنا مدة معلومة وسمياً جزاءً من الثمرة مشاعاً وتجاوز المساقاة في النخل والشجر والكرم والرطاب وأصول الباذنجان فإن دفع نخلاً فيه ثمره مساقاة والثمره تزيد بالعمل جاز وإن كانت قد انتهت لم يجز وإذا فسدت المساقاة فللعامل أجر مثله وتبطل المساقاة بالموت وتفسخ بالإعذار كما تفسخ بالإجارة(٣)".

(١) بدائع الصنائع ٨ / ٣٨٣٧ ، والهداية ٤ / ٥٧ .

(٢) بدائع الصنائع ٨ / ٣٨٣٠ ، ٣٨٣٧ ، وتبيين الحقائق ٥ / ٢٨٢ ، ٢٨٣ .

(٣) مختصر القدوري لأبي الحسين القدوري ص ١٤٤ .

ويمكن أن نستنتج من هذا الدرس ما يلي :

١-المساقاة: عبارة عن معاقدة بين طرفين بمقتضاه يدفع المالك الأشجار إلى من يقوم بسقيها وإصلاحها وعمل ما تحتاج إليه على أن يكون لهم سهم معلوم من ثمرها وركنها الإيجاب والقبول.

٢- مشروعية المساقاة مختلف فيها عند فقهاء الحنفية قال أبو حنيفة: المساقاة بجزء من الثمرة باطلة وقال أبو يوسف ومحمد: جائزة إذا ذكرنا مدة معلومة وسميا جزءاً من الثمرة مشاعاً والراجح مشروعيتها .

٣-تجوز المساقاة في النخل والشجر وكل ما يزيد بالعمل .

٤-إذا فسدت المساقاة فللعامل أجر مثله.

شروط صحة المساقاة

أن يكون العاقدان عاقلين.

أن يكون المدفوع من الشجر الذي فيه ثمرة معاملة فيما يزيد ثمره بالعمل.

أن يكون الخارج لهما، فلو شرطاً أن يكون لأحدهما فسدت.

أن يكون محل العمل وهو الشجر معلوماً.

التسليم إلى العامل وهو التخلية حتى لو شرطاً العمل عليهما فسدت لانعدام التخلية.

أن تكون المدة معلومة.

أن تكون الشركة بينهما بجزء معلوم مما يخرج (نصف أو ربع أو نحوه) .

ما يفسد المساقاة: تفسد المساقاة بتخلف شرط من شروط صحتها التي ذكرناها ؛

لأن ما كان وجوده شرطاً للصحة كان انعدامه شرطاً للإفساد.

ما يفسخ المساقاة: تنفسخ المساقاة بموت أحد العاقلين أو بالأعذار كالمرض،

والسفر البعيد مدة طويلة ونحو هذه الأعذار.

اسئلة وتدريبات على الدرس

س١- بين معنى المساواة لغة وشرعاً، وركنها، وأدلة مشروعيتها، وحكمة مشروعيتها.

س٢- ما هي شروط صحة المساواة؟ وما محل عقدها؟ مع التوضيح لكل ما تذكر.

س٣- تحدث عن شروط صحة المساواة مبيناً ما يفسدها، وما هي أسباب فسخها؟

كتبه

أ.د/ إبراهيم رمضان عطايا. أستاذ ورئيس قسم الفقه بكلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالسادات

د/ أحمد سيد أحمد عبد المقصود الشافعي. مدرس الفقه بكلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنين بالديمامون شرقية

الفصل الثاني عشر القسمة

يتوقع من الدارس بعد دراسته لهذا الدرس أن:

يبين المراد بالقسمة لغة وشرعا .

يوضح أنواع القسمة وشرعية كل نوع .

يذكر ركن القسمة وشرطها ومحاسنها.

يدرك صفات القسمة وحكمها.

معرفة كيفية القسمة.

معرفة ما يوجب نقض القسمة بعد وجودها.

هذا الفصل يقع في ستة مباحث على النحو التالي:

المبحث الأول: تعريف القسمة لغة وشرعا .

المبحث الثاني: أنواع القسمة وشرعية كل نوع .

المبحث الثالث: ركن القسمة وشرطها ومحاسنها.

المبحث الرابع: صفات القسمة وحكمها.

المبحث الخامس: كيفية القسمة .

المبحث السادس: ما يوجب نقض القسمة بعد وجودها.

المبحث الأول

تعريف القسمة

أولاً: تعريف القسمة لغة:

عبارة عن إفراز النصيب، والقسم بكسر القاف وسكون السين الحظ والنصيب (١)

ثانياً: تعريف القسمة شرعاً:

عبارة عن إفراز بعض الأنصباء عن بعض، ومبادلة بعض ببعض.

شرح التعريف:

إنه ما من جزأين من العين المشتركة لا يتجزآن قبل القسمة، إلا وأحدهما ملك أحد الشريكين، والآخر ملك صاحبه غير عين، فكان نصف العين مملوكاً لهذا،

(١) مختار الصحاح مادة قسم، وبدائع الصنائع ١٨/٧.

والنصف مملوكا لذاك على الشيوع، فإذا قسمت بينهما نصفين، والأجزاء المملوكة لكل واحد منهما شائعة غير معينة، فتجتمع بالقسمة في نصيبه دون نصيب صاحبه، فلا بد وأن يجتمع في نصيب كل واحد منهما أجزاء، بعضها مملوكة له، وبعضها مملوكة لصاحبه على الشيوع .

فلو لم تقع القسمة مبادلة في بعض أجزاء المقسوم، لم يكن المقسوم كله ملكا للمقسوم عليه، بل يكون بعضه ملك صاحبه، فكانت القسمة منهما بالتراضي، أو بطلبها من القاضي رضا من كل واحد منهما بزوال ملكه عن نصف نصيبه بعوض - وهو نصف نصيب صاحبه - وهو تفسير المبادلة، فكانت القسمة في حق الأجزاء المملوكة له إفرارا وتمييزا، أو تعيينا لها في الملك وفي حق الأجزاء المملوكة لصاحبه معاوضة، وهي مبادلة بعض الأجزاء المجتمعة في نصيبه ببعض الأجزاء المجتمعة في نصيب صاحبه، فكانت إفرار بعض الأنصباء ومعاوضة البعض ضرورة، وهذا هو حقيقة القسمة المعقولة في الأملاك المشتركة، فكان معنى المعاوضة لازما في كل قسمة شرعية، إلا أنه أعطى لها حكم الإفرار في ذوات الأمثال في بعض الأحكام ؛ لأن المأخوذ من العوض مثل المتروك من المعوض، فجعل كأنه يأخذ عين حقه بمنزلة المقرض، حتى كان لكل واحد منهما أن يأخذ نصيبه من غير رضا صاحبه، فجعل إفرارا حكما، وهذا المعنى لا يوجد في غير ذوات الأمثال (١).

وفي "فتح القدير": "القسمة لا تعرى عن معنى المبادلة؛ لأن ما يجتمع لأحدهما بعضه كان له وبعضه كان لصاحبه فهو يأخذه عوضا عما بقي من حقه في نصيب صاحبه فكان مبادلة وإفرارا، والإفرار هو الظاهر في المكيلات والموزونات لعدم التفاوت، حتى كان لأحدهما أن يأخذ نصيبه حال غيبة صاحبه، ولو اشترياه فاققسماه يبيع أحدهما نصيبه مرابحة بنصف الثمن، ومعنى المبادلة هو الظاهر في الحيوانات والعروض للتفاوت حتى لا يكون لأحدهما أخذ نصيبه عند غيبة الآخر" (٢).

(١) بدائع الصنائع ١٨/٧.

(٢) فتح القدير ٤٢٦/٩.

وقيل: هي جمع نصيب شائع له في مكان معين ((١)).

سبب القسمة:

طلب الشركاء أو بعضهم الانتفاع بملكه على وجه الخصوص فلو لم يوجد طلبهم

لا تصح القسمة ((٢)).

مشروعية القسمة:

القسمة مشروعة بالكتاب والسنة والإجماع:

أما الكتاب: فقوله تعالى: {وَنَبِّئْهُمْ أَنَّ الْمَاءَ قِسْمَةٌ بَيْنَهُمْ} (٣) أي لكل شرب

محتضر: وقوله تعالى: {لَهَا شِرْبٌ وَلَكُمْ شِرْبُ يَوْمٍ مَعْلُومٍ} (٤) وقوله تعالى {وَإِذَا

حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَىٰ} (٥).

وأما السنة: فإنه ﷺ باشرها في الغنائم والمواريث وقال: "أعط كل ذي حق حقه"

وكان يقسم بين نسائه { وهذا مشهور (٦).

وأما الإجماع:

فقد أجمعت الأمة من لدن بعثة النبي ﷺ إلي يومنا هذا على مشروعيتها ((٧)).

((١)) رد المختار ٢٥٣/٦.

((٢)) مجمع الأنهر ٤٨٧/٢.

((٣)) سورة القمر الآية (٢٨).

((٤)) سورة الشعراء الآية (١٥٥).

((٥)) سورة النساء الآية (٨).

((٦)) أخرجه الزيلعي في نصب الراية عن عائشة رضي الله عنها" بلفظ { أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يعدل في

القسم بين نسائه، وكان يقول: اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تولاخذي فيما لا أملك { نصب الراية باب القسم.

((٧)) حاشية رد المختار علي الدر المختار ٢٥٤/٦.

المبحث الثاني أنواع القسمة وشرعية كل نوع

القسمة في الأملاك المشتركة نوعان:

أحدهما - قسمة الأعيان والثاني - قسمة المنافع وقسمة كل واحد من النوعين مشروعة.

أما قسمة الأعيان فقد عرفت شرعيتها بالسنة والإجماع .

أما السنة: فما روي {أن النبي عليه الصلاة والسلام قسم غنائم خيبر بين الغانمين، وأدنى درجات فعله عليه الصلاة والسلام الشرعية {

وأما الإجماع: فإن الناس استعملوا القسمة من لدن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا من غير نكير، فكانت شرعيته متوارثة، والمعقول يقتضيه توفيراً على كل واحد مصلحته بكمالها.

وأما قسمة المنافع:

فهي المسماة بالمهايئات، والكلام فيها يقع في عدة مطالب علي النحو التالي:

المطلب الأول: في أنواع المهايئات وما يجوز منها وما لا يجوز.

المطلب الثاني: في محل المهايئات وفي صفة المهايئات.

المطلب الثالث: في ما يملك كل واحد من الشريكين من التصرف بعد المهايئات

وما لا يملك.

المطلب الأول

أنواع المهايئات وما يجوز منها وما لا يجوز

المهايئات نوعان: نوع يرجع إلى المكان ونوع يرجع إلى الزمان.

لأن مبادلة المنفعة بجنسها غير جائزة عندنا، كإجازة السكنى بالسكنى والخدمة بالخدمة، وكذلك لو تهايئا في دارين وأخذ كل واحد منهما داراً يسكنها أو يستغلها فهو جائز بالإجماع.

أما عند أبي يوسف ومحمد فلا شك فيه؛ لأن قسمة الجمع في عين الدور جائزة، فكذا في المنافع.

وأما أبو حنيفة - رحمه الله - فيحتاج إلى الفرق بين العين وبين المنفعة.

وجه الفرق عند أبي حنيفة:

أن الدور في حكم أجناس مختلفة؛ لتفاحش التفاوت بين دار ودار في نفسها وبنائها وموضعها، ولا تجوز قسمة الجمع في جنسين مختلفين على ما مر .
وأما التفاوت في المنافع فقل ما يتفاحش بل يتقارب، فلم تلتحق منافع الدارين بالأجناس المختلفة فجازت القسمة، وكذلك لو تهاينا في عبيدين على الخدمة جاز بالإجماع.

أما وجه الفرق عندهما:

أن قسمة الجمع في أعيان الرقيق جائزة، وكذا في منافعها.
ووجه الفرق لأبي حنيفة - رحمه الله - على نحو ما ذكرنا في الدارين ولو تهاينا في عبيدين فأخذ كل واحد منهما عبدا يخدمه وشرط كل واحد منهما على نفسه طعام العبد الذي يخدمه ؛ جاز استحسانا، والقياس أن لا يجوز .
ووجهه أن طعام كل واحد من العبيدين على الشريكين جميعا على المناصفة، فاشتراط كل الطعام من كل واحد منهما على نفسه يخرج مخرج معاوضة بعض الطعام بالبعض، وإنها غير جائزة للجهالة.

ووجه الاستحسان:

إن هذا النوع من الجهالة لا يفضي إلى المنازعة؛ لأن مبنى الطعام على المسامحة في العرف والعادة دون المضايقة، بخلاف ما إذا شرط كل واحد منهما على نفسه كسوة العبد الذي يخدمه أنه لا يجوز؛ لأنه يجري في الكسوة من المضايقة ما لا يجري في الطعام في العرف والعادة، فكانت الجهالة في الكسوة مفضية إلى المنازعة، مع ما إن الجهالة في الكسوة تتفاحش بخلاف الطعام؛ لذلك افترقا.

وأما التهايو في الدواب بأن أخذ أحدهما دابة ليركبها والآخر دابة أخرى من جنسها يستغلها، وشرط الاستغلال فغير جائز عند أبي حنيفة، وعندهما جائز.

وجه قولهما ظاهر ؛ لأن قسمة الجمع في أعيان الدواب من جنس واحد جائزة، فكذا قسمة المنافع، ولأبي حنيفة الفرق بين المنفعة وبين المنفعة أنه جوز قسمة الجمع في أعيانها ولم يجوز في منافعها.

ووجه الفرق:

أنها باعتبار أعيانها جنس واحد لكنها في منفعة الركوب في حكم جنسين مختلفين، بدليل أن من استأجر دابة ليركبها لم يملك أن يؤجرها للركوب، ولو فعل لضمن، فأشبهه اختلاف جنس المنفعة اختلاف جنس العين، واختلاف جنس العين عنده مانع جواز قسمة الجمع، كذا في المنفعة، بخلاف المهايئات في الدارين والعبدان أنها جائزة؛ لأن هناك المنافع متقاربة غير متفاحشة، بدليل أن المستأجر فيها يملك الإجارة من غيره فلم يختلف جنس المنفعة فجازت المهايئات (١).

وأما النوع الثاني:

وهو المهايئات بالزمان فهو أن يتهايا في بيت صغير على أن يسكنه هذا يوما، وهذا يوما، أو في عبد واحد على أن يخدم هذا يوما وهذا يوما، وهذا جائز؛ لقوله تبارك وتعالى { قَالَ هَذِهِ نَاقَةٌ لَهَا شِرْبٌ وَلَكُمْ شِرْبُ يَوْمٍ مَعْلُومٍ } (٢) أخبر سبحانه وتعالى عن نبيه سيدنا صالح عليه الصلاة والسلام المهايئات في الشرب، ولم ينكره سبحانه وتعالى، والحكيم إذا حكى عن منكر غيره، فدل على جواز المهايئات بالزمان بظاهر النص، وثبت جواز النوع الآخر من طريق الدلالة؛ لأنها أشبه بالمقاسمة من النوع الأول، ولأن جواز المهايئات بالزمان لكان حاجات الناس، وحاجتهم إلى المهايئات بالمكان أشد؛ لأن الأعيان كلها في احتمال المهايئات بالزمان شرع، سواء من الأعيان ما لا يحتمل المهايئات بالمكان كالعبد والبيت الصغير ونحوهما، فلما جازت تلك فلأن تجوز هذه أولى (٣).

(١) بدائع الصنائع ٣٢/٧ وما بعدها.

(٢) سورة الشعراء الآية (١٥٥).

(٣) بدائع الصنائع ٣٣/٧.

المبحث الثالث ركن القسمة وشروطها ومحاسنها

أولاً: ركنها:

هو الفعل الذي يحصل به الإفراز والتمييز بين النصيبين كالكيل في المكيلات والوزن في الموزونات والذرع في المذروعات والعد في المعدودات. (١)

ثانياً: شروطها:

للقسمة شرط عام وهو أن لا تقوت المنفعة بالقسمة ولهذا لا يقسم الحائط والحمام وما أشبه ذلك. (٢)

وأما الشروط التفصيلية للقسمة، فأنواع:

بعضها يرجع إلى القاسم، وبعضها يرجع إلى المقسوم، وبعضها يرجع إلى المقسوم له.

(أما) الذي يرجع إلى القاسم فنوعان:

نوع: هو شرط الجواز.

ونوع: هو شرط الاستحباب.

أما شرائط الجواز فأنواع:

العقل، فلا تجوز قسمة المجنون والصبي الذي لا يعقل ؛ لأن العقل من شرائط أهلية التصرفات الشرعية، فأما البلوغ فليس بشرط لجواز القسمة حتى تجوز قسمة الصبي الذي يعقل القسمة بإذن وليه، وكذلك الإسلام والذكورة والحرية ليست بشرط لجواز القسمة، فتجوز قسمة الذمي والمرأة والمكاتب والمأذون ؛ لأن هؤلاء من أهل البيع فكانوا من أهل القسمة.

الملك والولاية، فلا تجوز القسمة بدونهما أما الملك فالمعني به: أن يكون القاسم مالكا فيقسم الشركاء بالتراضي .

(١) فتح القدير ٤٢٧/٩.

(٢) المرجع السابق نفس الصفحة.

وأما الولاية فنوعان:

ولاية قضاء، وولاية قرابة، إلا أن شرط ولاية القضاء الطلب، فيقسم القاضي وأمينه على الصغير والكبير، والذكر والأنثى، والمسلم والذمي، والحر والعبد، والمأذون والمكاتب، عند طلب الشركاء كلهم أو بعضهم - على ما نذكره - ولا يشترط ذلك في ولاية القرابة، فيقسم الأب ووصيه، والجد ووصيه، على الصغير والمعتوه، من غير طلب أحد، والأصل فيه أن كل من له ولاية البيع فله ولاية القسمة، ومن لا فلا، ولهؤلاء ولاية البيع فكانت لهم ولاية القسمة، وكذا القاضي له ولاية بيع مال الصغير والكبير في الجملة، فكان له ولاية القسمة في الجملة .

وأما وصي الأم ووصي الأخ والعم فيقسم المنقول دون العقار ؛ لأن له ولاية بيع المنقول دون العقار، وفي وصي المكاتب إذا مات عن وفاء أنه هل يقسم ؟ فيه روايتان، وهذا كله يقرر ما قلنا: إن معنى المبادلة لازم في القسمة، حيث جعل سبيله سبيل البيع في الولاية، ولا يقسم وصي الميت على الموصى له ؛ لانعدام ولايته عليه، وكذا لا يقسم الورثة عليه ؛ لانعدام ولايتهم عليه ؛ لأن الموصى له كواحد من الورثة، ولا يقسم بعض الورثة على بعض ؛ لانعدام الولاية فلا يقسمون على الموصى له، ولو اقتسموا وهو غائب نقضت قسمتهم، لكن هذا إذا كانت القسمة بالتراضي، فإن كانت بقضاء القاضي - تنفذ ولا تنقض.

وأما شرائط الاستحباب فأنواع:

أن يكون عدلاً أميناً عالماً بالقسمة؛ لأنه لو كان غير عدل خائناً، أو جاهلاً بأمور القسمة يخاف منه الجور في القسمة لا يجوز.

أن يكون منصوب القاضي؛ لأن قسمة غيره لا تنفذ على الصغير والغائب، ولأنه أجمع لشرائط الأمانة، والأفضل أن يرزقه من بيت المال؛ ليقسم للناس من غير أجر عليهم؛ لأن ذلك أرفق بالمسلمين، فإن لم يمكنه أن يرزقه من بيت المال يقسم لهم بأجر عليهم، ولكن ينبغي للقاضي أن يقدر له أجر معلومة كي لا يتحكم على الناس، ولو أراد الناس أن يستأجروا قساماً آخر غير الذي نصبه القاضي لا يمنعهم القاضي عن

ذلك، ولا يجبرهم على أن يستأجروا قساماً؛ لأنه لو فعل ذلك لعله لا يرضى إلا بأجرة كثيرة فيتضرر الناس، وكذا لا يترك القسامين يشتركون في القسم ؛ لما قلنا.

المبالغة في تعديل الأنصباء، والتسوية بين السهام بأقصى الإمكان ؛ لئلا يدخل قصور في سهم، وينبغي أن لا يدع حقاً بين شريكين غير مقسوم من الطريق والمسيل والشرب، إلا إذا لم يمكن، وينبغي أن لا يضم نصيب بعض الشركاء إلى بعض إلا إذا رضوا بالضم ؛ لأنه يحتاج إلى القسمة ثانياً، وينبغي أن لا يدخل في قسمة الدار ونحوها الدراهم، إلا إذا كان لا يمكن القسمة إلا كذلك ؛ لأن محل القسمة الملك المشترك، ولا شركة في الدراهم فلا يدخلها في القسمة إلا عند الضرورة.

أن يقرع بينهم بعد الفراغ من القسمة، ويشترط عليهم قبول من خرج سهمه أولاً فله هذا السهم من هذا الجانب من الدار، ومن خرج سهمه بعده فله السهم الذي يليه هكذا، ثم يقرع بينهم ؛ لا لأن القرعة يتعلق بها حكم ؛ بل لتطبيب النفوس ؛ ولورود السنة بها ؛ ولأن ذلك أنفى للتهمة فكان سنة، والله سبحانه وتعالى أعلم وإذا قسم بأجرة فأجرة القسمة على عدد الرعوس عند أبي حنيفة - رحمه الله، وعندهما - رحمهما الله - على قدر الأنصباء .

وجه قولهما: أن أجرة القسمة من مؤنات الملك فيقدره كالنفقة .

وجه قول أبي حنيفة - رحمه الله - إن الأجرة بمقابلة العمل، وعمله في حق الكل على السواء فكانت الأجرة عليهم على السواء ؛ وهذا لأن عمله تمييز الأنصباء، والتمييز عمل واحد ؛ لأن تمييز القليل من الكثير، هو بعينه تمييز الكثير من القليل، والتفاوت في شيء واحد محال، وإذا لم يتفاوت العمل لا تتفاوت الأجرة بخلاف النفقة ؛ لأنها بمقابلة الملك، والملك يتفاوت فهو الفرق (١).

أما الذي يرجع إلى المقسوم فواحد:

وهو أن يكون المقسوم مملوكاً للمقسوم له وقت القسمة، فإن لم يكن لا تجوز القسمة؛ لأن القسمة إفراز بعض الأنصباء، ومبادلة البعض، وكل ذلك لا يصح إلا في

(١) بدائع الصنائع ١٩/٧ وما بعدها.

المملوك، وعلى هذا إذا استحققت العين المقسومة تبطل القسمة في الظاهر، وفي الحقيقة تبين أنها لم تصح، ولو استحق شيء منها تبطل في القدر المستحق، ثم قد تستأنف القسمة وقد لا تستأنف، ويثبت الخيار وقد لا يثبت. (١)

وأما الذي يرجع إلي المقسوم له فأنواع:

أن لا يلحقه ضرر بسبب القسمة.

الرضا، وهو رضا الشركاء فيما يقسمونه بأنفسهم إذا كانوا من أهل الرضا، أو رضا من يقوم مقامهم، إذا لم يكونوا من أهل الرضا فإن لم يوجد لا يصح، حتى لو كان في الورثة صغير لا وصي له، أو كبير غائب، فاققسموا؛ فالقسمة باطلة.

البينة في قسمة القضاء في الإقرار بميراث الإقرار عند أبي حنيفة - رحمه الله - وعند صاحبين ليست بشرط ويقسم بإقرارهم.

أن يكون المقسوم عليه مالكا للمقسوم وقت القسمة، وهو أن يكون له فيه ملك فإن لم يكن، لم تجز القسمة (٢).

ثالثاً: محاسنها:

من محاسن القسمة أن أحد الشريكين قد يحصل له من صاحبه سوء الخلق وضيق الفطن وسوء التصرف الجالب للضرر وقوة الرأس وليس له مخرج من هذه الأمور إلا الركون إلى الاقتسام. (٣)

فبالقسمة تنتفي هذه المضار عن الشريكين وتستقيم أمورهما المادية والمعنوية وهي تعد التطبيق الأمثل للقاعدة الفقهية "الضرر يزال". (٤)

(١) المرجع السابق ص ٢٥.

(٢) بدائع الصنائع ١٩/٧ وما بعدها.

(٣) البحر الرائق شرح كنز الدقائق ١٦٨/٨.

(٤) الأشباه والنظائر لابن نجيم ٢٧٤/١ ط دار الكتب العلمية بيروت ١٩٩٩م.

المبحث الرابع صفات القسمة وحكمها

أولاً: صفات القسمة:

أن تكون عادلة غير جائرة وهي أن تقع تعديلاً للأنصباء من غير زيادة على القدر المستحق من النصيب ولا نقصان عنه ؛ لأن القسمة إفراز بعض الأنصباء، ومبادلة البعض، ومبنى المبادلات على المراضاة، فإذا وقعت جائرة ؛ لم يوجد التراضي، ولا إفراز نصيبه بكماله ؛ لبقاء الشركة في البعض فلم تجز وتعاد.

وعلى هذا إذا ظهر الغلط في القسمة المبادلة بالبيئة أو بالإقرار تستأنف؛ لأنه ظهر أنه لم يستوف حقه، فظهر أن معنى القسمة لم يتحقق بكماله، ولو ادعى أحد الشريكين الغلط في القسمة فهذا لا يخلو من أحد وجهين: إما أن يكون المدعي قد أقر باستيفاء حقه، وإما أن يكون لم يقر بذلك، فإن كان قد أقر باستيفاء حقه لا يسمع منه دعوى الغلط ؛ لكونه مناقضاً في دعواه ؛ لأن الإقرار باستيفاء الحق إقرار بوصول حقه إليه بكماله، ودعوى الغلط إخبار أنه لم يصل إليه حقه بكماله فيتناقض.

وإن كان لم يقر باستيفاء حقه ؛ لا تعاد القسمة بمجرد الدعوى ؛ لأن القسمة قد صحت من حيث الظاهر فلا يجوز نقضها إلا بحجة، فإن أقام البيئة أعيدت القسمة. وإن لم تقم له بيئة وأنكر شريكه، فأراد استحلافه حلفه على ما ادعى من الغلط ؛ لأنه يدعي عليه حقا هو جائز الوجود والعدم، وهو ينكر فيحلف.

وبيان ذلك:

دار بين رجلين اقتسما، واستوفى كل واحد منهما حقه ثم ادعى أحدهما غلطا في القسمة لا تعاد القسمة، ولكن يسأل البيئة على الغلط، فإن أقام البيئة وإلا فيحلف شريكه إن شاء، فإن حلف أحد الشريكين ونكل الآخر، فإن كان الشركاء ثلاثة يجمع بين نصيب المدعي وبين نصيب الناكل، فيقسم بينهما على قدر نصيبهما ؛ لأن نكوله دليل كونه المدعي صادقا في دعواه في حقه، فكان حجة في حقه لا في حق الشريك الحالف، فلم تصح القسمة في حقهما فتعاد في قدر نصيبهما، وكذلك لو ادعى الغلط بعد القسمة والقبض في المكيلات والموزونات والمذروعات.

ولو كان بين رجلين داران اقتسماهما، فأخذ كل واحد منهما دارا، ثم ادعى أحدهما الغلط في القسمة وأقام البينة على ذلك، فالقسمة باطلة عند أبي حنيفة - رحمه الله - وعند صاحبين لا تبطل ولكن يقضى للمدعي بذلك الذرع من الدار الأخرى، وبنوا هذه المسألة على بيع ذراع من دار أنه لا يجوز عنده، وعندهما جائز.

ووجه البناء أن قسمة الجمع في الدور بالتراضي جائزة بلا خلاف، ومعنى المبادلة وإن كان لازما في نوعي القسمة لكن هذا النوع بالمبادلات أشبه، وإذا تحققت المبادلة صح البناء.

ولو اقتسما دارا بينهما، فأخذ كل واحد منهما طائفة، ثم ادعى أحدهما بيتا في يد صاحبه أنه وقع في قسمته، وأقام بينة ؛ سمعت بينته، وإن أقاما جميعا البينة ؛ أخذت بينة المدعي ؛ لأنه خارج وإن كان قبل الإشهاد والقبض تحالفا وترادا، وكذا لو اختلفا في الحدود فادعى كل واحد منهما حدا في يد صاحبه أنه أصابه وأقام البينة ؛ قضي لكل واحد منهما بالحد الذي في يد صاحبه ؛ لأن كل واحد منهما عما في يد صاحبه خارج، وإن قامت لأحدهما بينة يقضى ببينته، وإن لم تقم لهما بينة تحالفا وهل يفسخ العقد بنفس التحالف أم يحتاج فيه إلى فسخ القاضي ؟

اختلف المشايخ فيه على قولين:

فقال بعضهم يفسخ بنفس التحالف وقال البعض الآخر يحتاج إلي فسخ القاضي. الوجوب عند الطلب، حتى يجبر على القسمة فيما ينتفع كل واحد من الشريكين بقسمته، وكذا فيما ينتفع بها أحدهما ويستنصر الآخر عند طلب المنتفع بالإجماع، وعند طلب المستنصر اختلاف روايتي الحاكم، والقُدوري - رحمهما الله - وقد ذكرناه.

اللزوم بعد تمامها في النوعين جميعا، حتى لا يحتمل الرجوع عنها إذا تمت، وأما قبل التمام فكذلك في أحد نوعي القسمة، وهو قسمة القضاء دون النوع الآخر، وهو قسمة الشركاء، بيان ذلك: أن الدار إذا كانت مشتركة بين قوم فقسماها القاضي أو الشركاء بالتراضي فخرجت السهام كلها بالقرعة ؛ لا يجوز لهم الرجوع، وكذا إذا خرج الكل إلا سهم واحد ؛ لأن ذلك خروج السهام كلها ؛ لكون ذلك السهم متعينا بمن بقي

من الشركاء، وإن خرج بعض السهام دون البعض فكذا في قسمة القضاء ؛ لأنه لو رجع أحدهم لأجبره القاضي على القسمة ثانيا فلا يفيد رجوعه .
وأما في قسمة التراضي فيجوز الرجوع ؛ لأن قسمة التراضي لا تتم إلا بعد خروج السهام كلها، وكل عاقد بسبيل من الرجوع عن العقد قبل تمامه كما في البيع ونحوه(١).

دور خيار الرؤية والشرط والشفعة في القسمة:

أما الرد بخيار الرؤية والشرط فيثبت في قسمة الرضا ؛ لأن القسمة فيها معنى المبادلة، وهذا النوع أشبه بالمبادلات ؛ لوجود المراضاة من الجانبين فيثبت فيه خيار الرؤية كما في البيع، ولا يثبت في قسمة القضاء لا لخلوها عن المبادلة بل لعدم الفائدة؛ لأنه لو ردها بخيار الرؤية والشرط ؛ لأجبره القاضي ثانيا فلا يفيد.
وأما الشفعة فلا تجب في القسمة ؛ لأن حق الشفعة يتبع المبادلة المحضة ؛ لثبوتها على مخالفة القياس، والقسمة مبادلة من وجه فلا تحتل الشفعة ؛ ولأنها لو وجبت لا يخلو إما أن تجب للشريك أو للجار، لا سبيل إلى الأول ؛ لأن الشفعة تجب لغير البائع والمشتري، ولا سبيل إلى الثاني ؛ لأن الشريك أولى من الجار.

ثانياً: حكم القسمة:

واعني بالحكم هنا الأثر المترتب عليها وهو ثبوت الاختصاص بالمقسوم عينا تصرفا فيه، فيملك المقسوم له في المقسوم جميع التصرفات المختصة بالملك، حتى لو وقع في نصيب أحد الشريكين ساحة لا بناء فيها، ووقع البناء في نصيب الآخر فلصاحب الساحة أن يبني في ساحته، وله أن يرفع بناءه، وليس لصاحب البناء أن يمنعه، وإن كان يفسد عليه الريح والشمس ؛ لأنه يتصرف في ملك نفسه فلا يمنع عنه، وكذا له أن يبني في ساحته مخرجا أو تتورا أو حماما أو رحي ؛ لما قلنا، وكذا له أن يقعد في بنائه حدادا، أو قصارا، وإن كان يتأذى به جاره ؛ لما قلنا، وله أن يفتح بابا أو كوة ؛ لما ذكرنا ألا ترى أن له أن يرفع الجدار أصلا ففتح الباب والكوة أولى، وله أن

(١) بدائع الصنائع ٢٧/٧ وما بعدها.

يحفر في ملكه بئرا أو بالوعة، ولو سقط الحائط من ذلك لا يضمن ؛ لأنه لا صنع منه في ملك الغير، والأصل أن لا يمنع الإنسان من التصرف في ملك نفسه إلا أن الكف عما يؤذي الجار أحسن .

قال الله تبارك وتعالى { وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا ۚ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا } إلى قوله تعالى { وَالْجَارِ الْجُنُبِ } (١) خصه سبحانه وتعالى بالأمر بالإحسان إليه، فلئن لا يحسن إليه فلا أقل من أن يكف عنه أذاه .

وعلى هذا دار بين رجلين، ولرجل فيها طريق فأرادا أن يقتسماها، ليس لصاحب الطريق منعهما عن القسمة ؛ لأنهما بالقسمة متصرفان في ملك أنفسهما فلا يمنعان عنه، فيقتسمان ما وراء الطريق، ويتركان الطريق على حاله على سعة عرض باب الدار.

ولو باعوا الدار والطريق فإن كانت رقة الطريق مشتركة بينهم ؛ قسموا ممر الطريق بينهم أثلاثا، وإن كانت الرقة لشريكي الدار ولصاحب الطريق حق المرور، حكى القدوري عن الكرخي - رحمهما الله - أن لا شيء لصاحب الطريق من الثمن، ويكون الثمن كله للشريكين، وروى محمد أن كل واحد من الشريكين يضرب بحقه من المنفعة، ويضرب صاحب الطريق بحق المرور، وطريق معرفة ذلك أن ينظر إلى قيمة العرصة بغير طريق، وينظر إلى قيمتها وفيها طريق، فيكون لصاحب الطريق فضل ما بينهما، ولكل واحد من الشريكين نصف قيمة المنفعة إذا كان فيها طريق .

وجه ما حكى عن الكرخي - رحمه الله - أن حق المرور لا يحتل البيع مقصودا بل يحتمله تبعا للرقبة، ألا ترى أنه لو باعه وحده لم يجز، فإذا بيع الطريق بإذنه فقد أسقط حقه أصلا فلا يقابله ثمن .

وجه ما روي عن محمد أن حق المرور لا يحتل البيع مقصودا بل يحتمله تبعا للرقبة، وهنا ما بيع مقصودا بل تبعا للرقبة فيقابله الثمن، لكن ثمن الحق لا ثمن الملك على ما ذكرنا .

(١) سورة النساء الآية (٣٦).

وكذلك دار بين رجلين فيها مسيل الماء، فأرادا أن يقتسماها، فليس لصاحب المسيل منعهما من القسمة، بل يقسم الدار ويترك المسيل على حاله كما في الطريق، وكذلك لو كان في الدار منزل لرجل وطريقه في الدار، فأرادا أن يقتسما الدار لا يمنعان من القسمة، ولكن يتركان طريق المنزل على حاله على سعة عرض باب الدار، لا على سعة باب المنزل على ما ذكرنا، ولو أراد صاحب المنزل أن يفتح إلى هذا الطريق بابا آخر له ذلك ؛ لأنه متصرف في ملك نفسه، ألا ترى أن له أن يرفع الحائط كله فهذا أولى، ولو اشترى صاحب المنزل دارا من وراء المنزل وفتح بابا إلى المنزل، فإن كان ساكن الدار والمنزل واحدا فله أن يمر من الدار إلى المنزل، ومن المنزل إلى الطريق الذي في الدار الأولى ؛ لأن له حق المرور في هذا الطريق، وإن كان ساكن الدار غير ساكن المنزل فليس لساكن الدار أن يمر في الطريق الذي في الدار الأولى؛ لأنه لا حق له في هذا الطريق فيمنع من المرور فيه.

دار بين رجلين في سكة غير نافذة اقتسماها، وأخذ كل واحد منهما طائفة منها، فأراد كل واحد منهما أن يفتح بابا أو كوة إلى السكة له ذلك، ولا يسع لأهل السكة منعهما ؛ لأن كل واحد منهما متصرف في ملك نفسه فيملكه، ألا ترى أن له رفع الحائط أصلا فالباب والكوة أولى .

وعلى هذا حائط بين قسيمين ولأحد القسيمين عليه جذوع الحائط الآخر فإن شرطوا قطع الجذوع في القسمة قطعه ؛ لقول النبي عليه الصلاة والسلام: {المسلمون عند شروطهم}(١).

وإن لم يشترطوا ترك على حالها ؛ لأن الترك وإن كان ضررا لكنهم لما لم يشترطوا القطع في القسمة فقد التزم الضرر وكذلك لو كان وقع على هذا الحائط درجة أو أسطوانة جمع عليها جذوع ؛ لما قلنا، وكذلك روشنا وقع لصاحب العلو شرفا على نصيب الآخر لم يكن لصاحب السفلى أن يقلع الروشن من غير شرط القلع لما قلنا، ولو كان لأحدهما أطراف خشب على حائط صاحبه، فإن كان مما يمكن أن يجعل عليها

(١) أخرجه ابن ماجه في سننه برقم ٢٣٥٣ وقال الألباني هذا حديث حسن صحيح.

سقف لم يكلف قلعها، وإن كان لا يمكن كلف القلع ؛ لأنه إذا أمكن أن يجعل عليها سقف أمكنه الانتفاع به فيلتحق بالحقوق، فأشبهه الروشن وإذا لم يمكن تعذر إلحاقها بالحقوق فبقي شاغلا هو لصاحبه بغير حق، فيكلف قطعها، ولو كان لأحدهما شجرة أغصانها مظلة على نصيب الآخر فهل تقطع ؟ ذكر ابن سماعه - رحمه الله - أنه لا تقطع ؛ لأن في القطع ضررا لصاحبها، وذكر ابن رستم - رحمه الله - أنه تقطع كما يقطع أطراف الخشب الذي لا يمكن تسقيفها، ولو اختلف أهل طريق في الطريق، وادعى كل واحد منهم أنه له ؛ فهو بينهم بالتسوية على عدد الرعوس، لا على ذرعان الدور والمنازل ؛ لأنهم استتوا في اليد ؛ لاستوائهم في المرور فيه إلا أن يقوم لأحدهم بينة فيسقط اعتبار اليد بالبينه .

دار لرجل وفيها طريق بينه وبين رجل فمات صاحب الدار، فاقترست الورثة الدار بينهم، وتركوا الطريق كان الطريق بينه وبين الرجل نصفين لا على عدد الرعوس، حتى لو باعوا الدار يقسم الثمن بين الورثة وبينه نصفين لا على عدد الرعوس ؛ لأن الورثة قاموا مقام المورث، وقد كان الطريق بينهما نصفين فكذا بينه وبينهم، ولو لم يعرف أن الدار ميراث بينهم وجدوا ذلك فالطريق بينهم بالسوية على عدد الرعوس ؛ لاستوائهم في اليد.(١)

المبحث الخامس كيفية القسمة

ينبغي للقاسم أن يقرع بينهم، ممن خرج اسمه على سهم أخذه وذلك بعد ما يصور ما يقسمه ويعدله على سهام القسمة، ويذرع الساحة ويقوم البناء لحاجته إلى معرفة ذلك، ويفرز كل نصيب بحقوقه عن بقية الأنصباء ليتحقق معنى القسمة، ويلقب الأنصباء بالأول والثاني والثالث، ثم يخرج القرعة كما تقدم، ويقسم على أقل الأنصباء، فإن كان سدسا جعلها أسداسا، أو ثمنا فأثمانا؛ لأنه إذا خرج أقل الأنصباء خرج الأكثر، ولا كذلك بالعكس، ولو عين لكل واحد نصيبا جاز من غير قرعة؛ لأنه في معنى القضاء فيصح إلزامه . أما القرعة فلتطبيب النفوس ونفي التهمة والميل .

(١) بدائع الصنائع ٢٩/٧ وما بعدها.

وليس لأحد الرجوع إذا قسم القاضي أو نائبه؛ لأنها صدرت عن ولاية تامة فلزمت كالقضاء، وكذلك ليس له ذلك إذا خرج بعض السهام، فكما لا يلتفت إلى إباطه قبل القسمة لا يلتفت إلى رجوعه بعدها، وكذلك إذا حصل التراضي وبينت الحدود؛ لأن المؤمنين عند شروطهم . وقيل يصح رجوعه إذا خرج بعض السهام إلا إذا بقي سهم واحد لتعينه للباقي .

فإن كان في نصيب أحدهم مسيل أو طريق لغيره لم يشترط، فإن أمكن صرفه عنه صرفه تحقيقاً لمعنى القسمة وهو قطع الاشتراك .

والإفراز فسخت القسم لاختلالها، وتستأنف لأن المقصود تكميل المنفعة، ولا يتأتى ذلك إلا بالطريق والمسيل .

وإذا شهدوا عليهم ثم ادعى أحدهم أن من نصيبه شيئاً في يد صاحبه لم تقبل إلا ببينة لأنه مدع، فإن لم تكن له بينة استحلف شركاؤه، فمن نكل جمع نصيبه ونصيب المدعي فيقسم بينهما على قدر نصيبهما؛ لأن النكول حجة على ما عرف، وقيل لا تقبل دعواه للتناقض .

وتقبل شهادة القاسمين على ذلك وقال محمد: لا تقبل؛ لأنها شهادة على فعلهما. ولهما أنهما شهدا بالاستيفاء وهو فعل الغير وبه تلزم القسمة فتقبل، أما فعلهما الإفراز وهو غير ملزم ولا حاجة إلى الشهادة عليه، وعن محمد مثل قولهما.

ومنهم من قال: إن كانت القسمة بأجر لا تقبل؛ لأنها دعوى إيفاء عمل استؤجرا عليه . وجوابه أن أجرتهما وجبت باتفاق الخصوم على إيفاء العمل وهو التمييز فلم تجر لهما مغنما فلا تهمة، وإن قال قبضته ثم أخذه مني فبينته أو يمين خصمه كسائر الدعاوى.

وإن قال ذلك قبل الإشهاد تحالفا وفسخت القسمة وكذلك إذا قال: لم يسلم إلى بعض نصيبي وهو نظير الاختلاف في قدر المبيع، وسنبين التحالف وأحكامه في كتاب الدعوى إن شاء الله تعالى .

وإن استحق بعض نصيب أحدهم رجع في نصيب صاحبه بقسطه كما في البيع، هذا عند أبي حنيفة ؛ وقال أبو يوسف: تفسخ القسمة، وهو قول محمد في رواية أبي

سليمان أبو حفص أنه مع أبي حنيفة، وقيل الخلاف في بعض شائع في نصيب أحدهما، أما المعين لا يفسخ بالإجماع ؛ ولو استحق نصيب شائع في الكل انفسخت بالإجماع؛ لأبي يوسف أن بالاستحقاق ظهر شريك ثالث ولا قسمة بدون رضاه؛ والفقه فيه أن باستحقاق الجزء الشائع يبطل معنى القسمة، وهو التمييز والإفراز؛ لأنه يرجع بجزء شائع في نصيب الآخر بخلاف المعين، وصار كاستحقاق الشائع في الكل؛ ولأبي حنيفة أن القسمة على هذا الوجه تجوز ابتداء بأن يكون نصف الدار المقدم بينهما وبين ثالث، والمؤخر بينهما على الخصوص، فاقسما على أن لأحدهما نصيبهما من المقدم وربع المؤخر، ولآخر ثلاثة أرباع المؤخر فإنه يجوز، وإذا جاز ذلك ابتداء جاز انتهاء، فمعنى القسمة موجود وصار كالجزء المعين، بخلاف الشائع في الكل؛ لأن القسمة لو بقيت يتفرق نصيب المستحق في الكل فيتضرر ولا ضرر هنا فافترقا. (١)

المبحث السادس

ما يوجب نقض القسمة بعد وجودها

الذي يوجب نقض القسمة بعد وجودها أنواع:

١- ظهور دين على الميت ؛ إذا طلب الغرماء ديونهم ولا مال للميت سواء، ولا قضاء الورثة من مال أنفسهم، وبيان ذلك: أن الورثة إذا اقتسموا التركة ثم ظهر على الميت دين فهذا لا يخلو من أحد وجهين: إما أن يكون للميت مال آخر سواء، وإما أن لم يكن، فإن لم يكن له مال سواء، ولا قضاء الورثة من مال أنفسهم ؛ تنتقض القسمة سواء كان الدين محيطا بالتركة أو لم يكن ؛ لأن الدين مقدم على الإرث قليلا كان أو كثيرا، قال الله - تبارك وتعالى: { مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ } . (٢)

قدم سبحانه وتعالى الدين على الوصية من غير فصل بين القليل والكثير ؛ لأن الدين إذا كان محيطا بالتركة ؛ تبين أنه لا ملك للورثة فيها إلا من حيث الصورة بل هي ملك للميت يتعلق بها بحق الغرماء، وقيام ملك الغير في المحل يمنع صحة القسمة، فقيام الملك والحق أولى .

(١) الاختيار لتعليل المختار ٣٣٨/٢ وما بعدها.

(٢) سورة النساء الآية (١١).

وإذا لم يكن محيطا بالتركة فملك الميت وحق الغرماء - وهو حق الاستيفاء - ثابت في قدر الدين من التركة على الشيوخ، فيمنع جواز القسمة فإن لم يكن للميت مال آخر سواه يجعل الدين فيه، وتمضي القسمة ؛ لأن القسمة تصان عن النقض ما أمكن، وقد أمكن صيانتها بجعل الدين فيه، وكذا الورثة إذا قضوا الدين من مال أنفسهم لا تنقض ؛ لأن حق الورثة كان متعلقا بصورة التركة، وحق الغرماء بمعناها وهو المالية، فإذا قضوا الدين من مال أنفسهم فقد استخلصوا التركة لأنفسهم صورة ومعنى، فتبين أنهم في الحقيقة اقتسموا مال أنفسهم صورة ومعنى، فتبين أنها وقعت صحيحة فلا تنقض، وكذلك إذا أبرأه الغرماء من ديونهم لا تنقض القسمة ؛ لأن النقض لحقهم وقد أسقطوه بالإبراء، وكذلك إذا ظهر لبعض المقتسمين دين على الميت، بأن ادعى دينا على الميت وأقام البينة عليه ؛ فله أن ينقض القسمة ؛ لما قلنا، ولا تكون قسمته إبراء من الدين ؛ لأن حق الغريم يتعلق بمعنى التركة وهو ماليتها لا بالصورة، ولهذا كان للورثة حق الاستخلاص، وإذا كان كذلك فلا يكون إقدامه على القسمة إقرارا منه ؛ لأنه لا دين له على الميت فلم يكن مناقضا في دعواه فسمعت .

٢- ظهور الوصية حتى لو اقتسموا ثم ظهر ثم موصى له بالثلث ؛ نقضت قسمتهم ؛ لأن الموصى له شريك الورثة، ألا ترى أنه لو هلك من التركة شيء قبل القسمة يهلك من الورثة والموصى له جميعا، والباقي على الشركة بينهم، ولو اقتسموا وثمة وارث آخر غائب تنقض، فكذا هذا، وهذا إذا كانت القسمة بالتراضي، فإن كانت بقضاء القاضي لا تنقض ؛ لأن الموصى له وإن كان كواحد من الورثة، لكن القاضي إذا قسم عند غيبة أحد الورثة لا تنقض قسمته ؛ لأن القسمة في هذا الموضوع محل الاجتهاد، وقضاء القاضي إذا صادف محل الاجتهاد ينفذ ولا ينقض.

٣- ظهور الوارث حتى لو اقتسموا ثم ظهر أن ثمة وارث آخر ؛ نقضت قسمتهم، ولو كانت القسمة بقضاء القاضي لا تنقض ؛ لما ذكرنا، ولو ادعى وارث وصية لابن له صغير بعد القسمة لا تصح دعواه، حتى لا تسمع منه البينة ؛ لكونه مناقضا في الدعوى إذ لا تصح قسمتهم الميراث وثم موصى له، فكان إقدامه على القسمة إقرارا منه بانعدام الوصية، فكان دعوى وجود الوصية مناقضة فلا تسمع، ولكن لا يبطل حق

الصغير بقسمة الأب ؛ لأنه لا يملك إبطال حقه، وكذلك لو ادعى بعض الورثة أن أبا له من أبيه وأمه ورث أباه معهم، وأنه مات بعد موت الأب وورثه هذا المدعي، وجدد الباقيون ذلك، فأقام المدعي البينة لا تقبل بينته ؛ لأنه هنا قضي في دعواه ؛ لدلالة إقراره بانعدام وارث آخر بإقدامه على القسمة، وكذلك كل ميراث يدعيه أو شراء أو هبة أو صدقة أو وصية بعد القسمة ؛ للتناقض بدلالة الإقدام على القسمة.

دار بين رجلين أقر أحدهما ببيت منها لرجل، وأنكر الآخر يصح إقراره ؛ لأن إقرار الإنسان حجة على نفسه ؛ لأن هذا الإقرار لم يوجب تعلق الحق بالعين لحق الشريك الآخر بل هو موقوف، وإذا لم يتعلق بالعين لا يمنع جواز القسمة فتقسم الدار ويجبر على القسمة، ومتى قسمت فإن وقع البيت المقر به في نصيب المقر دفعه إلى المقر له ؛ لأن الإقرار قد صح وتسليم عين المقر به ممكن، فيؤمر بالتسليم، وإن وقع في نصيب شريكه يدفع إليه قدر ذرع المقر به من نصيب نفسه، فيقسم ما أصابه بينه وبين المقر له، فيضرب المقر له بذرع البيت ويضرب المقر بنصف ذرع الدار بعد البيت، وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف - عليهما الرحمة - وقال محمد - رحمه الله - يضرب المقر بنصف ذرع الدار كما قالوا، ولكن المقر له يضرب بنصف ذرع البيت لا بكاه، حتى لو كان ذرع الدار مائة، وذرع البيت عشرة، فتقسم الدار بينهما نصفين، يكون للمقر له عشرة أذرع عندهما ؛ لأنه جميع ذرع البيت والباقي - وهو خمسة وأربعون - للمقر ؛ لأنه نصف ذرع الدار بعد ذرع البيت، وعند محمد - رحمه الله - يكون للمقر له خمسة أذرع، إذ هو نصف ذرع البيت المقر به .

وجه قول محمد - رحمه الله - أن الإقرار صادق محلاً معيناً مشتركاً بينه وبين غيره ؛ لأن كل جزأين من الدار أحدهما له، والآخر لصاحبه على الشيوع فيبطل في نصيب صاحبه ويصح في نصيبه، وذلك يوجب للمقر له نصف ذرع البيت .

وجه قولهما أن الإقرار بالمشترك لا يتعلق بالعين قبل القسمة بل هو موقوف، وإنما يتعلق بهما بعد القسمة، ألا ترى أنه لم يمنع صحة القسمة، ولو تعلق بالعين لمنع، فإذا قسمت الدار الآن يتعلق بالعين، فإن وقع المقر به في نصيب المقر يؤمر بالتسليم ؛ لأنه قادر على تسليم العين وإن وقع في نصيب صاحبه فقد عجز عن تسليم عينه فيؤمر بتسليم بدله من نصيبه، وهو تمام ذرع المقر به، هذا إذا كان المقر به شيئاً يحتمل القسمة، فإن كان

مما لا يحتمل القسمة، كبيت من حمام مشتركة بينه وبين غيره أقر أنه لرجل وأنكر صاحبه فيصح إقراره، ولكن يجبر على قسمته ؛ لأن قسمة الإضرار فيما لا يحتمل الجبر على ما ذكرناه في موضعه، ويلزمه نصف قيمة البيت ؛ لأنه عجز عن تسليم العين والإقرار بعين معجوز التسليم يكون إقرارا ببدله تصحيحا لتصرفه، وصيانة لحق الغير بالقدر الممكن، كالإقرار بجذع في الدار. (١)

من خلال دراستك لفصل القسمة أجب عما يلي:

- عرف القسمة لغة وشرعاً، واذكر أدلة مشروعيتها، وما هو سببها.
- قسمة الأملاك المشتركة نوعان، اذكرهما ودلل على شرعية كل نوع.
- ما هو ركن القسمة وشرطها ومحاسنها؟.
- ما هي صفات القسمة وحكمها؟.
- ما هي كيفية القسمة؟.
- اذكر ما يوجب نقض القسمة بعد وجودها .

كتبه

أ.د/ إبراهيم رمضان عطايا. أستاذ ورئيس قسم الفقه بكلية الدراسات الإسلامية والعربية
للبنات بمدينة السادات

د/ أحمد محمد السيد المرسي العفيفي. مدرس الفقه بكلية الشريعة والقانون بطنطا

(١) بدائع الصنائع ٣١/٧ وما بعدها.

الفصل الثالث عشر الوديعة

ويقع في أربعة مباحث:

المبحث الأول : تعريف الوديعة والأصل في جوازها .

المبحث الثاني : رُكنُ الوديعة وشُرَائطُها

المبحث الثالث : وحُكْمُ الوديعة وحالها إذا ضاعت أو تلفت .

المبحث الرابع : ما يوجب تغير حاله.

أهداف الدرس

بدراسة عقد الوديعة يكتسب الطالب ما يلي:

أولاً: المعلومات والمفاهيم .

التعرف على معنى الوديعة لغة وشرعاً وأدلة مشروعيتها.

التعرف على الحكم التكليفي للوديعة وحكمة مشروعيتها والآثار المترتبة عليها.

التعرف على ركنها، وشُرَائطها، وحكمها، وكيفية حفظها، وحالها.

التعرف على الأحكام الفقهية المتعلقة بالوديعة .

التعرف على موجبات ضمان الوديعة.

التعرف على انتهاء عقد الوديعة .

ثانياً: المهارات الذهنية.

يستنبط الطالب الحالات التي يتغير فيها حال الوديعة من الأمانة إلى الضمان.

يحلل الطالب متى تكون الوديعة واجبة ومتى تكون مستحبة؟.

يستطيع الطالب أن يستنبط حالات تضمين الوديعة

المبحث الأول : تعريف الوديعة والأصل في جوازها .

أولاً: تعريف الوديعة.

الْوَدِيعَةُ فِي اللُّغَةِ : مُسْتَقَّةٌ مِنَ الْوَدْعِ ، وَهُوَ مُطْلَقُ التَّرِكَ . قَالَ اللَّهُ تَعَالَى ﴿ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى ﴾ (١) فُرِئْتُ بِالتَّخْفِيفِ وَالتَّشْدِيدِ ، وَالْمُودَعُ الشَّيْءُ الْمُنْزَوَكُ ، فَعَلَى الْعَبْدِ أَنْ يَسْأَلَ التَّوْفِيقَ عَلَى حِفْظِ وَدِيعَةِ اللَّهِ تَعَالَى وَعَلَى حِفْظِ جَمِيعِ الْأَمَانَاتِ فَإِنَّهُ فَرَضَ (٢) .
الْوَدِيعَةُ شَرْعاً : الْإِيْدَاعُ هُوَ تَسْلِيْطُ الْغَيْرِ عَلَى حِفْظِ مَالِهِ (٣) .

ثانياً : الأصل في الوديعة . الوديعة مشروعة بالكتاب ، والسنة ، والأثر ، والإجماع ، لأن فيها إعانة لصاحبها لحفظ ماله .
فأما الكتاب :

فَقَوْلُهُ تَعَالَى : ﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا ﴾ (٤) ، فَهِيَ وَإِنْ نَزَلَتْ فِي رَدِّ مِفْتَاحِ الْكَعْبَةِ إِلَى عُثْمَانَ بْنِ طَلْحَةَ فَهِيَ عَامَّةٌ فِي جَمِيعِ الْأَمَانَاتِ .
وَقَوْلُهُ تَعَالَى : ﴿ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ ﴾ (٥) .
وأما السنة :

فَقَوْلَ النَّبِيِّ ﷺ : { أَدِّ الْأَمَانَةَ إِلَى مَنْ ائْتَمَكَ وَلَا تَخُنْ مَنْ خَانَكَ } (٦) .
وَقَوْلَ النَّبِيِّ ﷺ : { عَلَى الْيَدِ مَا أَخَذْتُ حَتَّى تُؤَدِّيَهُ } (٧) .
وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : " آيَةُ الْمُنَافِقِ ثَلَاثٌ : إِذَا حَدَّثَ كَذَبًا ، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ ، وَإِذَا أُؤْتِمِنَ خَانَ " (٨) .

(١) سورة الضحى ، الآية : ٣ .

(٢) لسان العرب ج ٨ ص ٣٨٠ .

(٣) تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق - (ج ١٤ / ص ١٩٤) ، البحر الرائق شرح كنز الدقائق - (ج ٢٠ / ص ٣٦)

(٤) سورة النساء ، من الآية : ٥٨ .

(٥) سورة البقرة ، من الآية : ٢٨٣ .

(٦) الحاكم : المستدرک علی الصحیحین کتاب البیوع رقم ٢٢٩٦ ج ٢ ص ٥٣ ، وقال صحیح علی شرط مسلم ولم یخرجاه .

(٧) الحاكم : المستدرک علی الصحیحین کتاب البیوع رقم ٢٣٠٢ ج ٢ ص ٥٥ ، وقال صحیح الإسناد علی شرط البخاری ولم یخرجاه .

(٨) صحیح البخاری - کتاب الإیمان ، رقم ٣٣ ج ١ ص ١٦ .

فَعَلَى الْمُوَحِّدِ أَنْ يَحْتَرِزَ عَمَّا هُوَ مِنْ عَلَامَةِ الْمُنَافِقِ ، وَذَلِكَ بِأَنْ يَحْفَظَ الْوَدِيعَةَ عَلَى الْوَجْهِ الَّذِي يَحْفَظُ بِهِ مَالَ نَفْسِهِ ؛ فَيَضَعَهَا فِي بَيْتِهِ ، أَوْ صُنْدُوقِهِ ؛ لِأَنَّهُ وَعَدَ لِصَاحِبِهَا ذَلِكَ ، وَخَلَفَ الْوَعْدَ مَذْمُومٌ ، وَإِذَا تَرَكَ الْحِفْظَ بَعْدَ غَيْبَةِ صَاحِبِهَا : فَفِيهِ تَرَكُ الْوَفَاءِ بِمَا التَزَمَ ، وَالْعُرُورُ فِي حَقِّ صَاحِبِهَا ، وَذَلِكَ حَرَامٌ (١).

وروي عنه عليه السلام أنه كانت عنده ودائع فلما أراد الهجرة أودعها عند أم أيمن وأمر عليا أن يردها على أهلها .

وأما الأثر :

عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ : (الْقَتْلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُكَفِّرُ كُلَّ ذَنْبٍ إِلَّا الْأَمَانَةَ يُؤْتَى بِصَاحِبِهَا وَإِنْ كَانَ قُتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيُقَالُ لَهُ : أَدَّ أَمَانَتَكَ فَيَقُولُ : رَبِّ ذَهَبَتِ الدُّنْيَا فَمِنْ أَيْنَ أُودِّيَهَا فَيَقُولُ : أَذْهَبُوا بِهِ إِلَى الْهَآوِيَةِ حَتَّى إِذَا أُتِيَ بِهِ إِلَى قَرَارِ الْهَآوِيَةِ مَثَلَتْ لَهُ أَمَانَتُهُ كَيَوْمٍ دُفِعَتْ إِلَيْهِ فَيَحْمِلُهَا عَلَى رَقَبَتِهِ يَصْعَدُ بِهَا فِي النَّارِ حَتَّى إِذَا رَأَى أَنَّهُ خَرَجَ مِنْهَا هَوَتْ وَهَوَى فِي أَثَرِهَا أَبَدَ الْآبِدِينَ) وَقَرَأَ عَبْدُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا ﴿٢﴾ ، (٣).

وَرَوَى الْبَيْهَقِيُّ عَنْ عُمَرَ . رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ . أَنَّهُ قَالَ وَهُوَ يَخْطُبُ لِلنَّاسِ : (لَا يُعْجِبَنَّكُمْ مِنَ الرَّجُلِ طُنْطُنَتُهُ (٤) ، وَلَكِنْ مَنْ أَدَّى الْأَمَانَةَ وَكَفَّ عَنْ أَعْرَاضِ النَّاسِ ، فَهُوَ الرَّجُلُ) (٥).

(١) السرخسي : المبسوط - (ج ١٣ / ص ٢٤٤)

(٢) سورة النساء ، من الآية : ٥٨ .

(٣) سنن البيهقي الكبرى - رقم ١٣٠٦٧ (ج ٦ / ص ٢٨٨)

(٤) والطَّنْطَنَةُ كثرة الكلام والتصويت به والطَّنْطَنَةُ الكلام الخفي وطَّنَ الرجلُ مات وكذلك لَعِقَ إصْبَعَهُ والطَّنُ القامة . /

لسان العرب - (ج ١٣ ص ٢٦٨)

(٥) البيهقي . السنن الكبرى . كتاب الوديعه . باب ما جاء في الترغيب في أداء الأمانات رقم ١٢٤٧٥ ج ٦ ص ٢٨٨ .

وأما الإجماع:

فاجمع علماء كل عصر على جواز الإيداع والإستيداع والعبرة تقتضيها، فإنَّ بالنَّاسِ حَاجَةً بَلْ ضَرُورَةً إِلَيْهَا ، فإنه يتعذر على جميعهم حفظ أموالهم بأنفسهم ويحتاجون إلى من يحفظ لهم .

وقبول الوديعة مستحب لمن يعلم من نفسه الأمانة، لأن فيه قضاء حاجة أخيه المؤمن ومعاونته، وهي عقد جائز من الطرفين متى أراد المودع أخذ وديعته لزم المستودع ردها لقوله تعالى : ﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا ﴾ (١)، فإن أراد المستودع ردها على صاحبها لزمه قبوله لأن المستودع متبرع بإمسакها فلا يلزمه التبرع في المستقبل.

وَمَنْ عَجَزَ عَنْ حِفْظِهَا حَرَّمَ عَلَيْهِ قَبُولُهَا ، لِأَنَّهُ يُعَرِّضُهَا لِلتَّلَفِ ، وَمَنْ قَدَرَ وَلَمْ يَتَّقْ بِأَمَانَتِهِ كُرْهًا ، فَإِنْ وَثِقَ أُسْتُحِبَّ .

وَحِفْظُهَا يُوجِبُ سَعَادَةَ الدَّارَيْنِ وَالْخِيَانَةُ تُوجِبُ الشَّقَاءَ فِيهِمَا.

المبحث الثاني : ركن الوديعة وشرايطها

أولاً : ركن الوديعة ، وشرايط الركن .

ركن الوديعة : الإيجاب، والقبول .

وهو : أن يقول لغيره : أودعتك هذا الشيء ، أو احفظ هذا الشيء لي ، أو خذ هذا الشيء وديعة عندك ، وما يجري مجراه ، ويقبله الآخر ، فإذا وجد ذلك ؛ فقد تم عقد الوديعة .

ثانياً : وأما شرايط الركن فأنواع منها :

١ . عقل المودع ، فلا يصح الإيداع من المجنون ، والصبي ، الذي لا يعقل ؛ لأن العقل شرط أهلية التصرفات الشرعية .

وأما بلوغه : فليس بشرط عند الحنفية ، حتى يصح الإيداع من الصبي المأذون ؛ لأن ذلك مما يحتاج إليه التاجر ؛ فكان من توابع التجارة ، فيملكه الصبي المأذون ، كما يملك التجارة .

(١) سورة النساء ، من الآية : ٥٨ .

وعند الشافعي: لا يملك التجارة ، فلا يملك توابعها .
وكذا حرّيته ليست بشرط فيملك العبد المأذون الإيداع ، لما قلنا في الصبي
المأذون .

٢ . عقل المودّع فلا يصح قبول الوديعة من المجنون ، والصبي الذي لا
يعقل؛ لأن حكم هذا العقد هو لزوم الحفظ ، ومن لا عقل له لا يكون من أهل الحفظ.
وأما بلوغه : فليس بشرط ، حتى يصح قبول الوديعة من الصبي المأذون ؛ لأنه
من أهل الحفظ ؛ لأن الولي أذن له ، ولو لم يكن من أهل الحفظ لكان الإذن له سفها.
وأما الصبي المحجور عليه ، فلا يصح قبول الوديعة منه ؛ لأنه لا يحفظ المال
عادة ألا ترى أنه منع منه ماله ؟ ولو قبل الوديعة فاستهلكها ؛ فإن كانت الوديعة عبدا
أو أمة ؛ يضمن بالإجماع .

وإن كانت سواهما: فإن قبلها بإذن الولي فذلك ، وإن قبلها بغير إذنه - لا ضمان
عليه عند أبي حنيفة ومحمد ، وعند أبي يوسف : يضمن .
وجه قوله : أن إيداعه لو صح فاستهلك الوديعة ؛ يوجب الضمان ، وإن لم يصح ؛
جعل كأنه لم يكن ، فصار الحال بعد العقد كالحال قبله، ولو استهلكها قبل العقد ؛
لوجب عليه الضمان إذا كانت الوديعة عبدا أو أمة .

وجه قولهما : أن إيداع الصبي المحجور إهلاك للمال معنى ، فكان فعل الصبي
إهلاك مال قائم صورة لا معنى ، فلا يكون مضمونا عليه .

ودلالة ذلك : أنه لما وضع المال في يده ، فقد وضع في يد من لا يحفظه عادة ،
ولا يلزمه الحفظ شرعا ، ولا شك أنه لا يجب عليه حفظ الوديعة شرعا ؛ لأن الصبي
ليس من أهل وجوب الشرائع عليه.

والدليل على أنه لا يحفظ الوديعة عادة ؛ أنه منع عنه ماله ولو كان يحفظ المال
عادة لدفع إليه ، قال الله تبارك وتعالى : ﴿ فَإِنْ أَنْسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ
أَمْوَالَهُمْ ﴾ (١)، وبهذا فارق المأذون ؛ لأنه يحفظ المال عادة ، ألا ترى أنه دفع إليه

(١) سورة النساء ، من الآية ٦ .

ماله . حِفْظُ مَالِهِ، ولو لم يوجد منه الحفظ عادة ؛ لكان الدفع إليه سفها ، بخلاف ما إذا كانت الوديعة عبدا أو أمة ؛ لأن هناك لا يجب عليه ضمان المال أيضا ؛ وإنما يجب عليه ضمان الدم ؛ لأن الضمان الواجب بقتل العبد ضمان الآدمي ، لا ضمان المال ، والعبد من حيث إنه آدمي قائم من كل وجه قبل الإيداع وبعده ، فهو الفرق .

وكذلك حرية المودع ليست بشرط لصحة العقد ، حتى يصح القبول من العبد المأذون، ويترتب عليه أحكام العقد ، لأنه يحتاج إلى الإيداع والاستيداع .

وأما العبد المحجور فلا يصح منه القبول ؛ لأنه لا يحفظ المال عادة ، ولو قبلها فاستهلكها ، فإن كانت عبدا أو أمة يؤمر المولى بالدفع أو الفداء، وإن كانت سواهما ، فإن قبلها بإذن وليه، يضمن بالإجماع ، وإن قبلها بغير إذن وليه لا يؤاخذ به في الحال عند أبي حنيفة ومحمد . وعند أبي يوسف يؤاخذ به في الحال ، كما في الصبي المحجور .

المبحث الثالث : حُكْمُ الْوَدِيعَةِ وَحَالِهَا إِذَا ضَاعَتْ أَوْ تَلَفَتْ .

أولاً : حكم الوديعة .

حكم عقد الوديعة : لزوم الحفظ للمالك ، لأن الإيداع من جانب المالك استحقاق . ومن جانب المودع التزام الحفظ وهو من أهل الالتزام فيلزمه لقوله : عليه الصلاة والسلام «الْمُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ ، إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا» والكلام في الحفظ في موضعين :

أحدهما : فيما يحفظ به . والثاني : فيما فيه يحفظ .

أما الأول : فالاستحفاظ لا يخلو من أن يكون مطلقا أو مقيدا .

فإن كان مطلقا : فللمودع أن يحفظ بيد نفسه ، ومن هو في عياله، وهو الذي يسكن معه ، ويمونه ، فيكفيه طعامه ، وشرابه ، وكسوته ، كائنا من كان قريبا ، أو أجنبيا ، من ولده ، وامرأته ، وخدمه ، وأجيريه ، لا الذي استأجره بالدرهم والدنانير ، ويبيده من ليس في عياله ممن يحفظ ماله بنفسه عادة ، كشريكه المفاوض ، والعنان ، وعنده المأذون ، وعنده المعزول عن بيته ، هذا عند الحنفية .

وقال الشافعي - رحمه الله - : ليس له أن يحفظ إلا بيد نفسه، إلا أن يستعين بغيره من غير أن يغيب عن عينه ، حتى لو فعل يدخل في ضمانه .
وجه قوله: أن العقد تناوله دون غيره ، فلا يملك الإيداع من غيره، كما لا يملك الإيداع سائر الأجانب .

وللحنفية: أن الملتزم بالعقد هو الحفظ ، والإنسان لا يلتزم بحفظ مال غيره عادة ؛ إلا بما يحفظ به مال نفسه ، وإنه يحفظ مال نفسه بيده مرة ويبد هؤلاء أخرى ، فله أن يحفظ الوديعة بيدهم أيضا، فكان الحفظ بأيديهم داخلا تحت العقد دلالة ، وكذا له أن يرد الوديعة على أيديهم ، حتى لو هلك قبل الوصول إلى المالك ، لا ضمان عليه ؛ لأن يدهم يد المودع معنى ، فما دام في أيديهم ؛ كان محفوظا بحفظه .

وليس له أن يدفع الوديعة إلى غيرهم ، إلا لعذر ، حتى لو دفع ، تدخل في ضمانه ؛ لأن المالك ما رضي بيده ، لأنه لا يرضى مال نفسه بيده ، فإذا دفع ؛ فقد صار مخالفا ، فتدخل الوديعة في ضمانه إلا إذا كان عن عذر ، بأن وقع في داره حريق، أو كان في السفينة فخاف الغرق ؛ فدفعه إلى غيره ؛ لأن الدفع إليه في هذه الحالة تعين طريقا للحفظ ، فكان الدفع بإذن المالك دلالة فلا يضمن .

فلو أراد السفر ؛ فليس له أن يودع ؛ لأن السفر ليس بعذر .
ولو أودعها عند من ليس له أن يودعه ، فضاعت في يد الثاني، فالضمان على الأول ، لا على الثاني عند أبي حنيفة .

وعند أبي يوسف ، ومحمد : المالك بالخيار ، إن شاء ضمن الأول وإن شاء ضمن الثاني ، فإن ضمن الأول لا يرجع بالضمان على الثاني ، وإن ضمن الثاني يرجع به على الأول .

وجه قولهما : أنه وجد من كل واحد منهما سبب وجوب الضمان .
أما الأول : فلأنه دفع مال الغير إلى غيره بغير إذنه .
وأما الثاني : فلأنه قبض مال الغير بغير إذنه ، وكل واحد منهما سبب لوجوب الضمان ، فيخير المالك إن شاء ضمن الأول ، وإن شاء ضمن الثاني ، غير أنه إن ضمن الأول ؛ لا يرجع بالضمان على الثاني، لأنه ملك الوديعة بأداء الضمان فتبين

أنه أودع ماله نفسه إياه فهذا مودع هلكت الوديعة في يده فلا شيء عليه ، وإن ضمن الثاني ، يرجع بالضمان على الأول ؛ لأن الأول غره بالإيداع ، فيلزمه ضمان الغرور .

وجه قول أبي حنيفة : أن يد المودع الثاني ليست بيد مانعة ، بل هي يد حفظ وصيانة الوديعة عن أسباب الهلاك ، فلا يصلح أن يكون سببا لوجوب الضمان ؛ لأنه من باب الإحسان إلى المالك ، قال الله تعالى - جل شأنه - : ﴿ مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ ﴾ (١) .

وكان ينبغي أن لا يجب الضمان على الأول أيضا ؛ لأن الإيداع منه مباشرة سبب الصيانة والحفظ له ، فكان محسنا فيه ، إلا أنه صار مخصوصا عن النص ، فبقي المودع الثاني على ظاهره .

ولو أودع غيره وادعى أنه فعل عن عذر ، لا يصدق على ذلك إلا ببينة عند أبي يوسف ، وهو قياس قول أبي حنيفة - رحمه الله - ؛ لأن الدفع إلى غيره سبب لوجوب الضمان في الأصل ، فدعوى الضرورة دعوى أمر عارض ، يريد به دفع الضمان عن نفسه ، فلا يصدق إلا بحجة ، هذا إذا هلك الوديعة في يد المودع الثاني .

فأما إذا استهلكها ، فالمالك بالخيار ، إن شاء ضمن الأول ، وإن شاء ضمن الثاني بالإجماع .

غير أنه إن ضمن الأول ، يرجع بالضمان على الثاني ، وإن ضمن الثاني ؛ لا يرجع بالضمان على الأول ؛ لأن سبب وجوب الضمان وجد من الثاني حقيقة ، وهو الاستهلاك ، ولم يوجد من الأول إلا الدفع إلى الثاني . فكان الضمان في الحقيقة على الثاني .

وأما الثاني : وهو فيما فيه تحفظ الوديعة .

فإن كان العقد مطلقا : فله أن يحفظها فيما يحفظ فيه مال نفسه من داره وحانوته وكيسه وصندوقه ؛ لأنه ما التزم حفظها إلا فيما يحفظ فيه مال نفسه ، وليس له أن

(١) سورة التوبة، من الآية ٩١ .

يحفظ في حرز غيره، ؛ لأن حرز غيره في يد ذلك الغير ، ولا يملك الحفظ بيده فلا يملكه بما في يده أيضا ، إلا إذا استأجر حرزا لنفسه ، فله أن يحفظ فيه ؛ لأن الحرز في يده فما في الحرز يكون في يده أيضا فكان حافظا بيد نفسه فملك ذلك .
وله أن يحفظ الحضر والسفر بأن يسافر بها عند أبي حنيفة سواء كان للوديعة حمل ومؤنة ، أو لم يكن .

وعند أبي يوسف ومحمد : إن كان لها حمل ومؤنة ؛ لا يملك المسافرة بها ، وإن لم يكن يملك .

وعند الشافعي - رحمه الله - : لا يملك كيف ما كان .
وجه قوله : أن المسافرة بالوديعة تضييع المال ؛ لأن المفازة مضيعة ، فكان التحويل إليها تضييعا فلا يملكه المودع .
وللحنفية : أن الأمر بالحفظ صدر مطلقا عن تعيين المكان ، فلا يجوز التعيين إلا بدليل .

قوله : المفازة مضيعة. قلنا : ممنوع أو نقول: إذا كان الطريق مخوفا أما إذا كان آمنا فلا ، والكلام فيما إذا كان الطريق آمنا ، والحديث محمول على ابتداء الإسلام ، حين كانت الغلبة للكفرة ، وكانت الطريق مخوفة ، ونحن به نقول .
وأما وجه قول أبي يوسف ومحمد : أن في المسافرة بما له حمل ومؤنة ضررا بالمالك ، لجواز أن يموت المودع في السفر ، فيحتاج إلى الاسترداد من موضع لا يمكنه ذلك ، إلا بحمل ومؤنة عظيمة فيتضرر به ، ولا كذلك إذا لم يكن لها حمل ومؤنة.

ولأبي حنيفة : أن الأمر بالحفظ لا يتعرض لمكان دون مكان، ولا يجوز تقييد المطلق من غير دليل .

والرد على قولهما فيه ضرر : أن هذا النوع من الضرر ليس بغالب ، فلا يجب دفعه ، على أنه إن كان ، فهو الذي أضر بنفسه حيث أطلق الأمر ، ومن لم ينظر لنفسه لا ينظر له. هذا إذا كان العقد مطلقا عن شرط .

فأما إذا شرط فيه شرطا نظر فيه ، إن كان شرطا يمكن اعتباره ويفيد ؛ اعتبر ، وإلا فلا ، بيان ذلك ؛ إذا أمره بالحفظ وشرط عليه أن يمسكها بيده ليلا ونهارا ولا يضعها ؛ فالشرط باطل حتى لو وضعها في بيته ، أو فيما يحرز فيه ماله عادة ، فضاعت ؛ لا ضمان عليه ؛ لأن إمساك الوديعة بيده ، بحيث لا يضعها - أصلا غير مقدور له عادة ، فكان شرطا لا يمكن مراعاته ، فيلغى .

ولو أمره بالحفظ ونهاه أن يدفعها إلى امرأته ، أو عبده ، أو ولده الذي هو في عياله ؛ أو من يحفظ مال نفسه بيده عادة .

نظر فيه إن كان لا يجد بدا من الدفع إليه ؛ له أن يدفع ؛ لأنه إذا لم يجد بدا من الدفع إليه كان النهي عن الدفع إليه نهيا عن الحفظ فكان سفها فلا يصح نهيه ، وإن كان يجد بدا من الدفع إليه ليس له أن يدفع .

ولو دفع - يدخل في ضمانه ؛ لأنه إذا كان له منه يد في الدفع إليه أمكن اعتبار الشرط وهو مفيد ؛ لأن الأيدي في الحفظ متفاوتة ، والأصل في الشروط اعتبارها ما أمكن .

ولو قال : لا تخرجها من الكوفة ، فخرج بها تدخل في ضمانه ؛ لأنه شرط يمكن اعتباره وهو مفيد ؛ لأن الحفظ في المصر أكمل من الحفظ في السفر ؛ إذ السفر موضع الخطر ؛ إلا إذا خاف التلف عليها ، فاضطر إلى الخروج بها ، فخرج لا تدخل في ضمانه ؛ لأن الخروج في هذه الحالة طريق متعين للحفظ ، كما إذا وقع في داره حريق ؛ أو كان في سفينة فخاف الغرق ، فدفعها إلى غيره .

ولو قال له : احفظ الوديعة في دارك هذه ، فحفظها في دار له أخرى ، فإن كانت الداران في الحرز سواء أو كانت الثانية أحرز ، لا تدخل في ضمانه ؛ لأن التقيد غير مفيد ، وإن كانت الأولى أحرز من الثانية دخلت في ضمانه ؛ لأن التقيد به عند تفاوت الحرز مفيد .

ولو قال له: أخبئها في هذا البيت ، وأشار إلى بيت معين في داره فخبأها في بيت آخر في تلك الدار ، لا تدخل في ضمانه ؛ لأن البيتين من دار واحدة ، لا يختلفان في

الحرز عادة ، بخلاف الدارين ، فلا يكون التعيين مفيدا ، حتى لو تفاوتنا بأن كان الأول أحرز من الثاني ، تدخل في ضمانه .

والأصل المحفوظ في هذا الباب ، أن كل شرط يمكن مراعاته ، ويفيد فهو معتبر ، وكل شرط لا يمكن مراعاته ، ولا يفيد فهو هدر ، وهذا عند الحنفية .

وعند الشافعي : تجب مراعاة الشروط في المواضع كلها حتى أن المأمور بالحفظ في بيت معين لا يملك الحفظ في بيت آخر من دار واحدة .

ثانياً : حال الوديعة إذا ضاعت أو تلفت .

الوديعة في يد المودع أمانة ؛ لأن المودع مؤتمن ، فكانت الوديعة أمانة في يده ، ويتعلق بكونها أمانة أحكام منها :

١ . وجوب الرد عند طلب المالك ، لقوله تعالى - جل شأنه - : ﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا ﴾ (١) .

حتى لو حبسها بعد الطلب فضاعت ضمن هذا إذا كانت الوديعة لرجل واحد .
فأما إذا كانت مشاعاً لرجلين ، فجاء أحدهما ، وطلب حصته لا يجب عليه الرد ؛ بأن أودع رجلان رجلاً وديعة ، دراهم ، أو دنانير أو ثياباً ، وغاب ثم جاء أحدهما ، وطلب بعضها ، وأبى المستودع ذلك ، لم يأمر القاضي بدفع شيء إليه ما لم يحضر الغائب عند أبي حنيفة .

وقال أبو يوسف ومحمد : يقسم ذلك ، ويدفع إليه حصته ، ولا يكون ذلك قسمة جائزة على الغائب بلا خلاف .

حتى لو هلك الباقي في يد المودع ، ثم جاء الغائب له أن يشارك صاحبه في المقبوض عندهم جميعاً . ولو هلك المقبوض في يد القابض ثم جاء الغائب فليس للقابض أن يشارك صاحبه في الباقي .

(١) سورة النساء ، من الآية : ٥٨ .

وجه قول أبي يوسف ومحمد : أن الآخذ بأخذ حصته متصرف في ملك نفسه ، فكان له ذلك من غير حضرة الغائب ، كما إذا كان لرجلين دين مشترك على رجل ، فجاء أحدهما وطلب حصته من الدين ؛ فإنه يدفع إليه حصته لما قلنا كذا هذا .

وجه قول أبي حنيفة : أن المودع لو دفع شيئاً إلى الشريك الحاضر ، لا يخلو إما أن يدفع إليه من النصيبين جميعاً ، وإما أن يدفع إليه من نصيبه خاصة ، لا وجه إلى الأول ؛ لأن دفع نصيب الغائب إليه ممتنع شرعاً .

ولا سبيل إلى الثاني ؛ لأن نصيبه شائع في كل الألف ؛ لكون الألف مشتركة بينهما ، ولا تتميز إلا بالقسمة ، والقسمة على الغائب غير جائزة ؛ ولو سلمنا ذلك حتى قالوا : إذا جاء الغائب وقد هلك الباقي ، له أن يشارك القابض في المقبوض . ولو نفذت القسمة لما شاركه فيه ؛ لتمييز حقه عن حق صاحبه بالقسمة .

والقياس على الدين المشترك غير سديد ؛ لأن الغريم يدفع نصيب أحد الشريكين ، بدفع مال نفسه لا مال شريكه الغائب ، وهنا يدفع مال الغائب بغير إذنه ، فلا يستقيم القياس .

٢ . إذا ضاعت في يد المودع بغير صنعه ، لا يضمن ، لما روي عن النبي ﷺ ، قَالَ : « لَيْسَ عَلَى الْمُسْتَعِيرِ غَيْرِ الْمُغْلِ ضَمَانٌ ، وَلَا عَلَى الْمُسْتَوْدِعِ غَيْرِ الْمُغْلِ ضَمَانٌ » (١) ؛ ولأن يده يد المالك ، فالهلاك في يده كالهلاك في يد المالك . وكذلك إذا دخلها نقص ؛ لأن النقصان هلاك بعض الوديعة ، وهلاك الكل لا يوجب الضمان ، فهلاك البعض أولى .

المبحث الرابع : ما يوجب تغير حاله ..

ما يغير حال المعقود عليه من الأمانة إلى الضمان ، أنواع :

١ . ترك الحفظ ؛ لأنه بالعقد التزم حفظ الوديعة على وجه لو ترك حفظها حتى هلكت يضمن بدلها ، وذلك بطريق الكفالة ، ولهذا لو رأى إنساناً يسرق الوديعة ، وهو قادر على منعه ضمن ، ؛ لترك الحفظ الملتزم بالعقد ، وهو معنى قول مشايخ الحنفية إن المودع يؤخذ بضمان العقد .

(١) سنن الدارقطني . ١٣ كتاب البيوع . رقم ٢٩٦١ ج ٣ ص ٤٥٦ .

٢ . ترك الحفظ للمالك بأن خالفه في الوديعة، بأن كانت الوديعة ثوبا فلبسه ، أو دابة فركبها ، أو عبدا فاستعمله ، أو أودعها من ليس في عياله ، ولا هو ممن يحفظ ماله بيده عادة ؛ لأن الملتزم بالعقد هو الحفظ للمالك ، فإذا حفظ لنفسه ، فقد ترك الحفظ للمالك ، فدخلت في ضمانه .

٣ . إِذَا اخْتَلَفَا الْمُودِعُ مَعَ الْمُودَعِ فَقَالَ الْمُودِعُ : هَلَكَتِ الْوَدِيعَةُ أَوْ رَدَدْتُهَا إِلَيْكَ . وقال المالك : استهلكتها ، إن كان قبل الخلاف فالقول قول المودع ، وإن كان بعده فالقول قول المالك ، ونحو ذلك مما يدل على دخول الوديعة في ضمانه بالخلاف . وإن خالف في الوديعة ، ثم عاد الوفاق ، يبرأ عن الضمان عند أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد .

وعند زفر ، والشافعي : لا يبرأ عن الضمان . وجه قولهما : أن الوديعة لما دخلت في ضمان المودع بالخلاف ؛ فقد ارتفع العقد ، فلا يعود إلا بالتجديد ، ولم يوجد ؛ فصار كما لو جحد الوديعة ، ثم أقر بها ، وكذلك المستعير ، والمستأجر ، إذا خالفا ، ثم عاد إلى الوفاق ، لا يبرآن عن الضمان لما قلنا كذا هذا .

ولأبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد : إِنَّهُ بَعْدَ الْخِلَافِ مُودِعٌ ، وَالْمُودِعُ إِذَا هَلَكَتِ الْوَدِيعَةُ مِنْ غَيْرِ صُنْعِهِ لَا ضَمَانَ عَلَيْهِ ، كَمَا قَبْلَ الْخِلَافِ ، وَدَلَالَةُ أَنَّهُ بَعْدَ الْخِلَافِ مُودِعٌ ، أَنَّ الْمُودِعَ مَنْ يَحْفَظُ مَالَ غَيْرِهِ لَهُ بِأَمْرِهِ ، وَهُوَ بَعْدَ الْخِلَافِ وَالِاشْتِغَالِ بِالْحِفْظِ حَافِظٌ مَالَ الْمَالِكِ لَهُ بِأَمْرِهِ ؛ لِأَنَّ الْأَمْرَ تَتَأَوَّلُ مَا بَعْدَ الْخِلَافِ .

٤ . جحد الوديعة في وجه المالك عند طلبه ، حتى لو قامت البينة على الإيداع ، أو نكل المودع عن اليمين ، أو أقر به ، دخلت في ضمانه ؛ لأن العقد لما ظهر بالحجة ؛ فقد ظهر ارتفاعه بالجحد ، أو عنده ؛ لأن المالك لما طلب منه الوديعة ، فقد عزله عن الحفظ ، والمودع لما جحد الوديعة حال حضرة المالك ، فقد عزل نفسه عن الحفظ ؛ فانفسخ العقد ، فبقي مال الغير في يده بغير إذنه ؛ فيكون مضمونا عليه ، فإذا هلك تقرر الضمان .

ولو جحد ، الودیعة ، ثم أقام البينة على هلاكها ، فهذا لا يخلو من ثلاثة أوجه :
إما إن أقام البينة على أنها هلكت بعد الجحود ، أو قبل الجحود ، أو مطلقا .
فإن أقام البينة على أنها هلكت بعد الجحود ، أو مطلقا لا ينتفع ببينته ؛ لأن العقد
ارتفع بالجحود ، أو عنده ؛ فدخلت العين في ضمانه ، والهالك بعد ذلك يقرر الضمان
، لا أن يسقطه .

وإن أقام البينة على أنها هلكت قبل الجحود ، تسمع بينته ولا ضمان عليه ؛ لأن
الهالك قبل الجحود لما ثبتت بالبينة ؛ فقد ظهر انتهاء العقد قبل الجحود ، فلا يرتفع
بالجحود ، فظهر أن الودیعة هلكت من غير صنعه ، فلا يضمن .

ولو ادعى الهالك قبل الجحود ولا بينة له ، وطلب اليمين من المودع ، حلفه
القاضي بالله تعالى ما يعلم أنها هلكت قبل جحوده ؛ لأنه الأصل في باب الاستحلاف
، أن الذي يستحلف عليه لو كان أمرا ، لو أقر به الحالف للزمه ، فإذا أنكر يستحلف
وهنا كذلك ؛ لأن المالك لو أقر بالهلاك قبل الجحود لقبل منه ، ويسقط الضمان عن
المودع فإذا أنكر يستحلف ، لكن على العلم ؛ لأنه يستحلف على فعل غيره ، هذا إذا
جحد حال حضرة المالك .

فإن جحد عند غير المالك حال غيبته .

قال أبو يوسف : لا يضمن .

وقال زفر - رحمه الله - : يضمن في الحالين جميعا .

وجه قول زفر : أن ما هو سبب وجوب الضمان لا يختلف بالحضرة ، والغيبة
كسائر الأسباب .

وجه قول أبي يوسف : أن الجحود سبب للضمان من حيث إنه يرفع العقد بالعزل
على ما بينا .

ولا يصح العزل حالة الغيبة ، فلا يرتفع العقد ؛ ولأن الجحود عند غير المالك حال
غيبته معدود من باب الحفظ والصيانة عرفا ، وعادة ؛ لأن مبنى الإيداع على الستر ،
والإخفاء ، فكان الجحود عند غير المالك - حال غيبته - حفظا معني ، فكيف يكون
سببا لوجوب الضمان ؟

٥ . الإلتلاف حقيقة أو معنى وهو إعجاز المالك عن الانتفاع بالوديعة، لأن إلتلاف مال الغير بغير إذنه سبب لوجوب الضمان حتى لو طلب الوديعة ، فمنعها المودع مع القدرة على الدفع ، والتسليم إليه ، حتى هلكت ، يضمن ؛ لأنه لما حبسها عنه ؛ عجز عن الانتفاع بها للحال ؛ فدخلت في ضمانه ، فإذا هلكت تقرر العجز ؛ فيجب الضمان.

ولو أمر غيره بالإلتلاف ، وادعى ؛ أنه كان بإذن المالك ، لا يصدق إلا ببينة ؛ لأن الإلتلاف سبب لوجوب الضمان في الأصل ، وقوله : كان بإذن المالك دعوى أمر عارض ، فلا تقبل إلا بحجة .

٦ . إذا خلط المودع الوديعة بماله خلطا لا يتميز ، يضمن ؛ لأنه إذا كان لا يتميز ، فقد عجز المالك من الانتفاع بالوديعة ؛ فكان الخلط منه إلتافا ؛ فيضمن ، ويصير ملكا بالضمان، وإن مات كان ذلك لجميع الغرماء ، والمودع أسوة الغرماء فيه .

ولو اختلطت بماله بنفسها من غير صنعه لا يضمن وهو شريك لصاحبها، أما عدم وجوب الضمان ؛ فلانعدام الإلتلاف منه ، بل تلفت بنفسها ؛ لانعدام الفعل من جهته . وأما كونه شريكا لصاحبها ؛ فلوجود معنى الشركة ؛ وهو اختلاط الملكين.

ولو أودعه رجلان ، كل واحد منهما ألف درهم ، فخلط المودع المالين خلطا لا يتميز ؛ فلا سبيل لهما على أخذ الدراهم ؛ يضمن المودع لكل واحد منهما ألفا ويكون المخلوط له وهذا قول أبي حنيفة.

وقال أبو يوسف ومحمد : هما بالخيار إن شاء اقتسما المخلوط نصفين ، وإن شاء ضمنا المودع ألفين ، وعلى هذا الخلاف سائر المكيلات ، والموزونات ، إذا خلط الجنس بالجنس خلطا لا يتميز ، كالحنطة بالحنطة ، والشعير بالشعير ، والدهن بالدهن .

وجه قولهما: أن الوديعة قائمة بعينها ، لكن عجز المالك عن الوصول إليها بعارض الخلط ، فإن شاء اقتسما ؛ لاعتبار جهة القيام ، وإن شاء ضمنا ، لاعتبار جهة العجز.

وجه قول أبي حنيفة : أنه لما خلطهما خطأ لا يتميز ، فقد عجز كل واحد منهما عن الانتفاع بالمخلوط ؛ فكان الخلط منه إتلاف الوديعة عن كل واحد منهما ؛ فيضمن ؛ ولهذا يثبت اختيار التضمين عندهما واختيار التضمين لا يثبت إلا بوجود الإتلاف ، دل أن الخلط منه وقع إتلافا .

ولو أودعه رجل حنطة ، وآخر شعيرا ، فخلطهما ، فهو ضامن لكل واحد منهما مثل حقه عند أبي حنيفة ؛ لأن الخلط إتلاف .

وعندهما : لهما أن يأخذا العين ، ويبيعاها ، ويقتسما الثمن على قيمة الحنطة مخلوطا بالشعير ، وعلى قيمة الشعير غير مخلوط بالحنطة ؛ لأن قيمة الحنطة تنقص بخلط الشعير ؛ وهو يستحق الثمن لقيام الحق في العين ، وهو مستحق العين ، بخلاف قيمة الشعير ؛ لأن قيمة الشعير تزداد بالخلط بالحنطة ، وتلك الزيادة ملك الغير ، فلا يستحقها صاحب الشعير .

٧ . لو أنفق المودع بعض الوديعة ؛ ضمن قدر ما أنفق ، ولا يضمن الباقي ؛ لأنه لم يوجد منه إلا إتلاف قدر ما أنفق .

ولو رد مثله فخلطه بالباقي يضمن الكل ؛ لوجود إتلاف الكل منه : النصف بالإتلاف ، والنصف الباقي بالخلط ؛ لكون الخلط إتلافا على ما بينا .

ولو أخذ بعض دراهم الوديعة ؛ لينفقها فلم ينفقها ، ثم ردها إلى موضعها بعد أيام ؛ فضاعت لا ضمان عليه عند الحنفية .

وعند الشافعي : يضمن .

وجه قوله : أنه أخذها على وجه التعدي ؛ فيضمن كما لو انتفع بها .

والحنفية: أن نفس الأخذ ليس بإتلاف ، ونية الإتلاف ليست بإتلاف ؛ فلا توجب الضمان .

والأصل فيه ما روي عن أبي هريرة، عن رسول الله ﷺ قال: { إِنَّ اللَّهَ عَفَا عَنْ أُمَّتِي مَا حَدَّثَتْ بِهِ أَنْفُسَهَا مَا لَمْ تَعْمَلْهُ أَوْ تَكَلَّمْ بِهِ } (١).

ظاهر الحديث : يقتضي أن يكون ما حدثت به النفس عفوا على العموم ، إلا ما خص بدليل .

وعلى هذا الخلاف إذا أودعه كيسا مسدودا ؛ فحله المستودع ، أو صندوقا مقفلا ، ففتح القفل ؛ ولم يأخذ منه شيئا ، حتى ضاع أو مات المودع ؛ فإن كانت الوديعة قائمة بعينها ترد على صاحبها ؛ لأن هذا عين ماله ، لقول رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : «مَنْ وَجَدَ عَيْنَ مَالِهِ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ».... (١) ، وإن كانت لا تعرف بعينها ، فهي دين في تركته يحاص الغرماء ؛ لأنه لما مات مجهلا للوديعة ، فقد ألتفها معنى ، لخروجها من أن يكون منتقعا بها في حق المالك بالتجهيل ، وهو تفسير الإلتاف .

ولو قال الورثة : إنها هلكت أو ردت على المالك ، لا يصدقون على ذلك ؛ لأن الموت مجهلا سبب لوجوب الضمان ، لكونه إلتافا ، فكان دعوى الهلاك ، والرد دعوى أمر عارض فلا يقبل إلا بحجة ، ويحاص المودع الغرماء ؛ لأنه دين الاستهلاك ؛ فيساوي دين الصحة (٢).

وجاء في مختصر القُدوري ما يدل على ذلك حيث قال : "الوديعة: أمانة في يد المودع إذا هلكت لم يضمنها وللمودع أن يحفظها بنفسه وبمن في عياله، فإن حفظها بغيرهم أو أودعها ضمن إلا أن يقع في داره حريق فيسلمها إلى جاره أو يكون في سفينة يخاف الغرق فلقنها إلى سفينة أخرى وإن خلطها المودع بماله حتى لا تتميز ضمنها فإن طلبها صاحبها فحبسها عنه وهو يقدر على تسليمها ضمنها وإن اختلطت بماله من غيره فعله فهو شريك لصاحبها وإن أنفق المودع بعضها ثم رد مثله فخلطه بالباقي ضمن الجميع وإذا تعدى المودع في الوديعة - بأن كانت دابة فركبها أو ثوبا فلبسه أو عبدا فاستخدمه أو أودعها عند غيره - ثم أزال التعدي وردها إلى يده زال الضمان فإن طلبها صاحبها فجدها إياه فهلكت ضمنها فإن عاد إلى الاعتراف لم يبرأ من الضمان وللمودع أن يسافر بالوديعة وإن كان لها حمل ومؤنة وإذا أودع رجلان

(١) المعجم الكبير للطبراني (٧/ ٢٠٧).

(٢) الكاساني : بدائع الصنائع ج ٥ ص ٣٠٧ . ٣١٧ .

عند رجل وديعة ثم حضر أحدهما فطلب نصيبه منها لم يدفع إليه شيئاً حتى يحضر الآخر عند أبي حنيفة وقال أبو يوسف ومحمد: يدفع إليه نصيبه وإن أودع رجل عند رجلين شيئاً مما يقسم لم يجز أن يدفعه أحدهما إلى الآخر ولكنهما يقتسمانه فيحفظ كل واحد منهما نصفه وإن كان مما لا يقسم جاز أن يحفظه أحدهما بإذن الآخر وإذا قال صاحب الوديعة للمودع: لا تسلمها إلى زوجتك فسلمها إليها لم يضمن وإن قال له: احفظها في هذا البيت فحفظها في بيت آخر من الدار لم يضمن فإن حفظهما في دار أخرى ضمن" (١)

ومن خلال ما سبق يمكن أن نستنتج عدة نتائج على النحو التالي:

١- الوديعة هي تسليط الغير على حفظ المال صراحة أو دلالة وهي مشروعة بالكتاب والسنة والإجماع والمعقول .

٢- الفرق بين الوديعة والامانة: أنَّ الأمانة أعمُّ من الوديعة؛ فالأمانة تشمل الوديعة وغيرها من الصور التي لا ضمان فيها كالعارية؛ فكلُّ وديعة أمانة، وليس كلُّ أمانة وديعة .

الفرق بين الوديعة والعارية: أنَّ الوديعة هي عين يضعها مالكها أو نائبه عند آخر ليحفظها، وأمَّا العارية فهي: إباحة الانتفاع بما يحلُّ الانتفاع به مع بقاء عينه. الأثر المترتب على كل منهما:

أنَّ العارية مضمونة، فرط المستعير أو لم يفرط، أمَّا الوديعة فلا تضمن إلا إن تعدى أو فرط.

أنَّ العارية أخذتها اليد للانتفاع بها منفرداً، أمَّا الوديعة فإنَّها تُدفع إلى المودع لحفظها نفعاً لمالكها.

الوديعة عقد جائز غير لازم ، يجوز لكل واحد من العاقلين فسخ الإيداع متى شاء. وإن طلبها صاحبها وجب ردها إليه، وإن ردها المودع لزم صاحبها قبولها، وهي من التعاون على البر والتقوى.

(١) مختصر القدوري لأبي الحسين القدوري ص ١٣١.

حكمة مشروعية الوديعة:

حاجة الناس إليها ؛ لأنها من باب التعاون على البر والتقوى وفيها تنفيس عن الناس ، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه وفيها التيسير على الناس، وتحقيق مصلحتهم، ودفع الحرج عنهم، فهم في حاجة شديدة لأن يستعين بعضهم ببعض؛ لحفظ أموالهم وصيانة أمتعتهم، فقد يكون أحد الناس يريد السفر لقضاء مصلحة، ولا يأمن أن يترك ماله وما لديه دون رعاية أو إشراف.

الحكم التكليفي للوديعة: الوديعة تعثرها الأحكام التكليفية الخمسة.

رُكْنُ الوديعة: عند السادة الحنفية: الإيجاب والقبول.

مصطلحات خاصة بالوديعة: العين المودعة: تسمى وديعة، والصيغة: الإيجاب والقبول صراحة أو كناية، والمودع - بكسر الدال - هو صاحب الوديعة الأصلي، والمودع - بفتح الدال - ويقال له وديع: وهو الأمين الذي يحفظ الوديعة.

ويشترط في الوديعة: أن يكون المال قابلاً لإثبات اليد عليه فلا يجوز أن يدع مالا لا يمكن إثبات اليد عليه مثل السمك في الماء والطير في الهواء.

لا يشترط للوديع الحافظ للوديعة معرفة نوع الوديعة فقد يقبلها في ظرف مغلق ولا يجوز له معرفة ما فيها .

من أحكام الوديعة: أنها إذا تلفت عند المودع (بفتح الدال) وهو الأمين على الوديعة ولم يفرط؛ فإنه لا يضمنها؛ كما لو تلفت منه .

ومن أحكام الوديعة: أنه يجب على المودع حفظها في حرز مثلها كما يحفظ ماله؛ لأن الله تعالى أمر بأدائها في قوله: {إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ} (النساء: ٥٨) ويجوز للمودع (بفتح الدال) وهو الأمين على الوديعة أن يدفع الوديعة إلى من يحفظ ماله عادة؛ كزوجته وعياله وخادمه، وإن تلفت عند أحد من هؤلاء من غير تعد ولا تفریط؛ لم يضمن؛ لأن له أن يتولى حفظها بنفسه أو من يقوم مقامه.

المودع (بفتح الدال) لو سلمها إلى أجنبي فهلكت أو ضاعت وهي في يد الثاني، فالضمان على الأول، لا على الوديع الثاني عند أبي حنيفة؛ لأن الثاني محسن إلى المالك بصيانة الوديعة عن أسباب الهلاك، والله سبحانه يقول: {مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ

سَبِيلِ { التوبة ٩١، وأما الوديع الأول فهو مخصوص عن النص. وقال صاحبان: المالك بالخيار، إن شاء ضمن الأول، وإن شاء ضمن الثاني، فإن ضمن الأول، لا يرجع بالضمان على الثاني لأنه ملك الوديعة.

حالات تضمن فيها الوديعة:

يتغير حال الوديعة من الأمانة إلى الضمان في الحالات التالية:

- ١- ترك الحفظ؛ لأن واجب الوديع حفظ الوديعة، فإذا تركها وهلكت ضمنها.
- ٢- إذا أخرج الوديع الوديعة من يده وأودعها عند غيره بغير عذر.
- ٣- تعدى المودع في الوديعة باستعمال والانتفاع بها، فيضمنها إذا تلفت.
- ٤- السفر بالوديعة، فإذا أراد السفر ردّها إلى صاحبها وله أن يسافر بها عند الإمام أبي حنيفة بخلاف قول الصحابين .
- ٥- جحود الوديعة: إذا طلب المودع الوديعة فجحدها الوديع ضمنها.
- ٦- خلط الوديعة بغيرها؛ لأن عليه حفظ الوديعة في حرز مثلها دون خلطها بماله أو متاعه الذي لا تتميز عنه إذا خلطت به.
- ٧- مخالفة شرط المودع في حفظ الوديعة، كما إذا أمره بحفظها في مكان معين أو بطريقة معينة، فخالف في هذا وحفظها في مكان آخر.
- ٨- إذا مات الوديع وجب على الوارث ردها للمودع وتكون يده عليها يد أمانة إلى أن يتمكن من ردها.

أسئلة وتدريبات على الوديعة:

س١: ما المراد بالوديعة لغة وشرعا؟ وما أدلة مشروعيتها؟ وما الحكمة من تشريعها؟

س٢- ما الفرق بين الوديعة والأمانة والعارية؟ مع التمثيل.

س٣- علل لما يأتي:

أ- الوديعة عقد جائز غير لازم.

ب- إذا تلفت الوديعة عند المودع بفتح الدال لا يضمنها .

س٤- ما ركن الوديعه عند الحنفية؟ وما الفرق بين المودع والمودع؟ وما هو الحكم التكليفي للوديعه؟

س٥- بين الحالات التي يتغير فيها حال الوديعه من الأمانة إلى الضمان مع التمثيل.

كتبه

أ.د/ هناع فهمي أحمد عيسى. أستاذ ورئيس قسم الفقه بكلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالمنصورة

د/ أحمد سيد أحمد عبد المقصود الشافعي. مدرس الفقه بكلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنين بالديمامون شرقية

الفصل الرابع عشر العارية.

ويقع في أربعة مباحث:

المبحث الأول : تعريف العارية والأصل في جوازها وحكمها.

المبحث الثاني : ركن العارية وشرائطها وأنواعها، وصفاتها.

المبحث الثالث : التصرفات التي يملكها المستعير في المستعار والتي لا يملكها

المبحث الرابع : حال الشيء المستعار إذا ضاع أو تلف وما يوجب تغيير

حاله.

أهداف الدرس :

بدراسة عقد العارية ينبغي على الطالب أن يستنتج ما يلي:

أولاً : المعلومات والمفاهيم :

التعرف على معنى العارية لغة وشرعاً وأدلة مشروعيتها.

التعرف على صيغة العارية والحكم التكليفي لها، وحكمة مشروعيتها .

التعرف على ركنها، والطبيعة الفقهية لعقد العارية، وهل عقد العارية جائز أم لازم؟

والآثار المترتبة على الطبيعة الفقهية لعقد العارية.

التعرف على أنواع العارية وصفاتها وشروط العارية، وأبرز الأحكام الفقهية المتعلقة

بها

ثانياً: المهارات الذهنية:

يستطيع الطالب أن يستنبط من الدرس ما يفيد عقد العارية.

يحلل الطالب الآثار الفقهية المترتبة على عقد العارية.

يستطيع الطالب أن يستنبط ما يصلح للعارية وما لا يصلح .

المبحث الأول : تعريف العارية والأصل في جوازها وحكمها.

أولاً : تعريف العارية.

العارية لغة : بتشديد الياء وتخفيفها اسم لما يعار مشتقة من عار إذا ذهب وجاء ، وسميت بذلك لذهابها من يد المعير إلي يد المستعير ثم عودها إلي يد المعير .
وقيل مأخوذة من التعاور أي التداول ، وقد أعاره الشيء وأعاره منه وعاوره إياه والمعاورة والتعاور : شبه المداولة والتداول في الشيء يكون بين اثنين .
وتعور واستعار . طلب العارية ، واستعاره الشيء واستعاره منه طلب منه أن يعيره إياه .

وغلط من قال مأخوذة من العار، إذ العار مستقبح شرعا وعاده، وهي مستحسنه شرعا وعادة (١).

العارية شرعاً هي : تملك المنافع بغير عوض (٢).

ثانيا : الأصل في مشروعية العارية .

العارية مشروعة بالكتاب والسنة والإجماع .
فأما الكتاب :

فقول الله تعالى : ﴿ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ ﴾ (٣).

قال جمهور المفسرين هو ما يستعيره الجيران بعضهم من بعض وفسرها ابن مسعود فقال : القدر والميزان والدلو (٤).

فالله سبحانه وتعالى توعّد مانعي الماعون بالويل ، وهذا يعني أنها مشروعة ومستحبة ومندوب إليها وإلا ما توعّد علي تركها .

(١) ابن منظور : لسان العرب ج ٤ ص ٦١٨ . مادة عور .

(٢) تكملة شرح فتح القدير ج ٩ ص ٣ .

(٣) سورة الماعون، الآية : ٧ .

(٤) نيل الأوطار ص ٣٣٨ .

وأما السنة :

. روي عن النبي ﷺ . أنه قال: «أَلَا إِنَّ الْعَارِيَةَ مُؤَدَّاةٌ ، وَالذَّيْنَ مَقْضِيٌّ ، وَالزَّرْعِيمُ

غَارِمٌ» (١) ..

. وَعَنْ أُمِّيَّةَ بْنِ صَفْوَانَ بْنِ أُمِّيَّةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَعَارَ مِنْهُ يَوْمَ حُنَيْنٍ أَذْرَاعًا ، فَقَالَ: أَغْصَبًا يَا مُحَمَّدُ؟ ، قَالَ: «بَلْ عَارِيَةٌ مَضْمُونَةٌ؟» (٢).

. وعن جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «مَا مِنْ صَاحِبِ إِبِلٍ، وَلَا بَقَرٍ، وَلَا غَنَمٍ، لَا يُؤَدِّي حَقَّهَا، إِلَّا أُفْعِدَ لَهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِقَاعٍ قَرَقَرٍ تَطَوُّهُ ذَاتُ الظِّلْفِ بِظِلْفِهَا، وَتَنْتَطِحُهُ ذَاتُ الْقَرْنِ بِقَرْنِهَا، لَيْسَ فِيهَا يَوْمُئِذٍ جَمَاءٌ وَلَا مَكْسُورَةٌ الْقَرْنِ» قُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَمَا حَقُّهَا؟ قَالَ: " إِطْرَاقُ فَحْلِهَا، وَإِعَارَةُ دَلْوِهَا، وَمَنِيحَتُهَا، وَحَلْبُهَا عَلَى الْمَاءِ، وَحَمْلٌ عَلَيْهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَلَا مِنْ صَاحِبِ مَالٍ لَا يُؤَدِّي زَكَاتَهُ، إِلَّا تَحَوَّلَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شُجَاعًا أَقْرَعَ، يَتَّبِعُ صَاحِبَهُ حَيْثُمَا ذَهَبَ، وَهُوَ يَفِرُّ مِنْهُ، وَيُقَالُ: هَذَا مَالِكٌ الَّذِي كُنْتَ تَبْخُلُ بِهِ، فَإِذَا رَأَى أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْهُ، أَدْخَلَ يَدَهُ فِي فِيهِ، فَجَعَلَ يَقْضِمُهَا كَمَا يَقْضِمُ الْفَحْلُ " (٣)، (٤).

(١) سنن الدارقطني (١٢٢ / ٥)

(٢) سنن الدارقطني - كتاب البيوع - رقم ٢٩٥٥ ج ٣ ص ٤٥٢ .

(٣) صحيح مسلم - كتاب الزكاة - ٦ باب إثم مانع الزكاة - رقم ٢٨ . (٩٨٨) ج ٢ ص ٦٨٥ .

معني بعض ألفاظه

(٤) (بقاع قرقر: أي المكان المستوي الأملس من الأرض

إطراق فحلها. أي عارية الفحل لمن أراد أن يستعييره من مالكة ليطلق به علي ماشيته.

وإعارة دلوها : أي من حقوق الماشية أن يعير صاحبها الدلو الذي يسقها به إذا طلبه منه من يحتاج إليه

ومنتحها : المنحة في الأصل العطية . قال أبو عبيدة : المنحة عند العرب علي وجهين : أحدهما : أن يعطي

الرجل صاحبه فيكون له .

والآخر : أن يعطيه ناقة أو شاة ينتفع بحلبها ووبرها زمنا ثم يردها ، والمراد به هنا عارية ذوات الألبان ليؤخذ لبنها

ثم ترد لصاحبها وحلبها علي الماء : لنفع من يحضر من المساكين . / نيل الأوطار ج ٥ ص ٣٤٠

وأما الإجماع :

أجمع المسلمون علي جواز العارية واستحبابها لما فيها من التيسير والتعاون علي البر بين العباد .

ثالثاً : حكم العارية.

العارية قربة مندوب إليها يثاب علي فعلها ، لأنها من باب المعروف والتعاون علي البر لقوله تعالى " ﴿ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى ﴾ (١)

وكانت في أول الإسلام واجبة ، ثم نسخ وجوبها وصارت مستحبة، وقد تصير واجبة كإعارة نحو ثوب لدفع حر وبرد ، أو ثوب توقفت صحة الصلاة عليه ، وإعارة حبل لإنقاذ غريق ، ونحو سكين لذبح حيوان محترم يخشي موته .

وقد تحرم كإعارة السلاح والخيل للحربي ، ومصحف لكافر .
وتكره كراهة تنزيهية إعارة وإجارة عبد مسلم لكافر ، ويكره استعارة والديه لخدمته ، لأنه يكره له استخدامهما فكره استعارتهما لذلك (٢) .

وأما (أصل الحكم) : فهو ملك المنفعة للمستعير بغير عوض، أو ما هو ملحق بالمنفعة عرفاً وعادة عند الحنفية .

وعند الشافعي : إباحة المنفعة حتى يملك المستعير الإعارة .

وجه قول الشافعي: دلالة الإجماع والمعقول .

أما الإجماع : فلجواز العقد من غير أجل ، ولو كان تملك المنفعة لما جاز من غير أجل كالإجارة ، وكذا المستعير لا يملك أن يؤجر العارية ، ولو ثبت الملك له في المنفعة لملك .

وأما المعقول: فهو أن القياس يأبى تملك المنفعة ؛ لأنه بيع المعدوم ، لانعدام المنفعة حالة العقد ، والمعدوم لا يحتمل البيع ؛ لأنه بيع ما ليس عند الإنسان ، وقد نهى رسول الله ﷺ عنه ، إلا أنها جعلت موجودة عند العقد في باب الإجارة حكماً للضرورة ، ولا ضرورة إلى الإعارة ، فبقيت المنافع فيها على أصل العدم .

(١) سورة المائدة من الآية ٢

(٢) نهاية المحتاج ج ٥ ص ١١٧ ، ص ١١٨ ، ص ١٢٣ ، المغني ج ٥ ص ١٣٨

وللحنفية :أن المعير سلطه على تحصيل المنافع وصرفها إلى نفسه على وجه زالت يده عنها ، والتسليط على هذا الوجه يكون تمليكا لا إباحة كما في الأعيان .
وإنما صح من غير أجل ؛ لأن بيان الأجل للتحرز عن الجهالة المفضية إلى المنازعة ، والجهالة في باب العارية لا تقضي إلى المنازعة ؛ لأنها عقد جائز غير لازم ، ولهذا المعنى لا يملك الإجارة ؛ لأنها عقد لازم ، والإعارة عقد غير لازم ، فلو ملك الإجارة لكان فيه إثبات صفة اللزوم بما ليس بل لازم ، أو سلب صفة اللزوم عن اللزوم ، وكل ذلك باطل .

المبحث الثاني : ركن العارية وسرائطها وأنواعها ، وصفتها .

أولاً: ركن العارية :

ركنها عند الحنفية : الإيجاب : من المعير .
وأما القبول: من المستعير فليس بركن عند أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد استحساناً .

والقياس أن يكون ركناً . وهو قول زفر ، كما في الهبة ، حتى أن من حلف لا يعير فلانا فأعاره ولم يقبل يحنث، كما إذا حلف لا يهب فلانا شيئاً فوهبه ولم يقبل .
والإيجاب هو أن يقول : أعرتك هذا الشيء ، أو منحتك هذا الثوب أو هذه الدار ، أو أطعمتك هذه الأرض أو هذه الأرض لك طعمة ، أو أخدمتك هذا العبد أو هذا العبد لك خدمة ، أو حملتك على هذه الدابة إذا لم ينو به الهبة أو داري سكنى أو داري لك عمرى سكنى .

أما لفظ الإعارة فصريح في بابها .

وأما المنحة فهي اسم للعطية التي ينتفع الإنسان بها زماناً ثم يردها على صاحبها وهو معنى العارية ، قال النبي ﷺ : { الْمُنْحَةُ مَرْدُودَةٌ } (١) وقال النبي ﷺ : « أَرْزَعَهَا أَوْ امْتَحَهَا أَخَاكَ » (٢) وكذا الإطعام المضاف إلى الأرض ، هو إطعام منافعها التي تحصل منها بالزراعة من غير عوض عرفاً وعادة ، وهو معنى العارية

(١) مسند البزار = البحر الزخار - رقم ٥٤٠٨ ج ١٢ ص ٣٢ .

(٢) السنن الكبرى للنسائي - رقم ٤٥٧٥ ج ٤ ص ٣٩١ .

وأما إخدام العبد إياه فجعل خدمته بغير عوض ، وهو تفسير العارية ، وكذا قوله :
داري لك سكنى أو عمري سكنى ، هو جعل سكنى الدار له من غير عوض ، وسكنى
الدار منفعتها المطلوبة منها عادة ، فقد أتى بمعنى الإعارة .

وأما قوله : حملتك على هذه الدابة ، فإنه يحتمل الإعارة والهبة ، فأبي ذلك نوى
فهو على ما نوى ؛ لأنه نوى ما يحتمل لفظه ، وعند الإطلاق ينصرف إلى العارية ؛
لأنها أدنى فكان الحمل عليها أولى .

ولو قال : داري لك رقبى أو حبس ، فهو عارية عند أبي حنيفة ومحمد .

وعند أبي يوسف : هبة ، وقوله رقبى أو حبس باطل .

وأما أركانها عند الجمهور فأربعة :

معيير : مالك العين أو المنفعة .

ومستعير : وهو المملك لمنافع الحيوان أو الدار إلي وقت معلوم .

ومعار : كالحيوان والثياب ، والعقار .

وصيغة : الإيجاب والقبول (١) .

ثانياً: شرائط العارية ، وأنواعها ، وصفتها :

أ- : شروط الصيغة :

يشترط في الناطق لفظ يشعر بالإعارة لأن الانتفاع بمال الغير يتوقف علي إذنه
كأن يقول المعير : أعرتك هذا أو أعرتك منفعته ، أو خذه لتنتفع به ، أو يقول المستعير
أعرتني ويكفي لفظ من أحدهما مع فعل الآخر كما في إباحة الطعام فلو قال المعير :
أعرتك تلك الدابة فقبضها أي تسلمها المستعير انعقدت بذلك العارية ، أو قال المستعير
: أعرتني تلك الدابة فسلمها إليه المعير انعقدت أيضا .

ولا يشترط أن يكون اللفظ من جانب المعير بخلافه في الوديعة حيث يشترط كون
اللفظ صادراً من جانب المودع [المالك] وذلك لأنها مقبوضة لغرض المالك وغرضه
هذا لا يعلم إلا بلفظ من جانبه (٢) .

(١) (الجعلي : سراج السالك ح ٢ ص ٢١٣)

(٢) (تكملة شرح فتح القدير ج ٩ ص ٦ ، ص ٧ .)

ب- : شروط المعير :

١. العقل : فلا تصح الإعارة من المجنون والصبي الذي لا يعقل، وأما البلوغ فليس بشرط عند الحنفية حتى تصح الإعارة من الصبي المأذون ؛ لأنها من توابع التجارة ، وأنه يملك التجارة فيملك ما هو من توابعها .
وعند الشافعي : لا يملك .

٢. الاختيار: فلا تصح إعارة المكره. (١).

ج - : شروط المستعير :

١. أن يكون أهلاً لقبول التبرع ، فلا تصح العارية لمن لا أهلية ولا عبارة له كمجنون والصبي الذي لا يعقل كما لا يصح تبرعهم.
٢. أن يكون معيناً : فلا تصح العارية لغير معين كأن يقول مثلاً : أعرت أحكما ، وللمستعير أن يستنيب غيره ليستوفي له المنفعة إذا لم يكن فيها ضرر زائد علي استعمال المستعير أو دونه مالم يكن عدواً للمعير .
كأن يركب الدابة المستعارة للذي مثله أو دونه وليس أثقل منه في تحصيل حاجته .
كما يجوز ذلك أيضاً بالنسبة لزوجته وخادمه لرجوع الانتفاع إليه.

د - : شروط المستعار :

١ . يشترط في المستعار كونه منتفعاً به انتفاعاً مباحاً مقصوداً ، فلا يعار ما لا نفع فيه كحمار زمن ، ولا ما كانت منفعته محرمة شرعاً كآلات الملاهي ، ولا ما كانت منفعته ضعيفة غير مقصودة كاستعارة النقدين إذ منفعة التزين بهما الضرب علي طبعهما منفعة ضعيفة قل ما تقصد ، ومعظم منفعتهما في الإنفاق والإخراج ، فإن قصد في استعارة النقدين التزين بهما أو الضرب علي طبعهما أي نوي ذلك صحت الإعارة لاتخاذ هذه المنفعة مقصداً وإن ضعفت .

(١) (تحفة الفقهاء ج ٣ ص ١٧٧ .

٢. أن يكون المستعار مما يمكن الانتفاع به بدون استهلاكه أي ينتفع به مع بقاء عينه كالعقار والثياب والدواب والحلي ، فلا تصح إعاره طعام لأكل ونحو شمعة لوقود لأن منفعتهما باستهلاكهما ومن ثم صحت للتزين بهما كالنقدين .
والأصل في العارية أن لا يكون فيها استهلاك المعار .
ولا يشترط تعيين المستعار فيكفي خذ ما شئت من دوابي بخلاف الإجارة لأنها معاوضة .
القبض من المستعير ؛ لأن الإجارة عقد تبرع فلا يفيد الحكم بنفسه بدون القبض كالهبة .

وأما أنواع العارية فهي نوعان:

مطلقة، ومؤقتة؛ نحو أن يقول في الإجارة شهراً، أو يقول: إلى مكان كذا، أو يقول: يحمل عليها كذا، ففيما كانت مطلقة يجب إجراؤها على إطلاقها، أو فيما كانت مقيدة يجب رعاية القيد فيه

وأما صفة العارية:

فهي أن الملك الثابت للمستعير ملك غير لازم ؛ لأنه ملك لا يقابله عوض ، فلا يكون لازماً كالملك الثابت بالهبة ، فكان للمعير أن يرجع في العارية سواء أطلق العارية أو وقت لها وقتاً ؛ لأن الإجارة تبرع بالمنفعة، فلا تكون لازمة قبل قبضها؛ كالتبرع بالعين، وما لم يستوف من المنفعة في المستقبل لم يتصل بها القبض، ومن صفتها أنها ترتفع لمجرد النهي، ويبطل بموت أحدهما أيهما مات.

المبحث الثالث : التصرفات التي يملكها المستعير في المستعار والتي لا يملكه

عقد الإجارة لا يخلو من أحد وجهين : إما إن كان مطلقاً ، وإما إن كان مقيداً .
فإن كان مطلقاً: بأن أعار دابته إنساناً ولم يسم مكاناً ولا زماناً ولا الركوب ولا الحمل ، فله أن يستعملها في أي مكان وزمان شاء .

وله أن يركب أو يحمل ؛ لأن الأصل في المطلق أن يجري على إطلاقه ، وقد ملكه منافع العارية مطلقاً ، فكان له أن يستوفيها على الوجه الذي ملكها ، إلا أنه لا يحمل عليها ما يعلم أن مثلاً لا يطبق بمثل هذا الحمل ، ولا يستعملها ليلاً ونهاراً ما لا

يستعمل مثلها من الدواب لذلك عادة ، حتى لو فعل فعطبت يضمن ؛ لأن العقد وإن خرج مخرج الإطلاق ، لكن المطلق يتقيد بالعرف والعادة دلالة ، كما يتقيد نصا .
وله أن يعير العارية سواء كانت العارية مما يتفاوت في استيفاء المنفعة أو لا ؛ لأن إطلاق العقد يقتضي ثبوت الملك للمستعير ، فكان هو في التملك من غيره على الوجه الذي ملكه متصرفا في ملك نفسه ، إلا أنه لا يملك الإجارة ؛ لأنها عقد لازم ، والإجارة عقد غير لازم ، فلو ملك الإجارة لكان فيه إثبات صفة اللزوم بما ليس بلزوم ، أو سلب صفة اللزوم عن اللزوم ، وكل ذلك باطل .

وإن كان مقيدا : فيراعى فيه القيد ما أمكن ؛ لأن أصل اعتبار تصرف العاقل على الوجه الذي تصرف ، إلا إذا لم يكن اعتباره لعدم الفائدة ونحو ذلك ، فلغا الوصف ؛ لأن ذلك يجري مجرى العبث ، ثم إنما يراعى القيد فيما دخل لا فيما لم يدخل ؛ لأن المطلق إذا قيد ببعض الأوصاف يبقى مطلقا فيما وراءه ، فيراعى عند الإطلاق فيما وراءه .

وعلى ذلك : إذا أعار إنسانا دابة على أن يركبها المستعير بنفسه ليس له أن يعيرها من غيره ، وكذلك إذا أعاره ثوبا على أن يلبسه بنفسه ، لأن الأصل في المقيد اعتبار القيد فيه إلا إذا تعذر اعتباره ، واعتبار هذا القيد ممكن ؛ لأنه مقيد لتفاوت الناس في استعمال الدواب والثياب ركوبا ولبسا ، فلزم اعتبار القيد فيه ، فإن فعل حتى هلك ضمن لأنه خالف .

ولو أعاره دارا ليسكنها بنفسه فله أن يسكنها غيره ؛ لأن المملوك بالعقد السكنى ، والناس لا يتفاوتون فيه عادة فلم يكن التقيد بسكناه مفيدا فيلغو ، إلا إذا كان الذي يسكنها إياه حدادا أو قصارا ونحوهما ممن يوهن عليه البناء ، فليس له أن يسكنها إياه ، ولا أن يعمل بنفسه ذلك ؛ لأن المعير لا يرضى به عادة ، والمطلق يتقيد بالعرف والعادة .

ولو قيدها بالمكان ، بأن قال : على أن تستعملها في مكان كذا في المصر يتقيد به ، وله أن يستعملها في أي وقت شاء بأي شيء شاء ؛ لأن التقيد لم يوجد إلا بالمكان فبقي مطلقا فيما وراءه ، لكنه لا يملك أن يجاوز ذلك المكان ، حتى لو جاوزه دخل في

ضمانه ، ولو أعادها إلى المكان المأذون لا يبرأ عن الضمان ، حتى لو هلك من قبل التسليم إلى المالك يضمن ، وهذا قول أبي حنيفة الآخر .

وكان يقول أولا : يبرأ عن الضمان كالمودع إذا خالف ثم عاد إلى الوفاق ثم رجع . وكذلك لو قيدها بالزمان بأن قال : على أن يستعملها يوما يبقى مطلقا فيما وراءه ، لكنه يتقيد بالزمان ، حتى لو مضى اليوم ولم يردها على المالك حتى هلك يضمن ولو اختلف المعير أو المستعير في الأيام أو المكان أو فيما يحمل عليها ، فالقول قول المعير ؛ لأن المستعير يستفيد ملك الانتفاع من المعير ، فكان القول في المقدار والتعيين قوله ، لكن مع اليمين دفعا للتهمة .

المبحث الرابع : حال الشيء المستعار إذا ضاع أو تلف وما يوجب تغير حاله .
حال المستعار أنه أمانة في يد المستعير في حال الاستعمال بالإجماع ، فأما في غير حال الاستعمال فكذاك عند الحنفية .

وعند الشافعي : مضمون .

واحتج بما روي عَنْ أُمِّيَّةَ بِنِ صَفْوَانَ بِنِ أُمِّيَّةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ اسْتَعَارَ مِنْهُ يَوْمَ حُنَيْنٍ أَدْرَاعًا ، فَقَالَ : أَغْصَبًا يَا مُحَمَّدُ؟ ، قَالَ : «بَلْ عَارِيَّةٌ مَضْمُونَةٌ؟» .(١)

ولأن العين مضمونة الرد حال قيامها ، فكانت مضمونة القيمة حال هلاكها كالمغصوب ، وهذا لأن العين اسم للصورة والمعنى ، وبالهلاك إن عجز عن رد الصورة لم يعجز عن رد المعنى ؛ لأن قيمة الشيء معناه ، فيجب عليه رده بمعناه كما في الغصب ، ولأنه قبض مال الغير لنفسه ، فيكون مضمونا عليه كالمقبوض على سوم الشراء .

وللحنفية : أنه لم يوجد من المستعير سبب وجوب الضمان ، فلا يجب عليه الضمان كالوديعة والإجارة ، و ذلك لأن الضمان لا يجب على المرء بدون فعله ،

(١) سنن الدارقطني - كتاب البيوع - رقم ٢٩٥٥ ج ٣ ص ٤٥٢ .

وفعله الموجود منه ظاهرا هو العقد والقبض ، وكل واحد منهما لا يصلح سببا لوجوب الضمان .

أما العقد : فلأنه عقد تبرع بالمنفعة تملিকা أو إباحة على اختلاف الأصلين .
وأما القبض فلوجهين :

أحدهما : أن قبض مال الغير بغير إذنه لا يصلح سببا لوجوب الضمان ، فبالإذن أولى ، وهذا لأن قبض مال الغير بغير إذنه ، هو إثبات اليد على مال الغير وحفظه وصيانته عن الهلاك وهذا إحسان في حق المالك قال الله - تبارك وتعالى - جل شأنه : ﴿ هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ ﴾ (١) ، وقال تبارك وتعالى : ﴿ مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ ﴾ (٢) دل أن قبض مال الغير بغير إذنه لا يصلح سببا لوجوب الضمان ، فمع الإذن أولى .

والثاني : أن القبض المأذون فيه لا يكون تعديا ؛ لأنه لا يفوت يد المالك ، ولا ضمان إلا على المتعدي ، قال الله تبارك وتعالى : ﴿ فَلَا عُذْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ ﴾ (٣) بخلاف قبض الغصب .

والرد على الاستدلال بضمان الرد ، قالوا : إن وجب عليه رد العين حال قيامها ، لم يجب عليه رد القيمة حال هلاكها .
والرد على قوله : قيمتها معناها .

قالوا : هذا ممنوع ، لأن القيمة هي الدراهم والدنانير ، والدراهم والدنانير عين أخرى لها صورة ومعنى غير العين الأولى ، فالعجز عن رد أحد العينين لم يوجب رد العين الأخرى ، وفي باب الغصب لا يجب عليه ضمان القيمة بهذا الطريق ، بل بطريق آخر ، وهو إتلاف المغصوب معنى ، وهنا لم يوجد ، حتى لو وجد يجب الضمان ، ثم نقول : إنما وجب عليه ضمان الرد ؛ لأن العقد متى انتهى بانتهاء المدة أو بالطلب

(١) سورة الرحمن ، الآية : ٦٠ .

(٢) سورة التوبة ، من الآية ٩١ .

(٣) سورة البقرة ، من الآية ١٩٣ .

بقي العين في يده كالمغصوب ، والمغصوب مضمون الرد حال قيامه ومضمون القيمة حال هلاكه ، وعند الحنفية إذا هلك في تلك الحالة ضمن .

وأما قوله : قبض مال الغير لنفسه . فنعم ، لكن قبض مال الغير لنفسه بغير إذنه لا يصلح سببا لوجوب الضمان ، فمع الإذن أولى .
والمقبوض على سوم الشراء غير مضمون بالقبض بل بالعقد بطريق التعاطي ، بشرط الخيار الثابت دلالة .

ولا حجة له في حديث صفوان ؛ لأن الرواية قد اختلفت ، فقد روي { أنه هرب من رسول الله ﷺ . فأرسل إليه فأمنه ، وكان رسول الله ﷺ يريد حنينا ، فقال : (هل عندك شيء من السلاح) فقال : عارية أو غصبا فقال ﷺ : (عارية) (١) ، فأعاره { ولم يذكر فيه الضمان ، والحادثة حادثة واحدة مرة واحدة ، فلا يكون الثابت إلا إحداهما فتعارضت الروايتان فسقط الاحتجاج ، مع ما أنه إن ثبت فيحتمل ضمان الرد ، وبه نقول ، فلا يحمل على ضمان الغير مع الاحتمال .

يؤيد ما قال الحنفية ، ما روي عن رسول الله ﷺ أنه قال : { العارية مؤداة } .
ثامناً : ما يوجب تغير حال العارية .

فالذي يغير حال المستعار من الأمانة إلى الضمان ، هو المغير حال الوديعة وهو
١ . الإلتاف حقيقة أو معنى بالمنع بعد الطلب أو بعد انقضاء المدة .
٢ . وبترك الحفظ .
٣ . وبالخلاف .

حتى لو حبس العارية بعد انقضاء المدة أو بعد الطلب قبل انقضاء المدة يضمن ؛
لأنه واجب الرد في هاتين الحالتين ، لقوله ﷺ : (العارية مؤداة) (٢) وقوله ﷺ : (على اليد ما أخذت حتى ترده) (٣) ولأن حكم العقد انتهى بانقضاء المدة أو الطلب ،

(١) أخرجه الحاكم في " المستدرک " ج ٢ ص ٤٧ بلفظ " قال : عارية مؤداة " دون ذكر الضمان ، وقال الحاكم

صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه ، وأقره الذهبي .

(٢) سبق تخريجه .

(٣) سبق تخريجه .

فصارت العين في يده كالمغصوب ، والمغصوب مضمون الرد حال قيامه ، ومضمون القيمة حال هلاكه .

ولو رد العارية مع عبده أو ابنه أو بعض من في عياله ، أو مع عبد المعير ، أو ردها بنفسه إلى منزل المالك وجعلها فيه ، لا يضمن استحسانا . والقياس أن يضمن كما في الوديعة.

وكذا إذا ترك الحفظ حتى ضاعت، وكذا إذا خالف، إلا أن في باب الوديعة إذا خالف ثم عاد إلى الوفاق يبرأ عن الضمان عند أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد، وهنا لا يبرأ.

ولو تصرف المستعير وادعى أن المالك قد أذن له بذلك، وجدد المالك ، فالقول قول المالك حتى يقوم للمستعير على ذلك بينة ؛ لأن التصرف منه سبب لوجوب الضمان في الأصل ، فدعوى الإذن منه دعوى أمر عارض فلا تسمع إلا بدليل .

وإذا كانت العارية مؤقتة بوقت، فأمسكها بعد الوقت، فهو ضامن لها.

ومن مشايخ الحنفية من قال: هذا إذا انتفع به بعد مضي المدة، فأما إذا لم ينتفع به فلا ضمان، ومنهم من قال: يضمن على كل حال . والله سبحانه وتعالى أعلم (١).

ولقد جاء في مختصر القدوري ما نصه: "العارية: جائزة وهي: تملك المنافع بغير عوض وتصح بقوله: أعرتك وأطعمتك هذه الأرض ومنحتك هذا الثوب وحملتك على هذه الدابة إذا لم يرد به الهبة وأخدمتك هذا العبد وداري لك سكنى وداري لك عمرى سكنى وللمعير أن يرجع في العارية متى شاء . والعارية أمانة: إن هلك من غير تعد لم يضمن شيئا وليس للمستعير أن يؤجر ما استعاره ولا أن يرهنه وله أن يعيره إذا كان مما لا يختلف باختلاف المستعمل وعارية الدراهم والدنانير والمكيل والموزون قرض وإذا استعار أرضا ليبني فيها أو يغرس نخلا جاز وللمعير أن يرجع فيها ويكلفه قلع البناء والغرس فإن لم يكن وقت العارية فلا ضمان عليه وإن كان وقت العارية فرجع قبل الوقت ضمن المعير ما نقض البناء والغرس بالقلع وأجرة رد العارية على المستعمر

(١) الكاساني : بدائع الصنائع ج ٥ ص ٣١٨ - ٣٢٥ .

وأجرة رد العين المستأجرة على المؤجر وأجرة المغصوبة على الغاصب وإذا استعار دابة فردّها إلى دار مالكها ولم يسلمها إليه ضمن وإن رد الوديعة إلى دار المالك ولم يسلمها إليه ضمن (١)

ويمكن أن نستنتج من هذا الدرس ما يلي :

١-العارية: هي تملك المنافع بغير عوض، وسميت بهذا الاسم لتعري المبادلة فيها عن المنافع المادية.

٢-حكم العارية: كانت واجبة في أول الاسلام ثم نسخت إلى الاستحباب وقد يعتريها الأحكام التكليفية.

٣-حكمة مشروعيتها: العارية من أعمال البر والمعروف الذي يربط بين القرابة والجيران فهي داعية للتودد والتواصل فالحاجة إليها لها فضل عظيم في قضاء حاجة المسلم، ولما فيها من البر والمعروف والإحسان، والله يحب المحسنين.

٤-ركن العارية: اتفق فقهاء الحنفية على أن الإيجاب ركن في العارية، لكنهم اختلفوا حول كون القبول ركناً فيها، حيث ذهب أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد إلى أن القبول ليس بركن استحساناً، والقياس كونه ركناً، وذهب زفر إلى أن القبول ركن في العارية وهو القياس.

هل العارية تفيد التملك أم تفيد الإباحة؟

ذهب الحنفية من غير الكرخي: إلى أنها تفيد تملك المنفعة، وبالتالي يجوز للمستعير أن يعير ما استعاره.

بينما ذهب الكرخي: إلى أن العارية تفيد إباحة المنفعة في الشيء المستعار فقط ولا تفيد تملكها وبالتالي لا يملك إعاره ما استعاره وهذا ما ذهب إليه الشافعي أيضاً.

ما الحكم لو تلفت العارية؟

لا خلاف بين الفقهاء في أنّ العارية إنّ تلفت بالتّعدي من المستعير فإنّه يضمنها أما إذا تلفت العارية بدون تعدي لم يضمن شيئاً عند الإمام أبي حنيفة وأحد قولي الإمام مالك وأشهب رضي الله عنهم لما روى عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده

(١) مختصر القدوري لأبي الحسين القدوري ص ١٣٣.

مرفوعاً: ليس على المُستَعِير غير المُغَلِّ ضمان، ويرى الإمام الشافعي وأحمد رضي الله عنهم أن من أئلف العارية يضمنها واسْتَدَلُّوا : بِحَدِيثِ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا " أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ اسْتَعَارَ مِنْ صَفْوَانَ بْنِ أُمَيَّةَ أَدْرَعًا ، يَوْمَ حُنَيْنٍ ، فَقَالَ : أَغَصَبًا يَا مُحَمَّدُ ؟ قَالَ : بَلْ عَارِيَّةٌ مَضْمُونَةٌ " ويرى المالكية يرون ضمان ما يمكن إخفاؤه إذا لم تقم البينة على التلف.

حكم رد العارية: رد العين المستعارة واجب على المستعير عند انتهاء مدة العارية.

شروط العارية متعددة منها:

أولاً: ما يرجع إلى الصيغة ويشترط فيها أن تكون دالة على إنشاء تصرف لفظاً أو

كناية

ثانياً: ما يرجع إلى العاقلين وهما: المعير والمستعير، فيشترط فيهما أن يكونا عاقلين ، أما كونهما بالغين فليس بشرط حتى تصح العارية من الصبي المميز لأن العارية من توابع التجارة وهما يملكان التجارة فيملكان ما هو من توابعها وأن يكون المعير أهلاً للتبرع، أن يكون المعير مالكا لما يعيره، أو مأذوناً له فيه.

ثالثاً: الشروط المتعلقة بالمعقود عليه، فيشترط في العين المستعارة أن تكون مما يمكن الانتفاع بها مع بقاء عينها، وأن تكون معينة لأن الجهالة تقضى إلى المنازعة وقبضها من المستعير؛ لأن عقد العارية عقد تبرع، وعقود التبرع لا يترتب عليها أثرها إلا بالقبض، أن تكون العارية مباح الانتفاع بها شرعاً.

ينتهي عقد العارية بما يلي: ١- طلب المعير العارية، ٢- رد المستعير العارية، ٣-

موت أحد العاقلين أو جنونه، ٤- الحجر على المعير بسبب الإفلاس، ٥- الحجر على أحد العاقلين بالسفه.

أسئلة وتدريبات

- س ١: عرف العارية لغة واصطلاحاً، مبيناً أدلة مشروعيتها.
- س ٢: بين الحكم التكليفي للعارية، وما حكمة مشروعيتها، ثم بين ما يفيد عقد العارية.
- س ٣: ما ركن العارية عند الحنفية؟ وما الأثر المترتب على هذا الخلاف؟ مع التوضيح بالأمثلة.
- س ٤: هل العارية تفيد التملك أم تفيد الإباحة؟ بين الأثر المترتب على هذا الخلاف.
- س ٥: ماهي شروط العارية إجمالاً؟

كتبه

- أ.د/ هناء فهمي أحمد عيسى. أستاذ ورئيس قسم الفقه بكلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالمنصورة
- د/ أحمد محمد السيد المرسي العفيفي. مدرس الفقه بكلية الشريعة والقانون بطنطا

فهرس المحتويات

الصفحة	الموضوع
٤	موضوعات الدراسة النصية
٥	البيع
٤٨	الخيارات
٨٨	بيع المربحة والتولية
١١١	موضوعات الدراسة الموضوعية
١١٣	الفصل الأول الفصل التمهيدي: التعريف بالمال وأقسامه والعقد وأنواعه.
١٥٢	الفصل الثاني: الربا.
٢٠٢	الفصل الثالث: السلم.
٢٣٢	الفصل الرابع: الاستصناع.
٢٤٤	الفصل الخامس: المضاربة.
٢٨٧	الفصل السادس: الصرف.
٢٩٥	الفصل السابع: الكفالة.
٣١٨	الفصل الثامن: الحوالة.
٣٣٢	الفصل التاسع: الشركة.
٣٤٧	الفصل العاشر: المزارعة
٣٦٩	الفصل الحادي عشر: المساقاة.
٤٠١	الفصل الثاني عشر: القسمة
٤٢٤	الفصل الثالث عشر: كتاب الوديعة.
٤٤٥	الفصل الرابع عشر: العارية.
٤٦١	فهرس المحتويات

تم بحمد الله